Répertoire de droit civil

Contrat d'entreprise

Bernard BOUBLI
Conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation
Avocat associé, Cabinet CAPSTAN

novembre 2016

Table des matières

Tit. 1 - Règles générales du contrat d'entreprise 1 - 139

Chap. 1 **-** Définition et nature **2 - 39**

Sect. 1 **-** Définition **3 - 4**

Sect. 2 **-** Nature du contrat **5 - 39**

Art. 1 **-** Objet du contrat d'entreprise **6 - 10**

Art. 2 **-** Distinction du contrat d'entreprise et des contrats voisins **11 - 39**

§ 1 **-** Distinction d'avec le contrat de travail **12 - 19**

§ 2 **-** Distinction d'avec la vente **20 - 28**

§ 3 **-** Distinction d'avec le mandat **29 - 33**

§ 4 **-** Distinction d'avec les contrats de dépôt, de transport, de commodat, d'association, d'assistance **34 - 39**

Chap. 2 **-** Formation et preuve du contrat **40 - 54**

Sect. 1 **-** Formation du contrat d'entreprise **41 - 45**

Sect. 2 **-** Fixation du prix **46 - 50**

Art. 1 **-** Fixation par les parties **47 - 48**

Art. 2 **-** Fixation par le juge **49 - 50**

Sect. 3 **-** Preuve du contrat **51 - 54**

Chap. 3 **-** Effets du contrat d'entreprise **55 - 130**

Sect. 1 **-** Obligations du locateur d'ouvrage **56 - 103**
Art. 1 **-** Louage d'ouvrage s'appliquant aux services **59 - 68**
§ 1 **-** Exécution du travail **60 - 62**
§ 2 **-** Obligation de renseignement et de conseil **63 - 64**
§ 3 **-** Obligation de sécurité **65 - 68**
Art. 2 **-** Louage d'ouvrage s'appliquant aux choses **69 - 103**
§ 1 **-** Exécuter le travail commandé **70 - 81**
§ 2 **-** Conserver la chose remise par le maître de l'ouvrage **82 - 86**
§ 3 **-** Livrer la chose et exécuter le travail dans le temps convenu **87 - 95**
§ 4 **-** Obligation de renseignement et de conseil **96 - 99**
§ 5 **-** Obligation de sécurité **100 - 103**
Sect. 2 **-** Obligations du maître de l'ouvrage **104 - 116**
Art. 1 **-** Faciliter l'exécution de l'ouvrage **105 - 109**
Art. 2 **-** Recevoir l'ouvrage **110 - 113**
Art. 3 **-** Prendre livraison **114**
Art. 4 **-** Payer le prix **115 - 116**
Sect. 3 **-** Responsabilité **117 - 125**
Art. 1 **-** Défauts apparents **120 - 121**
Art. 2 **-** Défauts cachés **122 - 125**
Sect. 4 **-** Risques **126 - 130**
Chap. 4 **-** Fin du contrat **131 - 139**
Sect. 1 **-** Nullité **132 - 133**
Sect. 2 **-** Résolution **134 - 135**
Sect. 3 **-** Décès de l'entrepreneur **136**
Sect. 4 **-** Résiliation unilatérale du marché à forfait **137 - 139**

Tit. 2 - Règles particulières au contrat d'entreprise dans la construction immobilière 140 - 686

Chap. 1 **-** Construction de l'ouvrage **141 - 385**
Sect. 1 **-** Montage de l'opération **142 - 152**
Art. 1 **-** Formule « ensemblier » **143 - 151**

§ 1 - Cas général **144 - 146**
§ 2 - Construction de maison individuelle **147 - 149**
§ 3 - Contrat de promotion immobilière **150 - 151**
Art. 2 - Formule « maître d'œuvre » **152**
Sect. 2 - Parties au contrat d'entreprise **153 - 248**
Art. 1 - Maître de l'ouvrage **154 - 165**
§ 1 - Définition **155 - 157**
§ 2 - Maître d'ouvrage délégué **158 - 161**
§ 3 - Prérogatives **162 - 164**
§ 4 - Lutte contre le travail dissimulé **165**
Art. 2 - Constructeurs **166 - 248**
§ 1 - Personnes qui concourent à la maîtrise d'œuvre **167 - 171**
§ 2 - Entrepreneur **172 - 230**
§ 3 - Contrôle technique de la construction **231 - 248**
Sect. 3 - Marchés privés de travaux immobiliers **249 - 311**
Art. 1 - Conclusion du marché **252 - 259**
§ 1 - Dévolution **253 - 256**
§ 2 - Pièces contractuelles **257 - 259**
Art. 2 - Marché à forfait **260 - 303**
§ 1 - Conditions du marché à forfait **263 - 274**
§ 2 - Exécution et cessation du marché à forfait **275 - 285**
§ 3 - Travaux supplémentaires **286 - 303**
Art. 3 - Autres marchés privés **304 - 311**
§ 1 - Marché sur devis ou au métré **305 - 308**
§ 2 - Marché sur dépenses contrôlées **309 - 310**
§ 3 - Marché « à maximum » **311**
Sect. 4 - Cession de marché, sous-traitance, action directe **312 - 385**
Art. 1 - Cession de marché **313**
Art. 2 - Sous-traitance **314 - 374**
§ 1 - Contrat relevant de la sous-traitance réglementée **315 - 340**

§ 2 **-** Règles de paiement du sous-traitant **341 - 361**
§ 3 **-** Rapports créés par la sous-traitance **362 - 374**
Art. 3 **-** Action directe des ouvriers contre le maître de l'ouvrage **375 - 385**
§ 1 **-** Nature de l'action **376 - 377**
§ 2 **-** Bénéficiaires **378 - 379**
§ 3 **-** Exercice de l'action **380 - 382**
§ 4 **-** Effets de l'action directe **383 - 385**
Chap. 2 **-** Achèvement de l'ouvrage **386 - 512**
Sect. 1 **-** Livraison de l'ouvrage **388 - 407**
Art. 1 **-** Distinction d'avec la réception **389 - 392**
Art. 2 **-** Livraison dans le délai **393 - 407**
§ 1 **-** Responsabilité **394 - 399**
§ 2 **-** Sanction du retard **400 - 407**
Sect. 2 **-** Prix du marché : paiement et garantie **408 - 432**
Art. 1 **-** Conditions de paiement **409 - 414**
Art. 2 **-** garanties de paiement **415 - 422**
§ 1 **-** Domaine de la garantie **416**
§ 2 **-** Constitution de la garantie **417 - 419**
§ 3 **-** Régime de la garantie **420 - 422**
Art. 3 **-** Retenue de garantie **423 - 432**
§ 1 **-** Constitution de la retenue de garantie **424 - 426**
§ 2 **-** Régime de la garantie **427 - 432**
Sect. 3 **-** Réception des travaux **433 - 473**
Art. 1 **-** Nature juridique **434 - 442**
§ 1 **-** Définition **435 - 436**
§ 2 **-** Difficultés de qualification **437 - 438**
§ 3 **-** Difficultés de classification **439 - 442**
Art. 2 **-** Moment de la réception **443 - 452**
§ 1 **-** Pseudo-abandon de la distinction entre réception définitive et réception provisoire **444 - 446**

§ 2 - Achèvement requis pour réceptionner **447 - 452**
Art. 3 - Formes de la réception **453 - 462**
§ 1 - Réception expresse **454 - 455**
§ 2 - Réception tacite **456 - 458**
§ 3 - Réception judiciaire **459 - 460**
§ 4 - Assistance de l'architecte **461 - 462**
Art. 4 - Effets de la réception **463 - 473**
§ 1 - Point de départ des garanties **464 - 466**
§ 2 - Charge des risques **467 - 473**
Sect. 4 - Garantie de parfait achèvement **474 - 512**
Art. 1 - Fonction de la garantie **476 - 480**
§ 1 - Débiteur de la garantie **477 - 479**
§ 2 - Nature de la garantie **480**
Art. 2 - Domaine d'application de la garantie **481 - 498**
§ 1 - Désordres proprement dits **482 - 487**
§ 2 - Défauts de conformité **488 - 493**
§ 3 - Défauts d'isolation phonique **494 - 498**
Art. 3 - Régime juridique de la garantie **499 - 512**
§ 1 - Objet de la garantie **500 - 502**
§ 2 - Mise en œuvre de la garantie **503 - 507**
§ 3 - Caractère non exclusif de la garantie **508 - 512**
Chap. 3 - Responsabilité des constructeurs **513 - 686**
Sect. 1 - Responsabilité contractuelle **514 - 662**
Art. 1 - Garantie décennale et garantie biennale **515 - 635**
§ 1 - Principes généraux **516 - 538**
§ 2 - Acteurs des garanties **539 - 568**
§ 3 - Conditions propres à la garantie décennale **569 - 586**
§ 4 - Conditions propres à la garantie biennale **587 - 590**
§ 5 - Conditions relatives au dommage garanti **591 - 602**
§ 6 - Régime juridique des garanties **603 - 635**

Art. 2 **-** Responsabilité contractuelle de droit commun **636 - 662**

§ 1 **-** Responsabilité avant réception **637 - 644**

§ 2 **-** Responsabilité après réception **645 - 662**

Sect. 2 **-** Responsabilité extracontractuelle **663 - 686**

Art. 1 **-** Acteurs de la responsabilité **664 - 669**

Art. 2 **-** Fondement de la responsabilité **670 - 678**

§ 1 **-** Faute **671**

§ 2 **-** Garde **672**

§ 3 **-** Ruine du bâtiment **673**

§ 4 **-** Troubles de voisinage **674 - 678**

Art. 3 **-** Responsabilité du fait des produits défectueux **679 - 686**

§ 1 **-** Généralités **680 - 681**

§ 2 **-** Cas particulier de la construction **682 - 686**

Bibliographie

I. Bibliographie générale

ANTONMATTÉI, RAYNARD et SEUBE, Droit civil, Contrats spéciaux, 8e éd., 2015, LexisNexis. – AUBRY et RAU, Droit civil français, t. 5 par ESMEIN, 6e éd., Litec, § 374. – BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, Du contrat de louage, t. 2, 1898, L. Larose. – BÉNABENT, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11e éd., 2015, coll. Domat Droit privé, LGDJ. – BEUDANT et LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, t. 12 par RODIÈRE, Cours de droit civil français, t. XII *bis,* contrats civils divers, vol. 2, p. 195, nos 173 s. – DELEBECQUE et COLLART-DUTILLEUL, Contrats civils et commerciaux, 10e éd., 2015, Précis Dalloz. – HUET, Traité de droit civil, sous la direction de GHESTIN, Les principaux contrats spéciaux, 1996, LGDJ. – MALAURIE et AYNÈS, Droit des contrats spéciaux, 4e éd. par GAUTHIER, 2009, Defrénois. – H. L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 3, 2e vol., par DE JUGLART, 5e éd., Montchrestien, nos 1328 s. – PUIG, Contrats spéciaux, 6e éd., 2015, coll. HyperCours, Dalloz. – RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. 3, 1956-1960, LGDJ, nos 2061 s.

PUIG, La qualification du contrat d'entreprise, thèse, Paris 2, 1999.

II. Éléments de bibliographie propre à la construction immobilière

Sur la construction en général :

J.-B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit de l'urbanisme et de la construction, 9e éd., 2012, Montchrestien. – Dalloz Action, Droit de la construction 2014/2015 sous la direction de Ph. MALINVAUD. – GIRIBILA, J.-Cl. Civ., art. 1787, fasc. 10 et 20. – Lamy, Droit immobilier, 2014. – LIET-VEAUX et THUILLIER, Le droit de la construction, 10e éd., 1994, Litec. – P. GRELIER-BESSMANN, Le mémento des marchés privés de travaux, Intervenants, passation et exécution, 2006, éd. Eyrolles ; Pratique du droit de la construction, 4e éd., 2007, éd. Eyrolles. – MALINVAUD, JESTAZ par JOURDAIN et TOURNAFOND, Droit de la promotion immobilière, 9e éd., 2015, Précis Dalloz. – Mémento F. Lefebvre, Urbanisme - Construction 2016. – MONTMERLE, CASTON et HUET, Passation et exécution des marchés de travaux privés, 1996, LGDJ. – M. THIOYE, J.-Cl. Civ., art. 1788 à 1794, fasc. 1 et 20, Louage d'ouvrage et d'industrie, Contrat d'entreprise. – PENNEAU, Règles de l'art et normes techniques, 1989, LGDJ. – H. PÉRINET-MARQUET (sous la dir. de), Pratique du droit de la construction : contrats et responsabilités, 2003, Litec. – SABLIER et CARO, Guide de la sous-traitance dans la construction, 6e éd., 2007, éd. du Moniteur. – R. SAINT-ALARY, Droit de la construction, 8e éd., 2006, coll. « Que sais-je ? », PUF. – C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit de la construction, 11e éd., 2016, Mementos, Dalloz.

ABBATUCCI, La sous-traitance dans le bâtiment, RJ Centre-Ouest 1993, no 13. – BACHELOT, Le financement bancaire des marchés et les problèmes posés par la sous-traitance, Gaz. Pal. 1979. 2. Doctr. 385. – BÉNABENT, Le conflit entre banquiers et sous-traitants, RDI 1990. 149 . – BERLY, Désordres évolutifs : état de la jurisprudence, RDI 2000. 115 ; La responsabilité du sous-traitant, Mon. TP 8 nov. 1991. 88 ; *adde :* RDI 1995. 483 . – BOUBLI, Les travaux supplémentaires dans le marché à forfait, RDI 1986. 415 . – BOULANGER, L'entrepreneur immobilier et le droit de rétention, JCP N 2000. 163. – CARO, Les dangers de la sous-traitance irrégulière, Mon. TP 20 févr. 1987. 52. – CARO, MANILEVÉ et SILVESTRI, Le point sur la retenue de garantie, Mon. TP 8 févr. 1991. 52. – DELEBECQUE, Les garanties de l'entrepreneur contre l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, RDI 1993. 39 . – EMON, Les risques de l'entrepreneur face à l'innovation, points essentiels, RDI 1998. 41 . – DESSUET, Le régime juridique applicable aux dommages intermédiaires sous l'empire de la loi du 4 janvier 1978, RDI 2001. 113 . – FABRE et SCHMITT, La clause de renonciation à la règle de l'accession foncière dans les marchés privés de travaux, RDI 1990. 453 ; Le nouvel article 1799-1 du code civil, RDI 1994. 347 ; Le décret du 18 novembre 1994, RDI 1995. 17 . – FEUCHER, Les contrôleurs techniques : le mythe et la raison, RDI 1999. 343 . – FLECHEUX, La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, JCP 1976. I. 2791. – GOURIO, La garantie de paiement des entreprises dans les marchés privés de travaux JCP N 1994. 277. – JOURDAIN, La nature de la responsabilité civile dans les chaînes de contrats après l'arrêt du 12 juillet 1991, D. 1992. Chron. 149 . – KARILA, L'action directe du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant est nécessairement de nature délictuelle, Gaz. Pal. 8-9 janv. 1992, p. 7. – LARROUMET, L'effet relatif des contrats et la négation de l'existence d'une action en responsabilité nécessairement contractuelle dans les ensembles contractuels, JCP 1991. I. 3531. – MARGANNE, Marché à forfait : le régime des travaux supplémentaires, Mon. TP 10 mai 1996. 52 ; Le prix dans le contrat d'entreprise, JCP N 1998.

Chron. 602. – PEISSE, L'action directe du sous-traitant en concours avec une cession de créance loi Dailly, Gaz. Pal. 19 mars 1989, p. 2. – PÉRINET-MARQUET, Le droit français de la sous-traitance. L'entreprise et le droit 1991, n° 1 ; La responsabilité du maître d'ouvrage privé à l'égard du sous-traitant impayé, RDI 1996. 159 . – SAINT-ALARY-HOUIN, La genèse de l'article 1799-1, RDI 1994. 339 . – M. THIOYE, Retour sur un thème rémanent du droit de la construction : la réparabilité des dommages futurs et évolutifs, RDI 2004. 229 . – ZAVARO, Les règles de l'art, Gaz. Pal. 4 nov. 2000, p. 3.

Sur la responsabilité en particulier :

BOUBLI, La responsabilité et l'assurance des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs, 1991, JNA. – BOUBLI, FRITSCH-HÉMARD et la rédaction F. Lefebvre, Responsabilité des constructeurs, 2002, Thème Express. – CASTON, La responsabilité des constructeurs, 6e éd., 2006, éd. du Moniteur. – CASTON, AJACCIO, PORTE et TENDEIRO, Traité de la responsabilité des constructeurs, 2013, éd. Le Moniteur. – KARILA, Les responsabilités des constructeurs, 1991, Delmas. – MODERNE, La responsabilité décennale des constructeurs en droit public, 1993, Dalloz. – Rapport SPINETTA, Proposition pour une réforme de l'assurance-construction, La documentation française, 30 juin 1975. – SOINNE, La responsabilité des architectes et des entrepreneurs après la réception des travaux, 1969, LGDJ. – Travaux de l'association Capitant, La responsabilité des constructeurs, 1991, Litec. – ZAVARO, La responsabilité des constructeurs, 2e éd., 2007, Litec.

AMBACHER, Faut-il supprimer l'article 1792-4 ?, L'assurance française 1989. 213. – ARTZ, Responsabilité solidaire des fabricants, Administrer janv. 1994. 2. – BERLY, Désordres évolutifs, état de la jurisprudence RDI 2000. 116 . – BIGOT, Commentaire de la loi du 4 janvier 1978, JCP 1978. I. 2923. – BOUBLI, La responsabilité des constructeurs dans la loi du 4 janvier 1978, RDI 1979. 1 ; La responsabilité contractuelle de droit commun après la réception des travaux, RDI 1982. 1 . – CASTON, Réforme de la responsabilité et de l'assurance, AJPI 1978. 93 ; Garantie décennale et responsabilité de droit commun, AJPI 1993. 535. – CHAPRON, Observations sur la réception des travaux, RDI 1995. 7 . – B. et X. CHEMIN, De quelques pièces de procédure dans les litiges de construction, RDI 1993. 481 . – DE LESCURE, Responsabilité des constructeurs : quelle responsabilité contractuelle de droit commun en cas de dommage à l'ouvrage ?, RDI 2007. 307 . – DELMAS, Le contrôle technique de la construction, RDI 1979. 129 . – DESSUET, Le problème des travaux sur existant, Gaz. Pal. 21-23 févr. 1999, p. 2. – E. GAVIN-MILAN-OOSTERLYNCK, Pour une durée décennale de la responsabilité du constructeur, RDI 2006. 259 . – GROSLIÈRE, La réforme de la responsabilité en matière de construction, Droit et ville 1979, n° 7, p. 7 ; Glossaire pour la responsabilité en matière de construction, Mélanges P. Hébraud, 1981, Université des Sciences sociales de Toulouse, p. 393. – KARILA, Responsabilités des constructeurs et assurance construction : la réforme du 8 juin 2005, D. 2005. 2236 ; Bilan de la nouvelle responsabilité décennale et des responsabilités satellites, Droit et ville 1988, n° 26, p. 26 ; Les garanties légales et la responsabilité contractuelle de droit commun…, D. 1990. 307 , Gaz. Pal. 24-25 mai 1991, p. 2, AJPI 1993. 583, AJPI 1997. 4. – LARROUMET, La responsabilité des organes de contrôle technique, RDI

1981. 311 . – LIET-VEAUX, La loi du 4 janvier 1978, la nouvelle responsabilité de plein droit, Gaz. Pal. 1979. 1. Doctr. 261 ; du même auteur : Gaz. Pal. 1979. 1. Doctr. 149, Gaz. Pal. 1979. 1. Doctr. 32. – LLORENS, La mission du maître d'ouvrage délégué, RDI 1996. 463 . – MALINVAUD, L'autonomie de la garantie des vices en matière immobilière, RDI 1998. 321 ; Les dommages aux voisins dus aux opérations de construction, RDI 2001. 479 ; La responsabilité en matière de construction après l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, RDI 2005. 237 ; L'action directe du maître de l'ouvrage contre les fabricants et fournisseurs de matériaux et composants, D. 1984. Chron. 41 ; L'application de la directive communautaire du fait des produits défectueux…, RDI 1987. 409 ; L'autonomie de la garantie des vices en matière immobilière, RDI 1998. 322 ; La loi du 9 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux…, D. 1999. 85 . – MATHURIN, Les différents systèmes de responsabilité et d'assurance dans les États membres de la CEE, Droit et ville 1988, n° 26, p. 119. – MODERNE, Le nouveau régime de la responsabilité décennale, Mon. TP 6 févr. et 24 mars 1978. – PÉRINET-MARQUET, La réception des travaux, état des lieux, D. 1988. Chron. 287 ; Remarques sur la force de la garantie des constructeurs, JCP 1992. I. 3553. – RAKOTOVAHINY, Les conséquences résultant de la qualité de constructeur du vendeur particulier d'un ouvrage achevé, JCP N 2000. I. 226. – RIBERA, Vers un transfert des risques inhérents à l'acte de construire, Gaz. Pal. 14-16 mai 2000, p. 2. – ROULET et PEISSE, Commentaire de la loi du 4 janvier 1978, Gaz. Pal. 1978. 1. Doctr. 115. – SIZAIRE, Dommages intermédiaires…, Constr. et Urb. 1999. Chron. 7. – SPINETTA, La réforme de la responsabilité et de l'assurance dans le domaine de la construction, Annales des Ponts et Chaussées, 4e trim. 1978, p. 7. – THIBIERGE, Responsabilité et assurance dans le domaine de la construction après la loi du 4 janvier 1978, Defrénois 1979, art. 32021. – TIRARD, Le domaine de la maîtrise d'ouvrage déléguée, RDI 1996. 451 . – ZAVARO, Achèvement, inachèvement et réception, Gaz. Pal. 1er-3 août 1999, p. 2.

CANTELAUBE, La responsabilité des constructeurs en droit public français, thèse, Paris, 1966. – CHARVET, La responsabilité des architectes, thèse, Aix, 1969. – LABIN, La responsabilité des architectes et son assurance, thèse, Paris 1, 1978. – LE BLOND, De la responsabilité des architectes et des entrepreneurs, thèse, Lille, 1893.

ACTUALISATION

Bibliographie. - M. MEKKI, La loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016, une réforme de la réforme ?, D. 2018. 900 .

ACTUALISATION

Création des tribunaux judiciaires La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (JO 24 mars), dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a été adoptée pour simplifier les procédures judiciaires. Ainsi, depuis le 1er janvier

2020, les tribunaux de grande instance ont fusionné avec les tribunaux d'instance pour devenir les tribunaux judiciaires.

Titre 1er - Règles générales du contrat d'entreprise

1. Le contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage est le contrat par lequel une des parties – l'entrepreneur – s'engage à faire quelque chose, moyennant rémunération, pour l'autre, le maître de l'ouvrage (C. civ., art. 1710 . – V. *infra,* nos 2 s.). Le régime du contrat s'articule autour de la formation du contrat (V. *infra,* nos 40 s.), de l'exécution (V. *infra,* nos 55 s.) puis de la fin du contrat (V. *infra,* nos 131 s.).

Chapitre 1er - Définition et nature

2. Le contrat d'entreprise, ainsi que le relève M. PUIG, constitue vraisemblablement une catégorie générique des contrats de service. Sa définition mérite donc d'être précisée (V. *infra* nos 3 s.), et il convient d'identifier sa nature juridique notamment pour le distinguer des autres variétés de contrats relevant de la catégorie (V. *infra,* nos 5 s.).

Section 1re - Définition

3. Variété de louage d'ouvrage. - Le contrat d'entreprise est une variété de *louage d'ouvrage.* Peut-être même est-il le seul qui, aujourd'hui, mérite cette qualification. L'article 1708 du code civil distingue « deux sortes de contrats de louage : celui des choses et celui d'ouvrages ». L'article 1779, modifié par la loi no 67-3 du 3 janvier 1967 (D. 1967. 51), énumère, pour sa part, trois catégories de « louage d'ouvrage et d'industrie » : le louage des gens de travail, le louage des voituriers et le louage d'architectes, entrepreneurs et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. Sont ainsi regroupés sous la dénomination unique de louage d'ouvrage et d'industrie : le contrat de travail, le contrat de transport, et le contrat de « louage par devis et marchés ». Le *contrat de travail* n'est pas un louage d'ouvrage, mais un louage de services. Il fait l'objet d'une réglementation particulière inscrite dans les articles L. 1211-1 et suivants du code du travail. La distinction existait déjà à Rome où l'on opposait la « locatio operis faciendi » à la « locatio operatum », mais alors, la fourniture de la matière par le maître était l'élément caractéristique du contrat d'entreprise alors qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. Le *contrat de transport* est, juridiquement, une espèce d'entreprise, dont on estime en général qu'il constitue aujourd'hui un « contrat

particulier » (A. BÉNABENT, ancienne étude, J.-Cl. Civ., art. 1787, n° 2), car le contrat d'entreprise relève d'une « famille qui se démembre » (MALAURIE et AYNÈS, Contrats spéciaux, par GAUTHIER, 4e éd. par GAUTHIER, 2009, Defrénois, n° 701). Reste alors le *contrat de louage par devis et marchés.* Mais la dénomination ne correspond pas au contenu des articles 1787 à 1799 qui réglementent cette convention, les mots « devis » et « marchés » convenant seulement à des subdivisions de celle-ci (PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., t. 11, 1952-1960, LGDJ, n° 906) ; aussi lui préfère-t-on celle de « contrat d'entreprise » (PLANIOL et RIPERT, *op. cit.* ; AUBRY et RAU, Droit civil français, t. 5, par ESMEIN, 6e éd., Litec, § 374 ; RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. 3, 1956-1960, LGDJ, n° 2061 ; MAZEAUD et DE JUGLART, Leçons de droit civil, t. 3, 2e vol., 5e éd., Montchrestien, nos 1328 s.). Comme la notion de louage d'ouvrage s'est rétrécie, la qualification vise en pratique le contrat d'entreprise. Ainsi que le relève M. PUIG (« La qualification du contrat d'entreprise », thèse, Paris 2, 1999), le louage (d'ouvrage, dans le code civil, n'a plus rien de commun avec ce qu'il était à Rome. Le maître de l'ouvrage était alors un locateur qui fournissait à l'ouvrier la matière à façonner ; l'exigence d'une chose remise par le maître de l'ouvrage à l'ouvrier ne figure plus dans le code civil, et il est probable que celui qui fournit son travail et la chose sur laquelle il porte ne loue en rien ses services. L'expression « contrat d'entreprise » suggérée par PLANIOL a donc pris le pas sur la qualification du contrat préconisée par le code civil. Le louage d'ouvrage n'est pas, pour autant, une catégorie inutile. Comme le montre encore M. PUIG (thèse préc.), il désigne vraisemblablement une catégorie générique, tandis que le contrat d'entreprise désigne une catégorie spécifique.

4. Définition. - Le contrat d'entreprise peut être défini comme étant « la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant » (Civ. 1re, 19 févr. 1968, Bull. civ. I, n° 69). Celui qui commande le travail est le client ou le *maître de l'ouvrage* (sur la notion, V. *infra,* nos 104 s. et 153 s.) ; celui qui se charge d'effectuer le travail est un prestataire fréquemment dénommé « ouvrier » par le code civil. Ce terme alimente la confusion entre le contrat d'entreprise et le contrat de travail, aussi lui préfère-t-on, dans le langage contemporain, ceux de *locateur* ou d'*entrepreneur,* ou même de *façonnier* ou d'*artisan.* M. BÉNABENT relève que le contrat d'entreprise occupe une situation particulière parmi les contrats spéciaux et il estime que c'est un contrat « quasi-innomé » (*in* Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11e éd., 2015, LGDJ, coll. Domat Droit privé, n° 479).

Section 2 - Nature du contrat

5. Le contrat d'entreprise se caractérise par son objet (V. *infra,* n°s 6 s.), et ses particularités permettent de le distinguer des contrats voisins » (V. *infra,* n°s 11 s.).

Art. 1er - Objet du contrat d'entreprise

6. Diversité de l'objet. - Contrairement à ce qu'avaient prévu les rédacteurs du code civil, le contrat d'entreprise ne se limite pas aux conventions relatives aux choses. Il peut porter sur « l'exécution d'ouvrages de toutes sortes » (PLANIOL et RIPERT, *op. cit.,* n° 914). Il implique une obligation de faire (BÉNABENT, *op. cit,* n° 482).

7. Certains contrats portent sur la fabrication, la réparation, ou la transformation d'une *chose mobilière ou immobilière* : il en est ainsi du contrat que le client passe avec un garagiste (Civ. 1re, 19 mars 1968, Bull. civ. I, n° 106), un teinturier (Civ. 1re, 11 mai 1966, Bull. civ. I, n° 281), un fourreur ou un tailleur (Colmar, 10 févr. 1970, D. 1971. Somm. 28), un bijoutier (Com. 2 nov. 1965, Bull. civ. IV, n° 546), un agriculteur, lorsqu'il n'existe entre les parties aucun lien de subordination (Civ. 3e, 25 oct. 1972, Bull. civ. III, n° 554), un entrepreneur de bâtiment (V. *infra,* n°s 140 s.).

8. D'autres contrats ne portent pas sur une chose corporelle, mais sur un service. Le service peut prendre la forme d'une prestation intellectuelle ; tel est le cas en ce qui concerne le médecin (COLIN et CAPITANT, *op. cit.,* n° 1085), l'avocat, lorsque du moins, il ne représente pas son client (MAZEAUD et DE JUGLART, *op. cit.,* n° 1334), encore qu'on estime souvent que le contrat liant les parties est un contrat mixte, teinté de mandat et de louage d'ouvrage (V. sur la question, L. SEBAG, La détermination des honoraires de l'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1970, D. 1970. Chron. 177), le conseil juridique (R. SAVATIER, Les contrats de conseil professionnel en droit privé, D. 1972. Chron. 137 ; La profession de conseil juridique, D. 1969. Chron. 145) et, dans une certaine mesure, les ingénieurs conseils et les bureaux d'études (Civ. 3e, 21 janv. 1971, Bull. civ. III, n° 43 ; 17 juin 1971, D. 1971. 515 ; 6 mars 1973, Bull. civ. III, n° 163) qui, il est vrai, procèdent bien souvent à la réalisation de l'œuvre qu'ils conçoivent (V. *infra,* n°s 169 s. ; et sur la question, M.-F. MIALON, Contribution à l'étude juridique d'un contrat de conseil, RTD civ. 1973. 6 ; G. VINEY, La responsabilité des entreprises prestataires de conseil JCP 1975. I. 2750 ; J.-Cl. GOLDSCHMIDT, Étude générale des conditions de la responsabilité des bureaux d'engineering, Gaz. Pal. 1976. 1. Doctr. 1 ; A. D'HAUTEVILLE, Responsabilité et assurance des ingénieurs conseils et des bureaux d'études, thèse, Paris I, 1977) ; il faut sans doute ranger dans cette catégorie des prestataires de services intellectuels, les architectes qui, juridiquement, sont des locateurs d'ouvrage (V. *Architecte [Civ.]* et *infra,* n°s 167 s.), ainsi que toutes les entreprises en organisation ; entreprises de

spectacles, agences de voyages, lorsqu'elles organisent le voyage (V. *infra,* n° 30) et, dans le bâtiment et les travaux publics, les entreprises chargées du pilotage ou de la coordination des travaux (V. *infra,* n°s 180 s. ; plus généralement sur la notion d'entreprise à capital intellectuel, V. SAYAG, BABEAU, DAVID et BOUBLI, L'entreprise personnelle, 1981, Librairies techniques).

9. Le service peut prendre la forme d'une *prestation matérielle.* Souvent celle-ci est solidaire d'une prestation intellectuelle (avocat, chirurgien, bureaux d'études, architectes) ; parfois, elle constitue l'obligation majeure, et même exclusive du débiteur : ainsi en est-il dans le contrat d'hôtellerie (sur la distinction avec le bail : Civ. 1re, 19 oct. 1999, n° 97-13.525, Bull. civ. I, n° 278. – Civ. 3e, 1er juill. 1998, n° 96-17.515, Bull. civ. III, n° 145, D. 1998. IR 207) et, dans une moindre mesure, dans le contrat d'édition à compte d'auteur, que la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 (D. 1957. 102 et 350, rect. 166) sur la propriété littéraire et artistique analyse en un contrat d'entreprise (art. 49 ; CPI, art. L. 132-2).

10. Nature civile ou commerciale. - Le contrat d'entreprise peut être purement civil (aucune des parties n'est commerçante), commercial (les deux parties sont commerçantes et le travail à exécuter concerne leur commerce), ou mixte (une seule des parties est commerçante). Il peut également être conclu par les collectivités et les personnes publiques et devenir alors un contrat administratif. La prise en considération de l'objet du contrat pour qualifier le contrat d'entreprise pose des problèmes lorsque le prestataire fournit à la fois la matière et le travail. Est-ce bien une entreprise ? Ne s'agit-il pas plutôt d'une vente, voire d'un autre contrat ? La doctrine s'est partagée à partir des thèses de POTHIER et de PLANIOL, en tenant compte d'un critère économique (poids respectif de la main-d'œuvre et des matériaux) nuancé en matière de construction (le terrain est-il objet du contrat, ou a-t-il du moins un caractère « principal » dans le contrat ?). M. PUIG propose de distinguer non pas selon l'objet du contrat, mais selon sa *finalité.* Le contrat peut avoir pour finalité soit de transférer un bien, soit de fournir un service. C'est la finalité de service qui doit caractériser le contrat d'entreprise et spécialement le contrat d'entreprise immobilière : la construction sur un terrain nu constitue un service (transformer le terrain nu en terrain bâti) ; la construction sur un existant implique une distinction entre la réparation qui caractérise le service, même s'il peut y avoir adjonction – pièce de rechange, remplacement – et la transformation. Le simple ajout d'équipements n'est pas toujours un service ; la transformation qui répond à une commande constitue un service.

Art. 2 - Distinction du contrat d'entreprise et des contrats voisins

11. Le contrat d'entreprise se distingue de nombreux autres types de contrats de services comme le contrat de travail (V. *infra,* n°s 12 s.), la vente (V. *infra,* n°s 20 s.), le mandat (V. *infra,* n°s 29 s.), les contrats de dépôt, de transport, de commodat, d'association, d'assistance (V. *infra,* n°s 34 s.).

§ 1er - Distinction d'avec le contrat de travail

12. Critère de la distinction. - Le critère qui permet d'opposer le louage de services (ou contrat de travail) au contrat d'entreprise est le « lien juridique de subordination » : à la subordination de l'employé à l'égard de l'employeur, on oppose l'indépendance juridique de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Celui qui loue ses services contracte une obligation de moyens, et c'est dans la mise en œuvre de ces moyens que se manifeste l'état de subordination du salarié. Au contraire, le louage d'ouvrage oblige l'entrepreneur à un résultat ; mais pour obtenir ce résultat, le locateur est libre des moyens qu'il met en œuvre. Tenu d'exécuter le travail, il décide comme il l'entend de la façon dont il va y procéder (MAZEAUD et DE JUGLART, *op. cit.,* n° 1332 ; PLANIOL et RIPERT, *op. cit.,* n°s 769 et 907 ; COLIN et CAPITANT, *op. cit.,* n° 1084 ; B. BOUBLI, Le lien de subordination juridique réalité ou commodité ?, JS Lamy 1999, n° 35/1 ; Le recours à la main-d'œuvre extérieure, Dr. soc. 2009. 806. – Civ. 5 juin 1935, DH 1935. 508. – Soc. 2 déc. 1970, Bull. civ. V, n° 683 ; 14 juin 1973, *ibid.* V, n° 382). La difficulté de distinction entre le contrat de travail et le contrat d'entreprise n'existe que lorsque le prestataire est une personne physique. Il ne peut y avoir contrat de travail entre deux personnes morales.

13. Le critère tiré de l'indépendance juridique, pour n'être pas aussi simple qu'il y paraît, est cependant préférable à celui de la subordination économique parfois proposé. On avait suggéré une distinction fondée sur le mode de rémunération, le salarié étant payé au temps passé, l'entrepreneur non. Mais elle n'a pas grande signification et ne recueille pas l'adhésion des tribunaux (Soc. 12 mai 1971, Bull. civ. V, n° 346. – Com. 6 juill. 1966, Bull. civ. IV, n° 693).

14. La distinction entre le contrôle des moyens et le contrôle du seul résultat n'est pas toujours aisée. Il en résulte « une casuistique nuancée parfois déroutante » (BÉNABENT, Droit civil : Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 11e éd., 2015, coll. Domat Droit privé, LGDJ, n° 23). Ainsi, ni le paiement à l'heure, ni la fourniture des matériaux par le maître, ni l'initiative qu'il conserve dans l'exécution du travail n'excluent nécessairement l'existence d'un contrat d'entreprise (Com. 12 nov. 1952, Bull. civ. III, n° 349. – Civ. 1re, 7 juill. 1955, *ibid.* I, n° 291. – Soc. 12 mai 1971, préc. ; 3 nov. 1998, CSB 1999. 53. A. 11). Réciproquement, la rémunération à la tâche et la relative liberté laissée à un ouvrier dans l'exécution d'un travail ne suffisent pas à exclure l'existence

d'un lien de subordination (Soc. 28 nov. 1974, Bull. civ. V, n° 579 ; B. BOUBLI, article préc., JS Lamy 1999, n° 35/1. – Soc. 13 nov. 1996, Dr. soc. 1996. 1067, note Dupeyroux).

15. Néanmoins, la *rémunération* selon le travail fourni est souvent révélatrice du contrat d'entreprise (Soc. 2 déc. 1970, Bull. civ. V, n° 683), alors que « l'absence de supplément » en contrepartie d'une responsabilité ou d'un risque est de « nature à exclure l'existence d'un tel contrat » (Soc. 19 juill. 1968, Bull. civ. V, n° 400). La *qualité* de commerçant d'une partie fait parfois présumer l'existence d'un louage d'ouvrage, car le salarié n'a pas cette qualité (Soc. 16 déc. 1963, Bull. civ. IV, n° 884). Mais le plus souvent, la distinction s'opérera à partir d'un *certain nombre d'indices,* comme la liberté de l'ouvrier dans l'exécution du travail (Civ. 1re, 7 juill. 1955, Bull. civ. I, n° 291. – Soc. 16 oct. 1959, Bull. civ. IV, n° 1021 ; 29 janv. 1970, *ibid.* V, n° 68), la liberté des horaires (Soc. 2 déc. 1970, préc.), la possibilité pour le locateur de traiter directement avec les fournisseurs tout en gardant la responsabilité de l'ouvrage (Soc. 6 mars 1969, Bull. civ. V, n° 163 ; 21 nov. 1968, Bull. civ. V, n° 521), la propriété du matériel (Soc. 14 nov. 1968, Bull. civ. V, n° 505), encore que cette indication ne soit pas toujours significative (Soc. 23 avr. 1964, Bull. civ. IV, n° 328 ; 2 juill. 1964, *ibid.* IV, n° 585 ; voir à propos des franchises : Soc. 27 sept. 1989, Bull. civ. V, n° 548), autant d'éléments qui permettent, en général, de qualifier le contrat de louage d'ouvrage.

16. Les juges du fond fondent d'ailleurs leur appréciation sur des « présomptions graves précises et concordantes » (Soc. 3 févr. 1965, Bull. civ. IV, n° 100), mais ils ne sont pas liés par la qualification donnée au contrat par les parties. Ils statuent sous le contrôle de la Cour de cassation (Soc. 23 avr. 1964, Bull. civ. IV, n° 328. – Civ. 3e, 19 juin 1969, *ibid.* III, n° 505. – Soc. 27 avr. 1972, *ibid.* V, n° 292. – Civ. 1re, 15 juin 1973, *ibid.* I, n° 202). Les indices sont encore à rechercher dans l'existence d'un service organisé par le bénéficiaire du travail, ce qui permet de retenir l'existence d'un contrat de travail (médecin : Soc. 7 déc. 1983, Bull. civ. V, n° 592) ou dans l'existence d'une clientèle propre au propriétaire, ce qui caractérise plutôt l'entreprise (MALAURIE et AYNÈS, par GAUTHIER, *op. cit.,* n° 711. – Civ. 3e, 9 juin 2004, n° 03-11.172 , BPIM 5/04, inf. 286). Les règles applicables à l'avocat collaborateur sont souvent de nature à exclure le salariat en ce qui les concerne (Soc. 16 sept. 2015, n° 14-17.842 , RDT 2015. 682, obs. Lucas Bento de Carvalho). La tendance dite à « l'ubérisation » de l'économie est un élément d'actualisation du problème. Schématiquement des personnes physiques sont rassemblées dans une plate-forme dont les gestionnaires assurent leur relation avec la clientèle. Particulièrement sensible avec les conducteurs de voitures qui, sans être des chauffeurs de taxis professionnels, transportent des usagers, la pratique peut concerner différents prestataires dont des particuliers concernés par les travaux de bâtiments. Théoriquement autonomes et relevant alors

davantage du statut d'entrepreneur que de celui de salarié, ces particuliers sont à la recherche d'un statut social qui est à définir, ce qui incite certains interprètes à réclamer en leur faveur la reconnaissance de la qualité de salarié. À l'instar de ce qui s'est passé pour les médecins des cliniques ou hôpitaux dont la qualité de salarié a été reconnue à la suite d'actions des URSSAF, le statut du personnel « ubérisé » risque d'être influencé par les réclamations de ces dernières.

17. Intérêts de la distinction. - La distinction du contrat de travail et du contrat d'entreprise présente plusieurs intérêts. Placé sous la subordination juridique de l'employeur, le salarié bénéficie de la *protection spéciale* que lui confère la loi en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, alors que la fin des relations contractuelles en matière d'entreprise obéit aux règles de droit commun. Le salarié relève du régime général de la sécurité sociale et, à ce titre, il est notamment protégé contre le risque « accidents du travail ». Au contraire, le locateur est un travailleur indépendant et il relève du régime de cette catégorie professionnelle : c'est lui qui supporte les cotisations sociales qui, dans le régime général, sont pour la quote-part la plus élevée à la charge de l'employeur. Cela explique que, dans certains cas, les parties soient en opposition sur la qualification juridique de l'acte. Il a été jugé que le contrat par lequel une entreprise mettait à la disposition d'une autre du matériel et de l'outillage pour l'exécution d'un travail nécessitant des connaissances techniques particulières était un contrat d'entreprise (Civ. 1re, 7 janv. 1955, Bull. civ. I, n° 291) ; alors qu'au contraire l'organisation du travail en équipe n'a pas été jugée suffisante pour caractériser ce contrat (Soc. 16 mai 1962, Bull. civ. IV, n° 446). Il est certain qu'un faisceau de présomptions relevant l'autonomie du locateur l'emportera sur le mode de rémunération convenu (Paris, 25 mai 1979, D. 1979. IR 505, RDI 1980. 169, obs. P. Malinvaud et B. Boubli). Il faut aussi éviter que sous couvert d'un louage d'ouvrage impliquant la mise à disposition d'une personne pour exécuter une prestation, on procède à un prêt de main-d'œuvre illicite (C. trav, art. L. 8241-1 s. – Paris, 21 mai 1999, RG n° 2621/97, RDI 1999. 651).

18. La distinction présente également des intérêts en matière de *responsabilité civile.* Aux termes de l'ancien article 1384, devenu article 1242 du code civil (pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016), l'employeur est responsable de ses préposés, même occasionnels : le maître de l'ouvrage ne l'est pas de l'entrepreneur qui reste libre du mode d'exécution des travaux (Com. 13 avr. 1972, Bull. civ. IV, n° 100). L'employeur répond, en principe, des conséquences dommageables de son fait envers le salarié, et la Cour de cassation considère qu'il est tenu à son égard d'une *obligation de sécurité de résultat* dont elle tire toutes les conséquences lorsque la santé du salarié est en cause, notamment pour cerner la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une lésion d'origine professionnelle (B. BOUBLI, Une pincée de droit pour l'obligation de sécurité de résultat, JCP S 2008. 1624). Le salarié n'est responsable à l'égard de l'employeur que de ses fautes lourdes (G. LYON-CAEN, Le salaire, *in* Traité de droit du travail, sous

la direction de G.-H. CAMERLYNCK, t. II, 2e éd., 1981, Dalloz, n° 230. – Soc. 19 mai 1958, D. 1959. 20, note R. Lindon ; 27 nov. 1958, JCP 1959. II. 11143, note J. Brethe de la Gressaye ; 27 mai 1964, JCP 1965. II. 14056 ; 21 janv. 1971, D. 1971. 291 ; 8 juin 1978, Bull. civ. V, n° 450).

19. Enfin, il faut souligner que les différends nés à l'occasion du travail relèvent de la *compétence prud'homale,* alors qu'en matière d'entreprise, c'est la juridiction de droit commun qui est compétente ; que la prescription quinquennale était applicable aux salaires (C. civ., anc. art. 2277, depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 la prescription est de 3 ans : C. trav., art. L. 3245-1) est désormais généralisée (C. civ., art. 2224) et concerne les créances nées du contrat d'entreprise, réserve faite des actions en garantie ou en responsabilité dirigées contre les constructeurs (art. 1792 s.) ; que les *moyens juridiques pour se faire payer* le prix du travail sont différents dans l'entreprise et dans le louage de services où le salarié bénéficie d'un privilège général (C. civ., art. 2101-4°), et que les *risques* de la chose sur laquelle porte l'ouvrage sont supportés par le locateur (V. *infra,* n°s 126 s.), mais pas par le salarié.

§ 2 - Distinction d'avec la vente

20. Il convient de revenir sur le critère de la distinction entre la vente et le contrat d'entreprise (V. *infra,* n°s 21 s.) et d'en établir l'intérêt (V. *infra,* n°s 28 s.).

A - Critère de la distinction

21. 1° La matière est fournie par le maître. - Lorsque l'ouvrage porte sur une chose fournie par le maître, il ne peut y avoir vente, car l'entrepreneur n'apporte que son travail (MAZEAUD et DE JUGLART, *op. cit.,* n° 2872). Il en est ainsi notamment, lorsque le contrat a pour objet l'entretien, ou la réparation de la chose appartenant au maître (RIPERT et BOULANGER, *op. cit.,* n° 2601 ; C. civ., art. 1711).

22. Lorsque le contrat a pour objet l'*édification d'un immeuble sur un terrain dont le maître est propriétaire,* ce contrat est toujours un contrat d'entreprise. En effet, le terrain et la matière appartiennent déjà au maître de l'ouvrage et l'entrepreneur n'est alors qu'un façonnier qui apporte son travail. De plus, la finalité de service de l'opération résulte de la transformation du terrain nu en terrain bâti.

23. 2° La matière est fournie par l'entrepreneur. - Dans une première opinion, qui s'appuie sur les travaux préparatoires du code civil (LOCRÉ, XIV, p. 328 et 401), la convention dans un tel cas serait toujours une vente (LAURENT, Principes de droit civil,

t. XXVI, n° 5 ; GUILLOMOND, t. 2, n° 772 ; RIPERT et BOULANGER, *op. cit.,* n° 2068 ; BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, *op. cit.,* t. 2, n° 3872 ; M. PLANIOL, note sous Civ. 5 janv. 1897, DP 1897. 1. 89 ; A. WAHL, note sous Paris, 2 déc. 1897, S. 1900. 2. 201). Dans une seconde opinion, la convention serait un contrat mixte, à la fois vente et louage d'ouvrage, certains auteurs proposant d'appliquer les règles de l'entreprise pendant l'exécution du travail, celles de la vente après la réception (AUBRY et RAU, t. 5, par ESMEIN, § 374-1°, texte et note 2), d'autres décomposant le contrat en une vente de la matière et un louage d'ouvrage pour le travail fourni (PLANIOL et RIPERT, par ROUAST, Traité civil de droit français, Contrats civils, n° 912).

24. Ces opinions se heurtent aux articles 1787 et 1788 qui placent le travail exécuté sur la matière fournie par l'ouvrier dans le cadre du louage d'ouvrage. Ces articles se combinent avec l'article 1711 qui précise qu'il y a louage d'ouvrage lorsque la matière est fournie par celui pour le compte de qui « l'ouvrage se fait ». On en déduit que le seul fait que la matière soit fournie par l'entrepreneur ne suffit pas à caractériser la vente par rapport à l'entreprise. L'analyse appelle sans doute une distinction selon qu'elle s'incorpore à une chose mobilière (terrain) et devient la propriété de celui qui en bénéficie par accession, ou qu'elle accroît par façonnage, une chose mobilière (pose d'une pierre sur une bague). La distinction n'est pas toujours apparente en droit positif et la Cour de cassation retient parfois la vente lorsque le prestataire fournit des matériaux sur catalogue (Civ. 3e, 24 mai 2006, n° 05-11-938, BPIM 5/06, inf. 358) et qu'il se borne à en assurer la maintenance (Civ. 3e, 12 sept. 2006, n° 05-16.597, BPIM 6/06, inf. 424) ; elle semble alors privilégier l'intention des parties et la modicité du service.

25. Critère économique. - En matière immobilière, la jurisprudence s'est, un moment, montrée favorable à un *critère économique.* Est un entrepreneur celui qui fournit les matériaux qu'il assemble et met en place (Civ. 3e, 18 janv. 1983, RDI 1983. 452 ; 31 janv. 1996, n° 93-19.662, Bull. civ. III, n° 28), dès lors que la part du travail est essentielle (Civ. 1re, 1er août 1950, Bull. civ. I, n° 184, S. 1951. 1. 110. – Civ. 3e, 24 nov. 1987, Gaz. Pal. 29-30 janv. 1988. Pan. 8). Le critère économique a longtemps prévalu en cas de construction sur le terrain d'autrui. Le contrat est une *vente* lorsque la matière constitue la partie principale du contrat ; c'est une entreprise lorsque le poids de la main-d'œuvre est prédominant (Civ. 1re, 1er août 1950, Bull. civ. I, n° 184, S. 1951. 1. 110. – Com. 2 janv. 1968, *ibid.* IV, n° 6. – Civ. 1re, 17 oct. 1973, Gaz. Pal. 1973. 2. Somm. 285 ; 27 avr. 1976, Bull. civ. I, n° 143. – Rouen, 7 juill. 1972, Gaz. Pal. 1972. 2. Somm. 106. – Nancy, 30 août 1979, RDI 1980. 171, obs. P. Malinvaud et B. Boubli), même si ce critère trouve sa limite lorsque travail et matière sont d'égale importance (E. GAUDEMET, note sous Civ. 18 oct. 1911, S. 1912. 1. 449 ; CONTES, Essai sur la nature juridique du contrat d'entreprise, thèse, Toulouse, 1913). On peut donc penser qu'en général la construction sur le terrain du maître de l'ouvrage relève du contrat

d'entreprise, car : 1° les matériaux deviennent la propriété du maître par voie d'accession au fur et à mesure de leur incorporation au sol, et non par l'effet d'une vente (PLANIOL et RIPERT, *op. cit.,* n°s 112 s. ; COLIN et CAPITANT, *op. cit.,* n° 1091 ; MAZEAUD et DE JUGLART, *op. cit. n° 1,* n° 1336 ; P. MALINVAUD et B. BOUBLI, obs. RDI 1980. 171. – Civ. 20 févr. 1883, DP 1884. 1. 32 ; 18 oct. 1911, DP 1912. 1. 113. – Civ. 1re, 27 janv. 1959, Bull. civ. I, n° 54 ; 10 juin 1963, *ibid.* I, n° 302. – Civ. 3e, 17 oct. 1973, *ibid.* III, n° 533 ; 23 avr. 1974, D. 1975. 287, note J. Mazeaud) ; 2° le poids de la main-d'œuvre est prédominant (Com. 23 avr. 1974, D. 1975. 537, note J. Mazeaud et Civ. 1re, 27 avr. 1976, JCP 1977. II. 18635 ; V. P. MALINVAUD, obs. sous Paris, 18 févr. 1977, JCP 1977. II. 18675 ; G. VINEY, Sous-traitance et responsabilité civile, *in* La sous-traitance des marchés de travaux et de services, 1978, Economica, p. 44, spéc. n°s 26 à 30 ; P. MALINVAUD et B. BOUBLI, obs. préc. *in* RDI). Plus généralement, la construction sur le terrain du maître de l'ouvrage répond à la finalité de service du contrat d'entreprise et suffit à retenir cette qualification, car il y a transformation du terrain nu en terrain bâti (PUIG, thèse préc.).

26. Travail spécifique. - Depuis quelques années, spécialement dans l'entreprise de chose mobilière, ou pour le sous-traité, on voit se dessiner un critère tiré de l'*intention des parties* associé à d'autres éléments (V. *supra,* n° 24) ; il y aurait vente si le fabricant conçoit seul l'ouvrage, et entreprise s'il l'exécute conformément aux désirs du client (Colmar, 5 nov. 1954, D. 1956. Somm. 20, Gaz. Pal. 1955. 1. 154), ce qui revient à dire que le contrat portant sur un modèle de série est une vente, celui répondant à une *commande* spéciale du maître de l'ouvrage, un contrat d'entreprise (Com. 4 juill. 1989, JCP 1990. II. 21515, obs. Y. Dagorne-Labbe, RTD civ. 1990. 105, obs. P. Rémy ✐). Ce critère doit être précisé car il est d'une application délicate dans le contrat de louage d'ouvrage principal portant sur l'aménagement d'un terrain (V. *supra,* n° 24), sauf à dire que demander la construction d'un ouvrage est toujours une commande spécifique, ce qui est probable. Le contrat de construction de maison individuelle, qui concerne souvent des constructions en série, selon un modèle type, est-il une variété de louage d'ouvrage, ce qui était admis sous l'empire des dispositions de l'article 45 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 (D. 1971. 316) (MALINVAUD, JESTAZ, JOURDAIN et TOURNAFOND, Droit de la promotion immobilière, 9e éd., 2015, Précis Dalloz, n°s 473 et 480. – Crim. 20 déc. 1978, Bull. crim. n° 361, RDI 1979. 479, obs. Ph. Jestaz et J.-C. Groslière) et n'est plus discutable depuis la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 (D. 1991. 23, rect. 485) (V. par ex., B. BOUBLI, Commentaire de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 sur la construction d'une maison individuelle, ALD 1991. 165). En revanche, le critère paraît convenir à l'entreprise sous-traitante pour distinguer le sous-traitant du fournisseur de matériaux. À la suite des travaux de la commission technique de la sous-traitance, la jurisprudence, après avoir paru privilégier le critère du travail sur le site en retenant l'accomplissement d'actes de production ou de service se rattachant à l'exécution de l'ouvrage (Civ. 3e, 18 janv. 1983, RDI 1983. 344, obs. P. Malinvaud et

B. Boubli, RTD civ. 1983. 552, obs. P. Rémy), semble s'en tenir au *critère de la spécificité* du travail destiné à un chantier déterminé en vertu d'indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalent (Civ. 3e, 5 févr. 1985, Bull. civ. III, n° 23, RDI 1985. 256, obs. P. Malinvaud et B. Boubli, RTD civ. 1985. 737, obs. P. Rémy, D. 1986. 499, obs. J. Huet. – Com. 4 juill. 1989, préc. – Civ. 3e, 19 juin 1991, n° 89-21.906, Bull. civ. III, n° 185 ; 3 janv. 1995, n° 92-20.735, Bull. civ. IV, n° 2. – Civ. 3e, 3 juin 1999, RJDA 11/99. – Civ. 3e, 2 juill. 2008, n° 06-20.946). Le travail spécifique est destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordres (Civ. 1re, 14 déc. 1999, n° 97-19.620, Bull. civ. I, n° 340) et il s'applique au marché principal qui porte sur la fourniture d'un chalet en bois, alors même que celui-ci est fourni en kit et que le prestataire en assure le montage avec zinguerie et conduit de cheminée (Civ. 3e, 17 déc. 2014, n° 13-17.485, RDI 2015. 125, obs. Boubli, BPIM 1/15, inf. 31). Cette orientation suggère une distinction entre la fourniture d'une chose de genre et celle d'un corps certain. Un arrêt estime que la fourniture d'eau est une vente (Com. 27 nov. 2001, n° 99-13.133, CCC 2002, n° 42, note Leveneur) ; un autre décide que la fourniture d'un produit de distillation spécifique est un contrat d'entreprise (Com. 7 nov. 2006, n° 05-11.694, Bull. civ. IV, n° 215). La nuance est parfois plus subtile, en particulier pour distinguer le sous-traité du fabricant de composants ou d'EPERS dans la construction immobilière (V. *infra,* n° 552). On estime que le critère du travail spécifique exclut la production en série et la qualification de vente (BÉNABENT, *op. cit.,* n° 486 qui cite Civ. 3e, 18 nov. 2009, n° 08-19.355, Bull. civ. III, n° 252).

27. Le critère du travail ou de la commande spécifique qui est toujours d'actualité en matière de sous-traitance (Civ. 3e, 18 nov. 2009, n° 08-19.355, Bull. civ. III, n° 252 ; D. 2010. 741, note F. Labarthe ; RDI 2010. 543, obs. H. Périnet-Marquet), peut se combiner avec celui de « l'apport de conception, d'industrie ou de matière » (Civ. 3e, 23 janv. 2002, n° 00-17.759, RJDA 8-9/02, n° 883. – Comp. Civ. 3e, 11 juill. 2001, n° 00-11.984, Bull. civ. III, n° 95 ; AJDI 2001. 1016, obs. P. Gareau ; RDI 2001. 512, obs. F. de Béchillon-Boraud). Ce dernier critère est-il susceptible de s'appliquer au contrat principal ? L'entreprise d'échafaudage, qui n'est pas un sous-traitant selon les arrêts précités est-elle néanmoins un locateur d'ouvrage ? Celui du travail spécifique paraît, en revanche, convenir au contrat de louage d'ouvrage relatif à la mise en œuvre de matériaux fournis, qu'il soit principal ou secondaire. Lorsque *le constructeur fournit le terrain,* la question ne se pose pas car, selon les cas, il y a vente d'immeuble achevé (Civ. 1re, 26 févr. 1963, Gaz. Pal. 1963. 1. 433, RTD civ. 1963. 749, obs. G. Cornu ; 13 nov. 1967, D. 1968. 257, note R. Saint-Alary ; 11 mars 1970, Bull. civ. I, n° 93. – Civ. 3e, 7 mai 1971, *ibid.* III, n° 286 ; 11 déc. 1973, *ibid.* III, n° 619 ; 19 janv. 1977, *ibid.* III, n° 28), ou vente d'immeubles à construire (C. civ., art. 1601-1 s. ; CCH, art. L. 261-1 s.). Il arrive que pour qualifier le contrat d'entreprise, le juge fasse une

application distributive des différents critères (Civ. 3e, 19 juin 1991, n° 89-21.906 Bull. civ. III, n° 185. – Civ. 3e, 31 janv. 1996, RJDA 1/97, n° 47).

B - Intérêts de la distinction

28. La distinction du contrat d'entreprise et de la vente présente plusieurs intérêts. Tandis que l'accord sur le prix est un élément essentiel de la vente (Civ. 1re, 13 mars 1973, Bull. civ. I, n° 96 ; MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 3, 5e éd., par De JUGLART, nos 862 et 875 ; J. GHESTIN, L'indétermination du prix de vente et la condition potestative, D. 1973. Chron. 293), le contrat de louage d'ouvrage n'exige pas pour sa validité la fixation du prix par les parties (V. *infra,* nos 46 s.). Une garantie de conformité est mise à la charge du vendeur professionnel de chose mobilière (C. konsom., art. L. 217-4 s.). La garantie des vices cachés obéit à des règles différentes dans la vente et le louage d'ouvrage (Civ. 3e, 11 déc. 1973, Bull. civ. III, n° 619) ; cependant, le législateur, pour assurer une meilleure protection des acquéreurs, a étendu à la vente d'immeubles les articles 1792 et suivants relatifs au contrat d'entreprise de construction (C. civ., art. 1646-1). Dans la vente à livrer, le transfert de propriété ne s'opère que lorsque la chose est en mesure d'être livrée ; il en résulte que jusqu'à ce moment la chose est aux risques du vendeur ; ces solutions ne s'étendent au louage d'ouvrage que dans l'hypothèse où la matière est fournie par le locateur. Alors que la prescription trentenaire était la règle dans le contrat d'entreprise (Civ. 1re, 16 juill. 1968, RTD civ. 1969. 355, obs. G. Cornu), sauf cas particuliers (C. civ., art. 1792 s. [anc. art. 2272]), elle est désormais, sauf exception, généralisée à cinq ans (C. civ., art. 2224 , réd. L. du 17 juin 2008). Un autre intérêt de la distinction réside dans le fait que la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 (D. 1980. 200) et désormais les articles 2367 et suivants du code civil relatifs aux effets des clauses de réserve de propriété s'appliquent essentiellement à la vente ; mais les articles 2367 et suivants ne font pas cette restriction et le contrat d'entreprise contient parfois une clause de réserve de propriété (Com. 17 mars 1998, n° 95-11.209 , Bull. civ. IV, n° 108 ; 29 mai 2001, CCC 2001, n° 133, note Leveneur ; Com. 19 nov. 2003, n° 01-01.137 , Bull. civ. IV, n° 174). Le bien-fondé de cette stipulation peut toutefois se discuter dans le contrat d'entreprise immobilière. Par l'effet de l'accession et de l'« incorporation » au sol qui en résulte, la matière fournie par l'entrepreneur devient alors la propriété indivisible du maître de l'ouvrage et rend la revendication impossible (Com. 2 mars 1999, n° 95-18.643 , Bull. civ. V, n° 50, RTD civ. 1999. 449, obs. Crocq). L'article 2370 du code civil réserve d'ailleurs le cas où les « biens ne peuvent être séparés sans subir de dommage ». L'entrepreneur n'a aucun droit réel sur l'immeuble et même s'il n'est pas payé, il ne bénéficie d'aucun droit de rétention sur le bien construit ou sur le produit de sa vente (Com. 2 juin 1999, n° 98-82.418 , RJDA 11/99, n° 1252). Il faut en conclure que, si la stipulation d'une clause de réserve de propriété dans le contrat d'entreprise n'est pas

illicite, son effectivité est limitée lorsque le contrat d'entreprise a un caractère immobilier.

§ 3 - Distinction d'avec le mandat

29. Représentation. - La définition même du contrat de louage d'ouvrage exclut tout pouvoir de représentation. Le locateur exécute des actes matériels ou d'ordre intellectuel ; le mandataire accomplit des actes juridiques pour le compte de son mandant. Si pendant longtemps, les tribunaux ont considéré comme un mandat les missions données, bien que sans pouvoir de représentation, aux membres de certaines professions libérales, la jurisprudence de la Cour de cassation est aujourd'hui bien fixée en ce sens qu'il ne saurait y avoir mandat, salarié ou non, sans pouvoir de représentation (Civ. 1re, 19 févr. 1968, Gaz. Pal. 1968. 2. 144, note J.-P. Doucet. – Civ. 3e, 5 déc. 1973, Bull. civ. III, no 616 ; V. TGI Seine, 5 juill. 1961, D. 1962. Somm. 2. – Paris, 5 déc. 1969, Gaz. Pal. 1970. 2. 55). Spécialement, l'architecte « est un locateur d'ouvrage ne représentant pas le maître » (Civ. 1re, 21 janv. 1963, Gaz. Pal. 1963. 1. 333 ; 2 févr. 1965, JCP 1965. II. 14089) ; de même l'entrepreneur, car « le contrat d'entreprise […] ne confère […] aucun pouvoir de représentation » (Civ. 1re, 19 févr. 1968, préc.), ou l'entrepreneur général, puisqu'il traite en son propre nom avec les sous-traitants (Civ. 1re, 22 janv. 1962, Bull. civ. I, no 44). La difficulté de qualification est aggravée par le fait que le contrat d'entreprise n'oblige pas seulement à l'accomplissement d'actes matériels, mais également à des prestations intellectuelles (cas de l'architecte : B. BOUBLI, La responsabilité et l'assurance des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs, 1991, JNA, no 74 ; du conseil juridique – aujourd'hui, avocat – : Civ. 3e, 28 févr. 1984, Bull. civ. III, no 51).

30. Toutefois, le contrat de mandat et le contrat d'entreprise ne sont pas exclusifs l'un de l'autre : locateur lorsqu'il assiste le client, *l'avocat postulant* en est le mandataire, depuis la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 (D. 1972. 38 ; V. sur la distinction entre le conseil et la postulation : Civ. 1re, 15 janv. 2002, no 99-21.799, Bull. civ. I, no 15). La même remarque peut être faite pour l'*agence de voyages* (COUVRAT, Les agences de voyages en droit français, thèse, Poitiers, 1967, LGDJ). Les dispositions de l'article L. 211-17 du code du tourisme, résultant de la codification de l'article 1er de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 (JO 14 juill.) qui définit les opérations entrant dans l'objet de cette agence, conduisent à lui reconnaître plusieurs qualités : *entrepreneur,* notamment lorsqu'elle organise le voyage (Civ. 1re, 27 oct. 1970, Bull. civ. I, no 284, D. 1971. 449, note Couvrat, JCP 1971. II. 16624, note Rodière ; 15 oct. 1974, Bull. civ. I, no 264 ; 23 févr. 1983, Bull. civ. I, no 73, D. 1983. 81, note Couvrat, JCP 1983. II. 19967, note Gulphe ; 16 févr. 1999, JCP 2000. II. 10323, note Lachassagne ; JOURDAIN, obs. RTD civ. 1989. 753 ; CHEMEL, obs. CCC 1996. Chron. 2 ; V. *supra,* no 8) ; *mandataire,* en

particulier lorsqu'elle loue des places au nom et pour le compte des clients (T. com. Nice, 2 juill. 1965, Gaz. Pal. 1965. 2. 327 ; V. aussi : Civ. 1re, 5 janv. 1961, Bull. civ. I, no 7 ; 31 mai 1978, *ibid.* I, no 210 ; 7 févr. 2006, no 03-17.642, Bull. civ. I, no 63 ; rappr. : Civ. 1re, 12 juin 1985, Bull. civ. I, no 185) ; *transporteur* (Civ. 1re, 26 avr. 1966, Bull. civ. I, no 257) ; *vendeur* (Paris, 9 févr. 1988, D. 1988. IR 73 ; 21 sept. 1990, Juris-Data no 02.6120*).*

31. Groupe de contrats. - En matière de *construction immobilière,* le mandat fait souvent partie, avec l'entreprise, du *groupe de contrats* qui constitue le support juridique de l'opération (BOUBLI, *op. cit.,* nos 69 s.). Ainsi, l'*architecte* qui est normalement un locateur d'ouvrage (C. civ., art. 1779-3o, 1792-1, al. 1er), et à ce titre ne représente pas le maître de l'ouvrage (V. plus généralement pour celui qui accomplit une mission de maîtrise d'œuvre : Civ. 3e, 30 oct. 1978, 12 déc. 1978, RDI 1979. 207, obs. Malinvaud et Boubli, et égal. Civ. 1re, 31 mars 1965, Bull. civ. I, no 234), peut être chargé par son client d'accomplir, au nom et pour le compte de celui-ci, certains actes juridiques déterminés (Civ. 1re, 17 déc. 1964, D. 1965. Somm. 75 ; 2 févr. 1965, préc. – Civ. 3e, 8 janv. 1970, Bull. civ. III, no 13 ; comp. la jurispr. suisse qui retient que le contrat d'architecte est un acte mixte : T. féd. 13 déc. 1983, ATF 109.II, p. 462 ; MALAURIE et AYNÈS, par GAUTHIER, *op. cit.,* no 705, note 6 ; B. BOUBLI, *op. cit.,* nos 124 et 133 ; LABIN, La responsabilité de l'architecte et son assurance, thèse, Paris I, p. 4 s. ; G. LIET-VEAUX et A. THUILLIER, Droit de la construction, 10e éd., 1994, Litec, p. 251 s. ; V. *Architecte [Civ.]*). L'architecte qui agit comme mandataire doit apporter la preuve du pouvoir qui lui a été donné par le client (Civ. 3e, 14 nov. 1970, Bull. civ. III, no 604). Il peut alors représenter le maître de l'ouvrage auprès de l'Administration (Civ. 3e, 13 juin 1968, Bull. civ. III, no 275 ; 4 avr. 1973, *ibid.* III, no 259) ; passer et modifier les marchés (Civ. 3e, 8 janv. 1970, Bull. civ. III, no 13 ; 8 févr. 1978, *ibid.* III, no 74) ou régler les mémoires. Il peut également obliger le maître sur le fondement de la théorie du mandat apparent (Civ. 3e, 21 mai 1974, Bull. civ. III, no 219 ; 8 févr. 1978, préc.), sauf à engager la responsabilité envers lui s'il a outrepassé ses pouvoirs (P. MALINVAUD et B. BOUBLI, obs. sous Civ. 3e, 8 févr. 1978, préc., RDI 1979. 87).

32. Le *contrat de promotion immobilière* est, selon l'article 1831-1 du code civil (L. no 71-579 du 16 juill. 1971, D. 1971. 316), un « mandat d'intérêt commun ». Mais le projet gouvernemental classait ce contrat parmi les contrats d'entreprise, et la doctrine y voit « un mandat mélangé de louage d'ouvrage » (MALINVAUD, JESTAZ, JOURDAIN et TOURNAFOND, *op. cit.,* no 663 ; V. égal. B. BOUBLI, *op. cit.,* nos 98 et 306). La loi a étendu en effet à cette convention les garanties du contrat d'entreprise (V. *infra,* nos 150 s.).

33. Intérêts de la distinction. - Les conventions passées par le locateur d'ouvrage avec les sous-entrepreneurs ou fournisseurs n'engagent pas le maître qui n'a aucun lien contractuel avec eux (Civ. 1re, 7 oct. 1963, Bull. civ. I, n° 414. – Civ. 3e, 8 mars 1968, *ibid.* III, n° 103), réserve étant faite toutefois des conséquences de l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée (V. RDI 1992. 70). Le maître de l'ouvrage, à la différence du mandant (art. 2000), n'a pas à indemniser l'entrepreneur des pertes éprouvées dans l'exécution des travaux. Si les responsabilités du locateur et celles du mandataire sont voisines lorsque le contrat d'entreprise ne porte par sur une chose, elles sont très différentes dans le cas contraire, notamment s'il s'agit de la construction d'un édifice. Toutefois, on vient de l'indiquer (V. *supra,* n° 32), le législateur a étendu au contrat de promotion immobilière, considéré par lui comme un mandat, les garanties du contrat d'entreprise (C. civ., art. 1831-1). Selon une tradition qui remonte au droit romain, les tribunaux s'arrogent le droit de réduire les honoraires des mandataires ; ils ne disposent pas d'un tel pouvoir à l'égard des locateurs d'ouvrage, sauf de ceux dont les travaux ne portent pas sur une chose – agents d'affaires, médecins et autres professions libérales – en raison sans doute de la confusion longtemps faite entre leurs activités et celles des mandataires (MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 3, n° 1334 ; MALAURIE et AYNÈS, par GAUTHIER, *op. cit.,* n° 710).

§ 4 - Distinction d'avec les contrats de dépôt, de transport, de commodat, d'association, d'assistance

34. Dépôt. - Le louage d'ouvrage implique un *dépôt* lorsque la matière est remise au façonnier par le maître. Parallèlement, le dépôt comporte parfois l'obligation accessoire d'exécuter certains travaux pour préserver la chose déposée. Plutôt que de scinder les deux opérations (Lyon, 30 juill. 1946, D. 1947. 377, note A. Tunc), il paraît préférable de considérer toutes les obligations comme découlant d'un contrat unique, les obligations retenues comme principales imposant au contrat sa qualification (Civ. 1re, 7 oct. 1963, D. 1963. 748). La distinction du louage d'ouvrage et du dépôt ne présente un intérêt que sur le plan de la naissance des obligations : le louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui se forme dès l'accord des volontés, tandis que le dépôt, contrat réel, ne se forme que par la remise de la chose, différence d'ailleurs atténuée par la validité des promesses de dépôt (MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 3, n° 1495). Sur le plan de la responsabilité, il n'est pas de différence sensible entre le dépôt et le louage d'ouvrage portant sur une chose mobilière.

35. Transport. - Le contrat de louage d'ouvrage implique parfois des *opérations de transport* et inversement. Les tribunaux recherchent si l'exécution du transport est ou non l'obligation principale de la convention (Com. 19 juin 1957, D. 1958. 113, note R. Rodière ; 25 févr. 1963, D. 1963. 422) ; une opération qui comprend démontage

d'une machine, chargement et mise en place sur wagon peut être qualifiée de louage d'ouvrage (Com. 25 févr. 1963, préc.) ; une agence de voyages organisatrice d'un voyage est un locateur d'ouvrage (V. *supra,* n° 30) ; bien que le contrat de transport ne soit qu'une variété du contrat d'entreprise, la distinction doit être faite, notamment en ce qui concerne la prescription : l'action contre le transporteur obéit à la prescription spéciale de l'article 108 du code de commerce ([devenu art. L. 133-6] (Com. 25 févr. 1963, préc.).

36. Autres. - Les tribunaux recherchent également l'obligation principale dans les contrats qui comportent à la fois les obligations propres au louage d'ouvrage, au *commodat* et au *louage de chose* (Civ. 1re, 7 oct. 1963, préc. ; V. cep. Paris, 9 mars 1959, Gaz. Pal. 1959. 2. 115 : l'arrêt scinde l'opération ; un arrêt considère comme un prêt à usage la remise d'une échelle par le maître à son entrepreneur : Civ. 1re, 26 oct. 1960, Bull. civ. I, n° 463).

37. Sur la distinction du contrat d'entreprise et du *contrat d'association,* V. TGI Paris, 22 janv. 1970 (D. 1970. Somm. 204) : l'article 1855 prohibant toute clause affranchissant un des associés de toute participation aux pertes est inapplicable au contrat d'entreprise.

38. Sur la distinction du contrat d'entreprise et du *contrat d'assistance bénévole,* V. Paris, 3 déc. 1963 (JCP 1964. II. 13504, note P. Esmein. – Soc. 29 janv. 2002, n° 99-42.697, Bull. civ. V, n° 38 : le contrat d'assistance bénévole oblige l'assisté à réparer le dommage subi par l'assistant. Si l'architecte, qui accepte à titre gracieux d'assumer la direction des travaux, est responsable des désordres résultant du défaut de surveillance (Civ. 3e, 20 juin 1972, Bull. civ. III, n° 405), il n'est pas un locateur d'ouvrage, et n'est tenu de sa faute que selon le droit commun.

39. Sur la distinction entre contrat d'entreprise et louage de chose avec prêt de main-d'œuvre, voir ci-après à propos de la sous-traitance des marchés de travaux (V. *infra,* nos 311 s.).

Chapitre 2 - Formation et preuve du contrat

40. Le contrat d'entreprise est un contrat à titre onéreux dont il convient d'examiner la formation (V. *infra,* nos 41 s.), le mécanisme de fixation du prix (V. *infra,* nos 46 s.), et le régime de preuve (V. *infra,* nos 51 s.).

Section 1re - Formation du contrat d'entreprise

41. Contrat consensuel. - Le contrat de louage d'ouvrage est un *contrat consensuel* qui n'exige aucune forme particulière pour sa validité (Civ. 3e, 17 déc. 1997, n° 94-20.709, Bull. civ. III, n° 226), en particulier, « l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à l'existence du contrat d'entreprise » (Civ. 23 oct. 1945, D. 1946. 19. – Civ. 3e, 18 juin 1970, D. 1970. 674 ; V. cep. CCH, art. L. 231-1 et L. 231-2 ; comp. pour un chirurgien-dentiste : Versailles, 4 févr. 1988, JCP 1988. IV. 367. – Sur le principe du consensualisme, V., C. civ, nouv. art. 1172 issu de l'Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, JO 11 févr.). Toutefois, le contrat d'architecte doit être conclu par écrit, formalité prescrite au plan déontologique (Paris, 28 juin 1985, RDI 1985. 373, obs. P. Malinvaud et B. Boubli. – Civ. 3e, 11 juin 1986, D. 1987. 285, note A. Gourio. – Civ. 3e, 15 mars 1989, Bull. civ. III, n° 59. – Civ. 3e, 6 nov. 1996, n° 95-11.010 ; V. *Architecte [Civ.]*) qui ne fait pas échapper la preuve du contrat aux dispositions de l'article 1341 du code civil (Civ. 3e, 24 mars 1987, RDI 1987. 453, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli. – Civ. 3e, 28 févr. 1996, RDI 1996. 212 ; Civ. 3e, 14 mars 2001, 2 esp., n° 98-20.247 et 98-20.248 ; rappr. Civ. 1re, 14 déc. 1999, D. 2000. IR 20 ; V. aussi : Versailles, 24 nov. 2000, RDI 2001. 230). Un arrêt a fait produire effet à un contrat de louage d'ouvrage *apparent* (Angers, aud. sol., 3 avr. 1973, JCP 1973. II. 17478, note R. Rodière ; rappr. Civ. 3e, 21 mai 1974, Bull. civ. III, n° 219). Les parties, plutôt que de préciser les conditions de leur contrat, se réfèrent parfois aux normes de l'Association française de normalisation homologuées par l'Administration (V. L. et Décr. 24 mai 1941, DA 1941. 275) ; ces normes ne s'imposent nullement aux contractants dans les marchés privés (Civ. 1re, 21 juin 1967, JCP 1968. II. 15341, note G. Liet-Veaux), mais l'adoption de leurs clauses, sérieusement étudiées, donne une grande sécurité aux parties. Les normes, auxquelles il est fait référence, sont les normes p. 03-011 de 1966 et surtout la norme p. 03-001 homologuée en dernier lieu en décembre 2000. Des formalités peuvent toutefois être requises en application du code de la consommation lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur (art. L. 211-1 s.).

42. Le contrat peut être *conclu par voie électronique* dans les conditions prévues aux articles 1125 nouveau et suivants du code civil ; l'article1127-1 vise notamment le contrat de prestations de service. L'écrit n'étant pas une condition de validité du contrat, les dispositions du nouvel article 1174 du même code n'ont pas vocation à s'appliquer.

43. Des règles particulières sont relatives aux marchés publics (V. Dalloz Action, Droit de la construction 2014/2015, Dossiers 410 à 417, p. 799 s.).

44. Pourparlers. - Le contrat est souvent précédé d'une phase dite de « pourparlers » qui relève de la négociation précontractuelle consacrée désormais par le nouvel article 1112 du code civil. Les documents recueillis par le client pendant cette période ne le lient pas, sauf stipulation contraire ; en sorte qu'aucune rémunération n'est due à l'entrepreneur (Civ. 22 oct. 1894, DP 1895. 1. 252. – Nancy, 9 oct. 1959, D. 1960. 90. –

TGI Lille, 31 mai 1968, AJDA 1969. 421 ; rappr. Com. 20 mars 1972, JCP 1973. II. 17543, note J. Schmidt. – Civ. 3e, 6 mars 1973, Bull. civ. III, n° 163 ; V. *infra,* n° 244). Toutefois, la règle selon laquelle les pourparlers ne lient pas les parties ne s'applique pas lorsque le travail porte sur des plans et projets. Ainsi l'architecte a droit à ses honoraires même si les projets demeurent sans suite (V. Civ. 3e, 29 avr. 1985, RDI 1985. 374 ; V. *Architecte [Civ.]*). Même solution pour les bureaux d'études (Civ. 3e, 6 mars 1973, Bull. civ. III, n° 163). De plus, il faut être certain que les parties sont simplement au stade des pourparlers et que le contrat n'est pas définitivement conclu. La charge de la preuve du contrat incombe à celui qui s'en prévaut (Civ. 3e, 18 févr. 1981, Bull. civ. III, n° 36) et si elle est rapportée, l'entrepreneur a droit à une rémunération même si l'engagement s'est limité à l'établissement du devis.

45. La rupture des pourparlers peut être fautive : c'est le cas lorsque le maître de l'ouvrage demande abusivement des devis sans intention sérieuse d'exécuter les travaux, ou si des négociations importantes sont rompues brutalement sur simple coup de téléphone (Pau, 14 janv. 1969, D. 1969. 716, RTD civ. 1970. 358, obs. G. Durry. – Com. 20 mars 1972, préc.). Selon le nouvel article 1112-1 du code civil, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

Section 2 - Fixation du prix

46. Contrat à titre onéreux. - Le prix est un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage qui est un contrat à titre onéreux ; si aucun prix n'était exigé par l'exécutant, la convention s'analyserait en un contrat de services gratuits ou d'assistance bénévole susceptible d'ailleurs de créer des obligations à la charge du contractant qui exécuterait mal la mission qu'il a assumée (Civ. 3e, 20 juin 1972, préc. *supra,* n° 33). Le contrat d'entreprise est valable bien que le prix n'ait pas été fixé lors de l'accord des parties : « un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel d'un contrat de cette nature » (Civ. 1re, 15 juin 1973, D. 1973. IR 199 : pour un conseil en organisation d'entreprise. – Civ. 3e, 18 janv. 1977, Bull. civ. III, n° 25. – Civ. 1re, 28 nov. 2000, n° 98-17.560, Bull. civ. I, n° 305). Le contrat d'entreprise échappe à l'obligation d'une détermination préalable de la contrepartie pécuniaire (Civ. 3e, 2 juill. 1997, JCP 1997. IV. 1900 ; V. Leçons de droit civil, par MAZEAUD et CHABAS, t. 2, 1er vol., nos 237 s. – BÉNABENT, *op. cit.,* n° 514). L'ancien article 1129 du code civil, n'était pas applicable à la détermination du prix (Cass., ass. plén., 1er déc. 1995, n° 93-13.688, Bull. civ., n° 409, D. 1996. 13, concl. Jéol, note Aynts, JCP 1996. II. 22565, concl. Jéol, note Ghestin, Gaz. Pal. 1995. 1. 626, concl. Jéol, note de Fontbressin, Defrénois 1996. 747, obs. Delebecque, RTD civ. 1996. 153, obs.

Mestre) ; cette règle concerne le contrat d'entreprise (deux des arrêts d'assemblée plénière visent l'article 1710 C. civ. ; V. aussi Civ. 1re, 20 févr. 1996, n° 94-14.074 , Bull. civ. I, n° 91). L'article 1165 nouveau, issu de l'ordonnance de 2016, précise qu'à défaut d'accord entre les parties avant l'exécution du contrat de prestation de services, le prix peut être fixé par le créancier à charge d'en motiver le montant en cas de contestation ; en cas d'abus, le juge peut être saisi d'une demande en dommages-intérêts. Ces règles doivent être tempérées par les dispositions protectrices du consommateur qui requièrent que le prestataire de services doit informer le consommateur sur les prix (C. konsom. art. L. 112-1). Il convient d'étudier le mécanisme de fixation du prix, ce dernier peut se faire soit par les parties (V. *infra,* nos 47 s.) soit par le juge (V. *infra,* nos 49 s.).

ACTUALISATION

46. Ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 - Outre l'octroi de dommages et intérêts, le nouvel article 1165 du code civil, tel que modifié par l'article 7, 1°, de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 portant ratification de l'ordonnance du 10 février 2016, prévoit que le juge peut, en cas d'abus dans la fixation du prix, être saisi d'une demande tendant à obtenir la résolution du contrat.

Dépassement du budget des travaux : caractérisation du lien de causalité. Le lien de causalité entre le préjudice consécutif au dépassement du budget et la faute de l'architecte ayant sous-évalué les travaux n'est pas établi si le maître de l'ouvrage devait nécessairement payer le surcoût correspondant aux prestations complémentaires dont l'évaluation a été omise (Civ. 3e, 19 janv. 2022, n° 20-15.376, D. actu. 14 févr. 2022, obs. N. De Andrade).

Art. 1er - Fixation par les parties

47. Convention. - Sauf pour les petits travaux, où le maître s'en remet généralement à l'appréciation du locateur (Colmar, 5 nov. 1954, Gaz. Pal. 1955. 1. 154), les parties conviennent, en général, du prix. Il est fréquent, notamment en matière de construction, que les parties se réfèrent à un *barème* préexistant pour fixer le prix du travail : ainsi pour déterminer les honoraires de l'architecte (V. *Architecte [Civ.]*). À défaut de barème, les parties conviennent d'un mode de fixation. Le prix peut, parfois, être fixé par le créancier (C. civ., nouv. art. 1164 , V. *supra,* n° 46 et *infra,* n° 49). Selon les cas, le marché peut être à *forfait,* sur *devis,* sur *série de prix,* ou à *prix maximum.*

48. Lorsque le prix a été fixé par les parties, les juges ne peuvent le modifier, tandis qu'ils peuvent modérer les honoraires des mandataires (V. *supra,* n° 33). Toutefois, la

jurisprudence a étendu à certaines professions libérales la réduction judiciaire des honoraires : avocats, agents d'affaires, médecins (Civ. 9 mai 1866, DP 1866. 1. 246 ; Req. 28 mai 1913, S. 1915. 1. 116. – Civ. 1re, 17 juin 1970, Gaz. Pal. 1970. 2. 81 ; L. SEBAG, La détermination des honoraires de l'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1970, D. 1970. Chron. 177 ; V. pour les avocats, Décr. n° 72-468 du 9 juin 1972, art. 97 s., D. 1972. 268, puis Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 174 s., D. 1991. 490 ; V. *Avocat : responsabilité [Civ.]*), conseils en organisation d'entreprise (Rennes, 17 avr. 1969, RTD civ. 1971. 172, obs. G. Cornu), sauf si la rémunération n'a été convenue qu'après exécution de la mission (Rouen, 20 déc. 1966, D. 1967. 260). La Cour de cassation refuse aux tribunaux le droit de réduire les honoraires des généalogistes au motif peu convaincant que le contrat est aléatoire (Civ. 1re, 17 avr. 1956, D. 1956. 427).

Art. 2 - Fixation par le juge

49. Pouvoir du juge. - À défaut d'accord sur le prix ou de référence, même implicite (Civ. 3e, 4 juill. 1972, Bull. civ. III, n° 442), à un mode de détermination licite (exclusion des barèmes publiés par l'ordre des architectes, Cons. conc. 21 janv. 1992, n° 92. D. 06, rapport Cons. conc. 1992, p. 164 ; V. *Architecte [Civ.]* ; exclusion des séries de prix établies par l'académie d'architecte, Cons. conc. n° 97. D. 41 du 30 juill. 1997 et n° 99. D. 68 du 2 févr. 1999 ; V. *infra,* n° 271), les juges du fond déterminent le montant de la rémunération en fonction des éléments de la cause (Civ. 1re, 4 oct. 1989, Bull. civ. I, n° 301) ; ils disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation (Civ. 3e, 3 déc. 1970, Bull. civ. III, n° 663 ; 10 janv. 1973, D. 1973. IR 58 ; honoraires d'architecte : 15 juin 1973, préc. – Civ. 1re, 19 déc. 1973, Bull. civ. I, n° 360 ; 4 oct. 1989, Bull. civ. I, n° 301 ; 24 nov. 1993, RTD civ. 1994. 631, obs. Gautier ; comp. Com. 13 avr. 1999, n° 97-16.632, Bull. civ. IV, n° 89, JCP 1999. II. 10222, obs. Fages ; V. sur la réfaction du prix, Com. 2 mars 1993, n° 90-20.289, Bull. civ. IV, n° 83). Il appartient à l'entrepreneur d'établir la valeur des travaux effectués (Civ. 3e, 12 déc. 1972, Bull. civ. III, n° 674 ; V. pour le prix de modifications apportées à une commande de tableaux : Paris, 14 mars 1962, D. 1963. 104, note P. Esmein, RTD civ. 1963. 119, obs. G. Cornu). Nonobstant les dispositions du nouvel article 1165 du code civil qui prévoit que le prix peut être fixé par le créancier (V. *supra,* n° 46), il semble qu'en ce cas, le débiteur qui n'est pas d'accord puisse demander au juge de fixer le prix, comme il en avait, naguère la possibilité.

50. TVA. - La taxe à la valeur ajoutée doit être incluse dans le prix ; c'est au maître, s'il prétend être dans un cas d'exception, à en apporter la preuve (Civ. 3e, 21 mai 1969,

Bull. civ. III, n° 401), et s'il n'a pas mis son cocontractant « à même de ne pas inclure la taxe dans la facture », il lui appartient après avoir payé de solliciter une détaxation (Com. 12 mai 1965, Bull. civ. III, n° 307 ; V. Doc. fiscale, F. Lefebvre, TVA. VI. 220 s. ; sur l'intégration de la TVA dans l'indemnité destinée à réparer un préjudice, V. *infra,* n° 633).

Section 3 - Preuve du contrat

51. Modes de preuve. - Si l'on tient pour un accident un arrêt rendu par la première chambre civile aux termes duquel « l'existence » du contrat d'entreprise « peut être établie par tous moyens de preuve » (Civ. 1re, 17 déc. 1964, D. 1965. Somm. 75), on observera que la jurisprudence fait dans ce domaine application des règles du droit commun, sauf lorsque le contrat a été exécuté au vu et au su du maître. Nombreux sont les arrêts qui imposent au contractant la preuve du contrat d'entreprise selon les règles prescrites par les articles 1359 et suivants (anciens art. 1341 s. c. civ.) : *commencement de preuve par écrit* (Civ. 1re, 30 oct. 1961, Bull. civ. I, n° 492 : mention « convenu » et signature portées par le maître sur le devis, complétées par le fait de l'exécution. – Civ. 3e, 16 oct. 1969, Bull. civ. III, nos 649 et 5 mars 1974, *ibid.* III, n° 97 : correspondance ; 2 avr. 1979, JCP 1979. IV. 203, RDI 1979. 471, obs. Malinvaud et Boubli : demandes de permis de construire refusées) ; *impossibilité morale de se procurer un écrit* (Civ. 1re, 29 mai 1961, Bull. civ. I, n° 276 ; 16 janv. 1973, D. 1973. IR 52) ; *preuve écrite contre le contenu aux actes* (Civ. 1re, 23 nov. 1964, Bull. civ. I, n° 514. – Civ. 3e, 8 janv. 1970, *ibid.* III, n° 26) ; la qualité de *commerçant* du défendeur – qu'il soit le locateur (Com. 9 nov. 1966, Bull. civ. III, n° 424. – Civ. 3e, 8 mai 1969, *ibid.* III, n° 367. – Civ. 1re, 6 mars 1974, Bull. civ. I, n° 80) ou le maître (Com. 22 avr. 1964, Bull. civ. III, n° 203 ; 31 mai 1965, *ibid.* III, n° 345) – permettant de faire contre lui la preuve par tous moyens. Les règles de preuve prescrites par l'article 1359 du code civil (anc. art. 1341) sont applicables au contrat d'architecte (V. *supra,* n° 41 ; comp. pour le chirurgien-dentiste qui doit parfois établir un devis : Versailles, 4 févr. 1988, JCP 1988. IV. 367 ; V. *supra,* n° 41). Le régime de la preuve est maintenu par les nouveaux textes du code civil : le principe est celui de la preuve par tout moyen (C. civ., art. 1358), les règles relatives à la nécessité de prouver le contrat par écrit (C. civ., art. 1359), par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit, au-dessus d'un certain seuil, sont maintenues (C. civ., art. 1361). L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier (C. civ., art. 1366).

52. La preuve du contrat étant rapportée, la Cour de cassation admet que sa qualification (Civ. 1re, 7 oct. 1963, D. 1963. 748. – Civ. 3e, 15 nov. 1968, Bull. civ. III, n° 470 ; 17 juill. 1972, Bull. civ. III, n° 462) comme son contenu peuvent être établis par

interprétation, les juges ayant la possibilité de recourir à tous moyens de preuve pour interpréter la volonté des parties (V. *Preuve*) et établir la nature du marché à forfait ou sur devis (Civ. 1re, 23 nov. 1964, Bull. civ. I, no 514), l'adhésion des parties aux conditions des normes AFNOR (Civ. 1re, 21 juin 1967, JCP 1968. II. 15341, note G. Liet-Veaux), l'étendue de la mission de l'architecte (Civ. 3e, 15 janv. 1974, Bull. civ. III, no 16), ou celle du réparateur ou garagiste (Civ. 1re, 3 nov. 1970, Bull. civ. I, no 291. – Rouen, 27 févr. 1942, S. 1942. 2. 26).

53. En marge des règles des articles 1358 et suivants (C. civ., anc. art. 1341 s.), certains arrêts, en dehors d'écrit ou de commencement de preuve par écrit, admettent la preuve du contrat d'entreprise par interprétation de l'attitude du maître corroborée par l'exécution des travaux ; ils font ainsi produire effet au profit de l'entrepreneur à une sorte de possession d'état, les travaux ayant été exécutés et n'ayant pu l'être qu'avec l'assentiment du maître, on en déduit son accord (Civ. 1re, 19 févr. 1962, Bull. civ. I, no 105. – Civ. 3e, 11 juin 1986, D. 1987. 285. – Paris, 28 juin 1985, D. 1987. 13 ; *contra* : Civ. 1re, 24 mars 1987, Bull. civ. I, no 101). Encore faut-il que cette attitude ne soit pas équivoque : le fait de travailler sur le terrain du propriétaire ne permet pas de décider si l'exécutant était entrepreneur ou sous-traitant (Civ. 3e, 23 janv. 1969, Bull. civ. III, no 72 ; rappr. Civ. 3e, 25 mars 1971, *ibid.* III, no 218). Lorsque des travaux supplémentaires sont effectués, la preuve de leur commande par le maître de l'ouvrage doit être apportée pour que ces travaux lui soient opposables, quelle que soit la nature du marché (Civ. 3e, 27 sept. 2006, no 05-13.808, Bull. civ. III, no 189). Les travaux exécutés sans ordre peuvent être ratifiés par le maître de l'ouvrage (V. *infra,* nos 286 s.).

54. À l'attitude du maître pendant les travaux, on assimile celle qu'il a observée lors de la réception de la facture (Civ. 3e, 19 oct. 1971, Bull. civ. III, no 495). Un arrêt, plus orthodoxe, n'admet cependant comme moyen de preuve du contrat « ni la présomption résultant du silence [du maître] devant les réclamations de l'architecte, ni l'aveu extrajudiciaire qu'est le paiement d'acomptes » (Civ. 3e, 23 janv. 1969, Bull. civ. III, no 66).

Chapitre 3 - Effets du contrat d'entreprise

55. Une fois le contrat signé, le locateur d'ouvrage (V. *infra,* nos 56 s.) et le maître de l'ouvrage (V. *infra,* nos 104 s.) ont des obligations dans l'exécution du contrat. Il existe des risques lors de l'exécution du contrat pouvant engager la responsabilité des parties (V. *infra,* nos 117 s.) sauf cas particuliers (V. *infra,* nos 126 s.).

Section 1re - Obligations du locateur d'ouvrage

56. Les obligations du locateur d'ouvrage varient dans leur nature comme dans leur contenu, selon l'objet du contrat, et notamment suivant que la convention concerne une chose ou un service. On réservera d'ailleurs le cas particulier de la construction immobilière (sur ce point, V. *infra,* nos 140 s.). Nonobstant leur variété, les obligations du locateur ont des caractères communs.

57. Travail personnel ou non ? - Le locateur d'ouvrage est-il tenu d'exécuter lui-même le travail ou peut-il le faire exécuter par des sous-traitants ? Les rédacteurs du code civil ont souligné l'*intuitus personae* dans le contrat de louage d'ouvrage, conclu en raison de la « confiance qu'on a dans la probité et dans l'intelligence de celui qu'on en charge » (TRONCHET, Locré, t. XIV, p. 367) ; ils en ont déduit que la mort de l'entrepreneur entraîne l'extinction du contrat d'entreprise (C. civ., art. 1795). Mais on s'accorde généralement pour admettre que c'est la volonté et, à défaut, l'usage qui déterminent si le contrat a été conclu en considération de la personne du locateur : il n'y a pas les mêmes motifs à s'opposer à l'exécution du travail par une autre personne que le peintre à qui on a commandé un tableau que par le sous-traitant d'un entrepreneur de travaux de construction (BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, *op. cit.,* no 3059 ; CONTAMINE-RAYNAUD, L'*intuitus personae* dans les contrats, thèse, Paris, 1975). Sauf pour certains contrats où l'*intuitus personae* est évident, la tendance est d'admettre que depuis la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 (D. 1976. 64), « la liberté de sous-traiter » est « le principe » (GAVALDA, *in* La sous-traitance des marchés de travaux et de services). Même l'architecte, sauf pour la mission relevant du monopole architectural (L. du 3 janv. 1977, préc., art. 3), peut sous-traiter les tâches qui lui sont confiées (Décr. no 80-217 du 20 mars 1980, art. 37, D. 1980. 159 ; V. *Architecte [Civ.]*). Toutefois, cette liberté de sous-traiter connaît un tempérament : le locateur d'ouvrage, même s'il est architecte (Décr., art. 37, al. 2), doit faire accepter par le titulaire chaque sous-traitant (L. du 31 déc. 1975 préc., art. 3). Le maître de l'ouvrage reçoit également un certain pouvoir de contrôle des clauses financières du sous-traité ; mais un refus systématique des sous-traitants présentés par l'entrepreneur principal pourrait être considéré comme un abus de droit (V. *infra,* nos 314 s., étude générale de la sous-traitance).

58. Qu'il exécute l'ouvrage lui-même ou par ses ouvriers et sous-traitants, le locateur d'ouvrage demeure responsable vis-à-vis du maître de l'exécution de ses prestations (Civ. 3e, 22 mai 1968, D. 1970. 453, note Ph. Jestaz. – Civ. 1re, 5 mars 1974, Bull. civ. I, no 70. – Civ. 3e, 5 janv. 1978, Bull. civ. III, no 9, RDI 1979. 67, obs. Malinvaud et Boubli ; CE 2 août 1907, DP 1909. 3. 17), sauf si les salariés travaillent sous la direction et la surveillance du maître à titre de préposés occasionnels (Com. 13 avr. 1972, Bull. civ. IV, no 100. – Civ. 3e, 24 juin 1971, *ibid.* III, no 409 ; sur la responsabilité des

constructeurs en cas de sous-traitance, V. *infra,* n°s 314 s.). La prestation porte sur un service ou sur le façonnage d'une chose.

Art. 1er - Louage d'ouvrage s'appliquant aux services

59. L'obligation principale du locateur est d'exécuter le travail (V. *infra,* n°s 60 s.). S'y ajoutent celle de conseiller ou de renseigner le client (V. *infra,* n°s 63 s.), et parfois celle d'assurer sa sécurité (V. *infra,* n°s 65 s. – V. *Responsabilité contractuelle [Civ.]*).

§ 1er - Exécution du travail

60. Exécution d'une prestation. - L'obligation consiste en l'exécution d'une prestation. Le débiteur *doit* exécuter certains actes : donner des soins, organiser le transport, éclairer le client de ses conseils. Si après s'être engagé à accomplir l'acte, le locateur s'y refuse, il manque à son obligation qui alors est déterminée, c'est une évidence. Toutefois, l'engagement n'est déterminé que dans sa *matérialité,* ou, si l'on préfère, sous son aspect purement *quantitatif.* Il en va tout autrement lorsqu'il s'agit d'apprécier la *qualité* de la prestation fournie, ou tout simplement l'efficacité du travail accompli : cette fois, l'obligation qui pèse sur le locateur est *seulement de moyens.* Le débiteur ne s'engage pas à un résultat, mais à tout mettre en œuvre pour y parvenir : une chose est de savoir si le médecin a dispensé des soins, une autre chose est de savoir si ces soins étaient conformes aux données de la science pour favoriser une guérison. Lorsque l'objet du louage d'ouvrage est une prestation de services, le locateur, sauf convention contraire, ne garantit pas l'efficacité des moyens qu'il met en œuvre : de ce point de vue, il n'est tenu qu'à une obligation de moyens (pour le médecin : Civ. 20 mai 1936, DP 1936. 1. 88, concl. Matter, rapp. Josserand, note E.P., S. 1937. 1. 321, note Breton. – Civ. 1re, 18 juill. 1983, Gaz. Pal. 1984. 1. Pan. 54, note F. Chabas ; pour un chirurgien-dentiste en ce qui concerne les soins : Civ. 1re, 15 nov. 1988, Bull. civ. I, n° 319 ; ou la prothèse : Civ. 1re, 10 déc. 1996, n° 95-13.154, Bull. civ. I, n° 445 ; pour un vétérinaire : Civ. 1re, 18 janv. 2000, n° 98-16.203, Bull. civ. I, n° 15 ; sur ce sujet, V. *Médecine : réparation des conséquences des risques sanitaires [Civ.]* et *Corps humain – Bioéthique [Civ.]*). En jurisprudence, avant la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (CSP, art. L. 1142-1), le *médecin* ne supporte pas les conséquences de l'aléa thérapeutique qui n'entre pas dans le champ des obligations dont il est contractuellement tenu à l'égard du patient (Civ. 1re, 8 nov. 2000, n° 99-11.735, Bull. civ. I, n° 287, D. 2001. Somm. 2236, obs. Mazeaud ; D. 2001. 3083, obs. J. Penneau, JCP 2001. II. 10493, Rapport Sargos, obs. Chabas, RTD civ. 2001. 154, obs.

Jourdain ; 27 mars 2001, n° 99-13.471, Bull. civ. I, n° 86 ; V. aussi pour un chirurgien : Civ. 1re, 27 mars 2001, n° 99-13.471, Bull. civ. I, n° 86) ; il répond de sa faute (Civ. 1re, 4 janv. 2005, n° 03-13.579, Bull. civ. I, n° 5). Mais il est tenu d'une *obligation de sécurité de résultat* en cas d'*infection nosocomiale* consécutive à un acte médical dans un établissement de santé ou au cabinet (Civ. 1re, 13 févr. 2001, n° 98-19.433, Bull. civ. I, n° 32 ; V. aussi : 30 sept. 1997, n° 95-16.500, Bull. civ. I, n° 259 ; 7 janv. 1997, n° 94-19.497, *ibid.* I, n° 6, D. 1997. 189, Rapport Sargos, obs. Thouvenin ; 7 janv. 1997, n° 95-10.939, [2e esp.], Bull. civ. I, n° 7 ; 29 juin 1999, n° 97-15.818, Bull. civ. I, n° 222, D. 1999. 559 [2e esp.] obs. Thouvenin), sous condition que la victime établisse le caractère nosocomial de l'affection (Civ. 1re, 27 mars 2001, n° 99-17.672, Bull. civ. I, n° 87, D. 2001. IR 1284 ; pour ce type d'affection, la même solution est retenue : contre l'établissement de soins : Civ. 1re, 29 juin 1999, n° 97-14.254, Bull. civ. I, n° 220, D. 1999. 559 [1re esp.] obs. Thouvenin ; le principe, en dehors de ce type d'affection, est cependant que l'établissement de soins a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du malade, les exigences étant fonction de son état, ce qui crée, semble-t-il, une obligation de moyens renforcée : Civ. 1re, 18 juill. 2000, n° 97-10.513, Bull. civ. I, n° 221).

61. Santé. - L'article L. 1142-1 du code de la santé publique (L. n° 2002-303 du 4 mars 2002) après avoir posé que les professionnels de santé ne répondent que de leur faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du *défaut d'un produit de santé,* déclare que les personnes visées au texte sont responsables des affections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (V. *Médecine : réparation des conséquences des risques sanitaires [Civ.]* et *Corps humain – Bioéthique [Civ.]*). Cet article invite à tenir compte des différentes situations qu'il envisage : défaut du produit, soins, infections nosocomiales (V. notamment : CE 10 oct. 2011, req. n° 328500, Centre hospitalier universitaire d'Angers, Lebon ; D. 2012. 47, obs. Brun et Gout). S'agissant du *chirurgien dentiste,* la Cour de cassation se rapproche de l'obligation de résultat lorsqu'elle consacre « l'obligation de précision du geste de chirurgie dentaire » (Civ. 1re, 9 oct. 2001, n° 99-20.826, Bull. civ. I, n° 248 ; 23 mai 2000, n° 98-20.440, Bull. civ. I, n° 153 ; 17 janv. 2008, n° 06-20.107, Bull. civ. I, n° 14 ; sur la tendance jurisprudentielle en faveur de l'obligation de sécurité de résultat en matière de soins, V. également : Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 99-12.255, Bull. civ. I, n° 279, qui consacre l'obligation de résultat d'une *clinique privée* pour les produits fournis. – Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-10.007, Bull. civ. I, n° 108 ; 13 févr. 2001, n° 99-13.589, Bull. civ. I, n° 35 ; 9 mai 2001, n° 99-18.161, Bull. civ. I, n° 130 ; 18 juin 2002, n° 01-00.381, Bull. civ. I, n° 169. – Civ. 2e, 25 janv. 2007, n° 06-12.106, Bull. civ. II, n° 20, D. 2007. Pan. 2905, obs. Jourdain, RTD civ. 2007. 362,

obs. Jourdain, JCP 2007. II. 10035, note Radé, RLDC 2007/38, n° 2519, note Corgas-Bernard, RDC 2007. 725, obs. Borghetti, à propos des centres de *transfusion sanguine,* qui affirment l'existence d'une obligation de résultat sous condition de preuve de la contamination et de l'absence de mode de contamination propre, le centre ayant à sa charge la preuve de l'absence de vice caché du produit ; mais dans le principe, la responsabilité médicale ne procède pas du manquement à une obligation de sécurité de résultat : Civ. 1re, 8 nov. 2000, n° 99-11.735, Bull. civ. I, n° 287).

62. Applications diverses. - Ne sont tenus que d'une obligation de moyens les *agences de conseils en organisation d'entreprise* qui se chargent de planifier ou réorganiser une entreprise mais ne promettent pas de leur faire réaliser des bénéfices (Civ. 1re, 21 déc. 1964, JCP 1965. II. 14005. – Lyon, 23 déc. 1969, *ibid.* 1970. II. 16557, note P.L., RTD civ. 1971. 162, obs. Durry ; T. com. Paris, 19 avr. 1971, JCP 1971. II. 16752 ; comp. : Com. 8 janv. 2002, n° 98-21.039, D. 2002. Somm. 2708, obs. Karaquillo, qui retient une obligation de résultat à la charge d'une agence de communication chargée des intérêts d'un sportif ; MIALON, obs. RTD civ. 1973. 5 ; VINEY, La responsabilité des entreprises prestataires de conseils, JCP 1975. I. 2750) ; les *agences de renseignements commerciaux* qui promettent non de découvrir la situation financière réelle de la personne sur laquelle doivent porter leurs investigations, mais de vérifier cette situation avec tout le soin nécessaire, ce qui suppose qu'elles ne doivent pas se borner à consulter « l'opinion de la place », la modicité de leurs honoraires se justifiant par l'insuffisance de leur enquête (Req. 27 nov. 1911, DP 1913. 1. 111. – Paris, 12 mai 1920, DP 1921. 2. 39 ; T. com. Seine, 19 janv. 1953, Gaz. Pal. 1953. 1. 238. – Lyon, 27 oct. 1971, D. 1972. 327, note Tendler, JCP 1972. II. 17012, note Savatier. – Com. 30 janv. 1974, Bull. civ. IV, n° 41 ; VASSOGNE, Les agences de renseignements commerciaux, thèse, Poitiers, 1942 ; MAZEAUD, Traité, t. 1, n° 501, note 2 ; SAVATIER, Responsabilité, t. 1, 2e éd., n° 87) ; les agences dites *sociétés de classification* (Req. 15 mai 1923, DP 1925. 1. 15 : bureau Véritas ; CA Tunis, 23 févr. 1955, JCP 1955. II. 8810 : bureau Véritas ; V. cep., en ce qui concerne le contrôle technique de la construction tel qu'il est réglementé par la loi n° 78-12 du 4 janv. 1978, D. 1978. 74 ; V. *infra,* nos 231 s.) ; les *agences de voyages,* lorsqu'elles agissent en qualité de locateur d'ouvrage (sur la question, V. *supra,* n° 30), sont responsables de la mauvaise exécution de leur obligation qui, alors, consiste, pour l'essentiel, à organiser le voyage. La jurisprudence estimait que cette obligation était de *moyen* (Civ. 1re, 15 déc. 1969, D. 1970. 326, note P. Couvrat ; 15 oct. 1974, D. 1975. Somm. 13 ; 29 mai 1990, Bull. civ. I, n° 128, qui retient que le véhicule où avait pris place la victime était le mieux adapté au type d'excursion), mais il s'agissait plutôt d'une obligation de moyen renforcée, car la responsabilité de l'organisateur était aisément retenue (Angers, 3 avr. 1973, JCP 1973. II. 17878, note R. Rodière : choix d'un transporteur sans garanties professionnelles. – Civ. 1re, 10 nov. 1971 [2 esp.], D. 1972. 593, note Couvrat : choix d'un transporteur déjà en grève lors de l'organisation du

voyage ; Civ. 1re, 29 janv. 1991, n° 89-17.227, D. 1992. 435, note Diéner [2e esp.], Gaz. Pal. 1993. 1. 205, note Tandonnet-Gency : qui insiste sur l'obligation de veiller à ce que le transporteur exécute le transport dans des conditions de sécurité suffisantes ; Civ. 1re, 15 janv. 1991, n° 89-16.370, D. 1992. 242, note Dagorne-Labbe, *ibid.* 435, note Diéner [1re esp.] et Civ. 1re, 3 mai 2000, n° 97-20.329, Bull. civ. I, n° 129, D. 2001. 670, note Dagorne-Labbe, qui retiennent à la charge de l'organisateur la même responsabilité que celle de l'hôtelier ; comp. : Crim. 1er juill. 1997, n° 96-85.320, Bull. crim. n° 259, D. 1998. Somm. 199, obs. Jourdain, qui paraît raisonner comme en matière d'obligation de résultat). La *loi n° 92-645 du 13 juillet 1992* (D. 1992. 374 ; C. tourisme, art. L. 211-17) a consacré la responsabilité de plein droit de l'organisateur de voyages et de séjour, qui répond du fait des personnes auxquelles il fait appel et qui ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère (Civ. 1re, 15 mars 2005, n° 02-15.940, Bull. civ. I, n° 138 ; 13 déc. 2005, n° 03-17.897, Bull. civ. I, n° 504). Toutefois, lorsqu'il se borne à délivrer des billets, l'agent de voyages n'est responsable que s'il commet une faute (Civ. 1re, 22 oct. 2002, CCC 2003, n° 35, note Leveneur ; Civ. 1re, 30 janv. 2007, D. 2007. 2374, note Dagorne-Labbe). L'*agent de publicité* (Com. 9 oct. 1990, n° 88-19.804, Bull. civ. IV, n° 234), l'*avocat* (Civ. 1re, 7 oct. 1998, n° 96-13.614, Bull. civ. I, n° 282 ; *adde :* Civ. 1re, 8 juill. 1997, n° 95-14.067, Bull. civ. I, n° 234 ; Civ. 1re, 18 déc. 2001, n° 98-20.246, Bull. civ. I, n° 321), le *gestionnaire en bourse,* surtout si la gestion est spéculative (Com. 13 juin 1995, n° 93-17.982, Bull. civ. IV, n° 173. – Paris, 12 avr. 1996, JCP 1996. II. 22705, note le Tourneau), sont tenus eux aussi d'une obligation de moyens (V. toutefois : Com. 24 sept. 2002, n° 00-16.245, Bull. civ. IV, n° 130). Mais c'est l'obligation de résultat qui est mise à la charge d'un *parc de stationnement* (Civ. 1re, 29 janv. 1991, n° 89-16.315, Bull. civ. I, n° 39 ; 23 févr. 1994, n° 92-11.378, *ibid.* I, n° 76), d'une société de *télésurveillance* (Civ. 1re, 20 oct. 1998, RCA 1998, n° 389, 1re esp.), et parfois même d'un *garagiste* pour la réparation des véhicules, car alors, le contrat porte sur un bien, comme il est expliqué aux numéros 62 et suivants (Civ. 1re, 2 févr. 1994, n° 91-18.764, Bull. civ. I, n° 41, RTD civ. 1994. 613, obs. Jourdain ; 8 déc. 1998, n° 94-11.848, *ibid.* I, n° 343 ; 12 janv. 1994, n° 91-17.386, *ibid.* I, n° 9 ; 14 déc. 2004, n° 02-10.179, Bull. civ. I, n° 322. – Com. 22 janv. 2002, GIE ATICAM c/ société Carrier et autres, RTD civ. 2002. 514, obs. Jourdain, RCA 2002. Comm. 175 ; comp. en cas de remorquage et dépannage : Civ. 1re, 11 mai 1971, D. 1971. 477. – Civ. 2e, 16 janv. 1974, D. 1974. Somm. 36. – Orléans, 12 avr. 1943, S. 1943. 2. 63. – Poitiers, 5 févr. 1964, D. 1964. Somm. 94), ou d'un *réparateur* (pour un ascenseur : Civ. 1re, 15 juill. 1999, n° 95-22.796, Bull. civ. I, n° 238 ; sur les prestataires constructeurs, V. *infra,* nos 140 s.).

§ 2 - Obligation de renseignement et de conseil

63. Caractère général et principal. - L'obligation d'information est générale (Civ. 1re, 31 oct. 2012, n° 11-15.529, Bull. civ. I, n° 222 ; D. 2012. 2658) et énoncée désormais par l'article 1112-1 nouveau du code civil. Elle pèse depuis longtemps sur les professionnels et elle s'accompagne souvent d'une obligation de conseil, car l'information doit permettre à celui à qui elle est donnée de se déterminer. Dans certaines professions, l'obligation de conseiller et renseigner est l'*obligation principale* : conseil en organisation d'entreprise (MIALON, RTD civ. 1973. 5) ; renseignements commerciaux ; conseil juridique ou avocat (V. Com. 2 avr. 1974, Bull. civ. IV, n° 119. – Paris, 18 nov. 1988, D. 1989. IR 11. – Civ. 1re, 9 mai 1996, n° 94-14.022, Bull. civ. I, n° 191 ; 13 nov. 1997, n° 95-14.141, Bull. civ. I, n° 303 ; 12 janv. 1999, n° 96-18.775, Bull. civ. I, n° 15, Defrénois 1999. 382, note Aubert ; 19 mai 1999, n° 96-20.332, Bull. civ. I, n° 164, D. 2000. Somm. 153, obs. Blanchard, qui retiennent l'obligation malgré la compétence du client ; sur l'étendue de l'*obligation d'informer :* V. Civ. 1re, 18 juill. 2000, n° 97-14.713, Bull. civ. I, n° 214, D. 2002. 854, note Blanchard, qui concerne la rémunération. – Civ. 1re, 23 mai 2000, n° 97-19.223, Bull. civ. I, n° 152, qui vise l'obligation du conseil juridique, *de s'informer,* lui-même pour conseiller utilement ; rappr. sur ce dernier point : Civ. 3e, 10 juill. 2002, n° 00-20.696, analysé sous Civ. 3e, 15 mai 2002, n° 99-15.600, RDI 2002. 390, obs. Boubli ; sur la circonstance que le conseil juridique confie le dossier à un auxiliaire de justice chargé de la postulation, V. Civ. 1re, 15 janv. 2002, n° 99-21.799, Bull. civ. I, n° 15) ; cette obligation est assortie d'une obligation de vigilance (Civ. 1re, 28 juin 1983, Bull. civ. I, n° 188), et parfois d'une garantie de validité des actes (Com. 28 nov. 1984, Bull. civ. IV, n° 326 ; ingénieur-conseil en propriété industrielle : Paris, 8 mai 1971, Gaz. Pal. 1971. 2. 805 ; V. R. SAVATIER, La profession de conseil juridique, D. 1969. Chron. 145 ; Les contrats de conseil professionnel en droit privé, D. 1972. Chron. 137 et 145). Il faut, cependant que celui qui est tenu d'informer utilement, dispose des informations permettant de mettre en garde le client (pour un avocat : Civ. 1re, 31 oct. 2012, D. 2012. 2737, note Avril) et un arrêt estime même que l'architecte chargé d'établir un dossier de permis de construire n'est tenu, ni de procéder aux études de sol, ni d'informer le maître de l'ouvrage d'y faire procéder alors même qu'il existe un risque de pollution du sol (Civ. 3e, 30 janv. 2013, n° 11-27.792, RDI 2013. 208. – V. aussi : Civ. 3e, 21 nov. 2012, n° 11-19.778 RDI 2013. 149). Parfois, l'obligation de conseil, sans l'être, fait figure d'obligation principale : l'agent immobilier ne doit pas se contenter de mettre en présence acheteur et vendeur ; comme le notaire, il doit se renseigner sur leurs qualités et leurs pouvoirs (Civ. 1re, 11 mai 1966, Bull. civ. I, n° 281) ; indiquer à l'acquéreur les projets de voirie susceptibles de modifier l'environnement ou la valeur de l'immeuble (Civ. 3e, 20 déc. 1971, D. 1972. 157, note F.B. – TGI Paris, 17 mars 1971, Gaz. Pal. 1971. 2. 806 ; plus généralement : Civ. 1re, 15 juin 1989, Bull. civ. I, n° 231 ;

17 janv. 1995, n° 92-21.193, *ibid.* I, n° 29 ; 25 nov. 1997, n° 96-12.325, Bull. civ. I, n° 321). Une obligation identique pèse sur l'agent d'affaires (TGI Toulon, 20 janv. 1971, Gaz. Pal. 1971. 2. 807 ; rappr. Com. 9 nov. 1971, JCP 1972. II. 16962, note P.L.) ; sur l'agence de voyages qui, même après la fin du voyage, doit renseigner ses clients sur leurs droits relatifs à un dommage subi en pays étranger (Civ. 1re, 27 oct. 1970, JCP 1971. II. 16624, note R. Rodière, D. 1971. Somm. 49 ; T. com. Nice, 2 juill. 1965, Gaz. Pal. 1965. 2. 327. – Civ. 1re, 24 nov. 1998, n° 96-22.782, Bull. civ. I, n° 330), sur l'entreprise d'entretien d'ascenseur qui doit signaler les réparations qui s'imposent (Civ. 11 nov. 1941, DC 1942. 153, note P.L.-P.) et sur l'entrepreneur de désherbage obligé d'indiquer à ses clients la date favorable pour le traitement (Douai, 20 oct. 1964, JCP 1965. II. 14108). Généralement de moyens en raison du caractère aléatoire du conseil, l'obligation devient déterminée lorsqu'elle concerne l'exactitude d'une information (MALAURIE et AYNÈS, par GAUTHIER, *op. cit.,* n° 723). L'obligation d'information est spécialement renforcée dans les contrats de prestations thérapeutiques (Civ. 1re, 7 oct. 1998, n° 97-10.267, Bull. civ. I, n° 291 ; 7 oct. 1998, n° 97-12.185, *ibid.* I, n° 287 ; 18 janv. 2000, n° 97-17.716, Bull. civ. I, n° 13, D. 2001. 3559, note. M.-L. Mathieu-Izorche), notamment pour les interventions de chirurgie esthétique (Civ. 1re, 17 févr. 1998, n° 95-21.715, Bull. civ. I, n° 67). C'est au professionnel, légalement ou contractuellement tenu, d'établir qu'il a exécuté son obligation d'information (pour un médecin : Civ. 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685, Bull. civ. I, n° 75 ; pour un avocat : Civ. 1re, 29 avr. 1997, n° 94-21.217, Bull. civ. I, n° 132, RTD civ. 1997. 924, obs. J. Mestre ; pour un banquier : Com. 11 déc. 2007, n° 03-20.747, Bull. civ. IV, n° 260, D. 2008. 2820, obs. Vasseur, RTD com. 2008. 165, obs. D. Legeais…).

64. Caractère accessoire. - Dans les autres contrats, l'obligation de conseiller le client est *accessoire* de l'obligation principale d'exécuter le travail. On peut en donner quelques exemples : l'*agent immobilier* doit renseigner ses clients sur la situation exacte du lieu qu'il est chargé de vendre (Civ. 3e, 20 déc. 1971, D. 1972. 157, note F.B.), ou sur la solvabilité des parties contractantes (Civ. 16 juin 1969, Journ. not. et av. 1970, art. 49516), ou sur les possibilités d'obtention d'un prêt compte tenu des revenus de l'éventuel acquéreur (TGI Paris, 17 mars 1971, Gaz. Pal. 1971. 2. 806 ; ROUJOU DE BOUBÉE, La responsabilité pénale des agents immobiliers, RDI 1979. 295). Le *géomètre* doit établir des plans de nature à renseigner efficacement le client (Civ. 3e, 14 janv. 1975, Bull. civ. III, n° 6, JCP 1975. IV. 69 ; plus généralement, sur l'obligation de conseil qui pèse sur ceux qui concourent à la *maîtrise d'œuvre,* dans la construction, V. *Architecte [Civ.]*), l'*agent d'affaires* (Com. 9 nov. 1971, JCP 1972. II. 16962, note P. L. ; 2 avr. 1974, Bull. civ. IV, n° 119. – TGI Toulon, 20 janv. 1971, Gaz. Pal. 1971. 2. 807), l'*agent de voyages* (V. *supra,* n° 63), le *notaire,* s'il agit en tant que négociateur, doivent renseigner le client (V. MESTRE, obs. RTD civ. 1989. 325). Il a été jugé qu'un *conseiller juridique et fiscal* a l'obligation de procéder à l'inscription du privilège du

vendeur et du nantissement, lorsqu'il rédige l'acte de vente du fonds de commerce (Com. 2 avr. 1974, Bull. civ. IV, n° 119, Gaz. Pal. 1974. 1. Somm. 148. – Civ. 1re, 31 janv. 1984, *ibid.* I, n° 43). Le *médecin* également doit informer le client, notamment en ce qui concerne le caractère dangereux du traitement envisagé (Civ. 1re, 8 oct. 1974, Bull. civ. I, n° 255 ; 5 nov. 1974, *ibid.* I, n° 292. – Montpellier, 5 juill. 1949, D. 1950. Somm. 11 ; V. *Médecine : réparation des conséquences des risques sanitaires [Civ.]*). Cette obligation est désormais le corollaire d'un *droit à l'information* reconnu aux usagers par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO 5 mars) dans les articles L. 1111-1 et suivants du code de la santé publique. La première chambre civile de la Cour de cassation avait posé que l'obligation d'informer procédait du « respect du principe constitutionnel de sauvegarde et de dignité de la personne » (Civ. 1re, 9 oct. 2001, n° 99-20.826, Bull. civ. I, n° 248). Elle en a tiré la conséquence : 1°) que l'information s'impose même si le risque encouru est exceptionnel (Civ. 1re, 9 oct. 2001, n° 00-14.564, Bull. civ. I, n° 249), y compris en cas de chirurgie esthétique (Civ. 1re, 9 oct. 2001, n° 00-14.553, Bull. civ. I, n° 252) ; 2°) que l'information est nécessaire sous peine de priver le patient de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé (Civ. 1re, 20 juin 2000, n° 98-23.046, Bull. civ. I, n° 193) ; 3°) que la violation de l'obligation d'informer peut être invoquée par la mère et l'enfant victime (Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, Bull. civ., n° 9. – Civ. 1re, 9 oct. 2001, n° 99-20.826, Bull. civ. I, n° 248). Même solution pour l'assureur qui est tenu d'une obligation précontractuelle d'information (Civ. 1re, 30 janv. 2001, n° 98-18.145, Bull. civ. I, n° 14) qui ne s'achève pas lors de la souscription du contrat (Civ. 2e, 5 juill. 2006, n° 04-10.273, Bull. civ. II, n° 180, D. 2008. 120, obs. Groutel ; V. aussi : Civ. 3e, 17 déc. 2003, n° 01-12.259, Bull. civ. III, n° 235 [arrêt n° 1] ; 11 mai 2006, n° 04-20.250, Bull. civ. III, n° 116 ; V. plus généralement, G. VINEY, Traité de droit civil, t. 5, Les obligations, 4e vol. : La responsabilité, 1988, LGDJ, nos 502 s. ; FABBRE MAGNAN, De l'obligation d'information dans le contrat. Essai d'une théorie, thèse, Paris I, 1992, préf. GHESTIN, LGDJ).

§ 3 - Obligation de sécurité

65. Nature. - Cette obligation longtemps oubliée est tantôt de moyens, tantôt déterminée : de moyens lorsque l'utilisation présente certains aléas et laisse au maître une certaine initiative, le locateur d'ouvrage étant tenu seulement d'apporter tous ses soins à la protection de la personne du client et de ses biens ; de résultat, lorsque, faute d'aléa et l'initiative du client étant réduite, l'entrepreneur s'engage à une sécurité dont il n'est dégagé que par la force majeure ou la faute de la victime (V. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, 1965, préf.

R. NERSON ; G. DURRY, obs. RTD civ. 1968. 363 ; MAZEAUD, Leçons, t. 2, n°s 21 et 402). Une promenade à dos d'âne, l'animal tenu par le locateur, ne comporte aucun aléa ; l'obligation de sécurité est donc de résultat (Civ. 1re, 25 avr. 1967, D. 1967. Somm. 101, JCP 1967. II. 15156, note R. Rodière), tandis que le moniteur dirigeant une sortie de cavaliers n'est tenu que d'une obligation de prudence (Civ. 1re, 16 mars 1970, Bull. civ. I, n° 103).

66. Applications. - Une obligation de moyens pèse sur : l'*entreprise de gardiennage* qui se charge de la surveillance de locaux, et pour qui l'obligation de sécurité est d'ailleurs l'obligation principale (V. Civ. 5 mars 1974, préc.) ; le *laboratoire d'analyses* tenu de surveiller les réactions de ses clients pendant les soins (Civ. 1re, 6 déc. 1972, D. 1973. Somm. 31 ; 16 juill. 1997, CCC 1997, n° 174, note Leveneur ; 2 déc. 1997, n° 95-21.907, Bull. civ. I, n° 349 ; comp. Civ. 1re, 20 oct. 1998, cité *supra,* n° 54) ; les *coiffeurs* tenus de prendre certaines précautions pour éviter les accidents allergiques causés par les teintures (Civ. 1re, 4 oct. 1967, D. 1967. 652, RTD civ. 1968. 163, obs. G. Durry ; V. Angers, 7 mars 1967, Gaz. Pal. 1967. 2. Somm. 7 ; *contra* : Paris, 18 févr. 1957, JCP 1957. II. 9944, note P. Esmein, et, sur pourvoi du seul fabricant de teinture : Civ. 2e, 5 mai 1959, JCP 1959. II. 11159). Il était généralement admis qu'une obligation de moyens était à la charge des *agences de voyages* qui doivent choisir des transporteurs sérieux et convenablement assurés, « porter assistance à leurs clients dans toute la mesure de leurs moyens » et, en cas d'accident, même si la responsabilité incombe à un tiers, assurer leurs hospitalisation et rapatriement (Civ. 1re, 15 déc. 1969, D. 1970. 326, note P. Couvrat) et faciliter leur action devant les tribunaux étrangers (Civ. 1re, 27 oct. 1970, JCP 1971. II. 16624, note R. Rodière, D. 1971. Somm. 49). Mais depuis la loi du 13 juillet 1992 (C. tourisme, art. L. 211-17 ; V. *supra,* n° 62), la tendance est de considérer que l'organisateur de voyages, responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat, doit indemniser le client victime d'une chute s'il n'établit pas l'existence d'une cause étrangère exonératoire (Civ. 1re, 2 nov. 2005, n° 03-14.862, Bull. civ. I, n° 401).

67. C'est, en principe, une obligation de moyens (Civ. 1re, 21 nov. 1995, n° 94-11.294, Bull. civ. I, n° 424), qui est renforcée en cas de sport dangereux (Civ. 1re, 16 oct. 2001, n° 99-18.221, Bull. civ. I, n° 260, D. 2001. IR 1766 : planeur. – Civ. 1re, 16 mai 2006, n° 03-12.537. Bull. civ. I, n° 249 : hockey sur glace), qui pèse sur l'*organisateur de manifestations sportives* tenu de veiller à la sécurité des *participants* (Civ. 1re, 23 nov. 1966, D. 1967. 313, note Cabrillac, RTD civ. 1967. 651, obs. Durry. – Nîmes, 25 févr. 1969, D. 1969. 375, RTD civ. 1969. 772 : course de taureaux. – Civ. 27 mai 1952, JCP 1952. II. 7275, note Rodière. – Civ. 1re, 16 juill. 1964, Bull. civ. I, n° 391 ; 28 nov. 1966, *ibid.* I, n° 524 : courses cyclistes ; 28 juin 1967, D. 1967. 631 : assaut d'escrime ; 7 nov. 1967, Bull. civ. I, n° 326 : culture physique. –

Aix-en-Provence, 27 juin 1963, RTD civ. 1964. 99, et Bordeaux, 13 oct. 1966, D. 1967. 763 : karting ; la 1re chambre civile considère cette responsabilité comme contractuelle, l'obligation résultant d'une convention entre organisateur et participants, par ex. : Civ. 1re, 23 nov. 1966, préc. ; 1er déc. 1999, no 97-21.690, Bull. civ. I, no 330, qui la fonde sur une obligation de moyens ; tandis que la 2e chambre civile a retenu la responsabilité quasi délictuelle de l'organisateur : Civ. 1re, 28 juin 1967, préc. ; mais la 2e chambre civile s'est ralliée : Civ. 2e, 27 mai 1999, no 97-16.200, Bull. civ. II, no 104 ; V. aussi Civ. 1re, 15 juill. 1999, no 97-15.984, Bull. civ. I, no 251, à propos d'une épreuve d'endurance motocycliste sur circuit non couvert ; V. sur ce point, DURRY, obs. RTD civ. 1968. 366), même s'ils pratiquent librement leur activité (Civ. 1re, 15 déc. 2011, no 10-23.528 et no 10-24.545, D. 2012. 539, note Develoy), et des *spectateurs* (Civ. 1re, 17 mai 1965, D. 1966. 1, note Azard, RTD civ. 1965. 813, obs. Rodière, et 30 janv. 1968, D. 1968. 360, RTD civ. 1969. 135, obs. Durry : match de rugby) ; l'*exploitant d'une piscine* qui doit exercer une surveillance très sérieuse sur le bassin, ses abords, comme sur les cabines (Req. 30 mars 1939, Gaz. Pal. 1939. 1. 897, sur pourvoi contre Amiens, 5 juin 1935, *ibid.* 1935. 2. 376), sa responsabilité étant même engagée s'il n'a pas recherché l'identité de l'auteur d'une bousculade ayant blessé un nageur et a fait perdre ainsi à la victime la possibilité d'une action (Civ. 1re, 20 oct. 1971, Bull. civ. I, no 269, RTD civ. 1972. 608, obs. G. Durry) ; le *guide de montagne* tenu de prendre les mesures de sécurité de la technique moderne (V. Civ. 1re, 8 mai 1967, Bull. civ. I, no 159 : accident survenu dans une école d'escalade ; pour le moniteur de ski, rappr. Civ. 2e, 13 mai 1969, Bull. civ. II, no 156) (V. *Sport [Civ.]*) ; l'*entrepreneur de spectacles,* qui, obligé d'assurer la sécurité des spectateurs, tant par les règlements que par son contrat, doit se faire assister d'un médecin et disposer de médicaments de première urgence (Paris, 27 juin 1964, JCP 1964. II. 13893, note Esmein ; sur le cas du *contrat médical,* V. *supra,* nos 61 et 63 ; sur le parc de stationnement, V. *supra,* no 62 ; V. aussi sur *les activités sportives* : équitation, Civ. 1re, 29 juin 1994, no 92-16.442, Bull. civ. I, no 231 ; 28 nov. 2000, no 98-10.290, Bull. civ. I, no 310, D. 2001. IR 44 : obligation de sécurité de moyens ; moniteur de ski : Civ. 1re, 9 févr. 1994, no 91-17.202, Bull. civ. I, no 61 ; 19 mars 1996, no 94-15.651, Bull. civ. I, no 142 : obligation de sécurité de moyens).

68. C'est une obligation déterminée de sécurité, dispensant le client de faire la preuve de la faute, qui pèse sur les *exploitants de remonte-pentes* (Civ. 1re, 8 oct. 1968, D. 1969. 157, note Mazeaud. – TGI Albertville, 30 nov. 1973, JCP 1974. II. 17828, note Rabinovitch, ces décisions marquant un revirement de jurisprudence ; V. Civ. 1re, 8 oct. 1963, D. 1963. 750. – Grenoble, 15 oct. 1969, JCP 1970. II. 16164, note W.R. ; 10 juin 1970, Gaz. Pal. 1970. 2. 291, note Rabinovitch. – TGI Thonon-les-Bains, 15 oct. 1972, Gaz. Pal. 1972. 1. 201, note Rabinovitch ; mais l'obligation de résultat est limitée au transport et non à l'embarquement et au débarquement : Civ. 1re, 10 mars 1998, no 96-

12.141, Bull. civ. I, n° 110 ; V. pour un ULM : Civ. 1re, 7 mars 2000, JCP 2000. IV. 1718 ; 11 juin 2002, n° 00-10.415, Bull. civ. I, n° 166 ; pour un parapente, Civ. 1re, 21 oct. 1997, n° 95-18.558, Bull. civ. I, n° 287, qui retiennent aussi, dans cette limite, l'obligation de résultat) et ceux de *manèges forains,* d'autos tamponneuses (Civ. 1re, 28 avr. 1969, D. 1969. 650, note G. C.-M. ; 12 févr. 1975, D. 1975. 512, note le Tourneau, JCP 1975. II. 18179, 2e esp., note Viney ; auparavant, la jurisprudence était en sens contraire : Civ. 1re, 9 janv. 1957, D. 1958. 245, note Savatier ; 6 janv. 1959, D. 1959. 106 ; pour les balançoires : Rouen, 12 déc. 1961, RTD civ. 1962. 311, obs. Tunc). La position prise par la Cour de cassation, malgré les réticences des juges du fond, est fondée sur le fait que l'indépendance de l'usager de remonte-pentes ou de manèges forains est très relative, et surtout sur le peu d'aléas sérieux que présentent ou devraient présenter dans des conditions normales d'installation et de fonctionnement ces exploitations : les téléskis ne sont interdits ni aux enfants ni aux débutants qui en constituent la meilleure clientèle. L'obligation déterminée est d'ailleurs limitée au temps de l'utilisation des appareils par le contractant ; avant comme après l'utilisation, l'obligation de sécurité de l'exploitant aux approches des installations mécaniques n'est que de moyens (Civ. 1re, 1er juill. 1969, D. 1969. 640, note G. C.-M., JCP 1969. II. 16091, concl. Lindon ; 2 nov. 1972, D. 1972. 713, note G. C.-M. : accidents survenus sur le manège avant et après le jeu ; V. pour les transports, Civ. 1re, 21 juill. 1970, D. 1970. 767, note Abadir ; V. *Responsabilité contractuelle [Civ.]*).

Art. 2 - Louage d'ouvrage s'appliquant aux choses

69. L'entrepreneur est tenu, par les termes du contrat, d'exécuter le travail commandé dans les temps convenus (V. *infra,* nos 70 s.), de conserver la chose (V. *infra,* nos 82 s.) et de la livrer (V. *infra,* nos 87 s.), d'informer le maître de l'ouvrage (V. *infra,* nos 96 s.) et, le cas échéant, d'assurer la sécurité d'autrui (V. *infra,* nos 100 s.). Quoique portant sur un bien, qui est créé ou transformé, le contrat n'a pas pour finalité un transfert de propriété mais une finalité de service : c'est donc un contrat d'entreprise.

§ 1er - Exécuter le travail commandé

70. Chaque contrat détermine l'étendue de l'obligation (V. *infra,* nos 71 s.) et les conditions du travail à réaliser (V. *infra,* nos 79 s.).

A - Nature de l'obligation

71. Obligation déterminée. - L'obligation d'exécuter le travail commandé est une obligation déterminée. Mais cette fois (pour l'obligation du prestataire de services, V. *supra,* n°s 60 s.), le débiteur ne s'oblige pas seulement à accomplir les actes relevant de son activité professionnelle ; il s'engage aussi à livrer une chose et à obtenir un résultat : le garagiste promet de rendre le véhicule qu'il répare en état de marche ; le teinturier promet que la tache sur le vêtement disparaîtra, etc. Ici, le prestataire promet la réalisation d'un ouvrage qui pourra remplir la fonction à laquelle il est destiné ; l'aspect qualitatif est un élément prépondérant de la promesse, mais il n'y a pas toujours garantie des vices cachés (Com. 19 févr. 1973, Bull. civ. IV, n° 84. – Civ. 1re, 2 juin 1982, *ibid.* I, n° 204), car si le débiteur doit exécuter ses obligations ainsi qu'il l'a promis, il faut, pour qu'il y ait garantie, qu'il fabrique ou fournisse la chose (V. MALAURIE et AYNÈS, par GAUTHIER, *op. cit.,* n° 717).

ACTUALISATION

71 s. Nature de l'obligation du garagiste. - Il résulte des anciens articles 1147 et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-19.732 et n° 20-18.867, 2 arrêts, D. actu. 17 mai 2022, obs. C. Hélaine).

72. On admet généralement que l'*entrepreneur,* lorsque le travail porte sur une chose, *est tenu d'une obligation de résultat* (GIRIBILA, Louage d'ouvrage et d'industrie, J.-Cl. Civ., art. 1787, n°s 60 et 61 ; MAZEAUD et DE JUGLART, *op. cit.,* t. 3, n° 1347 ; FOSSEREAU, Le clair-obscur de la responsabilité des constructeurs, D. 1977. Chron. 13 ; BOUBLI, *op. cit.,* n° 171 ; MALINVAUD et BOUBLI, obs. RDI 1979. 341 ; MALAURIE et AYNÈS, par GAUTHIER, *op. cit.,* n° 715). Il s'agit d'un principe général en matière d'entreprise (H., L. et J. MAZEAUD, Traité de la responsabilité civile, t. 2, n° 1070), qui se justifie d'autant plus que l'entrepreneur peut être regardé comme un fabricant ou en tout cas, un professionnel qualifié, et qu'à ce titre, il est censé connaître les défauts de la matière qu'il utilise ou de l'objet qu'il façonne ou répare.

73. Jurisprudence. - Malgré des tendances parfois contradictoires, la jurisprudence dominante est en ce sens. Quelques arrêts semblent, certes, ignorer le principe, dans la mesure où ils exigent du maître *la preuve de la faute du locateur d'ouvrage* (Com. 30 mai 1967, Bull. civ. III, n° 216. – Civ. 3e, 17 oct. 1972, D. 1973. 314, note J. Mazeaud ; V. égal. Req. 22 avr. 1872, DP 1873. 1. 119. – Civ. 1re, 16 mai 1960, D. 1960. 737, note A. Tunc ; 3 nov. 1966, D. 1967. Somm. 29. – Rouen, 5 janv. 1950, D. 1951. 30, note H. Lalou ; plus généralement, lorsqu'il s'agit de la conformité aux

instructions du client : Versailles, 9 juin 1988, D. 1988. IR 244 ; encore qu'il faut réserver le cas où la réparation est dépourvue d'aléa, l'obligation étant alors de résultat : Versailles, 15 avr. 1988, D. 1988. IR 152). Mais la plupart des décisions estiment que le prestataire *est tenu d'atteindre le résultat promis.* Ainsi pour le teinturier (Civ. 1re, 8 déc. 1965, Bull. civ. I, no 684; Civ. 1re, 20 déc. 1993, no 90-17.965, Bull. civ. I, no 375 ; comp. Civ. 1re, 7 févr. 1978, *ibid.* I, no 46) ; pour le garagiste lorsqu'il est réparateur d'automobiles (Civ. 1re, 16 mai 1960, Gaz. Pal. 1960. 2. 134 ; 4 févr. 1963, Bull. civ. I, no 75, D. 1964. 17. – Civ. 2e, 4 juin 1969, Bull. civ. II, no 183. – Civ. 1re, 3 nov. 1970, Bull civ. I, no 291, D. 1971. 226 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994, no 91-17.386, Bull civ. I, no 9 ; Civ. 1re, 2 févr. 1994, no 91-18.764, *ibid.* I, no 41 ; Civ. 1re, 8 déc. 1998, no 94-11.848, *ibid.* I, no 343 ; Civ. 1re, 5 févr. 2014, no 12-23.467, D. 2014. 422 ; V. *supra,* no 62) ; pour le spécialiste chargé de renflouer un bateau (Civ. 1re, 9 févr. 1966, Bull. civ. I, no 103) ; pour l'entrepreneur d'abattage (Civ. 1re, 5 juill. 1973, D. 1973. IR 199 ; rappr. pour l'entrepreneur de battage : Civ. 1re, 9 févr. 1966, Bull. civ. I, no 104), etc. ; pour un installateur d'alarme (Civ. 1re, 20 oct. 1998, RCA 1998, no 389, 1re esp.). Sur l'entreprise de construction, V. *infra,* nos 195 et 490 s.

74. Exonération. - C'est en ce qui concerne les *causes d'exonération* que la jurisprudence est la moins claire. Normalement tenu d'une obligation de résultat quant à l'exécution de la chose prévue au contrat, le locateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en justifiant que l'inexécution du contrat est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (MAZEAUD et DE JUGLART, *op. cit.,* t. 3, no 1347 ; V. BÉNABENT, *op. cit.,* nos 558 s. ; sur la définition de la force majeure, V. C. civ., nouv. art. 1218). Conformément à cette règle, plusieurs décisions exigent du locateur la preuve de la *force majeure ou cas fortuit* (Req. 9 juill. 1934, DH 1934. 505. – Civ. 22 nov. 1950, D. 1951. 76. – Com. 25 mars 1963, D. 1964. 17, note Rodière. – Civ. 1re, 17 juill. 1963, Bull. civ. I, no 402. – Com. 30 mai 1967, *ibid.* III, no 216. – Civ. 3e, 6 juin 1972, Bull. civ. III, no 366, D. 1973. Somm. 14 ; CE 2 juill. 1975, D. 1975. IR 218. – Com. 4 févr. 1963, D. 1964. 17, note Rodière et Civ. 1re, 3 nov. 1970, D. 1971. 226, RTD civ. 1971. 391, obs. Cornu, qui concernent un garagiste-réparateur. – Colmar, 10 févr. 1970, D. 1971. Somm. 28 ; V. aussi : Civ. 1re, 23 févr. 1994, no 92-11.378, Bull. civ. I, no 76, pour un parc de stationnement), ou fait du tiers, ou de la *faute de la victime,* c'est-à-dire du maître de l'ouvrage (CE 2 juill. 1975, préc. ; 27 févr. 1974, RD adm. 1974. 91. – Civ. 1re, 11 mai 1966, Bull. civ. I, no 281), encore que, dans ce dernier cas, il ne soit pas toujours facile de savoir dans quelles circonstances précises l'exonération est acquise.

75. Ainsi, il est admis que l'entrepreneur demeure responsable même s'il s'est conformé aux ordres du maître de l'ouvrage lorsque celui-ci n'est pas notoirement compétent en la matière (Civ. 1re, 9 nov. 1960, Bull. civ. I, no 485, Gaz. Pal. 1961. 1. 83 ; 17 juill.

1967, Gaz. Pal. 1967. 2. 141, JCP 1967. II. 15247. – Civ. 3e, 12 juin 1968, D. 1969. 216 ; 19 nov. 1970, Bull. civ. III, n° 617 ; 1er juill. 1971, *ibid.* III, n° 439 ; V. *infra,* garantie décennale), tandis que la responsabilité de l'entrepreneur peut être atténuée ou supprimée si le maître de l'ouvrage qui a donné les ordres est notoirement compétent (Civ. 3e, 18 juin 1970, Bull. civ. III, n° 422 ; CE 21 mars 1973, Rev. adm. 1973, n° 128. – Civ. 3e, 17 oct. 1972, D. 1973. 314, note J. Mazeaud ; 9 oct. 1973, Bull. civ. III, n° 518. – Civ. 1re, 7 juin 1995, n° 93-14.916, Bull. civ. I, n° 235, à propos d'une réparation de fortune par un garagiste).

76. Les juges du fond sont en principe souverains pour déterminer si le maître est notoirement compétent. Mais ils doivent motiver leur décision (Civ. 3e, 12 juin 1968, D. 1969. 216 ; sur la notion et ses applications en droit de la construction immobilière, V. *infra,* n° 613). Cette distinction, selon que le maître est ou non notoirement compétent, ne lève pas toute ambiguïté. Il a été jugé que n'était pas responsable le garagiste auquel le maître a refusé l'autorisation de faire une réparation nécessaire (Civ. 1re, 3 nov. 1970, D. 1971. 226, RTD civ. 1971. 391, obs. G. Cornu), ou celui qui a fait toutes les réparations nécessaires et est totalement étranger au dommage subi par un véhicule à la suite de l'utilisation par son propriétaire d'un produit dangereux (Civ. 1re, 9 mars 1968, Bull. civ. I, n° 106). Ou celui auquel le maître d'ouvrage a fourni des matériaux inadéquats ou en mauvais état (CE 21 mars 1973, préc. *supra,* n° 75. – Civ. 3e, 14 juin 1972, Bull. civ. III, n° 401 ; 17 juill. 1972, *ibid.* III, n° 466). Ou encore l'entrepreneur qui est totalement étranger au préjudice subi par un propriétaire ayant fait exclure du devis primitif certains aménagements dont il ne pouvait ignorer la nécessité (Civ. 3e, 20 déc. 1971, Bull. civ. III, n° 647).

77. Cette jurisprudence alimente l'équivoque en ce qui concerne la force de la présomption qui pèse sur le locateur (MALAURIE et AYNÈS, par GAUTHIER, *op. cit.,* n° 718, évoquent une obligation de moyens « renforcée » pour le teinturier, qui cède devant la preuve de l'absence de faute : Civ. 1re, 20 déc. 1993, n° 92-11.385, Bull. civ. I, n° 376, solution qui tend à s'imposer aussi pour le garagiste : Civ. 1re, 2 févr. 1994, n° 91-18.764, Bull. civ. I, n° 41 ; 20 juin 1995, n° 93-16.381, *ibid.* I, n° 263 ; 8 déc. 1998, n° 94-11.848, *ibid.* I, n° 343). La règle étant que le débiteur d'une obligation de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de la cause étrangère (V. *supra,* n° 65), il existe une présomption que la non-réalisation de l'objectif contractuel est imputable au locateur d'ouvrage. En sorte qu'il n'appartient pas au maître de l'ouvrage d'établir autre chose que la matérialité du dommage, c'est-à-dire la non-conformité du résultat à la promesse. Or, certains arrêts paraissent exiger que *la relation de cause à effet entre les travaux et le dommage* soit établie (Civ. 1re, 20 avr. 1966, Bull. civ. I, n° 223 ; V. BÉNABENT, *op. cit.,* nos 558 s.), tandis que d'autres, tout en admettant qu'une présomption pèse sur le prestataire, lui permettent de s'en

décharger par *la preuve de l'absence de faute* (outre les arrêts précités et *supra,* n° 66, à propos de l'exonération de l'entrepreneur en raison d'un fait du maître de l'ouvrage, V. Req. 9 juill. 1934, DH 1934. 505. – Civ. 1re, 28 nov. 1962, Bull. civ. I, n° 507 ; 18 nov. 1964, Bull. civ. I, n° 509 : garagiste ; V. aussi : Com. 7 nov. 1979, *ibid.* IV, n° 278. – Civ. 1re, 22 juin 1983, Bull. civ. I, n° 181. – Civ. 1re, 9 avr. 1957, Bull. civ. I, n° 179 ; 24 mars 1987, *ibid.* I, n° 106 ; 17 nov. 1987, Gaz. Pal. 1988. 1. Pan. 22 : teinturier, mais en ce qui le concerne, certains arrêts requièrent la preuve de la « cause étrangère » : Civ. 1re, 28 nov. 1973, D. 1974. Somm. 14, et admettent l'exonération par la preuve que la détérioration est due à une autre cause que la faute : Civ. 5 août 1935, DH 1935. 539 et Civ. 1re, 27 mai 1968, D. 1968. Somm. 121 ; V. aussi pour l'entreprise de construction : Civ. 3e, 2 juill. 2002, n° 00-15.067 cité RDI 2002. 390, note Boubli, qui rappelle que l'entreprise est « tenue d'une obligation de résultat » et ne s'en exonère pas par la preuve d'une cause étrangère, alors que le manquement de l'entrepreneur consistait à n'avoir pas « appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque d'inadaptation des ouvrages au sol »).

78. En tout cas, n'est pas libératoire l'événement interne à la prestation de l'entrepreneur : ainsi, ce dernier ne peut se prévaloir utilement des fautes commises par son sous-traitant pour se dégager de sa responsabilité (CE 21 juill. 1970, Lebon 509. – Civ. 3e, 12 déc. 1968, Bull. civ. III, n° 545 ; 5 janv. 1978, *ibid.* III, n° 9 ; V. obs. MALINVAUD et BOUBLI, RDI 1979. 345 ; V. *infra,* n° 548).

B - Contenu de l'obligation

79. L'étendue de l'obligation est variable. Elle dépend de la volonté des parties. Les règles relatives à la responsabilité des locateurs, en dehors de la construction, ne sont pas, en principe, d'ordre public. Les usages professionnels peuvent y déroger : ainsi, l'usage est établi en matière mécanique de dégager la responsabilité du façonnier sauf preuve de sa faute (T. com. Paris, 2 mars 1970, Journ. agréés 1971. 94), et dans la taille du diamant ; celle du locateur sauf faute lourde (Civ. 1re, 25 févr. 1964, D. 1964. Somm. 90).

80. Clauses de responsabilité. - Les *clauses* limitatives de *responsabilité* et les clauses d'exonération totales, lorsqu'elles ne sont pas relatives à des dommages causés à la personne et ne privent pas le contrat de son utilité en l'affectant dans une « obligation essentielle » (Com. 22 oct. 1996, n° 93-18.632, Bull. civ. IV, n° 261 ; sur l'altération d'un élément essentiel comme cause de caducité du contrat, V. C. civ., nouv. art. 1186 issu de l'Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016), sont en principe licites (BÉNABENT, *op. cit.,* nos 542 s. ; MAZEAUD, par CHABAS, t. 2, 1er vol., nos 634 s. – Civ. 1re, 25 févr. 1964, Gaz. Pal. 1964. 1. 391. – Com. 30 mai 1967, Bull. civ. III,

n° 216), et produisent leur plein effet sauf *dol* ou *faute lourde* du locateur (MAZEAUD, *op. cit.,* t. 2, n° 635. – Civ. 1re, 25 févr. 1964, préc. – Com. 18 déc. 1967, Bull. civ. III, n° 419 ; CE 19 juin 1974, Rev. adm. 1974. 240 ; 27 nov. 1974, *ibid.* 1974. 392). Toutefois, ce principe doit tenir compte des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (D. 1978. 86), sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services. L'article 35 de cette loi (C. consom., anc. art. L. 132-1 dont les dispositions sont reprises aux art. L. 212-1 s. du code, issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) répute non écrites les clauses abusives incluses dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs lorsque ces clauses apparaissent imposées par le professionnel par un abus de sa puissance économique et lui confèrent un avantage excessif. Le décret d'application n° 78-464 du 24 mars 1978 (D. 1978. 228) contient deux dispositions qui concernent les clauses relatives à la responsabilité ou à la garantie : l'article 4 et l'article 2. Ce dernier (C. consom., art. R. 212-1), notamment, répute abusive la clause « ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ». Le texte du décret ne concerne que la vente. Mais celui de la loi est général. Il en résulte, à notre avis, que les clauses de non-garantie sont inopposables au maître d'ouvrage lorsqu'elles procurent au professionnel un avantage excessif (Civ. 1re, 16 juill. 1987, Bull. civ. I, n° 226, D. 1988. 49, note Calais-Auloy. – Civ. 1re, 6 déc. 1989, D. 1990. 289, note Ghestin ; comp. Civ. 1re, 25 janv. 1989, Bull. civ. I, n° 43 ; rappr. sur le délit « d'abus de faiblesse » créé par la loi n° 92-60 du 18 janv. 1992, D. 1992. 129, GHESTIN, Traité de droit civil : La formation du contrat, 3e éd., 1993, LGDJ, n° 581).

81. Exécution conforme. - La chose réalisée doit être *conforme* à la convention et aux usages. Elle ne doit comporter aucune malfaçon, puisque l'obligation du locateur est le résultat (V. *supra,* n° 72), mais il est possible de tenir compte d'une certaine marge d'erreur admise par les usages professionnels (V. Civ. 1re, 3 févr. 1969, Bull. civ. I, n° 58 ; T. com. Paris, 2 mars 1970, Journ. agréés 1971. 94). L'exécution doit être *complète* : un garagiste doit remettre le véhicule en état de marche et non se contenter d'une réparation partielle (Civ. 1re, 3 nov. 1970, Bull. civ. I, n° 291, Gaz. Pal. 1971. 1. 144, D. 1971. 226. – Lyon, 28 juin 1954, S. 1954. Chron. 103). On présume que le locateur à qui la chose a été remise pour la réparer a été chargé de faire toutes les réparations nécessaires (T. civ. Bordeaux, 4 juill. 1904, DP 1905. 5. 5. – Rouen, 27 févr. 1942, S. 1942. 2. 21). Ce qui ne le dispense pas de prévenir le client si ces réparations apparaissent comme devant être très onéreuses.

§ 2 - Conserver la chose remise par le maître de l'ouvrage

82. Obligation. - Tout débiteur de corps certain a l'obligation non seulement de livrer ou restituer la chose dans l'état où elle se trouve, obligation déterminée (V. *infra,* n° 88), mais de la *restituer en bon état,* sauf convention contraire (Civ. 1re, 25 févr. 1964, Bull. civ. I, n° 111 ; cette obligation pèse sur le locateur même si la chose est fongible : Req. 22 avr. 1872, DP 1873. 1.119 : blé. – Civ. 1re, 7 oct. 1963, D. 1963. 748 : lavandes. – Paris, 17 juill. 1946, D. 1948. 169, note Weill) : or, ce qui implique l'obligation de la conserver jusqu'à restitution ou livraison (Civ. 1re, 30 mai 2006, n° 05-13.980, Bull. civ. I, n° 270). Les anciennes dispositions du code civil étaient très édifiantes à ce sujet ; les nouveaux articles qui se veulent plus synthétiques, sont peut-être moins précis.

83. Conservation. - L'ancien article 1137 du code civil définit sans aucune ambiguïté la nature de l'obligation du débiteur : « l'obligation de veiller à la conservation de la chose […] soumet celui qui en est chargé à y apporter *tous les soins d'un bon père de famille* » ; l'article 1187 nouveau relatif à l'obligation de délivrer, précise que celui qui conserve la chose doit lui apporter « tous les soins d'une personne raisonnable ». Ni les anciens article 1245 et 1302, non plus que le nouvel article 1342-5 ou, en matière de louage d'ouvrage, l'article 1789 du code civil (« l'ouvrier n'est tenu que de sa faute ») n'apportent de restriction à ce principe qui a pour conséquence de faire peser sur le maître de l'ouvrage la charge de la preuve de la faute ; si certains arrêts se fondent sur ces derniers articles pour obliger le locateur d'ouvrage à apporter la preuve de l'absence de faute (par ex., Com. 14 janv. 1963, Bull. civ. III, n° 33 : perte d'une drague après réparation. – Civ. 1re, 7 oct. 1963, D. 1963. 748 : incendie de lavandes entreposées chez un distillateur ; 9 févr. 1966, D. 1966. Somm. 69 : vol ; 9 févr. 1966, Bull. civ. I, n° 104 : incendie de récoltes confiées à l'entrepreneur de battage ; 5 juill. 1973, *ibid.* I, n° 234. – Colmar, 10 févr. 1970, D. 1971. Somm. 28 : vol au cours de l'expédition, le locateur n'ayant pas fait l'envoi en valeur déclarée), c'est qu'ils ne font pas la distinction entre l'obligation d'exécuter le travail et celle de conserver la chose, et qu'ils privilégient la première qui se réalise dans la livraison (V. *infra,* nos 90 s.).

84. Ainsi, lorsque la chose est la propriété du maître de l'ouvrage, c'est-à-dire s'il a fourni la matière, ou celle-ci étant fournie par le locateur, si la chose est en état d'être livrée, le locateur ne devrait être déclaré responsable de la perte ou de la détérioration de la chose survenue à propos de sa conservation, que si sa faute est démontrée (Aix-en-Provence, 23 févr. 1960, D. 1960. 697, note L. Mazeaud, à propos de la perte d'une drague due à la négligence d'un chantier naval ; V. aussi Civ. 5 août 1935, DH 1935. 539. – Rouen, 5 janv. 1950, D. 1951. 30, note H. Lalou). Mais cette solution n'est guère retenue en pratique, la jurisprudence instituant une véritable présomption de faute à la charge de l'entrepreneur (Civ. 1re, 2 oct. 1980, Bull. civ. I, n° 240 ; 10 janv. 1990, n° 88-14.656, Bull. civ. I, n° 6. – Com. 15 juill. 1970, D. 1971. 151).

85. Alors que l'origine de la détérioration (mauvaise exécution du travail, ou défaut de vigilance dans la conservation de la chose), devrait permettre de déterminer à qui incombe la charge de la preuve, il est admis que la détérioration est présumée provenir de l'exécution du travail, en vertu du principe selon lequel l'obligation de conserver est l'accessoire du contrat d'entreprise (H., L. et J. MAZEAUD par DE JUGLART, Leçons de droit civil, t. III, 2e vol., n° 1508. – Civ. 1re, 11 févr. 2003, LPA 10 déc. 2003, note Babert), et du caractère onéreux du dépôt dans ce cas (Civ. 1re, 5 avr. 2005, n° 02-16.926, Bull. civ. I, n° 165) ; mais le locateur peut s'exonérer soit en prouvant que le dommage n'est pas dû à son travail, soit en prouvant qu'il n'est pas dû à sa faute (Comp. : MAZEAUD et DE JUGLART, *op. cit.,* t. 3, n° 1351 ; rappr. GIBIRILA, *op. cit.,* nos 73 s. ; V. Colmar, 10 févr. 1970, D. 1971. Somm. 28). La Cour de cassation, qui pose le principe que le contrat d'entreprise n'exclut pas que l'entrepreneur soit tenu des obligations du dépositaire (Civ. 1re, 11 juill. 1984, Bull. civ. I, n° 230), précise que l'entrepreneur qui exécute les travaux commandés n'est pas déchargé de ses obligations de dépositaire et qu'il doit garder et conserver la chose jusqu'à restitution (Civ. 1re, 30 mai 2006, n° 05-13.980, Bull. civ. I, n° 270) ; elle laisse entendre que c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve que le dommage n'est pas imputable à sa faute (Civ. 1re, 3 juill. 2001, CCC 2001, n° 169, note Leveneur, à propos d'un cheval de course. – Civ. 1re, 20 juill. 1994, préc.) ; elle distingue parfois, cependant, selon que le dommage procède du dépôt ou de l'exécution du contrat d'entreprise (Civ. 1re, 26 janv. 1999, n° 97-11.952, Bull. civ. I, n° 28).

86. Lorsque le maître est en demeure de prendre livraison, si les risques passent à sa charge (art. 1788 et 1790 et sur le principe relatif à la charge des risques, C. civ., nouv. art. 1344-2 ; V. *infra,* n° 130), l'obligation de conserver ne cesse pas pour autant ; si la responsabilité du locateur d'ouvrage est encourue (Civ. 22 févr. 1897, DP 1901. 1. 75 ; ROUAST, *op. cit.,* n° 928) et que le maître a lui-même commis une faute en ne prenant pas livraison, la responsabilité peut être partagée.

§ 3 - Livrer la chose et exécuter le travail dans le temps convenu

87. Matière fournie. - Au jour convenu, l'entrepreneur doit livrer la chose. Lorsque *la matière est fournie par le maître,* celui-ci en est propriétaire et le reste pendant l'exécution du travail ; il peut donc exiger l'exécution de l'obligation de livraison, au besoin par le moyen d'une astreinte (MAZEAUD et DE JUGLART, par CHABAS, *op. cit.,* t. 2, 1er vol., nos 934 et 942). L'entrepreneur n'a pas le choix entre la restitution de la chose et le paiement de la valeur des marchandises qu'il désirerait conserver (Com. 10 janv. 1956, Bull. civ. III, n° 19). Lorsque *la matière est fournie par l'entrepreneur,* le maître de l'ouvrage en devient propriétaire dès que la chose est en état d'être livrée,

c'est-à-dire avant même que la livraison ait été faite (Civ. 1re, 1er août 1950, Bull. civ. I, no 184, qui statue, il est vrai, en matière de vente ; sur la portée de la clause de réserve de propriété, V. *supra,* no 28).

88. L'obligation de livrer la chose est une obligation de *résultat* (J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et de résultat, thèse, Lyon, 1962, no 292 ; MAZEAUD et DE JUGLART *op. cit.,* t. 3, no 1349 ; V. *infra,* no 398). L'entrepreneur ne peut s'exonérer, s'il n'exécute pas dans le délai convenu, qu'en rapportant la preuve d'un événement de force majeure (Lyon, 28 mai 1895, Gaz. T. 4 oct. 1895. – Civ. 3e, 13 oct. 1971, Bull. civ. III, no 489) : cas fortuit, fait d'un tiers imprévisible pour lui (Civ. 3e, 7 mars 1968, D. 1970. 27, note B. Soinne) ou faute de la victime. Encore faut-il que les éléments qui caractérisent la force majeure soient réunis. Tel n'est pas le cas du retard dans la livraison d'un fournisseur (Rennes, 5 juin 1871, S. 1871. 2. 176), des difficultés dans l'exécution des travaux (Paris, 18 mai 1854, DP 1855. 2. 14), des circonstances rendant l'exécution du travail plus onéreuse (Civ. 26 déc. 1923, Gaz. Pal. 1924. 1. 384). Le cas échéant, il y aura lieu de faire application des articles 1788 et 1789 du code civil relatifs à la charge des risques (V. *infra,* nos 126 s.).

89. On estime, parfois, que l'exécution de l'obligation de livraison est remplie dès que le locateur livre la chose, qu'importe l'état dans lequel elle se trouve (art. 1245) : si la chose est en mauvais état, la responsabilité du locateur ne pourra être recherchée que du fait de la mauvaise exécution du travail ou de l'absence de soins apportés à la conservation de la chose. Cette manière de poser le problème appelle cependant des éclaircissements.

90. Tant que le délai de livraison convenu n'est pas échu, l'entrepreneur conserve en principe la maîtrise totale du travail qu'il est chargé d'accomplir. Le client s'interdit alors toute immixtion dans l'exécution des travaux : il n'exerce son contrôle que sur le résultat atteint par le prestataire, résultat qu'il appréciera à la date de la livraison. Tel est l'élément majeur de la distinction entre le contrat d'entreprise et le contrat de travail.

91. a) *Si l'entrepreneur ne livre pas dans le délai,* il interdit au maître de l'ouvrage de procéder au contrôle de la qualité du travail accompli : en sorte que le manquement à l'obligation de livraison, s'il révèle d'abord que le travail n'a pas été exécuté dans le temps convenu (aspect quantitatif ou objectif de la prestation), laisse présumer aussi que l'ouvrage ne répond pas aux exigences du maître de l'ouvrage (aspect qualitatif de la prestation), puisque celui-ci n'est pas en mesure de contrôler qu'il y a été satisfait. À travers la sanction de l'obligation de livraison, c'est donc l'obligation d'exécuter le travail, dont la première n'est finalement que la réalisation, que l'on censure. Le maître de l'ouvrage peut alors obtenir la résolution du contrat (Req. 3 sept. 1940, Gaz. Pal. 1940. 2. 88), ou l'exécution de l'obligation sous astreinte assortie, le cas échéant, de dommages-intérêts pour le retard (Civ. 3e, 10 avr. 1973, Bull. civ. III, no 268, D. 1973.

IR 128), qui, dans le bâtiment et les travaux publics, prennent la forme de pénalités, c'est-à-dire, juridiquement, de clauses pénales soumises au contrôle judiciaire (ALFANDARI, Le contrôle des clauses pénales par le juge, JCP 1971. I. 2395). Bien entendu, l'entrepreneur peut justifier d'une cause légitime de retard pour se soustraire à sa responsabilité : *force majeure* (V. *supra,* n° 88), ou « exception d'inexécution » ; il est admis en effet, que le défaut de paiement par le maître de l'ouvrage permet à l'entrepreneur d'invoquer cette exception pour justifier le retard apporté à l'exécution des travaux (PLANIOL et RIPERT, *op. cit.,* n° 924 ; rappr. sur un retard imputable au maître de l'ouvrage : Civ. 3e, 4 juill. 1979, RDI 1980. 64. – Lyon, 30 nov. 1978, *ibid.* 1979. 340, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; V. *infra,* nos 368 s.).

92. En principe (C. civ., art. 1230), le retard ne peut être constaté que par une mise en demeure de livrer (PLANIOL et RIPERT, *op. cit.,* n° 924. – Civ. 6 juill. 1908, DP 1909. 1. 510 ; V. C. civ., art. 1344 s.) ; mais les parties peuvent en écarter la nécessité (C. civ., art. 1344. – Civ. 1re, 18 mai 1966, Bull. civ. I, n° 306. – Civ. 3e, 7 mars 1969, *ibid.* III, n° 208, JCP 1970. II. 16461 ; 17 nov. 1971, Bull. civ. III, n° 564. – Com. 3 nov. 1972, Gaz. Pal. 1973. 2. 533, 2e esp.), les juges disposant d'un pouvoir d'appréciation à cet égard (Civ. 3e, 18 avr. 1972, Bull. civ. III, n° 236 ; 22 avr. 1975, Bull. civ. III, n° 130) et pouvant constater une renonciation implicite des parties à l'exigence d'une mise en demeure (Com. 8 oct. 2002, n° 01-01.200, Bull. civ. IV, n° 138). Quant au délai, il doit être raisonnable, eu égard à la nature du travail exécuté (PLANIOL et RIPERT, *op. cit.,* n° 924 ; Req. 9 mai 1921, Gaz. Pal. 1921. 2. 83). Lorsque l'inexécution est acquise et qu'elle est préjudiciable au créancier, celui-ci est en droit d'obtenir des dommages-intérêts malgré l'absence de mise en demeure (Cass., ch. mixte, 6 juill. 2007, Bull. civ., n° 9, D. 2007. 2642, note Viney, JCP 2007. II. 10175, note Mekki ; comp. Civ. 1re, 22 nov. 2007, Bull. civ. I, n° 367).

93. b) *Si l'entrepreneur livre dans le délai ouvrage non achevé,* une difficulté se présente : la chose devant être livrée dans « l'état où elle se trouve » l'exécution de l'obligation de livraison n'a aucun effet libératoire pour le débiteur : celui-ci a manqué à son obligation d'exécuter le travail dans le délai convenu et le caractère déterminé de cette prestation se révèle alors au grand jour (V. *supra,* nos 71 s.). Le maître de l'ouvrage peut, comme dans le cas précédent, demander la résolution du contrat ou la condamnation du débiteur à exécuter le travail convenu. Il y a donc une évidente solidarité entre l'obligation d'exécuter le travail et celle de livrer la chose dans le délai convenu ; il est alors permis de se demander si la règle édictée par l'ancien article 1245 repris sous une autre forme par l'article 1342-5 nouveau, s'applique en matière d'entreprise : en effet, contrairement aux dispositions du texte, le locateur n'est pas libéré par la remise de l'ouvrage : tout au plus *se décharge-t-il de l'obligation de restitution* qui est l'accessoire nécessaire de celle de conserver la chose. Pour le reste, son engagement demeure, et le défaut d'achèvement peut même constituer, sauf force

majeure, une détérioration imputable au fait du débiteur au sens des articles 1245 et 1342-5 nouveaux du code civil. Il en résulte que la livraison n'éteint pas la dette et que la convention demeure : l'entrepreneur qui doit conserver la chose en bon état n'est pas *délivré* de son obligation s'il remet une chose détériorée. Cette conséquence conduit à conclure que la livraison d'une chose inachevée devrait être sans portée : ne pouvant être imposée au maître de l'ouvrage, elle ne lui est opposable que s'il y consent et s'il modifie ainsi les termes du contrat. Cette ambiguïté explique probablement que la pratique, puis la loi, qui reçoit l'appui de la doctrine, aient fait ressortir une notion distincte de la livraison, la réception qui, en matière immobilière au moins, n'exige pas l'achèvement.

94. c) *Si la livraison dans le délai porte sur un ouvrage achevé,* c'est-à-dire sur un ouvrage qui a l'apparence de la conformité et qui ne présente pas de malfaçons immédiatement décelables, l'article 1342-5 (à compter du 1er oct. 2016 ; C. civ., anc. art. 1245) peut s'appliquer. La remise de la chose libère alors l'entrepreneur. C'est elle seule et non la réception, qui produit cet effet. L'article 1245 est à la section relative au « paiement » dans le code civil, et c'est l'exécution de l'obligation conformément à son objet qui éteint la dette. La réception, à cet égard, est indifférente et l'entrepreneur peut d'ailleurs faire constater judiciairement la livraison nonobstant le refus du maître de l'ouvrage. La livraison d'une chose non achevée n'a pas grande signification en matière d'entreprise : il ne sert à rien de dire que l'entrepreneur de construction qui a construit la moitié de la maison est libéré de l'obligation de livraison s'il remet l'ouvrage dans cet état à son client, et qu'il reste tenu par ailleurs d'exécuter les autres obligations du contrat. La livraison a, de toute évidence, pour objet de mettre fin à l'*exécution matérielle* du contrat, et celle-ci n'est réalisée que si la chose remise par le débiteur au créancier est un *corps certain* (C. civ., art. 1342-545, anc. 1245), c'est-à-dire un corps *identifiable par ses qualités objectives ou définies spécialement par les parties.* À défaut, il n'y a pas de délivrance et la dette subsiste. Comme l'observe SOINNE (note sous Civ. 3e, 7 mars 1968, D. 1970. 27), lorsque l'ouvrage n'est pas achevé dans son entier au jour dit, l'obligation est définitivement et entièrement inexécutée.

95. Seule la livraison dans le délai, d'une chose achevée, est donc en mesure de décharger le débiteur. Cette libération n'est toutefois pas absolue. Elle emporte délivrance de l'entrepreneur pour ce qui est apparent, car la conformité, condition de la livraison, relève de l'apparence. La garantie des défauts de la chose lui succède alors pour ce qui est caché (BÉNABENT, note sous Civ. 1re, 5 mai 1993, D. 1993. 506 ; V. aussi GIBIRILA, *op. cit.,* no 80).

§ 4 - Obligation de renseignement et de conseil

96. On a déjà rencontré (V. *supra,* n° 63) l'obligation qui pèse sur le locateur de renseigner le client ; il suffirait de renvoyer aux indications données si, en plus du devoir général pesant sur tout locateur, celui dont le travail porte sur une chose n'assumait une obligation particulière de conseil *relativement à la chose* ou à l'opération à laquelle est soumise la chose (Com. 24 juin 1969, Bull. civ. IV, n° 242 : « le spécialiste doit conseiller son client sur les conditions d'installation et d'emploi des appareils qu'il lui fournit »). Dans ce domaine, le locateur sera traité avec plus ou moins de rigueur selon l'ignorance du client et le danger de la chose ou du travail à exécuter sur elle ; parfois, le locateur doit même se refuser à exécuter l'ouvrage commandé si son conseil n'est pas suivi (Montpellier, 12 mai 1954, D. 1954. Somm. 58 : installation de chauffe-eau).

97. Applications. - En matière de construction, le devoir de conseil pèse sur tous les locateurs d'ouvrage, mais plus spécialement sur ceux qui concourent à la *maîtrise d'œuvre* : architecte (Civ. 3e, 25 févr. 1998, n° 96-10.598, Bull. civ. III, n° 44), ingénieur-conseil, bureaux d'étude (V. *Architecte [Civ.]*). L'entrepreneur y est également tenu à des degrés variables suivant sa compétence et son rôle dans l'opération (Civ. 3e, 3 janv. 1979, Bull. civ. III, n° 1 ; 4 oct. 1978, *ibid.* III, n° 302 ; 17 juin 1997, RDI 1997. 592 ; 10 juill. 2002, n° 1232, cité *in* note sous Civ. 3e, 15 mai 2002, RDI 2002. 390, qui insiste sur l'obligation de l'entrepreneur d'informer son contractant et de *s'informer* lui-même auprès de l'architecte). C'est dans la compétence professionnelle du locateur qu'il faut en effet chercher le fondement de l'obligation (V. MALINVAUD et BOUBLI, obs. RDI 1979. 210, *ibid.* 1980. 172).

ACTUALISATION

97. Étendue du devoir de conseil et caractère averti du maître de l'ouvrage. - Le maître d'ouvrage qui connaissait l'état de grande vétusté de l'existant ne peut reprocher à l'entrepreneur intervenant pour de simples réparations de n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité de faire davantage de travaux (Civ. 3e, 28 févr. 2018, n° 17-13.478, Dalloz actualité, 22 mars 2018, obs. Garcia).

98. Plusieurs exemples de l'obligation de conseil du locateur d'ouvrage sont fournis par la jurisprudence. L'*entrepreneur de plomberie* doit s'opposer à l'utilisation d'un chauffe-eau avant les essais (Civ. 1re, 29 nov. 1961, Bull. civ. I, n° 561 ; V. aussi : Civ. 1re, 20 juin 1995, n° 93-15.801, Bull. civ. I, n° 276, pour l'installateur d'un matériau), souligner les inconvénients d'une installation sanitaire sans ventilation (Civ. 3e, 13 juin 1973, D. 1973. IR 191) ou d'appareils frigorifiques (Com. 29 oct. 1973, Bull. civ. IV, n° 296), refuser de faire des raccords dangereux à des canalisations (Rouen, 14 oct. 1971, Gaz. Pal. 1972. 1. Somm. 21) ; l'information et le conseil s'imposent qu'il y ait un maître d'œuvre (Civ. 3e, 11 févr. 1998, n° 96-12.228, Bull. civ. III, n° 30) ou qu'il n'y en ait pas (Civ. 3e, 6 mai 1998, n° 95.18.367, Bull. civ. III, n° 89), que le bâtiment soit

vieux ou neuf (Civ. 3e, 22 juill. 1998, n° 97-11.727, Bull. civ. III, n° 172) ; l'*entrepreneur de forage* ne peut laisser ignorer au client le risque d'insuccès (Civ. 1re, 7 janv. 1963, Bull. civ. I, n° 13), ni le sertisseur du danger d'une taille de pierre précieuse (Com. 2 nov. 1965, Bull. civ. III, n° 546 ; sur une clause de non-responsabilité consacrée par l'usage de la profession de diamantaire : Civ. 1re, 25 févr. 1964, Bull. civ. I, n° 111, D. 1964. Somm. 90, RTD civ. 1964. 575, obs. G. Cornu) ; ni l'entrepreneur de « métallisation » celui du procédé utilisé (Com. 13 déc. 1965, Bull. civ. III, n° 639. – Civ. 3e, 30 mai 1969, *ibid.* III, n° 443) ; le *teinturier* ne doit pas accepter sans réserves un travail sur un vêtement dont l'état ne lui paraît pas normal (Civ. 1re, 17 nov. 1965, Bull. civ. I, n° 622) ou si le traitement est aléatoire (Civ. 1re, 8 déc. 1965, *ibid.* I, n° 684) ; le locateur qui pulvérise des produits contre les termites doit prévenir son client, pâtissier-confiseur, des dangers du traitement et des précautions à prendre pour ses marchandises (Com. 28 juin 1971, Bull. civ. IV, n° 178).

99. Le *garagiste* doit d'autant mieux renseigner son client que les temps sont révolus des automobilistes mécaniciens amateurs et que « le contrat conclu avec un garagiste est un contrat de confiance » (RODIÈRE, note sous Civ. 1re, 4 févr. 1963, D. 1964. 17 ; JACK, Les obligations et la responsabilité du garagiste, RTD civ. 1932. 603). Si, à la demande de son client, il ne fait qu'une réparation provisoire ou partielle, il doit en souligner les dangers (Civ. 1re, 16 mai 1960, D. 1960. 737, note Tunc ; 3 nov. 1970, D. 1971. 226 ; 4 févr. 1963, préc.) ; il commet une faute en effectuant des réparations dépassant le prix de la voiture sans en avertir le propriétaire (Civ. 1re, 3 mai 1966, D. 1966. 649, note J. Mazeaud. – Com. 12 mai 1966, Bull. civ. III, n° 243 ; 8 juin 1968, JCP 1969. II. 15724, note Prieur. – Rouen, 18 mai 1973, D. 1973. 752, JCP 1974. II. 17867, note Gross, RTD civ. 1974. 164, obs. Cornu. – Civ. 1re, 20 juin 1979, Bull. civ. I, n° 190 ; V. Civ. 1re, 5 nov. 1996, n° 94-21.975, Bull. civ. I, n° 369, qui limite l'étendue de l'obligation d'informer du garagiste, et Civ. 1re, 2 mai 2001, CCC 2001 n° 132, note Leveneur ; plus généralement, dans le même sens pour d'autres réparateurs : Civ. 1re, 30 mars 1999, CCC 1999, n° 87, obs. Leveneur ; comp. Civ. 1re, 28 févr. 1989, Bull. civ. I, n° 102. – Com. 25 mai 1993, *ibid.* IV, n° 211). Il doit informer celui à qui il prête un véhicule de l'étendue des garanties en matière d'assurance (Civ. 1re, 25 nov. 2003, Bull. civ. I, n° 235).

§ 5 - Obligation de sécurité

100. Discussion. - Existe-t-il une obligation de sécurité à la charge de l'entrepreneur lorsque le travail porte sur une chose corporelle ? Sans aucun doute lorsque la sécurité est l'objet indéniable de l'obligation (transfusion sanguine : Civ. 1re, 12 avr. 1995, n° 92-

20.747, Bull. civ. I, n° 179 ; 14 nov. 1995, n° 92-18.199, *ibid.* I, n° 414 ; 9 juill. 1996, n° 94-18.666, *ibid.* I, n° 305), mais la tendance est alors de tenir l'organisme concerné comme le fournisseur d'un produit défectueux (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-10.007, Bull. civ. I, n° 108, RTD civ. 2000. 577, obs. Jourdain ; Civ. 1re, 13 févr. 2001, n° 99-13.589, *ibid.* I, n° 35 ; Civ. 1re, 9 mai 2001, n° 99-18.161, *ibid.* I, n° 130 ; Civ. 1re, 18 juin 2002, n° 01-00.381, *ibid.* I, n° 169 ; V. CSP, art. 1142-1, réd. L. n° 2002-303 du 4 mars 2002, préc. *supra,* n° 61). La jurisprudence tend à faire une distinction selon le moment où le dommage s'est produit. Selon un arrêt, *avant la livraison* de la chose, les seules obligations contractuelles du locateur sont relatives à la chose travaillée. « L'obligation de construire ou de réparer […] ne comporte pas en elle-même une obligation de sécurité » (Civ. 3e, 27 nov. 1970, Bull. civ. III, n° 653 ; même sens : 22 avr. 1971, *ibid.* III, n° 253). Il en résulte que les dommages causés au maître par la chose, au cours des travaux, relèvent de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité contractuelle (Civ. 3e, 19 oct. 1971, D. 1972. 77. – Paris, 20 déc. 1971, D. 1972. Somm. 108). La solution vaut pour les dommages à la personne (Civ. 2e, 4 janv. 1963, Bull. civ. II, n° 16. – Aix-en-Provence, 11 janv. 1962, D. 1962. 496, RTD civ. 1963. 92), et pour les dommages aux biens (Civ. 3e, 27 nov. 1970, 12 oct. 1971, Paris, 20 déc. 1971, préc.). Mais le principe est loin d'être convaincant (FOSSEREAU, Le « clair-obscur » de la responsabilité des constructeurs, D. 1977. Chron. 13) et lorsqu'il s'agit de travaux de rénovation dans un immeuble (V. BOUBLI, *op. cit.,* n° 201), certains arrêts semblent favorables à la responsabilité contractuelle (Civ. 1re, 3 nov. 1966, D. 1967. Somm. 29. – Civ. 3e, 21 nov. 1972, Bull. civ. III, n° 623 ; 10 juin 1976, inédit. – Civ. 1re, 22 févr. 1967, Bull. civ. I, n° 76. – Civ. 3e, 6 juin 1972, *ibid.* III, n° 366 ; 9 oct. 1991, *ibid.* III, n° 234. – Civ. 2e, 26 mai 1992, n° 91-11.149, *ibid.* II, n° 154 ; V., pour un artisan chaudronnier qui a causé des dommages à une usine de papiers avec son chalumeau, Civ. 1re, 29 mai 1996, n° 94-15.720, Bull. civ. I, n° 228, qui retient l'obligation de sécurité ; V. *infra,* n° 652).

101. *Après la livraison,* il est généralement admis que l'obligation d'exécuter l'ouvrage sans vice entraîne celle de réparer tous les dommages causés par la malfaçon. Par conséquent, une obligation de sécurité, qui n'est que le prolongement de celle d'exécuter sans défaut, pèse sur le locateur en raison du vice de la chose (pour un garagiste : Civ. 1re, 9 juin 1993, n° 91-17.387, Bull. civ. I, n° 209 ; pour une maintenance d'ascenseur : Civ. 3e, 1er avr. 2009, n° 08-10.070, Bull. civ. III, n° 71). Le principe reçoit une application dans l'entreprise de construction, notamment lorsque le maître de l'ouvrage est victime d'un préjudice corporel (Civ. 1re, 28 mai 1962, Bull. civ. I, n° 267. – Civ. 3e, 15 oct. 1970, *ibid.* III, n° 514 ; 22 févr. 1978, *ibid.* III, n° 93), encore que l'incertitude subsiste sur le fait de savoir si la responsabilité encourue emprunte son régime à la garantie décennale, à la garantie biennale, ou à la

responsabilité contractuelle de droit commun (V. B. BOUBLI, *op. cit.,* n°s 448 s. ; MALINVAUD et BOUBLI, obs. RDI 1979. 215 ; V. *infra,* n°s 602 et 653).

102. D'une façon générale, le locateur doit réparer les dommages consécutifs, c'est-à-dire ceux causés au maître par la malfaçon, à condition qu'ils en soient la conséquence directe (Civ. 1re, 5 juill. 1956, D. 1956. 719 : dépenses supplémentaires entraînées par le désordre ; 16 mai 1960, D. 1960. 737, note Tunc ; 29 nov. 1961, Bull. civ. I, n° 561 : dommages corporels à la suite d'une explosion d'un chauffe-eau électrique ; 4 févr. 1963, D. 1964. 17 ; 1re esp., note Rodière. – Com. 6 janv. 1965, Bull. civ. III, n° 14 et Lyon, 28 juin 1954, S. 1954. Chron. 103 : réparation défectueuse cause d'un accident. – Montpellier, 12 mai 1954, D. 1954. Somm. 58 ; T. civ. Sousse, 12 déc. 1956, JCP 1957. II. 9752, note R. Rodière : mauvaise installation d'un chauffe-eau ayant provoqué l'asphyxie de l'utilisateur. – Rouen, 3 nov. 1972, Jurispr. auto. 1973. 104 : réparation défectueuse cause d'un accident).

103. La limite à la réparation des conséquences du vice est fixée par l'article 1231-3 du code civil (C. civ., anc. art. 1150) : le dommage ne doit pas seulement être direct ; il doit être prévisible lors de la conclusion du contrat (Civ. 1re, 17 juill. 1963, Bull. civ. I, n° 402). Tel est le cas du montant des indemnités versées par le client au tiers victime d'un accident (Civ. 16 mai 1960, préc.), des troubles de jouissance consécutifs à des travaux de réfection (Civ. 1re, 5 juill. 1956, D. 1956. 719 ; 13 mars 1973, D. 1973. IR 98), de la dépréciation de la valeur de l'immeuble (Civ. 14 nov. 1900, DP 1901. 1. 153, S. 1902. 1. 265, note E. Naquet ; rappr. CE 5 nov. 1965, Gaz. Pal. 1966. 2. 221), ou du préjudice commercial (Rouen, 2 févr. 1971, D. 1971. Somm. 146).

Section 2 - Obligations du maître de l'ouvrage

104. Le contrat de louage d'ouvrage fait naître à la charge du maître les obligations suivantes : faciliter le travail du locateur (V. *infra,* n°s 105 s.) ; recevoir l'ouvrage (V. *infra,* n°s 110 s.) ; prendre livraison (V. *infra,* n° 114) ; payer le prix (V. *infra,* n°s 115 s.).

Art. 1er - Faciliter l'exécution de l'ouvrage

105. Obligations du maître de l'ouvrage. - Il est évident que le maître de l'ouvrage qui empêche ou rend plus difficile l'exécution de l'ouvrage par le locateur commet une faute. Ainsi, le client qui cause un dommage à l'entrepreneur en apportant au projet primitif des modifications inconsidérées provoquant des arrêts de travail et des retards

sur le chantier, commet un abus de droit dont il est responsable sur le plan extracontractuel (Civ. 3e, 22 mai 1968, D. 1970. 453, note Jestaz). Le maître commet également une faute s'il fait exécuter des travaux sans se soucier de leur coût et de ses propres disponibilités (TGI Seine, 4 févr. 1964, Gaz. Pal. 1964. 1. 411) et si le retard dans le paiement des acomptes provoque des retards sur le chantier (V. *infra,* nos 115 s.). Non seulement le client ne doit pas gêner l'exécution, mais parfois il doit la faciliter ; en effet, la simple abstention du maître peut être fautive : faciliter l'exécution des travaux suppose en effet une certaine collaboration, notamment obtenir les autorisations administratives nécessaires, renseigner l'entrepreneur sur certaines difficultés de réalisation connues du maître (Civ. 1re, 11 mai 1966, Bull. civ. I, no 281 : clients ayant omis de prévenir le teinturier d'une tentative de détachage à l'eau de javel. – Civ. 1re, 17 mars 1969, D. 1969. 532, RTD civ. 1970. 171, obs. G. Durry : présence d'un oléoduc non signalé par le maître ; T. civ. Orthez, 15 mai 1952, D. 1952. 503 : propriétaire ne prévenant pas le maréchal-ferrant que la bête est vicieuse. – Civ. 3e, 3 janv. 1980, RDI 1980. 175, obs. B. Malinvaud et P. Boubli : information du maître d'œuvre sur les limites du terrain ; V. MAZEAUD, Traité, t. 2, no 1106, note 3).

106. L'article 1790 impose au maître l'obligation de rémunérer le travail du locateur lorsque la matière fournie par le client a péri par suite d'un vice sans distinguer selon qu'il connaissait ou ignorait ce vice (Civ. 3e, 17 juill. 1972, JCP 1973. II. 17392, note P. L. ; rappr. Civ. 1re, 18 nov. 1964, Bull. civ. I, no 509. – Paris, 23 juin 1958, JCP 1959. II. 11082, note Savatier) ; encore faut-il que le vice ne soit pas apparent aux yeux d'un locateur, technicien avisé (Com. 6 janv. 1965, Bull. civ. III, no 111 ; rappr. 30 mars 1971, *ibid.* IV, no 97).

107. Lorsque plusieurs entrepreneurs de construction doivent travailler successivement sur le même chantier, le maître ou son architecte doivent organiser le planning des travaux afin de ne pas provoquer de gêne ou de retards préjudiciables aux techniciens (Civ. 3e, 9 mai 1972, D. 1972. Somm. 162 ; V. cep. Com. 28 mai 1963, Bull. civ. III, no 258 ; V. *infra,* nos 174 s. et 204 s.).

108. L'obligation de renseigner le locateur est particulièrement impérieuse dans les contrats qui supposent une étroite collaboration entre les parties : ainsi, les conseils en organisation d'entreprise ne sont en mesure d'exécuter leurs obligations que si, de leur côté, le client et son personnel leur fournissent tous les renseignements utiles sur la situation et la marche de l'affaire (Lyon, 23 déc. 1969, JCP 1970. II. 16557 ; MIALON, obs. RTD civ. 1973. 5, nos 19 à 21 ; pour la location d'ordinateurs : T. com. Paris, 19 avr. 1971, D. 1971. 482, note J. Fourgoux. – Paris, 21 juin 1971, D. 1972. Somm. 51, RTD civ. 1971. 870, obs. Cornu ; comp. Paris, 18 juin 1985, Gaz. Pal. 1986. 1. 72). De même qu'il doit renseigner, le client doit faire l'effort de comprendre le sens

juridique de l'avis qui lui est donné par un ingénieur-conseil en propriété industrielle (Paris, 21 avr. 1972, D. 1972. 570, note Savatier).

109. Obligé de renseigner le locateur, de lui faciliter la tâche, le client n'a pas cependant à s'immiscer dans les travaux. On verra, à propos du contrat d'entreprise dans la construction, que le maître engagerait sa responsabilité par son immixtion intempestive, à la condition toutefois qu'il soit notoirement compétent ; dans le cas contraire, les constructeurs doivent écarter ses suggestions ou refuser d'exécuter l'ouvrage (Rappr. Civ. 22 mai 1968, préc.).

Art. 2 - Recevoir l'ouvrage

110. Principes. - Le maître doit recevoir l'ouvrage à son achèvement. On estime, en général, que la réception est l'approbation donnée par le client aux travaux (V. Civ. 3e, 8 oct. 1974, Bull. civ. III, n° 337) et qu'elle est un acte juridique qui marque la fin du contrat, idée qui s'est répandue avec l'interprétation de l'article 1792-6 du code civil en matière de construction immobilière (V. *infra,* nos 435 s.). On enseigne également qu'elle ne doit pas être confondue avec le fait de prendre livraison ou possession de l'ouvrage (V. *infra,* n° 114). Cette analyse proposée en matière de construction immobilière, et dont l'influence sur la jurisprudence n'est pas contestable, n'appelle pas nécessairement l'adhésion. On retrouvera la théorie de la réception dans l'entreprise de construction (V. *infra,* nos 435 s.), mais d'ores et déjà, deux observations peuvent être faites ici. L'une est de pure logique : prendre livraison de la chose, n'est-ce pas la recevoir ? Et dès lors, la réception n'est-elle pas autre chose que la livraison vue du côté du créancier ? L'autre est de pur droit : on l'a vu (V. *supra,* n° 94), la livraison n'est libératoire, dans le contrat d'entreprise, que si elle porte sur une chose achevée, c'est-à-dire apparemment conforme à l'objet de l'engagement. C'est alors la livraison qui libère le débiteur et non la réception (V. sur ce point, GIBIRILA, *op. cit.,* n° 80, qui paraît approuver une opinion que nous avons toujours exprimée). La réception n'est alors rien d'autre que la vérification des travaux par le maître de l'ouvrage qui permet à la livraison d'un immeuble achevé de produire son plein effet.

111. Ce n'est donc pas l'approbation du maître de l'ouvrage qui est déterminante, sauf si ce dernier se satisfait d'une chose inachevée ou non conforme ; c'est la livraison conforme qui libère. La réception est le constat d'un fait, et la loi assigne à ce fait des conséquences qui sont celles de la livraison. Du reste, la théorie de la réception reçoit peu ou pas d'application dans le louage d'ouvrage de chose mobilière, et n'a guère eu l'occasion de manifester son utilité dans les sous-traités, même en matière immobilière.

112. Conséquences. - Il faut cependant tenir compte des conséquences communément attachées à la réception. Le maître de l'ouvrage peut exprimer son

désaccord si la chose n'est pas conforme à la convention ou aux usages ou si elle comporte des vices ; il formule alors des *réserves* auxquelles le locateur doit satisfaire. La réception produit des effets importants. Elle oblige le maître à régler le solde du prix (Civ. 3e, 15 nov. 1968, Bull. civ. III, no 475 ; V. L. no 71-584 du 16 juill. 1971, art. 2, D. 1971. 308, pour la retenue de garantie en matière de construction) ; elle opère transfert de garde (Civ. 2e, 22 avr. 1966, Bull. civ. II, no 475. – Civ. 3e, 10 déc. 1970, *ibid.* III, no 690 ; 9 mai 1972, *ibid.* III, no 293) et des risques ; elle *libère le constructeur des vices apparents,* mais non des vices cachés dont le locateur reste tenu. Encore faut-il réserver les cas où le locateur d'ouvrage ne fabrique ni ne fournit la chose, et que la garantie des vices est alors exclue (V. *supra,* no 71).

113. Exigence de l'entrepreneur. - Le locateur a le droit d'exiger la réception et peut y contraindre le maître si les travaux sont conformes à la commande et exempts de vices. S'il s'agit d'un ouvrage « à plusieurs pièces ou à la mesure », la réception peut être exigée dès l'achèvement de chaque partie (C. civ., art. 1791 : le texte dit « vérification »). Les juges du fond sont souverains pour apprécier si le maître a reçu et approuvé les travaux, le paiement ou même la prise de possession pouvant constituer une présomption d'approbation ; l'article 1791 précise que le paiement d'acomptes, dans le cas d'ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, fait présumer la « vérification » des parties payées si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait, mais il ne s'agit que d'une présomption simple (V. en ce sens : J. CARBONNIER, obs. RTD civ. 1958. 272). Sur la réception en matière immobilière, V. *infra,* nos 433 s.

Art. 3 - Prendre livraison

114. Distinction. - Le maître doit prendre livraison de la chose à l'époque fixée. À notre avis, la « prise de livraison » et la réception sont une seule et même chose (V. *supra,* nos 110 s. et *infra,* nos 433 s.) : la réception n'est rien d'autre que la livraison vue du côté du créancier. Mais la doctrine dominante réservant à la réception un rôle particulier dans le contrat d'entreprise immobilière, elle fait de la livraison une obligation distincte de celle-là. L'obligation de livraison est sanctionnée de façon particulière s'il s'agit d'objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés, qui n'ont pas été retirés dans le délai d'un an, délai réduit à six mois pour les véhicules automobiles : la loi du 31 décembre 1903 modifiée par celle no 68-1248 du 31 décembre 1968 (D. 1969. 40) permet à l'entrepreneur de se faire autoriser par le juge d'instance à vendre ces objets aux enchères publiques et à se faire payer sur le prix.

Art. 4 - Payer le prix

115. Le maître de l'ouvrage *doit payer le prix* (sur la fixation du prix, V. *supra,* n°s 46 s.). Le paiement du prix intervient en principe à la livraison, mais les acomptes peuvent être versés en cours d'exécution, le solde étant remis à l'achèvement des travaux (sur les acomptes et la retenue de garantie dans le contrat de construction immobilière, V. *infra,* n°s 408 s.). Le retard du maître dans le paiement entraîne, sauf clause pénale, l'allocation des intérêts légaux. Toutefois, l'entrepreneur peut obtenir des dommages-intérêts supplémentaires s'il subit un préjudice indépendant du retard (par ex., arrêt de chantier : Civ. 3e, 24 juin 1971, Bull. civ. III, n° 408 ; 9 oct. 1973, Gaz. Pal. 1973. 2. Pan. 265), et si le maître est de mauvaise foi (Civ. 3e, 9 oct. 1973, préc. ; rappr. Civ. 1re, 17 juin 1968, Bull. civ. I, n° 174), conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil (sur les applications en matière de construction, V. *infra,* n°s 407 et 410).

116. *L'action en paiement* du prix est une *action mobilière* même si les travaux sont immobiliers. Le contrat peut valablement comporter une clause de prorogation de compétence au profit du tribunal de commerce (Com. 11 juin 1968, Bull. civ. IV, n° 185 ; 24 mars 1969, *ibid.* IV, n° 114). En plus de l'action oblique et de la saisie-arrêt (désormais saisie-attribution), le locateur bénéficie de plusieurs sûretés : privilège spécial sur meubles, si le travail a contribué à la conservation d'un objet mobilier (V. pour le réparateur d'automobile : Civ. 1re, 13 nov. 1962, JCP 1963. II. 12976 ; V. *Privilèges mobiliers spéciaux [Civ.]*), privilège immobilier, en matière de construction immobilière (C. civ., art. 2103-4° ; V. *Privilèges immobiliers [Civ.]*) ; droit de rétention (par ex. Com. 11 juin 1969, D. 1970. 244, note P. Bihr : garagiste ; entreprise de construction) ; ce droit serait perdu si le locateur faisait des réparations importantes sans prévenir le maître (Civ. 1re, 3 mai 1966, D. 1966. 649, note J. Mazeaud). *La créance se prescrit désormais par cinq ans* (C. civ., art. 2224 ; sur l'action des ouvriers du locateur contre le maître, V. *infra,* n°s 376 s.).

Section 3 - Responsabilité

117. Le locateur a l'obligation de réparer le dommage causé au maître par l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. La responsabilité est encourue en cas de manquement à l'une des obligations mises à la charge de l'entrepreneur. Il suffit de se reporter à ce qui a déjà été dit à ce sujet.

118. Lorsqu'il s'agit d'un *louage d'ouvrage s'appliquant aux choses,* une distinction est à faire suivant que la réparation est demandée avant ou après la réception des travaux. Avant la réception, la logique voudrait que la seule obligation du locateur susceptible d'être censurée fût l'obligation de livrer la chose dans le délai. Avant l'échéance en effet, le maître de l'ouvrage s'interdit toute immixtion dans la réalisation de l'ouvrage : il ne peut donc, en principe, opérer aucun contrôle. En revanche, à l'échéance, si la livraison

n'a pas lieu, le locateur répond de l'entier dommage qu'il cause, le préjudice pouvant aller du simple retard à l'inexécution pure et simple de l'engagement. Cette logique n'est cependant pas toujours vérifiée dans la pratique. Dans l'entreprise de construction notamment, le maître de l'ouvrage peut, sans pour autant empiéter sur la tâche de l'entrepreneur, constater que les travaux en cours ne correspondent pas à ce qui a été convenu. Il peut alors mettre le locateur en demeure de respecter l'engagement convenu, ou tout simplement demander la résolution du contrat.

119. Après la réception, le maître ayant exercé son droit de contrôle, la responsabilité du locateur est encourue à certaines conditions. Aucune difficulté particulière n'est à signaler en ce qui concerne le *retard* dans la livraison : le locateur s'expose le plus souvent à des dommages-intérêts qui peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une fixation forfaitaire et prendre la forme de pénalités de retard (V. *supra,* n° 115 et *infra,* n°s 403 s., dans l'entreprise de construction). Il n'y a pas de problème non plus lorsque le dommage allégué procède du manquement par le locateur à son *obligation de conseil* : tantôt la réparation du dommage est soumise au régime de la garantie des vices de la chose, tantôt elle relève du droit commun de la responsabilité contractuelle. En revanche, un régime de responsabilité propre à l'entreprise concerne *les défauts de la chose.* Une distinction est à faire suivant que le défaut est caché (V. *infra,* n°s 122 s.) ou non (V. *infra,* n°s 120 s.) à la date de la réception.

Art. 1er - Défauts apparents

120. Distinction. - Il est d'usage de distinguer les défauts de conformité des malfaçons. La malfaçon est un vice de la chose, tandis que le défaut de conformité est simplement la manifestation d'une différence entre ce qui a été convenu et ce qui est réalisé. La distinction est faite, notamment, dans l'entreprise de construction, où l'on peut envisager un régime de responsabilité différent suivant la nature du défaut. Elle a moins de raison d'être dans les autres cas de louage d'ouvrage où il n'existe pas de garantie s'appliquant spécialement aux vices de la chose.

121. Si l'ouvrage présente un défaut, le maître peut le refuser : il peut alors exiger la remise en état, sinon la réfection totale de l'ouvrage, ou abandonner la chose au locateur : c'est le « laissé-pour-compte » (Civ. 3e, 6 juin 1969, Bull. civ. III, n° 455). Seuls les défauts d'une certaine gravité permettent au maître d'agir de la sorte : un pourcentage de « loupés » est admis selon certains usages professionnels (T. com. Paris, 2 mars 1970, Journ. agréés 1971. 94 ; rappr. Civ. 3e, 7 nov. 1973, Bull. civ. III, n° 572). Le laissé-pour-compte entraîne-t-il automatiquement résolution du contrat de louage d'ouvrage aux torts du locateur ? On peut le penser, bien qu'en cette matière, il faille se livrer à une recherche de la volonté des parties. Outre la réfection de l'ouvrage

ou la pratique du laissé-pour-compte, le maître de l'ouvrage peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du retard et de la perte de la matière lorsque c'est lui qui l'a fournie.

Art. 2 - Défauts cachés

122. Absence de réserves. - S'il reçoit l'ouvrage sans exprimer de réserves, le maître ne peut réclamer la réparation du dommage procédant d'un défaut alors apparent (Civ. 3e, 22 oct. 1974, Bull. civ. III, n° 369). Mais l'ouvrage peut présenter des défauts indécelables au moment de la réception. En matière de construction, il existe une garantie légale des vices cachés (C. civ., art. 1792 s.). Mais aucun texte ne consacre une telle garantie dans l'entreprise de chose mobilière. À s'en tenir à l'idée que la réception est un acte juridique, on devrait décider qu'elle marque la fin du contrat, et que l'approbation donnée par le maître de l'ouvrage décharge l'entrepreneur de toute obligation. Cette attitude a bien entendu quelque chose d'excessif ; aussi, la doctrine prend-elle des libertés avec la notion de réception-acte juridique et estime que le maître de l'ouvrage conserve une *garantie pour les vices cachés de la chose,* nonobstant l'absence de texte la consacrant dans le louage d'ouvrage portant sur une chose mobilière (AUBRY et RAU, t. 5, par ESMEIN, § 374, texte et note 29 *ter* ; RODIÈRE, *op. cit.,* nos 191 et 207, note sous Civ. 4 janv. 1958, D. 1958. 457 ; GROSS, La notion d'obligation dans le droit des contrats, thèse, Nancy, 1963 ; J. CARBONNIER, obs. RTD civ. 1958. 272 ; J. BORRICAND, Observations sur le marché à forfait, D. 1965. Chron. 105 et spéc. 109 ; R. SAINT-ALARY, La vente d'immeubles à construire et l'obligation de garantie à raison des vices de construction, JCP 1968. I. 2146, n° 61 ; *contra* : BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, t. 2, n° 3946 ; ROUAST, *op. cit.,* n° 928 *bis*) et la jurisprudence est dans le même sens (Civ. 1re, 16 mai 1960, D. 1960. 737, note A. Tunc ; 4 févr. 1963, 1re esp., D. 1964. 17, note R. Rodière : réfection d'une malfaçon à un travail sur une automobile. – Civ. 3e, 30 mai 1969, Bull. civ. III, n° 443 : corrosion d'un appareil métallique après métallisation. – Civ. 1re, 3 nov. 1970, D. 1971. 226 : mauvaise réparation sur une automobile).

123. Aléa. - On considère que la réception, qui n'est pas un acte aléatoire, n'est un *quitus* que dans la mesure de ce qui est connu du client ; on ne renonce « qu'à ce que l'on doit savoir » (CARBONNIER, obs. préc.). On hésite toutefois sur le fondement à donner à cette responsabilité : est-ce une garantie des vices cachés ou une responsabilité contractuelle fondée sur la violation de l'obligation de résultat (cas du garagiste qui répare : Civ. 1re, 2 févr. 1994, n° 91-18.764, Bull. civ. I, n° 41 ; 20 juin 1995, n° 93-16.381, Bull. civ. I, n° 263 ; 8 déc. 1998, n° 94-11.848, *ibid.* I, n° 343 ; rappr. Civ. 1re, 7 juin 1995, n° 93-14.916, Bull. civ. I, n° 235, qui tient compte de l'acceptation des risques par le client). La jurisprudence subit sans doute l'influence du

régime appliqué aux constructeurs (Civ. 1re, 4 janv. 1958, Bull. civ. I, no 10 ; 25 janv. 1960, *ibid.* I, no 50 : règles générales de la responsabilité contractuelle ; 19 oct. 1964, D. 1965. 161 : art. 1641 s. – Com. 30 mars 1971, D. 1971. Somm. 136 ; Req. 26 mars 1941, S. 1941. 1. 100. – Civ. 1re, 25 oct. 1967, D. 1968. 104 ; 9 oct. 1973, D. 1973. Somm. 158 : art. 2270, mais dans ces dernières espèces, les travaux se rapprochent des ouvrages de construction ; c'est la responsabilité contractuelle qui est retenue dans la sous-traitance, V. *infra,* nos 307 s. – Civ. 14 déc. 1964, D. 1965. 409, note Plancqueel ; 28 nov. 1969, Bull. civ. III, no 776 ; comp. *supra,* no 71).

124. Pouvoirs du juge. - Les juges du fond sont souverains pour décider si le vice est apparent ou caché (Civ. 2e, 19 mai 1958, JCP 1958. II. 10808, note Starck ; V. SAINT-ALARY, article préc., JCP 1968. I. 2146, no 61). Sauf pour les travaux de construction, où les délais de garantie sont fixés par les articles 1792 et suivants, la jurisprudence exigeait, par emprunt aux règles de la vente (ancien art. 1648 du code civil), que l'action du maître fut exercée dans un *bref délai de la découverte du vice,* la brièveté du délai étant appréciée souverainement par les juges (Civ. 1re, 25 janv. 1960, préc. ; 8 nov. 1960, Bull. civ. I, no 479 ; 19 oct. 1964, préc.) ; mais l'ordonnance du 17 février 2005 a modifié l'article 1648 du code civil qui prévoit désormais que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce texte s'applique-t-il à l'entreprise de chose mobilière ? La solution ainsi dégagée en cas de *vice caché* vaut-elle lorsque l'ouvrage présente *un défaut de conformité,* non décelable à la réception ? La jurisprudence paraît lier la conformité à la délivrance et applique les règles du droit commun (V. *infra,* nos 559 et 657). Une distinction est parfois faite selon que la matière est fournie par le maître de l'ouvrage ou par l'entrepreneur. Dans le premier cas, l'entrepreneur ne répond pas des vices qui affecteraient déjà la chose remise (Civ. 1re, 24 oct. 1995, no 93-19.695, Bull. civ. I, no 376), mais il peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil (Civ. 1re, 16 févr. 1999, RJDA 4/1999, no 401). Dans le second cas, il répond des vices cachés de la chose fournie ou façonnée par lui (B. GROSS, La notion d'obligation de garantie dans les contrats, 1964, LGDJ, no 28). Mais, ainsi qu'il a été dit (V. *supra,* no 123), dans ce cas, la jurisprudence paraît plutôt favorable à la sanction de l'obligation de résultat (V. en particulier, Rouen, 8 nov. 1995, JCP 1996. IV. 2037, qui écarte le droit commun de la garantie des vices). Par ailleurs, les dispositions de l'ancien article L. 211-1 du code de la consommation [art. L. 217-1 nouv.] instituant une garantie de conformité à la charge du vendeur ne semblent pas devoir s'appliquer à l'entrepreneur de chose mobilière.

125. Délai. - L'article L. 4411-7 du code du travail accorde à l'acheteur un délai d'un an à compter de la livraison pour demander la résolution de la vente avec dommages-intérêts, si la chose est un instrument dangereux pour la sécurité des travailleurs. Les textes du code du travail ne distinguent pas entre les vices cachés et les vices

apparents. Les dispositions, qui visent l'exposition, la mise en vente et la location, doivent être étendues au louage d'ouvrage, en raison du but de la loi. Lorsque l'ouvrage présente des malfaçons, la garantie des vices couvre-t-elle les *conséquences de ces malfaçons* et notamment le dommage causé par la chose ? Malgré des réserves (MALINVAUD et BOUBLI, obs. RDI 1979. 215), la tendance est d'admettre l'existence d'une obligation de sécurité dans le contrat d'entreprise, qui se manifeste essentiellement après la livraison de l'ouvrage (V. *supra,* n° 101).

Section 4 - Risques

126. Charge. - Lorsque l'exécution du travail est rendue impossible par un événement de force majeure, qui, du maître ou du locateur, supportera les conséquences du cas fortuit ? Pour qui sont les risques ? L'article 1196 nouveau du code civil, précise que le transfert de propriété entraîne le transfert de la charge des risques avec les nuances qu'il prévoit. Dans le contrat d'entreprise les règles sont particulières : les risques sont relatifs à l'exécution du contrat et à la chose elle-même lorsque le travail est exécuté sur une chose dont la matière a été fournie par l'ouvrier ou par le maître. Les articles 1788 et suivants gouvernent ce sujet. La convention des parties peut d'ailleurs modifier l'attribution des risques, les règles légales n'étant pas d'ordre public (Req. 8 janv. 1906, DP 1906. 1. 262. – Civ. 1re, 25 févr. 1964, D. 1964. Somm. 90, RTD civ. 1964. 575, obs. Cornu).

127. a) La force majeure rendant impossible l'*exécution du travail,* même au sens du nouvel article 1218, alinéa 1er, il faut déterminer si le maître demeure tenu d'en payer le prix ou si l'ouvrier subira les conséquences de l'événement. Les articles 1788 et 1790, faisant application de la théorie générale des risques, décident que le locateur n'aura droit à aucune rémunération, que la matière ait été fournie par l'un ou l'autre des contractants ; sa situation est donc sur ce point moins favorable que celle du salarié ; elle est, dit-on, la contrepartie de son indépendance (V. *supra,* nos 12 s.). L'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité (Civ. 3e, 27 janv. 1976, Bull. civ. III, n° 34 ; 19 févr. 1986, *ibid.* III, n° 10, RDI 1986. 362, obs. Malinvaud et B. Boubli, RTD civ. 1986. 607, obs. Rémy). Il ne semble pas que le nouvel article 1196 du code civil, remette en cause cette solution. La force majeure n'interdit parfois que partiellement l'exécution : le maître sera-t-il tenu de recevoir et rémunérer le travail partiel ? L'article 1791 répond affirmativement, mais seulement pour les ouvrages « à plusieurs pièces ou à la mesure ». En dehors de cette hypothèse, il paraît difficile d'imposer au client un ouvrage inachevé ; l'article 1722, texte exceptionnel, est sans application en matière de louage d'ouvrage (MAZEAUD, Leçons, t. 2, n° 1110 ; rappr. Civ. 1re, 21 juill. 1964, Bull. civ. I, n° 405, Gaz. Pal. 1964. 2. 384).

128. Encore faut-il, pour que le locateur supporte les risques, d'une part, que le maître ne soit pas responsable de l'événement qui interdit l'exécution (art. 1790. – Civ. 3e, 17 juill. 1972, JCP 1973. II. 17392, note P. L. : matériaux de fabrication trop récente fournis par le client), d'autre part, que le maître ne soit pas en demeure de vérifier ou de prendre livraison (art. 1788 et 1790. – Civ. 22 févr. 1897, DP 1901. 1. 75).

129. b) Les articles 1788 et 1789 attribuent les *risques de la chose* sur laquelle est effectué le travail et dont la perte résulte de la force majeure. Si l'ouvrier fournit la matière, « la perte en est pour l'ouvrier » (art. 1788. – Civ. 3e, 14 juin 1983, Bull. civ. III, no 138) tant que l'ouvrage n'a pas été reçu (ROUAST, *op. cit.,* no 926. – Civ. 3e, 19 févr. 1986, Bull. civ. III, no 10), que la matière ait été ou non choisie par le maître (en ce sens, BAUDRY-LACANTINERIE, t. 2, no 3904). Cette perte s'entend des salaires et rémunérations (Civ. 3e, 19 févr. 1986, préc. *supra,* no 127) et de la valeur des matériaux fournis car, selon P. RÉMY, ce n'est pas la règle *res perit domino* qui est ici à appliquer ; ce sont les pouvoirs de l'entrepreneur qui fondent le principe (obs. préc. *supra,* no 127). L'entrepreneur s'expose même à une action résolutoire avec restitution des acomptes versés (Civ. 3e, 27 janv. 1976, Bull. civ. III, no 34) et à dédommager le maître de l'ouvrage pour la perte totale ou partielle de l'ouvrage sur lequel il travaillait (Civ. 3e, 27 mars 1991, D. 1991. IR 113 ✎). Lorsque la perte survient après la réception ou la mise en demeure de recevoir, les risques passent au maître qui devra payer le prix prévu (art. 1788) ; la réception partielle d'un « ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure » ayant les effets d'une réception complète quant aux parties reçues (art. 1791). Ces principes s'appliquent à tous les marchés d'entreprise, même, sauf discussion, aux marchés relatifs à la construction. L'article 1788 ne s'applique pas lorsque la perte de la chose ne procède pas de la force majeure et que le problème posé est seulement de savoir quel est le contractant qui en est responsable (Civ. 1re, 2 déc. 1997, no 95-19.466 ⚙, Bull. civ. I, no 339). L'offre de l'entrepreneur, qui supporte la charge des risques, de rembourser le coût de la construction ou de reconstruire l'ouvrage, a un caractère satisfactoire (Civ. 3e, 28 oct. 1992, no 90-16.726 ⚙, Bull. civ. III, no 2817 ; sur les conséquences de la charge des risques à l'égard de l'assureur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage : Civ. 3e, 27 mars 1991, no 89-19.498 ⚙, Bull. civ. III, no 103. – Civ. 1re, 3 nov. 1993, no 90-18.876 ⚙, *ibid.* I, no 309 ; 9 nov. 1999, no 97-16.306 ⚙, *ibid.* I, no 293, Gaz. Pal. 2000. 1. somm. 257, obs. Peisse : absence de recours contre l'entrepreneur). L'article 1196 nouveau qui prévoit que le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose, peut-il modifier cette jurisprudence ? Cela reste peu probable.

130. Si la matière est fournie par le maître, la perte en est pour celui-ci, sauf faute du locateur ou si ce dernier était en demeure de livrer l'ouvrage (art. 1789). L'entrepreneur n'est tenu que de sa faute. Il importe peu que la matière fournie par le maître soit un corps certain ou une chose fongible : remise à l'ouvrier par le maître, elle est considérée

comme un corps certain (Paris, 17 juill. 1946, D. 1948. 169, note Weill). C'est en principe à l'entrepreneur tenu de l'opération de restituer, de faire la preuve de l'absence de faute (Civ. 1re, 17 oct. 1963, Bull. civ. I, n° 412 ; 9 févr. 1966, *ibid.* I, n° 103. – Civ. 1re, 24 mars 1987, Bull. civ. I, n° 106. – Civ. 3e, 17 févr. 1999, n° 95-21.018, *ibid.* III, n° 41. – Civ. 1re, 20 déc. 1993, n° 92-11.385, *ibid.* I, n° 376 ; V. Req. 19 mars 1886, DP 1886. 1. 409 ; comp. Civ. 1re, 12 oct. 1971, Bull. civ. I, n° 482 ; 14 mai 1991, n° 89-20.999, *ibid.* I, n° 153 ; rappr. Civ. 3e, 24 mars 1993, RDI 1993. 376 ; sur les risques dans l'opération de construction, V. *infra,* nos 446 s.). Lorsque la cause de la perte ou de la détérioration de la chose est inconnue, l'entrepreneur n'établit pas l'absence de faute, et il est responsable (Civ. 1re, 14 mai 1991, préc.). Mais l'absence de faute est établie lorsque les mesures de prévention d'un incendie criminel ont été prises (Civ. 1re, 24 mars 1993, Gaz. Pal. 1994. 1. somm. 113, obs. Peisse).

Chapitre 4 - Fin du contrat

131. Il existe plusieurs causes de fin du contrat comme la nullité (V. *infra,* nos 132 s.), la résolution (V. *infra,* nos 134 s.), le décès de l'entrepreneur (V. *infra,* n° 136). Dans le cadre d'un marché à forfait il y a une possibilité de résiliation unilatérale (V. *infra,* nos 137 s.).

Section 1re - Nullité

132. Nullité ou caducité. - Les nullités du contrat d'entreprise sont celles de droit commun. La convention serait nulle de nullité absolue si elle était contraire à une règle d'ordre public, par exemple si elle portait sur une chose dont la fabrication est interdite (V. C. trav., art. L. 233-5 à L. 233-6 nouv. : relatifs aux instruments et machines dangereux pour les travailleurs ; rappr. Civ. 1re, 23 janv. 1961, Bull. civ. I, n° 51 ; POTHIER, n° 396) ou si l'exercice de la profession était interdit au locateur. L'article L. 324-10 du code du travail répute clandestin l'exercice à titre lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou l'accomplissement d'actes de commerce, par toute personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité (sur le travail clandestin, V. *Travail dissimulé [Trav.]* ; sur les principes de prévention applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, V. L. n° 93-1418 du 31 déc. 1993, D. 1994. 75 ; C. trav., art. L. 235-19 s., L. 4535-1).

133. Les nouvelles dispositions du code civil confirment la distinction entre la nullité absolue et la nullité relative (C. civ., nouv. art. 1178) et prévoient la *caducité du contrat* si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Dans quel cas le contrat d'entreprise peut-il être affecté dans un élément essentiel au point de devenir caduc ? L'avenir le dira.

Section 2 - Résolution

134. Exception d'inexécution. - L'inexécution des obligations par l'un ou l'autre des contractants peut entraîner le jeu de l'exception *non adimpleti contractus* ou exception d'inexécution (C. civ., nouv. art. 1219) ou la résolution du contrat (C. civ., nouv. art. 1224 s.). Cette résolution peut résulter d'une clause résolutoire ou être judiciaire. Dans ce dernier cas, le nouvel article 1228 du code civil peut donner lieu à une difficulté d'interprétation. Alors que la résolution judiciaire peut être assortie de dommages-intérêts, sous l'empire des textes modifiés (anc. art. 1184), il semble désormais que le juge peut prononcer la résolution, ordonner l'exécution du contrat en accordant un délai au débiteur « ou allouer seulement des dommages-intérêts ». Les retards dans le paiement des acomptes par le maître peuvent justifier l'une ou l'autre de ces sanctions, mais il ne suffirait pas, pour que le locateur arrête ses travaux, qu'il ait seulement des doutes sur la solvabilité du client (Req. 22 oct. 1894, DP 1895. 1. 252). La résolution pourrait être prononcée aux torts de l'entrepreneur, par exemple, dans l'hypothèse où le retard dans les paiements proviendrait du refus du Crédit foncier de régler les échéances du prêt consenti au maître, en raison des malfaçons constatées (Civ. 7 nov. 1973, Klein, inédit). Le client est en droit de ne payer le solde du prix que si les réfections nécessaires ont été opérées (Civ. 1re, 15 juin 1966, Bull. civ. I, n° 364. – Civ. 3e, 15 nov. 1968, *ibid.* III, n° 475 ; V. sur les retenues de garantie dans la construction, L. n° 71-584 du 16 juill. 1971, D. 1971. 308 ; V. *infra,* nos 357 s.) ; il demandera la résolution si l'objet n'est pas conforme à la commande (V. *supra,* nos 87 s.), ou en raison de retards dans l'exécution (Req. 3 sept. 1940, Gaz. Pal. 1940. 2. 88 ; sur la résolution dans les marchés de construction, V. normes AFNOR p. 03-001 et p. 03-011 ; V. *infra,* n° 241).

135. Dommages-intérêts. - Sous réserve de ce qui vient d'être dit à propos du nouvel article 1228 du code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il subit (Com. 12 juin 1967, Bull. civ. III, n° 239). Mais si la résolution est prononcée aux torts des deux contractants, les juges peuvent refuser toute indemnité (Civ. 3e, 15 mai 1974, Bull. civ. III, n° 195). Des arrêts se fondant sur les principes de l'enrichissement sans cause admettent le locateur, contre qui la résolution est prononcée, à demander paiement des frais engagés par lui, dans la mesure où ils ont été utiles au maître (Civ. 1re, 21 juill.

1964, Bull. civ. I, n° 105, Gaz. Pal. 1964. 2. 384 : contrat d'impression à compte d'auteur ; rappr. Civ. 3e, 12 mars 1969, Bull. civ. III, n° 220) ; il est en effet équitable que le maître de l'ouvrage, qui a obtenu la résolution du marché à l'encontre de l'entrepreneur, règle cependant le montant des ouvrages qui lui sont utiles et qu'il entend conserver (Civ. 3e, 8 mai 1969, Bull. civ. III, n° 366). Plus généralement, si le marché est un contrat *à exécution successive* (art. 1791 : « à la pièce ou à la mesure »), la résolution n'opérant qu'à dater de l'inexécution (V. MARTY et RAYNAUD, t. 2, 1er vol., n° 303 ; MAZEAUD, Leçons, t. 2, nos 1101 et 1103), le locateur aura droit à rémunération pour les travaux antérieurs (Civ. 1re, 1er juill. 1963, Bull. civ. I, n° 355 : l'arrêt considère un marché de construction comme un contrat à exécution successive ; rappr. Civ. 3e, 8 mai 1969, préc.). La résolution étant rétroactive, il a été jugé que la clause d'indexation stipulée au marché était inapplicable (Civ. 3e, 15 mai 1974, préc.), mais cette solution ne saurait être admise pour un marché à exécution successive.

Section 3 - Décès de l'entrepreneur

136. Le contrat de louage d'ouvrage, même lorsque le locateur est autorisé à ne pas exécuter lui-même les travaux, demeure, au moins dans une certaine mesure, un contrat conclu *intuitu personae,* l'entrepreneur devant conserver la responsabilité des travaux. Aussi, aux termes de l'article 1795, qui n'est pas d'ordre public, la mort du locateur éteint-elle le louage d'ouvrage, alors même que les héritiers de l'entrepreneur exerceraient la même profession ; la norme AFNOR p. 03-011, article 19-7, préconise au contraire la continuation des travaux par les ayants droit du défunt, à condition qu'ils présentent les qualifications requises. Le maître comme les héritiers du locateur peuvent invoquer la règle de l'article 1795 ; cette disposition s'applique à tout contrat de louage d'ouvrage, aux marchés directs comme aux sous-traités. La règle ne semble concerner que l'entrepreneur qui exploite à titre personnel et non la société. La seule dissolution de celle-ci, y compris en cas de mort de l'un de ses dirigeants, ne semble pas concernée (réserve faite des entreprises unipersonnelles). Il a néanmoins été jugé que la liquidation judiciaire de l'entrepreneur emporte résiliation du contrat d'entreprise (Civ. 1re, 3 mars 1998, n° 95-10.293, Bull. civ. I, n° 83, Defrénois 1998. 1461, obs. Bénabent). Sauf si les héritiers préfèrent conserver l'ouvrage inachevé quand la matière est leur propriété, ils sont en droit de réclamer au maître, en proportion du prix prévu, la valeur des travaux exécutés et des matériaux préparés, mais seulement s'ils lui sont utiles (art. 1796). Le décès du maître ne met pas fin au louage d'ouvrage (BÉHARD-TOUCHAIS, Le décès du contractant, thèse, Paris, 1988, Economica).

Section 4 - Résiliation unilatérale du marché à forfait

137. Aux termes de l'article 1794, le maître de l'ouvrage peut résilier le *marché à forfait* par sa seule volonté en dehors de toute faute du locateur (Civ. 3e, 6 févr. 1973, Bull. civ. III, n° 100 ; sur la définition du marché à forfait et le régime applicable en matière de construction, V. *infra,* nos 278 s.) C'est une dérogation aux règles du droit commun, dérogation d'ailleurs plus apparente que réelle étant donné les conditions auxquelles ce texte soumet la résiliation. Celle-ci ne peut être demandée que par le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 10 mai 1972, Bull. civ. III, n° 298), et si elle est limitée au *marché à forfait* (Civ. 1re, 13 janv. 1958, Bull. civ. I, n° 28 ; en ce sens : ROUAST, *op. cit.,* n° 937 ; *contra* : AUBRY et RAU, t. 5, § 374-1°, texte et note 12), il importe peu que ce dernier concerne ou non des travaux immobiliers (Civ. 5 janv. 1897, DP 1897. 1. 89, concl. av. gén. Desjardins, note Planiol : construction de machines à vapeur. – TGI Seine, 29 févr. 1960, Gaz. Pal. 1960. 2. 230). Des arrêts ont cependant refusé l'exercice de cette faculté à propos d'un marché de sous-traitance (Paris, 26 nov. 1891, DP 1895. 1. 81 ; 23 mai 1961, D. 1962. Somm. 17, RTD civ. 1962. 130, obs. G. Cornu : agence de voyages ; V. MALAURIE et AYNÈS, par GAUTHIER, *op. cit.,* n° 738). La résiliation peut être demandée à tout moment, même avant le commencement des travaux (T. com. Seine, 17 juin 1949, Gaz. Pal. 1949. 2. 246. – Paris, 28 juill. 1949, *ibid.* 1949. 2. 427), et quel que soit leur degré d'avancement, dès lors du moins que les travaux n'ont pas atteint un état d'achèvement suffisant pour permettre de considérer que l'entrepreneur a exécuté ses obligations (Civ. 3e, 18 févr. 1976, Bull. civ. III, n° 69). Si la résiliation est demandée, l'entrepreneur peut prendre, aux frais du maître de l'ouvrage, des mesures de protection de l'ouvrage (Req. 3 févr. 1851, DP 1851. 1. 52). La faculté de résiliation cesse à partir du moment où le maître de l'ouvrage est mis en demeure de recevoir ou de prendre livraison (Civ. 27 juill. 1914, S. 1914. 1. Somm. 110), et même, semble-t-il, dès lors que l'ouvrage est achevé.

138. La résiliation de l'article 1794 n'est pas fondée sur la faute du locateur ; elle résulte de la seule volonté du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 6 févr. 1973, Bull. civ. III, n° 100). Elle oblige ce dernier à dédommager « l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise » (art. 1794), ce qui correspond à la réparation intégrale du préjudice compte tenu du manque à gagner. Les « dépenses » peuvent comprendre les frais d'installation du matériel (*contra :* Bordeaux, 16 mars 1908, DP 1909. 2. 206, mais l'arrêt tient compte moins de l'article 1794 que du caractère à exécution successive du contrat), sauf si cette installation a été faite à l'insu du maître de l'ouvrage et contrairement aux conditions du marché (Com. 22 févr. 1961, Bull. civ. III, n° 101). Certaines décisions ont même inclus le préjudice moral dans le dommage réparable (T. civ. Dax, 29 déc. 1887, Gaz. Pal. 1888. 1. 558). L'indemnisation peut résulter de la convention qui institue alors une faculté de dédit (V. *infra,* n° 282). Le maître de l'ouvrage qui exerce la faculté de résiliation unilatérale n'est pas privé de la possibilité de se prévaloir du manquement de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles (Civ. 3e, 9 mars 1988, Bull. civ. III,

n° 55) ; on peut penser qu'il s'agit d'une règle générale reprise dans le contrat de sous-traitance par la loi du 31 décembre 1975 : le sous-traitant non accepté, dont le contrat qui le lie à l'entrepreneur principal est irrégulier, reste tenu des vices affectant les ouvrages dont il a reçu ou réclame le paiement (Civ. 3e, 13 avr. 1988, Bull. civ. III, nos 72 et 73. – Civ. 3e, 3 juin 1992, n° 89-19.724, RDI 1992. 330). La dérogation apportée au droit commun par l'article 1794 est donc de peu d'importance. L'article 1794 ne confère pas au maître le droit de suspendre la confection de l'ouvrage (Civ. 27 juill. 1914, préc.).

139. On admet que la faculté de l'article 1794 est un droit personnel qui appartient aux héritiers, mais ne peut être exercé par les créanciers (ROUAST, *op. cit.,* n° 937). L'article 1794 n'étant pas d'ordre public, le maître peut renoncer à la faculté de résiliation, de même que le locateur peut renoncer à toute indemnité en cas de résiliation unilatérale (PIC, note DP 1895. 1. 81 ; ROUAST, *op.* et *loc. cit.*).

Titre 2 - Règles particulières au contrat d'entreprise dans la construction immobilière

140. La section « Des devis et marchés » du chapitre 3, consacré au louage d'ouvrage et d'industrie, dans le code civil, comporte, à côté de dispositions applicables à toute espèce de louage d'ouvrage, des règles propres au contrat d'entreprise dans la construction immobilière. Elles sont, pour la plupart, inscrites dans les articles 1792 et suivants qui tiennent compte de la réforme issue de la loi du 4 janvier 1978 déjà citée, dont les dispositions ont été modifiées par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 et par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. L'étude qui va suivre tentera de préciser ces règles : on examinera, dans un chapitre 1er, la construction de l'ouvrage (V. *infra,* nos 141 s.), puis on étudiera les opérations qui accompagnent l'achèvement (V. *infra,* nos 386 s.), avant de dégager les responsabilités (V. *infra,* nos 513 s.).

Chapitre 1er - Construction de l'ouvrage

141. Le contrat relatif à la construction d'un ouvrage immobilier est complexe. Il Implique souvent un montage de l'opération, le cas échéant avec l'assistance de prestataires divers (V. *infra,* nos 142 s.), et les parties au contrat peuvent être multiples (V. *infra,* nos 147 s.). Il faut distinguer les marchés privés de travaux immobiliers

(V. *infra,* n°s 150 s.) et de la procédure de cession de marché, sous-traitance ou d'action directe (V. *infra,* n°s 249 s.).

Section 1re - Montage de l'opération

142. Plusieurs formules sont concevables qui dépendent de l'importance du programme et de la nature des ouvrages à réaliser. Une distinction est à faire entre deux formules, celle dite « ensemblier » (V. *infra,* n°s 143 s.) et celle de « maître d'œuvre » (V. *infra,* n°s 152 s.).

Art. 1er - Formule « ensemblier »

143. La formule « ensemblier » est la plus simple et la plus répandue (V. *infra,* n°s 144 s.). Des règles spécifiques sont relatives aux contrats de construction individuelle (V. *infra,* n°s 147 s.) et aux contrats de promotion immobilière (V. *infra,* n°s 150 s.).

§ 1er - Cas général

144. Dans le cadre de cette formule, le maître de l'ouvrage s'adresse directement à un constructeur, qui prend en charge l'ensemble de l'opération et s'oblige à livrer l'ouvrage « clés en mains ». La formule « ensemblier » en usage dans certains marchés publics est sensiblement remise en cause dans ces contrats avec le principe de l'allotissement. On la rencontre encore dans la vente, et notamment dans la vente de locaux industriels. Elle est plus difficilement adaptable au contrat d'entreprise en raison du monopole architectural (V. *Architecte [Civ.]*). Avant la réforme du 3 janvier 1977 conférant à l'architecte le monopole de la conception des ouvrages dont la surface de plancher « hors œuvre nette » dépasse 170 m^2 (V. *Architecte [Civ.]*), le maître de l'ouvrage pouvait s'adresser à un bureau d'études techniques qui prenait en charge l'ensemble des travaux, sauf à sous-traiter ceux qu'il n'était pas en mesure de réaliser lui-même. La formule « ensemblier » s'appliquait parfaitement. Depuis la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (D. 1977. 71) son intérêt est moindre.

145. Pour les *constructions relevant du monopole architectural,* la consultation de l'architecte ne peut pas, en principe, être évitée : on ne peut donc plus, comme par le passé, s'adresser directement à un bureau d'études. La question est posée, toutefois,

de savoir si le maître de l'ouvrage peut encore demander à une société d'architecture pluridisciplinaire de prendre en charge l'ensemble de l'opération. Pour répondre par l'affirmative, il faut reconnaître à cette société le droit de procéder à la conception et à la réalisation de l'ouvrage, option qui est possible dans le marché public de « conception-réalisation ». Or, l'architecte exerce, de manière générale, la fonction de maître d'œuvre, et il est admis que les professions d'architecte et d'entrepreneur sont distinctes (V. *Architecte [Civ.]*) ; mais les dispositions du code de devoirs professionnels issues du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 (D. 1980. 162) semblent moins draconiennes que celles de l'ancien texte, et la réponse à la question de savoir si une société d'architecture peut être composée à la fois de concepteurs et de réalisateurs est à cet égard déterminante (V. *Architecte [Civ.]*). Le marché public de « conception-réalisation », comme sa dénomination l'indique, n'exclut pas qu'un même contrat puisse confier à un prestataire la maîtrise d'œuvre et la réalisation de l'ouvrage. Enfin, certaines pratiques en vigueur dans le CCMI donnent à penser qu'en ce cas au moins la formule ensemblier est concevable alors même que l'ouvrage relève du monopole architectural (V. *infra,* n° 147).

146. Pour les *constructions ne relevant pas du monopole architectural,* il est possible de confier à un « ensemblier » le soin de mener l'opération à terme ; il en sera ainsi, notamment, lorsque le maître de l'ouvrage consultera directement un entrepreneur qu'il chargera de la conception et de la réalisation de l'ouvrage (travaux non soumis à permis de construire : piscine par exemple, SHON <170 m^2). Toutefois, lorsque l'ouvrage est soumis à autorisation de construire, il est difficile, en pratique, d'échapper à la conclusion d'un contrat réglementé au sens de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 (D. 1991. 23, rect. 485) sur le contrat de construction de maison individuelle, dans le secteur de l'habitation et du logement (V. *Contrat de construction d'une maison individuelle [Civ.]* et *infra,* n° 147).

§ 2 - Construction de maison individuelle

147. La formule « ensemblier » connaît son application la plus courante dans le contrat de construction de maison individuelle, puisque sans représentation, le constructeur prend toute l'opération en charge. Le contrat doit répondre aux conditions, autrefois posées par l'article 45 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée par la loi n° 72-649 du 11 juillet 1972 (D. 1972. 372) et contenues désormais dans la loi du 19 décembre 1990 (CCH, art. L. 230-1 s.). À défaut, il doit être conclu un contrat de promotion immobilière ou, éventuellement, une vente en l'état futur si le constructeur procure le terrain sans fournir les plans.

148. La loi du 19 décembre 1990 institue deux contrats réglementés relatifs à la construction d'une maison individuelle : avec fourniture de plan (CCH, art. L. 231-

1 s.) et sans fourniture de plan (art. L. 232-1). Le contrat de construction de maison individuelle devient un passage quasi obligé lorsque le maître de l'ouvrage entend faire édifier un immeuble à usage mixte ou à usage d'habitation, comportant au maximum deux logements. La conséquence en est que le contrat de construction de maison est incontestablement un louage d'ouvrage plus ou moins réglementé selon qu'il y a ou non fourniture de plan (V. B. BOUBLI, article préc., ALD 1991. 165, n° 4 ; MALINVAUD, JESTAZ, par JOURDAIN et TOURNAFOND, *op. cit.,* nos 595 s. ; V. déjà Crim. 20 déc. 1978, Bull. crim. n° 361).

149. La réglementation était destinée à atteindre les industriels en maisons préfabriquées, les opérateurs qui les placent ou font construire selon des plans types, et les constructeurs qui proposent des plans dressés par leurs correspondants ou leur adressent le client (MALINVAUD, JESTAZ, par JOURDAIN et TOURNAFOND, *op. cit.,* nos 571 s. ; GIVERDON, Les contrats relatifs à la construction de maisons individuelles, Gaz. Pal. 1972. 2. Doctr. 546 ; LANCEREAU, Le statut des constructeurs de maisons individuelles, Mon. TP 3 févr. 1973 ; MEYSSON et TIRARD, La réglementation des contrats portant sur la construction de maisons individuelles, JCP 1973. 1. 2579 ; V. égal. Dalloz-Action Droit de la construction 2014-2015, nos 220-10 s.). Les termes de la loi, dans sa rédaction de 1971, n'étaient cependant pas assez restrictifs. On s'est donc longtemps demandé si le contrat réglementé s'imposait dans tous les cas ou seulement pour les constructions selon un modèle type proposé par le constructeur. La loi de 1990 qui réglemente à présent le contrat sans fourniture de plan ne lève pas toutes les ambiguïtés sur ce point. Elle fait du prestataire qui fournit les plans un constructeur s'obligeant selon la formule « ensemblier », et du constructeur (entrepreneur), qui ne fournit pas les plans, un prestataire assujetti à une réglementation obligatoire, sans pour autant que la formule « ensemblier » soit toujours possible : si, dans le contrat avec fourniture de plan, le constructeur tient implicitement de la loi le pouvoir de sous-traiter la maîtrise d'œuvre, puisqu'il fournit les plans, dans le contrat sans fourniture de plan, cette faculté paraît limitée lorsque la construction doit dépasser 170 m^2, car alors le concours de l'architecte est obligatoire, et la mission relevant du monopole doit en principe lui être confiée par le maître de l'ouvrage (V. *Contrat de construction d'une maison individuelle [Civ.]*).

§ 3 - Contrat de promotion immobilière

150. Plutôt que de prendre la responsabilité du choix des constructeurs, de traiter avec eux, de procéder à toutes les opérations juridiques, administratives et financières nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, ou tout simplement pour éviter d'avoir à établir le *programme* (sur cette mission, V. *Architecte [Civ.]*), le maître de l'ouvrage peut contracter avec un promoteur immobilier (V. *Promotion immobilière [Civ.]*). Le contrat de promotion immobilière est « un mandat mélangé de louage d'ouvrage »

(MALINVAUD, JESTAZ, par JOURDAIN et TOURNAFOND, *op. cit.,* n° 663. – V. sur la nature de ce contrat : Dalloz-Action, Droit de la construction 2014-2015, nos 230-60 s.) ; le promoteur immobilier est donc un ensemblier qui agit aussi par représentation, ce qui en fait un prestataire à part. La loi du 4 janvier 1978 soumet le promoteur immobilier au régime de la garantie due par le locateur d'ouvrage : V. not. BOUBLI, *op. cit.,* n° 298). Le promoteur est investi d'un mandat d'intérêt commun (Civ. 3e, 8 mars 1977, JCP 1978. II. 18945, note Meysson, Gaz. Pal. 1977. 2. 421, note Peisse ; V. *supra,* n° 27) ; il se charge notamment de faire édifier les ouvrages dont certains peuvent même être exécutés par ses soins s'il est entrepreneur. Il se comporte alors, pour ces travaux, en locateur d'ouvrage, et il est responsable en cette qualité (C. civ. art. 1831-1, al. 2). S'il se contente d'agir comme mandataire, il est *garant* de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité (art. 1831-1), et il « est tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil ».

151. Cette rigueur est destinée à protéger le maître de l'ouvrage qui recourt à un intermédiaire. Aussi, la conclusion d'une convention de promotion immobilière répondant aux exigences de la loi s'impose-t-elle, lorsqu'une « personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un *immeuble d'habitation* ou d'un immeuble à *usage professionnel et d'habitation,* en une qualité autre que celle de vendeur ou que celles qui sont visées au 3° de l'article 1779 du code civil » (il s'agit des locateurs d'ouvrage ; L. n° 71-579 du 16 juill. 1971, préc. ; CCH, art. L. 221-1 s.). Des dérogations sont toutefois prévues aux articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de la construction et de l'habitation. En outre, si les conditions en sont remplies, le maître de l'ouvrage peut conclure un contrat de construction de maison individuelle qui peut être plus favorable pour lui. Il est probable que le contrat de promotion immobilière est la forme la plus sophistiquée, dans les opérations de droit privé, de la *maîtrise d'ouvrage déléguée* qui est souvent de règle dans les marchés publics et qui s'est développée dans les marchés privés à la faveur de programmes importants, ou du financement de la construction par le crédit-bail immobilier (V. *infra,* nos 158 s.).

Art. 2 - Formule « maître d'œuvre »

152. La formule la plus classique, sinon la plus banale, est celle qui consiste, pour le maître de l'ouvrage, à contracter avec différents locateurs d'ouvrage, parmi lesquels on trouve au moins, d'une part, le *maître d'œuvre,* c'est-à-dire le plus souvent l'architecte (d'où la qualification de la formule empruntée au langage de l'ingénierie), d'autre part, l'*entrepreneur* et enfin, lorsque la loi l'impose, le *contrôleur technique.* Le maître de l'ouvrage contracte séparément avec chacun de ces prestataires qui n'ont entre eux aucun lien de droit. Le nombre des contractants peut se multiplier, notamment lorsque les représentants de chaque corps de métier s'engagent directement envers le maître

de l'ouvrage. Cette convergence vers le maître fait penser à un « éventail ». Le nombre des contractants peut également être limité sans pour autant que celui des personnes qui concourent effectivement à la réalisation de l'ouvrage le soit : il en est ainsi lorsque le maître d'œuvre, et plus fréquemment l'entrepreneur, sous-traitent une partie du marché (V. BOUBLI, *op. cit.,* n°s 11 et 12). Les deux techniques peuvent coexister dans la formule « maître d'œuvre » qui associe la « cotraitance » et la « sous-traitance » (V. *infra,* n°s 312 s.). Il est possible aussi de diminuer le nombre des contrats liant le maître de l'ouvrage aux constructeurs sans pour autant limiter le nombre des prestataires directement liés au maître de l'ouvrage ; les entreprises peuvent, en effet, se constituer en un groupement momentané d'entreprises (GME) qui désigne un mandataire commun et l'architecte, notamment depuis la loi n° 2012-387 du 3 mars 2012 qui a modifié l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977, peut également constituer un groupement momentané avec les prestataires qui concourent à la maîtrise d'œuvre.

Section 2 - Parties au contrat d'entreprise

153. Les parties au contrat sont le maître de l'ouvrage (V. *infra,* n°s 154 s.) et les constructeurs (V. *infra,* n°s 166 s.).

Art. 1er - Maître de l'ouvrage

154. Le maître de l'ouvrage est la personne « pour le compte de qui les travaux sont exécutés » (norme AFNOR p. 03-001 de déc. 2000, art. 3.1.9 ; V. *infra,* n°s 155 s.) ; il est possible de déléguer la maîtrise de l'ouvrage (V. *infra,* n°s 158 s.). Il faut aussi rappeler quelles sont ses prérogatives (V. *infra,* n°s 162 s.) et obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé (V. *infra,* n°s 165 s.).

§ 1er - Définition

155. Éléments. - La définition donnée mérite d'être corrigée en tenant compte des circonstances de fait propres à chaque opération ; mais si l'on s'en tient aux principes applicables au louage d'ouvrage (V. *supra,* n° 22), le maître de l'ouvrage est en principe le propriétaire du terrain ou le titulaire du droit de construire ; c'est lui qui fait édifier, au moyen de louages d'ouvrage, la construction à laquelle il donnera la destination qu'il désire. Le maître de l'ouvrage est, sociologiquement, celui qui détient le *pouvoir économique* dans l'opération de construction. « Le centre du pouvoir s'est déplacé de

l'architecte au maître de l'ouvrage » (Proposition pour une réforme de l'assurance construction. Rapport SPINETTA, du nom de son inspirateur, La documentation française, 1975, p. 22) ; il est le *destinataire immédiat* de l'ouvrage et, à ce titre, il harmonise l'action des différents intervenants et répond de certains de ses choix, notamment envers ses ayants cause. Il doit respecter la réglementation applicable à la construction et en particulier veiller à ce que l'organisation du chantier soit conforme aux règles imposées par la loi sous peine de sanction pénale. À ce titre, il répond de la sécurité du chantier dans des conditions qui restent ambigües car, en général, il désigne un prestataire en qualité de coordonnateur ; mais la désignation d'un coordonnateur ne modifiant ni la nature, ni l'étendue de la responsabilité incombant à chacun des participants (C. trav., art. L. 4532-6), la portée de cette désignation reste incertaine. La Cour de cassation estime, en effet, que le louage d'ouvrage, dont le contrat de coordination est une application, n'emporte pas délégation de pouvoirs (Crim. 12 déc. 1989, RJS 1/1990, n° 36) et un arrêt a retenu la responsabilité civile du maître de l'ouvrage qui n'a pas déclaré au coordonnateur, la présence d'un artisan sur le chantier (Civ. 3e, 17 juin 2015, n° 14-13.350 , BPIM 4/15, inf. 248).

ACTUALISATION

155, 512. Défaut de déclaration de l'activité de construction de maison individuelle. - Le défaut de déclaration de l'activité de construction de maison individuelle prive le maître de l'ouvrage de ses demandes en garantie formées à l'encontre de l'assureur de la société de construction, laquelle avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes (Civ. 3e, 26 sept. 2018, n° 17-23.741, Dalloz actualité, 12 nov. 2018, obs. R. Bigot).

156. Droit de construire. - Le maître d'ouvrage s'entend, non seulement de celui qui possède un droit réel sur le terrain (usufruitier, preneur d'un bail à construction), mais aussi de celui qui possède un simple droit de créance. Ainsi, le *locataire* d'une maison ou d'un appartement qui commande des travaux n'agit pas, en principe, pour le compte du propriétaire, et il est débiteur du prix des ouvrages (CASTON et MONTMERLE, Passation et exécution des marchés de travaux privés, 1979, Le Moniteur, n° 96 ; pour une application : Civ. 3e, 4 mars 1980, JCP 1980. IV. 195). Ce n'est pas la *nature* du droit que le client possède sur la chose qui importe, mais son *étendue* : a-t-il ou non le droit de construire ? S'il l'a, la qualité de maître de l'ouvrage doit lui être reconnue, ne serait-ce qu'au titre de l'apparence. Toutefois, un arrêt dénie au locataire la qualité de maître de l'ouvrage qu'il réserve au propriétaire pour l'exercice de l'action en garantie décennale (Civ. 3e, 1er juill. 2009, n° 08-14.714 , RDI 2009. 539, obs. L. Tranchant , RDI 2009. 547, obs. Malinvaud et Leguay , RTD com. 2009. 801, obs. Bouloc) ; il s'agit d'une regrettable confusion : s'il est concevable que l'action en garantie soit un attribut de la propriété, la qualité de maître de l'ouvrage procède du seul louage d'ouvrage : l'un (l'entrepreneur), loue son « ouvrage » ; l'autre en est le maître. Il est vrai

qu'il n'est pas toujours facile de savoir pour le compte de qui les travaux sont exécutés, et que c'est le constructeur qui, le plus souvent, invoque l'apparence. Il semble alors qu'il ait l'obligation de s'informer de la qualité de celui qui commande les travaux, au moins lorsque ceux-ci revêtent une certaine importance.

157. Distinction. - Le maître de l'ouvrage ne doit pas être confondu avec le promoteur immobilier. Le promoteur immobilier peut certes s'identifier au maître de l'ouvrage : il en est ainsi lorsqu'une société de promotion commercialise les ouvrages qu'elle fait construire. Le promoteur est alors à la fois maître d'ouvrage et vendeur, et c'est en l'une ou l'autre de ces qualités qu'il doit être pris. Plus souvent, le promoteur immobilier, et c'est alors que la qualification se justifiera, *représentera* le maître de l'ouvrage, et parfois même cumulera cette mission de représentation et la qualité de locateur d'ouvrage ; il en sera ainsi du contrat de promotion immobilière conclu avec un constructeur prenant en charge une partie du programme (sur la notion de maître de l'ouvrage et sa responsabilité, V. RDI 2002. 441 s.).

§ 2 - Maître d'ouvrage délégué

158. Notion. - Le maître d'ouvrage peut déléguer ses pouvoirs et les confier à un tiers. La maîtrise d'ouvrage déléguée est réglementée dans les marchés publics (L. n° 85-704 du 12 juill. 1985 ; le nouveau régime issu de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, se réfèrent à la loi de 1985). Elle obéit au droit commun du mandat dans les marchés privés (V. pour un syndic de copropriété, retenu en qualité de maître d'ouvrage et non de maître d'ouvrage délégué : Civ. 3e, 12 mai 2004, n° 02-17.793 , Bull. civ. III, n° 94). L'architecte peut être désigné en qualité de maître d'ouvrage délégué (Civ. 3e, 2 mai 2010, n° 08-20.544, Bull. civ. III, n° 92). La maîtrise d'ouvrage déléguée donne lieu en principe à un accord exprès ; elle peut, cependant, résulter d'un mandat apparent (Civ. 3e, 12 janv. 2005, n° 03-17.668 , BPIM 2/05, inf. 121. – Civ. 3e, 12 sept. 2006, n° 05-18.927. – Civ. 3e, 12 mai 2010, n° 08-20.544 , Bull. civ. III, n° 92, préc.). Lorsque la construction relève du secteur protégé pour lequel il faut conclure un contrat de promotion immobilière, la maîtrise d'ouvrage déléguée doit se couler dans le moule du contrat de promotion immobilière. Il est d'usage d'avoir recours à la maîtrise d'ouvrage déléguée lorsque la construction est financée par un crédit-bail. Le crédit-bailleur propriétaire du sol est le maître de l'ouvrage, et il délègue ses pouvoirs au crédit-preneur auquel l'ouvrage est destiné. Il appartient au maître d'ouvrage délégué d'exécuter loyalement son mandat : la résiliation de celui-ci à son initiative pour des motifs fallacieux présente un caractère abusif (Civ. 3e, 27 sept. 2000, BPIM janv. 2001, n° 25). Si la délégation n'est pas consentie dans le respect des dispositions contractuelles, les risques de la construction restent à la charge du crédit-bailleur (Civ. 3e, 13 sept. 2006, n° 04-20.729 , RJDA

12/06, n° 1260). Le maître d'ouvrage délégué ne peut, en principe, agir en garantie décennale (Civ. 3e, 27 mai 1999, BPIM 4/99, inf. 292. – V. toutefois : Civ. 3e, 16 mai 2001, n° 99-19.085) ; mais s'il reçoit mandat du maître de l'ouvrage d'agir en justice et de percevoir les indemnités pour les affecter aux réparations, son action est recevable (Civ. 3e, 24 oct. 2007, n° 06-16.504 ; comp. pour les marchés publics : Civ. 3e, 28 janv. 2009, n° 07-20.891, RDI 2009. 254, obs. Malinvaud, D. 2009. 2008, obs. D. Houtcieff, D. 2010. 224, obs. S. Amrani Mekki, RTD civ. 2009. 317, obs. B. Fages).

159. Obligations du délégué. - La maîtrise d'ouvrage déléguée *oblige le mandant* envers les tiers pour les actes accomplis en cours de mandat et dans la limite des pouvoirs délégués (Civ. 1re, 8 nov. 1994, n° 93-12.426, Bull. civ. I, n° 324. – Civ. 3e, 15 avr. 1980, *ibid.* III, n° 73 ; 2 oct. 2002, n° 01-01.783, Bull. civ. III, n° 201). Le maître de l'ouvrage doit alors exécuter les engagements souscrits par le maître d'ouvrage délégué (Civ. 3e, 23 nov. 2005, n° 04-17.737. – Civ. 3e, 21 févr. 2006, n° 05-11.959, RDI 2006. 212). Il est généralement admis que le maître de l'ouvrage délégué peut exercer l'action en responsabilité contre les constructeurs (Civ. 3e, 16 mai 2001, n° 99-19.085, BPIM 4/01, inf. 253) et qu'il peut procéder au paiement des entreprises, la prise en charge définitive du coût du marché par le maître de l'ouvrage intervenant lors de la reddition des comptes ; l'absence de stipulation expresse est difficile à déterminer : il a été jugé que le paiement effectué sans 'accord préalable du maître de l'ouvrage sur le montant de la rémunération d'un tiers ne lie pas le mandant (Civ. 3e, 22 mai 1997, BPIM avr. 1997, n° 251). Un arrêt a même estimé que l'entrepreneur lié à forfait ne peut réclamer au crédit-bailleur le prix de travaux supplémentaires exécutés sur la foi d'une autorisation écrite du crédit-preneur pourtant maître d'ouvrage délégué (Civ. 3e, 19 juill. 2000, BPIM 6/00 inf. 367). Nonobstant le mandat, le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité personnelle dans certains cas, sans préjudice d'un appel en garantie de celui qu'il a délégué en particulier lorsque ce dernier commet une faute constitutive d'un manquement à une obligation à laquelle le maître de l'ouvrage est personnellement tenu : ainsi, lorsque le maître d'ouvrage délégué n'a pas veillé au respect des dispositions de l'article 14-1, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, il a été jugé que le maître de l'ouvrage doit en en assumer les conséquences (Versailles, 10 déc. 1993, RDI 1994. 250 ; V. *infra,* n° 160).

160. Obligations du déléguant. - Le maître d'ouvrage délégué *engage également sa responsabilité personnelle.* À l'égard des *tiers,* cette responsabilité est délictuelle (Civ. 1re, 11 avr. 1995, RTD civ. 1995. 887, obs. Jourdain ; 13 oct. 1992, n° 91-10.619, Bull. civ. I, n° 250. – Civ. 3e, 6 juill. 2010, n° 09-12.323, BPIM 5/10, inf. 365) : ainsi le sous-traitant peut se prévaloir de sa faute s'il n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de remplir les formalités de présentation (Civ. 3e, 6 janv. 1999,

n° 96-18.690 Bull. civ. III, n° 3. – Civ. 3e, 12 janv. 2005, n° 03-17.668, BPIM 2/05, inf. 121, à propos d'un délégué « apparent »). Le maître d'ouvrage délégué engage également sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage selon les règles du mandat (C. civ, art. 1992) ; il répond de ses fautes : ainsi en est-il lorsqu'il procède au paiement des sous-traitants sans s'assurer que les garanties principales à la charge de l'entrepreneur principal sont constituées (Civ. 3e, 6 juill. 2010, n° 09-12.323, BPIM 5/10, inf. 365) ; cette responsabilité ne fait guère de doute lorsque le mandat transfère l'obligation de contrôler la sous-traitance (Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 07-21.198. – Civ. 3e, 6 juill. 2010, n° 09-12.323, BPIM 5/10, inf. 365, préc.) ; la jurisprudence est plus nuancée en l'absence d'une telle clause (V. *supra,* n° 159)… Lorsqu'il est promoteur immobilier (C. civ., art. 1831-1) ou lorsqu'il accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage (C. civ., art. 1792-1, 3°, qui vise le mandat teinté de louage d'ouvrage sans pour autant constituer un contrat de promotion immobilière), le maître d'ouvrage délégué peut engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, et de l'article 1792-3 du même code.

161. Sans déléguer l'ensemble de ses pouvoirs, le maître de l'ouvrage peut donner *mandat* à un constructeur, et en particulier au maître d'œuvre, d'accomplir certains actes (V. *Architecte [Civ.]*). Le mandat doit être spécial et précis, car le maître d'œuvre, l'architecte en particulier, est un locateur d'ouvrage qui n'a pas vocation à être de plein droit le mandataire du maître de l'ouvrage (Civ. 1re, 21 janv. 1963, Bull. civ. I, n° 41).

§ 3 - Prérogatives

162. Marché. - Le maître de l'ouvrage est une personne de droit privé ou de droit public. Dans les marchés privés, seuls étudiés ici, le maître de l'ouvrage est en principe une personne de droit privé. Mais une personne publique peut également conclure un marché de travaux privés ne présentant pas les caractères d'un contrat administratif. Il en est ainsi lorsque l'objet du contrat n'est pas un travail public et que le contrat ne comporte pas des clauses exorbitantes du droit commun. Les sociétés de construction, civiles ou commerciales, et les sociétés d'économie mixte sont des personnes de droit privé. Toutefois, les marchés des organismes d'HLM ou des SEM sont soumis à la procédure réglementaire applicable aux marchés publics. Il incombe au maître de l'ouvrage d'élaborer le programme en déterminant les contraintes et les exigences qui s'attachent à la réalisation du projet. C'est lui qui passe le marché.

163. Programme. - Le maître de l'ouvrage *compétent* peut procéder lui-même à l'élaboration du programme. Il le fera en particulier lorsqu'il est un véritable professionnel ou un investisseur institutionnel qualifié en matière de construction, et aussi lorsqu'il a la qualité de maître d'ouvrage public, qui recourt à une mission

d'ingénierie, par exemple. Les réformes issues de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (D. 1985. 401), des décrets du 14 mars 1986 (Décr. n° 86-520, D. 1986. 335 et Décr. n° 86-666, JO 20 mars) et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 (D. 1993. 557) remplacent les dispositions relatives à l'ingénierie (Décr. n° 73-207 du 28 févr. 1973, D. 1973. 141) qui obligeaient le maître de l'ouvrage à dire ce qu'il voulait, et à en définir le cadre financier. Pour utiliser des expressions qui se sont longtemps maintenues et qui sont édifiantes, le maître d'ouvrage doit dégager les *données,* les *besoins,* les *contraintes* et les *exigences,* ce qui correspond aux éléments d'un programme. Il engage sa responsabilité s'il commet des erreurs dommageables dans l'établissement du programme.

164. Assistance d'un tiers. - Le maître d'ouvrage, *qui n'a pas la compétence nécessaire* pour établir seul le programme, peut recourir à un spécialiste qui sera soit un bureau d'études ou un architecte (V. sur ce point, *Architecte*), soit un promoteur immobilier. Le maître de l'ouvrage a intérêt à confier à un spécialiste le soin d'établir le programme. À défaut, il court le risque d'engager sa responsabilité personnelle (Civ. 3e, 5 avr. 1995, n° 93-12.511, Bull. civ. V, n° 97, RDI 1995. 551, obs. Malinvaud et Boubli, RDI 1995. 553, obs. Malinvaud et Boubli, RDI 1995. 596, obs. Capoulade et Giverdon, D. 1998. 276, note Capoulade), en particulier s'il accepte une « offre anormalement basse », notion qui, pour relever du droit des marchés publics, a vocation à s'appliquer à tous les contrats. Plus généralement, sa responsabilité est encourue s'il apparaît en cours d'exécution que le programme est trop ambitieux (Civ. 19 févr. 1971, Rev. adm. 1971. 284, obs. G. Liet-Veaux), que le choix d'une solution trop économique a été fait en connaissance de cause (Civ. 3e, 20 déc. 1971, Bull. civ. III, n° 647 ; 10 avr. 1975, D. 1975. IR 155), ou que les incidents du terrain n'ont pas été portés à la connaissance du constructeur (Civ. 1re, 17 mars 1969, D. 1969. 532. – Civ. 3e, 12 janv. 1978, Bull. civ. III, n° 34. – Reims, 13 févr. 1978, JCP 1979. IV. 341), obligation particulièrement sévère pour les ouvrages enterrés (Décr. n° 91-1147 du 4 oct. 1991, art. 4), alors même qu'un maître d'œuvre est constitué (Civ. 3e, 20 nov. 2013, n° 13-10.279, BPIM 1/14, inf. 20 ; plus généralement sur la concordance entre le programme et le projet, V. Civ. 2e, 4 juin 1998, Jur. Lamy AGECA, cité par HUET, Le rôle du maître de l'ouvrage dans la définition du programme, RDI 2002. 442). Il faut rattacher cette responsabilité à la compétence du maître de l'ouvrage et non à la circonstance que le programme a été établi par ses soins. En effet, les locateurs ne doivent s'engager qu'après avoir pris les précautions d'usage, s'être informés et avoir éclairé le client sur les conditions et les possibilités de réalisation du projet (BOUBLI, *op. cit.,* n° 112 ; V. spéc. Civ. 3e, 9 déc. 1992, n° 91-10.195, Bull. civ. III, n° 318, RDI 1993. 222, RDI 993. 226). Mais il est vrai que la jurisprudence, sur les incidents de terrain notamment, paraît mettre à la charge du maître de l'ouvrage une *obligation générale de renseignement,* et la responsabilité qu'il encourt à ce titre peut être regardée comme une extension de la notion d'immixtion fautive (B. BOUBLI, *op.* et *loc.*

cit. ; V. MALINVAUD et BOUBLI, obs. RDI 1979. 71 et 1980. 66 et 174 ; V. *supra,* n°s 105 s. ; V. Civ. 3e, 16 juill. 1987, Mon. TP 12 févr. 1988 ; 15 juin 1988, JCP 1988. IV. 297 ; 21 févr. 1990, Gaz. Pal. 1990. 2. Somm. 623, obs. M. Peisse ; V. *infra,* n°s 608 s.).

§ 4 - Lutte contre le travail dissimulé

165. Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la loi (C. trav., art. L. 8221-1 s.) fait obligation au donneur d'ouvrage de s'assurer que son contractant s'est exécuté de ses obligations au regard des articles L. 8221-3, L. 8222-4 et L. 8221-5 du code du travail lorsque le contrat porte sur une obligation d'au moins 5 000 euros. Des dérogations sont prévues en faveur des particuliers qui contractent pour leur usage personnel ou celui de leur famille. Les justifications demandées varient selon que l'entrepreneur est établi ou domicilié en France (C. trav., art. D. 8222-5), avec des souplesses pour les particuliers, ou qu'il ne l'est pas (C. trav., art. D. 8222-6), avec la même solution pour les particuliers (C. trav., art. D. 8222-4).

Art. 2 - Constructeurs

166. Dans la formule la plus classique, c'est-à-dire la formule maître d'œuvre (V. *supra,* n° 152), le maître de l'ouvrage contracte séparément avec chaque constructeur (V. *infra,* n°s 167 s.). Mais il est possible de concilier cette cotraitance avec une sous-traitance, ainsi qu'on va le voir en distinguant les différents intervenants à l'acte de construire, comme l'entrepreneur (V. *infra,* n°s 172 s.) mais aussi l'organe de contrôle technique de la construction (V. *infra,* n°s 233 s.).

§ 1er - Personnes qui concourent à la maîtrise d'œuvre

167. Ensemble de missions. - La maîtrise d'œuvre est un ensemble de missions. Elle comprend trois étapes : la conception de l'œuvre, la direction et la surveillance des travaux et l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception. Un préalable, que l'on peut rattacher à la conception réside dans l'établissement du dossier de permis de construire. Ces missions relèvent tout naturellement de la compétence de l'architecte ; l'étude de la maîtrise d'œuvre est présentée dans ce recueil, *V^{o} Architecte.* Elles peuvent aussi être ventilées entre plusieurs prestataires qui ont des compétences techniques différentes. Il est en général préférable de préserver l'*unité de la maîtrise d'œuvre* et d'opter pour un « processus simple », comme le suggérait le décret n° 73-

207 du 28 février 1973 sur l'ingénierie (D. 1973. 141). L'*architecte* est alors le mieux désigné : d'une part, il est le maître d'œuvre type, d'autre part, son concours est obligatoire pour les constructions soumises à autorisation de construire. L'architecte peut prendre en charge l'ensemble des missions sans concours extérieurs : il existe à présent des sociétés d'architecture pluri-disciplinaires ayant cette vocation. L'architecte peut également s'obliger en même temps que d'autres techniciens rassemblés avec lui en un groupement ayant ou non une structure juridique propre (L. n° 77-2 du 3 janv. 1977, art. 3 mod. par L. n° 2012-387 du 22 mars 2012) : mandataire du groupe, il est lié, comme chacun des prestataires, par un contrat de louage d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage ; c'est un cas type de *cotraitance.* L'architecte peut enfin s'engager à assurer la maîtrise d'œuvre, sans pour autant exécuter personnellement toutes les missions : le code des devoirs professionnels (Décr. n° 80-217 du 20 mars 1980, D. 1980. 159) l'autorise à *sous-traiter* les missions qui ne relèvent pas du monopole architectural (V. *Architecte [Civ.]*).

168. Les exigences du programme contraignent parfois le maître de l'ouvrage à *ventiler les missions entre différents prestataires.* On est alors en présence d'un « processus composé », le client contractant séparément avec chacun des prestataires qui n'ont entre eux aucun lien de droit. L'architecte et les autres techniciens sont liés au maître de l'ouvrage par des contrats de louage d'ouvrage distincts (C. civ., art. 1779-3° et 1792-1, al. 1er).

169. Participants. - Les techniciens qui concourent avec l'architecte à la maîtrise d'œuvre, et appelés parfois « techniciens d'études » pour les distinguer des organismes chargés du contrôle technique (AUBY et PÉRINET-MARQUET, Droit de l'urbanisme et de la construction, 19e éd., 2012, Montchrestien, n° 1192), sont d'abord les *ingénieurs-conseils* ou les *bureaux d'études techniques.* Ils interviennent dans des domaines divers : calculs de résistance de béton, d'isolation thermique ou phonique, installation de chauffage, de ventilation, d'ascenseurs, étude des sols (Civ. 3e, 20 juin 1979, Bull. civ. III, n° 139). Leur rémunération résulte de l'accord des parties (Civ. 3e, 4 juin 2008, n° 07-14.665). Les services d'assistance technique aux usagers comme, par exemple, le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) qui est financé par des cotisations des entreprises, ne doivent pas excéder leur mission d'assistance. S'ils le font, ils sont assimilés à un bureau d'études (Civ. 3e, 21 juin 2000, BPIM 5/00, n° 319).

170. Sont également des techniciens qui s'obligent par des louages d'ouvrages le *métreur-vérificateur* et le *géomètre-expert.* Le premier dresse la liste des travaux effectués, vérifie s'ils sont conformes aux devis et procède aux évaluations qui s'imposent. Mais, sauf convention contraire, il ne surveille pas les travaux (Civ. 3e, 19 juin 1969, D. 1970. Somm. 19). Le métreur-vérificateur n'est un constructeur que si

le contrat lui confie cette fonction (Civ. 3e, 10 juill. 1997, BPIM 1/97, n° 38). Le second lève, puis dresse des documents topographiques ou des plans et fixe les limites des propriétés immobilières ; il est responsable des erreurs commises (Civ. 3e, 28 févr. 2007, n° 05-20.754, RDI 2007. 274, obs. Boubli). Il est passible de sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de l'ordre (CE 11 avr. 1986, RDI 1986. 362 ; 13 juin 1984, RDI 1984. 412). Le contrat qu'il conclut est en principe écrit (Décr. n° 96-478 du 31 mai 1996, art. 49. – Civ. 3e, 10 févr. 2010, n° 09-12.328, Bull. civ. III, n° 34).

171. Qu'ils soient architectes ou techniciens, les prestataires qui concourent à la maîtrise d'œuvre, en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, sont soumis aux *obligations* qui incombent au maître d'œuvre dans la limite de la mission qui leur est confiée (V. *Architecte [Civ.].* – Civ. 3e, 24 mai 1989, RDI 1989. 471, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; 9 déc. 1992, préc., V. *supra,* n° 164. – Civ. 3e, 21 nov. 2012, n° 11-19.778, BPIM 1/13, inf. 47 ; sur la maîtrise d'œuvre, V. *Architecte [Civ.]*). On peut préciser en particulier que, comme l'architecte, les techniciens sont soumis à une *obligation de conseil* pour ce qui relève de leur spécialité (Civ. 3e, 28 nov. 1978, D. 1979. IR 220 ; 24 janv. 1979, RDI 1979. 343, obs. Malinvaud et Boubli ; 17 oct. 1984, RDI 1985. 158. – Civ. 1re, 31 mai 1989, RDI 1989. 469 ; CE 28 nov. 1990, OPHLM de la Meuse, RDI 1991. 55, obs. Llorens et Terneyre), qu'ils doivent *exécuter correctement les études* qui leur sont demandées (Civ. 3e, 3 janv. 1969, D. 1969. Somm. 67 ; rappr. Civ. 3e, 28 févr. 1973, Bull. civ. III, n° 156 : calculs de béton armé ; 15 mai 1973, D. 1973. Somm. 130 : isolation thermique ; 21 janv. 1971, JCP 1971. II. 16729, note P.L. : chauffage ; 20 juin 1979, RDI 1980. 174 et 4 juill. 1979, *ibid.* 1980. 65, obs. Malinvaud et Boubli : étude de sols, question qui fait l'objet d'une approche controversée à propos de l'architecte en jurisprudence : Civ. 3e, 21 nov. 2012, n° 11-79.778, RDI 2013. 149, obs. Boubli. – Civ. 3e, 30 janv. 2013, n° 11-27.792, RDI 2013. 208, obs. Boubli) et qu'ils sont soumis *aux mêmes contraintes que l'architecte* lorsqu'ils assurent l'ensemble de la maîtrise d'œuvre (Paris, 25 mai 1979, D. 1979. IR 505, RDI 1980. 169 ; CE 4 févr. 1991, Société méridionale d'Études techniques, RDI 1991. 211, obs. Llorens et Terneyre). La circonstance que les intéressés n'ont pas la qualification de l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment (OPQCB) est, à cet égard, indifférente (Civ. 3e, 16 juill. 1974, Bull. civ. III, n° 306 ; 6 févr. 1974, *ibid.* III, n° 59 ; T. civ. Béthune, 6 mai 1958, D. 1958. Somm. 134). Les techniciens d'études liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont, comme l'architecte, soumis aux garanties décennale et biennale (sur le mandat accessoire à un louage d'ouvrage, V. *supra,* nos 31 et 158 ; V. *Architecte [Civ.]*). Il a été jugé que celui qui, dans la maîtrise d'œuvre, succède à un autre, prend à son compte la réalisation de l'ouvrage tel qu'il était conçu : il répond alors des erreurs de conception d'un prédécesseur (Civ. 3e, 26 févr. 1980, JCP 1980. IV. 184). Les

techniciens d'études qui sont *missionnés par l'entrepreneur* engagent leur responsabilité contractuelle envers lui qui est généralement retenue pour faute (Civ. 3e, 21 juin 2000, BPIM 5/00, inf. 319. – Civ. 3e, 20 oct. 2004, arrêt no 1033 F-D, inédit. – Civ. 3e, 6 juill. 2004, arrêt no 855 F-D, inédit) ; celle encourue envers le maître de l'ouvrage est délictuelle (Civ. 3e, 28 nov. 2001, Bull. civ. III, no 136).

§ 2 - Entrepreneur

172. L'entrepreneur est le prestataire classique du maître de l'ouvrage. Il peut être seul à s'obliger directement envers le maître de l'ouvrage et il fait alors office d'entrepreneur général ; il peut aussi concourir avec d'autres à la conclusion du marché (V. *infra,* nos 173 s.). Dans tous les cas, il doit faire face à diverses obligations (V. *infra,* nos 220 s.).

A - Pluralité d'entreprises

173. Il est rare qu'une seule entreprise puisse assurer l'ensemble des travaux des différents corps d'état dont l'intervention est nécessaire. Plusieurs modalités sont alors envisageables (V. *infra,* nos 174 s.), il faut prévoir une coordination de travaux (V. *infra,* nos 180 s.), établir un compte « prorata » entre les participants (V. *infra,* nos 186 s.), et mettre en place une coordination sécurité et protection de la santé (SPS, V. *infra,* nos 190 s.).

1° - Formules possibles

174. Les modalités des formules possibles sont en général prévues et précisées dans les documents contractuels. Au contrat proprement dit, s'ajoutent les documents ayant valeur de contrat type : CCAG dans les marchés publics, norme AFNOR dans les marchés privés, documents propres à certains marchés (HLM, SNCF…). La norme AFNOR, en général homologuée, acquiert valeur contractuelle lorsque le marché s'y réfère, sauf en ses articles contraires à une disposition légale impérative (Civ. 3e, 24 mars 2009, no 08-12.768). La coactivité sur le chantier s'ordonne autour de trois modèles :

175. 1o Entreprises non groupées. - Le maître de l'ouvrage contracte alors séparément avec des entreprises distinctes. Les marchés sont relatifs à des travaux concourant à la réalisation du même ouvrage, mais sont négociés indépendamment les uns des autres. On dit que les *entreprises sont séparées* ou *non groupées* (norme AFNOR p. 03-011, art. G. 4.18 et p. 03-001, éd. déc. 2000, art. 3.1.8).

176. 2° Entreprise générale ou principale. - Le maître de l'ouvrage peut confier à un seul entrepreneur l'exécution de l'ensemble des travaux. Cet *entrepreneur principal* ou *général sous-traite* avec des entrepreneurs particuliers pour chaque catégorie d'ouvrage ne relevant pas de son activité professionnelle habituelle. La sous-traitance s'opère dans les formes et aux conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (V. *infra,* nos 334 s.). L'entrepreneur général est seul responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des travaux qu'il fait effectuer en sous-traitance (Civ. 3e, 12 juin 2013, n° 11-12.283, BPIM 5/13, inf. 329) ; il répond du fait de ses sous-traitants même s'il est allégué que ce fait était imprévisible pour lui (B. BOUBLI, *op. cit.,* nos 338 s. – Civ. 3e, 12 déc. 1968, Bull. civ. III, n° 545 ; 5 janv. 1978, *ibid.* III, n° 9) ; il se comporte comme un véritable garant (Civ. 3e, 3 oct. 1979, RDI 1980. 66, obs. Malinvaud et Boubli, *ibid.* 1979. 345. – Civ. 3e, 21 oct. 2009, n° 08-19.087, Bull. civ. III, n° 226).

177. 3° Entreprises groupées. - Les entreprises peuvent se grouper ; elles pratiquent alors une co-traitance organisée et désignent l'une d'entre elles en qualité de *mandataire commun* (norme AFNOR p. 036001 art. 36167 t. 6-1-3). Dans le secteur du *bâtiment,* lorsque le marché est d'un montant de 100 000 euros au plus, il doit comporter un certain nombre d'informations prescrites à peine de nullité, visant à identifier les parties, à définir la nature des travaux et leur prix, à indiquer si la solidarité des prestataires est ou non retenue, le nom et la mission du mandataire commun (CCH, art. L. 111-3-2 issu de L. n° 2015-992 du 17 août 2015). Le groupement peut être un contrat « d'équipe » rassemblant plusieurs entreprises se rassemblent « au sein d'un contrat précis » (LIET-VEAUX, Droit de la construction, 1978, p. 265), du type GIE par exemple. Mais il n'est pas nécessaire qu'il ait une structure juridique propre. Un *Groupement momentané d'entreprises* (GME) peut être constitué, et il peut résulter d'un acte d'engagement unique (CCAG, art. 2.31). Le *mandataire commun,* agréé par le maître de l'ouvrage, après avoir groupé les offres, soumissionne l'ensemble du programme et assure la coordination des travaux (norme AFNOR p. 03-001, art. 3.1.7, et 6.1.3, et norme p. 03-011, art. G. 4.16). Le mandataire commun est l'*entrepreneur pilote,* qui, bien souvent, est l'entreprise de gros œuvre.

178. Le groupement ne constitue pas, en l'absence d'*affectio societatis,* une société de fait ayant pour objet la réalisation de travaux en commun. Sauf stipulation contraire, les entreprises sont rassemblées dans un *groupement conjoint :* chaque entreprise d'opération est directement et personnellement responsable des travaux de son lot, comme si elle était liée au maître de l'ouvrage par un contrat indépendant de celui liant les autres constructeurs (Rouen, 1er juill. 1960, Gaz. Pal. tables, 1961, *V°* Louage d'ouvrage, nos 3 et 4 ; T. com. Le Havre, 8 oct. 1957, Rec. Le Havre 1957. 1. 303. – Colmar, 17 avr. 1974, D. 1974. Somm. 132. – Com. 21 oct. 1968, Bull. civ. IV, n° 281 ; norme AFNOR p. 03.001, art. 3.1.7). Les entreprises peuvent aussi être rassemblées

dans un *groupement solidaire* (norme AFNOR p. 03.001, art. 3.1.7). La solidarité peut être *expressément stipulée* (Rouen, 20 mai 1999, BPIM 5/99, n° 354. – Civ. 3e, 27 mars 1991, JCP 1991. IV. 202 ; norme AFNOR : p. 03.001, art. 3.1.7). Lorsque le marché de travaux de bâtiment est égal à 100 000 euros au plus, le contrat doit préciser si la solidarité est ou non retenue (V. *supra,* n° 177). La convention doit, en principe, régler les rapports entre codébiteurs ; sauf disposition contraire, la solidarité est cantonnée aux rapports entre les entreprises et le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 22 avr. 1971, AJPI 1972. 438, note Caston. – Com. 13 mars 1978, Bull. civ. IV, n° 87). La solidarité peut aussi résulter *des circonstances* et, sans doute, faut-il admettre qu'elle est présumée lorsque les entreprises sont des commerçants et que l'acte d'engagement est unique, encore que l'obligation de stipuler la solidarité implicitement imposée par le nouvel article L. 111-3-2 du code de la construction et de l'habitation, puisse susciter un doute. Le groupement d'entreprise est possible entre les entreprises de premier rang ou de rang inférieur. Lorsque des sous-traitants constituent un groupement conjoint, c'est le contrat de sous-traitance qui fixe les obligations des parties : il peut, notamment, prévoir un délai de contestation du décompte de l'entreprise générale dérogatoire à celui de la norme AFNOR (Civ. 3e, 1er juill. 2009, n° 08-16.724, RDI 2009. 647, obs. Malinvaud, en l'espèce *120* jours).

179. Le *mandataire commun* au groupement (l'entreprise pilote) est-il toujours solidaire des entreprises du groupement ? De nombreux documents de référence le donnent à penser, alors même qu'il n'existerait entre les entreprises du GME que des engagements conjoints (CCAG [Cahier des clauses administratives générales], art. 2.31 ; norme AFNOR p. 03.011, art. 19.22). La norme p. 03.001 de décembre 2000, tout en précisant dans son article 3.1.11, que le mandataire commun est solidaire des entreprises du groupement « si le marché le prévoit », envisage dans son article 22.4.2.2 le cas de l'entrepreneur défaillant, et elle dispose alors que « le mandataire commun doit prendre les mesures nécessaires pour que les travaux correspondants soient exécutés aux conditions du marché de l'entrepreneur défaillant ». C'est pratiquement une solidarité liée aux circonstances que la norme consacre ou, à tout le moins, une responsabilité pour autrui qui entraîne des effets similaires. Le Conseil d'État paraît favorable à la solidarité, que le groupement soit constitué d'entreprises solidairement tenues (CE 4 nov. 1983, SAE ; 28 nov. 1986, CHR de Nice. – Rappr., CE 19 mars 2012, req. n° 346263, BPIM 3/12, inf. 228), ou qu'il soit constitué d'entreprises conjointement tenues, le contrat type étant alors à l'origine de cette solidarité (CE 7 nov. 1986, RDI 1987. 51). La Cour de cassation, après quelque hésitation (Civ. 3e, 15 mai 1973, D. 1973. Somm. 124), n'écarte plus cette orientation (Civ. 3e, 4 juill. 1979, D. 1979. IR 547 ; 26 févr. 1992, RDI 1992. 327. – Civ. 3e, 20 nov. 2013, n° 12-29.259, RDI 2014. 106 et 110. – Comp. : Civ. 3e, 23 oct. 1991, n° 89-18.511, RDI 1992. 522). Selon un arrêt, le mandataire commun qui garantit une entreprise est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage pour agir

contre l'organisme financier qui garantit l'entreprise défaillante (Rouen, 20 mai 1999, BPIM 5/99, n° 354). Le mandataire commun est d'ailleurs l'attributaire des versements lorsque le maître de l'ouvrage qui recourt à un prêt fournit la garantie de l'article 1799-1, alinéa 2, du code civil. Mais il ne représente les entreprises membres du groupement que dans les limites de son mandat qui est un mandat d'organisation ; le sous-traitant d'une autre entreprise du groupement ne peut donc lui faire grief de n'avoir pas mis en œuvre les formalités d'agrément et d'acceptation des conditions de paiement (Civ. 3e, 28 sept. 2005, n° 04-16.008, RDI 2006. 442), mais il peut lui reprocher de n'avoir pas exécuté une prestation particulière mise expressément à sa charge par le mandat (Civ. 3e, 13 sept. 2006, n° 05-10.125, RDI 2006. 470, obs. Boubli, RDI 2006. 433, obs. Dessuet, BPIM 6/06, inf. 438 : absence de souscription d'une police « tous risques chantier »). En l'absence de stipulation particulière dans le contrat de sous-traitance, il n'y a pas lieu de notifier le décompte de l'entreprise générale au mandataire commun d'un groupement conjoint d'entreprises sous-traitantes (Civ. 3e, 1er juill. 2009, n° 08-16.724, RDI 2009. 647, obs. Malinvaud).

2° - Coordination OPC (ordonnancement et pilotage de chantier)

180. Notion. - Lorsque plusieurs entreprises participent à la réalisation de l'ouvrage, une coordination des travaux est nécessaire. La coordination relève à la fois du pilotage et de la maîtrise d'œuvre, bien que les coordinateurs professionnels s'en défendent. L'apparition d'une mission de coordination dans l'opération de construction est à la fois l'illustration et la conséquence de deux mouvements de spécialisation et de fragmentation : l'un dû à la sophistication de la technique de construction et aux contraintes croissantes imposées par les coûts, l'autre dû à la multiplication des intervenants à l'acte de construire.

181. La coordination de chantier, qui implique l'organisation et le pilotage de chantier, est qualifiée dans la pratique, coordination OPC par opposition à une autre forme de coordination, la coordination SPS (V. *infra,* n° 190).

182. La coordination relève, classiquement, de la maîtrise d'œuvre. La norme AFNOR p. 03.001, dans sa rédaction antérieure à décembre 2000, le précisait dans un article 9.2.1 pour les entreprises séparées. La Cour de cassation valide d'ailleurs la requalification du contrat de coordination en contrat de maîtrise d'œuvre lorsque la prestation s'étend aux missions qui relèvent de celle-ci (Civ. 3e, 15 sept. 2015, n° 13-24.726 et n° 13-25.229). La coordination de chantier s'inscrit en effet dans le contrôle de qualité qui incombe à l'architecte et dans l'obligation qu'il assume de vérifier que les délais ne risquent pas d'être dépassés. Mais il est vrai que la mission ressortit également à l'organisation de chantier dont elle permet la maîtrise des coûts, tout en harmonisant l'intervention des différents prestataires. Cela explique que la norme AFNOR p. 03.001, dans sa rédaction de décembre 2000, confie la coordination au

mandataire commun (le pilote), toujours sous le contrôle du maître d'œuvre, lorsque les entreprises sont groupées, et au coordonnateur OPC lorsque les entreprises sont séparées (art. 12.2). Le coordonnateur est l'héritier du « maître de chantier », institué par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 reprenant les dispositions du décret du 28 février 1973 sur l'ingénierie et l'architecture. Selon un schéma aujourd'hui considéré comme « classique » par les spécialistes (V. J. MOULLOT, Coordination et pilotage des travaux de bâtiment, 1975, éd. Eyrolles ; La coordination dans les opérations de construction. Réflexions d'un groupe de professionnels, Mon. TP 17 juill. 1976 ; La coordination des entreprises dans les travaux de bâtiment, Tribune APROBA, n° spéc. ; D. LARGER, La coordination de chantier, RDI 1981. 165), la fonction de maître de chantier peut être confiée : à l'entrepreneur lorsqu'il agit comme entrepreneur général ou entrepreneur pilote ; au maître d'œuvre, qu'il soit unique, ou qu'il soit un maître d'œuvre général coiffant plusieurs maîtres particuliers ; au promoteur immobilier, lorsque c'est la solution « ensemblier » qui a été choisie. Elle peut également être attribuée à un prestataire spécialisé.

183. Les opérateurs modernes, rassemblés dans un syndicat, l'UNAPOC (Union nationale du pilotage et ordonnancement de chantier), conçoivent aujourd'hui leur mission autrement. Rassemblées dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler le pilotage et l'ordonnancement de chantier (POC), leurs obligations sont considérées comme une *prestation autonome* distincte de la maîtrise d'œuvre comme de la simple maîtrise de chantier. Désignés souvent en qualité de bureaux de coordination, ces opérateurs fournissent une prestation de services qui peut faire hésiter à les tenir pour des constructeurs, ce qui n'est pas sans inconvénient.

184. Mission. - La *mission de coordination* comporte deux volets essentiels : 1° l'*élaboration des documents spécifiques,* tel l'ordonnancement des travaux ou planning, et les documents financiers (budget de l'opération par simulation avant le début des travaux, élaboration d'états mensuels confrontés à ce budget en cours de travaux, appréciation en coût des retards, et le cas échéant, corrections…) ; 2° le *contrôle et l'activation du chantier,* qui implique un constat systématique de l'état d'avancement du chantier, du contrôle des stocks et des quantités, etc. Ces missions empruntent d'abord au *pilotage* qui lui-même s'effectue traditionnellement sous le contrôle du maître d'œuvre : organisation de chantier, coordination dans l'intervention des entreprises, détermination des potentialités de retard et attribution de quotas aux différents corps d'état, compte prorata. Elles empruntent aussi à la *maîtrise d'œuvre* proprement dite, dans la mesure où le respect du planning, le maintien des cadences, le contrôle des quantités (qui se confond souvent avec un contrôle qualitatif, exemple : lorsque des pieux de fondation doivent être coulés à une certaine profondeur, le contrôle des quantités de béton utilisées implique une vérification de la profondeur des pieux et des puits) procèdent de la mission de surveillance et de direction du maître d'œuvre.

185. Louage d'ouvrage. - Le contrat OPC est un *louage d'ouvrage,* et non, comme le soutiennent certains opérateurs, un contrat *sui generis* : le prestataire est lié au maître de l'ouvrage et il accomplit sa mission en toute indépendance (V. Civ. 3e, 10 juill. 1996, BPIM 1/97, n° 38, qui concerne un métreur-vérificateur chargé de la coordination). Ce louage d'ouvrage a-t-il un caractère immobilier et le bureau de coordination est-il assimilable à un constructeur dont la responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ? La réticence des professionnels est grande en ce domaine. Certaines conventions de coordination disposent que « le coordinateur ne jouant ni le rôle de l'architecte, ni celui du bureau d'études techniques, ni celui de l'entrepreneur ne saurait de ce fait assumer les responsabilités afférentes à ces professions » (V. Convention annexée à l'ouvrage de M. MOULLOT, préc.). Ces dispositions ne privent pas le juge de donner à l'engagement du coordonnateur sa véritable qualification et, s'il a pris une part dans la conception des travaux, de lui reconnaître la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Mais un arrêt ne paraît pas condamner l'analyse proposée par la convention précitée (Civ. 3e, 11 mai 1988, RDI 1988. 467 ; V. cep., pour une mission de pilotage impliquant la surveillance et le contrôle, ce qui, à notre avis, transforme le pilote en maître d'œuvre : Civ. 3e, 8 avr. 1992, RDI 1993. 81). Le coordonnateur est un prestataire de services qui n'est pas en principe un constructeur, mais il peut être tenu comme un constructeur s'il assume des obligations relevant de cette fonction (Civ. 3e, 10 juill. 1996, préc.).

3° - Compte prorata

186. Pluralité d'entreprises. - Lorsque plusieurs entreprises concourent à la réalisation de l'ouvrage, les frais de chantier sont répartis entre elles selon un compte prorata établi généralement par référence à la norme AFNOR p. 03-001 (V. STEPHAN, Le compte prorata dans le marché de travaux, RDI 2010. 524). Le compte prorata peut s'appliquer au sous-traitant. Il suffit de s'y référer dans les conditions générales des marchés et de faire de ces conditions un document contractuel annexé au sous-traité (Civ. 3e, 3 oct. 2001, n° 99-20.612, RDI 2002. 50). En pratique, seules sont admises au compte prorata les *dépenses communes* imprévisibles ou non susceptibles d'évaluations préalables telles que le gardiennage de chantier, les dégâts de provenance indéterminée, les consommations d'eau et d'électricité (J.- FOURGOUX et POUX-JALAQUIER, L'entreprise face au compte prorata, AJPI 1974. 981 ; PEISSE, Le compte prorata sur les chantiers du bâtiment, Mon. TP 17 juill. 1987). Une distinction est donc faite entre les dépenses d'intérêt commun incombant à chaque entrepreneur (bureau de chantier, prestations préliminaires antérieures à l'exploitation du chantier…) et les dépenses devant donner lieu à répartition (consommation d'eau, d'électricité…). L'annexe C de la norme p. 03-001 de décembre 2000 comporte différentes précisions sur les modalités de gestion du compte. Le plus souvent, les parties s'y réfèrent. Le compte prorata est ouvert à toutes les entreprises présentes sur le site ou qui y

adhèrent, y compris les sous-traitants (Civ. 3e, 3 oct. 2001, n° 99-20.612, préc.). Le gestionnaire du compte est le mandataire commun lorsque les entreprises sont groupées, ou l'entreprise chargée du lot principal lorsque les entreprises ne sont pas groupées. Mais il s'agit d'une pratique, recommandée d'ailleurs par la norme AFNOR, à laquelle il n'est pas interdit de déroger. Le gestionnaire procède à l'inscription des dépenses, à leur répartition, le cas échéant sous le contrôle du maître d'œuvre, si les parties en conviennent, ou d'un comité de contrôle dont la composition et le rôle sont indiqués par la norme AFNOR.

187. Dépenses. - L'inscription des dépenses concerne les prestations définies comme communes par le contrat et destinées à être portées au compte prorata. Il a été jugé que des primes d'assurance destinées à couvrir la responsabilité des entreprises relative au chantier constituent des dettes communes (CE 23 juin 1986, D. 1987. Somm. 281, obs. Terneyre). Le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre sont sans qualité pour demander une inscription (CE 13 févr. 1942, Lebon 51). Toutefois, il semble résulter d'un arrêt que le maître d'œuvre peut avoir un intérêt à l'inscription d'une dette au compte prorata, en particulier lorsque cette dette résulte de la responsabilité des constructeurs en cours de chantier et que leur solidarité est admise (Civ. 3e, 2 mai 1978, Bull. civ. III, n° 171).

188. Le plus souvent, la répartition est faite par l'entrepreneur titulaire du lot le plus important, entrepreneur général ou entrepreneur pilote, après ventilation des frais propres à chaque entreprise et des frais communs dont il est fait masse, et qui sont seuls portés au compte prorata. En fin d'entreprise, le règlement du compte est proposé par l'entreprise gestionnaire à l'architecte qui approuve les situations qui lui sont proposées, le cas échéant avec l'aide d'un comité de contrôle. Parfois désigné comme mandataire commun des entreprises, c'est lui qui procède à la répartition. Mais il n'est pas mandataire du seul fait qu'il est gestionnaire ; il doit recevoir cette qualité (Civ. 3e, 13 janv. 2010, n° 08-70.087, RDI 2010. 209). Le maître de l'ouvrage n'intervient donc à aucun titre dans les règlements interentreprises. S'il le fait néanmoins, on doit considérer qu'il s'immisce dans une tâche qui ne lui incombe pas et qu'il fait office de coordonnateur. Il peut alors être amené à régler le solde créditeur d'un entrepreneur au titre du compte prorata (Civ. 3e, 6 mars 1979, RDI 1979. 340, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; 6 janv. 1983, RDI 1983. 344. – Civ. 3e, 8 juin 2010, n° 09-12.968, BPIM 4/10, inf. 285. – Lyon, 19 mars 1987, Mon. TP 8 sept. 1989. – Rappr. Civ. 3e, 22 juill. 1987, Mon. TP 12 févr. 1988). Mais s'il est conduit à exposer des frais à titre de provision au bénéfice d'un entrepreneur, la somme peut s'imputer sur le solde du prix dû à ce dernier (Civ. 3e, 8 juin 2010, n° 09-12.968, préc.).

189. L'entrepreneur pilote, qui s'engage à régler personnellement les dépenses communes moyennant une participation forfaitaire des autres constructeurs, prend le risque que les règlements forfaitaires soient insuffisants. Il ne peut réclamer une somme

supplémentaire aux autres entreprises si les dépenses sont supérieures aux prévisions (Civ. 3e, 3 oct. 1979, RDI 1980. 169). Lorsque l'entrepreneur mandataire commun répartit de manière erronée les pénalités entre contractants, il engage sa responsabilité (Civ. 3e, 30 oct. 1990, Mon. TP 8 mars 1991). Il a encore été jugé que des primes d'assurances destinées à couvrir la responsabilité de l'ensemble des constructeurs représentent une dette commune (CE 23 juin 1986, Gaz. Pal. 1987. 1. Pan. 163, D. 1987. Somm. 281, obs. Terneyre).

4° - Coordination sécurité et protection de la santé (SPS)

190. La coactivité sur le chantier est une source de risque pour les personnes qui travaillent sur le site. La sécurité du chantier étant l'affaire du maître de l'ouvrage qui doit mettre en œuvre les principes généraux de prévention édictés par les articles L. 4121-1 et L. 4531-1 et suivants du code du travail, elle entraîne toute une série d'obligations qui doivent se concilier avec celles incombant aux différentes entreprises (V. *infra,* nos 191 s.). La prévention du risque d'accidents du travail (C. trav., art. L. 4531-1 s.) et, plus généralement, les mesures destinées à préserver la sécurité des personnes sur le site résultent de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 (JO 1er janv. 1994) qui a transposé deux directives : l'une générale (no 89/381 du 12 juin 1989), l'autre particulière (no 92/57 du 24 juin 1992). Complété par trois décrets des 26 décembre 1994, 4 mai 1995 et 6 mai 1995 et un décret du 24 janvier 2003 (Décr. no 2003-68, JO 26 janv. et Arr. du 25 févr. 2003, JO 6 mars), le nouveau dispositif, codifié, figure désormais aux articles L. 4531-1 et suivants, R. 4532-4 et suivants du code du travail (V. *infra,* nos 204 s.).

a. - Mise en place de la coordination

191. Chantiers assujettis. - Il est institué une *coordination* en matière de sécurité et de protection de la santé ; c'est au maître de l'ouvrage qu'il appartient de la mettre en place ; cette mesure, dont l'absence est pénalement sanctionnée, est *impérative* (C. trav., art. L. 4744-2 s.). Elle consiste à confier à un prestataire le soin d'organiser, selon un processus rationnel et sécurisant pour les différents acteurs, les modalités selon lesquelles les personnes effectueront leur travail. Cette mission d'organisation empiète sur celles des constructeurs dont il faut rappeler qu'ils ont pour mission de veiller à la sécurité de leurs propres salariés et de prévenir les dommages aux tiers, *y compris ceux qui, ultérieurement, utiliseront l'ouvrage achevé ;* pour cette raison, elle peut, dans certains cas, leur être confiée. Nonobstant une difficulté d'interprétation des textes, la coordination s'impose pour tout chantier temporaire de bâtiment ou de génie civil lorsque des entreprises interviennent en coactivité, qu'il y ait ou non sous-traitance.

192. *Le chantier* doit être pris au sens le plus large. Une circulaire du ministre du Travail suggère, semble-t-il, de ne tenir compte que des opérations de structure ou de

gros œuvre (Circ. MT 10 avr. 1996, BOMT 4 juin 1996, p. 21). Mais l'article L. 4532-3 du code du travail n'est pas aussi restrictif et la directive du 24 juin 1992 pas davantage (art. 2 a, et annexe I).

193. Il est essentiel, en revanche, qu'il y ait *coactivité sur le chantier,* c'est-à-dire qu'il y ait au moins deux entreprises différentes qui interviennent. La loi ne distinguant pas, et la prévention des risques professionnels étant une exigence de l'ordre public social, il n'y a pas lieu de faire une différence entre cotraitance et sous-traitance : peu importe le lien entre les entreprises, qu'il soit organique ou juridique. Les entreprises sont prises en considération de leur qualité d'employeur, de sorte qu'une direction départementale de l'équipement (DDE), un service non personnalisé de l'État relèvent de la réglementation. Un arrêt (Civ. 3e, 11 juill. 2001, n° 00-11.984, Bull. civ. III, n° 95, AJDI 2001. 1016, obs. P. Gareau, RDI 2001. 512, obs. F. de Béchillon-Boraud) statuant à propos d'une société de couverture qui s'était assurée les services d'une société d'échafaudages (qualifiée de sous-traitant par l'arrêt ; V. à titre de comparaison : Civ. 3e, 22 janv. 2002, RJDA 8.9/02, n° 883 ; V. *infra,* n° 291), retient la responsabilité de l'entreprise de couverture qui n'a pas informé le maître de l'ouvrage de la nécessité de mettre en place une coordination SPS.

194. Choix du coordonnateur. - Le coordonnateur est choisi par le *maître de l'ouvrage* qui conclut avec lui un contrat de prestation de services conformément aux articles L. 4532-4 et L. 4532-5 du code du travail ; le contrat peut être principal ou accessoire à une autre convention. Le choix est cependant encadré par la loi qui impose des conditions de compétence et de formation aux personnes susceptibles d'être désignées (C. trav., art. R. 4532-23 s.) : la coordination est en effet, une *fonction* et non un métier. Selon l'importance du chantier, et compte tenu de la compétence particulière que peut avoir le maître de l'ouvrage, le coordonnateur peut être pris parmi ses préposés, être désigné parmi les constructeurs ou être un tiers missionné en qualité de prestataire qualifié. La mission comporte deux phases d'intervention qui se situent aux stades de l'élaboration du projet et de la construction de l'ouvrage (C. trav., art. L. 4532-4 et R. 4532-12 s.) ; les missions peuvent être séparées entre deux coordonnateurs ou être confiées au même prestataire. Trois cas sont à distinguer :

195. 1° Lorsque le maître de l'ouvrage est un particulier qui fait construire pour son propre usage ou celui de sa famille, la coordination incombe au maître d'œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, au maître de chantier (en fait l'entrepreneur principal), pendant l'exécution des travaux. Si l'ouvrage n'est pas soumis à autorisation de construire, la coordination est assurée par l'entreprise qui, sur le chantier, a la part de main-d'œuvre la plus élevée (C. trav., art. L. 4532-7 et R. 4532-10). La coordination est, semble-t-il, un effet de la loi dans ce cas : un missionnement spécial n'est pas nécessaire : elle est un attribut naturel de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise de chantier. Le maître de l'ouvrage peut, toutefois, choisir un coordonnateur spécialisé, s'il le préfère. Le syndicat de copropriétaires qui fait réaliser des travaux

n'est pas considéré commun un particulier (Civ. 3e, 11 juill. 2001, n° 00-11.984, Bull. civ. III, n° 95, AJDI 2001. 1016, obs. Gareau, RDI 2001. 512, obs. de Béchillon-Boraud).

196. 2° Lorsque le maître de l'ouvrage est une commune ou un groupement de communes de moins de 5 000 habitants (C. trav., art. L. 4531-2), les opérations de bâtiment ou de génie civil peuvent donner lieu à une délégation des missions de prévention et de coordination au maître d'œuvre. De la rédaction du texte, il résulte que la délégation ne procède pas de plein droit du contrat de maîtrise d'œuvre : elle doit être spéciale et, probablement, expresse. Une obligation d'information, sinon de conseil, semble devoir être supportée par le maître d'œuvre si le maître d'ouvrage est profane en la matière.

197. 3° Lorsque l'on n'est dans aucune des deux situations examinées ci-dessus, la coordination est confiée à une personne *qualifiée.*

198. Les opérations confiées au *coordonnateur qualifié* sont réparties en trois catégories, dont les deux premières sont soumises à une obligation de déclaration préalable : *Catégorie 1* : opérations dont le volume excède 10 000 hommes/jour, soit 80 000 heures, et dont le nombre d'entreprises est supérieur à 10 pour les chantiers de bâtiment, à 5 pour les chantiers de génie civil ; *Catégorie 2* : opérations dont le volume est supérieur à 500 hommes/jour, soit 4 000 heures ; *Catégorie 3* : autres opérations, c'est-à-dire celles qui demandent, par jour, moins de 4 000 heures de travail.

199. Le coordonnateur qualifié est désigné en tenant compte de son niveau de compétence : niveau 1 (toutes opérations) ; niveau 2 (opérations de 2e et 3e catégories) ; niveau 3 (opérations de 3e catégorie). La qualification résulte d'un certain nombre de conditions définies aux articles R. 4532-25 et suivants du code du travail. En outre, s'il intervient au niveau de la conception, le coordonnateur doit justifier d'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre, d'une durée variable selon le niveau de compétence auquel il prétend.

200. Contrat de coordination. - Le contrat de coordination peut être *un contrat de travail* (C. trav., art. R. 4532-21). Il en est ainsi lorsque le maître de l'ouvrage désigne, en qualité de coordonnateur, l'un de ses salariés. La coordination salariée confirme que la sécurité de chantier est l'affaire du maître de l'ouvrage ; mais elle soulève différents problèmes. Le contrat doit être *écrit et il doit individualiser chaque opération* (C. trav., art. R. 4532-21). Est-ce un contrat ayant exclusivement cet objet, ou peut-on concevoir qu'un salarié de l'entreprise soit ponctuellement désigné en qualité de coordonnateur ? Si cette possibilité reste ouverte, il faut que chaque opération donne lieu à un avenant précis. Il est également permis de se demander si le contrat ou l'avenant emporte *délégation de pouvoirs* ou, à tout le moins, si le maître d'ouvrage peut accompagner la mission de coordination d'une délégation de pouvoirs,

d'autant plus concevable que les programmes du maître de l'ouvrage peuvent être nombreux et variés, et que la loi prévoit que la personne désignée doit disposer de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, qui sont des conditions de la délégation de pouvoirs. Bien que l'article L. 4532-6 du code du travail indique que l'existence d'une coordination ne modifie guère la responsabilité des autres participants, il semble qu'une délégation *régulière et effective* pourrait transférer une partie de la responsabilité pénale du maître de l'ouvrage au coordonnateur (V. *infra,* n°s 211 s.).

201. Le contrat de coordination conclu avec un tiers est probablement un *contrat de louage d'ouvrage.* Le coordonnateur fournit un service rémunéré en toute indépendance. D'ailleurs, dans les opérations banales, le coordonnateur est un locateur d'ouvrage constructeur (V. *supra,* n° 195). Il est parfois tiré argument de l'article R. 4532-11 qui dispose que le coordonnateur agit sous « la responsabilité du maître de l'ouvrage » pour soutenir que ce prestataire n'est pas un constructeur. À supposer cette restriction fondée, elle laisse intacte la question de la qualification du contrat de coordination avec une personne qualifiée. La tentation de ranger cette prestation de service dans la catégorie du mandat doit être écartée, ne serait-ce qu'en raison du fait que le maître d'œuvre peut être coordonnateur de plein droit et qu'il est d'autant plus difficile d'admettre l'existence d'un mandat légal, que les textes sont muets sur ce point. La circulaire du 10 avril 1996, qui considère que la mission de coordination ne peut pas être sous-traitée, incite, dans le meilleur des cas, à considérer le contrat de coordination comme un louage d'ouvrage *intuitu personae.*

202. Le contrat de coordination doit être *écrit.* Il doit comporter diverses mentions (Circ. 10 avr. 1996 ; art. R. 4532-20). La formalité, qui n'est pas exigée lorsque la coordination est l'accessoire nécessaire de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise de chantier (V. *supra,* n° 195), est requise dans tous les autres cas. Toutefois, la sanction de son inobservation n'est pas donnée par les textes. Ce silence peut poser problème, car le contrat ayant pour objet une prestation de services, il peut être conclu par voie électronique en application du nouvel article 1127-1 du code civil, ce qui pose la question de savoir si l'article 1174 nouveau est susceptible d'être applicable. Le contrat définit l'autorité et les moyens que le maître de l'ouvrage confère au coordonnateur (C. trav., art. R. 4532-22) ; compte tenu des deux phases d'intervention : élaboration du projet, réalisation de l'ouvrage, il ne semble cependant pas que cela suffise à caractériser une délégation de pouvoirs.

203. Compatibilité entre les fonctions de coordonnateur et de contrôleur technique. - L'activité de contrôle technique est réglementée. Les organismes habilités à exercer cette activité sont agréés par le ministre de tutelle (CCH, art. R. 111-29). L'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation précise qu'elle est incompatible avec « l'exercice de toute activité de conception, d'exécution et d'expertise des ouvrages ». Si l'on excepte l'expertise, l'incompatibilité se limite à l'activité de constructeur. Or, il est constant que les organismes de contrôle technique se sont

souvent immiscés dans la conception de l'œuvre et ont pris à cette occasion la qualité de constructeur (Civ. 3e, 11 juin 1981, Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 29). La sanction n'est pas la nullité du contrat, mais l'application à l'organisme de contrôle des sanctions qui frappent les constructeurs. Si, de surcroît, on considère que la coordination ne relève pas de la mission du constructeur, force est de considérer que l'organisme de contrôle technique qui accepte une mission de coordination ne commet aucune infraction à la loi ; le risque d'un retrait d'agrément est en principe exclu. Ce point de vue est confirmé par la rédaction de l'article R. 4532-19 du code du travail, selon lequel « la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ». Une difficulté d'interprétation subsiste, car le coordonnateur est une personne physique ou morale : 1o lorsqu'il s'agit d'une personne physique, qu'elle agisse en son nom ou au nom de la personne qui l'emploie, elle ne peut, dans la même opération, être également contrôleur technique : c'est le risque de confusion que la loi veut éviter ; 2o lorsqu'une personne morale intervient en une seule qualité (coordonnateur ou contrôleur technique), elle peut prendre en charge une mission de coordination alors même qu'elle est agréée en tant que contrôleur technique ; elle renonce alors à cette qualité dans l'opération : c'est la preuve qu'il n'y a pas d'incompatibilité de principe entre les deux fonctions, mais interdiction de les exercer en même temps. Depuis le décret du 24 janvier 2003 et l'arrêté du 25 février 2003, le coordonnateur ne peut être chargé d'une autre fonction lorsque l'opération excède 760 000 euros, sauf dans les opérations initiées par les communes de moins de 5 000 habitants (V. *supra,* no 196).

ACTUALISATION

203. Interdiction du cumul de fonction - L'interdiction édictée par l'article R. 4532-19 du code du travail vise le coordonnateur personne physique, sans distinguer selon qu'il exerce en son nom personnel ou au nom de la personne morale qu'il est chargé « de gérer, d'administrer ou de représenter » (Civ. 3e, 12 avr. 2018, no 16-17.769 ,Dalloz actualité, 11 mai 2018, obs. Garcia).

b. - Régime juridique de la coordination

204. Obligations du coordonnateur. - La coordination a pour objet de mettre en œuvre les *principes généraux de prévention* édictés par l'article L. 4531-1 du code du travail pour assurer la sécurité des travailleurs. Par analogie avec le chef d'établissement industriel ou commercial, la loi considère le maître de l'ouvrage comme un véritable chef d'entreprise. La prévention des risques lui incombe, ainsi qu'au maître d'œuvre ou au coordonnateur qu'il s'est substitué (C. trav., art. L. 4531-1). Le chantier est donc assimilé à une « entreprise » au sens du droit du travail ; le personnel

à protéger est au premier chef le personnel de chantier. Mais le chantier n'est qu'une étape dans le processus de réalisation de l'immeuble qui est destiné à recevoir du public ou d'autres personnes appelées à y travailler. La loi fait donc obligation au maître de l'ouvrage d'anticiper les risques auxquels ces personnes pourraient être exposées et elle l'oblige à *intégrer* la sécurité *dans les ouvrages* (C. trav., art. L. 4532-16 s.) : ces derniers doivent être conçus et réalisés en tenant compte des principes généraux de prévention. Or, le maître de l'ouvrage est souvent profane en la matière ; il entre dans les attributions des prestataires avec lesquels il contracte (maître d'œuvre, coordonnateur qualifié) de veiller à ce que cet objectif soit atteint : son obligation, mais non sa propre responsabilité, est transférée aux professionnels qu'il consulte.

205. Le coordonnateur, qui est visé par l'article L. 4531-1 au même titre que le maître de l'ouvrage, répond de la sécurité de chantier comme de la sécurité intégrée. Si l'ouvrage est dangereux pour les utilisateurs futurs, il est impropre à sa destination. Selon l'expression de C. SAINT-ALARY-HOUIN, on est dans un cas « d'impropriété-dangerosité ». S'il appartient au coordonnateur de contribuer à la prévention de ce risque, il est permis de se demander si la coordination SPS se réduit à une simple opération d'organisation de la sécurité sur le chantier, ou si, au contraire, le coordonnateur, à l'instar du maître d'œuvre dans les petites opérations, n'a pas une influence sur la conception des ouvrages et si, dès lors il ne se comporte pas comme un constructeur. Les dispositions du code du travail mettent à la charge du coordonnateur l'obligation de mettre en œuvre les principes de prévention, tant dans la réalisation des ouvrages (les travaux de chantier proprement dits), qu'au cours de la « phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet ». Si le coordonnateur est un observateur, passif à ce stade, qui se contente de prendre acte du projet pour établir son programme de coordination, la précision est sans grand intérêt, car elle va de soi. Si le coordonnateur est un prestataire actif au stade de l'élaboration du projet pour contribuer à la prévention des risques actuels et futurs, tout indique qu'il peut, par des préconisations, intervenir dans la maîtrise d'œuvre et pas seulement dans la maîtrise de chantier, comme paraît le confirmer l'article L. 4532-5 lorsqu'il vise les moyens de la coordination (V. *supra,* n° 202). Il est utile de rappeler que dans certaines opérations (maître d'ouvrage qui fait construire pour lui-même), la coordination est un attribut de la maîtrise d'œuvre. Le coordonnateur peut alors influencer les choix architecturaux compte tenu de sa compétence. L'article L. 4532-16, qui oblige le coordonnateur à établir un dossier rassemblant les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures, concerne manifestement la sécurité intégrée et pas seulement la sécurité du chantier. La sécurité du chantier est, souvent, indissociable de la sécurité des ouvrages, et l'intervention du coordonnateur dès la phase de conception est un facteur essentiel de prévention des risques.

206. La *mission de coordination* est arrêtée par le maître de l'ouvrage selon les modalités décrites aux articles R. 4532-11 et suivants du code du travail. Il s'adresse au maître d'œuvre ou à l'entreprise d'opération compétente, pour que la coopération entre

les différents acteurs ne connaisse pas de faille au stade tant du projet que de la réalisation (sur l'obligation du constructeur d'informer le maître de l'ouvrage de la nécessité de recourir à une coordination SPS et sur le coût qui en résulte : Civ. 3e, 11 juill. 2001, n° 00-11.984, Bull. civ. III, n° 95). Le coordonnateur désigné prend les mesures nécessaires pour que l'accès au chantier soit réservé aux personnes autorisées. Il coordonne les travaux pour assurer la meilleure sécurité possible sur le chantier (art. R. 4532-13). À cette fin, il établit un plan général de coordination dans les opérations de niveau 2 (art. R. 4532-43) ; il adresse aux entreprises qui en font la demande (art. R. 4532-58) le plan particulier que chacune d'elles doit établir et lui communiquer (art. L. 4532-9. – Civ. 3e, 11 mai 2006, n° 05-14.425, BPIM 4/06 inf. 262) ; il tient un registre-journal de coordination (art. R. 4532-38) ; il préside le collège interentreprises qui doit être institué dans les opérations de niveau 1 (art. R. 4532-84) ; il tient compte des interférences entre les activités diverses sur le site et il constitue ou complète le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (art. R. 4532-13).

207. Responsabilité civile. - Le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité civile lorsque le risque créé par la co-activité sur le chantier n'est pas maîtrisé par lui, alors même qu'il a désigné un coordonnateur. En effet, il reste tenu de la responsabilité pénale pouvant lui incomber (V. *infra,* n° 211), et sa faute peut donc l'obliger en matière civile ; cette responsabilité a été retenue par la Cour de cassation dans un cas où le maître de l'ouvrage avait omis d'informer le coordonnateur de la présence sur le chantier d'un artisan avec lequel il avait contracté et qui avait été victime d'un accident sur ce chantier (Civ. 3e, 17 juin 2015, n° 14-13.350, RDI 2015. 529). L'arrêt se fonde sur l'article L. 4532-2 du code du travail ; mais l'article L. 4532-6 précise que l'intervention d'un coordonnateur ne décharge pas les autres participants de leur responsabilité ce qui peut viser le maître de l'ouvrage, tenu en application de l'article L. 4531-1 de mettre en œuvre les principes généraux de prévention. Le coordonnateur *salarié du maître de l'ouvrage* n'engage sa responsabilité envers lui que s'il commet une faute dans l'exécution de son contrat de travail, faute qui, en principe, doit être lourde ou dolosive. À l'égard des tiers, il n'engage sa propre responsabilité qu'en sa qualité de préposé du maître de l'ouvrage, lequel répond de son fait. À l'égard des autres salariés intervenant sur le site, victimes d'accidents du travail, sa faute est de nature à engager la responsabilité du maître d'ouvrage, alors même qu'elle n'aurait pas le caractère d'une faute inexcusable, car le coordonnateur est un tiers, même s'il y a travail en commun des différentes entreprises d'opération.

208. Une difficulté de la coordination salariée consiste dans le rôle *actif* du coordonnateur. Lorsqu'il intervient au niveau de la réalisation du projet, et si l'on admet qu'il n'est pas un simple observateur dans la conception de la sécurité intégrée, il s'immisce dans la maîtrise d'œuvre. Notoirement compétent s'il a les qualifications requises, il peut décharger les constructeurs d'une partie de leur responsabilité au

détriment du maître de l'ouvrage pour qui la sécurité intégrée est une de ses obligations (C. trav. art. L. 4532-16 s., L. 4211-1 s.). Cette particularité, il faut en convenir, peut donner crédit à l'interprétation qui limite les prérogatives du coordonnateur et ne lui confère aucun rôle dans la maîtrise d'œuvre (V. *infra,* n° 210).

209. Le coordonnateur *non salarié* du maître de l'ouvrage, c'est-à-dire celui qui est lié à ce dernier par un contrat de prestation de services de la catégorie du *louage d'ouvrage,* engage sa responsabilité à des conditions qui varient selon la nature de la mission qu'on lui prête. S'il n'est qu'un simple agent chargé d'organiser la *sécurité du chantier,* sa responsabilité est celle d'un locateur d'ouvrage non constructeur. La responsabilité est contractuelle envers le maître de l'ouvrage et, par analogie avec le coordonnateur OPC (V. *supra,* n° 185), elle devrait impliquer la preuve de sa faute. Elle est délictuelle à l'égard des tiers, en particulier les constructeurs et leurs préposés. En cas d'accident du travail, et alors même qu'il y aurait « travail en commun », le coordonnateur engagerait sa responsabilité envers les salariés pour leur préjudice complémentaire et la caisse qui les a indemnisés pourrait être subrogée dans les droits des victimes.

210. Si l'on estime que le coordonnateur non salarié peut être amené, par une deuxième lecture du projet, à émettre des préconisations afin *d'intégrer la sécurité dans les ouvrages* en vue de leur utilisation future, le coordonnateur est sur la même ligne que le maître d'œuvre. Contribuant à la maîtrise d'œuvre pour prévenir le risque *impropriété-dangerosité,* il pourrait être considéré comme un constructeur, et engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil (en ce sens : LEGUAY, RDI 1996. 236 ; DE BECHILLON-BORAUD, RDI 1996. 505 ; DANEMANS, AJDI 1997. 194 ; lettre du ministère de la Justice à la FNPC du 23 avr. 1996, BPIM 4/96, inf. 277 ; *contra* : P. MALINVAUD, RDI 1997. 47 ; Avis CE du 16 juin 1998, n° 362-051 ; déc. BCT du 10 déc. 1997, RDI 1998. 116 ; rép. min. HYEST, JO Sénat 30 mai 1996, p. 1319 ; Circ. min. trav., 10 avr. 1996, BO trav. 96/10 du 5 juin 1996 ; rappr. : Civ. 3e, 14 mars 2006, RDI 2006. 184).

211. Responsabilité pénale. - La plupart des principes généraux de prévention s'imposent au maître de l'ouvrage, au maître d'œuvre et au coordonnateur, pour la sécurité du chantier (C. trav., art. L. 4121-2 auquel renvoie l'art. L. 4531-1). En outre, le maître de l'ouvrage doit en tenir compte lorsqu'il fait construire ou aménager l'immeuble (C. trav., art. L. 4211-1 et L. 4211-2). Aucun texte du code du travail n'érige l'absence de mise en œuvre des principes généraux de prévention en *infraction réglementaire,* sauf en ce qui concerne la mise en place de la coordination elle-même. Les obligations édictées par les articles L. 4531-1 et L. 4531-2 ne sont pas constitutives, en elles-mêmes, d'infractions : les articles L. 4732-1 et suivants dans leurs dispositions particulières ne les visent pas. Quant aux articles L. 4741-1 et L. 4741-9 d'application plus générale, ils ne visent que des infractions à des textes précis parmi lesquels ne figurent ni les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 (principes généraux de prévention), ni l'article L. 4531-1 (V. sur la responsabilité pénale liée aux risques du

chantier, CONTE, RDI 2001. 440 ; V. sur le risque pénal lié à la coordination SPS, B. BOUBLI, RDI 2001. 450 ; V. *Droit pénal du travail [Trav.]*).

212. Les infractions en matière de coordination peuvent être peu ou prou rangées en deux catégories :

213. 1° Les infractions qui sont nommées par le code du travail : manquement aux règles relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement de la coordination SPS (C. trav., art. L. 4744-4) ; manquement aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-2 relatives à la sécurité intégrée (art. L. 4744-1) ; manquement aux dispositions relatives à la déclaration préalable (art. L. 4644-2), ou au plan particulier de sécurité (art. L. 4744-5).

214. 2° Les infractions qui ne sont pas nommées par le code du travail : les principes généraux de prévention sont alors pris comme des principes de prudence et de précaution que la loi met à la charge des acteurs qu'elle désigne : maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur. Le manquement à ces règles est constitutif de diverses infractions au code pénal (blessures ou homicides par imprudence), ou de délits civils de nature à engager la responsabilité des personnes concernées pour faute inexcusable ou intentionnelle en matière d'accident du travail, ou à désigner le tiers responsable en cas de « travail en commun ».

215. Les infractions nommées au code du travail n'obligent que les personnes expressément désignées : le maître de l'ouvrage est visé par les textes rappelés ci-dessus ; l'entrepreneur, sous réserve des infractions réglementaires spécialement liées à son activité, n'est visé que par l'article R. 4741-5 à propos de la coordination. Le coordonnateur n'est visé par aucun texte. Il n'est donc tenu qu'à la mise en œuvre des principes généraux de prévention, et il répond des infractions au code pénal pour les fautes d'imprudence qu'il peut commettre comme le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre.

216. La qualification du contrat de coordination présente ici un grand intérêt. La question posée est en effet de savoir si le maître de l'ouvrage, qui est souvent un profane, doit supporter toute la responsabilité pénale du chantier ou des ouvrages qu'il fait construire, alors même qu'il s'adresse à des personnes qui ont pour fonction de prévenir les risques. Le louage d'ouvrage n'emporte pas, en principe, délégation de pouvoirs exonérant le maître de l'ouvrage de sa responsabilité pénale. La chambre criminelle l'a admis à propos de l'ancien article L. 235-16 (protection sanitaire du chantier : Crim. 12 déc. 1989, RJS janv. 1990, n° 36 ; 15 nov. 1994, RJS janv. 1995, n° 29). Si le contrat de coordination est un louage d'ouvrage, il n'échappe pas à cette règle, d'autant que l'article L. 4532-6 prévoit que l'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni la responsabilité des autres participants, ce qui semble viser aussi le maître de l'ouvrage. Alors même que le contrat de coordination serait rangé

dans la catégorie du mandat, il n'emporte pas délégation de pouvoirs car, selon l'article L. 4531-1, la mise en œuvre des principes généraux de prévention incombe tant au maître de l'ouvrage qu'au coordonnateur.

217. Qualité du coordonnateur. - Une distinction s'impose, toutefois, selon que le coordonnateur est ou non salarié du maître de l'ouvrage :

218. 1° Lorsque le coordonnateur est salarié, il semble que rien n'interdit au maître de l'ouvrage de lui déléguer ses pouvoirs et la responsabilité correspondante : cette délégation, sous réserve qu'elle corresponde aux exigences émises par la chambre criminelle, peut entraîner un transfert des pouvoirs en matière de sécurité et de la responsabilité pénale au préposé coordonnateur tant pour les infractions nommées que pour les infractions d'imprudence résultant d'une méconnaissance des principes généraux de prévention. La question demeure toutefois de savoir si cette délégation pourrait résulter de plein droit du contrat de coordination (qui est un contrat de travail), ou si elle doit être expresse.

219. 2° Lorsque le coordonnateur est un tiers, il ne semble pas que le contrat de coordination emporte, en lui-même, délégation de pouvoirs : le maître de l'ouvrage reste tenu des infractions visées plus haut (V. *supra,* n°s 213 et 215), et notamment des infractions liées à une absence de coordination ou à l'insuffisance de ses moyens ou de son contrôle (C. trav., art. L. 4744-4) ; en outre, il doit personnellement respecter les principes de prévention. Toutefois, dans ce dernier cas, la faute causale d'imprudence semble devoir être retenue à l'encontre du coordonnateur qui est l'agent chargé matériellement de la mise en œuvre de ces principes, plutôt qu'à l'encontre du maître de l'ouvrage qui est surtout chargé de désigner un coordonnateur, sous réserve qu'il ne commette pas lui-même une imprudence (V. *supra,* n° 207). On peut aussi se demander si une clause expresse du contrat de coordination ne pourrait pas déléguer les pouvoirs au coordonnateur.

B - Obligations de l'entrepreneur

220. L'entrepreneur exerce une profession commerciale ou artisanale. La plupart des entreprises sont soumises à un double contrôle administratif et professionnel. D'une part, elles reçoivent une classification dans les registres du commerce et des métiers, d'autre part, elles sont rassemblées dans des organisations professionnelles dont les plus importantes sont la Fédération nationale du bâtiment et la Fédération des travaux publics. Un protocole conclu le 3 novembre 1949 entre le ministre de la Reconstruction et la FNB a intitulé un « organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment » (OPQCB) qui classe les entreprises selon leur qualification. L'entrepreneur doit s'informer de la qualité du maître de l'ouvrage. Il doit, selon la Cour de cassation, consulter les titres de propriété de celui avec lequel il contracte et en tirer les

conséquences ; cette obligation lui permet notamment de veiller au respect des limites de propriété (Civ. 3e, 15 oct. 2015, n° 14-24.553, à propos de l'appui sur un mur voisin privatif. – V. aussi : Civ. 3e, 11 juill. 2012, n° 11-45.459, BPIM 5/12, inf. 392). Au titre des principales obligations qui lui incombent, l'entrepreneur doit notamment veiller à la conservation de la chose (V. *infra,* n° 221), exécuter le marché aux conditions prévues (V. *infra,* nos 222 s.), dans le respect des règles de l'art (V. *infra,* nos 224 s.), fournir renseignement et conseil (V. *infra,* nos 225 s.) et veiller à la garde du chantier (V. *infra,* n° 229). La nature des obligations qui lui incombent mérite d'être précisée (v. *infra,* n° 230).

1° - Conservation de la chose

221. L'entrepreneur doit conserver la chose qui lui est remise, qu'il doit restituer en bon état. Cette question concerne la charge des risques avant la réception des travaux qui peut justifier une approche différente selon que la chose confiée est un terrain nu ou qu'il s'agit d'un ouvrage existant. Tandis que dans le premier cas l'entrepreneur fournit la matière et que les risques sont en principe à sa charge (C. civ., art. 1788. – Civ. 3e, 28 oct. 1992, n° 90-16.726, RDI 1993. 225), dans le second cas, il n'est pas interdit de considérer que l'entrepreneur ne répond que de sa faute, car la matière (l'existant) est fournie par le maître de l'ouvrage (C. civ., art. 1789. – Civ. 3e, 6 juin 1972, Bull. civ. III, n° 366. – Civ. 3e, 15 nov. 1995, RDI 1996. 215 ; V. *infra,* nos 468 s.). La jurisprudence applique cependant le droit commun du contrat d'entreprise en cas de dommages aux existants pendant l'exécution du contrat d'entreprise (Civ. 3e, 9 oct. 1991, n° 90-12.059, Bull. civ. III, n° 234, RTD civ. 1992. 107, obs. P. Jourdain. – Civ. 2e, 26 mai 1992, n° 91-11.149, Bull. civ. II, n° 154, RTD civ. 1992. 766, obs. P. Jourdain) et exonère ce dernier de sa responsabilité en la matière en cas de force majeure (Civ. 3e, 28 janv. 1998, BPIM févr. 1998, n° 109, à propos d'un immeuble en construction détruit par un attentat terroriste ; sur la responsabilité encourue pour les dommages aux existants après la réception des travaux, V. *infra,* n° 601). On peut être tenté de rattacher à l'obligation de conserver la chose l'*obligation de sécurité* qui pèse sur chaque constructeur. Selon certains auteurs en effet, le prestataire doit veiller à la sécurité des personnes et des biens. L'obligation de sécurité relative aux personnes reçoit des applications en matière d'accident de chantier (accident du travail ; V. *supra,* nos 205 s. sur ce point) ; elle peut aussi être invoquée lorsqu'une mauvaise exécution du travail entraîne des dommages aux tiers, et que le maître de l'ouvrage mis en cause exerce l'action récursoire (Rappr. : Civ. 1re, 28 mai 1962, Bull. civ. I, n° 267). L'obligation de sécurité relative aux biens peut trouver une illustration dans la jurisprudence qui retient la responsabilité de l'entrepreneur en cas de dommages aux existants.

2° - Exécution du marché aux conditions convenues

222. Principe. - Lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, l'entrepreneur n'est qu'exceptionnellement son mandataire (Civ. 3e, 22 janv. 1974, Bull. civ. III, n° 32). Il a pour mission première *d'exécuter le marché aux conditions convenues.* Il doit notamment respecter le *prix fixé,* obligation qui est particulièrement rigoureuse dans le marché à forfait (V. *infra,* nos 264 s.) ; il a l'obligation d'exécuter les travaux en se *conformant au projet* qu'il n'a pas le pouvoir de modifier (Civ. 3e, 19 mars 1969, Bull. civ. III, n° 243). Mais n'étant pas un exécutant aveugle, il doit dénoncer les insuffisances du projet qu'il est en mesure de déceler (Civ. 3e, 19 mars 1969, préc.), résister aux ordres aberrants du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 14 mars 1973, Bull. civ. III, n° 204. – Civ. 3e, 28 mai 1979, D. 1979. IR 501), attirer l'attention de l'architecte sur les erreurs de conception et de plan qu'il relève (Civ. 3e, 19 nov. 1970, D. 1971. Somm. 82 ; 4 oct. 1978, Bull. civ. III, n° 302), et au besoin refuser d'effectuer le travail (V. aussi : Civ. 3e, 27 mars 1979, D. 1979. IR 406, et P. MALINVAUD et B. BOUBLI, obs. RDI 1979. 471).

223. Délai. - L'obligation d'exécuter le marché aux conditions convenues s'entend également de l'obligation *d'exécuter les travaux et de les livrer dans le délai fixé par le contrat (*Civ. 3e, 8 avr. 2008, n° 07-12.057 *).* L'obligation ne porte que sur le travail commandé (Civ. 3e, 16 janv. 2007, n° 03-16.830, RDI 2007. 277). Elle peut être garantie par un organisme financier, si les parties en conviennent (Civ. 3e, 18 juin 2008, n° 07-13.979 ; la pratique est de règle dans le CCMI), étant précisé que l'entrepreneur n'est libéré que si la livraison dans le délai convenu porte sur l'ouvrage exécuté conformément aux prescriptions du marché (Civ. 3e, 6 nov. 1984, RDI 1985. 155 ; CE 21 mars 1986, Mon. TP 2 mai 1986) L'obligation de respecter les directives reçues est sanctionnée par la responsabilité de l'entrepreneur et même par la résiliation judiciaire du contrat (Civ. 1re, 8 oct. 1962, Bull. civ. I, n° 400. – Civ. 3e, 17 oct. 1978, D. 1979. IR 68), ou par le remplacement de l'entrepreneur concerné par application de l'[ancien] article 1144 (nouv. art. 1222) du code civil (norme AFNOR p. 03-001, art. 49 et 49.2 CCAG ; CE 15 janv. 1986, Mon. TP 21 févr. 1986 ; 14 mai 1990, RDI 1990. 360, obs. P. Terneyre ; C. ATIAS et J. DEBAURAIN, L'abandon du chantier de construction, D. 1990. Chron. 291). En cas de non-respect du délai de livraison, l'entrepreneur s'expose également à la réparation des dommages consécutifs (Civ. 3e, 16 déc. 2008, nos 07-19.510 et 07-19.694).

3° - Respect des règles de l'art

224. L'entrepreneur, comme tout constructeur, doit exécuter ses obligations conformément aux *règles de l'art.* Ces règles ressortissent au savoir-faire de

professionnels réputés investis d'une qualification particulière en matière de construction. Elles ne sont donc pas codifiées, mais peuvent sur certains points être contenues dans des documents techniques unifiés (DTU) (sur l'obligation d'en tenir compte, Dijon, 5 janv. 1999, RDI 2000. 654 ; V. aussi Civ. 3e, 27 févr. 2001, RDI 2001. 175, obs. Malinvaud, qui rappelle que les DTU dans les marchés privés ne s'appliquent que si le marché y fait référence). Toutefois, le respect des normes DTU ne suffit pas à dégager la responsabilité du constructeur : il est censé maîtriser son art pour éviter que l'ouvrage ne cause un dommage (A. PENNEAU, Règles de l'art et normes techniques, 1989, LGDJ ; La notion de règles de l'art dans le domaine de la construction, RDI 1988. 407. – Civ. 3e, 22 oct. 1980, Bull. civ. III, no 162). De nombreux arrêts rappellent l'obligation de l'entrepreneur de respecter les règles de l'art (Civ. 1re, 19 oct. 1964, D. 1965. 161. – Civ. 3e, 3 déc. 1974, JCP 1975. IV. 28 : omission d'un système de drainage. – Besançon, 8 mars 1974, D. 1974. 383, note J. Mazeaud : défaut d'isolation phonique ; V. sur ce point, DERROUCHE et BOUBLI, L'isolation acoustique des constructions d'habitation, RDI 1979. 432 s. ;Civ. 3e, 6 nov. 1969, Bull. civ. III, no 719 : défaut de chaînage ; 15 févr. 1989, Bull. civ. III, no 37 : appareils proscrits par les DTU. – Paris, 27 sept. 1989, Juris-Data, no 024336 : produit malodorant. – Bourges, 14 mai 1986, RDI 1988. 300, obs. P. Malinvaud et B. Boubli : produit malodorant. – Civ. 3e, 27 avr. 2004, no 02-19.476 : contrôle du taux d'humidification du mortier. – Civ. 3e, 17 juin 2008, no 06-12.489, BPIM 5/08, inf. 356, compatibilité entre le support et le revêtement de façade, V. aussi, B. BOUBLI, *op. cit.,* no 175). S'il intervient sur le chantier en l'absence de maître d'œuvre, il peut lui être reproché une faute de conception (Civ. 3e, 10 déc. 2015, no 15-11.142, BPIM 1/16, inf. 23. – V. déjà. Civ. 1re, 6 janv. 1994, no 90-19.612, RDI 1994. 251) dans certaines limites toutefois (Civ. 3e, 14 janv. 2014, no 12-29.349, BPIM 2/14, inf. 106). Il est tenu également de *vérifier les matériaux* qu'il utilise (Civ. 1re, 9 nov. 1964, Bull. civ. I, no 487. – Com. 17 juin 1958, Bull. civ. III, no 250. – Civ. 3e, 2 nov. 1983, JCP 1984. IV. 11 ; comp. Civ. 1re, 23 févr. 1983, Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 185 ; comp. pour les marchés publics, CE 12 mai 1989 et 28 avr. 1989, Mon. TP 1er sept. 1989, et encore Rouen, 7 nov. 1972, D. 1973. Somm. 13 ; V. à ce sujet, MALINVAUD et B. BOUBLI, obs. RDI 1980. 172) et *vérifier l'état des existants* (Civ. 3e, 22 juill. 1998, no 97-11.727, Bull. civ. III, no 172. – Civ. 3e, 7 nov. 2012, no 11-20.532, Bull. civ. III, no 162) ; il doit se conformer à la *réglementation applicable de la construction* (Civ. 3e, 31 janv. 1969, Bull. civ. III, no 99 : règles relatives aux installations des bouteilles de gaz ; 2 oct. 1979, Bull. civ. III, no 164 : hauteur limite du mur de clôture d'une villa ; 17 avr. 1984, JCP 1984. IV. 198 et 15 mars 1988, Mon. TP 26 avr. 1988 : changement de la réglementation anti-pollution. – Civ. 3e, 26 mai 2004, no 02-19.017 : portes non conformes à la réglementation relative aux handicapés. – Civ. 3e, 11 juill. 2012, no 11-15.499 : respect des limites de propriétés. – Civ 3e, 25 sept. 2012, no 11-21.825, BPIM 6/12, inf.

438. – Civ. 3e, 6 nov. 2013, n° 12-18.844, BPIM 6/13, inf. 390 : respect des contraintes du permis de construire). Il peut être tenu d'accomplir certaines démarches telle celle qui permet l'obtention d'un « consuel » (attestation de conformité d'une installation électrique, Civ. 3e, 25 mars 2015, n° 14-11.872, BPIM 3/15, inf. 184).

4° - Renseignement et conseil

225. Parmi *les obligations qui tiennent à la compétence technique* de l'entrepreneur, dont on a déjà vu quelques manifestations figure l'obligation *de renseignement et de conseil* qui pèse, selon la Cour de cassation, sur « tout professionnel de la construction » (Civ. 3e, 27 janv. 2010, n° 08-18.026, BPIM 2/10, inf. 107). Elle commence dès la conclusion du contrat (Civ. 3e, 18 nov. 2008, n° 07-18.691).

226. L'obligation de renseignement et de conseil est due d'abord au *maître de l'ouvrage* (V. les arrêts cités *supra,* nos 98 et 214, à propos du contrôle du projet, et égal. Civ. 1re, 5 janv. 1960, Bull. civ. I, n° 5. – Civ. 3e, 5 nov. 1974, Bull. civ. III, n° 398 ; 3 janv. 1979, *ibid.* III, n° 1. – Civ. 3e, 8 oct. 1997, RJDA déc. 1997, n° 1534 ; 22 juill. 1998, préc. ; 17 mars 1999, BPIM mars 1999, n° 209 ; 11 févr. 2000, RJDA juin 1998, n° 70. – Civ. 3e, 30 juin 2009, n° 08-17.745. – Civ. 3e, 24 sept. 2013, n° 12-24.642, BPIM 6/13, inf. 391 ; l'obligation est particulièrement sévère en l'absence d'architecte. – Civ. 3e, 14 mars 1973, Bull. civ. III, n° 204 ; 13 juin 1973, *ibid.* III, n° 411 ; 4 oct. 1978, RDI 1979. 211, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; 5 févr. 1992, Mon. TP 17 juill. 1992 ; 15 mai 2002, RDI 2002. 390 ; 2 juill. 2002, RDI 2002. 390 ; 10 juill. 2002, RDI 2002. 390, cités dans la note, ce dernier arrêt précisant que l'entrepreneur sur qui pèse le « devoir d'information », devait « interroger » les autres constructeurs ; il confirme que l'obligation d'informer, implique celle de s'informer – dans le même sens : Civ. 3e, 25 sept. 2012, n° 11-21.269, RDI 2012. 632 ; 6 oct. 2010, n° 09-68.989, BPIM 6/10, inf. 456. – Civ. 3e, 15 févr. 2006, RDI 2006. 215 ; Civ. 3e, 2 oct. 2002, BPIM 6/02, n° 386. – Civ. 3e, 26 nov. 2003, n° 01-16.546. – Civ. 3e, 30 mars 2005, n° 04-10.403, RDI 2005. 216, obs. Boubli, RDI 2005. 225, obs. Malinvaud, qui invite l'entrepreneur à conseiller le concours d'un maître d'œuvre ; V. *supra,* n° 55. – Civ. 1re, 6 janv. 1994, RDI 1994. 251. – Versailles, 21 janv. 1994, RDI 1994. 455 ; 6 mai 1998, n° 95-18.357, Bull. civ. III, n° 89). L'entrepreneur doit refuser les ordres du maître de l'ouvrage qui pourraient mettre en cause la solidité de l'ouvrage (Civ. 3e, 14 mars 1973, Bull. civ. III, n° 204. – Civ. 1re, 21 nov. 1967, Bull. civ. I, n° 337). L'obligation implique un diagnostic exact qui tienne compte de l'état de l'ouvrage s'il y a lieu (Civ. 3e, 8 févr. 2011, n° 09-72.617, BPIM 2/11, inf. 114. – Civ. 3e, 10 mars 2015, n° 13-27.562, BPIM 3/15, inf. 185). Elle se combine, le cas échéant, avec celle de l'architecte (Civ. 3e, 30 nov. 2011, n° 10-21.273, BPIM1/12, inf. 29) et il est probable

que, comme ce dernier, l'entrepreneur doive tenir compte de la destination de l'ouvrage pour conseiller utilement son client (Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-16.981).

227. L'obligation, de renseignement à tout le moins, est également due à l'*architecte* (Civ. 19 nov. 1970 et 4 oct. 1978, préc. – Civ. 3e, 12 févr. 1974, D. 1974. IR 101 ; 7 mars 1979, JCP 1979. IV. 169 ; 28 mai 1979, RDI 1979. 471, obs. Malinvaud et B. Boubli ; 4 févr. 1981, *ibid.* 1982. 89, obs. Malinvaud et Boubli ; 17 mai 1983, *ibid.* 1983. 454 ; 13 déc. 1983, *ibid.* 1984. 188 ; comp. Civ. 3e, 22 févr. 1989, JCP 1989. IV. 150. – Civ. 3e, 12 janv. 2000, BPIM févr. 2000, n° 97. – Civ. 3e, 30 janv. 2008, n° 06-19.100 ; rappr. : 8 mars 2000, BPIM mars 2000, n° 171). L'entrepreneur ne doit pas s'engager à obtenir un résultat impossible à atteindre compte tenu du projet (Civ. 28 mai 1979, préc. ; 3 nov. 1987, Mon. TP 3 juin 1988 ; 30 mars 1989, *ibid.* 11 avr. 1989). Sur ce sujet, la jurisprudence est hésitante lorsque la direction de l'ouvrage est assurée par un architecte : tantôt elle admet qu'il suffit à l'entrepreneur de faire des réserves et de proposer des solutions saines (Civ. 3e, 13 mars 1973, D. 1973. IR 108 ; 23 avr. 1986, Mon. TP 29 avr. 1986 ; CE 22 oct. 1986, Mon TP 28 nov. 1986) ou de réclamer un ordre précis (Civ. 3e, 7 mars 1968, Bull. civ. III, n° 97), tantôt elle lui impute à faute de ne pas avoir refusé le marché (Civ. 3e, 13 juin 1973, Bull. civ. III, n° 412. – Civ. 3e, 5 oct. 1982, RDI 1983. 230, obs. Malinvaud et Boubli) ou interrompu les travaux (Civ. 3e, 6 nov. 1969, préc. ; 19 nov. 1970, D. 1971. Somm. 82 ; 12 mars 1974, préc.).

228. L'obligation de conseil s'étend également aux rapports des *entrepreneurs entre eux* (Civ. 3e, 14 mai 1985, RDI 1985. 378, obs. Malinvaud et Boubli. – Civ. 3e, 30 janv. 2008, n° 06-19.100. – Civ. 3e, 31 janv. 2007, n° 05-18.311, BPIM 3/07, inf. 188. – Civ. 3e, 31 janv. 2007, n° 05-18.311, RDI 2007. 277 ; V. pour un sous-traitant, Civ. 3e, 25 mars 1987, Mon. TP 11 sept. 1987. – Civ. 1re, 24 janv. 1995, Juris-Data n° 000820). L'existence d'un maître d'œuvre ne dispense pas l'entrepreneur concerné de son obligation (Civ. 3e, 18 nov. 1992, RDI 1993. 226) ; mais elle s'impose particulièrement en son absence (Civ. 3e, 14 mars 1973, Bull. civ. III, n° 199. – Paris, 31 mai 2000, RDI 2000. 571). Un arrêt précise que l'entrepreneur est tenu d'une « obligation de conseil et de résultat » (Civ. 3e, 27 avr. 2010, n° 08-18.026).

5° - Garde du chantier

229. L'entrepreneur *a la garde du chantier* (Civ. 2e, 15 avr. 1964, Bull. civ. II, n° 287 ; 24 mars 1965, JCP 1965. II. 14417, note Liet-Veaux) et de l'ouvrage qu'il construit (Civ. 1re, 7 févr. 1962, D. 1962. 433, note Esmein ; 15 avr. 1964, préc. ; 10 déc. 1970, Bull. civ. III, n° 690 ; rappr. Civ. 3e, 9 mai 1972, *ibid.* III, n° 293), mais non de l'immeuble déjà existant sur lequel il ne fait que des réfections (Civ. 3e, 27 nov. 1970, Bull. civ. III, n° 653 ; 20 oct. 1971, D. 1972. 414). La jurisprudence tend cependant à admettre que

le maître de l'ouvrage a la garde de l'immeuble en construction, dont la masse est susceptible de causer des troubles aux immeubles voisins, quelles que soient les conditions d'exécution des travaux (V. *infra,* n° 672). L'entrepreneur est même considéré comme un « voisin occasionnel » s'il y a lieu (V. *infra,* n° 676).

6° - Nature des obligations

230. Les obligations de l'entrepreneur de construction immobilière (qui sont de construire, donc de façonner une chose), sont, en principe, des obligations déterminées ou de *résultat* ; c'est au résultat non atteint que ressort le manquement présumé à l'engagement global de livrer dans le délai une chose exempte de vices. Ce principe est affirmé en jurisprudence (Civ. 3e, 30 mars 1989, RGAT 1989. 613, obs. J. Bigot. – Civ. 3e, 28 janv. 1998, n° 96-10.696. – Civ. 3e, 27 avr. 2010, n° 08-18.026, préc. *supra,* n° 228. – Versailles, 2 déc. 1988, RDI 1989. 472, obs. Malinvaud et Boubli. – BOUBLI, *op. cit.,* nos 19, 22, 326 et surtout 454 s. – J.-B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, *op. cit.,* n° 1044), spécialement dans le cas du sous-traitant, dont la responsabilité relève du droit commun (par ex. : Civ. 3e, 25 juin 1985, Bull. civ. III, n° 102 ; 15 janv. 1992, RDI 1992. 216, obs. Malinvaud et Boubli ; V. *infra,* nos 314 s.). L'entrepreneur répond à ce titre du fait d'un préposé (Civ. 3e, 11 mars 2009, n° 08-10.733, RDI 2009. 304, obs. Noguéro) ou d'un sous-traitant (Civ. 3e, 27 mars 2008, n° 07-10.473), et son obligation reste de résultat lorsqu'il intervient dans le cadre d'une convention de maintenance (Civ. 3e, 1er avr. 2009, n° 08-10.070, AJDI 2009. 701, obs. F. de La Vaissière, D. 2009. 1083, obs. Chenu, D. 2009. 2573, obs. Monge, RTD civ. 2009. 539, obs. Jourdain : entretien d'un ascenseur). En revanche, il n'est tenu que d'une obligation de *moyen,* lorsque sa responsabilité est encourue pour manquement à l'obligation de conseil (solution transposée de l'architecte, V. MALINVAUD, JESTAZ, par JOURDAIN et TOURNAFOND, Droit de la promotion immobilière, 9e éd., 2014, Précis Dalloz, n° 184), pour dépassement du prix des travaux dans le marché non forfaitaire (Civ. 3e, 3 juin 1987, Gaz. Pal. 1987. 2. Pan. 198, Mon. TP 23 oct. 1987, p. 61 ; mais un tel marché comporte une part d'aléa pour le maître de l'ouvrage), pour les désordres dits « intermédiaires » (Civ. 3e, 9 mars 1988, Bull. civ. III, n° 52), et pour certains travaux qui ne sont pas de construction (Civ. 3e, 24 juin 1987, Bull. civ. III, n° 133), mais ici, la solution est loin d'être satisfaisante d'autant que certains arrêts, tout en considérant qu'un ravalement ne relève pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur, font peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat (Civ. 3e, 5 févr. 1985, Bull. civ. III, n° 21 ; rappr. : 19 mars 1986, RDI 1986. 368 et 13 janv. 1988, *ibid.* 1988. 229).

§ 3 - Contrôle technique de la construction

231. Le contrôle technique de la construction, dont l'apparition remonte à 1929, (V. DELMAS, Contrôle technique : analyse de la loi du 4 janvier 1978 et de ses textes d'application, RDI 1979. Doctr. 129 ; Brochure du CEP, Le contrôle technique, 1979 ; BOUBLI, *op. cit.,* n°s 181 s. ; CASTON, *op. cit.,* t. 1, 4.464 s., n° 387, 342 ; BIGOT, *op. cit.,* n°s 121 s. – V. *infra,* n°s 232 s.) vise à prévenir les aléas techniques susceptibles de se produire dans les projets de construction (V. *infra,* n°s 238 s.). Les bureaux de contrôles, qui font l'objet d'un agrément sont parties au contrat de contrôle technique conclu avec le maître de l'ouvrage, ou un autre intervenant s'il y a lieu (V. *infra,* n°s 235 s.). Ils rendent un avis qui peut engager leur responsabilité (V. *infra,* n°s 244 s.).

A - Évolution du contrôle technique

232. Le rôle des bureaux de contrôle n'a cessé de se développer tout au long des années, mais il reste encore *marginal* dans le montage d'une opération de construction. Jusqu'à la loi du 4 janvier 1978, et probablement encore depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le contrôle technique est surtout la *condition imposée par les assurances* pour accepter de prendre en charge certains risques de la construction. Le contrôle technique a donc suivi une évolution parallèle à celle de l'assurance-construction. Aussi est-ce très logiquement que la loi du 4 janvier 1978, qui a généralisé l'obligation d'assurance dans la construction (V. *Assurance construction [Civ.]*), a défini un secteur obligatoirement soumis au contrôle technique. Par là même, et pour la première fois, la loi réglemente l'intervention des bureaux de contrôle (art. 11).

233. Pour bien comprendre le rôle des bureaux de contrôle dans le système de l'*assurance facultative,* il faut connaître le fonctionnement du système. L'assurance présente alors un caractère essentiellement *personnel* lorsqu'elle protège les constructeurs : elle garantit leur responsabilité *pour tous les chantiers,* dans la limite d'un plafond. Lorsque ce plafond est dépassé, ou susceptible de l'être, on souscrit une police complémentaire relative à un chantier déterminé : la police « complémentaire de groupe » devenue « complémentaire d'ouvrage ». Cette assurance a un caractère *réel.* Elle pallie les insuffisances des garanties des autres contrats. Pour apprécier l'étendue du risque qu'elles acceptent de prendre en charge, les compagnies imposent aux constructeurs et aux assurés un certain nombre de contraintes parmi lesquelles figure le contrôle technique. En pratique, cette exigence répond à des considérations technique et économique. *La raison technique* est la plus évidente : la meilleure façon de mesurer le risque est de faire appel à un spécialiste *indépendant* des intervenants à l'acte de construire. *La raison économique* n'est pas moins essentielle : le risque construction est difficile à assurer, car important et d'une durée exceptionnelle. Or, le marché manque de souplesse, la concurrence ne joue guère, car la gestion des risques

est trop lourde, et les réassureurs ne se bousculent pas pour conquérir le marché. Dans ce contexte, il est fondamental que le *risque soit apprécié au plus juste coût.* Telle est alors la finalité majeure du contrôle technique : la *normalisation du risque.*

234. Avec l'*assurance obligatoire,* les choses sont partiellement modifiées : le contrôle technique de facultatif qu'il était devient *obligatoire* dans certains cas, mais il a pour l'essentiel le même objet : la normalisation du risque même si la mission *de prévention* se veut prépondérante. Une différence importante avec le système antérieur est cependant à relever : autrefois, le bureau de contrôle intervenait souvent à la requête de l'assureur à défaut d'être mandaté par lui. Aujourd'hui, le bureau de contrôle est consulté directement par le maître de l'ouvrage et à sa seule initiative (CCH, art. L. 111-23 s.).

B - Contrat de contrôle technique

235. Généralités. - Dans la logique du système antérieur à la loi de 1978, les bureaux de contrôle auraient dû être mandatés directement par l'assureur. Pour préserver leur indépendance, c'est finalement une autre solution qui s'est imposée : les bureaux de contrôle contractent directement avec le maître de l'ouvrage, mais leur intervention est une condition de la garantie relevée par les assureurs. En réalité, cette indépendance était toute relative, car les bureaux de contrôle étaient, en fait, les conseillers des compagnies d'assurances et souvent désignés par elles. Aussi, le rapport de la commission « Spinetta » (V. *supra,* n° 155), met-il l'accent sur le fait que le contrôle technique « est un acte d'autorité qui implique l'indépendance de celui qui l'exerce, à l'égard de tous ceux qui participent à la mise au point et à la réalisation de ce qui est contrôlé, à l'égard de l'autorité qui édicte la réglementation à respecter et à l'égard de l'assureur… » (p. 44 et 45). De sorte que le contrôleur doit intervenir à la demande et au profit du seul maître de l'ouvrage (L. 4 janv. 1978, art. 8, al. 2 ; CCH, art. L. 111-23, al. 2), lorsque du moins le contrôle technique est obligatoire (V. *infra,* n° 202). Lorsque le contrôle technique n'est pas imposé par la loi, il peut avoir lieu à la demande d'un constructeur.

236. Le contrôle technique est confié à des organismes agréés par le ministre chargé de la construction après avis d'une commission. L'agrément, délivré pour cinq ans, est renouvelable (CCH, art. R. 111-29).

237. Malgré les incertitudes qui peuvent légitimement subsister à la suite de travaux préparatoires particulièrement décevants (lors des débats devant le Sénat, le rapporteur a déclaré que la « commission des lois a considéré que le contrôle technique n'est pas assimilé à un louage », et un premier projet du gouvernement faisant explicitement du contrôleur technique un locateur d'ouvrage a été repoussé par le Conseil d'État), le contrat de contrôle technique est une variété de *louage d'ouvrage,* reconnu comme tel

par la doctrine quasi unanime (B. BOUBLI, *op. cit.,* n° 182 ; Commentaire de la loi du 4 janvier 1978, RDI 1979. Doctr. 11 ; A. CASTON, La réforme de la responsabilité et de l'assurance dans le domaine de la construction, AJPI 1978. 93 ; P. MALINVAUD et P. JESTAZ, La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, JCP 1978. I. 2900 ; F. MODERNE, La responsabilité décennale des constructeurs en droit public, 1993, Dalloz, nos 425 s. ; note à la RDI 2002. 155 ; Rapport Spinetta, p. 45 ; V. *Assurance construction [Civ.]*). N'étant ni mandataire ni salarié, le contrôleur technique ne peut être qu'un locateur d'ouvrage : il est vain de soutenir qu'il s'agirait d'un nouveau type spécifique de contrat que l'on pourrait appeler « la mission » (DELMAS, *op. cit.,* n° 23). Il est probable, en revanche, que le contrôleur technique n'est pas un constructeur. Un contrat type est proposé par le COPREC (Comité des organismes de prévention et de contrôle technique) le 23 novembre 1992. Un décret n° 92-1186 du 30 octobre 1992 (JO 6 nov.) est relatif aux clauses techniques générales des marchés de contrôle technique qui s'y réfèrent. Le COPREC a également établi un code de bonne conduite, dit code COPREC (7 déc. 1997), qui s'inspire de la norme AFNOR p. 03-100 du 20 septembre 1995 et permet de dégager un cadre juridique type applicable aux marchés privés (V. NIZARA, Le contrôle technique de la construction, thèse, Nice, 1999). On notera que les clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique sont déterminées par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 (JO 1er juin), qui se réfère également à la norme p. 03-100 de septembre 1995.

C - Missions

1° - Domaine

238. Secteur obligatoire. - La loi du 4 janvier 1978 et le décret du 7 décembre 1978 pris pour son application (CCH, art. L. 111-23 et R. 111-38) instituent un contrôle technique obligatoire dans des cas limités qui représentent environ 20 % du volume du contrôle pratique avant l'entrée en vigueur de la loi. Relèvent du contrôle technique obligatoire, selon l'énumération figurant à l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation : 1° les établissements pouvant recevoir du public ; limité à l'origine aux établissements destinés à recevoir plus de 300 personnes, le contrôle est à présent généralisé : seuls les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'ouvrage y échappent (CCH, art. R. 111-38 mod. par Décr. n° 2002-244 du 20 févr. 2002, JO 23 févr. ; art. R. 123-19, al. 5) ; 2° les immeubles de grande hauteur ; 3° les bâtiments autres qu'industriels présentant des difficultés techniques de réalisation telles que précisées par l'article R. 111-38.

239. Le contrôle s'exerce alors sur deux fonctions de la construction : la *solidité* des ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil (mission dite L) et des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec ces ouvrages ; la *sécurité* des personnes (mission dite S). Limité à la *solidité* des constructions, le contrôle technique obligatoire ne porte pas sur l'impropriété à la destination (sauf si la sécurité des personnes est compromise) qui avec l'atteinte à la solidité de l'ouvrage est un cas de garantie décennale. Toutefois, le contrôle *peut* porter sur d'autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir (CCH, art. R. 111-39). Il ne s'agit là que d'une faculté pour le maître de l'ouvrage qui peut toujours assortir la mission de base d'une mission complémentaire (par ex., risque aux existants et aux avoisinants : Civ. 3e, 21 mai 2008, n° 06-20.587 , Bull. civ. III, n° 93, Mémento Fr. Lefebvre, Urbanisme Construction, 2016, n° 50615), à condition qu'elle ne dénature pas la *mission de base* et ne transforme pas le contrôleur technique en maître d'œuvre (ce qui serait le cas d'une mission de surveillance des travaux ou encore si le contrôleur technique formulait des préconisations : Civ. 3e, 11 juin 1981, RDI 1982. 240).

240. Lorsque le contrôle est obligatoire, il n'est pas prévu de sanctions autres que pénales (amende et emprisonnement en cas de récidive : CCH, art. R. 111-42), si le client n'y satisfait pas : tout au plus, peut-on envisager, en cas de sinistre, de retenir partiellement la responsabilité du maître de l'ouvrage, qui s'est privé d'une chance d'éviter le dommage, ou encore la déchéance de garantie si l'on considère que le contrat d'assurance est solidaire du contrôle technique dans le secteur obligatoire. Il est intéressant de relever, à cet égard, que les clauses types de la police d'assurance dommage, malgré une disposition obligeant le maître de l'ouvrage à communiquer à l'assureur les conclusions du contrôleur technique et même à ne pas s'opposer à des contrôles complémentaires demandés par la compagnie, n'instituent aucune sanction spécifique.

241. Autres secteurs. - Le recours au contrôle technique, lorsqu'il n'est pas obligatoire, peut-être spontané. Mais il peut également, et comme par le passé, être *incité,* en particulier dans le cas visé par l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation. Le contrôle obligatoire ne représente qu'environ 20 % du volume de contrôle pratiqué avant la mise en vigueur de la loi (DELMAS, *op. cit.,* n° 14). Or, si les compagnies d'assurances sont tenues de garantir certains risques même pour des ouvrages où le contrôle ne s'impose pas, elles peuvent, en revanche, favoriser les assurés ou souscripteurs qui accepteront de faire appel à un bureau de contrôle, en jouant sur le montant de la prime. Le décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 (JO 31 déc.) modifie l'article R. 250-4-1 du code des assurances et renforce les pouvoirs du Bureau central de tarification pour les opérations complexes. On pense, généralement, que ces opérations relèvent d'un secteur dans lequel le contrôle technique est incité

pour permettre l'appréciation du risque au plus juste coût. L'organisme de contrôle technique peut diversifier ses compétences et intervenir pour établir un diagnostic aujourd'hui rendu nécessaire tant en application des articles L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique que des articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Sa responsabilité civile est encourue si son diagnostic est insuffisant (en matière d'amiante : Civ. 3e, 7 avr. 2016, no 15-14.996. – Civ. 3e, 19 mai 2016, no 15-12.408).

ACTUALISATION

241. Missions du diagnostiqueur d'amiante. - Conformément à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostiqueur d'amiante ne saurait se limiter à un simple contrôle visuel. Même si le contrat circonscrit sa prestation à de simples constats visuels des parties accessibles, celui-ci reste néanmoins tenu de procéder à la mise en œuvre de moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, en réalisant notamment des sondages non destructifs ou en émettant des réserves relatives aux zones non analysées. À défaut, ce dernier engage sa responsabilité (Civ. 3e, 14 sept. 2017, no 16-21.942, Dalloz actualité, 20 sept. 2017, obs. Pelet).

2° - Contenu

242. Normalisation des risques. - C'est un point capital de la réforme. Dans le système antérieur à la loi du 4 janvier 1978, le contrôleur technique a pour mission essentielle, sinon exclusive, d'*informer* l'assureur de la nature de l'étendue du risque assuré. C'est une mission de *normalisation des risques.* Certains bureaux de contrôle se sont le plus souvent cantonnés à cette tâche. D'autres ont plutôt mis l'accent sur la prévention des risques qui est l'objectif que semble avoir poursuivi la loi. À dire vrai, la différence entre la mission de « normalisation » et celle de « prévention » est ténue si le contenu exact des obligations du bureau de contrôle n'est pas précisé : vérifier que la construction est, en apparence, conforme aux « normes » de toutes sortes qui la gouvernent, c'est bien s'engager dans la voie de la prévention. Aujourd'hui, le contrôleur technique exerce une mission de type consultatif : il s'oblige à informer le maître de l'ouvrage dans la limite de ce que le contrat l'oblige à contrôler. Ces limites sont librement fixées lorsque le contrôle est facultatif. Elles sont encadrées par la loi, lorsqu'il est obligatoire.

243. La méthodologie du contrôle implique des vérifications à tous les stades de l'opération : le contrôle s'exerce dès la conception de l'ouvrage ; il se poursuit lors de son exécution. Dans la *phase de conception,* le bureau de contrôle, qui ne se substitue en rien au maître d'œuvre, procède à une « deuxième lecture du projet », ce qui signifie, en clair, qu'il « se livre à l'examen critique de l'ensemble des dispositions

techniques du projet » (CCH, art. R. 111-40) : il contrôle alors l'ensemble des documents, plans, devis, etc., et s'ils sont insuffisants, il doit en faire part au maître de l'ouvrage et informer le maître d'œuvre. Mais il n'a pas à se livrer à des préconisations qui dénatureraient sa mission (Civ. 3e, 11 juin 1981, RDI 1982. 240. – Mémento Fr. Lefebvre, Urbanisme Construction, *op. cit.,* n° 50700 s.). Le contrôle technique porte sur l'examen critique des documents au regard des seules normes techniques (Civ. 3e, 30 mars 1989, Bull. civ. III, n° 75) ; il n'implique pas une analyse de la conformité du projet aux normes juridiques applicables (règles d'urbanisme) ni un examen de la consistance du projet (Civ. 3e, 4 janv. 1996, BPIM févr. 1996, n° 120. – TGI Rouen, 5e ch., 16 août 1985, SCI Village de la Vieille c/ SARL Texim), mais il nécessite une vérification de tous les éléments constitutifs de l'ouvrage projeté (Civ. 3e, 16 juin 1988, n° 1047 D). Dans la *phase d'exécution,* le contrôle technique se manifeste surtout par une surveillance de l'*autocontrôle* des exécutants. En fait, il s'agit de vérifier que les constructeurs procèdent eux-mêmes aux contrôles auxquels ils sont tenus : direction et surveillance de chantier, qualité des collaborateurs, quantités utilisées… On n'insistera jamais assez sur le rôle du bureau de coordination à cet égard : « Si le maître de l'ouvrage a pris la précaution de désigner un coordinateur spécialisé ayant un représentant permanent sur le chantier, le contrôleur technique aura, avec raison, tendance à considérer que l'autocontrôle est aussi sophistiqué que possible et qu'*a priori,* les garanties de bonne exécution sont réunies ». Le bureau de contrôle procède alors par sondages, en effectuant des prélèvements en *temps utile* (Civ. 3e, 15 févr. 1972, Bull. civ. III, n° 95), sans dépasser sa mission de base (Civ. 3e, 8 juill. 1981, RDI 1982. 240), sa présence sur le chantier pouvant être discontinue (Rennes, 16 févr. 1979, Omnium technique de l'habitation, Mémento Fr. Lefebvre, Urbanisme Construction, éd. 2010-2011, n° 1361). Il procède, en effet, par sondages et prélèvements (Civ. 3e, 23 juin 2004, n° 02-15.331 , BPIM 5/04, inf. 283. – V. aussi : Civ. 3e, 20 nov. 2013, n° 12-24.248 , BPIM 1/14, inf. 32, qui laisse entendre qu'il ne peut être tenu d'une vigilance constante). Toutefois, il répond du contrôle insuffisant des modalités techniques prévues par les constructeurs et il commet une faute s'il établit une fiche erronée qu'il ne corrige qu'après l'exécution des travaux et n'informe pas correctement le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 15 sept. 2016, n° 15-19.724).

D - Portée du contrôle et responsabilité du contrôleur

244. 1° Rapports avec le maître de l'ouvrage. - Dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, le contrôleur technique assume les obligations du locateur d'ouvrage. Jusqu'à la loi du 4 janvier 1978, les tribunaux avaient tendance à admettre qu'il n'engageait sa responsabilité qu'en raison d'une faute prouvée, car il était tenu, pour la mission de normalisation des risques au moins, d'une obligation de moyens (TGI Châlon-sur-

Saône, 30 mai 1978, inédit. – TGI Béziers, 10 mars 1976, inédit. – Paris, 6 déc. 1972, inédit. – Civ. 3e, 10 juin 1971, Bull. civ. III, no 368 ; 24 mars 1971, *ibid.* III, no 209), ce qui, en pratique, le soumettait au régime de la responsabilité de droit commun. Mais la solution était moins évidente lorsqu'à la mission de normalisation des risques était adjointe une mission plus directe de vérification ou de prévention (cas de certains contrats CEP). Les arrêts avaient tendance alors à retenir la responsabilité des bureaux de contrôle (Civ. 3e, 15 févr. 1972, Bull. civ. III, no 95, sol. impl. ; obs. ADAM et POIDATZ, Rev. ingénierie juin 1972 ; 15 mai 1973, Bull. civ. III, no 335 ; 1er juin 1976, *ibid.* III, no 239) en écartant toutefois la forclusion décennale (Civ. 3e, 18 nov. 1992, RDI 1993. 516).

245. Désormais, l'organisme de contrôle technique doit fournir un avis qui est donné au maître de l'ouvrage après « examen critique » (CCH, art. L. 111-23 et R. 111-40). N'ayant aucun pouvoir direct sur la chose à construire ou en cours de construction, l'organisme de contrôle, qui est responsable dans les termes des articles 1792 et suivants du code civil, assume une obligation qui relève du conseil induit par sa fonction, en particulier lorsque le contrôleur technique définit avec le maître de l'ouvrage les limites de la mission. Contrairement à l'opinion souvent émise (LORENS, Le devoir de conseil des constructeurs, RDI 1986. 1 s. ; LARROUMET, La responsabilité des organismes de contrôle, RDI 1981. 511 s.), il semble bien que le conseil soit indissociable de l'information que le contrôleur technique fournit au maître de l'ouvrage sur les aléas techniques de l'opération ; sans doute n'est-il pas tenu de préconiser une solution ; mais il lui appartient, notamment lorsque le contrat comporte une mission parcellaire de conseiller le maître de l'ouvrage, d'associer à cette mission une mission de base. Ainsi peut s'expliquer la jurisprudence qui a retenu la responsabilité d'un bureau de contrôle, au titre de la responsabilité décennale, alors que la mission était limitée aux avoisinants (Civ. 3e, 28 avr. 1993, 2e esp., RDI 1993. 376). De même, il a été jugé que le contrôleur technique engage sa responsabilité s'il n'attire pas l'attention du maître de l'ouvrage, voire du maître d'œuvre, sur la nécessité de procéder à une étude géotechnique (Civ. 3e, 5 avr. 1995, BPIM janv. 1996, no 41). Si l'obligation de conseil est discutée, il est constant, en revanche, que le contrôleur technique doit informer le maître de l'ouvrage, ou celui qui l'a missionné, des constatations qu'il fait. Il fournit à son donneur d'ordres des avis périodiques qu'il récapitule dans son rapport définitif ; il appartient au maître de l'ouvrage de faire connaître ces avis aux constructeurs pour qu'il soit remédié aux anomalies éventuellement constatées. Logiquement, le contrôleur technique remplit sa mission lorsqu'il donne en temps utile un avis pertinent ; si celui-ci n'est pas suivi d'effet, le dommage ne relève pas de son fait (Civ. 3e, 30 mars 1989, Bull. civ. III, no 75 ; 4 déc. 2002, BPIM 1/03, no 19, qui rappelle qu'alors l'obligation du contrôleur technique n'est que de moyens ; V. aussi Civ. 3e, 25 sept. 2002, RDI 2002. 547 , qui montre l'hésitation de la jurisprudence entre faute et présomption de responsabilité). Une distinction est cependant à faire.

246. Lorsque la mission confiée à l'organisme de contrôle est une mission de base (celle de l'art. L. 111-23 du CCH), qu'elle relève ou non du secteur obligatoire (Paris, 29 janv. 1987, RDI 1987. 455), et que le dommage répond aux conditions exigées en matière de responsabilité décennale, la responsabilité du contrôleur technique est engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du code civil (réserve étant faite de l'impropriété à la destination lorsque la sécurité des personnes n'est pas en cause). Le contrôleur technique ne peut, en principe, s'exonérer que par la preuve de la cause étrangère (CAA Paris, 23 mai 2001, RDI 2002. 154, note Moderne ; *adde :* CE 27 janv. 1988, Mondon et Cne de Langoiran, req. n° 51.405 ; 23 nov. 1988, ville de Saint-Lô, req. n° 51.505). Il peut toutefois faire valoir que le dommage invoqué est sans rapport avec sa mission (Civ. 3e, 26 févr. 2003, n° 01-15.717, Bull. civ. III, n° 48. – Civ. 3e, 16 févr. 2005, n° 03-16.266, Bull. civ. III, n° 37. – Civ. 3e, 9 juill. 2013, n° 12-17.369, BPIM 5/13, inf. 328) ; en outre, certains arrêts donnent à penser que la présomption est prise comme une présomption de faute, dans la mesure où ils constatent qu'une faute est (Civ. 3e, 15 juin 1988, n° 87-13.074; 27 avr. 2000, n° 98-15.050, BPIM avr. 2000, n° 239) ou n'est pas établie (Civ. 3e, 4 janv. 1996, BPIM févr. 1996, n° 120). Bien que la Cour de cassation affirme que la responsabilité du contrôleur technique est engagée de « plein droit » et qu'elle ne cède que devant la « cause étrangère » (Civ. 3e, 23 avr. 1997, n° 657 D), il est permis de se demander si, bien souvent, la seule preuve que la mission a été correctement accomplie et sans faute ne suffit pas à libérer le bureau de contrôle (Civ. 3e, 30 mars 1989, préc. ; V., pour une analyse plus complète, Mémento Fr. Lefebvre, Urbanisme Construction, 2016, nos 50380 s.). Lorsque la mission n'est pas celle visée à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve de l'arrêt déjà cité du 28 avril 1993 (2e esp.) qui fait problème dans la mesure où il applique la garantie décennale pour un dommage causé au voisin alors que la mission était limitée aux « risques avoisinants », le contrôleur technique qui manque à son obligation d'information ou de conseil ne répond que de sa faute (Civ. 3e, 28 avr. 1993, 1re esp., RDI 1993. 376 ; 12 janv. 2000, n° 98-13.928, BPIM févr. 2000, n° 96). Il en est également ainsi lorsque le désordre ne relève pas de la garantie décennale. C'est le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle qui est alors applicable (Civ. 3e, 4 déc. 2002, préc.). Il a été jugé que le contrôleur technique commet une faute lorsqu'il n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur le choix du matériau (non constitutif d'un EPERS en l'espèce) qui compromettait la solidité de l'isolation (Civ. 3e, 7 janv. 2016, n° 14-17.033 et n° 14-17.669, BPIM 2/16, inf. 111). L'action en garantie décennale, comme l'action en responsabilité de droit commun se transmettent aux acquéreurs successifs de l'immeuble (C. civ., art. 1792, pour la garantie décennale. – Civ. 3e, 28 févr. 1996 et 27 mars 1996, BPIM mars 1996, n° 205, pour l'action de droit commun). Le contrôleur technique ne peut pas limiter sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage, solution qui paraît de règle en matière décennale (C. civ., art. 1792-5), et qui s'impose en droit

commun de la responsabilité lorsque le maître de l'ouvrage n'est pas un professionnel de la construction (Civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 14-29.347, RDI 2016. 290).

247. 2° Rapports avec les autres constructeurs. - À l'égard des autres constructeurs (sauf s'il a été missionné par l'un d'eux, ce qui n'est pas interdit dans le secteur non obligatoire), le contrôleur technique est responsable des conséquences de la faute qu'il a commise dans l'exécution du contrat de contrôle technique (Civ. 3e, 8 mars 2000, n° 98-13.261, BPIM mars 2000, n° 165).

248. 3° Rapports avec la compagnie d'assurances. - Le contrôleur technique a toujours pour mission d'informer l'assureur. Cette obligation devrait être renforcée dans les opérations complexes (V. *supra,* n° 241). Les dispositions des clauses types de la police dommages-ouvrage confortent cette appréciation. Une incertitude subsiste toutefois : quelle est la nature du rapport entre les parties ? Deux explications sont possibles : ou bien, on fait de l'assureur un tiers subrogé aux droits du maître de l'ouvrage ; ou bien, on estime que la convention de contrôle technique contient une stipulation en faveur de la compagnie d'assurances (D'HAUTEVILLE, Responsabilité et assurance des ingénieurs-conseils et travaux d'études, thèse, Paris I, p. 147 et 148 ; BOUBLI, *op. cit.,* n° 188).

Section 3 - Marchés privés de travaux immobiliers

249. Notion. - Le marché est une opération commerciale ayant une fonction économique. Il désigne l'acte par lequel une relation patrimoniale se noue entre deux ou plusieurs parties. Ainsi compris, le marché ne se confond pas avec le contrat d'entreprise ; il peut désigner une vente ou une prestation de services. On sait aussi que le marché est une « réunion organisée en vue de la vente de marchandises et de denrées » (Larousse), et qu'il s'entend également du lieu, généralement public, où l'on vend et l'on achète des marchandises, ou encore du lieu théorique où se rencontrent l'offre et la demande. La diversité des sens du mot « marché » ne contribue pas à une approche rigoureuse de la notion de marché de travaux ; mais il suffit peut-être de préciser que les travaux en question sont immobiliers pour donner une cohérence à la formulation et tenter une explication de l'utilisation courante du terme « marché » pour désigner l'acte par lequel on réalise un ouvrage immobilier : les travaux immobiliers ont en effet ceci de particulier qu'ils s'exécutent sur un site déterminé.

250. Nature. - Le marché est, en droit de la construction, un contrat d'entreprise, c'est-à-dire, selon la définition la plus neutre, un « contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles » (C. civ., art. 1710). Cette définition du code civil est au titre VIII consacré au « Contrat de louage » ; elle désigne en réalité le contrat de louage d'ouvrage, qualification

controversée, mais générique, qui est également reprise par le législateur moderne (art. 1791-1, 1°), même s'il lui préfère souvent, comme le code civil le suggère d'ailleurs, dans la section III du chapitre III du titre VIII consacrée aux « Devis et marchés », la qualification « marché » (L. n° 71-584 du 16 juill. 1971, sur la retenue de garantie ; L. n° 75-1334 du 31 déc. 1975, relative à la sous-traitance ; C. civ., art. 1799-1, relatif à la garantie de paiement). L'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (art. 2) donne des marchés de travaux la définition suivante : « marchés conclus avec les entrepreneurs qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ». Le marché de travaux immobiliers est un louage d'ouvrage particulier que les puristes préfèrent qualifier « contrat d'entreprise ». Le marché de travaux est, traditionnellement, celui de l'entrepreneur ; on parle de marché de maîtrise d'œuvre, voire de « marché de conception » ou de « marché de conception-réalisation », selon l'étendue de la mission, pour désigner le contrat de l'architecte (V. *Architecte [Civ.]*). Selon la Cour de cassation, le contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise est « la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son contractant » (Civ. 1re, 19 févr. 1968, Bull. civ. I, n° 69). Ce contrat doit être distingué des contrats voisins (V. *supra,* nos 16 s.).

251. Le marché est *privé* lorsqu'il est conclu avec un maître de l'ouvrage privé. Toutefois, il est des cas où le marché peut être privé alors qu'il est conclu par une personne publique et, à l'inverse, des cas où le marché obéit aux règles des marchés publics alors qu'il est conclu par une personne de droit privé. Les marchés de travaux des personnes publiques se divisent en deux grandes catégories : les marchés de travaux publics, qui portent sur des travaux réalisés soit pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général (ils peuvent être réalisés sous une maîtrise d'ouvrage privée : T. confl. 18 déc. 2000, n° 3225, MACIF, BPIM 2/01, inf. 114), soit par une personne publique dans un but de service public. Les marchés publics de travaux qui sont commandés par une personne publique, aujourd'hui désignée « acheteur public » sont désormais réglementés par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (JO 24 juill.) et par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (JO 27 mars), qui rendent obsolète le code des marchés publics. Les marchés qui ont pour objet la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sont gouvernés par ces textes qui uniformisent la réglementation et font disparaître la distinction entre marchés soumis au code des marches publics et marchés non soumis à ce code… La conclusion du marché comporte plusieurs étapes (V. *infra,* nos 252 s.). Il existe plusieurs types de marchés de travaux (V. *infra,* nos 304 s.), notamment le marché à forfait (V. *infra,* nos 260 s.).

Art. 1er - Conclusion du marché

252. Pour conclure le marché, le candidat doit répondre à certaines conditions (V. *infra,* nos 253 s.) et fournir des documents contractuels (V. *infra,* nos 257 s.).

§ 1er - Dévolution

253. Le marché privé de travaux est ouvert à tout candidat pourvu qu'il ait une qualification professionnelle reconnue ou qu'il exerce sous l'autorité d'une personne ayant cette qualité (L. no 96-603 du 5 juill. 1996, art. 16-1, D. 1996. 322). Un CAP, un BEP ou un diplôme équivalent sont en pratique nécessaires, à moins qu'une expérience professionnelle de trois ans puisse être validée (Décr. no 98-246 du 2 avr. 1998, art. 2). Lorsque l'entreprise est une personne morale, la qualification doit être acquise en la personne de ses organes ou des agents qui la représentent. Le marché peut être passé par le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui est le plus souvent un maître d'ouvrage délégué. La théorie du mandat apparent peut trouver matière à s'appliquer si le mandat est concevable, ce qui n'est pas le cas du gestionnaire d'un immeuble qui n'engage pas les copropriétaires envers le constructeur (Civ. 3e, 9 nov. 1994, RDI 1995. 104).

254. Avant-contrat. - Le marché peut être précédé d'un avant-contrat. Les négociations précontractuelles sont désormais envisagées par l'article 1112 nouveau du code civil. Dans le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), qui est un contrat d'entreprise à forfait à protection renforcée, cet avant-contrat ne peut pas prendre la forme d'un contrat d'études préliminaires rémunéré (CCH, art. L. 231-1 et L. 232-1 , R. 231-5 ; V. *Contrat de construction d'une maison individuelle [Civ.]*). Dans les autres contrats, le marché est parfois précédé d'une période de pourparlers qui s'engagent autour de ce qu'il est convenu d'appeler dans le langage courant un « devis ». Il s'agit, en réalité, des éléments de l'offre de contracter émise par l'entrepreneur qui est plus ou moins précise. L'usage veut que le coût de ce devis s'impute sur le prix du marché lorsque ce dernier est conclu. À défaut, et sauf si le devis est stipulé « gratuit », rien ne s'oppose à ce que le travail de l'entrepreneur soit rémunéré. Une jurisprudence ancienne considérait que la proposition se consacrait par le devis et qu'avant que celui-ci soit présenté, le maître de l'ouvrage ne prenait aucun engagement (CE 28 févr. 1902, DP 1903. 3. 59. – Nancy, 9 oct. 1959, D. 1960. 90) ; mais cette position était contestée (BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, t. 2. p. 1127, note 7) et elle n'est plus conforme à la pratique. En tout cas, le maître de l'ouvrage ne pourrait, sans abus, multiplier les devis ou les adaptations du devis (Com. 20 mars 1972, JCP 1973. II. 17543). En outre, il est admis sans réserve que la consultation de l'architecte est rémunérée et que celui-ci a droit à des honoraires lorsque le projet n'est

pas suivi d'exécution (Civ. 1re, 7 févr. 1966, Bull. civ. I, n° 89. – Civ. 3e, 8 juill. 1986, RDI 1987. 56 ; 3 févr. 1999, RDI 1999. 253 ; V. *Architecte [Civ.]* ; même sens pour les autres techniciens d'études : Com. 25 juin 1973, D. 1973. Somm. 150. – Civ. 3e, 6 mars 1973, Bull. civ. III, n° 163. – Riom 24 nov. 1967, D. 1968. 188).

255. Le marché est soumis aux dispositions protectrices du consommateur lorsqu'il est conclu avec un non-professionnel : délai de rétractation de dix jours au moins lorsque la construction concerne un ouvrage neuf (CCH, art. L. 271-1) ; ce délai est étendu depuis le 1er juin 2001 aux acquéreurs non professionnels d'un bien situé dans un immeuble ancien, ce qui pourrait viser les maîtres d'ouvrage qui font effectuer des travaux de rénovation (CCH, art. L. 271-1 mod. par la loi SRU) ; délai de rétractation de l'article L. 221-18 du code de la consommation en cas de démarchage à domicile ; information du maître de l'ouvrage qui recourt à un prêt dans les conditions prévues aux articles L. 321-1 et suivants du même code, modifiés par l'ordonnance n° 2016-301 du 16 mars 2016. En outre, le maître de l'ouvrage doit respecter les règles relatives à la lutte contre le travail dissimulé (V. *supra,* n° 165).

256. *Le marché est consensuel* ; l'article 1172 nouveau du code civil rappelle ce principe auquel il n'est pas dérogé en matière d'entreprise ; il est susceptible d'être conclu par voie électronique (C. civ., nouv. art. 1125 s., anc. art. 1369-1), dans les conditions déjà exposées à propos du droit commun du contrat d'entreprise. Il est soumis aux règles qui gouvernent les contrats civils et, à ce titre, il peut être affecté d'un vice du consentement (Civ. 3e, 15 déc. 2004, n° 02-20.614 , Bull. civ. III, n° 239). Il est en général conclu de gré à gré, sans appel à la concurrence. Rien ne s'oppose cependant au choix d'un autre mode de dévolution : appel d'offres ; adjudication ; concours. Les principes qui gouvernent ces modes de dévolution sont inspirés de ceux applicables aux marchés publics. Mais la transposition, qui est volontaire en général, n'est pas totale : le choix du mode de dévolution des marchés publics n'emporte pas application des règles du droit public (Civ. 1re, 9 oct. 1991, n° 90-13.264, Bull. civ. I, n° 262). Il importe cependant, lorsque le marché n'est pas dévolu sur la base du seul choix initial du maître de l'ouvrage, que le principe « d'égalité de traitement » qui est un principe fondamental, ne soit pas méconnu. Les règles de concours, les modalités de sélection des offres ayant donné lieu à un appel public doivent définir des critères objectifs, alors même que la décision d'attribution relèverait du seul maître de l'ouvrage. En outre, les règles de transparence des marchés publics sont applicables aux personnes qui y sont soumises.

§ 2 - Pièces contractuelles

257. Documents nécessaires. - Si le marché privé est consensuel (V. *supra,* n° 256), il doit toutefois être passé par écrit, à peine de nullité, s'il est conclu en cotraitance et si le montant n'excède pas 100 000 € (CCH, art. L. 111-3-2). Il entre alors, semble-t-il, dans la catégorie des contrats solennels visés au nouvel article 1172 du code civil. Sous cette réserve, il n'a en principe, nul besoin d'être établi par écrit (Civ. 3e, 15 juin 1977, Bull. civ. III, n° 265), spécialement lorsque les parties sont des commerçants. L'écrit s'impose cependant en pratique pour établir l'existence de l'engagement et surtout son contenu (Civ. 3e, 2 avr. 1979, RDI 1980. 470. – Civ. 3e, 5 juill. 2005, BPIM 5/05, inf. 324) à défaut de quoi, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, notamment pour en arrêter le prix (Civ. 3e, 12 juin 2014, n° 13-19.410, BPIM 4/14, inf. 250). Si contre le commerçant la preuve du marché peut être librement administrée (Civ. 3e, 25 nov. 1998, n° 96-16.781, Bull. civ. III, n° 220. – Civ. 3e, 19 déc. 2006, n° 05-20.326, RDI 2007. 274), en matière civile, l'écrit est le mode de preuve normal lorsque la valeur du marché excède un certain montant (C. civ., nouv. art. 1359 ; 1 500 €, selon Décr. n° 2001-476 du 30 mai 2001, JO 3 juin. – Civ. 3e, 23 janv. 1969, Bull. civ. III, n° 72 ; 17 mars 1975, Bull. civ. III, n° 102) ; en l'absence d'écrit, un commencement de preuve par écrit rendant admissibles les témoignages et présomptions est nécessaire (C. civ., nouv. art. 1361, Civ. 3e, 21 janv. 1990, Mon. TP 13 juill. 1990. 37). Ce commencement de preuve par écrit peut être constitué par un courrier du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 1er oct. 1975, Gaz. Pal. 1975. 2. Somm. 270), mais non par la réception de factures sans protestation – à distinguer de leur paiement (Civ. 3e, 9 mars 1988, RDI 1988. 298), même accompagnée de mémoires détaillés (Civ. 3e, 10 nov. 1998, RDI 1999. 101). Il résulte d'une jurisprudence que lorsque les travaux ont été exécutés et que le maître de l'ouvrage ne les conteste pas, la preuve du marché est établie et le prix des travaux est dû (Civ. 3e, 14 févr. 1996, n° 94-12.268, Bull. civ. III, n° 46 ; 25 nov. 1998, JCP 1998. IV. 1061). Dans ce cas, le problème concerne la détermination du montant du prix ; si l'on a voulu un marché à forfait, il sera très difficile d'établir les éléments de cet accord, et il y a tout lieu de penser qu'en cas de contestation, le prix sera fixé à dire d'expert. Un arrêt estime toutefois que la preuve d'une commande et de l'existence d'un marché ne résulte pas de la seule exécution des travaux (Civ. 3e, 3 févr. 2004, BPIM 2/04, inf. 98). C'est à l'entrepreneur qui se prévaut d'une commande d'en établir l'existence (Civ. 3e, 8 nov. 2000, BPIM 1/01, inf. 28). Si les relations contractuelles s'engagent par voie électronique, il est fait application des articles 1125 et suivants, issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

258. Le contrat qui comporte les clauses que les parties décident de faire figurer dans l'acte, conformément au principe de liberté contractuelle, peut être établi à partir d'un modèle type. Un modèle type a été établi pour les petits entrepreneurs de la CAPEP (Mon. TP 30 juin 1989, suppl. TO, p. 38) et un autre, à vocation plus générale, a été mis au point par la FNB et l'Office général du bâtiment et des travaux publics sur la base de

la norme AFNOR p. 03-001. Cette norme ne s'applique qu'aux marchés de bâtiment qui s'y réfèrent (Civ. 3e, 30 déc. 1978, D. 1979. IR 187) dans la mesure où elle ne heurte pas une disposition impérative (Civ. 3e, 11 mai 2006, no 04-18.092, BPIM4/06, inf. 266). Les travaux de génie civil relèvent de la norme p. 03-002. Les parties peuvent également décider de soumettre le marché à des règles particulières telles que celles des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) (Civ. 3e, 6 oct. 2010, no 09-66.252, RDI 2010. 607, obs. Boubli).

259. Les documents annexés au contrat sont déterminés par les parties. La norme AFNOR fournit une liste de ces documents, à titre indicatif. Certains documents sont indispensables à certains marchés (devis descriptif dans le marché à forfait) ; les autres varient selon le marché choisi. Bien que les documents émanent des professionnels, on peut se demander s'il est toujours utile de multiplier les documents contractuels. Aux devis descriptifs, estimatifs et quantitatifs, qui sont souvent d'usage, l'article 2-2-1 de la norme p. 03-001 ajoute les pièces suivantes : CCAG et documents auxquels il se réfère ; cahier des clauses techniques, prescriptions cahier des clauses spéciales et règles de calcul DTU propres au corps d'état intéressé par les travaux, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par les documents particuliers du marché ; cahier des clauses administratives particulières ; cahier des clauses techniques particulières ; description des ouvrages par les plans, dessins descriptifs et localisation ; calendrier général et éventuellement, calendrier d'exécution ; échéancier des paiements. Il faut sans doute ajouter à ces documents la justification, par le maître de l'ouvrage, de la garantie du paiement des sommes dues à l'entrepreneur en application de l'article 1799-1 du code civil. Toutefois, si la justification peut résulter d'une attestation de l'organisme financier lorsque la garantie prend la forme d'un cautionnement, elle semble devoir se réduire à une information de l'entrepreneur principal lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique.

Art. 2 - Marché à forfait

260. Définition. - Le marché à forfait est le contrat par lequel l'entrepreneur s'engage à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix fixé à l'avance et globalement. Il est réglementé par l'article 1793 du code civil. La seule convention d'un prix forfaitaire ne suffit pas à caractériser le marché à forfait au sens de ce texte qui ne concerne en principe que le contrat de l'entrepreneur. Ainsi, le contrat de maîtrise d'œuvre qui peut prévoir un honoraire forfaitaire n'est pas un marché à forfait au sens de la réglementation spécifique édictée par l'article 1793 du code civil (V. Versailles, 26 oct. 1989, RDI 1990. 81). En effet, le contrat de maîtrise d'œuvre peut être conclu sur la base d'honoraires forfaitaires, alors que les travaux seront confiés à l'entrepreneur dans le cadre d'un marché sur devis, et réciproquement, le

marché de travaux peut être à forfait tandis que les honoraires de l'architecte sont calculés au déboursé ou au temps passé. Si l'article 1793 vise indifféremment l'architecte et l'entrepreneur cela tient au fait qu'à l'origine, les professions se confondaient ; elles se sont distinguées au début du XXe siècle et définitivement avec la réglementation de la profession d'architecte issue du décret de 1941 (V. *Architecte [Civ.]*).

ACTUALISATION

260, 262, 290 s. Apurement des comptes d'un marché à forfait. - La cour d'appel a exactement retenu que les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartées dès lors que les dispositions de l'article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF p. 03.001 (Civ. 3e, 3 déc. 2020, n° 19-25.392, D. actu. 11 janv. 2021, obs. G. Casu et S. Bonnet).

261. Applications. - Cependant, la Cour de cassation a jugé que l'architecte, qui reçoit une rémunération forfaitaire pour un ouvrage exactement défini dans sa contenance et ses dépendances, ne peut obtenir un complément de rémunération pour des travaux additifs, en l'absence d'écrit conforme à l'article 1793 ou de bouleversement de l'économie du marché (Civ. 3e, 6 déc. 2000, n° 99-13.429. – Civ. 3e, 28 mars 2001, RDI 2001. 239 note B. Boubli. – Civ. 3e, 3 oct. 2001, RDI 2001. 499, et la note critique B. Boubli. – Civ. 3e, 5 déc. 2006, n° 06-10.760, BPIM 2/07, inf. 115. – Civ. 3e, 2 nov. 2011, n° 10-20.499, BPIM 6/11, inf. 454). Si la référence au régime du forfait signifie seulement qu'en l'absence d'accord écrit aucun complément d'honoraires n'est dû à l'architecte, ce qui peut aussi se concevoir par simple application de l'ancien article 1134 du code civil, repris en partie par le nouvel article 1194 (V. Civ. 3e, 29 mars 2011, n° 10-30.253, BPIM 3/11, inf. 202, qui renvoie à ce texte), la solution n'est pas gênante ; elle le devient si l'écrit est le seul mode de preuve admissible ; en revanche, la notion de « bouleversement dans l'économie du contrat », généralement réservée au marché forfaitaire de l'article 1793 n'implique pas nécessairement l'application de ce texte au contrat de maîtrise d'œuvre lorsqu'il en est fait application (V. cep., Civ. 3e, 28 mars 2001, préc. – Comp. : Civ. 3e, 6 déc. 2000, n° 99-13.429, RJDA 3/01, n° 399, pour un contrat de « pilotage ». – V. B. BOUBLI, *in* RDI 2002. 482). Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), qui comporte un prix forfaitaire et définitif incluant la rémunération de tout ce qui est à la charge des constructeurs et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution (CCH, art. L. 231-2, d), et la désignation détaillée des ouvrages, est une variété de marché à forfait à protection renforcée. Le contrat de promotion immobilière, en revanche, qui comporte un prix « plafond » et non un prix forfaitaire, n'est pas un marché à forfait.

ACTUALISATION

261, 264, 290. Application de la notion de marché forfaitaire à une partie des travaux convenus. - Un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus (Civ. 3e, 25 juin 2020, no 19-11.412, D. actu. 23 juill. 2020, obs. G. Casu et S. Bonnet).

262. Dans le marché à forfait, les parties acceptent un aléa : pour le maître de l'ouvrage, que le coût réel des travaux soit finalement inférieur au prix convenu ; pour le constructeur, que le prix convenu ne soit pas suffisant pour financer le coût réel des travaux. Cet aléa, la loi le fait supporter essentiellement à l'entrepreneur : elle exige en effet, sous certaines conditions, que les travaux supplémentaires donnent lieu à une autorisation écrite du maître de l'ouvrage (C. civ., art. 1793). La particularité du marché à forfait réside dans cette disposition. Pour le reste, le marché à forfait est un contrat de droit privé soumis aux règles du droit commun des contrats. Le plus souvent, spécialement lorsque l'article 1793 ne s'applique pas (cas du marché du sous-traitant), il suffit, pour connaître le régime du marché à forfait, de s'en tenir aux stipulations du contrat, qui s'appliquent, sauf disposition légale d'ordre public contraire (V. sur la problématique du marché à forfait, BOUBLI, Les modifications apportées au marché par le maître de l'ouvrage, RDI 2002. 482). Il convient de préciser les conditions du marché à forfait (V. *infra,* nos 263 s.), son exécution (V. *infra,* nos 275 s.) et le régime des travaux supplémentaires (V. *infra,* nos 286 s.).

ACTUALISATION

260, 262, 290 s. Apurement des comptes d'un marché à forfait. - La cour d'appel a exactement retenu que les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartées dès lors que les dispositions de l'article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF p. 03.001 (Civ. 3e, 3 déc. 2020, no 19-25.392, D. actu. 11 janv. 2021, obs. G. Casu et S. Bonnet).

§ 1er - Conditions du marché à forfait

263. Dans le cadre de la conclusion d'un marché à forfait, il faut respecter des conditions de forme (V. *infra,* nos 264 s.), mais aussi préciser les bases de l'engagement contractuel (V. *infra,* nos 268 s.) et les documents à annexer au marché (V. *infra,* nos 266 s.).

A - Forme du marché à forfait

264. Écrit conseillé. - Bien que la loi ne l'exige pas et que les conditions de preuve du marché lui-même relèvent du droit commun, il est indispensable, en pratique, que le contrat à forfait soit conclu par *écrit.* On s'est posé la question de savoir si le formalisme de l'autorisation d'exécuter des travaux supplémentaires n'impliquait pas nécessairement que le contrat lui-même fut écrit (AUBRY et RAU, Traité de droit civil, t. 5, § 374). La Cour de cassation ne semble pas partager cette analyse (Civ. 3e, 10 nov. 1983, RDI 1984. 185. – Civ. 3e, 22 juin 2005, RDI 2005. 439. – Civ. 3e, 19 déc. 2006, no 05-20.754, RDI 2007. 274), ce qui n'empêche pas qu'en l'absence d'écrit la preuve du forfait est souvent impossible à administrer (Civ. 3e, 25 mai 2005, no 03-19.007 RDI 2005. 439. – Civ. 3e, 15 déc. 2010, no 09-17.063, BPIM1/11, inf. 24, 1re esp. – Civ. 3e, 1er déc. 2010, no 09-16.819, BPIM 1/11, inf. 24, 2e esp. – V. Cep. : Civ. 3e, 22 juin 2006, no 03-16.557, RDI 2005. 439). En effet, en cas de contestation sur l'étendue des travaux convenus, il faut établir sans équivoque ce sur quoi les parties se sont mises d'accord pour que les règles relatives aux travaux supplémentaires puissent utilement s'appliquer. En l'absence d'écrit, le contrat n'est pas présumé être à forfait (Civ. 3e, 10 nov. 1983, RDI 1983. 185) ; la charge de la preuve incombe en pratique à celui qui se prévaut du forfait ; elle est d'autant plus difficile à administrer que la production d'une photocopie a été jugée insuffisante (Civ. 3e, 3 oct. 1986, RDI 1986. 86).

ACTUALISATION

261, 264, 290. Application de la notion de marché forfaitaire à une partie des travaux convenus. - Un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus (Civ. 3e, 25 juin 2020, no 19-11.412, D. actu. 23 juill. 2020, obs. G. Casu et S. Bonnet).

265. Dès lors qu'il ne s'agit que de prouver le caractère forfaitaire du marché, l'écrit n'est pas soumis à un formalisme particulier. On peut se contenter d'un seul document comportant une description précise et détaillée de l'ouvrage à réaliser et mentionnant le prix forfaitaire convenu. C'est ce qui se passe en pratique lorsque le contrat porte sur la construction d'une maison individuelle. On peut alors s'inspirer des exigences de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction de maison individuelle qui est une variété de marché à forfait. Le contrat peut être conclu par voie électronique dans les conditions prévues par les nouveaux articles 1125 et suivants du code civil.

B - Documents annexés au marché

266. Documents types. - Le marché à forfait peut renvoyer à des documents types (V. *supra,* n°s 258 s.). Lorsqu'il concerne des travaux importants, il est difficile d'éviter l'établissement d'un *devis descriptif.* À ce devis doit être annexé le plan des ouvrages à réaliser, c'est-à-dire le document graphique qui permet de connaître exactement les détails de l'ouvrage. Ce document, s'il est assez précis, est parfois suffisant (Civ. 1re, 8 oct. 1962, Bull. civ. I, n° 400). Les pièces doivent être contractualisées et claires ; c'est à ces conditions qu'elles lieront les parties, et spécialement l'entrepreneur, sur leur contenu (Civ. 3e, 30 juin 1990, Mon. TP 5 oct. 1990 ; 20 nov. 1991, RJDA 1/92, n° 33 ; 7 mai 1996, n° 94-15.106 ; sur la dénaturation des termes « clairs et précis » d'un marché à forfait : Civ. 3e, 6 déc. 2000, RDI 2001. 162). Au devis descriptif, on ajoute parfois un *devis quantitatif* et un *devis estimatif* (V. Civ. 3e, 1er juill. 2009, n° 08-13.617 , BPIM 5/09, inf. 355) qui tient compte de la définition précise des travaux à exécuter dans ces devis). Ces documents ne sont pas indispensables lorsque le marché est à forfait ; il faut éviter en effet qu'il y ait doute sur la nature exacte du marché. Si un devis estimatif est annexé, il faut qu'il soit clairement précisé qu'il ne l'est qu'à titre indicatif pour que le maître de l'ouvrage ait une idée du détail du prix global et qu'il apprécie le sérieux de l'engagement de l'entrepreneur sur le prix global.

267. Le *devis quantitatif* pose moins de problème ; on peut le tenir comme un complément du devis descriptif destiné à préciser les quantités de matériaux utilisés. Cependant, comme le marché à forfait est aléatoire, l'acceptation d'un devis quantitatif pourrait être interprétée comme un consentement du maître de l'ouvrage sur les prestations forfaitaires dans les limites de ce qui est prévu au quantitatif. L'aggravation des coûts liés à des imprévus augmentant les quantités nécessaires d'ouvrages ou de matériaux pourrait, sous couvert d'interprétation des documents contractuels, conduire le juge à décider que l'entrepreneur n'est tenu au-delà du quantitatif que si les excédents sont imputables à sa faute (V. Civ. 3e, 14 mars 2001, n° 97-20.692 , RDI 2001. 240 , qui écarte le caractère forfaitaire d'un marché dont le prix dépend des quantités réalisées). Il est donc préférable de préciser que le devis estimatif comme le devis quantitatif sont annexés à titre indicatif et qu'ils ne modifient pas le caractère forfaitaire du marché. Le marché à forfait peut comporter en annexe un *cahier des charges* destiné à préciser les cadences de travail et, d'une manière générale, toutes les sujétions techniques et organisationnelles du chantier qui incombent à l'entrepreneur. Ce document, comme le document contractuel de base du reste, peut être inspiré des documents types proposés par les différentes instances professionnelles ou administratives.

C - Bases de l'engagement contractuel

268. Le marché à forfait implique un engagement précis de l'entrepreneur sur la base d'un plan arrêté et définitif (V. *infra,* n°s 269 s.), en contrepartie d'un prix global et immuable (V. *infra,* n° 273).

ACTUALISATION

268 s. Marché à forfait. Responsabilité du tiers au contrat. - Le fait que le maître de l'ouvrage fournisse et impose à l'entrepreneur des métrés erronés du maître d'œuvre ne constitue pas un bouleversement de l'économie du contrat à la demande du maître de l'ouvrage de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat (Civ. 3e, 19 janv. 2017, n° 15-20.846, Dalloz actualité 10 févr. 2017, obs. Diab).

1° - Le plan doit être stable

a. - Plan d'origine

269. Notion. - Le plan ne se réduit pas aux documents graphiques ; il est constitué de l'ensemble des éléments permettant une description précise des travaux à exécuter ; c'est une commodité de langage longtemps en usage dans la profession qui explique que tout soit ramené au « plan ». La stabilité du plan est une condition essentielle du marché à forfait. Ce plan est arrêté par les parties au contrat et il fixe l'étendue et les limites de leur engagement contractuel. Il est indifférent, toutefois, que le contrat à forfait soit conclu ou non par le maître de l'ouvrage ou que le projet immobilier soit relatif ou non à un bâtiment. Le forfait peut être conclu par quiconque. Mais il n'est soumis aux règles particulières relatives aux travaux supplémentaires édictées par l'article 1793 du code civil que s'il est conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur et qu'il concerne la construction de bâtiment (Civ. 3e, 15 févr. 1983, Bull. civ. III, n° 44 ; comp. Paris, 31 mars 1999, Mon. TP 9 juill. 1999, p. 51 ; V. *infra,* n°s 291 s.). Sous cette réserve, il peut y avoir conclusion d'un marché à forfait entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant (Civ. 3e, 21 nov. 2000, n° 98-19.975, BPIM 1/01, n° 29), ou entre l'architecte et l'entreprise de pilotage (Civ. 3e, 6 déc. 2000, n° 99-13.429, RJDA 3/01, n° 299. – Civ. 3e, 18 juin 2003, BPIM 5/03, inf. 285 ; V. analyse de cet arrêt sous Civ. 3e, 28 mars 2001, RDI 2001. 239), voire convention de forfait entre le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage (avec les réserves émises *supra,* n° 240).

b. - Modification du plan d'origine

270. Si le plan et le descriptif contractuel qui le complète ont été modifiés en cours de marché avec l'accord du maître de l'ouvrage, le marché peut perdre son caractère forfaitaire (Civ. 3e, 8 mars 1995, n° 93-13.659, Bull. civ. III, n° 73 ; 14 mars 2001, RDI

2001. 240) ; tout dépend, de la portée de l'accord : rien n'interdit de modifier le forfait d'origine par voie d'avenant, en particulier lorsqu'il s'agit de préciser la consistance de certains travaux (Civ. 3e, 13 nov. 1979, RDI 1980. 169), ce qui est d'ailleurs le cas lorsque des travaux supplémentaires donnent lieu à autorisation écrite du maître de l'ouvrage en application de l'article 1793 du code civil. Mais il semble résulter de la jurisprudence que la modification ne doit pas bouleverser le contrat d'origine (Civ. 3e, 13 janv. 1979, RDI 1979. 339) ; cette restriction est à nuancer lorsque le contrat est modifié par voie d'avenant écrit, d'autant qu'il est toujours possible de procéder à une novation et de substituer un autre forfait au forfait initial, ou de convenir que les travaux modificatifs seront soumis à un régime dérogatoire à ce dernier, en particulier lorsqu'ils concernent un lot différent (Civ. 3e, 28 nov. 2001, no 00-15.758 , RDI 2002. 49 ; comp. Civ. 3e, 26 juin 2002, cité et analysé sous Civ. 3e, 12 juin 2002, RDI 2002. 391). L'accord du maître de l'ouvrage doit toutefois être exempt d'équivoque. La modification peut soit fixer forfaitairement le coût des travaux additionnels ou modifier purement et simplement le prix global initial, soit prévoir un prix unitaire pour les travaux modifiés option à éviter, car elle risque de dénaturer l'ensemble du marché et de faire perdre au contrat initial son caractère forfaitaire. Il faut éviter de conclure un avenant modificatif ne précisant pas le prix des travaux modificatifs. Ainsi que cela sera expliqué plus loin, lorsque l'article 1793 est applicable, la preuve des travaux modificatifs est stricte. En revanche, lorsque l'article 1793 ne s'applique pas, l'accord verbal des parties sur les travaux modificatifs peut suffire et entraîner l'appréciation du prix, à dire d'expert, le cas échéant. Plus généralement, dans tout marché, qu'il soit forfaitaire ou non, le maître de l'ouvrage n'est tenu de payer le prix de travaux non prévus au contrat que s'il est établi qu'il les a commandés (Civ. 3e, 8 nov. 2000, no 99-11.327 , pour des travaux supplémentaires de démolition).

c. - Clauses contractuelles

271. Le plan n'est plus stable et le marché perd son caractère forfaitaire, si une clause du contrat a pour conséquence de le dénaturer. Certaines clauses sont sans influence sur la nature du marché, car elles ont pour objet de renforcer son caractère forfaitaire. Ainsi en est-il de la clause qui fixe un prix « toutes sujétions comprises » (Civ. 3e, 5 juin 1984, RDI 1985. 58), dont l'objet est de préciser que les difficultés de construction rencontrées par l'entrepreneur seront à la charge de celui-ci ; une telle clause ne fait que rappeler la règle selon laquelle les travaux « nécessaires » à l'objet du marché sont à la charge de l'entrepreneur malgré les imprévus éventuels (Civ. 3e, 17 oct. 1990, RDI 1991. 65). En revanche, la clause qui réserve au maître de l'ouvrage la possibilité de demander des travaux supplémentaires ou modificatifs évacue le forfait (Civ. 3e, 31 mars 1976, JCP 1976. IV. 127 ; 12 mai 1981, RDI 1982. 84 ; 12 déc. 1978, RDI 1979. 207). Il semble que la seule stipulation d'une clause modificative suffit à dénaturer le forfait, dont on dit parfois, mais sans pertinence, qu'il devient un marché à « forfait

imparfait » (V. Civ. 3e, 12 mai 1973, Bull. civ. III, n° 354 ; 12 déc. 1978, préc.). En effet, si des travaux sont effectivement exécutés, le maître de l'ouvrage pourrait, en l'absence d'ordre écrit lorsque la construction porte sur un bâtiment, soutenir que l'initiative en incombe au seul entrepreneur : la réserve de modification unilatérale des termes du marché exclut donc naturellement le forfait et peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de l'article 1793 du code civil, puisque le contrat perd la stabilité qui est de son essence (Civ. 3e, 12 juill. 1995, BPIM 196, inf. 124).

272. Néanmoins, on peut penser qu'une distinction doit être faite entre deux catégories de clauses : 1° les clauses qui prévoient la possibilité de travaux modificatifs et en fixent ou non le prix, sans préciser que ces travaux ne seront exécutés qu'en application d'un avenant modificatif : le marché perd son caractère forfaitaire (Civ. 3e, 7 mai 1996, n° 93-21.567) ; la solution ne fait guère de doute lorsque l'article 1793 a vocation à s'appliquer (Civ. 3e, 21 juill. 1999, n° 97-22.322, BPIM 6/99, n° 423 ; 12 déc. 1978 et 12 mai 1981, préc. ; V. déjà : Civ. 13 juin 1944, D. 1945. 80) ; 2° les clauses qui prévoient la possibilité de travaux supplémentaires et en fixent ou non le prix, mais précisent que ces travaux donneront lieu à un ordre écrit du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 22 nov. 1968, Bull. civ. III, n° 488) ou à un avenant modificatif (Civ. 3e, 11 oct. 2000, n° 98-21.509, BPIM 1/01, n° 30). On ne voit pas en quoi une telle clause dénature le forfait : lorsque le marché est soumis à l'article 1793, la clause ne fait que confirmer les conditions du texte (Civ. 3e, 22 janv. 2002, BPIM 2/02, inf. 112. – Civ. 3e, 15 mars 2005, n° 04-11.087) ; lorsqu'il n'est pas soumis à l'article 1793 et que la preuve des travaux supplémentaires éventuels relève du droit commun, la clause subordonnant les travaux modificatifs à un avenant écrit n'est qu'une application conventionnelle du texte (Civ. 3e, 22 nov. 1968, Bull. civ. III, n° 488 ; 12 juin 2002, n° 01-00.710, RDI 2002. 391). La clause du marché qui stipule « toutes sujétions comprises » n'affecte en rien le forfait : même en l'absence d'une telle clause, l'entrepreneur est tenu d'exécuter le contrat dans les conditions et prix convenus (Civ. 3e, 5 juin 1984, RDI 1985. 58), car les sujétions imprévues, en droit privé, font partie de l'aléa contractuel accepté par l'entrepreneur qui s'oblige à prix fait (Civ. 3e, 17 oct. 1990, n° 89-11.143, RDI 1991. 65).

2° - Le prix doit être forfaitaire

a. - Prix définitif

273. Le prix forfaitaire est un prix définitif, c'est-à-dire fixé une fois pour toutes et immuable. Selon un arrêt, le prix est censé être établi hors TVA (Civ. 3e, 2 mai 1978, Bull. civ. III, n° 168). Mais selon la Documentation fiscale Francis Lefebvre, il doit s'entendre, en l'absence de disposition contraire, TVA comprise (Mémento F. Lefebvre

Urbanisme Construction, n° 16140). Le prix est définitif alors même qu'il comporte une indexation, si du moins sa mise en œuvre aboutit à un calcul précis de la révision (Civ. 1re, 30 mai 1963, Bull. civ. I, n° 289 ; 11 févr. 1964, Bull. civ. I, n° 79. – Civ. 3e, 23 janv. 1979, RDI 1979. 339). Le caractère définitif du prix n'exclut cependant pas une vérification des mémoires de l'entrepreneur par l'architecte, même tardive (Civ. 3e, 17 mai 1995, n° 93-15.332, Bull. civ. III, n° 122). Le prix n'est pas définitif tant que l'un des postes du marché demeure incertain. Ainsi en est-il lorsque les conditions d'exécution du marché sont mal définies (Civ. 3e, 20 nov. 1991, n° 90-10.286, Bull. civ. III, n° 284), lorsque le maître de l'ouvrage se réserve certaines rectifications (Civ. 3e, 25 mars 1980, RDI 1980. 432 ; 6 mars 1985, JCP 1986. II. 20647, note Liet-Veaux), lorsque le devis comporte des réserves sur certains travaux aléatoires ou encore non autorisés (Civ. 3e, 15 déc. 1993, Mon. TP 6 mai 1994. 63 ; 12 juill. 1995, Mon. TP 20 oct. 1995. 61).

b. - Prix global

274. Le prix forfaitaire est un prix global. Il doit être fixé lors de la conclusion du contrat ou du moins, selon un arrêt, être déterminable avec précision (Civ. 3e, 23 mai 1978, RDI 1979. 67). Le prix global exclut l'application de prix unitaires aux quantités de travaux réellement exécutées (Civ. 3e, 26 févr. 1986, RDI 1986. 162), sauf si les prix unitaires sont donnés à titre indicatif ou pour servir de bordereau de base (Civ. 3e, 17 mai 1995, RDI 1995. 548 ; 23 juin 1999, BPIM 5/99, n° 356). Mais le marché peut être décomposé en forfaits partiels (Civ. 1re, 12 mai 1966, Bull. civ. I, n° 286. – Civ. 3e, 7 mai 1996, RDI 1986. 571) et le forfait peut ne concerner qu'une partie de la construction, ce qui donne au marché un caractère mixte (Civ. 3e, 20 mai 2008, n° 07-15.867, BPIM 5/08, inf. 357). Il résulte de la norme AFNOR p. 03-001 (art. 1.4.22.1), que le marché à prix global peut prévoir que certains travaux seront réglés au métré. On trouve, en jurisprudence, des arrêts nuancés. Un arrêt paraît avoir admis que le marché peut pour partie être à forfait et pour partie être à prix unitaires (Civ. 3e, 15 déc. 1982, Bull. civ. III, n° 254). Mais un autre a considéré que lorsque deux modalités du prix s'appliquent à des articles différents du même ouvrage, le marché échappe pour le tout aux dispositions de l'article 1793 (Civ. 3e, 9 janv. 1969, Bull. civ. III, n° 30). Il semble que l'on doit distinguer par nature d'ouvrage ; en cas d'ouvrages distincts, on peut considérer qu'il y a deux marchés (Civ. 1re, 14 janv. 1964, Bull. civ. I, n° 30). L'erreur de calcul, sauf mauvaise foi ou dol, n'est ni une cause de nullité du contrat ni une cause de modification du prix (Douai, 20 mars 1986, Juris-Data n° 046988. – Versailles, 17 juin 1985, RDI 1986. 72). Si le maître de l'ouvrage s'est réservé le droit de rectifier le prix, le marché perd son caractère forfaitaire, car le prix n'est plus définitif (V. *supra,* n° 271). Lorsque le prix est stipulé forfaitaire et global, l'entrepreneur ne peut en demander une augmentation au titre des sujétions imprévues (difficultés

économiques : Civ. 3e, 20 nov. 2002, n° 00-14.423, Bull. civ. III, n° 230 ; circonstances climatiques : Civ. 28 janv. 1846, DP 1846. 245 ; V. toutefois : Civ. 23 juin 1873, DP 1874. 332 ; V. *supra,* n° 271). Il pourrait, en revanche, se prévaloir d'un cas de force majeure ou de la mauvaise foi du maître de l'ouvrage (Dijon, 17 févr. 1971, D. 1971. 371) et de l'omission d'un poste (Civ. 3e, 15 janv. 2003, n° 01-01.563). Réciproquement le maître de l'ouvrage pourrait invoquer le dol de l'entrepreneur pour lui réclamer un trop perçu lorsque la surface réalisée est inférieure de deux fois à celle prévue au contrat (Civ. 3e, 2 mars 2005, n° 03-18.080).

§ 2 - Exécution et cessation du marché à forfait

275. Le marché à forfait est un contrat d'entreprise soumis comme tel aux règles applicables à ce contrat (V. *infra,* n° 276). La résiliation du contrat peut obéir à des règles propres (V. *infra* nos 277 s.).

A - Règles générales

276. L'entrepreneur a l'obligation d'exécuter les travaux conformément à l'engagement qu'il a pris et il doit respecter le délai de livraison convenu, sous peine d'être assujetti aux pénalités de retard prévues au contrat et, dans les cas les plus graves, de courir le risque d'une résiliation ou d'une résolution du contrat. Le maître de l'ouvrage est tenu, pour sa part, de payer le prix à l'échéance convenue conformément aux situations et mémoires arrêtés et vérifiés par le maître d'œuvre. Les travaux une fois exécutés donnent lieu à réception. Le prix donne lieu à retenue de garantie selon les modalités exposées précédemment (V. *supra* nos 371 s.) ; son paiement est garanti conformément à l'article 1799-1 du code civil (V. *infra,* nos 379 s.). Un tiers ne peut se prévaloir du caractère forfaitaire du marché ; tel est le cas du bureau d'études qui commet une erreur à l'origine d'un surcoût et doit en répondre (Civ. 3e, 13 févr. 2011, n° 11-25.978, BPIM 2/13, inf. 120). En outre, le caractère forfaitaire du marché n'est pas altéré par un retard dans l'exécution des travaux non imputable au maître de l'ouvrage, et l'entrepreneur ne peut prétendre à une indemnité pour ce retard (Civ. 3e, 10 déc. 2015, n° 14-25.165, RDI 2016. 147).

B - Résiliation du marché

277. Comme tout contrat d'entreprise, le marché à forfait peut être résilié en respectant les règles de droit commun (V. *infra,* n°s 278 s.), il existe néanmoins des règles spéciales (V. *infra,* n°s 282 s.).

1° - Règles de droit commun

278. Le marché à forfait peut être *résilié par le maître de l'ouvrage* (notion maintenue par le nouvel article 1229 du code civil), en cas d'inexécution par l'entrepreneur de ses engagements contractuels. Une clause du contrat peut stipuler la résiliation de plein droit. La norme AFNOR p. 03-001 le prévoit lorsque la force majeure rend impossible la poursuite du chantier (art. 22.2.1), lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier (ce qui implique une mise en demeure préalable, C. civ., nouv. art. 1226 ; l'entrepreneur s'expose à des dommages-intérêts : Civ. 3e, 22 oct. 2008, n° 07-18.204 et Civ. 3e, 18 nov. 2008, n° 07-18.691), lorsqu'il a trompé le maître de l'ouvrage sur la qualité des matériaux ou les conditions d'exécution du marché, lorsqu'il a procédé à une sous-traitance ou à un apport de marché occulte (art. 22.1.2.1).

279. La *résiliation unilatérale* est possible (Civ. 3e, 10 déc. 2014, n° 13-27.332, BPIM 1/15, inf. 32) aux risques de celui qui y procède (V. le nouvel article 1226) ; possible en cas de faute de l'entrepreneur (Civ. 3e, 11 févr. 1998, RDI 1998. 256. – Civ. 3e, 22 oct. 2008, n° 07-18.691, BPIM 1/09, inf. 23. – Civ. 3e, 25 sept. 2012, n° 11-21.825, BPIM 6/12, inf. 438), elle ne prive pas, en principe, le droit de l'entrepreneur au paiement du prix des travaux exécutés, mais elle compromet son droit même au titre des travaux exécutés (Civ. 3e, 7 nov. 1979, RDI 1980. 169. – Civ. 3e, 15 janv. 2008, n° 06-21.457 : perte du droit au paiement de travaux supplémentaires) et l'expose à des dommages-intérêts (Civ. 3e, 22 oct. 2008 et 18 nov. 2008, préc.). Lorsque le maître de l'ouvrage résilie unilatéralement le contrat, c'est à titre de sanction ; les dispositions de l'article 1794 du code civil (V. *infra,* n° 282) n'ont pas vocation à s'appliquer ; mais des arrêts visent ce texte alors même que la résiliation-sanction est en cause (Civ. 3e, 6 févr. 1973, Bull. civ. III, n° 100. – Civ. 3e, 9 mars 1988, Bull. civ. III, n° 55. – Civ. 3e, 15 juin 2000, n° 98-21.011, BPIM 5/00, inf. 321) ; il faut alors supposer qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'entrepreneur (V. *infra,* n° 285). La résiliation unilatérale implique la mise en demeure préalable de l'entrepreneur (C. civ., nouv. art. 1226) sauf urgence (V. Civ. 3e, 23 mai 2012, n° 11-13.011, Bull. civ. III, n° 81, pour une violation des prescriptions en matière de prévention des accidents).

280. La *résiliation* aux torts de l'entrepreneur *peut être judiciaire :* Ainsi, en est-il lorsque le maître de l'ouvrage reproche à l'entrepreneur d'avoir abandonné le chantier sous le prétexte non fondé qu'il aurait refusé de souscrire une police tous risques chantiers et que les risques de crues – dont il connaissait l'existence – auraient aggravé les coûts (Civ. 3e, 11 oct. 2000, n° 98-20.652 : il était allégué que le marché était à forfait). La

résiliation ou la résolution du contrat n'est pas automatique lorsque l'entrepreneur fait l'objet d'un redressement judiciaire (L. 25 janv. 1985, art. 37). Le maître de l'ouvrage doit mettre en demeure l'administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat dans le délai d'un mois, délai qui peut parfois être raccourci, mais qui ne peut être allongé au-delà de deux mois. À l'issue du délai, si l'administrateur n'a pas répondu ou s'il a donné une réponse négative, la résiliation du marché s'opère de plein droit. Le décès de l'entrepreneur, personne physique, entraîne la dissolution du contrat d'entreprise (C. civ., art. 1795). Les ayants droit de l'entrepreneur peuvent réclamer la valeur des ouvrages réalisés par leur auteur sous condition qu'ils soient utiles au maître de l'ouvrage et en proportion du prix convenu (art. 1796 ; V. *supra,* n°s 136 s.). L'article 1228 nouveau du code civil peut soulever une difficulté d'interprétation dans la mesure où il semble laisser une option au juge : prononcer la résolution ou accorder des dommages-intérêts. Nonobstant cette rédaction, il semble que la résiliation par le juge peut encore donner lieu à dommages-intérêts si elle sanctionne une faute.

281. La résiliation du marché peut être *imputable au maître de l'ouvrage* s'il n'exécute pas ses obligations. En pratique, la résiliation sanctionnera le non-paiement des premiers acomptes sur le prix (Civ. 3e, 7 avr. 2009, n° 08-11.987), la renonciation à poursuivre le projet (Civ. 3e, 14 déc. 2004, n° 03-18.350), l'éviction injustifiée de l'entrepreneur (Civ. 3e, 8 févr. 2011, n° 10-10.431 , BPIM 2/11, inf. 115) ou l'ajournement fractionné ou continu du chantier pendant plus de six mois (art. 22.1.3.1 de la norme AFNOR p. 03-001). Dans ce dernier cas, il faut que l'ajournement ou l'interruption soit effectivement imputable au maître de l'ouvrage ; il n'en est pas ainsi lorsque le maître de l'ouvrage n'a commis aucune faute et que l'interruption est imputable à une autre entreprise (Civ. 3e, 11 oct. 2000, n° 98-20.652 . – Civ. 3e, 9 avr. 2008, n° 07-13.572). Si le maître de l'ouvrage résilie le marché à forfait en imputant à tort une faute à l'entrepreneur, il peut se voir imputer cette résiliation et être tenu des obligations contenues dans l'article 1794 du code civil (Civ. 3e, 15 juin 2000, n° 98-21.011 , BPIM 5/00, n° 321). La résiliation, qui peut être judiciaire, ne dispense pas le maître de l'ouvrage de ses obligations envers les autres constructeurs, même si elle est prononcée aux torts réciproques (Civ. 3e, 17 mars 2004, n° 02-17.681 , Bull. civ. III, n° 57). En cas de redressement judiciaire, il appartient à l'administrateur qui dispose de fonds disponibles de décider s'il poursuit ou non le contrat. L'entrepreneur dira, en cas de poursuite, s'il consent ou non des délais de paiement. Si le contrat n'est pas poursuivi, il est résilié de plein droit (L. 1985, art. 37).

2° - Règles spéciales au marché à forfait

282. Texte. - L'article 1794 du code civil prévoit que le maître de l'ouvrage peut « résilier, par simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de

tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ». La résiliation est *unilatérale.* L'article 1794 ne s'applique pas en cas de résiliation judiciaire (Civ. 3e, 17 oct. 1978, RDI 1979. 207). Ce texte, qui n'est pas d'ordre public, est repris dans la norme AFNOR p. 03-001 (art. 22- 1- 3- 2). Le contrat qui s'y réfère y est donc soumis ; pour échapper à ce texte, les parties doivent en écarter expressément l'application et elles peuvent lui préférer une clause réduisant forfaitairement la réparation du préjudice de l'entrepreneur. Cette clause n'est pas une clause pénale, car elle ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation, mais une simple faculté de dédit (Paris, 29 oct. 1992, D. 1993. IR 37).

283. Le maître de l'ouvrage dispose d'un droit de résiliation unilatérale quasi discrétionnaire, dès lors qu'il indemnise l'entrepreneur (Civ. 3e, 6 mars 2002, RDI 2002. 212). Un arrêt laisse entendre que le droit de résiliation unilatérale ne peut s'exercer lorsque les ouvrages sont pratiquement achevés (Civ. 3e, 7 févr. 1976, Bull. civ. III, no 69) ; mais on ne voit pas pourquoi il en serait ainsi puisque, en pratique, la résiliation à ce stade donnerait lieu à paiement intégral du marché ; c'est plutôt l'intérêt du maître de l'ouvrage que l'on a du mal à discerner. Sauf clause contraire, le dédommagement de l'entrepreneur s'entend, comme le dit le texte, des dépenses exposées et des gains attendus. La jurisprudence y ajoute les frais d'amortissement du matériel (Civ. 1re, 18 mars 1963, Bull. civ. I, no 165). L'arrêt du 6 mars 2002 précité prévoit l'indemnisation du « manque à gagner » et des… « autres chefs de préjudice » (dans le même sens : Civ. 3e, 28 mars 2007, no 06-12.137).Selon la jurisprudence, l'indemnité tient compte du gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme (Civ. 3e, 14 mars 2012, no 11-13.266 , BPIM 3/12, inf. 225. – Comp. : Civ. 3e, 3 oct. 2001, no 99-21.414 , BPIM 6/01, inf. 366). Le droit de résiliation unilatérale ne confère pas le droit de suspendre le chantier (Civ. 27 juill. 1914, S. 1914. Somm. 110).

284. L'entrepreneur dont le contrat est résilié ne peut se maintenir sur le chantier. Il doit l'évacuer dans un délai raisonnable. S'il ne le fait pas, il s'expose au paiement d'une indemnité d'occupation.

285. Faute de l'entrepreneur. - Le maître de l'ouvrage peut résilier le marché pour faute. Dans ce cas, l'article 1794 ne s'applique pas. L'entrepreneur ne peut donc prétendre à la réparation liée à l'immobilisation du matériel (Civ. 3e, 17 oct. 1978, RDI 1979. 470) ; même solution si la résiliation est due à une procédure collective (Civ. 3e, 27 mars 1979, RDI 1979. 470). Il arrive cependant que le maître de l'ouvrage exerce la faculté de résiliation unilatérale qu'il tient de l'article 1794 pour sanctionner une faute de l'entrepreneur. Si la faute est caractérisée et qu'elle justifie la résiliation, l'entrepreneur peut être condamné à des dommages-intérêts (Civ. 3e, 9 mars 1988, Bull. civ. III, no 55 ; 8 juill. 1991, Gaz. Pal. 11 févr. 1982. 54) ; on en revient au droit commun de la résiliation pour faute. À l'inverse, si le maître de l'ouvrage résilie le marché en se

fondant sur une faute de l'entrepreneur qui apparaît vénielle, voire inexistante, le juge peut requalifier la résiliation et la fonder sur l'article 1794 (Civ. 3e, 15 juin 2000, no 98-21.011 : l'entreprise avait interrompu les travaux en raison du non-paiement des situations par le maître de l'ouvrage ; V. *supra,* no 255).

§ 3 - Travaux supplémentaires

286. Le marché à forfait n'interdit pas l'exécution de travaux supplémentaires dont le régime est encadré pour éviter la dénaturation du contrat ; ces travaux modifient (V. *infra* nos 287 s.) ou non l'objet du contrat (V. *infra* nos 290 s.).

A - Travaux supplémentaires ne modifiant pas l'objet du contrat

287. Notion. - Il s'agit des travaux qui sont nécessaires pour que l'ouvrage soit solide et conforme à sa destination. Même s'ils ne sont pas prévus au contrat ou si leur importance n'a pas été appréciée à leur juste mesure, l'entrepreneur est tenu de les réaliser, car il supporte l'aléa de l'opération. Ces travaux, nécessaires mais non prévus, sont soit le fruit d'une erreur de l'entrepreneur qui doit en assumer les conséquences (Civ. 3e, 31 oct. 2001, no 00-12.776, RDI 2001. 500) soit la suite de difficultés, généralement liées à l'état du sol, qui n'ont pu être décelées ou envisagées lors de la soumission et qui se révèlent lors de l'exécution. L'entrepreneur ne peut réclamer un supplément de prix pour ces travaux (Req. 20 avr. 1874, DP 1874. 329. – Civ. 3e, 17 juin 1997, BPIM 5/97, no 319 ; V. aussi : Paris, 4 mai 1988, RDI 1988. 299, pour des fondations à renforcer. – Civ. 3e, 21 janv. 1981, RDI 1981. 511 pour un dispositif d'évacuation de fumée oublié). Il lui appartient de prévoir, dans le montant du forfait, tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art (Civ. 3e, 17 nov. 1999, no 98-11.998, BPIM 1/00, no 22). L'entrepreneur ne peut soutenir utilement que les travaux nécessaires ne pouvaient pas être prévus compte tenu de l'état du sol (Civ. 3e, 6 mai 1998, no 96-12.738, Bull. civ. III, no 94, RDI 1998. 371 ; 21 juin 2000, no 98-12.844, BPIM 5/00, no 320 ; 28 févr. 2001, no 99-13.651, BPIM 2/01, no 112. – Civ. 3e, 22 juin 2005, no 03-16.557, BPIM 5/05, inf. 325), d'un aléa économique (Civ. 3e, 20 nov. 2002, no 00-14.423, Bull. civ. III, no 230) ou de la difficulté à apprécier les quantités nécessaires (Civ. 3e, 22 oct. 2008, no 07-18.204). La théorie des sujétions imprévues, appliquée aux marchés publics, n'est pas admise par le juge civil. Un arrêt se réfère à cette notion, mais pour constater qu'en fait, le maître de l'ouvrage avait tacitement accepté les travaux ; il faut bien comprendre cependant que ce n'est pas l'acceptation des travaux qui importe : elle va de soi puisque les travaux sont « nécessaires » ; c'est l'acceptation d'en payer le prix qu'il faut

constater (Civ. 3e, 17 mai 1995, Mon. TP 18 mai 1995. 22, qui est sibyllin sur ce point), étant entendu que, si les travaux nécessaires doivent être exécutés sans surcoût pour le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 8 juin 2005, no 04-15.046, RDI 2005. 440), ce dernier peut toujours consentir à en payer le prix. Un autre arrêt a néanmoins admis que les difficultés manifestement indécelables pour une entreprise hautement spécialisée pouvaient justifier un supplément de prix pour les travaux nécessaires (Civ. 3e, 4 mai 1995, Mon. TP 18 août 1995. 28). Cet arrêt, pour être d'espèce, fait une application nuancée de la force majeure qui ressemble fort à la notion de sujétion imprévue. En outre, il semble que le marché puisse comporter une clause relative au supplément de prix en cas de sujétions imprévues. Cette clause, qui ne fait qu'assouplir les conditions requises en cas de force majeure, n'est pas contraire au forfait qu'elle ne dénature pas. La norme AFNOR p. 03-001 réserve à l'entrepreneur le droit de se faire payer des travaux supplémentaires et urgents qui se révéleraient en cours d'exécution et qui seraient indispensables à la stabilité du bâtiment (art. 11-4). La valeur de cette clause peut cependant se discuter : il faut que les problèmes à l'origine du risque d'instabilité soient manifestement imprévisibles pour un entrepreneur hautement qualifié ; à défaut, le forfait perdrait tout intérêt.

288. Régime. - Sous réserve de ces restrictions encore mal définies, l'entrepreneur s'oblige, sans contrepartie autre que le prix forfaitaire, à exécuter tous les travaux « intrinsèquement nécessaires à la bonne fin de l'ouvrage » (Civ. 3e, 10 oct. 1983, RDI 1984. 186. – Civ. 3e, 17 nov. 1999, no 98-11.998, RDI 2000. 52 ; BPIM 1/00, no 22, à propos d'un mur de soutènement nécessaire). À l'inverse, s'il mène l'opération à bonne fin et qu'il améliore la qualité de l'ouvrage tout en diminuant les quantités de travaux nécessaires, il ne peut prétendre à une réduction du prix, car l'aléa fait partie du forfait (Civ. 3e, 26 mars 1997, no 95-16.086, BPIM 3/97, no 186, 1re esp.). Toutefois, la ligne de partage entre « travaux nécessaires » et « travaux supplémentaires » au sens de l'article 1793 du code civil est difficile à tracer : ainsi, un arrêt décide-t-il que le remplacement d'un escalier préfabriqué, initialement prévu, par un escalier traditionnel à l'instigation du contrôleur technique, implique l'accord du maître de l'ouvrage, alors que l'escalier est un ouvrage nécessaire, et l'erreur initiale de l'entrepreneur est en principe inopposable au maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 11 mars 2008, no 07-10.300, BPIM 3/08, inf. 215, 2e esp.). Il va de soi que si les travaux nécessaires sont soumis au maître de l'ouvrage et que ce dernier consent à en payer le prix, celui-ci est dû.

289. La règle relative aux travaux nécessaires est indépendante de la question de savoir si le marché est soumis aux dispositions de l'article 1793. Elle s'applique à tous les marchés à forfait, y compris celui du sous-traitant.

B - Travaux supplémentaires modifiant l'objet du contrat

290. Notion. - Il s'agit de travaux supplémentaires qui transforment la chose ; ils s'ajoutent ou modifient l'ouvrage prévu (sur la distinction entre travaux nécessaires et travaux supplémentaires, V. *supra,* n° 288). Ces travaux sont soumis à un régime juridique propre résultant de l'article 1793 du code civil (V. sur la distinction entre la modification et la dénaturation du marché à forfait, BOUBLI, article préc. RDI 2002. 482). L'article 1793 tend à protéger le maître de l'ouvrage qui, ayant contracté à forfait, est captif de l'entrepreneur qui peut être tenté de lui imposer des travaux supplémentaires : il se borne à exiger un ordre écrit du maître de l'ouvrage ; mais il ne précise pas les modalités de fixation du *prix* des travaux supplémentaires. Lorsqu'un ordre écrit est donné, les parties conviennent en général du coût des travaux en cause et l'accord les lie (Civ. 3e, 11 oct. 2000, n° 98-21.509, BPIM 1/01, inf. 30) ; à défaut, ou si l'obligation de payer les travaux supplémentaires résulte de leur ratification (V. *infra,* n° 300), ou d'un bouleversement de l'économie du marché (V. *infra,* n° 301), le prix est fixé judiciairement.

ACTUALISATION

260, 262, 290 s. Apurement des comptes d'un marché à forfait. - La cour d'appel a exactement retenu que les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartées dès lors que les dispositions de l'article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF p. 03.001 (Civ. 3e, 3 déc. 2020, n° 19-25.392, D. actu. 11 janv. 2021, obs. G. Casu et S. Bonnet).

261, 264, 290. Application de la notion de marché forfaitaire à une partie des travaux convenus. - Un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus (Civ. 3e, 25 juin 2020, n° 19-11.412, D. actu. 23 juill. 2020, obs. G. Casu et S. Bonnet).

1° - Marchés soumis à l'article 1793 du code civil

a. - Domaine d'application du texte

291. Selon l'article 1793, « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte des augmentations de la main-d'œuvre, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ». Le texte est d'application limitée : il concerne le contrat d'entreprise conclu avec « le propriétaire » portant sur la construction « à forfait » d'un « bâtiment ».

292. 1° Marché à forfait. - C'est une condition nécessaire. Il est cependant possible d'étendre la règle aux marchés non forfaitaires par une clause du contrat faisant application volontaire du texte, si l'on y trouve un intérêt.

293. 2° Marché principal. - La loi ne s'applique qu'au marché principal, c'est-à-dire celui conclu par le maître d'ouvrage. Il semble qu'il soit indifférent que le maître de l'ouvrage soit propriétaire ou qu'il soit seulement titulaire du droit de construire (preneur à bail à construction). Il suffit que le contrat constitue le marché principal. Une question est cependant soulevée par la maîtrise d'ouvrage déléguée, à la lumière d'un arrêt de la Cour de cassation. Alors que le maître d'ouvrage délégué avait donné l'ordre d'exécuter des travaux supplémentaires, l'arrêt décide que le coût ne pouvait en être réclamé au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur connaissait la qualité (Civ. 3e, 19 juill. 2000, n° 98-22.075). Cette application stricte du régime du mandat n'est peut-être pas adaptée à la *maîtrise d'ouvrage déléguée* surtout dans les opérations complexes pour lesquelles le délégataire s'oblige à faire réaliser un programme à coût et délai prédéterminés : le maître d'ouvrage délégué est donneur d'ordre, et cela suffit à obliger le déléguant sauf à faire le compte entre les parties à la délégation en fin de programme. La Cour de cassation laisse cependant clairement entendre dans son arrêt que le texte ne s'appliquerait qu'aux rapports directs entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. Le *sous-traité* n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1793 (Civ. 3e, 15 févr. 1983, Bull. civ. III, n° 44 ; 19 déc. 1984, RDI 1985. 255 ; 18 juin 2003, BPIM 5/03, inf. 285 ; comp. : Civ. 3e, 8 avr. 2008, n° 07-11.759) ; mais les parties peuvent conventionnellement se soumettre à ce texte (Civ. 3e, 5 juin 1996, n° 94-16.902 , BPIM 4/96, n° 272. – Civ. 3e, 16 mars 2004, n° 02-21.268 ; 16 janv. 2007, n° 05-20.160 , RDI 2007. 275).

294. La loi vise indifféremment le contrat de *l'architecte et de l'entrepreneur.* L'article 1793 remontant au code civil, l'explication est à rechercher dans le fait qu'alors les professions d'architecte et d'entrepreneur n'étaient pas différenciées. Aujourd'hui, l'architecte ne peut, théoriquement, prendre à son compte la réalisation de l'ouvrage même s'il la sous-traite. Sous réserve du bien-fondé de cette interdiction, très contestable depuis que la société d'architecture peut prendre la forme commerciale, le marché de travaux n'est pas le marché de l'architecte. Si ce dernier s'oblige à forfait, c'est simplement pour la fixation de ses honoraires ou pour des missions n'impliquant pas la réalisation et donc la construction du bâtiment, par exemple un contrat de pilotage à forfait avec une entreprise spécialisée (Civ. 3e, 6 déc. 2000, n° 99-13.429), ce qui ne relève pas de l'article 1793 (Versailles, 26 oct. 1989, RDI 1990. 81). La Cour de cassation a cependant appliqué l'article 1793 au contrat de maîtrise d'œuvre stipulant des honoraires forfaitaires (V. *supra,* n° 261).

295. 3° Construction d'un bâtiment. - L'ouvrage doit être un *bâtiment.* La notion de bâtiment se rencontrait aussi en garantie décennale et en assurance construction ; elle

a pratiquement disparu dans ces disciplines avec l'ordonnance n° 2005-568 du 8 juin 2005. L'ordonnance rompt brutalement avec l'esprit du code civil qui voulait protéger le maître de l'ouvrage qui s'obligeait à forfait à la fois contre le risque de voir l'entrepreneur procéder à des « économies excessives » préjudiciables à la qualité de la construction (d'où l'article 1792 instituant la garantie décennale) et contre la tentation de céder aux sollicitations de l'entrepreneur pour s'engager au-delà du forfait une fois le contrat conclu (objet de l'article 1793). L'extension de la garantie décennale ne laisse subsister le débat sur la notion de « bâtiment » qu'en ce qui concerne le champ d'application de l'article 1793. Elle y soulève moins de difficultés ; l'idée qui domine est celle qui, conformément au bon sens, tient le bâtiment pour l'ouvrage qui sert d'abri à l'homme. Ainsi, ont été exclus du champ de l'article 1793 des bâtiments flottants (Com. 16 mars 1963, S. 1963. 288), un court de tennis (Civ. 3e, 9 oct. 1973, D. 1973. IR 158), des cuves de réservoir (Civ. 3e, 10 févr. 1976, D. 1976. IR 145), une piscine (Civ. 3e, 17 janv. 1984, Gaz. Pal. 1984. 1. Pan. 133, obs. Jestaz), un bassin pour orques avec tribunes (Civ. 3e, 29 oct. 2003, n° 02-13.460, Bull. civ. III, n° 185).

296. Le texte vise la construction du bâtiment, mais il s'applique tant à l'*édification* de celui-ci qu'aux *travaux sur existant* si ce sont des travaux de construction. Ainsi, il a été jugé que sont des travaux de construction des travaux relatifs au lot électricité d'un immeuble en cours d'édification (Civ. 3e, 3 juill. 1991, n° 89-20.299, Bull. civ. III, n° 200 ; 11 mars 1998, BPIM 3/98, n° 187) ; la même solution a été retenue pour des opérations de traitement de l'amiante dans un immeuble (Versailles, 26 sept. 2005, RDI 2006. 213). Des travaux d'aménagement intérieurs ne sont pas, en général, considérés comme relevant de l'article 1793, sans que l'on discerne le motif de cette exclusion qui est très discutable (Civ. 3e, 15 oct. 1970, Gaz. Pal. 1971. Somm. 31, installation d'un chauffage central. – Civ. 3e, 23 juin 1999, BPIM 4/99, n° 286, travaux intérieurs sur cloisons et installation d'équipements). Il semble résulter d'un arrêt que les travaux doivent affecter le gros œuvre ou les pièces maîtresses de l'édifice (Civ. 3e, 15 déc. 1982, Bull. civ. III, n° 254) ; mais cette approche paraît trop restrictive. D'ailleurs, les parties peuvent volontairement soumettre le marché aux dispositions de l'article 1793 (pour des VRD : Civ. 3e, 6 déc. 1989, RDI 1990. 82 ; 28 févr. 2001, BPIM 2/01, n° 112 ; 18 juill. 2001, n° 1253 FS-D ; pour des travaux de rénovation : Civ. 3e, 31 mai 2000, BPIM 4/00, n° 240 ; rappr. Civ. 3e, 31 oct. 2001, RDI 2001. 500 ; de tuyauterie : Civ. 3e, 2 mars 2004, n° 02-20.147 ; pour un sous-traité : Civ. 3e, 16 janv. 2007, n° 05-20.160, RDI 2007. 275).

b. - Conditions résultant du texte

297. 1° Autorisation écrite du maître de l'ouvrage. - Les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement que si le maître de l'ouvrage les a autorisés par écrit (Civ. 3e,

6 déc. 1989, Gaz. Pal. 1989. Pan. 36 ; 24 janv. 1990, RDI 1990. 370 ; 18 juin 1997, BPIM 5/97, n° 319 ; 19 juill. 2000, n° 1229 FS-D ; 3 avr. 2002, RDI 2002. 212 ; 12 juin 2002, RDI 2002. 391. – Civ. 3e, 8 avr. 2008, n° 07-11.759. – Civ. 3e, 8 avr. 2008, n° 07-11.759, BPIM 3/08, inf. 215). L'écrit doit être dénué d'équivoque (Civ. 3e, 30 juin 1981, RDI 1982. 382 ; 20 avr. 1988, Mon. TP 9 sept. 1988). L'écrit doit émaner du maître de l'ouvrage lui-même et non de l'architecte, à moins que ce dernier soit mandaté (Civ. 3e, 4 nov. 1993, RDI 1994. 248 ; 17 févr. 1999, BPIM 3/99, n° 210 ; V. Civ. 3e, 30 janv. 2007, n° 05-20.927, qui subordonne les travaux supplémentaires à la conclusion d'un avenant, ce qui implique l'autorisation écrite du maître de l'ouvrage et l'accord de l'entrepreneur. – Civ. 3e, 24 mai 2006, n° 02-10.840, qui déclare des travaux inopposables au maître de l'ouvrage, des travaux dont l'ordre écrit n'est signé que par l'architecte alors que le contrat prévoit également celle du maître de l'ouvrage). Un arrêt retient le mandat apparent de l'architecte, ce qui est fort rare (Civ. 1re, 10 déc. 1996, RDI 1997. 233). L'ordre écrit émanant de l'architecte qui, lui-même, n'a pas reçu mandat écrit est insuffisant et il n'oblige que lui seul envers l'entrepreneur (Civ. 3e, 23 janv. 1979, RDI 1979. 339 ; 21 mars 1984, RDI 1984. 412 ; Civ. 3e, 26 nov. 1994, n° 93-11.278, RDI 1995. 104) ; le fait que des travaux sont réalisés par l'entreprise à l'initiative de l'architecte qui lui en a fait la commande, ne suffit pas à obliger le maître de l'ouvrage qui n'a pas ratifié les travaux (Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-16.673 ; rappr. à propos d'un marché dont l'arrêt ne dit pas qu'il est à forfait : Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-17.328). Un arrêt a jugé que l'ordre écrit du maître d'ouvrage délégué ne suffisait pas à obliger le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 19 juill. 2000, n° 98-22.075). La loi institue un mode de preuve renforcé qui exclut le droit commun de la preuve par production d'un commencement de preuve par écrit (Civ. 3e, 25 avr. 1972, JCP 1972. II, n° 17145 ; V. sur la discussion, BOUBLI, article préc. *in* RDI 2002. 482).

298. En l'absence d'autorisation écrite et sauf ratification par le maître de l'ouvrage ou bouleversement de l'économie du contrat, l'entrepreneur ne peut réclamer le prix en se fondant sur l'enrichissement injuste, car l'enrichissement est ici causé (Civ. 5 nov. 1934, DH 1934. 587. – Civ. 3e, 23 avr. 1974, Bull. civ. III, n° 162 ; 1er févr. 1984, Gaz. Pal. 1984. 1. Pan. 133, obs. Jestaz). Il s'expose également à la démolition des travaux supplémentaires à ses frais. Mais cette sanction est discutée : certains auteurs ont soutenu que l'autorisation se borne à conditionner le paiement. Lorsque l'immeuble est vendu en l'état futur, les accédants peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation écrite (Civ. 3e, 28 févr. 1984, RDI 1984. 312). L'autorisation doit viser les travaux, mais pas nécessairement le prix, dont il suffit, selon le texte de la loi, qu'il soit « convenu ». Une jurisprudence ancienne se contente d'un accord sur les modalités de fixation du prix ; il n'est pas nécessaire qu'un avenant en précise le montant, l'accord sur le prix obéissant au droit commun de la preuve (Req. 13 avr. 1860, DP 1861. 105. – Civ. 1re, 18 juin 1963, Bull. civ. I, n° 323). L'idée est parfois émise aujourd'hui que les travaux

supplémentaires relèvent d'un nouveau marché soumis à des règles propres ; mais cette suggestion est contestable en raison de l'existence de relations contractuelles en cours soumises à un régime spécifique ; la Cour de cassation semble, pour l'heure, réservée (Civ. 3e, 26 juin 2002, BPIM 5/02, inf. 319). Toutefois, si le contrat précise que les travaux supplémentaires seront subordonnés à un avenant en fixant le prix, il faut s'en tenir à l'accord des parties (Civ. 3e, 11 oct. 2000, no 98-21.509).

299. Il est possible de *renoncer à la formalité* de l'autorisation écrite (Civ. 3e, 24 mai 1979, Bull. civ. III, no 323) et le juge n'est pas tenu de soulever d'office l'application de l'article 1793. S'il le fait, il doit respecter le contradictoire (Civ. 3e, 21 juin 2000, no 98-12.844).

300. 2o Ratification des travaux par le maître de l'ouvrage. - Lorsque les travaux sont exécutés sans autorisation écrite du maître de l'ouvrage, la jurisprudence admet que l'entrepreneur peut, néanmoins, en obtenir le paiement si le maître de l'ouvrage les a ratifiés. Les modalités de cette ratification sont incertaines. Le maître de l'ouvrage ratifie les travaux si, une fois exécutés, il les a acceptés en donnant un accord exprès et non équivoque (Civ. 3e, 18 juin 1997, BPIM 5/97, no 319 ; 8 avr. 1998 et 3 juin 1998, RDI 1998. 372 ; 31 mai 2000, no 98-18.736, BPIM 4/00, no 241 ; 15 mai 2002, RDI 2002. 391 ; 14 févr. 2007, RDI 2007. 275, 1re esp. ; 8 avr. 2008, no 07-11.759 ; Civ. 3e, 2 juin 2016, no 15-16.673). Il est admis également que la ratification peut résulter d'un comportement à l'achèvement révélant sans équivoque l'intention du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux (Civ. 3e, 18 juin 1997, BPIM 5/97, no 319, 1re esp. – Civ. 3e, 13 févr. 2007, RDI 2007. 275, 2e esp.) ; elle ne peut toutefois résulter du silence du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 26 sept. 2006, no 05-18.070, BPIM 1/07, inf. 29), ni de la circonstance que le mémoire de l'entrepreneur n'ait pas été contesté dans le délai prévu par la norme AFNOR à laquelle le marché se réfère (Civ. 3e, 11 mai 2006, no 04-18.092 ; 24 mars 2009, no 08-12.768). Toutefois, les circonstances dans lesquelles la ratification est retenue dans ce dernier cas restent imprécises, d'autant que la jurisprudence semble admettre la ratification par acceptation expresse du maître de l'ouvrage dans des forfaits non soumis à l'article 1793 (Civ. 3e, 21 nov. 2000, BPIM 1/01, no 29, pour un sous-traité. – Civ. 3e, 27 sept. 2000, BPIM 6/00, no 367, 1re esp., pour des travaux d'électricité d'une usine, dont il est permis de se demander s'ils sont des travaux de bâtiment. – Civ. 3e, 27 sept. 2000, no 98-19.680, pour des travaux de peinture et de revêtements muraux d'un hôtel, qui sont des travaux d'aménagement intérieurs). Ainsi, tandis que nombre d'arrêts déduisent l'acceptation du comportement du maître de l'ouvrage à la réception (Civ. 3e, 11 juin 1981, RDI 1982. 84 ; 31 mai 2000, préc.), un arrêt a écarté la ratification alors que certains travaux avaient été autorisés par le maître de l'ouvrage, que d'autres étaient connus de lui et approuvés, que la réception avait eu lieu sans réserve et que les locaux étaient

occupés depuis plus de deux ans lorsque la contestation a pris un tour judiciaire (Civ. 3e, 20 juin 2001, BPIM 4/01, n° 256 ; V. dans le même sens, alors que la réception avait été prononcée sans réserve : Civ. 3e, 11 mars 2008, n° 07-10.300, BPIM 3/08, inf. 215, 2e esp. ; rappr. : Civ. 3e, 12 juin 2002, n° 01-00.710, Bull. civ. III, n° 135).

301. 3° Bouleversement de l'économie du marché. - Alors même que les travaux n'ont pas été autorisés par écrit et n'ont pas été ratifiés, l'entrepreneur peut en obtenir le paiement si ces travaux « bouleversent l'économie du marché » et que le maître de l'ouvrage n'a pu ignorer leur exécution (Civ. 3e, 4 déc. 2002, n° 01-11.105, BPIM 1/03, inf. 24, Bull. civ. III, n° 86 ; 26 nov. 2003 n° 02-13.875 ; 8 avr. 2008, n° 07-11.759) ; mais un arrêt, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié si les travaux litigieux avaient été commandés ou ratifiés, laisse subsister un doute sur l'autonomie du « bouleversement de l'économie du marché » (Civ. 3e, 27 sept. 2006, n° 05-13.808, BPIM 1/07, inf. 30 ; V. depuis, Civ. 3e, 8 avr. 2008, n° 07-11.759, BPIM 3/08, inf. 215, 1re esp., préc.). Le bouleversement est caractérisé par l'ampleur des travaux supplémentaires ou par l'exécution de travaux d'une nature différente de ce qui a été prévu à l'origine (Civ. 3e, 17 mars 1982, RDI 1982. 382 : atelier devenu un bureau et sous-sol un garage ; 26 févr. 1985, RDI 1985. 574 : adjonction d'une patinoire. – Civ. 3e, 14 févr. 1996, BPIM 3/96, n° 196, qui souligne « l'ampleur » des modifications ; 20 janv. 1999, Bull. civ. III, n° 241 ; 31 mai 2000, BPIM 4/00, n° 241). Mais les arrêts ne se bornent pas à sanctionner la différence sensible de nature des travaux (Civ. 3e, 8 mars 1995, n° 93-13.659, Bull. civ. III, n° 73). Ils mettent aussi en exergue leur coût (Civ. 3e, 14 févr. 1996, BPIM 3/96, n° 196 ; 12 mars 1997, n° 95-10.904, Bull. civ. III, n° 54 ; 12 juin 2002, n° 00-142.56 ; 26 juin 2002, n° 00-19.265, arrêts cités sous Civ. 3e, 2 juill. 2002, RDI 2002. 392. – Comp. : Civ. 3e, 27 sept. 2006, n° 05-13.808, BPIM 1/07, inf. 30). Un arrêt a même jugé que des modifications multiples mais mineures pouvaient, en raison de leur coût, caractériser un bouleversement de l'économie du marché (Civ. 3e, 11 oct. 2000, n° 97-22.253, marché : 807 000 F à l'époque ; travaux supplémentaires : 570 000 F). Il avait été jugé que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier l'existence d'un bouleversement de l'économie du marché et d'allouer une provision (Civ. 3e, 3 févr. 1999, BPIM 2/99, n° 130). Mais un arrêt en a décidé autrement, ce qui peut se justifier lorsque le bouleversement est manifeste et que le marché perd « son caractère forfaitaire initial » (Civ. 3e, 20 juin 2002, RDI 2002. 213).

302. La notion de *« bouleversement dans l'économie du marché »* peut connaître une illustration particulière avec le nouvel article 1195 du code civil qui prend en considération les « circonstances imprévisibles » qui rendent excessivement onéreuse l'exécution du contrat pour la partie qui n'en avait pas assumé le risque. Le forfait implique-t-il une acceptation du risque par l'entrepreneur, excluant l'application de ce

texte ? Conviendra-t-il au contraire de considérer que les sujétions normalement imprévues dans un marché, fut-il à forfait, ouvrent un droit à renégociation ou à résolution au sens du nouveau texte ?

2° - Marchés non soumis à l'article 1793

303. Droit commun. - Ces marchés échappent à la nécessité d'une autorisation écrite, à moins que les parties aient décidé de faire une application volontaire du texte par une clause contractuelle (pour un sous-traité : Civ. 3e, 5 juin 1996, n° 94-16.902, BPIM 4/96, n° 272 ; V. aussi *supra,* n° 264). Les travaux supplémentaires ne peuvent cependant être décidés unilatéralement par l'entrepreneur. Celui-ci doit obtenir l'accord du maître de l'ouvrage et établir qu'il les a commandés. La règle, qui s'applique aux marchés non forfaitaires (Civ. 3e, 11 févr. 2009, n° 08-10.813, RDI 2009. 241, obs. Boubli) s'impose, *a fortiori,* au marché à forfait qui ne relève pas de l'article 1793. La preuve de cet accord se fait conformément au droit commun de la preuve résultant désormais des nouveaux articles 1353 et suivants ; en particulier, si le maître de l'ouvrage est un commerçant, elle est administrée librement. Toutefois, plusieurs arrêts, qui ne se réfèrent pourtant pas à l'article 1793, exigent néanmoins que soit rapportée la preuve d'une acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage (*pour un sous-traité :* Civ. 3e, 21 nov. 2000, BPIM 1/01, n° 29 ; 28 nov. 2001, BPIM 1/02, inf. 30, qui se contente d'un faisceau d'indices suffisants ; 8 avr. 2008, n° 07-11.759 ; *pour l'électricité d'une usine :* Civ. 3e, 27 sept. 2000, BPIM 6/00, n° 367, 1re esp. ; *pour des travaux de peinture et de revêtements muraux intérieurs,* Civ. 3e, 27 sept. 2000, n° 98-19.680). Il est probable qu'il suffise que le maître de l'ouvrage ait expressément commandé les travaux ou qu'il les ait acceptés sans équivoque après exécution (Civ. 3e, 11 févr. 2009, n° 08-10.813. – Civ. 3e, 11 janv. 2011, n° 10-12.265, BPIM 2/11, inf. 116. – Civ. 3e, 29 janv. 2013, n° 10-25.705. – Civ. 3e, 7 juill. 2015, n° 13-23.620, BPIM 5/15, inf. 316. – Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-17.328 qui valide les travaux modificatifs en relevant que le « maître d'œuvre a joué un rôle actif »). Un arrêt se prononçant sur une convention de pilotage à forfait entre un architecte et une entreprise spécialisée a cassé une décision de cour d'appel qui avait retenu le bouleversement de l'économie du marché pour condamner l'architecte au paiement du supplément de prix correspondant à des dépenses supplémentaires ; la cassation n'est pas prononcée au motif que le bouleversement n'avait pas lieu d'être retenu, mais parce que les dépenses étaient imputables au maître de l'ouvrage non partie au contrat de pilotage (Civ. 3e, 6 déc. 2000, n° 99-13.429). Il semble que rien ne s'opposerait à l'application de la jurisprudence sur le bouleversement de l'économie du marché aux contrats à forfait non soumis à l'article 1793, alors que cette condition n'est pas nécessaire, ce qui soulève la question du pouvoir modificateur du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur dans les marchés privés (V. BOUBLI, article préc., RDI 2002. 482).

ACTUALISATION

303. Travaux supplémentaires : nécessité d'une preuve par écrit. - La preuve de la commande de travaux supplémentaires doit être rapportée par écrit si leur montant excède 1 500 euros, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage non commerçant (Civ. 3e, 17 nov. 2021, n° 20-20.409, D. actu. 9 déc. 2021, obs. C. Dreveau).

Art. 3 - Autres marchés privés

304. Si l'on met à l'écart certains marchés réglementés (CCMI, marchés soumis à des règles inspirées des marchés publics : HLM, SNCF, organismes de sécurité sociale…), la pratique connaît, outre le marché à forfait, déjà étudié, le marché au métré (V. *infra,* nos 305 s.), le marché sur dépenses contrôlées (V. *infra,* nos 309 s.) et le marché associant différents systèmes (lots au métré, lots à forfait). La norme AFNOR p. 03-001 de décembre 2000 le rappelle (art. 2-1). On peut y ajouter le marché « à maximum », étant relevé que la liberté contractuelle autorise toutes les adaptations (V. *infra,* nos 311 s.).

§ 1er - Marché sur devis ou au métré

305. Il s'agit d'un marché par lequel les parties conviennent d'un prix unitaire au mètre carré qu'elles fixent pour chaque catégorie de travaux (bordereaux) ou en se référant aux séries de prix publiées par différents organismes. Les séries de prix de référence étaient en général celles publiées par l'Académie d'architecture. Mais le Conseil de la concurrence a condamné cette publication (Décis. Cons. conc. n° 97-D.41 du 30 juill. 1997 et n° 99-D-08 du 2 févr. 1999).

306. Ce marché est caractérisé par la relative indétermination du prix. Le caractère déterminé ou déterminable du prix posé par l'article 1129 du code civil ne concerne pas le contrat d'entreprise (Civ. 1re, 20 févr. 1996, n° 94-14.074, Bull. civ. I, n° 91) et il n'est plus guère exigé même dans certaines ventes (Cass., ass. plén., 1er déc. 1995, Bull. civ., n° 9). Le contrat d'entreprise étant présumé à titre onéreux (Paris, 10 déc. 1998, RDI 1999. 254), il existe alors même qu'aucun accord n'est intervenu sur le montant des travaux. La difficulté sera alors d'établir l'étendue des obligations des parties. Pour éviter l'arbitrage systématique du juge, il importe donc de décrire les ouvrages à réaliser, les quantités à exécuter et le prix de base retenu. Un prix global peut être donné à titre « indicatif » ; le prix réel sera fonction des ouvrages

effectivement réalisés, et la responsabilité de l'entrepreneur ne sera retenue que si le dépassement est manifestement excessif (Civ. 3e, 22 avr. 1971, Bull. civ. III, no 260).

307. Le prix est calculé après un métré ; on multiplie le prix unitaire par les quantités réalisées. Lorsqu'il est fait référence à des séries de prix, celles-ci tiennent compte d'une quantité moyenne de travaux. Si les travaux objet du marché ont une certaine importance, il est d'usage de prévoir des rabais (Com. 19 juin 1958, Bull. civ. IV, no 260).

308. Les dispositions de l'article 1793 du code civil ne sont pas applicables au marché non forfaitaire (Com. 6 mars 1963, D. 1963. 501. – Civ. 1re, 16 déc. 1964, D. 1965. 347 ; CA Alger, 26 juin 1951, JCP 1953. II. 7642). Le marché au métré autorise implicitement ou explicitement le maître de l'ouvrage à augmenter ou à réduire les quantités de travaux dans le respect, toutefois, de l'objet du contrat. En l'absence d'accord du maître de l'ouvrage, le droit commun des contrats s'applique. L'entrepreneur doit exécuter les travaux prévus au devis sans pouvoir réclamer un supplément de prix par rapport au prix convenu (Civ. 3e, 24 oct. 2006, no 05-20.588). Il peut refuser des modifications excessives au projet primitif. Si le devis descriptif est clair, les travaux supplémentaires ou modificatifs ne sont opposables au maître de l'ouvrage que s'il y a consenti : un arrêt exige que ces travaux aient été commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution (Civ. 3e, 11 févr. 2009, no 08-10.813 ; V. aussi : Civ. 3e, 21 juin 2005, no 04-12.259 , RDI 2005. 441). Toutefois, la preuve n'est pas administrée dans les formes et conditions posées à l'article 1793, mais conformément au droit commun (V. *supra,* no 303).

§ 2 - Marché sur dépenses contrôlées

309. Le marché sur dépenses contrôlées est une variété de marché sur devis : le prix unitaire donne lieu à contrôle portant sur ses divers éléments de calcul (main-d'œuvre, matériaux, transport, gardiennage) ; il est augmenté d'un pourcentage pour les frais généraux, impôts et bénéfice. Impliquant des justifications produites par l'entrepreneur, il a souvent pour contrepartie la prise en considération des sujétions imprévues, qui augmentent le coût des travaux. Le marché sur dépenses contrôlées se rencontre lorsque aucun prix global indicatif n'est ou ne peut être fourni (Civ. 3e, 19 févr. 1992, no 90-18.583 , Bull. civ. III, no 49).

310. En aucun cas, les sujétions nouvelles ne peuvent justifier une fixation unilatérale et excessive du prix ; sauf stipulation contraire, seules les sujétions « imprévues » pour un constructeur qualifié justifient leur prise en compte pour le calcul du prix. Il ne faut pas ignorer le risque de cette situation : si le prix n'a pas été préalablement fixé, un contentieux sur son montant débouchera sur le coût des sujétions liées à l'exécution.

L'entrepreneur ne peut laisser le maître de l'ouvrage dans l'ignorance totale de l'état du sol ; il doit l'informer des études qu'il a faites ; si un prix « anormal » n'est pas dû à des sujétions manifestement imprévues mais à des études insuffisantes, l'entrepreneur ne pourrait tirer parti de ces sujétions pour se soustraire à ses obligations essentielles.

§ 3 - Marché « à maximum »

311. C'est un marché sur devis qui comporte un prix plafond. Ce prix n'est pas forfaitaire et il donne lieu à un contrôle du maître de l'ouvrage sur le coût réel des travaux : si ce coût est supérieur au prix plafond, le maître de l'ouvrage ne doit que le prix plafond ; s'il est inférieur, le maître de l'ouvrage ne doit que le prix réel.

Section 4 - Cession de marché, sous-traitance, action directe

312. Le contrat d'entreprise est un marché qui peut faire l'objet d'une cession (V. *infra,* n° 313), ou de la sous-traitance de certains lots attribués aux prestataires (V. *infra,* n°s 314 s.). Le droit positif connaît aussi l'action directe des ouvriers contre le maître de l'ouvrage, aujourd'hui peu pratiquée (V. *infra,* n°s 376 s.).

Art. 1er - Cession de marché

313. Notion. - Dans le régime antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, la cession de marché, qui est une opération plus rare que la sous-traitance, est une substitution d'entreprises dans l'exécution des travaux qui implique, en principe, l'accord du maître de l'ouvrage (norme p. 03-011, art. 01.72 ; p. 03-001 de 1980, art. 01.61 ; la norme p. 03-001 de décembre 2000 ne vise guère la cession de marché). Si la cession intervient sans son autorisation, le maître de l'ouvrage peut demander l'exécution forcée du contrat à son titulaire ou la résiliation de celui-ci. L'accord du maître de l'ouvrage, s'il est donné, n'emporte pas renonciation aux droits qu'il tient du marché (H. L. J. MAZEAUD, Leçons, t. 2, n° 1194-2° ; Req. 24 janv. 1876, DP 1876. 1. 262. – Paris 28 juill. 1885, DP 1886. 2. 246). L'accord peut être exprès ou tacite (sur un marché ayant fait l'objet d'un apport en société : Civ. 3e, 3 févr. 1876, Bull. civ. III, n° 44 ; sur l'action en paiement du cessionnaire contre le maître de l'ouvrage : Civ. 1re, 27 mai 1963, *ibid.* I, n° 281. – Civ. 3e, 14 nov. 1973, Gaz. Pal. 1974. 1. Pan. 14. – Com. 11 juin 1976, Bull. civ. IV, n° 196). La cession peut être intégrale mais il faut veiller à ce que les dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 propres aux cessions des créances relatives au marché soient respectées. Négligée par le code civil

de 1804, la cession de contrat est à présent prévue par les articles 1216 et suivants du code civil, issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Ces textes ont vocation à s'appliquer aux cessions de marché qui sont conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. En substance, on retiendra que *la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité* (C. civ., art. 1216, dern. al.) ; que l'accord du cédé (en pratique le maître de l'ouvrage) est nécessaire : il libère le cédant, s'il est expressément donné en ce sens, à défaut de quoi le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat (C. civ., art. 1216-1) ; que les exceptions peuvent être opposées dans les conditions prévues à l'article 1216-2 du code civil et que le régime des sûretés relève de l'article 1216-3 du même code.

Art. 2 - Sous-traitance

314. Notion. - La sous-traitance est une forme d'externalisation des activités d'une entreprise qui s'accompagne de prestations servies en retour par le prestataire. C'est une opération économique. Elle devient une opération juridique spécifique lorsqu'elle se réalise par un sous-contrat. Lorsque l'externalisation concerne des tâches sans rapport avec l'activité économique de l'entreprise (entretien de locaux), il n'y a pas sous-contrat et, par conséquent, il n'y a pas, juridiquement, sous-traitance, même si la tendance doctrinale est parfois contraire, notamment dans les rapports du travail. Lorsque l'externalisation s'accompagne d'une prestation de services en relation avec l'activité économique de l'entreprise, la sous-traitance s'identifie au mécanisme d'externalisation et ne désigne pas, en soi, l'acte juridique qui y contribue : la société tierce peut en effet fournir des services ou des biens, c'est-à-dire conclure un contrat d'entreprise ou une vente. La sous-traitance se borne alors à désigner, indépendamment du contrat qui lui sert de support, le fait de confier à un tiers ce que l'on ne veut ou ne peut pas traiter soi-même. On a tendance à qualifier cette opération de « sous-traitance industrielle ». Il s'agit en réalité, tout simplement, d'une sous-traitance susceptible de prendre des formes juridiques variables (vente, louage de chose, entreprise, mandat, société…) et d'avoir des objets divers (main-d'œuvre, matériel, services avec ou sans rapport avec l'activité économique…). À l'opposé, il existe une sous-traitance réglementée par la loi du 31 décembre 1975 caractérisée par deux conditions cumulatives : sous-contrats de même nature que le contrat principal ; contrat principal d'entreprise qu'il soit constitutif d'un marché privé ou d'un marché public (art. 1er de la loi). C'est cette *sous-traitance de marché* qui retiendra ici l'attention. La loi du 31 décembre 1975 la définit comme l'opération par laquelle « un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage » (L., art. 1er). Il peut y avoir sous-traitance en chaîne. Les règles posées par la loi de 1975 sont d'ordre public (art. 12 et 15). La loi du 31 décembre 1975 a été modifiée dans plusieurs de ses dispositions par la loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001

(JO 12 déc.). Le régime de la sous-traitance dans les marchés publics relevait de l'article 112 du code des marchés publics, dans ses dispositions issues du décret n° 2005-649 du 6 juin 2005 portant code des marchés publics (code modifié et complété par les décrets n° 2008-1334 du 17 déc. 2008, nos 2008-1335 et 2008-1356 du 19 déc. 2008, n° 2008-1550 du 31 déc. 2008) et des décrets n° 2002-231 et 2002-232 du 21 février 2002 (JO 22 févr. ; V. ABBATUCCI et SABLIER, Sous-traitance des marchés publics…, RDI 2002. 109). L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, s'appliquent désormais pour les consultations engagées et les avis d'appel à la concurrence publiés à compter du 1er avril 2016. Les articles 133 et suivants du décret organisent la sous-traitance en application de l'article 62 de l'ordonnance qui renvoie à la loi du 31 décembre 1975. L'article L. 2323-16 du code du travail contraint le donneur d'ordre qui procède à une restructuration à informer les sous-traitants, des incidents sur le volume d'activité ou d'emploi de l'entreprise sous-traitante. La loi du 31 décembre 1975 est une loi de police ; elle s'applique dès lors qu'un sous-traitant intervient dans la construction d'un immeuble en France (Cass., ch. mixte, 30 nov. 2007, n° 06-14.006, BPIM 1/08, inf. 26. – Civ. 3e, 30 janv. 2008, n° 06-14.641, BPIM 2/08, inf. 27. – Civ. 3e, 8 avr. 2008, n° 07-10.763, RJDA 8-9/08, n° 907. – V. auparavant, *contra* : Civ. 1re, 23 janv. 2007, n° 04-10.897, Bull. civ. I, n° 33). La sous-traitance est réglementée par la loi de 1975. Il convient de préciser quel est le contrat qui en relève (V. *infra,* nos 315 s.), les règles de paiement du sous-traitant qui s'en évincent (V. *infra,* nos 341 s.) et les rapports créés par la sous-traitance (V. *infra,* nos 362 s.).

§ 1er - Contrat relevant de la sous-traitance réglementée

315. Le contrat relevant de la loi de 1975 présente des caractéristiques qui lui sont propres (V. *infra,* nos 316 s.). Sa conclusion doit être précisée (V. *infra,* n° 323), les obligations qui s'en évincent devant, au sens de la loi du 31 décembre 1975, prévenir la sous-traitance occulte (V. *infra,* nos 324 s.).

A - Caractéristiques du contrat

316. Le sous-traité est un contrat de droit privé (V. *infra,* nos 322 s.), dont l'objet (V. *infra,* nos 317 s.), la nature juridique (V. *infra,* nos 318 s.), et la distinction à faire avec les contrats voisins (V. *infra,* n° 321) justifient l'analyse.

1° - Objet

317. Le contrat principal étant, aux termes de l'article 1er de la loi de 1975, un contrat d'entreprise (ou un contrat relatif à un marché public qui est de même nature), il en résulte que le sous-traité doit être lui-même un contrat d'entreprise. Il peut y avoir sous-traitance en chaîne, ce qui entraîne une chaîne de contrats d'entreprise. Le sous-traité peut porter indifféremment sur un service matériel ou intellectuel. En particulier, rien ne s'oppose à la sous-traitance de certaines missions relevant du contrôle technique (Décr. no 99-443 du 28 mai 1999 [JO 1er juin], art. 5) ; rien ne devrait s'opposer à la sous-traitance de certaines tâches relevant du coordonnateur SPS, nonobstant l'interprétation contraire émise par une circulaire du 10 avril 1996 (Circ. Travail 1er avr. 1996, BO travail 96/10 du 5 juin 1996 ; V. sur la question, Mémento F. Lefebvre Urbanisme Construction, nos 54055 s.). La sous-traitance de la mission de maîtrise d'œuvre est admise (Civ. 3e, 24 févr. 1984, Bull. civ. III, no 51 ; 22 mars 1995, RDI 1995. 547 ; 10 avr. 1996, no 704 D. – Civ. 3e, 26 mai 2004, no 02-19.629, RJDA 10/04 no 1117. – Civ. 3e, 9 mars 2011, no 10-30.253, BPIM 3/11, inf. 202. – Décr. du 20 mars 1980, art. 37), sauf s'il s'agit de celle qui relève du monopole architectural (L. 3 janv. 1977, art. 3, al. 2).

2° - Nature juridique

318. Le contrat principal est un contrat d'entreprise. - Il est caractérisé par le fait que l'entrepreneur qui fournit le travail et la matière édifie un ouvrage sur le terrain d'autrui. Comme le relève M. PUIG (La qualification du contrat d'entreprise, thèse, Paris 2, 1999, t. I, nos 127 s.), il y a une finalité de service dans le contrat d'entreprise, qui est certaine lorsque l'entrepreneur « transforme » un terrain nu en terrain bâti pour le compte du maître de l'ouvrage ; si cette finalité de service est moins évidente lorsque le travail est effectué sur un existant et que le prestataire fournit les matériaux, l'assemblage qu'ils nécessitent n'en est pas moins une fourniture de services permettant aisément de distinguer l'entreprise de la vente d'équipements standards destinés à être posés (remplacement d'une porte par une autre de même type). Le contrat, ou marché, principal est un contrat d'entreprise immobilière, puisqu'il y a transformation du sol (ou de l'existant) par le constructeur. La référence au critère de la « commande spécifique » parfois suggérée pour identifier le contrat d'entreprise principal est superflue, car la transformation de la chose, et du sol en particulier, répond à la commande précise du maître de l'ouvrage.

319. Le sous-traité doit être lui aussi un contrat d'entreprise. - Comment l'identifier ? Ni le critère suggéré par POTHIER (la propriété du terrain commande la qualification), ni celui de la transformation de la chose suggéré par M. PUIG (la chose n'appartient pas à l'entrepreneur principal) ne paraissent décisifs. La sous-traitance peut d'ailleurs porter sur une prestation de service intellectuel comme c'est le cas en matière de maîtrise d'œuvre (Civ. 3e, 28 févr. 1984, Bull. civ. III, no 51 ; 22 mars 1995,

préc. *supra,* n° 289 ; 10 avr. 1996, n° 94-16.785 ; si la fourniture d'un tel service suffit à qualifier le contrat d'entreprise, force est cependant de noter que l'apport à la transformation de la chose n'est pas matériel. La Cour de cassation a cependant tenu compte de la prise de responsabilité directe du sous-traitant dans la réalisation de l'ouvrage (Civ. 3e, 17 févr. 1982, RDI 1982. 515). L'analyse de PLANIOL, qui proposait de faire la part du poids respectif des matériaux et de la main-d'œuvre, paraît la mieux adaptée. La jurisprudence y a souvent souscrit (Civ. 3e, 23 avr. 1974, D. 1975. 787, obs. J. Mazeaud ; 27 avr. 1976, JCP 1977. II, n° 18635, note J. H.), et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 (art. 3) s'est exprimée en ce sens. Mais elle lui a, un moment, préféré le critère du travail sur le site, peut-être par une adhésion intuitive au critère de la « transformation » de la chose, qui est plus acceptable lorsque le sous-traitant est sur le chantier (Civ. 3e, 18 févr. 1983, Bull. civ. III, n° 15, qui souligne la participation aux actes de production ou de services se rattachant à l'exécution de l'ouvrage. – Civ. 1re, 31 janv. 1996, Bull. civ. I, n° 28, qui concerne des produits standards dont la pose est assurée) et qui, surtout, permet de donner au sous-contrat un caractère immobilier. Cette orientation a été de courte durée, le travail en atelier n'excluant pas nécessairement la sous-traitance (Civ. 3e, 7 nov. 2012, n° 11-18.138 , Bull. civ. III, n° 163, pour une charpente) : la Haute juridiction a finalement opté pour le critère de la « commande spécifique » : est un contrat d'entreprise, le sous-traité qui a pour objet la réalisation d'un travail spécifique pour répondre aux besoins particuliers du client et « rendant impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalent » (Civ. 3e, 5 févr. 1985, Bull. civ. III, n° 23. – Com. 4 juill. 1989, Bull. civ. IV, n° 210 ; 5 févr. 1991, RJDA 6/91, n° 488. – Civ. 3e, 3 juin 1992, RDI 1993. 79 ; 9 juin 1999, RJDA 11/99, n° 1207 ; 24 janv. 2001, RDI 241. – Civ. 2e, 22 juill. 2008, n° 06-20.946 BPIM 5/08, inf. 359. – Civ. 3e, 18 nov. 2009, n° 08-19.355 , Bull. civ. III, n° 252. – Comp., pour les sous-marchés publics : CAA Nantes, 30 déc. 1999, n° 96-2356, BPIM 3/00, n° 166). Le juge ne doit pas se borner à dire qu'un travail est spécifique : il doit préciser en quoi il l'est (Civ. 3e, 11 mai 2005, n° 03-13.891). Le critère de la commande spécifique appliquée au sous-traité paraît heurter la finalité de service du contrat d'entreprise mise en exergue par M. PUIG : en effet, l'appropriation de la chose commandée paraît être le but essentiel du contrat ; mais peut-être suffit-il d'admettre que la fourniture et la pose d'éléments spécifiques concernent un ouvrage particulier et qu'ils font partie du service rendu au maître de l'ouvrage.

320. La jurisprudence ne paraît pas indifférente aux inconvénients du critère de la commande spécifique. Quelques arrêts font une application distributive des différents critères (Civ. 3e, 19 juin 1991, n° 89-21.906 , Bull. civ. III, n° 185 ; 31 janv. 1996, RJDA 1/97, n° 47), tandis que d'autres exigent que l'entreprise sous-traitante participe par « apport de conception d'industrie ou de matière » à l'acte de construire (Versailles, 13 déc. 1999, RDI 2000. 178 ; 2 mai 2000, RDI 2000. 573 , et les obs. crit.

B. Boubli, RJDA 11/00, n° 981. – Civ. 3e, 22 janv. 2002, RJDA 8-9/02, n° 883. – Douai, 8 févr. 2007, Kaefer Wanner c/ Sollac, ces arrêts refusant la qualité de sous-traitant à l'entreprise d'échafaudage alors que rien n'interdit au maître de l'ouvrage de contracter directement avec un tel prestataire dans le cadre d'un GME et que, pour certains ouvrages tel que des hauts-fourneaux ou des immeubles de grande hauteur, l'apport de conception ne fait guère de doute ; comp. Civ. 3e, 11 juill. 2001, BPIM 5/01, n° 306, qui pouvait donner à penser le contraire ; rappr. : Civ. 3e, 9 juin 2004, n° 03-11.172). La sous-entreprise, en matière immobilière, implique que le sous-traité soit lui-même immobilier (RÉMY, obs. RTD civ. 1990. 105). La condition paraît remplie lorsque le sol ou l'existant participent au travail fourni. De ce point de vue, ni le critère de la commande spécifique, ni le critère économique ne sont opérants. Le travail sur le site pouvait l'être. Faut-il identifier l'objet précis du service comme paraît le suggérer M. PUIG, c'est-à-dire distinguer l'assemblage de l'adjonction, et finalement s'engager dans une distinction désormais acquise par l'interprétation des articles 1792 et suivants, voire de l'article 1793 entre travail de construction et travail d'une autre nature ? Certes la sous-entreprise immobilière n'obéit à des règles spécifiques que dans des cas limités (art. 14-1 de la loi de 1975, CCMI) ; mais ces particularités existent. Comment déterminer, sans risque, leur champ d'application ? Selon un arrêt, lorsque le prestataire est une *personne physique,* il faut qu'il ait une indépendance effective à l'égard du donneur d'ordres (Civ. 3e, 22 nov. 2000, RDI 2001. 57). Cette exigence permet d'éviter la confusion entre le sous-traité et le contrat de travail.

3° - Distinction des contrats voisins

321. Le critère qui permet de ranger le sous-traité dans la catégorie du contrat d'entreprise aide à distinguer celui-ci du contrat de fournitures qui est une vente (V. sur la situation particulière du « sous-traitant fabricant », H. PÉRINET-MARQUET, *in* JCP 1989. I. 3399 et Civ. 3e, 10 janv. 2001, RDI 2001. 177 , obs. Ph. Malinvaud). La Cour de cassation qui s'en tient à l'objet du marché principal, pour l'application de l'article 14-1 de la loi de 1975, dispense peut-être d'aller plus loin dans l'investigation (V. toutefois, Civ. 3e, 24 sept. 2014, n° 13-14.404 , BPIM 6/14, inf. 381, qui prend en compte l'objet du sous-traité pour des travaux de démolition). Mais il faut bien reconnaître que les différentes options jurisprudentielles ne favorisent pas une présentation claire de la distinction entre vente et entreprise : si les spécifications particulières permettent de retenir la sous-entreprise immobilière (arrêts cités *supra,* n° 300 ; V. aussi : Civ. 3e, 30 oct. 1991, n° 90-11.753 , Bull. civ. III, n° 257 ; 17 mars 1998, n° 95-17.997 , Bull. civ. III, n° 104. – Civ. 1re, 24 oct. 2000, JCP 2000. IV. 2253), celle-ci a été retenue pour du matériel standard dès lors qu'il a été posé (Civ. 1re, 31 janv. 1996, n° 93-11.246 , Bull. civ. I, n° 28), ou pour des éléments dont la spécificité n'apparaît pas évidente (éléments de cuisine : Paris, 25 mai 1990, D. 1990. IR 163 ; tuyaux : Com. 20 juin 1989, D. 1990. 246, obs. Virassamy). Il est vraisemblable que la simple fourniture

d'équipements, sans apport de main-d'œuvre évince la sous-traitance (Civ. 3e, 17 mars 2010, n° 09-12.208, RDI 2010. 543. – Civ. 3e, 15 déc. 2010, n° 09-68.894, BPIM 1/11, inf. 22. – Civ. 3e, 11 juill. 2012, n° 11-16.414, Bull. civ. III, n° 107. – Civ. 3e, 21 oct. 2014, n° 13-21.031, RDI 2015. 75. – CE 26 sept. 2007, req. n° 255993, Dpt du Gard, BPIM 1/08, inf. 25). La distinction entre la sous-entreprise de construction et d'autres contrats de services est parfois plus délicate. La sous-traitance se distingue du prêt de main-d'œuvre qui est caractérisé lorsque le travail s'effectue sous l'autorité du donneur d'ordres (V. B. BOUBLI, Le recours à la main-d'œuvre extérieure, Dr. soc. 2009. 806 s.) ; si le tiers ne fournit que du personnel sans production spécifique, il ne s'agit pas d'une sous-traitance (Com. 12 mars 1991, RDI 1991. 346. – Crim. 3 déc. 1991, n° 90-86.763, Bull. crim. n° 458. – Paris, 21 mai 1999, RDI 1999. 651). À l'inverse, il peut y avoir sous-traitance lorsque le tiers fournit de la main-d'œuvre accessoirement à un service spécifique (travaux de déblaiement : Civ. 2e, 11 janv. 1995, Gaz. Pal. 1995. 2. Pan. 155 ; conduite des travaux et sécurité du chantier : Civ. 3e, 22 nov. 2000, Mon. TP 2 févr. 2001. 85). Certains arrêts ont refusé cependant de considérer comme une sous-traitance la fourniture, avec le personnel spécialisé, de matériel de levage, en retenant l'existence d'un louage de chose (Com. 10 déc. 1992, D. 1994. Somm. 147, obs. Bénabent. – Paris, 22 mai 1990, RDI 1990. 369), ce qui ne se justifie que si le fournisseur place son personnel sous l'autorité exclusive de l'entreprise principale ; en revanche, on peut douter du bien-fondé de la jurisprudence qui considère que n'est pas une sous-traitance la fourniture et la pose d'échafaudages.

4° - Contrat de droit privé

322. Le contrat de sous-traitance est un contrat de droit privé qui échappe à la compétence de la juridiction administrative même lorsque le marché principal est un marché public, car il est conclu entre deux personnes de droit privé (T. confl. 15 janv. 1973, Lebon 844 ; 24 nov. 1997, BPIM 1/98, n° 20 ; 7 juin 1999, RDI 1999. 652 ; 22 janv. 2001, RJDA 4/01, n° 534 ; 9 févr. 2015, n° 3983, BPIM 2/16, inf. 102. – CE 10 févr. 1995, RDI 1995. 324 ; 10 juill. 1996, BPIM 1/97, n° 42. – Versailles, 20 mai 1999, RDI 1999. 653 et Paris, 10 juin 1999, RDI 1999. 653). Aucune clause dérogatoire ne peut être valablement stipulée (CE 24 mai 1974, JCP 1975, n° 17907). Le Tribunal des conflits a toutefois retenu la compétence du juge administratif à propos d'un marché de travaux publics où le maître d'ouvrage a recherché la responsabilité décennale du sous-traitant en relevant que les parties au litige n'étaient pas liées par un contrat de droit privé (T. confl. 2 juin 2008, n° 3621, Souscripteurs de Lloyd's de Londres c/ Cne de Dinville, BPIM 6/08, inf. 432), solution qui interroge puisque le sous-traitant n'est pas tenu de la garantie décennale. Le Conseil d'État qui admet pour sa part que le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité extracontractuelle du sous-traitant, confirme cette tendance à la compétence administrative (CE 7 déc. 2015, req. n° 380419, Cne de Bihorel, BPIM 1/16, inf. 26).

B - Conclusion du sous-traité

323. Le sous-traité obéit à des règles qui visent à protéger le sous-traitant et à prévenir les sous-traitances occultes. Le contrat est consensuel et il obéit aux règles applicables au marché principal. L'écrit n'est pas une formalité substantielle (V. Civ. 3e, 31 mars 2004, no 02-17.013, SCI Les Hameaux de l'étang, qui admet la preuve du sous-traité par les factures produites), mais il est en pratique nécessaire, car le maître de l'ouvrage doit être informé de l'objet de la sous-traitance et des conditions de paiement : c'est en particulier le cas lorsque le marché principal est un marché public. L'écrit est d'ailleurs exigé, lorsque le marché principal est un *CCMI* (contrat de construction de maison individuelle ; CCH, art. L. 231-13). Il doit alors comporter les mentions énumérées par ce texte. Ces formalités sont sanctionnées par un emprisonnement pouvant atteindre deux ans et une amende pouvant être portée à 18 000 € (CCH, art. L. 241-9). Dans les *marchés publics,* le sous-traité n'est possible qu'à la condition que l'entreprise principale ait obtenu de l'acheteur (le maître de l'ouvrage), l'agrément du sous-traitant et l'acceptation des conditions de paiement (Décr. du 23 mars 2016, art. 133). La sous-traitance tempère le caractère *intuitu personae* du contrat d'entreprise sans l'évincer totalement. On le verra ci-après, le sous-traitant doit être présenté au maître de l'ouvrage et être accepté par lui. Dans les marchés privés, la sous-traitance peut porter sur la totalité du marché ; c'est le plus souvent le cas lorsque le marché principal est un CCMI. Dans les marchés publics, la sous-traitance est considérée comme « normale » ; mais elle ne peut être que partielle ; c'était la règle sous l'empire du code des marchés publics (art. 113) ; nonobstant une rédaction équivoque de l'article 62 de l'ordonnance de 2015, la règle est maintenue par l'article 133 du décret du 23 mars 2016 qui vise « certaines parties » du marché et par la loi du 31 décembre 1975 (art. 1er). Le marché principal peut interdire le recours à la sous-traitance.

C - Prévention des sous-traitances occultes

324. La prévention des sous-traitances occultes résulte, dans la loi du 31 décembre 1975, de la combinaison de deux règles qui associent le maître de l'ouvrage au choix du sous-traitant (art. 3) : l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ; l'agrément par ce dernier des conditions de paiement convenues entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Les modalités de mise en œuvre de ces formalités varient selon que le marché principal est un marché privé (V. *infra,* nos 325 s.) ou un marché public (V. *infra,* nos 337 s.).

1° - Marché privé

325. L'*entrepreneur principal* a l'obligation de présenter le sous-traitant au maître de l'ouvrage, afin de le faire accepter et de faire agréer les conditions de paiement convenues (L. 1975, art. 3). Cette obligation ne s'étend pas au sous-traitant d'un cotraitant de l'entrepreneur, alors même que celui-ci serait mandataire d'un GME, à moins qu'il n'ait reçu un mandat spécial des autres mandataires groupés (Civ. 3e, 28 sept. 2005, n° 04.16.008, BPIM 6/05, inf. 399 ; comp. : Civ. 3e, 1er juill. 2009, n° 08-16.724, qui donne des indications sur les limites du pouvoir de représentation du mandataire d'un GME). En cas de *sous-traitance en chaîne,* chaque sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants (L. 1975, art. 2). C'est donc à lui et non à l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 12 juill. 1989, RDI 1990. 82. – Civ. 3e, 21 janv. 2015, n° 13-18.316, RDI 2016. 278 et les arrêts cités. – Comp. : Civ. 3e, 12 mai 1999, n° 97-13.106), de procéder aux formalités de présentation (Civ. 3e, 21 janv. 2004, BPIM 2/04, inf. 95) ; mais la solution n'est pas évidente, car le sous-traitant n'a pas de lien direct avec le maître de l'ouvrage (V. Civ. 3e, 12 mai 1999, n° 97-10.146. – Versailles, 16 janv. 1997, Dalloz affaires 1997. 376). Le sous-traité peut comporter une clause obligeant le sous-traitant à informer l'entrepreneur qu'il sous-traite à son tour (Civ. 3e, 7 oct. 2014, n° 13-22.821, RDI 2015. 79). La présentation par l'entrepreneur principal doit avoir lieu, normalement, lors de la soumission ou en cours de chantier si le sous-traité est envisagé à ce moment. Mais la Cour de cassation estime que la présentation peut intervenir pendant les travaux, même après la conclusion du sous-traité (Cass., ch. mixte, 13 mars 1981, Bull. civ., n° 3. – Civ. 3e, 12 mars 2008, n° 07-13.651) et lors de l'exercice de l'action directe (Civ. 3e, 16 déc. 1987, Bull. civ. III, n° 208. – Paris, 25 mai 1990, D. 1990. IR 163 ; V. *infra,* nos 339 s.).

326. Diligences. - Les articles 5, 6 et 14-1 de la loi de 1975 (modifiés par L. 11 déc. 2001, MURCEF) obligent les *sous-traitants* à diverses diligences : l'article 5, qui complète l'article 3, prévoit en substance, que l'entrepreneur principal peut faire appel à des sous-traitants en cours d'exécution du marché à condition de les déclarer au maître de l'ouvrage et qu'il doit indiquer la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que le sous-traitant appelé ; l'article 6 prévoit que le sous-traitant qui sous-traite à son tour doit fournir une caution à son propre sous-traitant ou procéder à la délégation prévue à l'article 14. Cette disposition ne paraît concerner que le sous-traitant de premier rang (V. al. 1er du texte), mais cette interprétation est sujette à discussion ; en outre, il semble que la délégation s'entende de celle qui délègue le maître de l'ouvrage au créancier de second rang, ce qui peut poser problème ; l'article 14-1 précise que ces textes, situés au titre du « paiement direct », sont applicables tant aux marchés publics qu'aux marchés privés (V. *infra,* nos 328 s.). Ces dispositions issues de la loi MURCEF ne semblent pas remettre en cause la règle antérieure selon laquelle le sous-traitant, qui n'a pas, en principe, l'obligation de se faire connaître du maître de l'ouvrage ne commet aucune faute s'il demeure passif (Cass., ch. mixte, 13 mars 1981, Bull. ch.

mixte, n° 2. – Civ. 3e, 29 janv. 1987, RJDA 4/97, n° 508 ; 29 mars 2000, BPIM 3/00, inf. 167 ; 22 nov. 2000, BPIM 1/01, inf. 27).

327. Acceptation ou non du sous-traitant. - Le *maître de l'ouvrage* peut accepter ou non le sous-traitant. Il n'est pas tenu de l'accepter (Civ. 3e, 25 sept. 2002, n° 00-18.163, Bull. civ. III, n° 177, principe rappelé dans les motifs de l'arrêt). Son refus ne doit cependant pas être abusif (Civ. 3e, 2 févr. 2005, n° 03-15.409, RJDA 5/05, n° 550) ; il doit être justifié (Civ. 3e, 8 juill. 2015, n° 12-22.641, BPIM 5/15, inf. 314). Si le sous-traitant n'est pas accepté et (ou) que les conditions de paiement ne sont pas agréées, le sous-traité est irrégulier (art. 3, al. 2 ; V. *infra,* n° 328). Pour autant, le refus du maître de l'ouvrage n'engage pas sa responsabilité si le sous-traitant reste sur le chantier (Civ. 3e, 16 juin 2015, n° 14-12.564, BPIM 4/15, inf. 246). L'acceptation, lorsqu'elle a lieu, peut être expresse ou tacite. Le principe de l'acceptation tacite, classique dans les marchés publics, est posé en droit privé (Civ. 3e, 18 juill. 1984, RDI 1985. 59), mais reçoit fort peu d'applications (Civ. 3e, 27 sept. 2000, RDI 2001. 56, et l'analyse de H. PÉRINET-MARQUET ; 25 sept. 2002, préc.).

ACTUALISATION

327 s. Caution. Sous-traitance. Action directe. - L'acceptation tacite du sous-traitant par le maître d'ouvrage autorise la caution de l'entrepreneur à exercer par subrogation l'action directe du sous-traitant, mais elle n'est pas fondée à réclamer les sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution d'un contrat distinct (Civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-10.719, Dalloz actualité 19 juin 2017, obs. Garcia).

328. Carence de l'entrepreneur principal. - Lorsque l'entrepreneur principal n'a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par les articles 3 et 5 de la loi, celle-ci fait peser une obligation positive sur le *maître de l'ouvrage* « pour les contrats de bâtiment et de travaux publics » (L. 1975, art. 14-1, al. 1er et 2 mod. L. 11 déc. 2001). Cette obligation peut peser sur le maître d'ouvrage apparent s'il induit en erreur le sous-traitant (Civ. 3e, 12 janv. 2005, n° 03-17.668, pour un crédit-preneur) ou sur maître d'ouvrage délégué (Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 07-21.198, BPIM 4/09, inf. 275. – Civ. 3e, 6 juill. 2010, n° 09-12.323, BPIM 5/10, inf. 365). Le « contrat de bâtiment et de travaux publics » s'entend du *contrat principal,* c'est-à-dire celui qui lie le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal ; les conventions annexes, hors marché, intervenues entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, ne sont pas concernées (Civ. 3e, 15 déc. 2004, n° 03-15.396 ; 22 juin 2005, n° 04-16.011, BPIM 5/05, inf. 257) ; le contrat principal doit avoir pour objet des travaux de bâtiment et de génie civil (Civ. 3e, 2 oct. 2002, arrêts nos 1414 à 1416 FS-PB, BPIM 6/02, n° 382, RJDA 12/02, n° 1269). Ce n'est donc pas la nature de la prestation fournie par le sous-traitant qui est ici à

considérer, dès lors du moins que les conditions du contrat de sous-traitance réglementée sont remplies (V. *supra,* n°s 290 s.). Toutefois, un arrêt laisse toutefois entendre que les travaux de démolition sous-traités ont la nature de travaux de bâtiment et il peut susciter une interrogation sur la question de savoir si la prestation du sous-traitant doit relever de cette catégorie (Civ. 3e, 24 sept. 2014, n° 13-14.404, BPIM 6/14, inf. 381).

329. Bâtiment. - Par « bâtiment », la jurisprudence semble entendre les « travaux de bâtiment » pris en considération au sens de la garantie décennale, avant que l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ne substitue à cette expression celle de « travaux de construction ». Ne sont pas des travaux de bâtiment : des travaux de modification et d'installation de machines (Com. 12 mars 1996, RJDA 7/96, n° 917) ; le montage et la mise en route d'équipements industriels (Civ. 3e, 4 déc. 2002, n° 01-03.929). En revanche, sont des travaux de bâtiment la réalisation d'une installation industrielle comportant, outre les équipements, les travaux nécessaires à les recevoir, tels que socle en béton armé et structure métallique (Civ. 3e, 2 oct. 2002, arrêt n° 1415, préc. ; V. déjà : Civ. 3e, 20 déc. 2000, RDI 2000. 164) ; l'installation d'un réseau électrique d'alimentation de matériel et de sécurité (Civ. 3e, 17 juin 2008, n° 07-15.060), la fourniture d'une charpente réalisée en atelier (Civ. 3e, 7 nov. 2011, n° 11-18.138, Bull. civ. III, n° 163). Les « travaux publics » s'entendent, en jurisprudence, des travaux de génie civil (Civ. 3e, 9 oct. 1998, RJDA 4/99, n° 407).

330. Obligations. - Cette condition étant remplie, l'article 14-1, alinéa 2, prévoit que le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de « l'emploi » (et pas seulement de la présence désormais) d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies aux articles 3, 5 et 6, doit mettre l'entrepreneur principal en demeure d'exécuter ses obligations (celles des art. 3 et 5) et le sous-traitant d'accomplir les siennes (celles de l'art. 6). Il doit veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en œuvre (Civ. 3e, 21 nov. 2012, n° 11-25.101, RJDA 4/13, n° 319). Il suffit que le maître de l'ouvrage ait eu connaissance de la présence du sous-traitant avant la fin des travaux, objet du marché principal (Civ. 3e, 2 oct. 2002 [2 esp.], n°s 00-22.461 et 01-10.328, Bull. civ. V, n° 199 ; V. toutefois n° 00-22.461, qui considère que la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en retenant que la simple demande d'agrément ne constitue pas la preuve que le maître de l'ouvrage a su que le sous-traitant était sur le chantier et qu'il n'a eu connaissance effective de cette présence qu'une fois les travaux terminés) ; un arrêt décide toutefois que son obligation subsiste s'il a connaissance de la présence du sous-traitant nonobstant l'achèvement des travaux ou la fin du chantier (Civ. 3e, 11 sept. 2013, n° 12-21.077, RJDA 12/13, n° 1006). Il faut cependant qu'il soit clairement établi qu'il n'a pas ignoré cette présence (Civ. 3e, 4 févr. 2004, n° 02-15.377 ; 26 janv. 2005, BPIM 2/05, inf. 125 ; 2 févr. 2005, n° 03-

18.554 , RJDA 6/05, n° 693. – Versailles, 5 nov. 1999, RDI 2000. 54), ce qui peut résulter de l'information donnée par le maître d'œuvre auquel aucun manquement à l'obligation de conseil ne peut alors être reproché (Civ. 3e, 12 mars 2008, n° 07-13.651). Il a été jugé que le maître d'œuvre chargé d'une mission de direction et de surveillance doit informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant (Civ. 3e, 10 févr. 2010, n° 09-11.562 , Bull. civ. III, n° 35) et qu'il doit aussi le conseiller de se faire présenter ce dernier (Civ. 3e, 10 déc. 2014, n° 13-24.892 , BPIM 1/15, inf. 29. – Comp. : Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 08-17.400 , BPIM 4/09, inf. 275). Le maître de l'ouvrage informé, doit, conformément aux dispositions combinées des articles 3 et 14-1, mettre l'*entrepreneur principal* en demeure de lui présenter le sous-traitant aux fins d'acceptation et d'agrément de ses conditions de paiement. La mise en demeure est nécessaire ; elle doit, à tout le moins, prendre la forme d'une lettre recommandée (Paris, 26 janv. 2001, RDI 2001. 242 , qui écarte la lettre simple. – Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 08-17.400 , sol. impl.). L'article 1344 nouveau du code civil qui vise l'acte « portant interpellation suffisante » à l'égard du débiteur conforte cette appréciation. Les obligations résultant de l'article 14-1 de la loi de 1975 sont étendues au maître d'ouvrage délégué lorsqu'il a reçu un mandat général (Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 07-21.198 . – Civ. 3e, 6 juill. 2010, n° 09-12.323 , BPIM 5/10, inf. 365, s'agissant d'un mandat plus précis. – V. déjà : Civ. 3e, 12 janv. 2001, BPIM 2/05, inf. 121).

331. S'il ne satisfait pas à cette exigence, le maître de l'ouvrage engage *sa responsabilité pour faute,* en pratique de nature extra-contractuelle (Civ. 3e, 29 janv. 1997, RJDA 4/97, n° 508. – Civ. 3e, 4 juin 1997, BPIM 5/97, n° 318. – Civ. 3e, 7 juill. 2015, n° 14-20. 353 , qui retient un contrat de sous-traitance à propos de la fourniture d'un plancher et d'un plafond), envers le sous-traitant, quel que soit son rang (Civ. 3e, 9 déc. 1998, RJDA 4/99, n° 407), à moins qu'il ait ignoré l'existence du sous-traitant (Civ. 3e, 22 juin 2011, n° 10-18.573 , BPIM 5/11, inf. 377). Peu importe que l'exercice de l'action directe soit impossible, en particulier parce que le maître de l'ouvrage a payé intégralement l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 14 nov. 2001, RDI 2002. 55) : les deux actions sont indépendantes (Civ. 3e, 25 sept. 2002, n° 00-18.163 , Bull. civ. III, n° 177) et peuvent même coexister (Civ. 3e, 15 nov. 2011, n° 10-26.240, RDI 2012. 505).

332. Depuis la réforme issue de la loi MURCEF, le maître de l'ouvrage s'adresse aussi au *sous-traitant,* tenu lui-même de procéder à certaines diligences en application des articles 5 et 6 (V. *supra,* n° 326). L'article 14-1, alinéa 2 modifié qui dispose que le maître de l'ouvrage met en demeure « l'entrepreneur principal *ou* le sous-traitant » institue une alternative. Pourtant, ce ne sont pas les *mêmes obligations* qui pèsent sur l'entrepreneur principal et sur le sous-traitant : l'article 5 confère à l'entrepreneur principal la faculté de faire appel à de nouveaux sous-traitants ; l'article 6 oblige les

sous-traitants de premier rang à fournir des garanties principales, aux conditions déjà exposées, mais il n'impose pas expressément au sous-traitant de se faire connaître ; ce dispositif étant applicable tant aux marchés privés que publics, il est permis de se demander si les règles relatives à l'obligation du sous-traitant de se faire connaître, dans les marchés publics (V. *infra,* n° 337), ne sont pas généralisées.

333. La loi MURCEF a rassemblé sous l'article 14-1, alinéa 2, deux questions distinctes : celle de la prévention des sous-traitances occultes ; celle de la carence dans la fourniture des garanties principales (sur ce point, V. *infra,* n° 334). Du coup, il ne semble pas qu'il y ait faute du maître de l'ouvrage à continuer d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il exécute son obligation de présentation : le maître de l'ouvrage ne fait qu'exercer l'option que la loi lui offre ; mais il est permis de se demander s'il bénéficie d'une option lorsqu'il constate que le sous-traitant qui sous-traite à son tour n'a pas fourni les garanties principales. Nulle part, il n'est dit que l'entrepreneur principal a un rôle à jouer dans ce cas.

334. Sous les réserves relatives à la carence du maître de l'ouvrage qui ne met pas le sous-traitant en demeure d'exécuter ses obligations, dont la sanction est incertaine (V. *supra,* n° 332), le *préjudice* subi par le sous-traitant non présenté est caractérisé par la perte des garanties principales (Civ. 3e, 22 nov. 2000, RDI 2001. 57) et (ou) de l'action directe (Civ. 3e, 10 janv. 2001, RDI 2001. 165 ; V. aussi : Civ. 3e, 5 juin 1996, n° 94-15.825, Bull. civ. III, n° 135 ; 4 nov. 1999, BPIM 1/00, n° 20). Certains arrêts ont retenu aussi la perte d'une chance d'être payé (Versailles, 10 déc. 1993, RDI 1994. 250 ; rappr. Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 08-17.400) ou l'incertitude du paiement des travaux exécutés (Civ. 3e, 28 mai 2013, n° 12-22.257, BPIM 4/13, inf. 254). La Cour de cassation décide que le préjudice est souverainement apprécié par les juges du fond (Civ. 3e, 26 févr. 1997, préc. ; 17 juill. 1997, BPIM 6/97, n° 381 ; 14 avr. 1999, RJDA 8/99, n° 929). L'étendue du dommage indemnisable correspond à ce qui reste dû au sous-traitant non payé ou insuffisamment payé par l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 14 avr. 1999, RJDA 8-9/99, n° 929 ; 22 nov. 2000, n° 98-17.923, RDI 2001. 57, BPIM 1/01, n° 27, 1re esp. ; comp. : Civ. 3e, 24 janv. 2001, n° 98-17.767, BPIM 2/01, n° 111, 1re esp. – Versailles, 13 mars 1994 et Toulouse, 14 mars 1994, RDI 1994. 453, qui retiennent ce qui est dû à l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage). Le juge saisi d'une action en responsabilité dirigée contre le maître de l'ouvrage doit rechercher si les sommes sur lesquelles porte le litige n'ont pas été payées par l'entrepreneur principal avant que le maître de l'ouvrage ait eu connaissance de la sous-traitance (Civ. 3e, 13 juill. 2016, n° 15-20.779).

335. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée à compter du moment où, ayant eu connaissance de la présence d'un sous-traitant, il a continué à payer l'entrepreneur principal. Cette responsabilité est-elle enfermée dans la double limite des

sommes restant dues à l'entrepreneur principal au moment où le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant et du montant de la créance non payée (ce qui expliquerait l'arrêt du 24 janv. 2001, préc. *supra,* n° 334) ? Au contraire, est-ce toute la créance du sous-traitant qui est à considérer lorsque le maître de l'ouvrage est en faute, même si le solde restant dû à l'entrepreneur principal est insuffisant pour la libérer ? Il n'y a aucune faute et, par suite, aucune responsabilité si le marché est achevé et que le maître de l'ouvrage a déjà payé intégralement l'entrepreneur principal lorsqu'il apprend que celui-ci a sous-traité certains lots. La jurisprudence qui décide que la responsabilité du maître de l'ouvrage reste engagée même s'il a payé intégralement l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 14 nov. 2001, RDI 2002. 55) ne semble concerner que le cas du maître de l'ouvrage qui avait connaissance de la présence du sous-traitant et a néanmoins payé son créancier sans le mettre en demeure d'accomplir ses obligations. La réparation, lorsqu'elle est due, peut être supportée solidairement par le maître de l'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué (Civ. 3e, 6 janv. 1999, BPIM 2/99, n° 129).

336. Sous-traitance irrégulière. - Le sous-traitant non accepté ou dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées est dans une situation « irrégulière » en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi. Ni l'entrepreneur principal (art. 3, al. 2), ni les créanciers ne peuvent se prévaloir de cette situation (Civ. 3e, 1er juin 1988, Bull. civ. III, n° 101 ; 12 juin 1991, RDI 1991. 347 ; 25 févr. 1998, RJDA 5/98, n° 589). Il est admis en jurisprudence que le sous-traitant peut alors renoncer à poursuivre le contrat (Civ. 3e, 11 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 169). Il s'agit sans doute d'une nullité relative. Une distinction doit être faite : 1° si l'acceptation et l'agrément sont refusés, le sous-traitant peut se retirer ; il pourrait aussi, semble-t-il, continuer à travailler mais à ses risques et périls ; son action en paiement contre l'entrepreneur principal demeure possible, soit pour obtenir le paiement du marché exécuté, soit, s'il se retire, pour réclamer la réparation du préjudice concernant les travaux exécutés (art. 3, al. 2), mais il n'a aucun droit contre le maître de l'ouvrage ; 2° si l'absence d'acceptation et d'agrément résulte du fait qu'il n'a pas été présenté, il dispose, outre les prérogatives ci-dessus décrites, du droit à réparation contre le maître de l'ouvrage aux conditions exposées plus haut (V. *supra,* nos 328 s.).

2° - Marché public

337. Ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. - La sous-traitance des marchés publics a été revue par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (JO 24 juill. ; art. 62 s.) et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (JO 27 mars ; art. 133 s.). Le titulaire du marché doit faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement. À cette fin, l'entrepreneur principal doit indiquer, lors de la soumission ou de l'offre, la nature et le montant des prestations qu'il envisage de sous-

traiter, et désormais (rédaction modifiée de l'art. 5, al. 1er) les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ; il indique à l'acheteur, par écrit, conformément à l'article 5 de la loi et à l'article 134 du décret, les précisions relatives à la sous-traitance projetée et formule ainsi une demande d'acceptation et d'agrément soit au moment de l'offre ou de la proposition, soit après la conclusion du marché. Le sous-traitant remet pour sa part au service contractant une déclaration attestant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner. Il a été jugé qu'il doit se faire connaître du maître de l'ouvrage et il doit demander à l'entrepreneur de le présenter à celui-ci ; à défaut, sa responsabilité est engagée (CE 6 mai 1988, D. 1989. somm. 18 ; 7 nov. 1980, D. 1981. IR 115, obs. Delvolvé). La Cour de cassation, appelée à statuer sur l'action directe dans certains marchés publics (V. *infra,* n° 339), en déduit que le sous-traitant qui continue à opérer malgré un refus du maître de l'ouvrage porté à la connaissance de l'entreprise principale, commet une négligence s'il ne s'informe pas (Civ. 3e, 22 nov. 2000, BPIM 1/01, n° 27). Conformément à l'article 5 de la loi de 1975 et à l'article 134, 2° du décret du 25 mars 2016, l'entrepreneur peut faire appel à de nouveaux sous-traitants en cours d'exécution du marché à condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage (art. 5, al. 2), sans préjudice de l'obligation qu'il a toujours de faire accepter ceux auxquels il envisage de faire appel dès la soumission (art. 3). Le texte distingue deux cas : celui des prestations que l'entrepreneur principal « envisage » de sous-traiter : la présentation doit avoir lieu dès la soumission ; celui des prestations dont la sous-traitance est décidée en cours de chantier (V. ABBATUCCI et SABLIER, article préc., RDI 2002. 114 ✎). Le décret apporte des précisions tenant compte du régime des avances et de l'éventualité d'une cession ou d'un nantissement de créances (Décr. n° 2016-360, art. 134, 3°).

338. Acceptation et agrément. - L'acceptation et l'agrément sont, en principe, *explicites.* Ils peuvent résulter soit de la notification du marché lorsque la demande accompagne l'offre du titulaire du marché (Décr. n° 2016-360, art. 134, 1°), soit d'une constatation expresse dans le marché ou dans un acte spécial signé des deux parties (Décr. n° 2016-360, art. 134, 2° et 3°).

339. L'acceptation et l'agrément peuvent aussi être *implicites.* Cette éventualité est prévue par l'article 135, 4°, du décret n° 2016-360 (préc., silence gardé par la personne publique contractante pendant 21 jours à compter de la réception des documents émanant de l'entrepreneur principal). L'accord implicite naguère prévu seulement par le code des marchés publics (pour des atténuations à cette restriction, V. CE 2 juin 1989, Ville de Boissy-Saint-Léger, Le Moniteur du 2 mars 1990. – Civ. 3e, 11 mars 1992, n° 90-18.150 ⚖, Bull. civ. III, n° 80) est désormais possible pour tous les marchés soumis à l'ordonnance de 2015 et au décret de 2016 (préc.). Le maître de l'ouvrage ne peut prononcer une acceptation d'office ; il doit attendre que les documents identifiant le sous-traité lui soient transmis. L'invitation faite à l'entrepreneur d'y procéder (CE 2 juin 1989, D. 1990. 228, note Bénabent ✎), pas plus que la connaissance qu'il peut avoir de

la présence du sous-traitant (Civ. 3e, 11 mars 1992, préc.), ne peuvent valoir acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage. Mais celui-ci ne peut, dans ce dernier cas, demeurer passif ; il est tenu d'une obligation de diligence dont l'inobservation peut lui être reprochée (CE 6 mai 1988, D. 1989. Somm. 18. – Civ. 3e, 22 nov. 2000, n° 98-20.875, BPIM 1/01, inf. 27). Le maître de l'ouvrage peut refuser le sous-traitant, en particulier lorsque l'offre est anormalement basse (Ord. 2015, art. 62 ; Décr. 2016, art. 134, qui renvoie à l'article 60).

340. En l'absence d'acceptation ou d'agrément, la sous-traitance est « irrégulière » au sens de l'article 3 de la loi de 1975. Cette irrégularité peut être soulevée par le maître de l'ouvrage et par le titulaire du marché à l'occasion du paiement direct (CE 2 juin 1989, D. 1990. 228, obs. Bénabent). Le maître de l'ouvrage public est tenu semble-t-il, des diligences mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi de 1975, comme dans les marchés privés (V. *supra,* n° 300) au moins lorsque l'action directe est ouverte. Il est probable qu'il engage sa responsabilité dans des conditions voisines (v. CE 28 mai 2001, req. n° 205449, SA Bernard travaux Polynésie, RJDA 10/01, n° 968), en particulier si le sous-traitant qui sous-traite à son tour ne fournit pas les garanties principales (V. *supra,* nos 328 s. ; V. *infra,* nos 361 et 373).

§ 2 - Règles de paiement du sous-traitant

341. Les règles de paiement du sous-traitant varient selon le caractère public (V. *infra,* nos 357 s.) ou privé du marché (V. *infra,* nos 342 s.).

A - Marchés privés

342. Des garanties de paiement du sous-traitant, dites « principales », sont exigées par la loi (V. *infra,* nos 343 s.). Le sous-traitant peut, cependant, exercer une action en paiement contre le maître de l'ouvrage qui l'a acceptée (V. *infra,* nos 348 s.).

1° - Garanties principales

343. La loi de 1975 institue des garanties qui sont destinées à pallier le risque d'insolvabilité de l'entreprise principale et, plus généralement, de celui avec lequel le sous-traitant a contracté (V. *infra,* nos 344 s.) et précise aussi les obligations du maître de l'ouvrage (V. *infra,* nos 347 s.).

a. - Obligation de l'entrepreneur principal

344. Types de garanties. - Parmi les règles de loi de 1975 figure l'obligation faite à l'entrepreneur principal de fournir des garanties au sous-traitant. Ces garanties sont de deux ordres et sont alternatives (art. 14). L'entrepreneur doit soit fournir une caution, soit déléguer le maître de l'ouvrage au sous-traitant.

– La *caution doit être personnelle et solidaire.* Elle est obtenue auprès d'un établissement bancaire agréé. L'acte de cautionnement doit être *spécial.* À peine de nullité, il doit indiquer le nom du sous-traitant et le montant du marché garanti (V. Civ. 3e, 18 déc. 2002, n° 00-12.511, Bull. civ. III, n° 267, qui résiste à la pratique dite des « cautions flotte » ; V. aussi : Civ. 3e, 15 déc. 2004, n° 03-13.588, Bull. civ. III, n° 242 ; V. ABBATUCCI, Garantie de paiement des sous-traitants : des avancées obtenues grâce à la concertation professionnelle, RDI 2006. 417 s. ; mais la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence restrictive en ce domaine : Civ. 3e, 22 juin 2012, n° 11-18.463, RJDA 11/12, n° 957). Le mécanisme des garanties de caution institué par les articles L. 313-50 et L. 313-51 du code monétaire et financier est étendu à cette caution (sur le sort de la caution lorsque la personne morale garantie transfère son patrimoine : Civ. 3e, 12 mars 2008, n° 07-15.278).

– La *délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant* pour le paiement du prix à concurrence des prestations effectuées par ce dernier s'effectue dans les conditions prévues par le code civil. Il s'agit, sauf stipulation contraire, d'une délégation imparfaite qui laisse subsister la dette de l'entrepreneur principal (Versailles, 29 sept. 1989, RDI 1989. 54. – Paris, 27 janv. 1991, RDI 1991. 223). L'article 1337 nouveau du code civil le confirme, bien qu'il ne fasse guère allusion au caractère parfait ou imparfait de la délégation ; il n'admet la novation par changement de débiteur que si le créancier y consent. La délégation porte sur le montant de chaque prestation sous-traitée, ce qui exclut la répartition au marc-le-franc entre sous-traitants (Civ. 3e, 7 oct. 1998, BPIM 1/99, n° 28). Si le maître de l'ouvrage consent à être délégué au sous-traitant, il est réputé l'avoir accepté (Civ. 3e, 8 nov. 2000, RDI 2001. 57) ; son acceptation est une condition de validité de la délégation (Civ. 3e, 4 févr. 2004, n° 02-19.147. – Civ. 3e, 10 juill. 2012, n° 11-20.976, RDI 2012. 503) mais il ne peut subordonner le paiement à un ordre de l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 23 mai 2007, n° 06-13.723, BPIM 4/07, inf. 272. – Civ. 3e, 19 déc. 2012, n° 11-25.622, RJDA 4/13, n° 320).

ACTUALISATION

344 s. Absence de condition suspensive pour la caution de l'entrepreneur principal. - Il résulte de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, qui trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant, que l'entrepreneur principal doit, sous peine de nullité du contrat, fournir la caution avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux

lui est antérieur, avant celui-ci (Civ. 3e, 21 janv. 2021, n° 19-22.219, D. actu. 16 févr. 2021, obs. F. Garcia).

345. Les *garanties principales sont d'ordre public* ; le sous-traitant ne peut y renoncer par avance (Civ. 3e, 9 juill. 2003, n° 02-10.644. – Civ. 3e, 4 févr. 2004, n° 02-19.147, RJDA 6/04, n° 703. – Civ. 3e, 23 juin 2004, n° 02-20.806, BPIM 5/05, inf. 287). Elles doivent être constituées dès la conclusion du sous-traité (Civ. 3e, 17 juill. 1996, RJDA 11/96, n° 1329 ; 7 févr. 2001, RJDA 5/01, n° 586 ; 14 nov. 2001, RDI 2002. 51, sol. impl.). L'obligation n'est pas subordonnée à l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 14 oct. 1992, n° 90-21.525, RDI 1993. 223). Ce principe semble devoir s'appliquer au sous-traitant qui sous-traite à son tour et qui doit fournir les garanties en application de l'article 6 modifié de la loi dont l'article 14-1, alinéa 2, modifié contraint le maître de l'ouvrage à vérifier la réalisation (V. *supra,* nos 300 s.). À défaut de constitution des garanties lors de sa conclusion, le sous-traité est nul (art. 14. – Civ. 3e, 11 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 189). Peu importe que la garantie soit fournie par la suite (Civ. 3e, 17 juill. 1996, RJDA 11/96, n° 1329), notamment lors de l'assignation en nullité (Civ. 3e, 7 févr. 2001, RJDA 5/01, n° 586) ; peu importe aussi que le sous-traité ait été exécuté (Versailles, 13 mars 1997, RDI 1997. 446. – Civ. 3e, 18 juill. 2001, RJDA 12/01, n° 1211. – Com. 12 juill. 2005, n° 02-16.048), ou que le sous-traitant ait été intégralement payé (Civ. 3e, 12 mars 1997, RJDA 5/97, n° 645 ; 7 févr. 2001, RDI 2001. 163, et l'analyse H. Périnet-Marquet. – Comp. Paris, 23 mai 2001, RDI 2002. 53, qui décide qu'une délégation peut purger la nullité résultée du défaut de fourniture de la caution). À plus forte raison, le sous-traitant est-il fondé à se prévaloir de l'absence des garanties avant l'exécution des travaux (Civ. 3e, 30 mars 1994, RJDA 6/94, n° 650). L'entrepreneur principal qui ne fournit pas l'une ou l'autre des garanties ne peut céder ou nantir que la part du marché correspondant à ses propres prestations (art. 13-1, al. 1er). Il ne peut nantir ou céder l'intégralité du marché que si la garantie est fournie. On a pu penser que l'article 13-1, alinéa 2, de la loi de 1975 qui prévoit cette possibilité et résulte d'une modification du texte d'origine par la loi du 24 janvier 1984, considérait que la fourniture des garanties principales n'était pas impérative puisque, à défaut, l'entrepreneur principal ne peut nantir que sa part de marché ; mais dans l'arrêt du 18 juillet 2001 précité, la Cour de cassation a considéré que la loi de 1984 ne remettait pas en cause la nullité édictée par l'article 14.

346. La nullité encourue est une *nullité relative* que seul le sous-traitant peut soulever (Com. 19 mai 1980, D. 1980. 443. – Civ. 3e, 12 mars 1997, préc. ; 10 nov. 1998, BPIM 1/99, n° 28. – Versailles, 13 mars 1997, préc.). Ni l'entrepreneur principal ou ses créanciers (Civ. 3e, 19 juill. 1982, Bull. civ. III, n° 178. – Com. 12 févr. 1991, RJDA 4/91, n° 298), ni le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 3 juill. 1997, n° 1215 D) ne peuvent s'en

prévaloir. Cette situation n'est pas sans inconvénient lorsque les travaux sont exécutés, voire lorsqu'ils ont été payés. L'exécution ou l'acceptation du paiement devraient valoir ratification du contrat et abandon de l'action en nullité ; ce n'est pas ce que dessine la jurisprudence (V. *supra,* n° 345). Le sous-traitant peut ainsi tenter de remettre en cause le montant des prestations convenues et réclamer le prix réel des travaux (et non le prix convenu), en particulier si le marché est à forfait. Cette rigueur, expliquée par l'idée que le sous-traitant a supporté un risque anormal (H. PÉRINET-MARQUET, RDI 2001. 56), donne au sous-traitant un moyen de chantage dont on peut douter de la valeur morale. S'il obtient la nullité, il ne peut réclamer le montant de l'indemnité conventionnelle de résiliation qui y est stipulée (Civ. 3e, 28 janv. 1998, BPIM 2/98, n° 101), mais il a droit à la contrevaleur des prestations fournies (Civ. 3e, 26 oct. 2010, n° 09-16.337, BPIM 1/11, inf. 23).

ACTUALISATION

346. Sous-traitance : suspension non-autorisée des travaux en cours de chantier. - Si le sous-traitant ne résilie pas unilatéralement le contrat pour défaut d'agrément du maître de l'ouvrage (L. du 31 déc. 1975, art. 3) ou s'il n'en sollicite pas la nullité pour absence de garantie de paiement (art. 14), le contrat doit recevoir application, de sorte que le sous-traitant ne peut pas suspendre ses travaux (Civ. 3e, 10 nov. 2021, n° 20-19.372, D. actu. 7 déc. 2021, obs. F. Garcia).

b. - Obligation du maître de l'ouvrage

347. Dans les contrats relatifs aux *bâtiments ou aux travaux publics* (sur la notion, V. *supra,* nos 328 s.), l'article 14-1, alinéa 3, de la loi de 1975 met à la charge du maître de l'ouvrage (sauf s'il fait construire un logement pour lui-même, art. 14-1, al. 4), qui a accepté le sous-traitant et qui a agréé les conditions de paiement, une obligation particulière si le sous-traitant ne bénéficie pas de la délégation de paiement : il « doit exiger de l'entrepreneur qu'il justifie avoir fourni la caution ».L'obligation pèse, le cas échéant, sur le maître d'ouvrage délégué (Civ. 3e, 6 juill. 2010, n° 09-12.323, BPIM 5/10, inf. 365). Le maître de l'ouvrage engage, à défaut, sa responsabilité envers le sous-traitant sur le fondement de l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil (Civ. 3e, 22 mai 1997, n° 95-13.676, Bull. civ. III, n° 108. – Civ. 3e, 18 févr. 2015, n° 14-10.604, BPIM 2/15, inf. 111). Sous condition qu'il ait accepté le sous-traitant (Civ. 3e, 9 mai 2012, n° 10-27.019, Bull. civ. III, n° 68), il doit mettre l'entrepreneur en demeure (Civ. 3e, 26 nov. 2003, n° 02-13.094, RJDA 4/04, n° 419) et, selon la jurisprudence, vérifier l'obtention effective de la garantie ainsi que la communication au sous-traitant des coordonnées de l'organisme financier et des termes de l'engagement (Civ. 3e, 18 juin 2003, n° 01-17.366). Si l'entrepreneur ne satisfait pas à l'injonction, le maître de l'ouvrage doit-il résilier ou suspendre le marché ? (V. Paris, 27 nov. 1996, RDI

1997. 236). La Cour de cassation écarte la responsabilité du maître de l'ouvrage qui, après avoir mis en demeure l'entrepreneur principal, conditionne l'agrément des conditions de paiement à la fourniture des garanties (Civ. 3e, 8 juill. 2015, n° 12-22.641 , BPIM 5/15, inf. 134) ; mais la simple mise en demeure est insuffisante (Civ. 3e, 8 sept. 2010, n° 09-68.724 , RDI 2010. 546 . – Civ. 3e, 21 nov. 2012, n° 11-25.101 , Bull. civ. III, n° 171). Quant au préjudice, il est difficile à circonscrire. Il peut résulter du solde restant dû au sous-traitant si celui-ci ne se prévaut pas de la nullité (Civ. 3e, 5 juin 1996, n° 94-15.825 , Bull. civ. III, n° 135. – Civ. 3e, 29 janv. 1997, RDI 1997. 235 . – Toulouse, 26 mai 1997, RDI 1998. 256) ; mais s'il s'en prévaut ? Il a été jugé que la nullité en elle-même n'est pas un préjudice caractérisé (Civ. 3e, 22 mai 1997, n° 95-13.676 , Bull. civ. III, n° 108). La Cour de cassation estime qu'il a droit à la contrevaleur des prestations fournies (V. *supra,* n° 346). Le sous-traitant ne peut se voir reprocher une absence de diligence particulière ou d'avoir commencé les travaux nonobstant l'absence de garantie (Civ. 3e, 3 avr. 2013, n° 12-16.795 , BPIM 3/13, inf. 184. – Civ. 3e, 12 juin 2013, n° 12-21.317 , BPIM 4/3, inf. 255). L'article 14-1, alinéa 2 (V. *supra,* nos 325 s.), dans sa rédaction issue de la loi MURCEF, oblige le maître de l'ouvrage à mettre le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations relatives à la fourniture des garanties principales au sous-traitant de second rang (art. 6 mod.). Outre que l'on ignore si, dans ce cas, le maître de l'ouvrage a le *choix* de mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de veiller au respect de cette obligation, on ne sait si la sanction de la carence du maître de l'ouvrage est la même que celle exposée à propos des obligations de l'entrepreneur principal. De plus, la question de savoir si chaque sous-traitance, en cas de sous-traités en chaîne, oblige à la constitution de garanties spécifiques, n'est pas clairement résolue par les textes. Lorsque des travaux supplémentaires sont exécutés sans l'autorisation du maître de l'ouvrage, celui-ci n'encourt aucun reproche pour n'avoir pas veillé à la constitution de garanties complémentaires (Civ. 3e, 27 avr. 2004, n° 02-19.298 . – Civ. 3e, 22 juin 2005, n° 04-16.011 , BPIM 5/05 inf. 321 ; *sur les obligations du maître d'ouvrage délégué en application de l'art. 14-1,* V. *supra,* n° 330).

2° - Action directe

348. Ouverture. - Le sous-traitant non payé par l'entrepreneur principal dispose d'une action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage (art. 12) (V. *infra,* n° 349). Cette action est, en principe, subsidiaire (V. *infra,* n° 356). En effet, si le maître de l'ouvrage est délégué dans le paiement, le sous-traitant a droit au paiement direct et l'action directe est inutile (V. *infra,* n° 350). Si l'entrepreneur principal a fourni une caution, celle-ci doit se substituer à lui dans le paiement (V. *infra,* nos 351 s.). L'action directe ne devrait donc jouer que si la garantie principale n'est pas constituée ou si elle n'est pas efficace, cette dernière éventualité ne pouvant concerner que la caution qui se dérobe à

son obligation (V. *infra,* n°s 354 s.). Le dispositif relatif à l'action directe est d'ordre public ; le sous-traitant ne peut y renoncer (Civ. 3e, 23 déc. 1983, Bull. civ. III, n° 170). L'action directe peut être portée devant le juge des référés (Com. 20 juin 1989, JCP 1990. IV, n° 170) et subsiste même en cas de difficultés dans l'entreprise (V. *infra,* n° 353).

a. - Domaine

349. Marchés privés. - L'action directe est réservée aux *marchés privés.* Toutefois, les marchés publics relèvent de l'action directe lorsque le contrat de sous-traitance est inférieur à 600 euros (L. du 21 déc. 1975, art. 6, al. 2) ; au-delà de ce seuil, c'est le droit au paiement direct qui s'applique (Décr. 25 mars 2016, art. 135, qui prévoit une dérogation pour les marchés passés par les services de défense). Les marchés des sociétés d'économie mixte, dans lesquelles plus de la moitié du capital est détenu par une personne publique, ne relèvent pas de l'action directe (Civ. 3e, 19 janv. 1982, préc. ; 12 janv. 1988, RDI 1988. 210 ; 2 oct. 2002, n° 00-12.271, Bull. civ. III, n° 198. – Paris, 16 déc. 1984, RDI 1985. 256 ; 11 mai 1988, RDI 1989. 54 ; CE 17 mars 1982, Lebon 123). Il suffit que la part des capitaux publics donne le contrôle de la société à une personne publique pour que le marché soit public et que l'action directe ne soit pas ouverte au sous-traitant (Com. 5 févr. 1991, RJDA 6/91, n° 489 ; *adde* : CE 17 mars 1982, préc.). Le droit au paiement direct, dans les marchés publics, étant réservé au « sous-traitant direct du titulaire du marché » (art. 6 mod. de la loi de 1975), il est permis de se demander si une action directe en paiement n'est pas ouverte aux sous-traitants de second rang et plus. L'instruction pour l'application du code des marchés publics (Instr. 28 août 2001, art. 112, JO 8-9 août, annexe) dispose que c'est désormais le mécanisme de caution prévu à l'article 14 et étendu par l'article 6, qui garantit le paiement. Or, l'article 14 est au titre de l'action directe. Le sous-traitant de second rang, dans les marchés publics, bénéficie-t-il de l'action directe contre le maître d'ouvrage public ? Le droit positif antérieur à la loi MURCEF incite à la prudence (V. *infra,* n° 361) ; le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 est muet sur ce point.

b. - Conditions d'ouverture

350. Sous-traitant accepté. - L'action directe est subordonnée à l'*acceptation du sous-traitant et à l'agrément des conditions de paiement* par le maître de l'ouvrage. Ces conditions sont nécessaires (Cass., ch. mixte, 13 mars 1981, D. 1981. 509, note Bénabent, JCP 1981. II. 1568, concl. Toubas, note Flécheux ; comp. Paris, 10 juin 1999, RDI 1999. 653, qui, au nom du fondement légal de l'action, n'exige pas l'accomplissement de la formalité) et cumulatives (Civ. 3e, 26 nov. 2003, n° 02-13.094, RJDA 4/04, n° 419). L'acceptation et l'agrément des conditions de paiement, pour les besoins de l'action directe, ne sont pas nécessairement préalables à la

conclusion du sous-traité (Cass., ch. mixte, 13 mars 1981, préc.). Ils peuvent intervenir en cours de marché (Civ. 3e, 12 mars 2008, n° 07-13.651) et même lors de l'exercice de l'action (Civ. 3e, 16 déc. 1987, Bull. civ. III, n° 208. – Paris, 25 mai 1990, D. 1990. IR 163 ; *contra* : Civ. 3e, 18 mai 1982, Bull. civ. III, n° 121, qui exigeait que la formalité fût antérieure à l'exécution des travaux). Un arrêt a admis que la formalité pouvait être accomplie lors de la liquidation judiciaire de l'entreprise principale (Civ. 3e, 30 mars 1993, RDI 1993. 378). L'acceptation est en principe *expresse.* Elle peut cependant être *tacite* (V. *supra,* n° 299). Elle doit alors résulter d'un comportement non équivoque du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 18 juill. 1984, RDI 1985. 59 ; 3 oct. 1985, RDI 1986. 206 ; 30 oct. 1991, RJDA 12/91, n° 1218 ; 3 mars 1999, RJDA 5/99, n° 553 ; 25 sept. 2002, n° 00-18.163, Bull. civ. IV, n° 114. – Versailles, 31 janv. 2000, RDI 2000. 179). Mais celui-ci est rarement retenu (arrêts précités). Il ne résulte pas, en tout cas, de la seule attitude passive du maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant (Civ. 3e, 7 oct. 1998, RJDA 11/98, n° 1218 ; 23 juin 1999, BPIM 5/99, n° 355).

c. - Exercice de l'action

351. Mise en demeure. - L'action directe peut être exercée par les sous-traitants quel que soit leur rang. Elle est toujours dirigée contre le maître de l'ouvrage. Le sous-traitant de second rang ne peut s'en prévaloir à l'égard de l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 12 juill. 1989, Bull. civ. III, n° 167 ; 15 janv. 2003, nos 01.02.967 et 01.13.148, qui précise qu'on ne peut reprocher à l'entrepreneur principal un manquement à l'article 14-1 de la loi qui ne concerne que le maître de l'ouvrage ; pour une action en responsabilité dirigée contre lui ; V. cep. : Versailles, 16 janv. 1987, Cah. dr. aff. 12/97, p. 376) ; mais il peut agir contre le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 29 mai 1980, Bull. civ. III, n° 107). L'action est précédée d'une *mise en demeure* adressée à l'entrepreneur principal lui demandant le paiement des sommes dues (L. du 21 déc. 1975, art. 12). Cette mise en demeure est obligatoire (Civ. 3e, 29 févr. 1984, RDI 1984. 315. – Com. 3 juill. 1990, n° 89-12.846, Bull. civ. IV, n° 199), même si le sous-traitant a reçu un acompte des mains du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 14 janv. 1998, BPIM 2/98, n° 102). L'action directe n'est recevable que si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure de le faire (Civ. 3e, 15 sept. 2016, n° 15-22.792, Sté Technilor et ac/ sté EMC ; L. 1975, art. 12). La forme de la mise en demeure n'étant pas précisée par les textes, elle doit être conforme au droit commun. Elle ne résulte pas de la mise en paiement d'une lettre de change émise au profit du sous-traitant par l'entrepreneur principal (Com. 3 juill. 1990, n° 89-12.846, Bull. civ. IV, n° 199) ; mais elle pourrait résulter d'une déclaration de créance au passif suivie d'une assignation (Versailles, 16 déc. 1993, RDI 1994. 249). Lorsque l'entrepreneur principal n'a pas fourni les garanties principales, la cession ou le nantissement des créances relatives

aux lots sous-traités sont inopposables au sous-traitant depuis l'introduction de l'article 13-1 dans la loi de 1975 ; auparavant, la jurisprudence avait admis que cette inopposabilité affectait les cessions ou nantissements postérieurs à la mise en demeure (par ex. : Com. 12 févr. 1991, RDI 1991. 347 ; 18 mars 1992, RDI 1992. 329). Lorsque la mise en demeure est postérieure à la mise à l'escompte des lettres de change tirées sur le maître de l'ouvrage et acceptées par lui, l'action directe est vouée à l'échec, car la provision a été transférée au banquier et le maître de l'ouvrage ne doit plus rien à l'entrepreneur principal (Com. 4 juill. 1989, D. 1990. 121 ; pour un billet à ordre : Com. 5 mars 1991, Gaz. Pal. 1991. Pan. 182).

352. Copie de la mise en demeure doit être adressée au maître de l'ouvrage (art. 12, al. 1er) - Cette formalité, est une condition de l'action directe (Versailles, 9 mars 1990, Gaz. Pal. 1990. Somm. 704). Elle est réputée acquise si le maître de l'ouvrage reconnaît avoir reçu copie de la mise en demeure et que le litige ne porte que sur la forme de la notification (Com. 9 juin 1999, n° 97-19.274, Bull. civ. III, n° 134) ; mais la circonstance que le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la mise en demeure par d'autres moyens ne suffit pas (Civ. 3e, 4 janv. 1996, RJDA 6/96, n° 782). La notification de la copie de la mise en demeure ne constitue pas une sommation de payer (Civ. 3e, 29 mai 1991, JCP 1991. IV. 289) et ne fait pas courir les intérêts moratoires contre le maître de l'ouvrage. Une sommation de payer, distincte, doit donc lui être adressée (Civ. 3e, 17 oct. 1990, RDI 1991. 65) qui, elle, fait courir les intérêts (Com. 3 juin 1992, RDI 1992. 329). Le maître de l'ouvrage qui reçoit copie de la mise en demeure ne peut plus payer l'entrepreneur principal ; s'il le fait, il s'expose à un double paiement. Réciproquement, il ne pourrait payer le sous-traitant avant d'avoir reçu copie de la mise en demeure ; s'il le faisait néanmoins, le paiement serait inopposable à l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 13 déc. 1995, RJDA 3/96, n° 346).

d. - Entreprises en difficulté

353. L'action directe subsiste si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire (L. du 21 déc. 1975, art. 12, al. 3. – Civ. 3e, 30 mars 1993, RDI 1993. 378), ou si elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le sous-traitant n'est pas tenu de procéder à la déclaration de sa créance si l'entrepreneur principal en difficulté a été mis en demeure avant le jugement d'ouverture de la procédure collective (Civ. 3e, 29 févr. 1984, Bull. civ. III, n° 56). Si la procédure est déjà ouverte lorsque le sous-traitant se manifeste, la déclaration de créance est assimilée à une mise en demeure (Com. 12 mai 1992, n° 89-17.908, Bull. civ. IV, n° 178 ; 9 mai 1995, n° 93-10.568, Bull. civ. IV, n° 131 ; 11 avr. 1995, RDI 1995. 549. – Civ. 3e, 20 juin 2007, n° 06-13.509, BPIM 5/07, inf. 331). Lorsque la créance n'est pas déclarée, la mise en demeure doit être adressée au représentant légal de l'entreprise principale, mais pas au débiteur lui-même qui est dessaisi (Civ. 3e, 3 juill. 1996, RJDA 11/96, n° 1328). Si les formalités ne

sont pas respectées, le paiement fait directement au sous-traitant est inopposable à l'entreprise principale en liquidation (Civ. 3e, 6 déc. 2006, n° 05-17.286).

e. - Effets de l'action directe

354. Obligations du maître de l'ouvrage. - Le maître de l'ouvrage contre lequel l'action directe est valablement exercée n'est tenu que dans la limite de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal au moment de la réception de la copie de la mise en demeure (L. du 21 déc. 1975, art. 13. – Com. 3 juin 1992 et 18 mars 1992, RDI 1992. 328). C'est à lui d'établir que les paiements faits à l'entrepreneur principal l'ont été avant qu'il n'ait eu connaissance du sous-traité (Civ. 3e, 8 nov. 2006, n° 05-16.948, BPIM 1/07, inf. 36). L'assiette du recours est constituée de l'ensemble des sommes restant dues au titre du marché, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des lots sous-traités (L. du 21 déc. 1975, art. 13. – Cass., ch. mixte, 18 juin 1982, D. 1983. 221, note Bénabent, JCP 1982. II, n° 19858, concl. Sadon. – Civ. 3e, 29 mai 1991, Bull. civ. III, n° 159 ; 19 juin 1996, n° 94-16.955). Les sommes éventuellement retenues par le maître de l'ouvrage en raison de malfaçons entrent dans l'assiette du recours (Civ. 3e, 7 mai 1996, BPIM 4/96, n° 270). Le maître de l'ouvrage n'est tenu que dans la limite du prix des travaux exécutés (Civ. 3e, 3 juill. 1996, RJDA 11/96, n° 1326). S'il fournit la garantie mise à sa charge par l'article 1799-1 du code civil, le sous-traitant peut agir contre la banque qui fournit le crédit spécifique. Le sous-traitant, pour sa part, ne peut réclamer que les sommes correspondant au lot sous-traité sans pouvoir réclamer le prix de travaux supplémentaires demandés par l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 31 mars 1993, D. 1993. IR 119. – Paris, 9 févr. 2000, RDI 2000. 179). Il ne peut pas demander non plus le paiement de dommages-intérêts réclamés à l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 8 juill. 1998, n° 96-16.562) et, en particulier, les intérêts de retard des sommes dues par celui-ci (Civ. 3e, 2 oct. 1984, Bull. civ. III, n° 158) ; mais à compter de la réception de la copie de la mise en demeure, le maître de l'ouvrage est tenu des intérêts qui courent alors (V. *supra,* n° 352). Si plusieurs sous-traitants exercent l'action directe, il y a lieu à répartition du solde disponible entre les mains du maître de l'ouvrage, proportionnellement au montant de leurs créances (Civ. 3e, 11 févr. 1987, JCP 1987 IV. 102. – Paris, 29 janv. 1985, RDI 1985. 256).

355. Paiement direct en cas de délégation. Le sous-traitant ne bénéficie que d'une action directe et non d'un droit au paiement direct, qui est toutefois possible lorsque le maître de l'ouvrage est délégué au sous-traitant (L. du 21 déc. 1975, art. 14 ; V. *supra,* n° 344), ou lorsque le contrat prévoit un paiement direct (Civ. 3e, 3 févr. 1988, Bull. civ. III, n° 30). Il en résulte que le sous-traitant conserve le droit d'agir contre l'entrepreneur principal, en particulier pour les sommes n'entrant pas dans l'assiette de l'action directe (Civ. 3e, 30 mars 1993, préc. *supra,* n° 322). La Cour de cassation considère d'ailleurs que le droit au paiement direct n'emporte pas délégation parfaite

(Civ. 3e, 10 mai 1991, n° 89-16.430, D. 1992. 115, obs. Bénabent), et qu'une clause de paiement direct ne prive pas le sous-traitant du droit d'exercer l'action directe (Com. 15 oct. 1996, RJDA 1/97, n° 48).

f. - Action subsidiaire

356. Fondement. - Le sous-traitant qui ne peut exercer l'action directe (non-acceptation ou refus d'agrément) peut toujours tenter d'agir contre le maître de l'ouvrage sur un autre fondement : l'enrichissement sans cause (Civ. 3e, 11 juin 1985, D. 1986. 456, obs. Dubois ; *contra :* Amiens, 8 janv. 1987, D. 1987. 336, note Dubois ; comp. Civ. 3e, 9 déc. 1992, RDI 1993. 223 ; 4 déc. 2002, n° 01-03.907, qui écarte cette possibilité lorsque le sous-traitant bénéficie d'une action directe qu'il ne peut exercer faute d'agrément) ; la gestion d'affaire (Civ. 3e, 13 déc. 1978, Bull. civ. III, n° 372) ; l'action en responsabilité contre le maître de l'ouvrage (V. *supra,* nos 331 s.), étant précisé que cette action et l'action directe sont indépendantes l'une de l'autre (Civ. 3e, 25 sept. 2002, n° 00-18.163, RJDA 2/03, n° 134 ; V. *infra,* nos 355 s.). Mais le sous-traitant n'a aucun droit particulier sur la somme correspondant à la retenue légale de garantie qui est opposable à tous les constructeurs (Civ. 3e, 25 nov. 1987, Bull. civ. III, n° 197).

B - Marchés publics

1° - Paiement direct

357. Exclusion des garanties principales. - Lorsque le marché principal est un marché public, il n'y a pas lieu à constitution des *garanties principales,* et le sous-traité n'est pas entaché de nullité à ce titre (Civ. 3e, 13 janv. 2009, n° 07-41.543), encore que la question puisse se discuter lorsque le marché est inférieur à 600 euros. Si le sous-traité n'est pas inférieur à 600 euros (s'il l'est, l'action directe est seule possible, V. *supra,* n° 349), le sous-traitant dispose d'un droit au *paiement direct* par le maître de l'ouvrage (L. du 1975, art. 4 s ; Décr. n° 2016-360, art. 134 s.) Ce droit est subordonné à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément des conditions de paiement, qui sont des conditions cumulatives (CE 13 juin 1986, D. 1986. IR 424, obs. Terneyre ; V. *supra,* nos 321 s.). Le droit au paiement direct est réservé aux sous-traitants directs du titulaire du marché (L. 1975, art. 6, al. 1er, mod.). Sauf à admettre la responsabilité du maître d'ouvrage public qui s'est soustrait aux obligations que lui impose l'article 14-1, alinéa 2 modifié, et qui pourrait se calquer sur celle du maître d'ouvrage privé (pour l'absence de présentation, V. *supra,* n° 328 ; pour l'absence de fourniture des garanties principales, V. *supra,* n° 348), il est permis de se demander si les sous-traitants de second rang et

plus disposent d'une action directe en paiement contre le maître d'ouvrage public (V. *supra,* n°s 349 et *infra* n° 361).

358. Demande en paiement. - Le sous-traitant « régulier » adresse sa *demande de paiement* au titulaire du marché qui la transmet à la personne qualifiée pour procéder au paiement et la procédure applicable est alors celle décrite par les articles 135 et suivants du décret du 25 mars 2016. Celle-ci avise le sous-traitant de la date de réception de la demande et lui indique les sommes dont le paiement a été accepté par le titulaire du marché. La Cour de cassation statuant sur les litiges portés devant elle sous le régime du code des marchés publics, a jugé que le titulaire du marché peut refuser les pièces justificatives qui doivent lui être adressées (Civ. 3e, 4 janv. 2006, n° 04-13.943, BPIM 2/06, inf. 111). S'il ne réagit pas, le sous-traitant adresse directement sa demande au responsable du marché qui met le titulaire en demeure de lui faire connaître s'il a opposé un refus motivé et de le lui faire connaître dans les quinze jours. Passé ce délai, si aucune justification n'est fournie, les sommes sont dues et doivent être payées dans le délai prévu à l'article 98 du code des marchés publics aujourd'hui abrogé, et remplacé par l'article 136 du décret n° 2016-360 (Civ. 3e, 30 mars 1994, RDI 1994. 454). Selon un arrêt, l'entrepreneur principal peut être contraint de remettre les pièces justificatives au maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 8 mars 1989, Le Moniteur 30 juin 1989). Les dispositions du droit des marchés publics concernant les acomptes, avances et règlements (Décr. n° 2016-360, art. 110 s.) sont applicables au sous-traitant aux conditions prévues par le décret (préc., art. 135 s.).

359. La demande de paiement direct conduit le maître de l'ouvrage à vérifier que le titulaire n'a pas *cédé ou nanti ses créances,* spécialement lorsque la demande d'acceptation est postérieure à la conclusion du marché, ou lorsque l'évolution du marché conduit son titulaire à sous-traiter une prestation supérieure à celle prévue. Le titulaire du marché doit alors produire l'exemplaire unique du marché ou une attestation de mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement (Décr. n° 2016-360, art. 135 2°).

360. Montant dû. - L'engagement du maître de l'ouvrage ne peut le conduire à payer plus que ce qu'il doit au titre du marché principal, ni à verser au sous-traitant plus que ce qui correspond au montant du sous-traité (CCAG, art. 13-51. – Civ. 3e, 31 mars 1993, n° 91-12.513, Bull. civ. III, n° 49, à propos de travaux supplémentaires). Le maître de l'ouvrage qui ne doit plus rien à l'entrepreneur principal lorsque le paiement direct lui est réclamé, n'est tenu à aucun paiement envers le sous-traitant (Civ. 3e, 7 mai 1997, RJDA 8.9/97, n° 1042). Cette solution, calquée sur celle de l'action directe, ne se justifie pas nécessairement : en effet, le maître de l'ouvrage a pour créancier le sous-traitant et non l'entrepreneur principal ; elle s'explique cependant par le fait que la Cour de cassation estime que le droit au paiement direct ne prive pas le sous-traitant de la possibilité d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal. Le *droit au paiement direct*

n'emporte donc pas délégation parfaite (Civ. 3e, 10 mai 1991, D. 1992. 115, obs. Bénabent ; 15 janv. 1992, n° 90-11.356, Bull. civ. III, n° 20 ; comp. : Civ. 3e, 15 déc. 1993, RDI 1994. 53, qui retient la délégation parfaite qui était contractuellement prévue. – Civ. 3e, 3 déc. 2008, n° 07-19.997). Le Conseil d'État décide que le droit au paiement direct est exclu lorsque l'entrepreneur principal a versé une somme équivalente au sous-traitant, même si cette somme concerne une créance extérieure à ce sous-traité (CE 3 nov. 1989, D. 1990. Somm. 244, obs. Terneyre). Un autre arrêt semble limiter le droit pour le sous-traitant de se faire payer par l'entrepreneur principal qu'au cas où les conditions du paiement direct ne sont pas réunies (CE 23 mars 1990, RDI 1990. 207).

2° - Sous-traitance irrégulière

361. Le sous-traitant non accepté ou dont les conditions de paiement ne sont pas agréées est dans une situation irrégulière et il doit accomplir diverses diligences pour se faire connaître (V. *supra,* nos 321 s.). Le maître de l'ouvrage, pour sa part, doit adresser une mise en demeure à l'entrepreneur principal afin de régulariser le marché. Le maître de l'ouvrage qui s'abstient peut engager sa responsabilité bien que l'article 14-1 de la loi de 1975 se trouve au titre de l'action directe (Versailles, 31 janv. 1991, D. 1992. Somm. 118, obs. Bénabent). En effet, le code des marchés publics (C. marchés, art. 114 et 116) ainsi que le Cahier des clauses administratives générales (CCAG, art. 49) donnent des moyens de coercition au maître de l'ouvrage, qui peut commettre une faute engageant sa responsabilité (CE 9 mars 1984, Havé, AJDA 1984. 100, note Sablier et Caro ; 13 juin 1986, D. 1986. IR 424, note Terneyre). Lorsque le sous-traitant ne peut agir en paiement direct, il ne peut exercer l'action directe qui n'a pas un caractère subsidiaire. Le paiement direct et l'action directe sont exclusifs l'un de l'autre (CE 26 oct. 1984, Éts Mure ; 17 mars 1982, Lebon 123). La question est posée de savoir si ces règles concernent le sous-traitant de second rang qui ne bénéficie pas du droit au paiement direct. La responsabilité du maître de l'ouvrage qui a méconnu les obligations mises à sa charge par l'article 14-1, alinéa 2, est probable ; l'action directe moins (V. *supra,* nos 349 et 357).

§ 3 - Rapports créés par la sous-traitance

362. Le contrat de sous-traitance est créateur d'obligations entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal (V. *infra,* nos 363 s.), le maître de l'ouvrage (V. *infra,* nos 368 s.), et les autres constructeurs (V. *infra,* nos 373 s.). L'entrepreneur principal répond du fait de son sous-traitant (V. *infra,* n° 372). Des règles particulières concernent le contrat de construction de maison individuelle (V. *infra,* n° 374).

A - Rapports entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal

363. Contrat d'entreprise. - Le sous-traitant est lié à l'entrepreneur principal par un contrat d'entreprise. Il relève par conséquent du droit commun de ce contrat, lequel implique en théorie une « réception des travaux », encore que l'on peut en discuter l'intérêt pratique, compte tenu de ce que la réception, en tant que constat spécifique de l'achèvement, n'a pas de raison d'être ici (BOUBLI, La responsabilité de l'assurance des architectes entrepreneurs et autres constructeurs, 3e éd., 1991, Journal des notaires, n° 236 ; MALINVAUD, Droits et obligations des sous-traitants dans les marchés privés, RDI 2006. 165). Ce contrat peut donner lieu à application de la retenue de garantie de 5 % applicable tant au marché principal qu'au sous-traité (L. 16 juill. 1971, art. 4). Cette retenue de garantie peut se cumuler avec une garantie contractuelle impliquant une retenue à d'autres fins que celle prévue par la loi de 1971 (Civ. 3e, 17 juin 2015, n° 14-19.863, D. 2015. 1389. – Rappr. Civ. 3e, 10 déc. 2015, n° 14-25.192, RDI 2016. 146). Non tenu des garanties décennale et biennale (Civ. 3e, 4 nov. 1999, BPIM 1/00, n° 21) et probablement pas de la garantie de parfait achèvement qui ne se conçoit qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, le sous-traitant est *responsable* selon le *droit commun.* Il est tenu, en cas de dommage, d'une *obligation de résultat* (Civ. 3e, 26 avr. 2006, n° 05-13.254, BPIM 4/06, inf. 264. – Civ. 3e, 22 juin 2010, n° 09-16.199, RDI 2010. 550. – V. déjà : Civ. 3e, 3 déc. 1980, RDI 1981. 224 ; 21 janv. 1981, RDI 1981. 512 ; 24 févr. 1982, RDI 1982. 515 ; 29 mai 1984, RDI 1984. 414 ; 3 oct. 1985, RDI 1986. 206 ; 3 juin 1987, RDI 1987. 454 ; 13 juin 1990, n° 88-17.234, Bull. civ. III, n° 145 ; 15 janv. 1992, RDI 1992. 216, pour un sous-traitant de second rang ; 3 juin 1992, RDI 1992. 330 ; 17 déc. 1997, BPIM 2/98, n° 103 ; 27 mai 1999, BPIM 4/99, n° 285 ; 4 nov. 1999, BPIM 1/00, n° 21. – Versailles, 13 déc. 1999, RDI 2000. 177 ; 6 déc. 2000, RDI 2001. 60 ; 26 avr. 2006, n° 05-13.254 ; V. B. BOUBLI, *op. cit.,* nos 82 et 454 ; AUBY et PÉRINET-MARQUET, *op. cit.,* n° 1132 ; V. égal. B. BOUBLI, La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs après la réception des travaux, RDI 1982. 1 s.). La responsabilité qu'il encourt ne cède que devant la cause étrangère (Civ. 3e, 23 oct. 1984, Bull. civ. III, n° 171 ; 14 janv. 1987, JCP 1987. IV. 94) qui ne résulte ni de la faute d'un autre sous-traitant (Civ. 3e, 20 oct. 1979, RDI 1980. 170), ni des vices des matériaux (Civ. 3e, 29 oct. 1986, Mon. TP 21 nov. 1986 ; *contra* : Paris, 14 sept. 1990, RDI 1991. 65), mais peut résulter de la faute de l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 4 déc. 1985, RDI 1986. 206. – Versailles, 30 janv. 1985, RDI 1986. 73), encore qu'il ne soit pas dispensé à son égard de respecter l'obligation de renseignement et de conseil qui pèse sur tout entrepreneur (Civ. 3e, 16 oct. 1985, Bull. civ. III, n° 125. – Civ. 1re, 24 janv. 1995, Juris-Data n° 000 820. – Civ. 3e, 14 déc. 2004, n° 03-18.222, RJDA 6/05, n° 694 ; 4 janv. 2006,

n° 04-18.455, BPIM 2/06, inf. 112. – Rouen, 22 juin 1988, Gaz. Pal. 1989. 1. Somm. 196). La règle s'applique au sous-traitant de *second rang* (Civ. 3e, 15 janv. 1992, RDI 1992. 216). Lorsque l'entrepreneur exerce un recours subrogatoire dans les droits du voisin (Civ. 3e, 26 avr. 2006, n° 05-13.254, BPIM 4/06, inf. 264) ou du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 3 déc. 1997, RDI 1998. 94), c'est la faute du sous-traitant qui conditionne sa part contributive au dommage.

364. Responsabilité. - La responsabilité du sous-traitant, qui relève de la compétence judiciaire dans les rapports avec l'entrepreneur, se prescrivait naguère par *trente ans* (Civ. 3e, 25 juin 1985, Bull. civ. III, n° 102 ; 13 juin 1990, n° 88-17.234, *ibid.* III, n° 145 ; V. BOUBLI, *op. cit.,* 3e éd., nos 458 s.) ou *dix ans* lorsque l'article 110-I.4 du code de commerce s'applique, le délai commençant à courir du jour où l'entrepreneur principal avait été assigné par le maître de l'ouvrage s'il était la victime (Civ. 3e, 29 janv. 1992, RDI 1992. 330). La prescription de droit commun a été ramenée par la jurisprudence à dix ans, dans le marché principal pour les seuls désordres intermédiaires (Civ. 3e, 11 juin 1981, Bull. civ. III, n° 120, et étude BOUBLI, RDI 1982. 1 s.), puis a été généralisée (Civ. 3e, 26 mai 1992, RDI 1992. 333 ; 12 mai 1993, RDI 1993. 514 ; 17 mars 1993, n° 90-20.640, Bull. civ. III, n° 38 ; 12 oct. 1994, RDI 1995. 109). On s'est demandé si cette extension ne concernait pas également le sous-traitant. Depuis l'ordonnance du 8 juin 2005 et la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur la prescription, les actions en responsabilité contre le sous-traitant sont soumises à un régime uniforme, les textes (C. civ., art. 1792-4-2 et 1792-4-3) visant « les actions en responsabilité » : l'action se prescrit par dix ans à compter de la réception lorsque le dommage affecte l'ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionné aux articles 1792 et 1792-2 du code civil (désordres de nature « décennale » : C. civ., art. 1792-4-2) ; elle se prescrit par deux ans à compter de la réception lorsque le dommage affecte les éléments d'équipement visés à l'article 1792-3 du code civil (désordres de nature « biennale » : art. 1792-4-2) ; elle se prescrit par dix ans lorsque la responsabilité de droit commun du sous-traitant est engagée (C. civ., art. 1792-4-3). L'entrepreneur mis en cause dans ces délais doit donc appeler le sous-traitant en garantie avant leur expiration. Toutefois, ces délais ayant pour point de départ la réception du marché principal à laquelle le sous-traitant n'est pas partie (Civ. 3e, 20 oct. 2009, n° 08-15.381), la responsabilité encourue pour les désordres avant réception peut relever de la prescription quinquennale, ce qui suppose la réunion de plusieurs conditions difficiles à constater lorsque le marché a été mené à son terme, de sorte que ce délai semble devoir s'appliquer aux dommages aux ouvrages réalisés par un sous-traitant qui n'achève pas le chantier. Avec les réserves d'usage, il est permis de se demander si le sous-traité peut procéder à un aménagement conventionnel de la prescription comme l'autorise le nouvel article 2254 du code civil (sur l'application dans le temps de la nouvelle prescription, V. Civ. 3e, 8 sept. 2010, n° 09-67.434, BPIM 6/10, inf. 459).

365. Dans le cadre des obligations qu'il assume envers l'entrepreneur principal, le sous-traitant ne supporte pas la charge des *pénalités de retard* figurant au marché principal (Paris, 20 janv. 1988, RDI 1988. 209), à moins qu'il ait consenti à le faire (Com. 25 juin 1991, n° 90-11.230, Bull. civ. IV, n° 234 : accord implicite. – Civ. 3e, 11 juill. 2001, BPIM 5/01, n° 307 ; comp., sur la retenue de garantie dans le sous-traité : Civ. 3e, 8 juill. 1992, RDI 1993. 79 ; V. aussi : Com. 20 nov. 1979, RDI 1980. 170). Il supporte, en revanche, la charge des risques par application de l'article 1788 du code civil si la chose périt avant qu'elle n'ait été livrée (Civ. 3e, 2 nov. 1983, RDI 1984. 186). N'étant pas le préposé de l'entrepreneur principal, celui-ci ne répond pas de son fait lorsqu'un dommage est causé à un tiers (Civ. 3e, 8 mars 1989, Bull. civ. III, n° 58), mais il répond tant de son fait que de celui du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage. Lorsque l'entrepreneur principal est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, il exerce son action contre le sous-traitant sur le fondement de l'article 1382 du code civil (Civ. 3e, 3 déc. 1997, n° 1705, RDI 1998. 94 ; 9 déc. 1998, BPIM 1/99, n° 30).

366. Sous-traitance irrégulière. - En cas de *sous-traitance irrégulière* (absence d'acceptation et d'agrément), le sous-traitant demeure tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat (Civ. 3e, 3 juin 1992, RDI 1992. 330). Toutefois, l'article 3, alinéa 2, de la loi de 1975 dispose que « lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage […] l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ». Ce texte réserve au sous-traitant une faculté de retrait s'il n'est pas accepté ou si l'entrepreneur principal n'est pas diligent : cette faculté de retrait peut s'analyser en une nullité relative ou une résiliation du contrat que le sous-traitant peut confirmer, ou à laquelle il peut renoncer. Mais il ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement des travaux qu'il a exécutés et le rejeter pour échapper à sa responsabilité contractuelle (Civ. 3e, 14 déc. 2011, n° 10-28.149, Bull. civ. III, n° 213) Même non accepté, il reste tenu envers l'entrepreneur principal de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou réclame le paiement (Civ. 3e, 13 avr. 1988, Bull. civ. III, nos 72 et 73, D. 1988. 521, note P. Dubois, RDI 1988. 299, Gaz. Pal. 1988. 2. 606, obs. B. Sablier et J.-E. Caro, D. 1988. IR 115, JCP 1989. II. 21302, note R. Martin, RGAT 1989. 390, note A. d'Hauteville ; 10 janv. 1990, n° 88-16.112, Bull. civ. III, n° 16 ; 3 juin 1992, RDI 1992. 330 ; 15 janv. 1992, n° 90-16.081, Bull. civ. III, n° 21 ; rappr. : Civ. 3e, 13 sept. 2006, n° 05-11.533, BPIM 6/06, inf. 428). Ces décisions mettent fin à l'incertitude alimentée par plusieurs arrêts des cours d'appel qui estimaient que le sous-traitant non accepté ne répondait que de sa faute (AUBY et PÉRINET-MARQUET, *op. cit.,* n° 1133). Le sous-traitant qui veut échapper à la responsabilité contractuelle objective doit donc résilier ou faire annuler le contrat ; mais il perd alors, semble-t-il, le droit d'obtenir le paiement des travaux exécutés, conformément à ce

contrat : la créance ne peut être que quasi contractuelle (pour un sous-traitant de second rang, V. Civ. 3e, 15 janv. 1992, RDI 1992. 216).

367. *L'entrepreneur principal peut engager sa responsabilité de contractant envers son sous-traitant* (Civ. 3e, 13 sept. 2006, no 05-10.125, BPIM 6/06, inf. 438), mais il n'engage pas sa responsabilité délictuelle envers les tiers en cas de faute du sous-traitant (Civ. 3e, 8 sept. 2009, no 08-12.273, Bull. civ. III, no 181. – Civ. 3e, 22 oct. 2010, no 09-11.007, RDI 2010. 604). Lorsque l'entrepreneur principal ne fournit pas les garanties principales, le sous-traité est frappé d'une nullité relative qui ne dispense pas l'entrepreneur principal de la réparation du préjudice subi par le sous-traitant, et peut engager la responsabilité du maître de l'ouvrage (V. *supra,* nos 293 s.). Un arrêt décide toutefois que si le cautionnement ne peut être fourni valablement après la conclusion du sous-traité, une délégation de paiement acceptée par le sous-traitant purge la cause de nullité de l'article 14 de la loi de 1975 (Paris, 23 mai 2001, RDI 2002. 52).

B - Rapports entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage

368. Responsabilités. - Aux rapports qui résultent de l'action directe et du paiement direct s'ajoutent ceux relatifs à la responsabilité encourue. Le sous-traitant peut rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage qui a connaissance d'une sous-traitance non déclarée et n'accomplit pas les diligences qui lui incombent (manquement aux dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1975, V. *supra,* nos 333, 334 et 347 ; règles relatives aux marchés publics, V. *supra,* nos 340 et 357). Il peut aussi se prévaloir d'une règle quasi contractuelle dans certains cas (V. *supra,* no 366).

369. Le maître de l'ouvrage, peut également rechercher la *responsabilité du sous-traitant* et obtenir, le cas échéant, sa condamnation « *in solidum* » avec les autres constructeurs responsables (Civ. 3e, 23 sept. 2009, no 07-21.634, Bull. civ. III, no 197. – Civ. 3e, 3 avr. 2013, no 12-16.475, BPIM 3/13, inf. 185). La compétence, en principe judiciaire (T. confl. 22 janv. 2001, RDI 2001. 164), est en partie remise en cause lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique (V. *supra,* no 322). L'indemnité mise à la charge du sous-traitant responsable ne se compense pas avec le prix de son marché qui concerne ses rapports avec l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 14 janv. 2014, no 12-20.673, BPIM 2/4, inf. 105). Le sous-traitant n'étant pas responsable des dommages sur le fondement des articles 1792 et suivants (par ex. : Civ. 3e, 20 juin 1989, Bull. civ. III, no 146) et le maître de l'ouvrage étant un tiers au sous-traité, l'action en responsabilité qu'il exerce contre le sous-traitant était fondée sur les articles 1382 et suivants (C. civ., art. 1240 s. issus de l'ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016) du code civil (Civ. 1re, 9 mars 1964, Bull. civ. I, no 138. – Civ. 3e, 22 janv.

1982, *ibid.* III, n° 164. – Com. 17 févr. 1981, RDI 1982. 86 ; V. aussi : CE 6 mars 1987, RDI 1987. 231). La chambre commerciale et la première chambre civile ont rompu avec ce principe, à la fin des années 80, en posant que la responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage est de « nature nécessairement contractuelle, et que l'action peut être exercée dans la double limite des droits du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur principal, et de l'étendue de l'engagement du sous-traitant » (Com. 17 févr. 1987, JCP 1987. II. 20892, note Dubois, D. 1987. 543, note Jourdain, Gaz. Pal. 1988. 1. 224, note Robine et Viandier, RGAT 1987. 593, obs. J. Bigot. – Civ. 1re, 8 mars 1988, Bull. civ. I, n° 69, JCP 1988. II. 21070, note Jourdain, D. 1988. IR 87, RDI 1988. 317, obs. Dubois, RTD civ. 1988. 551, obs. Rémy ; 21 juin 1988, Bull. civ. I, n° 202, JCP 1988. II. 21125, note Jourdain ; V. LARROUMET, L'action de nature nécessairement contractuelle et la responsabilité civile dans les ensembles contractuels, JCP 1988. I. 3357). La troisième chambre civile a résisté à cette évolution (Civ. 3e, 22 juin 1988, Bull. civ. III, n° 115. – Civ. 3e, 12 août 1988, RDI 1988. 461. – Civ. 3e, 28 mars 1990, n° 88-15.197, D. 1991. 25, note Kullmann) et l'assemblée plénière s'est finalement rangée à sa jurisprudence, en énonçant que le « sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage », condamnant ainsi la solution retenue par la chambre commerciale, il est vrai difficile à appliquer au marché de travaux immobiliers (Cass., ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602, BICC nov. 1991, concl. Hourier, D. 1991. 549, obs. J. Ghestin, Gaz. Pal. 1992. 1. Somm. 2, note Peisse, Mon. TP 8 nov. 1991, RDI 1992. 71 ; dans le même sens : Civ. 3e, 11 déc. 1991, RDI 1992. 71 ; 7 juill. 1992 et 18 nov. 1992, RDI 1993. 79. – Civ. 1re, 7 juill. 1992, n° 91-10.162, Bull. civ. I, n° 221 ; 19 nov. 1997, RDI 1998. 93 ; 10 janv. 2001, RDI 2001. 166 ; CE 6 mars 1987, RDI 1987. 231 ; V. BOUBLI, Réflexions sur les obligations des parties dans la sous-traitance de marchés de travaux immobiliers, RDI 1988. 391 et sur l'arrêt du 12 juill. 1991 ; Transfert de propriété et responsabilité dans les groupes de contrats, *ibid.* 1992. 27 s.). Toutefois, un lien contractuel peut se créer entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage, en cas de *novation* (Civ. 3e, 6 mai 1981, RDI 1982. 86). Il est en outre admis que le sous-traitant peut, par *subrogation* aux droits du maître de l'ouvrage, agir contre un codébiteur (Civ. 3e, 6 janv. 1983, RDI 1983. 453).

370. Prescription. - Il est toutefois permis de se demander avec Ph. MALINVAUD (RDI 2009. 257), si l'uniformisation des délais de prescription (V. *supra,* n° 364) et la place des articles concernés (notamment l'article 1792-4-3 sur la responsabilité de droit commun) à la section « Devis et marchés » ne remettent pas en cause le fondement de la responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage. Toutes les responsabilités postérieures à la réception du marché principal se prescrivent (sauf le cas de la « biennale ») par dix ans à compter de cette date contre les « constructeurs […] et leurs sous-traitants » (art. 1792-4-3) ou contre le « sous-traitant » (art. 1792-4-2). Toutefois, le débat sur le fondement de la responsabilité encourue peut subsister sur la

question de la faute : celle-ci doit-elle être établie par le maître de l'ouvrage ou ce dernier peut-il se prévaloir d'une obligation de résultat en soutenant que la chose a été ouvrée à son profit ? Enfin, la question de l'aménagement conventionnel de la prescription, s'il est possible, et de son opposabilité au maître de l'ouvrage se pose : si l'aménagement est licite, le maître de l'ouvrage qui n'est pas d'accord peut-il refuser son agrément au sous-traitant ? *Quid* alors des répercussions pour l'entrepreneur principal ? La prescription des actions récursoires peut également poser problème : le maître de l'ouvrage peut être mis en cause par le voisin (Civ. 3e, 21 mai 2008, RDI 2008. 546), qui peut aussi agir contre le sous-traitant pris en qualité de « voisin occasionnel » (même arrêt). L'action contre le maître de l'ouvrage se prescrit par cinq ans ; mais *quid* de celle exercée contre le sous-traitant ? Est-il pris en tant que sous-traitant d'un constructeur au sens de l'article 1792-4-3 ou seulement en tant que voisin occasionnel ? L'action subrogatoire étant ouverte au maître de l'ouvrage contre le sous-traitant, il faudrait, dans un souci d'harmonisation, admettre que la prescription est toujours quinquennale ; mais même alors cela ne réglerait pas le sort des ouvrages empiétant sur le terrain d'autrui du fait du sous-traitant, car dans ce cas, la prescription acquisitive peut n'être acquise qu'au bout de 30 ans (art. 2272).

371. Le sous-traitant qui dispose d'un droit direct contre le maître de l'ouvrage peut demander le bénéfice de la garantie de paiement instituée par l'article 1799-1 du code civil (L. no 94-1475 du 10 juin 1994, art. 5-II modifiant l'art. 12 de la loi du 31 déc. 1975).

C - Rapports entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage

372. Fait d'autrui. - L'entrepreneur principal répond du fait du sous-traitant comme de son propre fait (Civ. 3e, 25 avr. 1984, RDI 1984. 414 ; CE 21 juill. 1970, Sieurs Lachaud et Aubineau, Lebon 509 ; 20 juill. 1990, RDI 1990. 490 ; Civ. 3e, 12 juin 2013, no 11-12.283, BPIM 5/13, inf. 329). Selon un arrêt, lorsque la responsabilité de l'entrepreneur principal n'est pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants, et que le dommage est imputable au sous-traitant, la preuve de la faute du sous-traitant dispense de la preuve de la faute de l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 13 mars 1991, no 89-13.833, Bull. civ. III, no 91), ce qui est logique puisque l'entrepreneur principal est contractuellement tenu pour autrui. Lorsque l'entrepreneur principal est mis en cause, au titre d'une garantie légale pour un fait du sous-traitant, l'action doit être engagée contre lui dans le délai de cette garantie, alors même, selon un arrêt, que la responsabilité du sous-traitant serait quasi délictuelle dans les rapports avec le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 21 oct. 2009, no 08-19.087, pour une garantie biennale ; mais avec le nouvel article L. 1792-4-2, l'action contre le sous-traitant se prescrit aussi par deux ans, V. *supra,* nos 364 et 370).

D - Rapports entre le sous-traitant et les autres constructeurs

373. Tiers. - Le sous-traitant est un tiers dans ses rapports avec les autres constructeurs. Il n'engage sa responsabilité envers eux et ne peut se prévaloir de la leur que sur le fondement des articles 1382 et suivants (Civ. 3e, 22 sept. 1982, RDI 1983. 65), à moins qu'il n'y ait subrogation (V. *infra,* n° 566). Depuis la loi du 17 juin 2008, l'action se prescrit en principe par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit (la victime) a *connu ou aurait dû connaître les faits* permettant de l'exercer (C. civ., art. 2224). Bien que la question soit discutable compte tenu de la rédaction des articles 1792-4-2 et 1792-4-3, il est probable que la prescription décennale n'est pas applicable, d'autant que l'action récursoire a un point de départ qui n'est pas la réception des travaux. La part du sous-traitant en cas de responsabilité *in solidum,* peut être influencée par son obligation de conseil (V. CHARBONNEAUX, De l'obligation de conseil du sous-traitant, RDI 2010. 593).

E - Cas particulier du contrat de construction de maison individuelle

374. Textes. - L'article L. 231-6 nouveau du code de la construction et de l'habitation, précisant les modalités de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-2 du même code, dispose dans son paragraphe III que le garant « doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ». Le même garant peut être amené à « proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même les marchés de travaux » destinés à l'achèvement de l'immeuble. Le garant fait donc ici figure à tout le moins de maître d'ouvrage délégué, sinon de constructeur substitué. Quelle que soit sa qualification, la désignation de la personne qui terminera les travaux emportera modification des sous-traités indépendamment de leur suspension probable ; ou bien la personne désignée se substituera au constructeur de maison individuelle, option qui pourrait relever de la délégation imparfaite plutôt que de la délégation parfaite s'inscrivant dans une novation par changement de débiteur, ou bien la personne désignée se substituera au sous-traitant du constructeur, hypothèse envisageable lorsque le sous-traitant est entrepreneur général. Le risque de résiliation du sous-traité n'est pas exclu, et si la garantie d'achèvement est conçue en faveur du maître de l'ouvrage, elle doit aussi permettre le paiement du sous-traitant. Encore que la loi n'en ait rien dit, le mécanisme de substitution d'un débiteur à l'autre, autant que l'objet de la garantie, donnent à penser que le garant de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 pourrait (et sans doute *devrait*) être le même organisme que celui qui est appelé à donner sa caution conformément à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 (V. *Contrat de construction d'une maison individuelle [Civ.]*).

Art. 3 - Action directe des ouvriers contre le maître de l'ouvrage

375. Même si le rapport n'est pas direct, il existe une action des ouvriers contre le maître de l'ouvrage. Il convient de préciser la nature de l'action (V. *infra,* n°s 376 s.), les bénéficiaires (V. *infra,* n°s 378 s.) de l'action (V. *infra,* n°s 380 s.), enfin d'en détailler les effets (V. *infra,* n°s 383 s.).

§ 1er - Nature de l'action

376. Notion. - En dehors des privilèges et garanties qui sont accordés à tout salarié, de ceux des ouvriers qui ont travaillé à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles ou à la conservation de la chose et de l'action oblique ou de la saisie-attribution données à tout créancier, les salariés du bâtiment et des travaux publics bénéficient d'une action qui leur permet de se faire payer par le maître de l'ouvrage le montant de leurs salaires dus par l'entrepreneur (C. civ., art. 1798 et C. trav., art. L. 3253-23, 1° ; sur l'action donnée en cas de marchandage ou de travail temporaire ; V. *Marchandage [Trav.]*). Mais l'article 1798 du code civil auquel renvoie l'article précité du code du travail ne vise pas spécialement les travaux publics ; la question de son application dans ce secteur d'activité se discute ; mais l'article L. 3253-22 donne aux salariés de ce secteur un droit de préférence (V. sur le privilège accordé aux ouvriers et fournisseurs de travaux publics de l'État par le décret du 26 pluviôse an II, G. FLÉCHEUX, La protection du sous-traitant [Le privilège de pluviôse], JCP 1973. I. 2514).

377. On a discuté de la nature de cette action ; cette discussion est aujourd'hui sans intérêt, la loi du 19 juillet 1933 (C. trav., art. L. 3253-23, 1°) ayant confirmé l'interprétation jurisprudentielle selon laquelle une *action directe* appartient aux salariés. Une convention passée entre le maître et l'entrepreneur écartant l'article 1798 serait *res inter alios acta* pour l'ouvrier qui tient son droit de la loi (Req. 28 janv. 1880, DP 1880. 1. 254). Au contraire, la convention par laquelle le maître s'obligerait à régler lui-même tous les salaires des ouvriers de l'entrepreneur au-delà de la créance de ce dernier contre lui serait valable comme stipulation faite au profit du personnel de l'entreprise (V. sur la question : SOLUS, L'action directe et l'interprétation des articles 1753, 1798, 1994 du code civil, thèse, Paris, 1914 ; R. DEBRAY, Privilèges sur les créances et actions directes, thèse, Lille, 1935 ; ROBINO, Les privilèges et autres causes de préférence sur les créances, thèse, Bordeaux, 1947). Il est permis de se demander si cette action a encore de l'intérêt depuis l'institution d'une garantie des salaires. L'insolvabilité de l'employeur qui entraîne une procédure collective permet en effet aux salariés de bénéficier de l'assurance de garantie des salaires (C. trav., art. L. 3253-8).

§ 2 - Bénéficiaires

378. Texte. - L'article 1798 du code civil énumère les bénéficiaires de l'action directe : « maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ». Par cette énumération, il semble que le législateur n'ait envisagé que les salariés employés aux travaux de construction (en ce sens : note anonyme, Gaz. Pal. 1960. 2. 212 ; MAZEAUD, Leçons, t. 3, n° 1378) ; toutefois, les termes « ouvrages faits à l'entreprise » pourraient être interprétés plus largement (T. com. Cambrai, 21 juin 1960, Gaz. Pal. 1960. 2. 212 ; ROUAST, *op. cit.,* n° 964 ; rappr. Rouen, 31 mai 1826, Jur. gén., *V°* Droit maritime, n° 256-1°). Selon une opinion, à notre sens dépassée, l'action directe bénéficierait aux seuls travailleurs manuels (Besançon, 16 juin 1863, DP 1863. 2. 103 ; AUBRY et RAU, t. 5, § 374-3° ; BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 4046 ; ROUAST, *op.* et *loc. cit.* ; *contra :* RODIÈRE, *op. cit.,* n° 225 : pour cet auteur, le travail salarié est la seule condition posée par la loi).

379. L'action est refusée aux fournisseurs et elle l'était aux *sous-traitants* jusqu'à la loi du 31 décembre 1975, précitée, qui distingue suivant que le marché est public ou privé. Dans le premier cas, le sous-traitant a droit au *paiement direct* ; dans le second, il ne dispose que d'une *action directe* (sur les conditions de cette action, V. *Sous-traitance [Com.]* ; V. égal. J. FOSSEREAU, Chron. à la RDI 1980, n° 3).

§ 3 - Exercice de l'action

380. 1° Défendeur. - L'action directe doit être dirigée « contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits » (art. 1798), formule équivoque qui peut aussi bien signifier la limitation de l'action aux rapports des ouvriers de l'entrepreneur et du seul maître de l'ouvrage (en ce sens, BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, *op. cit.,* n° 4049), que son extension aux rapports des salariés des sous-traitants et de l'entrepreneur général (en ce sens, ROUAST, *op. cit.,* n° 965 ; RODIÈRE, *op. cit.,* n° 226). Les marchés contiennent souvent des clauses imitées de celles des marchés publics, aux termes desquelles le maître de l'ouvrage impose à l'entrepreneur général l'obligation de garantir directement le paiement des salaires de tout le personnel du sous-traitant, comme des matériaux fournis à celui-ci (Comp. Civ. 2e, 6 févr. 1958, Bull. civ. II, n° 112. – Lyon, 7 mars 1968, Gaz. Pal. 1968. 2. 63).

381. 2° Insolvabilité du débiteur. - L'ouverture de l'action directe est en principe subordonnée à l'insolvabilité de l'entrepreneur ; mais le salarié ayant un droit propre contre le maître de l'ouvrage, il n'est pas indispensable que l'entrepreneur ou son syndic soit mis en cause.

382. Parce que l'ouvrier dispose d'un droit direct, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de l'entrepreneur ne font pas obstacle à l'action, même si l'ouvrier agit en même temps contre l'entrepreneur ou la faillite de celui-ci (Paris, 17 avr. 1863, DP 1863. 2. 150).

§ 4 - Effets de l'action directe

383. Créance. - L'action directe permet à l'ouvrier de réclamer au maître tout ce dont il est créancier à l'égard de l'entrepreneur, mais seulement en raison de son travail, dans la mesure de tout ce dont le maître est encore débiteur à l'égard de l'entrepreneur au moment de la demande, même pour des causes autres que les travaux auxquels il a été employé (Req. 31 juill. 1867, DP 1868. 1. 25. – Besançon, 16 juin 1863, préc. ; T. civ. Seine, 20 avr. 1898, Gaz. T. 6 mai 1898 ; ROUAST, *op.* et *loc. cit.*).

384. À partir de la demande, la créance de l'entrepreneur contre le maître est indisponible entre les mains de ce dernier ; les paiements, cessions, compensations, saisies-attribution postérieurs ne sont pas opposables à l'ouvrier. Les ouvriers exerçant l'action directe contre le même maître viennent en concours (Besançon, 16 juin 1863, préc.).

385. Une action directe est donnée aux ouvriers en cas de marchandage (C. trav., art. L. 8232-3) ou de travail temporaire (C. trav., art. L. 1251-39 et L.1251-40). Elle est plus efficace que celle de l'article 1798 ; en effet, le montant de la créance du salarié ou des caisses n'est pas limité au montant de la dette de l'utilisateur à l'égard de l'entrepreneur (Rappr. Soc. 17 févr. 1949, Bull. civ. IV, n° 144) : l'utilisateur est *substitué* à l'entrepreneur (V. *Marchandage [Trav.]*).

Chapitre 2 - Achèvement de l'ouvrage

386. Notion. - L'achèvement est, de toute évidence, une notion absolue et, par définition, parfaite (Le Petit Larousse donne ce sens de l'adjectif « achevé » *accompli dans son genre* et du mot « achèvement » : fin ; *exécution complète*). Cependant, la loi du 4 janvier 1978, cédant à la pratique, fait de l'achèvement une notion relative. Il existe désormais dans l'entreprise de construction une obligation légale de « parfait achèvement », ce qui suggère l'idée que dans le droit commun du louage d'ouvrage, on n'est obligé qu'à un achèvement « imparfait » (B. BOUBLI, *op. cit.,* n°s 256 s. ; La responsabilité des constructeurs dans la loi du 4 janvier 1978, RDI 1979. 1 s., n° 5). Il est acquis désormais que « si la réception ne peut intervenir qu'une fois l'immeuble achevé, cela ne signifie pas que cet achèvement soit parfait ! » (P. MALINVAUD et P. JESTAZ, La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à

l'assurance dans le domaine de la construction, JCP 1978. I. 2900). On ne s'étonnera pas, dès lors, des problèmes qui entourent la fin du contrat d'entreprise.

387. Si plusieurs textes prennent en compte diverses étapes du processus extinctif des droits et obligations dans l'opération de construction, l'état d'achèvement dont il est alors question concerne certains travaux et non l'immeuble pris dans son ensemble, car il ne s'agit que de fixer le terme des garanties d'exécution et des contraintes administratives ou fiscales (B. BOUBLI et B. STEMMER, L'achèvement de l'immeuble, BF Lefebvre 3/94 et 4/94). En revanche, le terme de l'obligation d'édifier, qui libère de l'obligation de faire et « délivre » le constructeur, suppose l'achèvement complet de l'ouvrage. L'institution d'un parfait achèvement dans le louage d'ouvrage immobilier est donc une source de confusion, car tant que l'achèvement n'est pas complet, l'obligation, qui n'est pas arrivée à terme, demeure. Ce qui complique les choses, c'est que la loi de 1978 érige en garantie ce qui n'est que l'obligation elle-même lorsque l'achèvement n'est pas total. On aurait pu, à la rigueur, admettre l'institution d'une garantie prenant le relais de l'obligation d'achever et ne se confondant pas avec elle. Il est clair aujourd'hui que le relais est pris alors même qu'il n'y a pas d'achèvement ! À l'achèvement de l'ouvrage, la livraison est une des étapes importantes (V. *infra,* n°s 388 s.), au même titre que la réception des travaux (V. *infra,* n°s 463 s.). Elles conditionnent la mise en œuvre du paiement (V. *infra,* n°s 408 s.) et des garanties dont celle dite de parfait achèvement (V. *infra,* n°s 474 s.).

Section 1re - Livraison de l'ouvrage

388. La notion de livraison se distingue de la réception (V. *infra,* n°s 389 s.). L'entrepreneur est tenu d'y procéder dans les délais prévus (V. *infra,* n°s 393 s.).

Art. 1er - Distinction d'avec la réception

389. Problématique. - La livraison et la réception peuvent être regardées soit comme deux aspects de la même obligation, soit comme deux obligations distinctes. Il s'agit des deux aspects de la même obligation, si l'on veut bien admettre cette logique élémentaire : le débiteur livre ce qu'il doit, et le créancier reçoit ce qui est dû ; la réception est l'aspect négatif de la livraison : c'est la livraison vue du côté du créancier. Livrer la chose, c'est, dans l'entreprise comme dans la plupart des contrats comportant obligation de faire, exécuter son engagement, c'est-à-dire payer sa dette. Or, il ne sert à rien de dire que la livraison libère le débiteur de son obligation, si la chose livrée n'est pas la chose convenue : dans le louage d'ouvrage, où le maître de l'ouvrage n'exerce

son contrôle que sur le *travail achevé,* la livraison est la synthèse de toutes les obligations du locateur (V. *supra,* n°s 87 s.). Il faut qu'elle soit parfaite : non seulement qu'elle s'opère dans le délai, mais aussi qu'elle soit conforme à l'objet de l'engagement. C'est l'exécution conforme à tous égards qui est libératoire (V. dans la vente : CCH, art. 261-14 : la mise à la disposition « oblige le vendeur à exécuter son obligation et à délivrer un immeuble conforme » ; V. égal. Civ. 3e, 20 mars 1979, D. 1979. IR 521 : « la mise à la disposition […] ne peut précéder l'achèvement » ; V. A. BÉNABENT, note sous Civ. 1re, 5 mai 1993, D. 1993. 506, qui rappelle que « la délivrance concerne tout ce qui est apparent [entendre "conforme"] et s'éteint par la réception »). La théorie classique du paiement qui fait de celui-ci un acte juridique conduit donc à considérer qu'il y a d'un côté celui qui livre (le débiteur), de l'autre celui qui reçoit et accepte (le créancier). Dans le meilleur des cas, on le voit, c'est-à-dire même dans la thèse qui fait du paiement un acte juridique, la réception est l'aspect négatif de la livraison.

390. Livraison et réception sont au contraire deux actes distincts, si l'on estime qu'à l'obligation de livrer correspond une obligation de prendre livraison et, qu'accessoirement à celle-ci, il existerait une obligation de réceptionner (V. *supra,* n°s 110 s. et 114). L'artifice du langage devrait suffire à condamner cette dualité. De toute évidence, prendre livraison, c'est recevoir. Les deux expressions ont le même sens. On peut certes opposer le *fait de recevoir au fait de réceptionner,* pour soutenir que le maître de l'ouvrage accomplit deux actes différents ; mais l'argument est de pur artifice. Le Petit Larousse donne du verbe réceptionner le sens particulier de « vérifier », et il n'exclut pas cette vérification lorsqu'il précise le sens du verbe « recevoir » : « admettre », « agréer »… Et que dire de la *réception,* définie par le même dictionnaire « l'action de recevoir » (!) et prise dans la définition juridique qu'en donne le nouvel article 1792-6, comme l'acte par lequel le maître « accepte » les travaux.

391. L'artifice de la distinction est particulièrement souligné par l'article L. 231-2 *k* et l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation qui, dans le contrat de construction de maison individuelle, variété de louage d'ouvrage, instituent une garantie financière « de livraison » qui cesse à la « réception des travaux » (art. L. 231-6 nouv.). Une garantie à objet précis (livraison) qui cesse à une date précise (réception) est une garantie qui montre que livraison et réception désignent un même fait : l'achèvement. Et comme la loi laisse subsister la garantie lorsque la réception a lieu avec réserve, elle postule que la délivrance est différée à l'achèvement complet, si les réserves concernent la conformité et que les défauts de construction apparents donnent lieu à une responsabilité spécifique couverte par la garantie de livraison. La livraison comme la réception requièrent l'achèvement, conformément au descriptif, mais les désordres mineurs n'empêchent pas la réception qui en est le constat et sert à la fois de point de départ et de domaine aux garanties légales.

392. Toutefois, en posant que la réception n'implique pas l'achèvement des travaux (Civ. 3e, 12 juill. 1989, RDI 1990. 83), la Cour de cassation dissocie définitivement la réception de la livraison qui, elle, implique toujours l'exécution d'un ouvrage conforme, donc achevé (V. dans le CCMI, Civ. 3e, 11 févr. 2009, no 08-10.476, qui rappelle que l'obligation du garant ne s'éteint pas à la réception, mais à la livraison et Civ. 3e, 21 oct. 2008, no 07-18.270, qui précise que les pénalités de retard ont pour terme la livraison ; comp. : Civ. 3e, 31 janv. 2007, no 05-20.683, Bull. civ. III, no 11, qui fixe la date de la livraison à celle de la réception). Cette distinction a un grave inconvénient. La livraison est absorbée par la garantie de parfait achèvement ou coexiste avec elle, ce qui, dans tous les cas, fait de l'achèvement une notion imprécise et variable selon l'intérêt en cause.

Art. 2 - Livraison dans le délai

393. La livraison dans le délai est une obligation de l'entrepreneur dont la défaillance engage sa responsabilité (V. *infra,* nos 394 s.) et l'expose à des sanctions (V. *infra,* nos 401 s.).

§ 1er - Responsabilité

394. Obligation de l'entrepreneur. - L'*entrepreneur* a l'obligation de livrer l'ouvrage qu'il construit dans les délais convenus (Civ. 3e, 6 nov. 1984, RDI 1985. 155 ; 13 juill. 1993, no 91-15.841, RDI 1993. 511. – Civ. 3e, 21 oct. 2008, préc.). Le délai peut être fixé par les parties (Civ. 3e, 8 avr. 2008, no 07-12.057), compte tenu, le cas échéant, des intempéries (Civ. 3e, 7 avr. 2009, no 08-14.096, BPIM 3/09, inf. 203) ; à défaut, d'être convenu, le délai doit être « raisonnable » (ROUAST, *op. cit.,* no 294 ; *adde* : AUBY et PÉRINET-MARQUET, *op. cit.,* no 1056. – Civ. 3e, 1er déc. 1982, JCP 1983. IV. 56. – Civ. 3e, 10 févr. 2009, no 07-21.656. – Civ. 3e, 16 mars 2011, no 10-14.051 RJDA 6/11, no 525. – Civ. 3e, 29 sept. 2016, no 15-18.238 PBI – Même sens pour les marchés publics : CE 4 juill. 2014, Sté Orme, req. no 371633, BPIM 5/14, inf. 318). La notion de « délai raisonnable » est reprise dans différentes dispositions du nouveau code civil, qui visent de manière directe ou indirecte, l'exécution de l'obligation (art. 1211, 1222, 1226…) et semblent l'ériger en principe général.

395. Selon la norme AFNOR p. 03-001 (art. 10.2), s'il n'en est autrement stipulé, le terme du « délai de réalisation » est la date à laquelle les travaux « sont effectivement

terminés ». Le délai d'exécution est donc un délai de livraison puisque la livraison implique l'*achèvement complet.* Ainsi, un arrêt sanctionne le retard en tenant compte de la date « d'achèvement contractuellement fixée » (Civ. 3e, 6 nov. 1996, n° 95-10.497). Un autre censure une cour d'appel qui avait fixé le terme des pénalités de retard à la réception, alors que le juge devait rechercher à quelle date les travaux avaient été « entièrement » exécutés (Civ. 3e, 21 juill. 1999, n° 97-19.901, BPIM 6/99, n° 426. – V. également : Civ. 3e, 3 oct. 2001, n° 00-13.046, BPIM 6/01, inf. 373).

396. Architecte. - Il n'est pas exclu que l'*architecte* (ou tout autre constructeur) soit déclaré responsable du retard. L'architecte peut avoir commis une faute en donnant un ordre vicieux auquel l'entrepreneur a résisté, ou bien il a pu déceler tardivement une erreur à laquelle il a fallu remédier (TGI Lyon, 8 janv. 1969, JCP 1969. II. 15768 ; cadences d'exécution. – Civ. 3e, 24 oct. 1978, D. 1979. IR 85, qui statue sur l'action récursoire de l'entrepreneur. – Civ. 3e, 29 mai 1984, RDI 1985. 58 ; 31 mai 1989, *ibid.* 1989. 471 ; V. B. BOUBLI, *op. cit.,* n° 196). Mais alors le maître de l'ouvrage doit démontrer sa faute (TGI Beauvais, 14 mai 1965, cité au J.-Cl. Civ., art. 1788-1794, 3e cahier, n° 10 ; rappr. Civ. 3e, 7 mars 1968, Bull. civ. III, n° 95, D. 1970. 27, note B. Soinne ; 13 oct. 1971, Bull. civ. III, n° 489 ; 29 mai 1984 et 31 mai 1989, préc.).

397. Lorsque le marché est conclu par corps d'état, chaque entreprise est responsable du retard qui lui est imputable (CE 4 oct. 1989, Centre hospitalier de Vitré, D. 1990. Somm. 245, obs. P. Terneyre), à moins que la solidarité ait été stipulée. Les recalages consécutifs à un retard ne peuvent cependant être trop stricts et pénaliser les entreprises non responsables (Civ. 3e, 24 févr. 1982, RDI 1982. 382 ; rappr. Lyon, 30 nov. 1978, RDI 1979. 340).

398. Nature de l'obligation. - Pour l'entrepreneur, l'obligation de livrer la chose à la date prévue est une *obligation de résultat* (Civ. 3e, 3 oct. 2001, BPIM 6/01, inf. 373 ; V. *supra,* nos 88 et 230 ; AUBY et PÉRINET-MARQUET, *op. cit.,* n° 1052). Il ne peut donc se décharger de sa responsabilité qu'en établissant la force majeure (désormais définie : C. civ., art. 1218 nouv.), la faute de la victime (Civ. 1re, 12 déc. 1960, Bull. civ. I, n° 536 ; 4 juill. 1979, D. 1980. IR 43 ; comp. Civ. 3e, 19 mars 1969, JCP 1970. II. 16361, note Lévy ; V. *supra,* n° 79) ou le fait du tiers, qui peut être un constructeur dont l'entrepreneur ne répond pas (Civ. 3e, 20 nov. 2007, n° 06-18.559 ; V. pour le fait d'un architecte : Civ. 3e, 7 mars 1968 et 13 oct. 1971, Bull. civ. III, n° 489). Par force majeure, la norme AFNOR entend non seulement les événements revêtant habituellement ce caractère, mais aussi les faits de grève s'étendant à toute la profession (V. cep. Civ. 1re, 16 mai 1977, Bull. civ. I, n° 229) et les intempéries au sens de la loi n° 46-2299 du 21 octobre 1946 (D. 1946. 416) ; toutefois, l'entrepreneur a

l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage et l'architecte de ces événements (Civ. 3e, 19 mars 1969, Bull. civ. III, no 242). Si l'entrepreneur qui livre l'ouvrage doit aussi remettre des attestations (consuel relatif à l'électricité par ex.), le retard qui en résulte est imputable à sa faute et il lui appartient d'établir qu'il a bien remis lesdites attestations (Civ. 3e, 5 déc. 2012, no 11-24.499, BPIM 1/13, inf. 48. – Civ. 3e, 25 mars 2015, no 14-11.872, BPIM 3/15, inf. 184).

399. Faute du maître de l'ouvrage. - Elle peut justifier un retard dans la livraison (Civ. 3e, 17 oct. 1968, AJPI 1969. 732, note A. Caston ; 4 juill. 1979, RDI 1980. 64. – Civ. 3e, 22 juin 2010, no 09-10.088, BPIM 5/10, inf. 371. – Civ. 3e, 9 juill. 2013, no 12-21.705, BPIM 5/13, inf. 330). D'ailleurs, le maître de l'ouvrage ne peut invoquer le retard que s'il établit la date des ordres de service marquant le point de départ du délai d'exécution des travaux (Civ. 3e, 27 mars 1979, Gaz. Pal. 1979. 2. Pan. 313). La faute du maître de l'ouvrage consiste généralement – sauf immixtion (V., pour une augmentation du volume des travaux : Civ. 3e, 18 janv. 1983, RDI 1984. 55 ; CE 29 juin 1990, RDI 1990. 488) – en non-paiement des acomptes à l'échéance. L'entrepreneur oppose alors l'*exception d'inexécution* lorsqu'il livre avec retard (Civ. 3e, 17 oct. 1968, AJPI 1969. 732, note Caston ; 16 mai 1984, RDI 1984. 413 ; 19 mars 1986, JCP 1986. IV. 151 ; 27 oct. 1982, RDI 1983. 228 ; V., pour un cas particulier, Lyon, 30 nov. 1978, RDI 1979. 340, qui retient la responsabilité du maître de l'ouvrage qui a imposé des délais trop stricts).

§ 2 - Sanction du retard

400. Le retard peut être imputable au constructeur (V. *infra,* nos 401 s.) ou au maître de l'ouvrage (V. *infra,* nos 407 s.). Les conséquences ne sont pas les mêmes.

A - Retard imputable au constructeur

401. Une *mise en demeure* est-elle nécessaire ? Il ne le semble pas, au moins lorsque le constructeur a commencé l'ouvrage et qu'un délai a été stipulé. Un marché établissant un programme auquel participent plusieurs techniciens, se succédant dans les travaux, comporte une obligation continue qui devrait échapper à la nécessité d'une mise en demeure (MAZEAUD et CHABAS, Leçons, t. 2, no 620) ; d'autre part, le marché qui fixe un délai contient, semble-t-il, une dispense implicite de mise en demeure (Civ. 3e, 7 mars 1969, Bull. civ. III, no 208 ; 17 nov. 1971, *ibid.* III, no 564 ; comp. Civ. 3e, 18 avr. 1972, *ibid.* III, no 236 ; 11 juill. 2001, no 1205 FS-D, BPIM 5/01, no 307 ; comp. : Civ. 3e, 13 avr. 1988, Bull. civ. III, no 72 ; sur la situation de

l'architecte : Civ. 3e, 29 mai 1984, RDI 1985. 58 ; 2 oct. 1996, RDI 1997. 80). L'article1344 nouveau du code civil vise le cas où la mise en demeure résulte de la « seule exigibilité » de l'obligation, et conforte cette interprétation. Le texte semble exiger que le contrat « le prévoit », mais la portée de cette exigence reste à préciser : l'exigibilité de la dette peut-elle résulter de la « nature » même de l'obligation souscrite par l'entrepreneur, qui serait alors nécessairement prévue par le contrat ? En revanche, une mise en demeure est nécessaire lorsque le contrat ne fixe pas de délai (Civ. 3e, 16 mars 2011, no 10-14.051, RJDA 6/11, no 525).

402. Le *préjudice* né du retard et de la gêne éprouvée de ce fait est distinct de celui résultant des malfaçons (Civ. 3e, 12 mars 1974, Bull. civ. III, no 113). Outre l'impossibilité pour l'entrepreneur de prétendre à une révision de prix (Civ. 3e, 4 juin 1986, Mon. TP 26 sept. 1986), celui-ci s'expose à des dommages-intérêts pour retard dans les travaux souvent fixés forfaitairement par les parties. La plupart des marchés comportent une clause pénale, d'autant plus utile que les autres techniciens, retardés dans leurs prévisions, peuvent demander réparation au maître, sauf son recours contre le responsable.

403. La *clause pénale* est la sanction apparemment la mieux adaptée au *retard imputable à l'entrepreneur.* En principe, la clause pénale ne peut jouer qu'après mise en demeure (Civ. 3e, 18 avr. 1972, Bull. civ. III, no 236 ; 20 juin 1978, Gaz. Pal. 1978. 2. somm. 350), sauf dispense de cette formalité (Civ. 3e, 7 mars 1969, Bull. civ. III, no 208 ; 22 avr. 1975, *ibid.* III, no 130 ; comp. toutefois Civ. 3e, 7 mars 1969 et 18 avr. 1972, préc. ; 17 nov. 1971, Bull. civ. III, no 565 ; 2 avr. 1974, D. 1974. 473). Mais le contrat peut expressément écarter la formalité (Civ. 3e, 9 juin 1999, no 97-20.977, Bull. civ. III, no 131, CCC 1999, no 154, note Leveneur ; V. aussi 24 mars 1971, Bull. civ. III, no 214). De plus, un plan de déroulement des travaux doit avoir été prévu (Civ. 3e, 25 avr. 1984, RDI 1984. 413).

404. En matière immobilière, elle prend la forme de pénalités de retard qui ont la nature de la clause pénale (Civ. 3e, 6 mai 1996, no 94-15.035, RDI 1996. 572). La peine est révisable aux conditions de l'ancien article 1152 du code civil (devenu nouv. art. 1231-5), même en cas de retard (Versailles, 20 déc. 1985, RDI 1986. 362. – Paris, 31 oct. 1989, RDI 1990. 82 ; V. toutefois, Civ. 3e, 22 nov. 2000, Bull. civ. III, no 174, D. 2001. IR 40, qui décide que la réduction des pénalités de retard dans le CCMI ne peut aboutir au versement d'une indemnité inférieure au minimum prévu par la loi) ; le juge ne peut toutefois en réduire le montant au motif qu'un tiers (l'architecte) a concouru au retard (Civ. 3e, 9 juill. 2014, no 13-19.765, BPIM 5/14, inf. 319). Mais lorsqu'elle est due, il n'est pas nécessaire d'établir le préjudice (Civ. 3e, 20 déc. 2006, no 05-20.065, RJDA 5/07, no 448. – Civ. 3e, 18 janv. 2006, RDI 2006. 216). La pénalité réservée au

préjudice né du retard ne peut concerner les désordres (Civ. 3e, 9 juill. 2014, n° 13-19.765, préc.). Des dommages-intérêts complémentaires à ceux résultant de l'application de la clause pourraient être alloués si la preuve d'un préjudice distinct du retard était rapportée, ce qui suppose alors la requalification de la clause pénale en clause d'astreinte (Civ. 3e, 30 janv. 1979, Gaz. Pal. 1979. 1. Pan. 214 ; 15 déc. 1958, Bull. civ. III, n° 435 ; V. Civ. 3e, 19 déc. 1984, RDI 1985. 256). L'architecte n'est, en principe, pas tenu des pénalités de retard prévues au marché de travaux (Civ. 3e, 16 juin 1982, Bull. civ. III, n° 156 ; 31 mai 1989, RDI 1990. 82). Toutefois, celles-ci peuvent être mises à sa charge si son contrat le prévoit (Civ. 3e, 11 juill. 1977, D. 1977. IR 477 ; 7 mai 1996, RDI 1996. 572) ou si la faute qu'il commet l'oblige à tout le dommage (Civ. 3e, 29 mai 1984, RDI 1985. 58 ; 2 oct. 1996, préc. *supra,* n° 401).

405. Le juge peut donner le plein de la clause s'il l'estime nécessaire sans avoir à donner un motif spécial à son refus de réduire le montant de la pénalité (Civ. 3e, 29 nov. 1978, RDI 1979. 208, obs. P. Malinvaud et B. Boubli). Si cela ne lui est pas demandé, il n'a pas à rechercher si la pénalité est manifestement excessive (Civ. 3e, 22 juill. 2007, n° 06-11.230, RDI 2007. 275). La clause serait écartée en cas de dol si elle aboutissait à une limitation de responsabilité (Civ. 3e, 24 oct. 1978, D. 1979. IR 116).

406. Dans le cas particulier de la *construction d'un groupe d'immeubles,* le constructeur ne saurait prétendre à une réduction des dommages-intérêts dus pour le retard apporté aux travaux de certaines tranches, au motif que d'autres tranches ont été livrées en avance (Civ. 3e, 6 nov. 1973, Gaz. Pal. 1973. 2. Pan. 266). Il en serait toutefois autrement si des primes pour avance d'achèvement étaient stipulées (norme AFNOR p. 03-001 ; rappr. art. 4.4.3 du CCAP, norme de 1989 et 7.5.3. du CCAG), encore faudrait-il que le retard apporté à l'exécution de certains ouvrages ne rendît pas inutile l'avance des autres. Si des pénalités de retard distinctes pour chaque immeuble ont été prévues, il y a lieu de préciser le retard pour chacun d'eux (Orléans, 22 mars 1973, D. 1974. Somm. 2).

B - Retard imputable au maître de l'ouvrage

407. Sanctions. - Lorsque le retard est imputable au maître de l'ouvrage (V. *supra,* n° 399), celui-ci s'expose à des sanctions : révision du prix du marché (Lyon, 30 nov. 1978, RDI 1979. 340) ; remboursement des hausses de prix supportées par l'entrepreneur du fait du retard (Civ. 6 janv. 1959, AJPI 1959. 40) ; dommages-intérêts (V. aussi pour d'autres sanctions : Civ. 3e, 15 janv. 2003, BPIM 2/03, inf. 95 ; 26 nov. 2003, n° 02-13.875). L'article 05.06.2 de la norme AFNOR p. 03-001 de 1972 prévoit d'ailleurs expressément cette dernière éventualité (Rappr. Civ. 22 mai 1968, Quot. jur. 15 sept. 1970 ; V. sur la question : CASTON et MONTMERLE, *op. cit.,* nos 374 s., et

égal. norme p. 03-001 de 2000, art. 10.3.2.1, qui précise que l'entrepreneur ne peut suspendre le chantier pour défaut de paiement des acomptes sans avoir informé le maître de l'ouvrage par lettre recommandée).

Section 2 - Prix du marché : paiement et garantie

408. Régime. - Le paiement du prix porte sur une somme d'argent, sauf si les parties conviennent d'une autre forme (dation ou autre). Il obéit aux dispositions des nouveaux articles 1342 et suivants du code civil. Il donne lieu, généralement, à un échelonnement pendant l'exécution du contrat. Les versements effectués à ce titre correspondent à des travaux exécutés. L'exécution ne doit pas être contestée ; elle ne résulte pas, selon un arrêt, de la seule production d'une facture (Civ. 3e, 13 juill. 2016, no 15-20.324). Le marché peut donner lieu à des avances, qui permettent à l'entreprise de disposer d'une trésorerie. Les avances ne sont versées que si le contrat le prévoit, le cas échéant par référence aux documents normalisés (norme AFNOR). La plupart des marchés prévoient des acomptes sur travaux exécutés qui correspondent à une partie de la valeur des prestations réalisées. On considère que l'acompte est un usage des marchés de travaux. L'avance, qui procède d'une pratique institutionnalisée dans les marchés publics, se distingue de l'acompte en ce qu'elle correspond à la valeur de certaines prestations (matériel, matériaux…) dont l'entrepreneur doit justifier de l'achat ou de la commande ; la somme versée ne dépasse pas 80 % de leur valeur. Nonobstant le paiement d'avances, les matériaux approvisionnés par l'entrepreneur restent sa propriété ; ils ne deviennent celle du maître de l'ouvrage que par accession, lors de leur incorporation à l'ouvrage bâti. Le non-paiement d'une avance de démarrage prévue par le contrat justifie la suspension de celui-ci, voire sa résiliation, aux torts du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 7 avr. 2009, no 08-11.987). Dans les marchés privés entre professionnels soumis au code de commerce, le principe des acomptes est généralisé pour certains marchés (CCH, art. L. 111-3-1 mod. par L. no 2014-344 du 17 mars 2014 [JO 18 mars] ; C. civ., art. 1779, 3o) ; les parties en étendent l'application aux marchés non visés aux textes. Le règlement des acomptes obéit aux dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 441-6 du code de commerce (V. ABBATUCCI, Le respect des délais de paiement dans les marchés de travaux, RDI 2012. 501 ; Nouvelles règles de paiement dans le marché privé de travaux, RDI 2014. 343. – MALINVAUD, Délais de règlement et exception d'inexécution, RDI 2012. 501). Le maître de l'ouvrage doit garantir le paiement des sommes dues à l'entrepreneur (V. *infra,* nos 409 s.), et il peut pratiquer une retenue de garantie (V. *infra,* nos 415 s.).

Art. 1er - Conditions de paiement

409. Situations et attachements. - Le paiement est une obligation du maître de l'ouvrage qui doit y satisfaire sur la base des situations établies chaque mois. Des attachements constatent la nature et les quantités de travaux réalisés ; ils sont contrôlés par l'architecte et portés à la connaissance du client. La prise d'attachement ne s'impose pas lorsque le marché est à forfait. Chaque mois, le cas échéant après la prise d'attachements, l'entreprise établit une situation des travaux, qui est un état comptable de la valeur des prestations réalisées. Cette situation est soumise à l'approbation de l'architecte qui délivre un bon d'acompte. Le règlement définitif intervient sur la base du mémoire définitif qui définit et chiffre les travaux exécutés tout en récapitulant le montant des acomptes et avances versés ; il révèle le solde débiteur. Le mémoire est établi par l'entrepreneur et soumis pour approbation à l'architecte, puis transmis au maître de l'ouvrage. Sur la base de ce document, le décompte définitif est arrêté. Le maître de l'ouvrage vérifie les pièces qui lui sont transmises et il propose le règlement de compte en notifiant à l'entrepreneur le document valant fixation de sa créance. Le mémoire approuvé est une condition du paiement (Civ. 3e, 2 juill. 1981, RDI 1981. 74). Si l'entrepreneur accepte la proposition de règlement, le décompte est arrêté. Si l'entrepreneur refuse, une contestation s'ouvre. Le contrat, par référence à la norme AFNOR le cas échéant, mais pas nécessairement (Civ. 3e, 1er juill. 2009, no 08-16.724), prévoit les modalités d'approbation et de contestation des comptes (V. Civ. 3e, 7 juin 2001, RDI 2001. 369 ; 31 oct. 2001, RDI 2002. 501). La procédure conventionnelle s'impose alors (Civ. 3e, 19 mai 2009, no 08-13.377. – Civ. 3e, 26 nov. 2014, no 13-24.888, RDI 2015. 126, obs. B. Boubli ; BPIM 1/15, inf. 33) mais seulement dans les rapports entre les parties liées par l'engagement (les modalités convenues dans un sous-traité ne concernent pas le maître de l'ouvrage : Civ. 3e, 10 déc. 2014, no 13-24.798, BPIM 1/15, inf. 34). Le maître de l'ouvrage qui conteste le mémoire produit par l'entrepreneur lui notifie un décompte dans le délai contractuellement fixé (60 jours selon la norme AFNOR). Le décompte définitif établi unilatéralement par le maître de l'ouvrage, surtout si la dernière situation n'a pas été vérifiée, n'est pas opposable à l'entrepreneur (Civ. 3e, 4 janv. 1996, RDI 1996. 213). L'entrepreneur peut contester le décompte qui lui a été notifié dans un délai déterminé (30 jours selon la norme AFNOR), à l'issue duquel le décompte est définitif et s'impose (Civ. 3e, 29 mai 2013, no 12-16.904, BPIM 4/13, inf. 257). Toutefois, le décompte non contesté par l'entrepreneur ne lie le maître de l'ouvrage que s'il émane de lui ou d'un mandataire : l'architecte ne l'oblige que s'il a reçu un mandat exprès (Req. 3 janv. 1900, D. 1900. 281. – Civ. 3e, 20 nov. 1996, no 95-11.573. – Rappr. : Civ. 3e, 26 nov. 2014, no 13-24.888, préc.). Les modalités de fixation de la créance de l'entrepreneur sont, en principe, sans incidence sur le sort des travaux supplémentaires non autorisés par écrit dans le marché à forfait (Civ. 3e, 11 mai 2006, BPIM 4/06, inf. 266). Lorsque le décompte est définitivement arrêté, il fixe la créance de l'entrepreneur. Il ne peut être remis en cause qu'en cas de dol (sur la portée du mémoire définitif, Civ. 3e, 4 déc. 1991, RDI 1992. 69).

410. Délai. - Le maître de l'ouvrage procède au paiement dans le délai convenu. Le délai de règlement des acomptes ne peut pas dépasser celui prévu au marché et, en tout cas, celui de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Il est responsable du retard et, le cas échéant, du préjudice distinct subi par l'entrepreneur (Civ. 3e, 17 oct. 1978, RDI 1979. 208), en particulier lorsque son attitude est dilatoire (Civ. 3e, 3 mars 1981, RDI 1981. 511). Les intérêts de retard qui sont dus (Civ. 3e, 2 juill. 1980, RDI 1981. 74 ; CE 11 juill. 1990, RDI 1990. 488) courent à compter de la sommation de payer (Civ. 3e, 17 déc. 1996, no 1957 D. – Civ. 3e, 27 févr. 2007, no 06-11.230, RDI 2007. 275) ou dès l'échéance, sans mise en demeure si le contrat le prévoit (Civ. 3e, 17 déc. 1996, no 1955 D). Le paiement émane du maître de l'ouvrage ou de son mandataire spécialement habilité. Le paiement par l'architecte décharge le maître de l'ouvrage s'il a reçu un mandat spécial ou s'il s'est porté fort de la ratification par celui-ci (Civ. 3e, 8 nov. 1978, RDI 1979. 208). Lorsque l'ouvrage a été exécuté pour le compte de plusieurs copropriétaires indivis, chacun n'est tenu que pour sa part, si la solidarité n'a pas été stipulée (Paris, 16 nov. 1911, Gaz. Pal. 1912. 1. 22 ; rappr. : Civ. 1re, 4 mai 1966, Bull. civ. I, no 266. – Civ. 3e, 10 mai 1968, Bull. civ. III, no 202). L'entrepreneur non payé régulièrement peut, à ses risques et périls toutefois, opposer l'exception d'inexécution.

411. Suspension. - Le maître de l'ouvrage peut suspendre le paiement si l'entrepreneur n'exécute pas toutes ses obligations (en cas de malfaçons par exemple : Civ. 3e, 3 oct. 1980, RDI 1981. 22 ; 11 juin 1981, RDI 1982. 85 ; 3 juill. 1996, RLDA 11/96, no 1418, 2e esp.). Il oppose à son tour l'exception d'inexécution, là encore à ses risques et périls (Civ. 3e, 28 févr. 1996, RDI 1996. 214 ; 19 juill. 2000, RDI 2000. 571 ; 16 sept. 2003, BPIM 6/03, inf. 342). Il a été admis que le maître de l'ouvrage a pu différer le paiement du prix alors que les malfaçons se sont manifestées postérieurement à la date d'échéance, ce qui contribue à justifier le droit de rétention par un événement postérieur (Com. 29 janv. 1996, Bull. civ. IV, no 222 ; 20 nov. 1978, *ibid.* IV, no 269. – Civ. 3e, 30 mars 1978, *ibid.* III, no 125). La compensation des créances n'est possible que si les conditions de son admission sont remplies (Civ. 3e, 3 juill. 1996, RJDA 11/96, no 1328).

412. Refus de payer. - Le maître de l'ouvrage peut refuser le paiement si l'entrepreneur ne peut exécuter son obligation. Il en est ainsi en application de la théorie des risques : lorsque l'immeuble périt par la force majeure avant la réception, les risques sont pour l'entrepreneur qui ne peut en réclamer le prix (C. civ., art. 1788. – Civ. 3e, 19 févr. 1986, RDI 1986. 362). Il peut même être tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 27 mars 1991, D. 1991. IR 113). S'il ne fournit pas les matériaux, l'entrepreneur ne répond que de sa faute, mais c'est à lui de l'établir (Civ. 1re, 24 mars 1987, Bull. civ. I, no 106. – Civ. 3e, 17 févr. 1999, no 95-21.018, Bull. civ. III, no 41).

Le maître de l'ouvrage, qui peut refuser de payer le prix en cas de malfaçons (Civ. 3e, 4 nov. 2008, n° 07-19.466), n'est pas privé de l'action en responsabilité pour obtenir réparation des dommages subis (Civ. 3e, 25 févr. 1998, BPIM 3/98, n° 188).

413. Prescription. - La créance du prix des travaux, et même des fournitures, se prescrivait par trente ans (Civ. 27 oct. 1924, DP 1926. 1. 132, travaux ; Req. 2 févr. 1925, DH 1925. 117. – Civ. 1re, 16 juill. 1968, D. 1968. 610, fournitures), et par dix ans lorsque l'obligation est entre commerçants ou entre un commerçant et un non-commerçant (C. com., art. L. 110-4). Elle obéit désormais aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui fixe la prescription à cinq ans.

414. Privilège. - La créance est garantie par le privilège des architectes et des entrepreneurs (C. civ., art. 2103 et 2110) ; ce privilège ne profite qu'à ceux qui ont contracté avec le maître de l'ouvrage (V. *Privilèges immobiliers [Civ.]*).

Art. 2 - garanties de paiement

415. Principe. - Le maître de l'ouvrage doit garantir le paiement des sommes dues à l'entrepreneur conformément à l'article 1799-1 du code civil (V. *infra,* nos 416 s., texte introduit par L. n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 5-1). La garantie, qui est d'ordre public (Civ. 3e, 1er déc. 2004, n° 03-13.949, RJDA 3/05, n° 252), est obligatoire. Elle prend des formes qui varient selon que le maître de l'ouvrage recourt ou non à du crédit (V. *infra,* nos 417 s.). Le seuil à partir duquel la garantie doit être fournie est de 12 000 euros HT (Décr. n° 99-658 du 30 juill. 1999, D. 1999. 461, qui remplace le décret du 18 nov. 1994 qui a été annulé par le Conseil d'État : CE 7 oct. 1998, req. n° 164799, Conféd. de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, BPIM 6/98, n° 394 ; sur la portée de cette annulation : Paris, 29 oct. 1999, RDI 2000. 177). Si le marché est modifié en cours d'exécution, le montant de la garantie doit être révisé sous condition de la preuve d'un accord des parties sur le nouveau prix (Civ. 3e, 4 janv. 2006, n° 04-17.226, BPIM 2/06, inf. 114).

§ 1er - Domaine de la garantie

416. Marchés visés. - La garantie concerne les marchés visés à l'article 1779, 3°, du code civil qui sont les marchés des constructeurs qui s'obligent sur devis ou à forfait. Bien que la loi n'en dise rien, l'obligation paraît se limiter aux marchés de travaux immobiliers. Les marchés publics (art. 1799-1, al. 1er, *a contrario*), les contrats de vente, ceux conclus par un organisme de HLM, ne sont pas concernés. Le contrat de maîtrise

d'œuvre paraît également échapper à l'obligation, car le texte fait de « l'entrepreneur » le bénéficiaire de la garantie ; mais cette interprétation banale peut se discuter, car le contrat de maîtrise d'œuvre est un contrat d'entreprise. Le CCMI, qui est une variété d'entreprise, entre dans le champ d'application de la loi ; il en résulte une particularité : le constructeur doit fournir une garantie financière d'achèvement dite « extrinsèque », et réciproquement, le maître de l'ouvrage doit fournir une garantie de paiement. Aussi, d'aucuns soutiennent que l'objet de la garantie de paiement rend son application délicate au CCMI. Le maître de l'ouvrage qui construit pour son propre compte ou pour des besoins non professionnels est exempté de l'obligation (art. 1799-1, al. 4. – Civ. 3e, 24 avr. 2003, n° 01-13.439, Bull. civ. III, n° 81, qui n'exempte pas une SCI).

§ 2 - Constitution de la garantie

417. Pour constituer une garantie, le maître de l'ouvrage peut avoir recours soit à un crédit (V. *infra,* n° 418) soit fournir une caution (V. *infra,* n° 419).

A - Recours à un crédit spécifique

418. Fonctionnement. - Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer la construction, l'établissement de crédit ne peut pas verser le montant du prêt à une autre personne que le créancier du prix, c'est-à-dire l'entrepreneur, tant que ce dernier n'a pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt (art. 1799-1, al. 2 et 3). Le versement a lieu sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains du créancier ou du mandataire désigné (en cas de GME par exemple). Il faut qu'il s'agisse d'un crédit spécifique correspondant exclusivement et totalement au financement des travaux ; à défaut, c'est l'autre forme de garantie qu'il faut choisir. Il semble que l'organisme de crédit soit délégué à l'entrepreneur dans la limite de l'ordre donné. C'est une modalité de paiement qui est instituée et qui devrait échapper aux dispositions de l'article L. 312-15 relatives à la protection du consommateur.

B - Caution solidaire

419. Conditions. - Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou si le crédit n'est que partiel, il doit fournir la caution solidaire d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de garantie collective selon les modalités fixées par le décret. La caution garantit les sommes dues en exécution du marché et que le maître de l'ouvrage n'a pas encore payées. La caution ne s'impose pas lorsque par voie conventionnelle une garantie efficace est fournie (consignation des

sommes dues ; hypothèque, sans doute de premier rang et sur d'autres immeubles, car l'entrepreneur dispose déjà du privilège des art. 2103 et 2110 du code civil). Elle n'est pas exigée dans les marchés visant à satisfaire des besoins non professionnels, ce qui peut viser le CCMI ; mais dans ce cas, le versement direct s'impose lorsqu'il est fait appel à un crédit spécifique. La caution bénéficie du mécanisme de garantie des cautions des articles L. 313-51 et suivants du code monétaire et financier.

§ 3 - Régime de la garantie

420. Prérogatives de l'entrepreneur. - L'absence de fourniture de la garantie autorise l'entrepreneur à refuser d'exécuter le marché. L'article 1799-1, alinéa 3, permet à l'entrepreneur de surseoir à l'exécution des travaux s'il n'est pas payé et qu'après mise en demeure, le maître de l'ouvrage ne fournit pas la garantie dans un délai de quinze jours. Un arrêt estime que l'entrepreneur peut procéder à un repli définitif de ses installations (Civ. 3e, 9 juin 2010, n° 09-68.038, BPIM 4/10, inf. 286). Placé au troisième alinéa du texte qui traite de la caution, ce dispositif paraît sans intérêt lorsqu'il est fait appel à un crédit spécifique, puisque les fonds sont indisponibles entre les mains du banquier tant que l'entrepreneur n'a pas été payé de l'intégralité de la créance. On peut certes penser que l'entrepreneur a la faculté de subordonner son engagement à une délégation immédiate de paiement, mais il est douteux qu'il puisse ensuite l'exiger et menacer de ne pas donner suite au marché : la délégation n'est pas générale, et l'on peut penser que la garantie tient davantage à l'indisponibilité des fonds chez le prêteur qu'à la substitution de débiteur. Lorsque la garantie prend la forme d'un cautionnement, le texte n'envisage que la sanction encourue en cas de travaux impayés, lorsque la garantie n'est pas constituée : l'entrepreneur peut surseoir à l'exécution des travaux (art. 1799-1, al. 3). Est-ce à dire que l'entrepreneur ne peut exiger la constitution de la garantie lors de la conclusion du contrat et, si celle-ci n'est pas fournie, que le contrat d'entreprise n'est pas affecté d'un vice de formation ? La question s'est posée, car la loi ne fait en réalité qu'institutionnaliser l'exception d'inexécution (V. SAINT-ALARY-HOUIN, obs. RDI 1994. 339 ; FABRE et SCHMIDT, chron. RDI 1994. 347). Mais il est logique d'admettre que l'entrepreneur peut refuser d'exécuter le contrat lorsque la garantie n'est pas fournie dès sa conclusion ; sa constitution peut d'ailleurs être ordonnée sous astreinte en référé (Civ. 3e, 9 nov. 2005, n° 04-20.047, BPIM 3/06, inf. 27 ; 7 nov. 2006, n° 06-11.288 ; sur l'obligation de constituer la caution dès la conclusion du marché : Dijon, 17 sept. 1996, RDI 1997. 80. – TGI Bordeaux, réf. 10 mai 1995, Dr. et patr. nov. 1995. 74, n° 1096. – TGI Bordeaux, fond, 4 juill. 1996, Gaz. Pal. 1997. 1. 286 ; CARO et FABRE, Gaz. Pal. 1996. 1. Doctr. 136). Lorsque la garantie n'est pas prévue l'entrepreneur conserve la possibilité d'exiger sa constitution au cours de l'exécution du contrat (Civ. 3e, 26 mars 2003, n° 01-01.281, RJDA 11/03, n° 1058), et même une fois la réception prononcée

si des sommes restent dues (Civ. 3e, 24 avr. 2003, n° 01-13.439, Bull. civ. III, n° 81 ; 9 nov. 2005, n° 04-20.047, BPIM 3/06, inf. 27), ou après la date de livraison convenue (Civ. 3e, 1er déc. 2004, n° 03-13.949, BPIM 4/10, inf. 286, préc. *supra,* n° 415, sol. impl. – Civ. 3e, 15 sept. 2016, n° 15-19.648 PB, qui précise que la garantie peut être exigée « même après la réalisation des travaux par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage »).

ACTUALISATION

420. Garantie du paiement de l'entrepreneur : invalidité du cautionnement conditionné. - Il ressort des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre (Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-25.964, D. actu. 24 mars 2021, obs. F. Garcia).

421. Le sous-traitant qui exerce l'action directe bénéficie des mêmes garanties que l'entrepreneur principal lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique (L. du 31 déc. 1975, art. 12, al. 4, mod. par L. du 10 juin 1994).

422. Réserve de propriété. - En remplacement de la garantie instituée par l'article 1799-1, il est parfois stipulé au contrat une clause de réserve de propriété des travaux réalisés par l'entrepreneur ; cette clause est nécessaire, car la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 ne s'applique qu'à « la vente et non à l'entreprise ». Une telle clause est cependant discutable, car contraire à la nature du contrat d'entreprise qui implique l'accession. La Cour de cassation rappelle d'ailleurs que l'entrepreneur n'a pas un droit réel sur l'immeuble et qu'il ne peut exercer un droit de rétention sur le bien construit ou sur le produit de sa vente (Civ. 3e, 23 juin 1999, RJDA 11/99, n° 1252). La clause de réserve de propriété peut-elle faire échec à ce principe ? Un arrêt a admis qu'en cas de redressement judiciaire, la clause de réserve de propriété n'est pas opposable aux autres créanciers du maître de l'ouvrage (Com. 2 mars 1999, RJDA 5/99, n° 579). Mais un autre a décidé que la clause de réserve de propriété est concevable dans le contrat d'entreprise (Com. 29 mai 2001, JCP E 2001. Pan. 2006, note Leveneur ; V. *supra,* n° 33).

Art. 3 - Retenue de garantie

423. Notion. - Le paiement des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés peut être amputé d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant (V. *infra,* nos 424 s.) et garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour

satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage (V. *infra,* n°s 427 s. ; L. 16 juin 1971, mod. par L. n° 72-1166 du 23 déc. 1972, D. 1973. 31, art. 1er). La retenue légale s'applique tant au louage d'ouvrage principal, qu'au sous-traité (art. 4 ; V. sur la question : BOUBLI note *in* RDI 2016. 147).

§ 1er - Constitution de la retenue de garantie

424. Contrat la prévoyant. - La retenue de garantie, quoique légale dans son plafond, doit être prévue par le contrat (Civ. 3e, 7 oct. 2009, n° 08-70.030). Celui-ci doit respecter les conditions fixées par la loi dont les dispositions sont d'ordre public. Les clauses contraires aux dispositions de l'article 1er sont nulles et de nul effet (art. 3).

425. Forme. - La retenue porte sur les acomptes versés par le maître de l'ouvrage, à valoir sur le montant définitif du marché. Elle est égale à 5 % de la valeur de chacun de ces acomptes, lesquels sont fonction des droits de l'entrepreneur constatés dans les situations proposées au paiement. Les acomptes rémunèrent les *travaux exécutés.* La pratique antérieure avait fixé à 10 % le montant de la retenue (V. *supra,* n° 351), ce qui pouvait compromettre la trésorerie des entreprises. Il est généralement admis que le taux légal est le taux maximum qui peut être pratiqué. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce une somme égale à la retenue effectuée. Si la consignation n'a pas été faite, l'entrepreneur peut obtenir le paiement de l'intégralité du prix nonobstant les réserves émises à la réception (Civ. 3e, 18 déc. 2013, n° 12-29.472 , BPIM 1/14, inf. 26).

426. La retenue n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit l'engagement, pour un montant égal, d'une caution bancaire (L., art. 1er, al. 2 et 4). Cette caution, fournie par un établissement figurant sur une liste donnée par le décret n° 71-1058 du 24 décembre 1971 (D. 1972. 17), est en principe concomitante à la conclusion du marché. Il ne semble pas, cependant, qu'il soit interdit de la fournir alors que le marché a reçu un commencement d'exécution. L'accord du maître de l'ouvrage qui a déjà pratiqué la retenue et en a consigné le montant est-il nécessaire ? Le doute est permis : dès lors que la sûreté remplit sa fonction, on voit mal pourquoi cet accord serait nécessaire alors que la loi ne l'impose pas (V. PEISSE, La retenue de garantie dans les marchés privés, Mon. TP 16 sept. 1988, et L'acte de caution en substitution de la retenue de garantie sur les marchés de travaux privés, Gaz. Pal. 1988. 2. Doctr. 728 ; CARO, MOLINIÉ et SILVESTRI, Le point sur la retenue de garantie, Mon. TP 8 févr. 1991. – TGI Metz, 4 juin 1997, RDI 1998. 372). La caution se substitue à la retenue de garantie (Civ. 3e, 6 mai 1998, n° 96-19.010 , Bull. civ. III, n° 93). Elle garantit la bonne exécution des travaux dans les limites de la retenue de garantie. Elle ne

s'applique qu'aux sommes pour lesquelles le maître de l'ouvrage ne peut plus opérer de retenue (même arrêt). Un arrêt a décidé que le maître de l'ouvrage qui fait construire une maison individuelle et retient la somme nécessaire à la bonne exécution de l'ouvrage ne peut pas exiger le bénéfice de la garantie de livraison à prix convenu prévue dans le CCMI (Civ. 3e, 15 déc. 1999, n° 98-15.652, Bull. civ. III, n° 245). On peut, sans doute, tirer de cette décision un enseignement pour apprécier la portée de l'arrêt du 6 mai 1998. Selon un autre arrêt, la garantie substituée, qui peut être mise en œuvre directement par le créancier, a un caractère spécifique et ne constitue pas un cautionnement au sens de l'article 2011 du code civil. Le maître de l'ouvrage n'est donc pas tenu de procéder à la déclaration de créance au passif de l'entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective (Civ. 3e, 3 oct. 2001, RDI 2001. 502). Il a également été jugé que la caution peut contester sa garantie lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas mis en jeu, en temps utile, la police unique de chantier (PUC). Il appartient au créancier qui ne veut pas être déchu de ses droits contre la caution d'établir que la subrogation de celle-ci dans ses droits, devenue impossible, aurait été inefficace (Civ. 3e, 4 déc. 2002, n° 01-03.567). La mise en œuvre de la caution, selon une cour d'appel, ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge des référés (Colmar, 3 déc. 1998, RDI 2000. 53). Il semble que le maître de l'ouvrage puisse renoncer à la caution au bénéfice de l'institution d'une garantie à première demande, qui oblige le garant au paiement sans discuter la créance (Civ. 3e, 17 sept. 2000, n° 98-23.281, BPIM 1/01, inf. 33). Cette garantie correspond à 5 % du montant du marché et non du montant des acomptes (Civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 14-29.837, BPIM 2/16, inf. 98). Elle garantit la levée des réserves et non la bonne fin du chantier (Civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 14-29.836, BPIM 2/16, inf. 99).

§ 2 - Régime de la garantie

427. Objet garanti. - La loi prévoit que la retenue de garantie a pour objet de garantir l'exécution des travaux destinés à satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception (art. 1er). Par ailleurs, la caution est libérée et la somme consignée remise à l'entrepreneur lorsque celui-ci a satisfait aux réserves, et de toute façon dans le délai d'un an à compter de la réception, qu'elle soit ou non assortie de réserves (art. 2) sauf opposition du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 15 avr. 1980, SA Jacques Ribourel c/ SETP, Bull. civ. III, n° 74 ; 31 mars 1999, n° 97-18.235, Bull. civ. III, n° 83). L'opposition abusive du maître de l'ouvrage l'exposerait à des dommages-intérêts.

428. La retenue effectuée et la caution qui la remplace ont pour but de garantir la bonne exécution des travaux (AUBY et PÉRINET-MARQUET, *op. cit.,* n° 1062). Limitées aux désordres, elles ne peuvent concerner le non-respect des délais (Rouen, 2 févr. 1983, D. 1985. IR 243, obs. M. Vasseur. – Civ. 3e, 28 sept. 1983, RDI 1984. 186 ; 23 juill.

1986, Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 229. – Com. 17 oct. et 12 déc. 1984, Mon. TP 4 oct. 1985), la non-assurance (CE 2 juin 1989, D. 1990. somm. 62, obs. P. Terneyre) ou les frais d'expertise (Com. 23 janv. 1990, RDI 1990. 213).

429. S'agissant des travaux concernés par la retenue de garantie, les solutions ne sont pas encore satisfaisantes trente ans après l'entrée en vigueur de la loi. Il ne semble pas qu'il faille limiter la garantie aux travaux permettant de satisfaire aux réserves (V. cep. MEYSSON et LIARD, La retenue de garantie dans les marchés de travaux privés, Mon. TP 12 mai 1972) : en effet, l'article 2 de la loi ne distingue pas suivant que la réception a été ou non assortie de réserves, de sorte que la garantie se maintient pendant un an, même si aucune réserve n'est émise à la réception. En droit positif, il est clair que les désordres réservés à la réception sont couverts par la garantie (Civ. 3e, 26 févr. 1992, n° 90-12.684, Bull. civ. III, n° 63. – Rouen, 20 mai 1999, BPIM 5/99, n° 359). En revanche, s'agissant des désordres après réception, la jurisprudence a donné lieu à des hésitations. Certains arrêts ont fait de la retenue légale ou de la caution, une *garantie de bonne fin des travaux* (Aix-en-Provence, 15 sept. 1983, RDI 1985. 156. – Paris, 29 mars 1991, RDI 1991. 345). Un arrêt de la Cour de cassation a posé que les garanties ne se limitent pas aux seuls travaux mal exécutés, mais concernent l'inexécution de l'ouvrage « contractuellement promis » (Civ. 3e, 15 nov. 1995, RDI 1996. 71), ce qui va au-delà des seuls désordres réservés. Un autre, plus équivoque, énonce dans ses motifs que la garantie permet de satisfaire aux travaux ayant donné lieu à des réserves, tout en relevant dans l'exposé des faits que les désordres sont survenus dans l'année (Civ. 3e, 3 oct. 2001, n° 1377 PB). Un arrêt plus ancien avait admis que la réception devait être assortie de réserves pour que la garantie puisse être mise en œuvre (Civ. 3e, 26 févr. 1992, RDI 1992. 328). Depuis quelques années cependant, la Cour de cassation limite l'objet de la retenue de garantie à la levée des réserves et non à la bonne fin du chantier (Civ. 3e, 7 déc. 2005, n° 05-10.153, BPIM 1/06, inf. 28. – Civ. 3e, 17 juin 2015, n° 14-19.863, D. 2015. 1369, à propos d'un sous-traité, BPIM 4/15, inf. 247. – Civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 14-29.286, BPIM 2/16, inf. 99, à propos d'une garantie à première demande substituée à la retenue légale, V. *supra* n° 426). Un arrêt a exclu du bénéfice de la garantie les désordres postérieurs à la réception, car il autorise l'architecte à libérer la caution en cas de réception sans réserve lorsque le maître de l'ouvrage ne démontre pas qu'il a fait des réclamations précises (Civ. 3e, 9 févr. 2000, n° 98-15.139, Bull. civ. III, n° 28. – V. également : Civ. 3e, 22 sept. 2004, n° 03-12.639, Bull. civ. III, n° 154).

430. Discussion. - Cette lecture restrictive de la loi est plus que discutable et semble devoir se limiter, en fait, à la caution substituée à la retenue. En effet, la loi de 1971 remonte à une époque où la réception impliquait l'achèvement complet de l'ouvrage. Ce n'est plus le cas aujourd'hui : il suffit que l'ouvrage soit en état d'être reçu, ce qui dans le secteur du logement signifie qu'il peut être habité. Or le prix n'est exigible qu'après

l'établissement du mémoire *définitif* et il n'est exigible qu'à l'achèvement total, c'est-à-dire à la livraison. Le solde du prix peut donc être conservé par le maître de l'ouvrage ; comme la garantie de parfait achèvement court entre la réception et la livraison, qu'elle couvre pendant sa durée les désordres réservés ou apparus après la réception et que l'article 1792-6 du code civil autorise le remplacement de l'entrepreneur récalcitrant, ce qui n'a de sens que si la somme retenue peut être, sans dommage pour le maître de l'ouvrage, affectée au paiement du remplaçant, poser que la retenue légale de garantie n'a pour objet que de garantir la levée des réserves est, à notre sens, une erreur. En outre, le texte de l'alinéa 1er de la loi (qui dispose : « pour satisfaire, *le cas échéant,* aux réserves ») rapproché de celui de l'article 2 (qui vise la réception « avec ou sans réserve »), suggère une interprétation téléologique qui, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ne doit pas limiter les désordres garantis à ceux ayant donné lieu à des réserves. La lecture restrictive que fait la jurisprudence récente est d'autant plus difficile à justifier que, d'une part, le maître de l'ouvrage peut opposer l'exception d'inexécution à l'entrepreneur, à ses risques et périls, s'il lui reproche des défaillances dommageables (V. *supra,* n° 432) et d'autre part, qu'il est admis que le contrat peut stipuler une garantie contractuelle n'ayant pas le même objet que la retenue de garantie mais se traduisant en fait par une rétention de sommes dues, supérieure au montant de la retenue légale (Civ. 3e, 10 déc. 2015, n° 14-25.192, RDI 2016. 146).

431. Limite. - La garantie ne peut s'appliquer à des désordres postérieurs à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement (Aix-en-Provence, 15 sept. 1983, préc. *supra,* n° 429), mais les sommes peuvent être retenues tant qu'il n'est pas remédié aux malfaçons garanties. La garantie, en particulier l'obligation de la caution, est limitée aux désordres eux-mêmes et non aux frais accessoires (expertise par exemple : Com. 23 janv. 1990, RDI 1990. 213 ; frais de contrôle : Civ. 3e, 22 sept. 2004, n° 03-12.639, Bull. civ. III, n° 154 ; comp. Civ. 3e, 7 mai 1996, n° 891 D, inédit), aux pénalités de retard (Civ. 3e, 28 sept. 1983, RDI 1984. 186 ; 23 juill. 1986, Gaz. Pal. 1986. Pan. 229. – Rouen, 2 févr. 1984, D. 1985. IR 243) ou au défaut d'assurance (CE 2 juin 1989, D. 1990. Somm. 62). Il a été jugé que le sous-traitant pouvait obtenir une provision sur le montant de la retenue de garantie consignée par l'entrepreneur principal (Civ. 3e, 8 juill. 1992, RJDA 11/92, n° 1013).

432. Exception d'inexécution. - La retenue légale de garantie n'est qu'une application de la théorie de l'exception d'inexécution. Tandis que le créancier oppose l'exception d'inexécution à ses risques et périls, celui qui procède à la retenue le fait par une autorisation de la loi. Dès lors, il est permis de penser que le maître de l'ouvrage peut retenir une somme supérieure à 5 % si les défauts qu'il relève sont importants, et qu'il conserve son droit de rétention alors même que le contrat n'a pas prévu la possibilité de pratiquer la retenue légale. La solution qui n'est pas condamnée en jurisprudence (Civ. 3e, 23 juill. 1986, Gaz. Pal. 1986. Pan. 229 ; *contra* : Paris, 29 mars 1991, RDI 1991. 345), est consacrée par certains arrêts lorsque des faits sérieux sont reprochés

à l'entrepreneur et paraît même être consacrée par un arrêt qui décide qu'une retenue de 10 % est justifiée par l'importance de la défaillance constatée (Civ. 3e, 21 juill. 1999, BPIM 6/99, no 424, qui autorise la rétention de 10 % du prix. – Civ. 3e, 17 févr. 2004, no 02-19.773. – V. aussi : Civ. 3e, 6 nov. 1996, no 95-10.497). Il va de soi que l'exception est opposée aux risques et périls de son auteur et qu'elle n'empêche pas la libération de la caution qui a pu être fournie en application de la loi de 1971, si l'inexécution dont le créancier se plaint n'est pas couverte par cette garantie (Civ. 3e, 26 févr. 1992, RDI 1992. 328).

Section 3 - Réception des travaux

433. Obligatoire et en principe unique, la réception est un acte important qui entraîne une interversion dans le régime du contrat d'entreprise et fait courir les garanties et l'application éventuelle des règles relatives à l'assurance construction. Sa nature juridique (V. *infra,* nos 434 s.), le moment (V. *infra,* nos 443 s.), les formes (V. *infra,* nos 453 s.) et les effets de la réception (V. *infra,* nos 463 s.) méritent l'analyse.

Art. 1er - Nature juridique

434. La réception est une notion probablement issue de la pratique (V. *infra,* nos 435 s.), qui peut poser des difficultés tant de qualification (V. *infra,* nos 437 s.) que de classification (V. *infra,* nos 439 s.).

§ 1er - Définition

435. Ambiguïté de la notion. - Elle concerne tant le contrat principal que le sous-traité. Dans ce dernier cas toutefois, son intérêt est relatif ; la question ne donne guère lieu à une contribution jurisprudentielle et la réception ne sert pas de point de départ à la garantie décennale ou biennale. Qualifiée indifféremment de « réception des travaux » (anc. art. 2270, transféré à l'article 1792-4-1 du code civil) ou « réception de l'ouvrage » (art. 1792-6), la réception fait l'objet pour la première fois avec la loi du 4 janvier 1978 d'une définition légale. L'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, en fait « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ». Selon l'opinion généralement émise, cette définition qui désigne un « acte », met fin à la controverse sur la nature juridique de la réception qui doit être regardée comme un *acte juridique unilatéral* (V. not. CASTON, *op. cit.,* nos 110 s., chron. AJPI 1978. 93 ;

Réflexions sur la réception des travaux après la loi du 4 janvier 1978, *ibid.* 1979. 9 ; MALINVAUD et JESTAZ, article préc., JCP 1978. I. 2900 ; ROULET et PEISSE, article préc., Gaz. Pal. 1978. 1. Doctr. 115 ; BIGOT, *op. cit.,* p. 133 s. ; GAUDEMET, La réception de l'ouvrage dans la loi refermant l'assurance construction, Mon. TP 16 et 23 avr. 1979 ; LIET-VEAUX, À propos de la réception des ouvrages, Gaz. Pal. 1979. 2. Doctr. 414 ; PÉRINET-MARQUET, La réception des travaux : état des lieux, D. 1988. Chron. 287).

436. Sans vouloir raviver la controverse, puisqu'on la dit éteinte, par des considérations de théorie juridique qui n'ont pas leur place dans ces colonnes, on se doit de souligner les difficultés soulevées par la définition légale.

§ 2 - Difficultés de qualification

437. Textes. - Le code civil ne fait aucune référence directe à la réception des travaux. Les articles 1788 et 1790 qui y font allusion parlent de l'ouvrage « reçu », et il est évident que le terme est employé pour éviter une inutile répétition du mot livrer. L'article 1792-6 nouveau, s'il tente de définir la réception, ne lui donne pas le sens que Le Petit Larousse attribue au verbe « réceptionner » ; en définissant la réception, l'acte par lequel le maître « déclare *accepter* l'ouvrage », la loi prend le terme réception au sens de « recevoir » la chose. Or, recevoir la chose n'est-ce pas tout simplement en prendre livraison ? Enfin, et surtout, il n'est pas évident qu'en recevant ou même en réceptionnant l'ouvrage, le maître manifeste une quelconque volonté créatrice qui seule caractérise l'acte juridique (MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, thèse, Toulouse, 1949 ; CATALA, La nature juridique du paiement, thèse, Paris, 1961, p. 165 s. ; BOUBLI, *op. cit.,* n°s 220 s.). Au contraire, c'est en exprimant un *refus* (d'accepter la livraison) ou des *réserves* (en refusant là encore de recevoir la livraison dans les conditions proposées par le débiteur), donc *en refusant* le paiement, qu'il modifie l'environnement juridique par sa volonté et, par conséquent, accomplit un acte juridique : il fait alors échec à un effet légal, l'extinction d'une partie de la dette.

438. Fait juridique ? - La réception n'est-elle pas plutôt un *fait juridique,* et ne doit-elle pas être regardée comme l'envers de la livraison ? N'est-ce pas la loi qui, une fois la livraison intervenue, fait produire à celle-ci des effets juridiques ? On peut l'admettre si l'on veut bien distinguer dans le paiement un élément matériel : l'exécution de l'obligation, et un élément légal : l'extinction de la dette dont les conditions sont aménagées par la loi (CATALA, La nature juridique du paiement, thèse, Paris I, 1961). Cette analyse éclaire certains aspects de la situation légale postcontractuelle, dont la théorie de l'acte juridique ne parvient pas à s'accommoder (pour un exposé complet : BOUBLI, *op. cit.,* n°s 221 s.). Mais elle n'a pas les faveurs de la majorité des interprètes, alors même qu'il existe désormais une réception judiciaire qui prend acte d'une situation

de fait (V. *infra,* n° 418), et que la jurisprudence semble bien tirer les conséquences d'un fait lorsqu'elle décide que la responsabilité de droit commun survit à la réception même sans réserves.

§ 3 - Difficultés de classification

439. Nature de « l'acte ». - En admettant même que la réception soit un acte juridique, il reste à le classer. Dans la théorie classique du paiement, qui regarde celui-ci comme un acte juridique, la présence de « deux acteurs » est toujours nécessaire : « le *solvens* qui exécute ; l'*accipiens* qui accepte » (H., L. et J. MAZEAUD par CHABAS, Leçons, t. 2, 1er vol., n° 830). Si l'on admet, avec la doctrine dominante, que la réception est distincte de la prise de livraison (V. *supra,* n°s 389 s.), ce n'est pas l'exécution conforme de l'obligation par le débiteur qui est libératoire, comme le suggère pourtant l'article 1245 du code civil (V. *supra,* n° 94), mais l'acte juridique de réception. Il y aurait alors dans le paiement, non pas un seul acte, mais deux actes unilatéraux impliquant chacun, comme il est de règle, l'acceptation ou du moins le consentement du créancier : d'une part, la livraison et son envers la prise de livraison ou la prise de possession (qui n'est rien d'autre que la livraison elle-même : JESTAZ et GROSLIÈRE, RDI 1980. 309) ; d'autre part, la réception, acte distinct du précédent, qui, s'il ne produit d'effet que d'un seul côté, doit néanmoins être accepté par le créancier, car il n'a pas un caractère abdicatif (*contra* : H., L. et J. MAZEAUD, *op. cit.,* n° 327). La loi du 4 janvier 1978, si l'on estime qu'elle accrédite la thèse de l'acte juridique, paraît être en ce sens : en tout état de cause, indique-t-elle, la réception est *prononcée contradictoirement* (art. 1792-6 ; V. *infra,* n°s 454 et 456). Cela permet d'éviter que les assurances de responsabilité soient mises en œuvre à la seule discrétion du maître de l'ouvrage.

440. Lien avec le paiement. - Ainsi, la libération du débiteur dans le contrat d'entreprise ne serait pas la conséquence du paiement, c'est-à-dire de l'exécution de son obligation par le locateur, mais procéderait au premier chef de la volonté du maître qui, en réceptionnant, consentirait une remise de dette ou une *renonciation* à certains droits. Ce qui serait singulier alors, c'est que cette renonciation serait… présumée ! Par surcroît, elle laisserait subsister une partie de l'obligation de faire du débiteur : achever l'ouvrage et le livrer !

441. Or, il est bien évident qu'en recevant l'ouvrage, le maître ne *renonce à rien* et surtout pas à l'achèvement de l'immeuble. H. MAZEAUD l'avait parfaitement montré (Mélanges R. Savatier, 1965, Dalloz, p. 645) : il soutenait même que, dans le contrat d'entreprise, les vices apparents relevaient de la garantie décennale. Son analyse reste une référence, même si toutes les conclusions n'ont pas été retenues en droit positif. La garantie des vices apparents n'est pas tout à fait absente dans la vente (art. 1642-1) et dans l'entreprise (garantie de parfait achèvement, *infra,* n°s 474 s.) ; un courant s'est

d'ailleurs dessiné en faveur de la prise en charge des défauts de conformité apparents dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, sinon dans celui de la garantie décennale (Civ. 3e, 23 avr. 1986, Bull. civ. III, nos 46 et 47) et il s'est amplifié.

442. Certains spécialistes (et tel est d'ailleurs l'*intérêt pratique* de la controverse) entendaient faire de la réception l'acte qui marque la fin du contrat (V. encore, en ce sens, PÉRINET-MARQUET *in* Dalloz Action 2014/2015, no 5578) et qui libère le constructeur de toute autre obligation que celles contenues dans les articles 1792 et 2270 du code civil. L'évolution du droit positif montre que cette analyse doit être corrigée. D'abord, il est douteux que la réception marque la fin du contrat (« L'œuvre est là qui subsiste, *res* du contrat », J. CARBONNIER, obs. RTD. civ. 1958. 273) : l'ouvrage n'étant pas achevé à la réception (V. *infra,* no 448), on voit mal comment la réception peut mettre un terme au contrat, alors que l'obligation d'édifier subsiste. Ensuite, la responsabilité contractuelle, dite de « droit commun », survit à la réception, ce qui prive de son effet majeur (et voulu par ses partisans) l'analyse qui fait de la réception un acte juridique. La réception n'a aucun effet *extinctif,* puisque le contrat n'est pas achevé à sa date (V. *infra,* nos 448 s.) ; elle n'a aucun effet *exonératoire,* puisque la responsabilité de droit commun lui survit (V. *infra,* nos 518 s.). On ne peut que se résigner à admettre aujourd'hui l'existence d'une responsabilité contractuelle de droit commun (MALINVAUD, JESTAZ, par JOURDAIN et TOURNAFOND, Droit de la promotion immobilière, *op. cit.,* nos 166 s. ; MALINVAUD et BOUBLI, RDI 1979. 473 ; BOUBLI, *op. cit.,* nos 255 et 425) qui survit à la réception, qui est désormais confirmée par la loi sur la prescription qui l'installe aux articles 1792 et suivants et à laquelle on n'assigne qu'une limite : le caractère apparent du désordre (MALINVAUD, JESTAZ, JOURDAIN et TOURNAFOND, *op. cit.,* no 170. – Civ. 3e, 8 juill. 1975, Bull. civ. III, no 247). Encore faut-il ajouter que cette restriction a une portée relative, car il est de principe que « tout vice est présumé caché jusqu'à preuve du contraire » (ROUAST, *op. cit.,* no 951 ; MALINVAUD, JESTAZ, JOURDAIN et TOURNAFOND, *op. cit.,* no 108), et que, même apparents, les défauts de conformité obligent les constructeurs. La réception n'est probablement aujourd'hui que le *constat d'un certain état d'avancement des travaux* qui permet de faire courir les garanties légales.

Art. 2 - Moment de la réception

443. Achèvement, notion équivoque. - La réception des travaux intervient normalement à l'achèvement des travaux. Marquant l'exécution des obligations contractuelles de l'entrepreneur, elle doit être prononcée une fois la construction achevée (Civ. 3e, 15 juin 1977, Bull. civ. III, no 260 ; 20 mars 1979, D. 1979. IR 521 ; V. égal. ancien CCAG, art. 41 ; norme AFNOR p. 03-001 [1972], art. 14.2.1.2 [1989], art. 15.2.6) ; mais la norme de décembre 2000 est plus nuancée et le nouveau CCAG

(Arr. du 8 sept. 2009, art. 41), tout en faisant allusion à l'achèvement, précise que le maître de l'ouvrage qui réceptionne « fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux » (art. 41-3, V. *infra,* n°s 444 s.). La pratique d'une part, la distinction opérée par la doctrine entre « prise de livraison » et « réception » d'autre part, la loi du 4 janvier 1978 enfin, qui introduit la notion de « parfait achèvement », rendent complexe une situation qui aurait dû être claire (V. *infra,* n°s 448 s.).

§ 1er - Pseudo-abandon de la distinction entre réception définitive et réception provisoire

444. Distinction. - La pratique a fait une distinction entre la réception dite provisoire et la réception définitive. La première marquait l'acceptation « provisoire » des travaux, l'autre qui intervenait à l'issue d'un délai fixé par le contrat, généralement un an, marquait l'acceptation définitive de l'ouvrage. La distinction est héritée d'un usage en vigueur dans les marchés de travaux publics où, à défaut de se justifier, elle peut s'expliquer : en effet, pendant le délai qui s'écoule entre les deux réceptions et qui constitue une « période de garantie », le maître de l'ouvrage public, avec le soutien de ses services techniques, peut procéder à des essais et à des contrôles avant de recevoir définitivement l'ouvrage et de le mettre en service ; sous une autre forme, cette pratique subsiste dans ces marchés (CCAG, art. 41-2), même si la double réception est désormais abandonnée. Rien de tel dans les marchés privés ; l'idée que le maître de l'ouvrage accepterait provisoirement les travaux, c'est-à-dire, si l'on s'en tient à la thèse de l'acte juridique, donnerait un agrément conditionnel, n'est pas sérieuse, puisqu'il ne renonce à rien et n'exprime aucune volonté créatrice ; d'où les difficultés d'application de la distinction. La réception servant de point de départ à la garantie décennale, on s'est demandé s'il convenait de tenir compte de la réception provisoire ou de la réception définitive. En l'absence de volonté clairement exprimée par le maître, les tribunaux ont retenu *la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu,* et la tendance a plutôt été de prendre en considération la réception définitive (Civ. 1re, 17 mai 1965, Bull. civ. I, n° 320 ; 21 juin 1967, *ibid.* I, n° 229. – Civ. 3e, 18 mars 1970, Bull. civ. III, n° 207 ; 18 avr. 1972, *ibid.* III, n° 234).

445. Il n'était pas nécessaire, alors, que la réception définitive fût expressément prononcée. Il suffisait que l'intention du maître d'accepter les ouvrages ait pu se dégager de son comportement (Civ. 3e, 10 janv. 1979, D. 1979. IR 220 ; 23 janv. 1979, RDI 1979. 470). L'acceptation effective des travaux pouvait cependant se manifester dès la réception provisoire, et, pourquoi pas, dès avant l'achèvement de l'ouvrage, cette notion devenant relative, car abandonnée à l'appréciation du maître qui, en recevant, reconnaissait implicitement la bonne exécution du contrat. On trouve ainsi des arrêts qui fixent à la date de la *réception provisoire* le point de départ des garanties

spécialement en l'absence de réserves (Civ. 3e, 3 avr. 1979 et 28 mai 1979, RDI 1980. 64, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; 15 févr. 1989, RGAT 1989. 379 ; 4 juill. 1990, n° 89-11.442, Bull. civ. III, n° 163 ; 21 nov. 1990, RGAT 1991. 125, note d'Hauteville ; comp. Civ. 3e, 3 juill. 1979, RGAT 1980. 170), et d'autres qui retiennent la *date de prise de possession des lieux* même si elle précède la réception provisoire (Civ. 3e, 10 oct. 1969, Bull. civ. III, n° 639), les juges du fond appréciant souverainement la date à laquelle l'acceptation des travaux a réellement eu lieu (Civ. 3e, 9 avr. 1962, Bull. civ. I, n° 205 ; 10 oct. 1969, préc. ; 17 oct. 1972, Bull. civ. III, n° 516 ; comp., pour une définition contractuelle de la réception : Civ. 3e, 4 nov. 1992, RDI 1993. 224).

446. Loi de 1978. - La loi du 4 janvier 1978 (C. civ., art. 1792-6) est censée avoir mis fin à cette situation. Déjà les articles 8 et 9 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 (D. 1968. 35) consacraient l'unité de réception en matière de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, et les principaux documents de référence avaient abandonné la distinction entre réception provisoire et réception définitive (nouv. CCAG ; norme AFNOR de 1972). L'article 1792-6 marque l'aboutissement de cette évolution. Il ne s'agit toutefois que d'une illusion. En effet, la loi institue une garantie de parfait achèvement dont le terme ressemble fort à celui qui était constaté par la réception définitive autrefois ; la jurisprudence n'exige pas l'achèvement complet pour que la réception ait lieu, ce qui postule un *double constat,* donc la possibilité (et même la nécessité) de dresser *deux actes* (pris en tant qu'instruments) ; enfin, la loi du 19 décembre 1990 qui, sans nul doute, associe réception et livraison, laisse cependant subsister la garantie extrinsèque d'achèvement jusqu'à la levée des réserves, ce qui confirme que le double constat est institutionnalisé.

§ 2 - Achèvement requis pour réceptionner

447. L'achèvement requis pour réceptionner est un « achèvement relatif » des travaux (V. *infra,* nos 448 s.) qui n'interdit pas la possibilité de procéder à des réceptions partielles en présence de lots séparés (V. *infra,* nos 452 s.).

A - Achèvement « relatif »

448. Pseudo achèvement. - L'achèvement des travaux a longtemps été considéré comme une condition de la réception, puisque c'est à cette date que le maître de l'ouvrage constate l'exécution de ses obligations par l'entrepreneur et accepte l'ouvrage (en ce sens : CASTON, La responsabilité des constructeurs, t. 1, 3e éd., 2000, éd. Le Moniteur, nos 215 s. ; norme p. 03-001 de 1948, art. 1.5.41 ; de 1989, art. 15.2.6 ; de 2000, art. 17.2.1.1.2 ; loi du 19 décembre 1990, qui assigne pour terme à la garantie de

livraison au prix convenu, la réception des travaux – CCH, art. L. 231-6-IV ; CE 3 juill. 1891, Cne de Valras, Lebon 519 ; 11 févr. 1991, RDI 1991. 210. – Civ. 3e, 17 juill. 1961, AJPI 1961. 167 ; 8 oct. 1974, Bull. civ. III, no 337 ; 15 juin 1977, *ibid.* III, no 260 ; 24 mars 1982, *ibid.* III, no 80 ; 3 avr. et 28 mai 1979, RDI 1980. 64. – Paris, 2 mars 1988, RDI 1988. 210. – Riom, 7 juill. 1988, RDI 1989. 213 ; plus récemment, BÉNABENT, note sous Civ. 1re, 5 mai 1993, D. 1993. 506, qui rappelle que la délivrance, qui n'est acquise que lorsque la chose est conforme, s'éteint par la réception et que la garantie prend alors le relais de la délivrance). Or, la Cour de cassation a jugé que c'était « ajouter à l'article 1792-6 » du code civil de décider que « la réception ne peut intervenir que lorsque l'ouvrage est achevé » (Civ. 3e, 12 juill. 1989, RDI 1990. 83, obs. Malinvaud et Boubli ; 9 oct. 1991, RDI 1992. 71, obs. P. Malinvaud et B. Boubli). L'achèvement de l'ouvrage n'est donc pas une condition nécessaire de la réception (Civ. 3e, 30 oct. 1991, RDI 1992. 518 ; 4 nov. 1992, RDI 1993. 224 ; 11 févr. 1998, no 96-13.142, Bull. civ. III, no 28 ; 12 janv. 2005, no 03-17.431 ; Civ. 3e, 7 juill. 2015, no 14-17.115, RDI 2015. 530). Cette position peut avoir deux explications : favoriser la mise en œuvre rapide de l'assurance obligatoire (V. Civ. 1re, 7 juin 1989, D. 1989. IR 202) ; aligner les conditions objectives permettant le paiement à concurrence de 95 % du prix dans le contrat d'entreprise sur celles qui permettent au maître d'ouvrage-vendeur d'obtenir 95 % du prix de vente lorsqu'il vend le même immeuble sous le régime de la vente d'immeuble à construire.

449. État des lieux. - À défaut d'un achèvement total, la jurisprudence se satisfait d'un état d'avancement suffisant des travaux pour que la réception soit valablement prononcée. Une difficulté vient toutefois du fait que la réception peut être amiable tacite ou judiciaire et que la Cour de cassation se prononce sur l'état d'achèvement requis à l'occasion de chacune de ces questions. Bien que l'on soit sur le terrain du fait, et par conséquent du pouvoir d'appréciation des juges du fond, il importe de dégager un critère objectif de ce que l'on peut tenir pour un « achèvement relatif ». Dans le secteur du logement, il est possible de s'inspirer de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation relatif à la vente en l'état futur d'achèvement. Mais l'exercice est plus délicat pour les ouvrages de génie civil. Un arrêt, se prononçant à propos d'une réception judiciaire, retient, d'une manière générale, la « date à laquelle les ouvrages sont en état d'être reçus » (Civ. 3e, 30 juin 1993, RDI 1993. 511). Si cette solution est généralement admise (Civ. 3e, 10 déc. 2015, no 13-16.086, RDI 2016. 148). Dans le secteur du logement, la plupart des arrêts tiennent compte du moment où l'immeuble est « habitable » (Civ. 3e, 30 oct. 1991, RDI 1992. 518 ; 4 déc. 2002, no 00-17.925 ; 21 mai 2003, no 01-17.484, Bull. civ. III, no 105 ; 27 janv. 2009, no 07-17.563 ; Civ. 3e, 29 mars 2011, no 10-15.824, BPIM 3/11, inf. 208). Dans le secteur du génie civil ou plus généralement lorsque la condition d'habitabilité est sans rapport avec la nature des travaux la jurisprudence ne fournit aucune indication précise, mais sans doute peut-on s'inspirer des motifs d'un arrêt qui, à propos d'une réception

judiciaire, retient que « l'achèvement » était « pour l'essentiel » réalisé (Civ. 3e, 4 avr. 2001, n° 99-17.142 ; V. plus généralement : Civ. 3e, 16 févr. 1994 et 16 mars 1994, RDI 1994. 455 ; comp. : Civ. 3e, 10 juill. 1991, RDI 1992. 71, qui tient compte de l'importance des malfaçons. – Civ. 3e, 9 déc. 1998, n° 1803, D, BPIM 1/99, n° 34, qui décide que la signature du procès-verbal de réception marque l'exécution des travaux commandés, ce qui est d'une portée relative si l'achèvement n'est pas complet. – Civ. 3e, 15 janv. 1997, RJDA 4/97, n° 587, qui retient que la mention, au procès-verbal, de « travaux à terminer », n'empêche pas la réception d'être acquise ; V. aussi Civ. 3e, 3 déc. 2002, n° 1823 FS-D, inédit, à propos d'une maison inhabitable pour un handicapé). Toutefois, un arrêt, statuant à propos d'un ravalement impliquant des reprises à 67 % fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé la réception judiciaire sans rechercher si « compte tenu de sa nature, l'ouvrage était en état d'être reçu » (Civ. 3e, 25 mars 2015, n° 14-12.875, RDI 2015. 298, obs. Boubli). Que doit constater le juge dans un tel cas ? (V. BOUBLI, obs. préc. *in* RDI 2015. 298). Un arrêt statuant à propos d'un abandon de chantier, énonce même en termes généraux, que la réception tacite n'est pas soumise à la condition que l'immeuble soit en état d'être reçu (Civ. 3e, 25 janv. 2011, n° 10-30.617, RDI 2011. 221). En application de l'article 42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), la jurisprudence administrative paraît s'en tenir, pour l'instant, à l'achèvement complet (CE 11 févr. 1991, RDI 1991. 210 ; 12 juill. 1993, D. 1994. Somm. 228, obs. Terneyre).

450. Accord des parties. - La réception peut, *contractuellement,* être fixée à l'*achèvement complet* des ouvrages (KARILA, AJPI 1997. 9). Il peut en être ainsi lorsque le marché se réfère à la norme AFNOR. Un arrêt confirme cette possibilité (Civ. 3e, 11 mars 1998, BPIM 3/98, n° 191. – Rappr. : Civ. 3e, 23 oct. 2007, n° 07-10.509, BPIM 1/08, inf. 36). En revanche, on ne peut conventionnellement faire produire à la prise de possession, l'effet d'une réception sans réserve (Civ. 3e, 6 mai 2015, n° 13-24.947, BPIM 3/15, inf. 190).

451. Marché interrompu. - À l'inverse, la réception est admise par la jurisprudence lorsque le *marché n'est pas mené à son terme.* L'*accord de résiliation* peut valoir réception pour les ouvrages exécutés (Civ. 3e, 3 juill. 1991, Le Moniteur, 20 mars 1992). Un relevé des travaux doit alors être dressé (Civ. 3e, 24 juin 1992, n° 90-19.493, Bull. civ. III, n° 217). Le maître de l'ouvrage doit être partie à l'acte : un état des travaux entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante n'est pas opposable au maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 20 nov. 1996, n° 1744 D, Banque BTP). Le remplacement d'une entreprise par une autre ne vaut pas réception des travaux exécutés par la première (Civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15-17.129), sauf, semble-t-il, si un état contradictoire des travaux est dressé (Civ. 3e, 24 juin 1992, n° 90-19.493, Bull. civ. III, n° 217). En cas d'*abandon de chantier,* l'acte qui fait l'inventaire des travaux exécutés peut valoir réception ; selon la

jurisprudence, celle-ci peut être tacite (Civ. 3e, 17 juill. 1997, BPIM 6/97, n° 386 ; 11 févr. 1998, n° 96-13.142, Bull. civ. III, n° 28). Mais le principe même d'une « réception » valant acceptation des travaux lorsque le débiteur se dérobe à ses obligations essentielles est plus que discutable : sauf si le maître de l'ouvrage consent une remise de dette à l'entrepreneur et lui donne *quitus,* l'état des lieux lors de l'abandon de chantier n'est qu'un constat d'éléments matériels, et si l'immeuble n'est pas habitable dans le secteur du logement, la réception a d'autant moins de raison d'être admise que les garanties légales ne peuvent sérieusement courir : si l'inachèvement caractérise à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et que la garantie décennale est admise l'assureur est-il tenu d'une garantie de bonne fin ? Néanmoins, la Haute juridiction admet la réception tacite en cas d'abandon de chantier et pose même dans un arrêt une règle qui paraît générale en décidant que la réception tacite n'est pas soumise à la condition que l'immeuble soit habitable ou en état d'être reçu (Civ. 3e, 25 janv. 2011, n° 10-30.617, RDI 2011. 221. – Rappr. : Civ. 3e, 5 déc. 2012, n° 11-25.905, BPIM 1/13, inf. 42. – Comp. : Civ. 3e, 27 janv. 2009, n° 07-17.563, à propos de la réception judiciaire).

B - Réceptions partielles

452. Lots. - La réception partielle des travaux est concevable en cas de *marchés par lots séparés* ; chaque contrat donne lieu à une réception particulière. Cette conséquence est défavorable au maître de l'ouvrage, mais elle ne paraît pas condamnée par l'article 1792-6 qui vise la réception de « l'ouvrage », cette désignation ne concernant pas nécessairement l'ensemble des travaux. D'ailleurs, l'article 1792-4-1 (anc. art. 2270) du code civil se contente de faire allusion à la réception des travaux. Le CCAG Travaux de 2009 (art. 42) envisage la réception par « tranche de travaux », ce qui ne s'entend pas nécessairement d'une réception par lot ; mais il ne s'explique pas sur les conséquences de cette pratique en matière de garantie : quel est le point de départ de celle-ci ? On peut d'ailleurs se demander si la réception par corps d'état est possible lorsque les entreprises sont « groupées solidaires ». La norme AFNOR p. 030-01 suggère la réception unique (art. 17.2.1.1 s.) même, semble-t-il, lorsque les entreprises sont « groupées conjointes ». La Cour de cassation ne condamne cependant pas les réceptions partielles (Civ. 3e, 20 nov. 2007, n° 06-18.404. – Civ. 3e, 16 nov. 2010, n° 10-10.828, RDI 2011. 285), en particulier lorsque chaque lot donne lieu à un marché particulier (Civ. 3e, 19 juin 2012, n° 10-25.971, RDI 2012. 449. – Civ. 3e, 23 sept. 2014, n° 13-18.183, BPIM 6/14, inf. 387) mais on se demande comment elle peut concilier cette solution avec sa jurisprudence sur les conditions de la réception, qui impliquent dans le secteur du logement que l'ouvrage soit habitable ; comment un « lot » peut-il satisfaire à cette condition ? Certaines cours d'appel tentent d'écarter la réception par lots en relevant que les lots sont constitutifs

d'un ensemble, mais la Cour de cassation ne se laisse pas convaincre (Civ. 3e, 23 sept. 2014, no 13-18.123, RDI 2014. 636. – Comp. toutefois : Civ. 3e, 7 févr. 2012, no 11-11.449, BPIM 2/12, inf. 121). La réception des travaux *par bâtiment,* lorsque le marché concerne des groupes différents d'ouvrage, n'est pas souhaitable (norme AFNOR p. 03-001). Mais elle ne paraît pas être condamnée en jurisprudence (Civ. 3e, 5 mai 1970, Bull. civ. III, no 304 ; 10 janv. 1990, no 88-14.656, Bull. civ. III, no 6 ; 13 juin 1990, Mon. TP 21 sept. 1990 ; CE 23 nov. 1985, Mon. TP 25 avr. 1986). Le principe est, cependant, que la réception doit être globale (Civ. 3e, 6 oct. 1999, BPIM 6/99, no 427 ; 21 juin 2000, BPIM 4/00, no 243. – Paris, 15 avr. 1999, RDI 1999. 654). *Il faut distinguer la réception partielle des réceptions successives* rendues nécessaires par les travaux de reprise ou de remise en état, en particulier lorsqu'ils sont réalisés par un nouvel entrepreneur ; la garantie de parfait achèvement en fournit une illustration. Ces garanties courent alors à compter de chacune des réceptions (et non de la dernière appréhendée comme une réception de synthèse, option qui n'a pas les faveurs de la Cour de cassation : Civ. 3e, 2 mars 2011, no 10-15.211, RDI 2011. 287, selon laquelle : « Viole les articles 1792 et 2270 du code civil une cour d'appel qui retient que c'est à partir de la date de réception des travaux de stabilisation pris dans leur ensemble que court la garantie décennale du constructeur, alors qu'elle avait constaté que la réparation des désordres était intervenue selon des paliers successifs ayant fait l'objet de réceptions distinctes »).

Art. 3 - Formes de la réception

453. La réception peut se présenter sous plusieurs formes. En principe, elle est expresse (V. *infra,* nos 454 s.) mais elle peut aussi être tacite (V. *infra,* nos 456 s.) ou judiciaire (V. *infra,* nos 459 s.), l'architecte peut assister le maître de l'ouvrage dans l'opération (V. *infra,* nos 461 s.).

§ 1er - Réception expresse

454. Accord. - La réception est le plus souvent *amiable.* L'article 1792-6, alinéa 1er, le rappelle. La réception amiable s'entend en réalité d'une réception volontaire à laquelle les deux parties doivent participer. L'article 1792-6 précise en effet qu'elle est, « en tout état de cause, *prononcée contradictoirement* » (Civ. 3e, 4 avr. 1991, RDI 1991. 347). La présence ou tout au moins la convocation régulière de l'entrepreneur est impérative (Civ. 3e, 16 févr. 1994, no 92-14.342 et 16 mars 1994, no 92-10.957, RDI 1994. 455. – Civ. 3e, 20 févr. 2002, BPIM 3/02, inf. 184. – Civ. 3e, 3 juin 2015, no 14-

17.744, BPIM 4/5, inf. 253). La réception doit être exempte de fraude (Civ. 1re, 21 févr. 1989, RGAT 1989. 372, note A. d'Hauteville) ; la présence du sous-traitant n'est pas nécessaire : celui-ci n'est pas partie à la réception (Civ. 3e, 20 oct. 2009, no 08-15.381). La réception amiable a lieu à la requête de la partie la plus diligente, selon des modalités particulières dans les marchés publics (CCAG, art. 41-1-2 s.). Elle donne lieu à la rédaction d'un *procès-verbal* dans lequel sont éventuellement consignées les *réserves* émises par le maître de l'ouvrage (sur la forme des réserves : Civ. 3e, 30 sept. 1998, Épx Kaufmann c/ Cogedim ; 7 oct. 1998, BPIM 1/99, no 33). Le maître de l'ouvrage peut toujours renoncer aux réserves émises ; sa renonciation doit être sans équivoque (Civ. 3e, 13 avr. 2005, no 03-15.892, BPIM 3/05, inf. 198). Le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence de réserves, sans constater l'existence d'une réception (Civ. 3e, 7 avr. 2016, no 15-15.071, BPIM 3/16, inf. 178). Lorsque des réserves sont émises, il appartient à l'entreprise de les « lever », c'est-à-dire de procéder aux réparations nécessaires sous peine d'engager sa responsabilité (Civ. 3e, 15 sept. 2016, no 15-19.692 ; cette obligation relève normalement du parfait achèvement, mai l'arrêt n'en fait pas mention). La *formalité de l'écrit* non exigée par la loi peut s'imposer, en pratique, pour des raisons de preuve. S'agissant par hypothèse d'un acte juridique, la réception est soumise au droit commun de la preuve par écrit au-dessus de 1 500 euros. Toutefois, malgré quelques décisions des juges du fond en ce sens (TGI Aix-en-Provence, 8 janv. 1985, D. 1986. 289. – TGI Chaumont, 31 mars 1988, RDI 1988. 300 ; V. BERGEL, RDI 1986. 363), et nonobstant l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation qui impose la réception par *écrit* dans le contrat de construction de maison individuelle, la Cour de cassation, en admettant la réception tacite, ne paraît pas exiger le respect des règles de preuve des actes juridiques. Un arrêt a même écarté expressément les formalités prévues par le code civil (Civ. 3e, 12 juin 1991, no 90-10.692, Bull. civ. III, no 166). Le procès-verbal peut ne pas être signé si son caractère contradictoire ne fait guère de doute (Civ. 3e, 4 janv. 2006, no 04-13.449, Bull. civ. III, no 1. – Civ. 3e, 12 janv. 2011, no 09-70.262 BPIM 2/11, inf. 119). L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de validité du procès-verbal (Civ. 3e, 7 juill. 2015, no 14-17.115, BPIM 3/05, inf. 198. – V. plus généralement, nos 448 s.).

ACTUALISATION

454. Réception contradictoire : preuve par tous moyens de la convocation de l'entreprise absente. - L'exigence du caractère contradictoire de la réception est respectée dès lors que le maître d'ouvrage rapporte la preuve, par tous moyens, que l'entreprise de travaux qui ne s'est pas présentée le jour de la réception a régulièrement été convoquée pour y participer, en temps utile (Civ. 3e, 7 mars 2019, no 18-12.221, D. actu. 18 mars 2019, obs. D. Pelet).

Incompatibilité entre la réception expresse et tacite. Dès lors que le maître de l'ouvrage a expressément accepté de recevoir l'ouvrage par la signature d'un procès-verbal, l'architecte ne peut pas solliciter du juge le constat d'une réception tacite à l'égard d'un autre constructeur non convoqué à la réception expresse, sous peine de violer l'exigence du contradictoire (Civ. 3e, 8 nov. 2021, n° 20-20.428, D. actu. 15 nov. 2021, obs. C. Dreveau).

455. Accord de résiliation. - La réception peut résulter d'un accord de résiliation amiable (V. *supra,* n° 451). Le procès-verbal de réception peut comporter d'autres mentions que les réserves (V. *supra,* n° 451). Enfin, la réception peut résulter de formes contractuellement définies (V. norme AFNOR. p. 03-001 : qui distingue réception expresse, tacite et judiciaire ou forcée et en précise les modalités aux art. 17.2 s. ; V. aussi CCAG de 2009, art. 41. – Civ. 3e, 23 oct. 2007, n° 07-10.509).

§ 2 - Réception tacite

456. Création jurisprudentielle. - C'est à la distinction artificielle entre livraison et réception que l'on doit le contentieux obscur de la *réception tacite.* En effet, la livraison est, selon l'expression de P. JESTAZ, l'état physique d'un immeuble « impeccable » (RDI 1982. 336) ; et la prise de possession n'est rien d'autre, selon l'opinion la plus autorisée, que la livraison (« une fois pour toutes, c'est la même chose », écrivent P. JESTAZ et J.-C. GROSLIÈRE, RDI 1980. 309). Or, il est acquis que toute prise de possession n'est pas nécessairement une réception (Civ. 1re, 27 juin 1977, Cie La Protectrice ; 15 juin 1977, Bull. civ. III, n° 260 ; 27 févr. 1979, RDI 1979. 477. – Paris, 27 sept. 1978, *ibid.* 1979. 209 ; arg. : Civ. 3e, 10 juill. 1991, RDI 1991. 481), et que la prise de possession peut précéder la livraison. Admise sous l'empire de la législation antérieure à 1978, la réception tacite l'est encore aujourd'hui. La Cour de cassation se prononce en faveur de la réception tacite (Civ. 3e, 22 juin 1994, n° 90-11.774 , RJDA 10/94, n° 1064), en insistant sur son caractère contradictoire (Civ. 3e, 16 juill. 1987, Bull. civ. III, n° 143, RDI 1987. 454 ; 12 oct. 1988, Bull. civ. III, n° 137 ; 7 déc. 1988, RDI 1989. 213 ; 4 avr. 1991, RDI 1991. 347 ; CE 11 févr. 1991, RDI 1991. 210 . – Civ. 3e, 18 nov. 1992, RDI 1993. 80 ; 6 mars 2002, RDI 2002. 214 ; comp. : Civ. 3e, 31 janv. 2007, n° 05-18.959 , Bull. civ. III, n° 10). Dans les marchés publics, la réception tacite a fait difficulté. Certains auteurs ont hésité à l'admettre en dehors des cas où la réception est réputée acquise (CCAG, art. 41-1-3) ; mais la jurisprudence administrative évolue dans un sens favorable (CE 30 janv. 1995, RDI 1995. 320 ; 10 mai 1995, RDI 1995. 544 ; V. CE 11 févr. 1991, RDI 1991. 210 , qui paraît exiger l'achèvement de l'ouvrage).

ACTUALISATION

456 s. Paiement du prix et réception tacite. - Le régime spécial du contrat de construction de maison individuelle n'exclut pas la reconnaissance d'une réception tacite de l'ouvrage. Une telle réception est notamment caractérisée lorsque 95 % du prix a été payé et que les locataires sont entrés dans les lieux, ce dont il résulte une volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux (Civ. 3e, 20 avr. 2017, n° 16-10.486, D. 2017. 919 ; Dalloz actualité, 9 mai 2017, obs. Garcia).

Présomption de réception tacite : paiement intégral et prise de possession. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception ; mais le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, dont la « volonté non équivoque » du maître d'ouvrage de recevoir les travaux se déduit. Celui qui conteste la réception tacite doit donc prouver que cette volonté fait défaut pour renverser cette présomption simple : la charge de la preuve est renversée sur ce point (Civ. 3e, 30 janv. 2019, n° 18-10.197, D. actu. 21 févr. 2019, obs. D. Pelet).

Conditions d'admission de la réception tacite. En l'absence de réception expresse, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (Civ. 3e, 18 avr. 2019, n° 18-13.734, D. actu. 22 mai 2019, obs. D. Pelet).

457. Volonté non équivoque de recevoir. - Selon la Cour de cassation, la réception tacite résulte d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 176 ; 18 juin 1997, BPIM 5/97, n° 320 ; 17 juill. 1997, BPIM 6/97, n° 386. – Civ. 3e, 20 mai 2014, n° 13-18.002, RDI 2014. 465. – Civ. 3e, 10 mars 2015, n° 13-19.997 et n° 14-10.053, RDI 2015. 300). Mais cette volonté ne peut que s'induire de circonstances de fait ; à défaut, quoique non écrite, la réception serait expresse. Selon un arrêt, elle ne peut être retenue lorsque la qualité des travaux est contestée (Civ. 3e, 24 mars 2016, n° 15-14.830, BPIM 3/16, inf. 177) ; elle se déduit en général d'éléments positifs et requiert, selon l'opinion généralement émise, que l'ouvrage soit « en état d'être reçu », condition commune à la réception tacite et judiciaire (Droit de l'urbanisme et de la construction, 7e éd., Montchrestien, n° 1270). La Cour de cassation a toutefois posé dans un arrêt que la réception tacite n'est pas soumise à la condition que l'ouvrage soit en état d'être reçu (Civ. 3e, 25 janv. 2011, n° 10-30.617, RDI 2011. 221, rendu à propos d'un abandon de chantier, V. *supra,* n° 409) et la portée de cette jurisprudence reste incertaine (V. Civ. 3e, 30 juin 1993,

n° 91-18.696, Bull. civ. III, n° 103, qui retient que l'ouvrage doit être en état d'être reçu. – Civ. 3e, 20 juin 2007, n° 06-13.565, qui relève que les équipements indispensables sont réalisés. – Civ. 3e, 23 févr. 2000, BPIM 3/00, n° 173 qui ne fait pas de la mise hors d'eau d'une piscine, une condition de la réception tacite). La prise de possession est à elle seule insuffisante (Civ. 3e, 3 mai 1990, n° 88-19.301, Bull. civ. III, n° 104 ; 1er déc. 1999, BPIM 1/00, n° 24. – Civ. 3e, 4 oct. 2000, n° 97-20.990, Bull. civ. III, n° 239 ; 24 mars 2009, n° 08-12.663. – Civ. 3e, 12 févr. 2014, n° 13-10.930, BPIM 2/14, inf. 107. – Civ. 3e, 8 avr. 2014, n° 13-16.250, BPIM 3/14, inf. 174, dans ces deux cas, prise de possession rendue nécessaire par l'exploitation commerciale). Mais elle est un élément d'appréciation utile si elle s'accompagne d'autres éléments : paiement du prix (Civ. 3e, 12 oct. 1988, RDI 1989. 213. – Civ. 3e, 4 juin 1998, RDI 1998. 373. – Civ. 3e, 23 mai 2012, n° 11-10.502, Bull. civ. III, n° 76). À lui seul, toutefois, le paiement du prix est insuffisant (Civ. 3e, 30 sept. 1998, n° 96-17.014, Bull. civ. III, n° 175 ; 13 janv. 2009, n° 08-11.015. – Civ. 3e, 24 mars 2015 n° 13-19.997 et n° 14-10.723, BPIM 3/15, inf. 191) ; il est souvent accompagné d'autres éléments : déclaration d'achèvement des travaux (Civ. 1re, 10 juill. 1995, n° 93-13.027, Bull. civ. I, n° 315. – Civ. 3e, 14 mars 2001, BPIM 3/01, n° 186) ou prise de possession. La réception tacite a ainsi été déduite d'une prise de possession du paiement d'une partie importante du prix et de l'exécution des travaux de remise en état par l'entrepreneur (Civ. 3e, 6 nov. 1996, BPIM 1/97, n° 32, 1re esp. ; rapp. : Civ. 3e, 6 oct. 1999, BPIM 6/99, n° 427 ; 14 mars 2001, BPIM 3/01, n° 186 ; 8 nov. 2006, n° 04-18.145, Bull. civ. III, n° 218 ; comp. : Civ. 3e, 16 févr. 2005, n° 03-16.880, Bull. civ. III, n° 36). Elle a également été retenue en cas d'abandon de chantier suivi du paiement immédiat du devis et de la prise de possession des lieux (Civ. 3e, 11 févr. 1998, n° 93-13.142, Bull. civ. III, n° 28). Mais elle a été écartée lorsqu'un désaccord immédiat s'est exprimé sur la qualité des travaux et le montant du prix (Civ. 3e, 4 déc. 1996, BPIM 1/97, n° 32, 2e esp. ; 24 mars 2009, n° 08-12.663), et lorsque la maison était inhabitable pour un handicapé (Civ. 3e, 3 déc. 2002, n° 1823 FS-D, inédit). Elle a été écartée à propos d'une chaudière mise en service pour vérification (Civ. 3e, 21 nov. 2000, RDI 2001. 55), pour des travaux ayant donné lieu à des reprises (Civ. 3e, 22 nov. 2000, RDI 2001. 55), même si les lieux ont été occupés (Civ. 3e, 13 janv. 2009, n° 08-11.015). Un arrêt de la Cour de cassation suscite la curiosité autant que la vigilance : alors que le juge du fond avait écarté la réception tacite en déduisant de la rétention d'une partie du prix, du risque de désordres structurels et de réserves, la circonstance que nonobstant la prise de possession rendue impérative pour des raisons économiques, la volonté non équivoque d'accepter les travaux n'était pas caractérisée, la Cour de cassation censure l'arrêt, en relevant que de tels motifs « ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage » (Civ. 3e, 13 juill.

2016, n° 15-17.208). La présentation du motif sous une forme négative, alors qu'il a été jugé que la prise de possession motivée par des contraintes économiques était équivoque (Civ. 3e, 12 févr. 2014, n° 13-10.930. – Civ. 3e, 8 avr. 2014, n° 13-16.250, préc.), invite à se demander si l'arrêt n'est pas favorable à une présomption d'acceptation des travaux sauf preuve contraire… Un autre arrêt reprend cette même motivation (Civ. 3e, 15 sept. 2016, n° 15.20.143) ce qui marque une évolution favorable à la reconnaissance de la réception tacite comme le relève l'arrêt du 13 juillet précité qui la retient nonobstant une prise de possession contrainte par les événements. Cette tendance permet au maître de l'ouvrage de bénéficier de la garantie décennale et surtout de l'assurance construction ; elle confirme en tout cas que la réception ne marque pas la fin du contrat d'entreprise puisque l'obligation d'achèvement de l'entrepreneur subsiste. *Le juge qui constate l'existence d'une réception tacite en fixe la date* (Civ. 3e, 30 mars 2011, n° 10-30.116, BPIM 3/11, inf. 207. – Civ. 3e, 11 avr. 2012, n° 11-12.505, BPIM 3/12, inf. 226) ; il suffit toutefois que celle-ci soit déterminable et permette de s'assurer par exemple, du point de départ de la garantie décennale (Civ. 3e, 23 mai 2012, n° 11-10.502, Bull. civ. III, n° 76).

ACTUALISATION

457. Absence de réception tacite en cas de contestation de la qualité des travaux. - Les contestations constantes de la qualité des travaux exécutés et la demande d'une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur peuvent permettre de désuire l'absence de la réception tacite par le maître de l'ouvrage, malgré la prise de possession et le paiement d'une partie des factures (Civ. 3e, 1er avr. 2021, n° 20-14.975, D. actu. 27 avr. 2021, obs. C. Dreveau).

458. Réserves. - Selon la Cour de cassation, la réception tacite n'est pas exclusive de *réserves* (Civ. 1re, 10 juill. 1995, n° 93-13.027, Bull. civ. I, n° 315 ; V. aussi Paris, 29 avr. 1994, RDI 1994. 662 ; rappr. : Civ. 3e, 7 mars 1990, n° 88-13.832, Bull. civ. III, n° 68 ; Civ. 3e, 17 oct. 1990, RDI 1991. 66 ; Civ. 3e, 2 oct. 2001, RDI 2002. 85). On peut certes se demander comment une volonté implicite d'accepter peut comporter une restriction constitutive de réserves… *Mais en réalité la réception tacite n'est qu'une réception judiciairement constatée,* à titre incident, en cas de contestation sur les responsabilités encourues. La réception *tacite n'existe que si le juge la constate.* Il le fait en tenant compte d'éléments objectifs, dont l'état d'avancement des travaux. Si celui-ci est caractérisé, alors même que des désordres ou défauts de conformité n'altérant pas substantiellement l'ouvrage sont identifiés, la réserve est retenue par le juge (Civ. 3e, 15 janv. 2008, n° 06-15.029). La réception tacite n'est alors qu'une réception judiciaire prononcée à titre incident, qui ne se heurte qu'à la volonté contraire manifeste de réceptionner (Civ. 3e, 5 juin 1999, BPIM 5/96, n° 349). On notera cependant que la Cour de cassation interdit au juge de transformer l'objet du litige en

prononçant une réception judiciaire, alors qu'il est saisi d'une question relative à la réception tacite (Civ. 3e, 22 févr. 1995, n° 93-13.346, Bull. civ. III, n° 55 ; 12 mai 1999, BPIM 5/99, n° 365), et qu'elle a jugé que le litige sur la réception tacite peut soulever une contestation sérieuse en référé (Civ. 3e, 12 mars 1997, n° 95-10.781).

§ 3 - Réception judiciaire

459. Réception forcée. - À défaut d'être amiable, la réception intervient « judiciairement » (art. 1792-6). La réception judiciaire est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente (qui ne peut pas être l'assureur de dommages : Civ. 3e, 23 avr. 1997, n° 95-18.317, Bull. civ. III, n° 84) lorsque l'autre est récalcitrante. Elle est prononcée par le juge (V. Civ. 3e, 20 nov. 2012, n° 11-22.682, BPIM 1/13, inf. 43, qui relève qu'elle ne peut intervenir tacitement) en considération de l'état d'achèvement relatif déjà évoqué (V. *supra,* n° 448) et qui implique que l'ouvrage soit en « état d'être reçu » (Civ. 3e, 10 déc. 2015, n° 13-16.086, RDI 2016. 148), ce qui peut résulter de la circonstance que l'immeuble est effectivement habitable (Civ. 3e, 30 oct. 1991, RDI 1992. 518. – Civ. 3e, 20 nov. 2007, n° 06-21.064. – Civ. 3e, 29 mars 2011, n° 10-15.824, BPIM 3/11, inf. 208. – V. toutefois : Civ. 3e, 8 juin 2006, n° 05-15.509, Bull. civ. III, n° 139, qui refuse la réception judiciaire lorsque l'immeuble est habitable mais que l'entrepreneur s'est opposé à la réception ; V. aussi pour un abandon de chantier : Civ. 3e, 27 janv. 2009, n° 07-17.563 ; pour d'autres cas de réception judiciaire : Civ. 3e, 10 juill. 1991 et 9 oct. 1991, RDI 1992. 71, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; 4 nov. 1992, RDI 1993. 224 ; 14 janv. 1998, n° 96-14.482, Bull. civ. III, n° 5). La notion d'ouvrage susceptible d'être reçu est cependant aléatoire dans bien des cas et dépend de facteurs parfois déroutants en jurisprudence (V. notamment, Civ. 3e, 25 mars 2015, n° 14-12.875, RDI 2015. 298). La réception, qui peut être assortie de réserves (Civ. 3e, 30 oct. 1991, préc.), semble donc être fixée à la date à laquelle les travaux sont en état d'être reçus (arrêts préc., sol. impl. ; V. égal. Civ. 3e, 23 avr. 1986, Bull. civ. III, n° 47. – Paris, 25 oct. 1989, RDI 1990. 84. – Civ. 3e, 30 juin 1993, RDI 1993. 511 ; 22 mai 1997, RJDA 8-9/97, n° 1087 ; 14 janv. 1998, n° 96-14.482, Bull. civ. III, n° 5 ; 24 janv. 2001, BPIM 2/01, inf. 11 ; 4 avr. 2001, n° 99-17.142 ; *contra* : Civ. 3e, 18 déc. 1996, n° 94-20.066, qui semblent retenir la date de l'arrêt, mais ces arrêts sont accidentels), ce qui assigne une portée limitée à « l'acte juridique » de réception, puisque la décision du juge est alors déclarative et non constitutive de droit. Le juge se borne à constater l'état d'achèvement qui permet de prononcer la réception et à tenir compte d'un *fait* selon la description que lui en fournit généralement l'expert.

ACTUALISATION

459 s. Conditions de mise en œuvre de la réception judiciaire. - Au visa de l'article 1792-6 du code civil, la Cour de cassation met fin à une jurisprudence fluctuante en précisant quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande de réception judiciaire. Pour la Cour, il n'y en a que deux : l'absence de réception amiable et l'existence de travaux en état d'être reçus (Civ. 3e, 12 oct. 2017, no 15-27.802, Dalloz actualité, 8 nov. 2017, obs. Garcia).

460. Portée. - Cette observation de bon sens limite la valeur de l'analyse qui fait de la réception un acte juridique et affaiblit la théorie de la réception tacite (V. *supra,* no 456). La réception judiciaire qui peut être prononcée à titre principal, peut l'être aussi à titre incident, dans le cadre d'un contentieux relatif aux garanties ou à l'assurance. Peut-être sera-t-il alors soutenu qu'il y a « eu » réception tacite. Mais cette réception ne sera reconnue comme telle que si le juge le dit ; or, il lui suffira de constater que l'immeuble était en état d'être reçu à la date indiquée. Il est même permis de penser que la constatation judiciaire de la réception pourrait être faite par le juge des référés, car on voit mal quelle contestation sérieuse pourrait s'opposer à la prise en compte d'un simple état de fait (V. en ce sens : Versailles, 20 déc. 1985, cité *in* RDI 1986. 363, obs. Malinvaud et Boubli ; sur ces questions : BOUBLI, *op. cit.,* nos 252 s.). Comme elle le fait pour la réception tacite, la jurisprudence admet d'ailleurs que la réception judiciaire peut être assortie de réserves (Civ. 3e, 30 oct. 1991, préc. ; 19 juin 1996, BPIM 5/96, no 350). Il semble qu'elle puisse être prononcée par le juge des référés (Versailles, 20 déc. 1985, préc.), mais cela peut se discuter. *Le juge qui prononce la réception judiciaire en fixe la date* pour que les garanties et l'assurance puissent éventuellement être mises en œuvre (Civ. 3e, 17 sept. 2014, no 13-22.536, BPIM 6/14, inf. 388) ; mais cet intérêt est peut-être plus théorique que réel (V. BOUBLI, note sous Civ. 3e, 25 mars 2015, no 14-12.875, préc., RDI 2015. 298).

§ 4 - Assistance de l'architecte

461. Rôle. - La réception ne peut émaner en principe que du maître de l'ouvrage. L'approbation donnée en ses lieu et place par l'architecte serait sans effet (Civ. 3e, 17 févr. 1982, Bull. civ. III, no 49), sauf s'il avait reçu *mandat* de son client à cette fin. Toutefois, conformément à l'article 1998 du code civil, la ratification donnée postérieurement par le maître, qui peut résulter de l'acceptation sans réserve du procès-verbal de réception lors de sa présence, rétroagirait au jour de l'approbation donnée par l'architecte (Civ. 3e, 23 avr. 1970, Bull. civ. III, no 266). La mission normale de l'architecte est cependant *d'assister le maître de l'ouvrage* au moment de la réception : il doit notamment attirer l'attention de son client sur certains désordres et l'inciter, le cas échéant, à refuser de réceptionner ou à formuler des *réserves.* La Cour

de cassation estime que l'architecte commet une faute s'il ne remplit pas correctement cette mission de conseil : sa responsabilité est alors engagée selon le droit commun (désordres procédant de vices ou de défauts de conformité apparents non signalés : Civ. 3e, 16 déc. 1970, Bull. civ. III, n° 701 ; Civ. 3e, 12 oct. 1978, RDI 1979. 68, obs. Malinvaud et Boubli ; 9 janv. 1980, JCP 1980. IV. 112 ; 4 juin 1986, Mon. TP 1er avr. 1986 ; 9 janv. 1991, n° 89-12.706, Bull. civ. III, n° 10 ; CE 26 oct. 1990, RDI 1991. 54 ; comp. Civ. 3e, 7 juin 1978, D. 1978. IR 502 ; 3 mai 1978, RDI 1979. 68 ; V. Civ. 3e, 20 juill. 1988, JCP 1988. IV. 351 ; 9 janv. 2002, RDI 2002. 153 ; conseil donné au maître de l'ouvrage sur les conséquences d'une absence de réserves : Civ. 3e, 30 oct. 1991, n° 90-12.993, Bull. civ. III, n° 250, ou sur les conséquences d'une prise de possession valant réception selon le contrat : Civ. 3e, 26 juin 2001, BPIM 4/01, n° 255 ; omission de faire mentionner au PV de réception des réserves exprimées lors d'une préréception : Civ. 3e, 3 févr. 1999, n° 97-13.427, Bull. civ. III, n° 27 ; 27 juin 2001, n° 00-10.153, *ibid.* III, n° 82, Defrénois 2002. 56, obs. Périnet-Marquet). Sa responsabilité est encourue même si le maître de l'ouvrage peut déceler le désordre (Civ. 3e, 19 avr. 1989, RGAT 1989. 617, obs. d'Hauteville ; comp. Civ. 3e, 12 mars 1986, JCP 1986. IV. 145 ; solution plus modulée dans le contentieux administratif : CE 14 mai 1986, Mon. TP 8 août 1986). Toutefois, il semble qu'un arrêt annonce plus de souplesse sur ce dernier point. Il décide que la faute de l'architecte, qui n'a pas invité un maître d'ouvrage à faire des réserves, n'est pas la cause du préjudice subi par ce dernier, promoteur professionnel qui ne peut ignorer les conséquences juridiques d'une absence de réserves (Civ. 3e, 27 sept. 2000, BPIM 1/01, n° 39).

462. Portée. - Cette jurisprudence, sévère pour l'architecte, mériterait d'être nuancée. En effet, sauf dans le CCMI où il peut recevoir une mission d'assistance à la réception, distincte de la maîtrise d'œuvre (CCH, art. L. 231-2 et L. 232-11), l'architecte intervient dans le marché de travaux en tant que maître d'œuvre. Il engage alors sa responsabilité décennale ou biennale, si les conditions de celle-ci sont réunies. Cette responsabilité suppose que le désordre soit caché à la réception. Or, le caractère apparent ou caché d'un tel dommage s'apprécie en tenant compte de la compétence *du maître de l'ouvrage* (Civ. 3e, 17 nov. 1993, RDI 1994. 53). Dès lors, on ne voit pas quel intérêt il y a à reprocher à l'architecte de n'avoir pas conseillé au maître de l'ouvrage d'exprimer des réserves, si le désordre est caché pour ce dernier. L'intérêt se limite au cas où l'absence de réserve purgerait l'ouvrage de ses vices, c'est-à-dire si le désordre est apparent compte tenu de la compétence du maître de l'ouvrage, et que l'architecte n'invite pas ce dernier à exprimer des réserves. Encore faut-il, depuis l'arrêt du 27 septembre 2000 précité, réserver le cas du maître d'ouvrage notoirement compétent.

Art. 4 - Effets de la réception

463. La réception sert de point de départ aux différentes garanties (V. *infra,* n°s 464 s.), et elle infuence la charge finale des risques (V. *infra,* n°s 467 s.).

§ 1er - Point de départ des garanties

464. Avant 1978. - En l'état d'une réception prononcée, la Cour de cassation, sous l'empire des *dispositions antérieures à la loi du 4 janvier 1978,* a posé plusieurs règles : 1° la réception avec réserves n'est pas une approbation, un *quitus.* Il en est notamment ainsi lorsqu'il s'agit d'une réception provisoire : assortie de réserves, elle ne fait pas courir le délai de garantie décennale, qu'il s'agisse d'ouvrages antérieurs (Civ. 1re, 16 juill. 1964, D. 1965. somm. 32. – Civ. 3e, 6 févr. 1973, Bull. civ. III, n° 90 ; 5 juin 1973, D. 1973. IR 199) ou postérieurs à la loi du 3 janvier 1967 (Civ. 3e, 24 mars 1982, Bull. civ. III, n° 80 ; 15 oct. 1985, *ibid.* III, n° 121 ; CE 21 févr. 1986, Mon. TP 31 oct. 1986) ; 2° une approbation sans réserves constitue toujours une réception et fait courir les délais de garantie, même si la réception est qualifiée de provisoire (Civ. 3e, 9 janv. 1969, Bull. civ. III, n° 29 ; 8 mai 1969, D. 1969. 653 ; 10 oct. 1969, Bull. civ. III, n° 639 ; 15 févr. 1989, RGAT 1989. 379 ; 4 juill. 1990, Bull. civ. III, n° 163, RDI 1991. 65) ; 3° la réception sert de point de départ aux délais de garantie concernant tous les locateurs d'ouvrage (Civ. 3e, 25 juin 1974, Bull. civ. III, n° 262), et si une convention passée avec l'un d'eux fixe un point de départ plus favorable, les autres constructeurs peuvent en bénéficier (CE 25 avr. 1969, D. 1969. 498, note F. Moderne ; V. J. CHANET, Responsabilité entre techniciens du bâtiment, Gaz. Pal. 1969. 1. Doctr. 99 ; comp. CE 2 avr. 1993, Ville de Bastia, RDI 1993. 383). Il faut signaler toutefois un arrêt qui va à l'encontre de cette jurisprudence : s'inspirant des conventions des parties, il admet que le point de départ des garanties peut être fixé à la réception provisoire des travaux pour l'entrepreneur et à la réception définitive pour l'architecte (Civ. 3e, 3 avr. 1979, RDI 1980. 66, obs. P. Malinvaud et B. Boubli).

ACTUALISATION

464, 569. Date de la réception en cas d'autoconstruction et point de départ du délai de la garantie décennale. - Lorsque le vendeur est le constructeur, fait courir le délai de la garantie décennale, la date à laquelle l'ouvrage est utilisable et propre à sa fonction (Civ. 3e, 19 janv. 2017, n° 15-27.068 , Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. Dreveau).

465. Depuis 1978. - *Avec la loi du 4 janvier 1978,* toutes les garanties courent à compter de la réception (Civ. 3e, 4 oct. 2000, BPIM 6/00, n° 371 ; 20 juin 2001, BPIM 4/01, n° 258 ; 16 oct. 2002, n° 01-10.330, Bull. civ. III, n° 205) qui est unique dans le nouveau texte (art. 1792-6 et 2270 nouv.) et concerne tous les constructeurs (CE 2 avr. 1993, Ville de Bastia, RDI 1993. 383), au moins lorsque la réception a lieu tous corps d'état. En revanche, il semblerait que les réceptions par corps d'état séparés pourraient donner lieu à des garanties dont le point de départ serait variable pour les entrepreneurs et l'architecte (Civ. 3e, 3 avr. 1979, RDI 1980. 66 ; CE 23 nov. 1985, Le Moniteur 4 avr. 1986). Mais l'incertitude demeure néanmoins pour les désordres ayant donné lieu à des réserves. D'après la loi, ces malfaçons relèvent de la garantie de parfait achèvement. Il n'empêche que la réparation peut intervenir plusieurs mois après la constatation des dommages : faire courir le délai à compter de la réception dans ce cas, c'est amputer la garantie de la durée des réparations et, pratiquement, la réduire à peu de chose lorsque le désordre relève de la garantie biennale. Il est vraisemblable que, pour ces réparations, il y a lieu, comme pour les autres, à un nouveau constat (une réception ?) qui fait courir de nouveaux délais (V. Civ. 3e, 17 mai 1995, n° 93-16.568, Bull. civ. III, n° 120). C'est en tout cas plus que probable lorsque les travaux de reprise émanent d'un entrepreneur substitué au garant (V. *infra,* nos 454 et 457). La Cour de cassation, tout en posant que le délai de la garantie court à compter de la réception avec ou sans réserves, considère que, pour les malfaçons réservées, la responsabilité contractuelle est prolongée (Civ. 3e, 16 oct. 2002, n° 01-10.330, Bull. civ. III, n° 205, arrêt n° 2, D. 2003. 300, obs. P. Malinvaud, qui pose un principe général).

466. Effet de purge. - La réception purge l'ouvrage de ses vices ou défauts apparents (Civ. 3e, 3 déc. 1997, RDI 1998. 95 ; 12 sept. 2006, BPIM 6/06, inf. 431). Les défauts apparents non réservés ne sont donc pas, en principe, source de responsabilité ; encore faut-il que le maître de l'ouvrage ait pu les déceler (Civ. 3e, 21 juin 2005, RDI 2005. 443 ; 21 juill. 2007, BPIM 6/99, inf. 428). Quant aux désordres réservés, ils relèvent de la garantie de parfait achèvement. On peut donc poser que c'est la réception avec ou sans réserves qui sert de point de départ aux garanties. En revanche, et contrairement à ce qui est souvent encore enseigné, la réception n'a ni *effet extinctif,* ni *effet exonératoire :* elle *n'a pas d'effet extinctif* puisque les travaux ne sont pas achevés à la réception et qu'ils doivent être exécutés pour que l'ouvrage soit livré : l'obligation d'achever survit à la réception (V. *supra,* n° 448) ; elle *n'a pas d'effet exonératoire* : non seulement la responsabilité légale s'applique, une fois la réception prononcée, mais la responsabilité contractuelle de droit commun persiste (V. *infra,* nos 510 s. et 645 s.).

§ 2 - Charge des risques

467. La charge des risques liés à la construction de l'ouvrage sont différents selon que l'on se trouve avant la réception (V. *infra,* n°s 468 s.) ou après elle (V. *infra,* n°s 472 s.), cependant il est possible d'en prévoir une répartition conventionnelle (V. *infra,* n° 473).

A - Avant la réception

468. Textes. - Les articles 1788 à 1791 règlent l'attribution des risques dans les devis et marchés. Lorsque l'ouvrage est détruit par force majeure, le *maître qui fournit la matière* supporte seul les risques. L'ouvrier (lire l'entrepreneur) n'est tenu que de sa faute (Civ. 3e, 22 avr. 1971, AJPI 1972. 626 ; 10 janv. 1979, RDI 1979. 341, obs. Malinvaud et Boubli ; comp. CE 2 juill. 1975, D. 1976. 228, note J. Mazeaud. – Civ. 1re, 11 janv. 1978, Bull. civ. I, n° 15. – Civ. 3e, 17 févr. 1999, Bull. civ. III, n° 41, CCC 1999, n° 67, RTD civ. 1999. 629, obs. Jourdain). Si la chose périt sans la faute du locateur avant la réception, et sauf vice de la matière, l'entrepreneur perd cependant sa rémunération (art. 1789 et 1790). C'est à l'entrepreneur d'établir que la chose a péri sans qu'il n'ait commis de faute. Cette solution est admise dans l'entreprise de chose mobilière (Civ. 1re, 9 févr. 1966, Bull. civ. I, n° 103 ; 23 avr. 1987, Bull. civ. I, n° 106). Elle a été adoptée dans un marché de prestation de services impliquant des travaux d'aménagement (Civ. 3e, 17 févr. 1999, n° 95-21.018, Bull. civ. III, n° 41). On peut se demander si, en cas de *dommages aux existants,* l'article 1789 ne devrait pas s'appliquer, car alors l'entrepreneur ne fournit pas la matière (V. Civ. 3e, 9 oct. 1991, n° 90-12.059, Bull. civ. III, n° 234. – Civ. 2e, 26 mai 1992, n° 91-11.149, Bull. civ. II, n° 154. – Civ. 3e, 28 oct. 1992, n° 90-16.726, Bull. civ. III, n° 281 ; comp. : Civ. 1re, 3 nov. 1993, RDI 1994. 251, obs. P. Malinvaud et B. Boubli. – Bordeaux, 8 févr. 2000, D. 2001. 804, note Malinvaud. – Civ. 3e, 15 nov. 1995, n° 94-12.100, Bull. civ. III, n° 234 ; 7 juill. 2004, n° 02-21.290). Lorsque le *locateur fournit la matière,* tous les risques sont en principe à sa charge (art. 1788) si la chose n'est pas encore livrée, à moins que le maître ne soit en demeure de la recevoir. Ce texte ne concerne que la charge des risques (Civ. 3e, 23 avr. 1974, D. 1974. IR 188, obs. J. Mazeaud). Il ne s'applique pas lorsque la responsabilité de l'un des contractants est en cause en raison de sa faute (Civ. 1re, 2 déc. 1997, n° 95-19.466, Bull. civ. I, n° 339).

469. Interprétation. - On a soutenu que l'article 1788 ne pouvait s'appliquer à l'entreprise de travaux immobiliers. Si avant leur incorporation à la chose, les matériaux approvisionnés par l'entrepreneur restent sa propriété (Com. 20 févr. 1962, Bull. civ. IV, n° 114), ils appartiennent au maître dès leur incorporation par voie d'accession. Or, du moment que la chose devient la propriété du maître, l'entrepreneur ne fournit plus que son travail, et il n'est plus tenu que de sa faute, aux conditions précisées par les articles

1789 et 1790 (Req. 13 août 1860, DP 1861. 1. 105 ; 19 juill. 1870, DP 1872. 1.18 ; comp. RODIÈRE, *op. cit.,* n° 199). L'attribution des risques doit se faire alors par application de l'adage *res perit domino.* C'est le propriétaire de la chose, donc le maître de l'ouvrage qui doit en répondre.

470. Cette interprétation ne résiste pas à l'analyse (V. BOUBLI, La responsabilité et l'assurance des architectes entrepreneurs et autres locateur d'ouvrage, *op. cit.,* n° 286 ; BERTRAND, L'opposabilité des contrats aux tiers, thèse, Paris II, 1979 ; V. surtout : MARTY et RAYNAUD, *op. cit.,* t. 2, 1er vol., n° 289). Rien ne permet d'affirmer que l'article 1788 ne s'applique qu'à l'entreprise de choses mobilières. Le texte est placé à la section des « Devis et marchés » qui ne comporte aucune disposition permettant de justifier la restriction. De plus, l'opposition apparente entre l'adage *res perit domino* (le principe est inscrit dans l'art. 1138) et la règle énoncée par l'article 1788 n'est pas irréductible. L'article 1138 règle la charge des risques dans les contrats portant obligation de donner, dont l'obligation de livrer n'est que l'accessoire : il sanctionne une livraison différée par le maître. Au contraire, l'obligation de livrer est l'obligation majeure de l'entrepreneur ; il est donc légitime que celui-ci supporte seul les risques de la chose avant la livraison. L'article 1788 régit alors un cas n'entrant pas dans les prévisions de l'article 1138 : *en matière d'entreprise, la charge des risques est indépendante de la propriété* (V. BOUBLI, *op.* et *loc. cit.* ; MARTY et RAYNAUD, *op.* et *loc. cit.*).

471. Jurisprudence. - La jurisprudence est en ce sens. Les tribunaux administratifs admettent sans restriction que « la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit […] avant la réception provisoire » est pour l'entrepreneur (CE 25 janv. 1971, Lebon 482 ; 17 mars 1976, *ibid.,* p. 166 ; 9 nov. 1984 et 18 janv. 1985, Mon. TP 18 oct. 1985 ; comp. CE 9 mars 1990, Mon. TP 7 déc. 1990). Les juridictions judiciaires, quoique parfois moins catégoriques, admettent la même solution dès lors que l'entrepreneur fournit la matière (Req. 11 mars 1939, Jur. gén., *V°* Louage d'ouvrage, n° 127 ; 4 janv. 1888, DP 1889. 1. 211 ; 1er août 1929, S. 1930. 1. 175. – Crim. 16 févr. 1934, DH 1934. 183. – Civ. 3e, 9 mai 1972, Bull. civ. III, n° 293 ; 23 avr. 1974, D. 1975. 287, note J. Mazeaud, rejet du pourvoi formé contre Lyon ; 21 nov. 1972, D. 1973. Somm. 25 ; 27 janv. 1976, D. 1976. Somm. 30 ; 19 févr. 1986, Bull. civ. III, n° 10 ; 15 juin 1988, *ibid.* III, n° 112 ; 27 mars 1991, n° 89-19.498, Bull. civ. III, n° 103 ; 26 janv. 2005 n° 03-14.765. – Civ. 3e, 17 déc. 2014 n° 13-17.485, BPIM 1/15, inf. 31. – Comp. Civ. 12 oct. 1976, Ciceron ; *contra* : les arrêts cités *supra,* n° 367 ; V. égal. Com. 24 oct. 1960, Bull. civ. IV, n° 332 et Civ. 1re, 20 avr. 1966, Bull. civ. I, n° 223. – Aix-en-Provence, 12 déc. 1983, RDI 1985. 157 ; V. sur la question : AUBRY et RAU, *op. cit.,* § 374-1° ; BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, t. 2, nos 3903, 3910 s. ; ROUAST, *op. cit.,* n° 926, note 3 ; LIET-VEAUX, La profession d'architecte, n° 594 ; CASTON, *op. cit.,* nos 328 s. ; notes anonymes au DP 1861. 1. 105, 72.1.18 et sous Lyon, 21 nov. 1972,

D. 1973. Somm. 25). L'entrepreneur n'est alors tenu que de procurer la chose qu'il s'était engagé à fournir. L'offre de rembourser le coût de la reconstruction selon les conditions du marché initial est dès lors satisfactoire (Civ. 3e, 28 oct. 1992, n° 90-16.726, Bull. civ. III, n° 281). L'article 1788 ne s'applique pas lorsque la chose détruite n'est pas la chose fournie (Civ. 3e, 12 oct. 1971, Bull. civ. III, n° 482 ; 14 juin 1983, Bull. civ. III, n° 138).

B - Après la réception

472. Transfert des risques. - Après la réception ou après la mise en demeure, les risques de la chose passent au maître de l'ouvrage. Aucun problème si la réception est unique et amiable. Que décider en revanche lorsqu'il n'en est pas ainsi ? Il ne semble pas qu'il faille s'attarder sur le cas de la double réception, puisque la jurisprudence n'accorde qu'un crédit relatif à la distinction entre réception définitive et réception provisoire qui est d'ailleurs condamnée depuis la loi du 4 janvier 1978. Mais quelle solution adopter lorsque la *réception est assortie de réserves* ? Pour satisfaire aux réserves, l'entrepreneur ne conserve-t-il pas la maîtrise des travaux, et n'est-ce pas lui qui fournit les matériaux ? Les conditions d'application de l'article 1788 paraissent réunies tant que les parties d'ouvrage qui font l'objet de réfections n'ont pas été livrées. Quelle attitude avoir, surtout en cas de *réception judiciaire* ? L'article 1788 prévoit le transfert des risques dès que le maître a été mis en demeure de recevoir la chose. Cela signifie-t-il que ce transfert est indépendant de l'acceptation du maître de l'ouvrage, donc de la *réception* au sens que lui donne la doctrine dominante ? Il est permis de le penser. La solution est peut-être de décider que la mise en demeure mettrait la chose aux risques du maître sous réserve de l'appréciation du juge ; mais il est vrai que si la chose périt avant que celui-ci se prononce, on ne saura jamais si le refus du maître était ou non justifié…

C - Répartition conventionnelle de la charge des risques

473. Accord. - Les parties peuvent répartir la charge des risques par convention. Ainsi, la norme AFNOR p. 03-011 (art. 05.02) prévoit la mise des risques à la charge du maître sauf pour les matériaux non encore utilisés, tandis que la norme p. 03-001 de 1972 (art. 05.14) les fait supporter à l'entrepreneur. La norme p. 03-001 de 1989 paraît transposer les risques au maître de l'ouvrage avant réception. Son article 20.2.2 prévoit l'indemnisation de l'entrepreneur en cas de résiliation du marché consécutive à la force majeure. Le barème des architectes prévoyait également un partage des risques, une fraction des honoraires restant due en cas d'interruption des travaux par force majeure (Civ. 3e, 4 oct. 1973, Bull. civ. III, n° 506). La norme AFNOR de décembre 2000 ne fait pas mention de la charge des risques.

Section 4 - Garantie de parfait achèvement

474. Originalité de la notion. - Création de la loi du 4 janvier 1978 (C. civ., art. 1792-6), la garantie de parfait achèvement est la meilleure illustration de l'emprise de la pratique sur le droit de la construction. Inspirée de la norme AFNOR p. 03-001, à laquelle les parties avaient la possibilité de se référer avant l'entrée en vigueur de la loi, elle est une source de confusion, qui, non seulement n'améliore pas, sur le plan pratique, la situation du maître de l'ouvrage, mais contribue sur le plan juridique à compliquer un système dont la clarté n'est pourtant pas la vertu majeure (V. *infra,* n°s 476 s.).

475. L'association des termes « achèvement » et « parfait » laisse perplexe. Ainsi, il existerait des achèvements imparfaits ? L'achèvement n'est-il pas cependant l'état de ce qui est fini, accompli, et par définition parfait ? Plus grave, l'institution d'une garantie de « parfait achèvement » dans la construction immobilière peut donner à penser que, dans les autres contrats de louage d'ouvrage où la loi ne dit rien, une telle garantie n'existe pas et que l'ouvrage réalisé par le locateur peut être « imparfaitement achevé » et cependant le libérer de sa dette… Or, les contrats « doivent être exécutées de bonne foi » (C. civ., anc. art. 1134 devenu nouv. art. 1104) ils obligent non seulement « à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité, l'usage ou la loi » (C. civ., nouv. art. 1194 qui reprend en partie l'anc. art. 1135) ce qui suffit à obliger le débiteur à l'exécution parfaite de ses engagements(V. *infra,* n°s 499 s.). Il allait de soi, dès avant 1978, que le constructeur livrant une chose inachevée n'était pas libéré de sa dette ; qu'il devait remédier aux désordres signalés ou immédiats et achever le travail. Point n'était besoin de le dire en une formule qui révèle que ce qui est normal doit être dit aujourd'hui, et explique, beaucoup mieux que de longs discours, l'équivoque entretenue en jurisprudence entre conformité (qui relève de la délivrance) et désordre (qui relève de la garantie) (V. *infra,* n°s 481 s.). On verra d'ailleurs que sur le plan pratique, il faut faire preuve d'un réel optimisme pour attendre, d'une obligation de parfait achèvement qui n'a pas de sanction spécifique, qu'elle conduise à une réparation rapide des sinistres (Civ. 3e, 17 juill. 1992, RDI 1993. 81). La garantie de parfait achèvement a vocation à s'appliquer aux marchés publics. L'article 44-1 du CCAG modifié le 3 mars 2014 introduit une garantie d'achèvement qui permet de s'assurer que l'ouvrage répond aux spécifications du contrat et que l'opération est effectuée selon les règles de l'art. Cette garantie est de « type contractuel » (H. de GAUDEMAR, *in* RDI 2015. 81). Selon la jurisprudence, elle relève de la même cause que la responsabilité contractuelle et peut être invoquée pour la première fois en appel lorsque la responsabilité contractuelle a été invoquée devant le premier juge (CE 9 juill. 2010, *Cne de Lorry-lès-Metz,* req. n° 310032, BPIM 5/10, inf. 375).

Art. 1er - Fonction de la garantie

476. Ordre public. - La loi du 4 janvier 1978 fait peser sur l'entrepreneur une garantie de parfait achèvement des désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit lors de la réception, soit, s'ils apparaissent dans l'année qui la suit, au cours de ce délai (C. civ., art. 1792-6). La garantie s'inspire des clauses de parachèvement contenues dans certains marchés, spécialement les marchés publics, à l'époque de la double réception. Leur objectif était d'assurer au maître de l'ouvrage la livraison d'un ouvrage aussi correct que possible au terme du délai de parachèvement. *La garantie a un caractère d'ordre public* : aucune clause ne peut exonérer le débiteur ou limiter la garantie (art. 1792-5). Elle a théoriquement pour fonction de favoriser la réparation en nature rapide des désordres, par la fixation de délais relativement courts et la désignation d'un débiteur précisément identifié.

§ 1er - Débiteur de la garantie

477. La garantie de parfait achèvement impose à l'entrepreneur de réparer tous les désordres (V. *infra,* n° 478), ce qui invite à déterminer quel est l'entrepreneur concerné (V. *infra,* n° 479).

A - Entrepreneur

478. À la différence des garanties décennale et biennale, la garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur, à l'exclusion des autres intervenants (art. 1792-6, al. 2. – Civ. 3e, 7 juill. 2004, n° 03-11.248). L'entrepreneur s'entend de celui qui est lié au maître de l'ouvrage par un louage d'ouvrage (art. 1792-6, al. 3), ayant pour objet la réalisation d'ouvrages de construction immobilière. Sont assimilés à l'entrepreneur le constructeur de maison individuelle, au sens des articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, et le promoteur immobilier s'il exécute lui-même une partie du programme. Le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3e, 30 mars 1994, n° 92-17.225 , Bull. civ. III, n° 69).

B - Entrepreneur concerné

479. Désignation. - L'entrepreneur garant étant normalement celui qui s'est lié au maître de l'ouvrage, la détermination de l'entrepreneur concerné dépend du processus de réalisation : lorsque le marché est exécuté par corps d'état séparés, la garantie est

due par chaque entrepreneur dans la limite du lot qui lui est attribué. Si les entreprises sont groupées dans un GME, la solidarité résultant des règles applicables au groupement peut avoir pour effet de faire supporter l'intégralité de la garantie à chacun des membres du GME ; mais, sauf si l'acte d'engagement le précise, cette éventualité est discutée, car la solidarité porte en général sur l'exécution du marché, non sur les garanties qu'il génère ; lorsque le marché est conclu tous corps d'état, l'entrepreneur concerné est l'entrepreneur principal, qu'il sous-traite ou non. Le sous-traitant n'a pas de lien de droit avec le maître de l'ouvrage dont il n'est pas le contractant. Il n'est donc pas personnellement tenu de la garantie. Mais l'entrepreneur principal est garant du fait de son sous-traitant et il répond de la garantie de parfait achèvement comme s'il avait exécuté lui-même les travaux.

§ 2 - Nature de la garantie

480. Notion de garant. - L'entrepreneur est présenté comme un garant qui n'est toutefois pas une caution même s'il peut lui ressembler puisqu'il prend provisoirement en charge des dommages qui peuvent être imputés après expertise à un autre constructeur : il ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion ou de division. La garantie trouve son fondement dans l'ordre de la responsabilité contractuelle (V. *supra,* n° 475) : le garant se trouve dans la situation d'une personne tenue de payer pour autrui (V. C. civ., nouv. art. 1342-1) ; débiteur de premier rang, il lui est permis de se retourner contre les autres constructeurs auxquels le dommage est effectivement imputé. L'entrepreneur joue un rôle qui le fait ressembler à un assureur pendant la garantie de parfait achèvement. Peu importe la cause du dommage ; peu importe qu'elle lui soit étrangère ; réserve étant faite du cas où les conditions de la force majeure sont réunies, il répond du fait d'autrui comme de son propre fait et il se comporte comme un assureur de la chose. On remarque d'ailleurs que, pendant la garantie de parfait achèvement d'un an, l'assurance dommage obligatoire a un caractère subsidiaire. Mais si en fait l'entrepreneur ressemble à un assureur, il n'en est pas un. La loi n'a pas institué une véritable assurance, mais une garantie qui s'ajoute aux responsabilités décennale, biennale ou de droit commun.

Art. 2 - Domaine d'application de la garantie

481. L'article 1792-6, alinéa 2, précise que la garantie s'étend « à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés après la réception ». Il convient de distinguer les désordres proprement

dits (V. *infra,* n°s 482 s.), des défauts de conformité (V. *infra,* n°s 488 s.) et des défauts dans l'isolation phonique (V. *infra,* n°s 494 s.).

§ 1er - Désordres proprement dits

482. Les désordres peuvent être apparents (V. *infra,* n° 483) ou apparaître après la réception des travaux (V. *infra,* n° 484), certains cas sont particuliers et dont le régime va dépendre des réserves qui auront pu être faites (V. *infra,* n°s 485 s.).

A - Désordres apparents ayant fait l'objet de réserves

483. Les désordres apparents qui ont donné lieu à des réserves au procès-verbal de réception, ne posent pas de problème de constatation et relèvent de la garantie (Civ. 3e, 29 avr. 1987, Bull. civ. III, n° 89. – Civ. 3e, 17 juill. 1992, n° 90-14.367, Bull. civ. III, n° 250). Leur degré de gravité est indifférent (Civ. 3e, 10 avr. 1996, BPIM 4/96, n° 273).

B - Désordres apparus dans l'année de la réception

484. Les désordres qui apparaissent dans l'année de la réception relèvent de la garantie s'ils ont été signalés au maître de l'ouvrage par voie de notification écrite : la notion de « notification » implique l'utilisation du courrier recommandé avec accusé de réception ; il semble que la notification doive, à peine de forclusion, intervenir dans l'année de la garantie (Civ. 3e, 15 janv. 1997, n° 95-10.097, Bull. civ. III, n° 12 ; 6 mai 1998, n° 96-18.038, Bull. civ. III, n° 90). Dans les marchés publics, la garantie de parfait achèvement peut être prolongée (CAA Nantes, 9 juill. 1997, req. n° 92NT00133, Sté Nord-France Entreprise. – Rappr. : CE 17 juin 2015, Sté des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, req. n° 383203, BPIM 5/15, inf. 254).

ACTUALISATION

484. Garantie de parfait achèvement : obligation de notification des désordres avant l'assignation. - En l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies (Civ. 3e, 15 avr. 2021, n° 19-25.748, D. actu. 6 mai 2021, obs. C. Dreveau).

C - Cas particuliers

485. Les désordres apparents et non réservés à la réception échappent à la garantie de parfait achèvement : à leur égard, la réception produit un effet de purge (Civ. 3e, 21 juin 2000, BPIM 5/00, n° 326) :

486. Le *désordre réservé à la réception,* qui n'est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, peut relever de la garantie décennale (Civ. 3e, 12 oct. 1994, n° 92-17.922, Bull. civ. III, n° 172 ; 28 févr. 1996, RDI 1996. 217 ; 23 avr. 1997, RDI 1997. 448. – Paris, 17 janv. 2001, RDI 2001. 253). Il relève aussi de la garantie de parfait achèvement puisqu'il a donné lieu à des réserves.

487. Le *désordre apparent non réservé à la réception,* qui n'est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, relève de la garantie décennale (Civ. 3e, 27 avr. 1977, Bull. civ. III, n° 178 ; 17 nov. 1999, BPIM 1/00, n° 30 ; 11 févr. 1998, RDI 1998. 260, sol. impl.). Lorsque ces conséquences ne se sont pas manifestées dans l'année, il y a tout lieu de penser que la garantie de parfait achèvement ne peut être mise en œuvre, la réception sans réserve produisant son effet de purge ; mais si par impossible le sinistre se produit pendant la période de garantie, il devrait être couvert par celle-ci, car il est alors censé procéder d'un désordre caché.

§ 2 - Défauts de conformité

488. Les défauts de conformité ne sont pas des vices. Ils relèvent néanmoins de la garantie de parfait achèvement, mais ils sont susceptibles d'entrer aussi, soit dans le champ d'application des garanties décennale ou biennale, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun. La distinction entre ce qui est apparent et ce qui est caché à la réception, posée en termes généraux par l'article 1792-6, s'applique aux défauts de conformité : les défauts apparents doivent faire l'objet de réserves (Civ. 3e, 9 oct. 1991, n° 87-18.226, *ibid.* III, n° 231 ; 30 mars 1994, n° 92-17.225, *ibid.* III, n° 69 ; 22 mai 1997, n° 852 D). Les défauts cachés doivent se révéler dans l'année et être signalés comme les désordres proprement dits. Il existe une différence entre les défauts résultant de l'inachèvement (V. *infra,* nos 493 s.) et ceux qui résultent d'une exécution différente (V. *infra,* nos 489 s.).

A - Non-conformité résultant d'une exécution différente

489. L'ouvrage est exécuté, mais il n'est pas conforme à certaines références. Plusieurs situations sont possibles :

490. 1° Non-conformité aux règles de l'art de bâtir ou aux normes techniques (DTU) - Ce sont en réalité des désordres, car il y a malfaçon. En pratique, on les traite comme tels pour les besoins du parfait achèvement. Tel est d'ailleurs le cas du défaut d'isolation phonique qui rend l'immeuble impropre à sa destination lorsque la norme d'isolation n'est pas respectée. La méconnaissance des DTU ne peut être invoquée que si le DTU a été contractualisé (V. *infra,* n° 492).

491. 2° Non-conformité aux prescriptions légales publiques ou privées. - Il s'agit d'une violation des règles d'urbanisme ou des servitudes publiques ou privées. Ce sont des dommages assimilables à des désordres, car ils exposent le maître de l'ouvrage à rétablir la conformité aux normes et, le plus souvent, à une démolition au moins partielle de l'ouvrage.

492. 3° Non-conformité aux documents contractuels. - Cette non-conformité est constitutive d'un désordre lorsque l'inobservation des documents contractuels entraîne cette conséquence : non-respect du devis entraînant un défaut d'étanchéité (Civ. 3e, 13 avr. 1988, Bull. civ. III, n° 67 ; V. aussi : Civ. 3e, 25 janv. 1989, Bull. civ. III, n° 20 ; 3 févr. 1993, RDI 1993. 239) ; la violation du DTU n'est à prendre en considération que si le document est visé par le marché (Civ. 3e, 27 févr. 2001, RDI 2001. 175). La non-conformité est une simple violation des règles du contrat lorsqu'elle n'entraîne pas la conséquence ci-dessus : construction d'un mur de 1,90 mètre, contre un mur de 2 mètres prévu au contrat : elle relève néanmoins de la garantie ; même solution lorsque le contrat exige un niveau d'isolation phonique supérieur à celui prescrit par les normes et que ce niveau n'est pas atteint, que les ouvrages exécutés ne présentent pas les caractéristiques convenues (Civ. 3e, 20 nov. 2007, n° 06-18.757), ou que des non-façons non constitutives de désordre sont constatées (Civ. 3e, 24 mars 2009, n° 08-16.460 ; rappr. : Civ. 3e, 11 févr. 2009, n° 07-19.410, à propos d'une absence d'ouvrage résultant des prévisions insuffisantes du constructeur).

ACTUALISATION

492. Absence de mise en conformité en cas de violation d'un DTU sans désordre. - Il résulte de la combinaison des article 1134 et 1240 du code civil qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20-15.277, D. actu. 24 juin 2021, obs. G. Casu et A. Cottin).

B - Non-conformité résultant de l'inachèvement

493. Depuis l'arrêt du 12 juillet 1989 (Bull. civ. III, n° 161), maintes fois confirmé (Civ. 3e, 9 oct. 1991, n° 87-18.226, Bull. civ. III, n° 230 ; 15 janv. 1997, RJDA 4/97, n° 587), la Cour de cassation décide que l'achèvement n'est pas une condition de la réception (V. *supra,* nos 448 s.). Il en résulte qu'à la réception, l'immeuble n'est pas achevé. La garantie de parfait achèvement court donc à compter de la réception, alors qu'à cette date, l'ouvrage est toujours en cours d'exécution. Il en résulte l'alternative suivante : ou bien l'obligation d'achever est absorbée par la garantie de parfait achèvement ; dans ce cas, il faut considérer que le contrat d'entreprise ne s'exécute que jusqu'à la réception et que ce qui reste à faire à cette date relève de la garantie ; ou bien l'obligation d'achever coexiste avec la garantie de parfait achèvement qui, alors, ne s'étend pas aux non-conformités résultant de l'inachèvement. La jurisprudence qui apprécie le retard à la date d'achèvement contractuellement fixée (Civ. 3e, 6 nov. 1996, n° 1622 D ; 21 juill. 1999, BPIM 6/99, n° 426 ; V. *supra,* n° 395), semble plutôt favorable à cette dernière interprétation, qu'elle n'a toutefois pas encore expressément consacrée. Le doute suggère la question de savoir si, à la réception, le maître de l'ouvrage doit faire état des inachèvements au procès-verbal de réception ou si, pour eux, la garantie va de soi…

§ 3 - Défauts d'isolation phonique

494. Lorsqu'un cas de défaut d'isolation phonique est constaté, il est possible de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement (V. *infra,* n° 495), qui est la solution légale mais ne joue que dans un délai d'un an (V. *infra,* n° 496), un concours est possible avec la garantie décennale (V. *infra,* n° 497) et la garantie de droit commun (V. *infra,* n° 498).

A - Principe

495. Ils relèvent de la garantie de parfait achèvement (CCH, art. L. 111-11). La loi ne fait aucune distinction selon qu'ils sont apparents ou cachés à la réception. Mais les défauts d'isolation phonique étant également susceptibles de relever de la décennale, il semble qu'ils doivent être cachés dans ce cas (sur le régime antérieur à la loi de 1978 : B. BOUBLI et DERROUCHE, RDI 1979. 437). L'insuffisance phonique est tantôt un désordre (Civ. 3e, 24 mars 2009, n° 08-16.460 ; par exemple si l'ouvrage est impropre à sa destination), tantôt une non-conformité (par exemple si le degré d'isolation requis par le contrat n'est pas atteint : Civ. 3e, 24 mars 2009, n° 08-16.460, BPIM 3/09, inf. 211).

B - Durée de la garantie

496. La garantie est limitée à un an à compter de la réception ; exceptionnellement, le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité aux exigences légales pendant un an à compter de la prise de possession (art. L. 111-11, al. 3).

C - Concours avec la garantie décennale

497. La loi de 1978 voulait faire échapper les défauts d'isolation phonique à la garantie décennale, car elle les tenait, selon le rapport « Spinetta », pour statiques. Elle n'y est pas parvenue. Quoique relevant de la garantie de parfait achèvement, ces défauts, s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination, engagent également la responsabilité décennale des constructeurs (Civ. 3e, 24 mars 1992, RDI 1992. 331 ; 3 févr. 1999, BPIM 2/99, n° 132) ; le sinistre, dans ce cas, est couvert par l'assurance dommages-ouvrage (Civ. 3e, 1er avr. 1992, n° 90-14.438, Bull. civ. III, n° 107. – Civ. 3e, 20 mai 2014, n° 14-15.107, BPIM 4/15, inf. 255). Il semble toutefois que l'ampleur du sinistre ne doit pas avoir pu être appréciée à la date de la réception (Civ. 3e, 3 févr. 1999, préc.). En revanche, le respect des normes d'isolation n'évince pas la garantie décennale si le dommage entre dans le domaine de celle-ci (Cass., ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-19.408, Bull. civ., n° 12).

D - Concours avec la responsabilité de droit commun

498. Les défauts d'isolation phonique peuvent, sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, consister en une non-conformité aux prescriptions contractuelles ; ils relèvent alors à la fois de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 20 déc. 1977, Bull. civ. III, n° 459 ; 12 juin 1979, RDI 1979. 478 ; 21 févr. 1990, n° 88-10.623, Bull. civ. III, n° 59).

Art. 3 - Régime juridique de la garantie

499. La garantie de parfait achèvement est une responsabilité objective dont tout entrepreneur partie à un marché privé de travaux est redevable (V. *infra,* nos 500 s.). Elle oblige l'entrepreneur à réparer tous les désordres réservés ou apparus pendant un

délai minimal d'un an après la réception des travaux (V. *infra,* n°s 503 s.). Elle n'est pas exclusive des autres formes de responsabilité (V. *infra,* n°s 508 s.).

§ 1er - Objet de la garantie

500. Réparation rapide. - La garantie a pour objet, et surtout pour intérêt, dans l'esprit de ses concepteurs, d'assurer une réparation en nature et rapide des malfaçons ou autres dommages relevant de son domaine, par ceux-là même qui ont procédé aux travaux. Cet objectif n'est pas toujours atteint, car il se heurte à des difficultés d'ordre pratique qui, bien souvent, mettent l'entrepreneur obligé dans une situation délicate lorsque le sous-traitant se dérobe (V., pour une illustration : Civ. 3e, 6 févr. 2002, n° 00-14.055). Toutefois, la jurisprudence administrative paraît favorable à l'obligation de rendre « l'ouvrage conforme aux prévisions du marché » (CE 29 sept. 2014, req. n° 370151 , BPIM 6/14, inf. 389).

501. Lorsque le désordre est sans gravité, le risque de voir l'entrepreneur concerné se soustraire à la réparation n'est pas négligeable, spécialement s'il n'est pas l'auteur matériel des travaux ; le maître de l'ouvrage doit alors le mettre en demeure de procéder aux réparations. Si la mise en demeure est infructueuse, l'article 1792-6 autorise le maître de l'ouvrage à faire effectuer les travaux par un autre entrepreneur aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Toutefois, ce « remplacement » n'est pas sans inconvénients pour le maître de l'ouvrage : difficulté à trouver un entrepreneur acceptant de succéder à l'ancien et de se faire payer par lui ; crainte pour le maître de l'ouvrage de payer deux fois ; affectation de la retenue légale de garantie au paiement du remplaçant, mais seulement si elle a été constituée et si elle est suffisante.

502. Lorsque le désordre est grave et qu'il relève de la décennale, le risque de dérobade de l'entrepreneur concerné est encore plus grand. Certes, les procédures de mise en demeure et du remplacement s'appliquent ici aussi, mais le maître de l'ouvrage a tout intérêt à se placer sur le terrain de la garantie décennale, ce qui demeure possible et lui ouvre des perspectives plus rassurantes, ne serait-ce qu'en raison de l'assurance obligatoire que l'entrepreneur doit avoir souscrite.

§ 2 - Mise en œuvre de la garantie

503. Le délai de la garantie court pendant une durée d'un an à compter de la réception des travaux (V. *infra,* n° 504), il convient de préciser les modalités de sa mise en œuvre (V. *infra,* n°s 505 s.), et éventuellement le délai d'exécution des travaux de reprises (V. *infra,* n° 507).

A - Délai de garantie

504. Durée d'un an. - Le délai de garantie, qui coïncide, en fait, avec celui institué par la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie a, selon une interprétation qui peut être donnée de la jurisprudence, une double fonction, comme en matière décennale : les dommages garantis doivent avoir été réservés à la réception ou s'être manifestés dans le délai d'un an qui court à compter de celle-ci (V. *supra,* n°s 483 s.) ; la garantie doit être mise en œuvre dans le délai d'un an, que le désordre ait donné lieu à des réserves (Civ. 3e, 19 avr. 1989, Bull. civ. III, n° 80 ; 6 mai 1998, n° 96-18.038, Bull. civ. III, n° 90), ou qu'il soit apparu après la réception (Civ. 3e, 15 janv. 1997, RJDA 4/97, n° 588). Le délai de garantie, comme le délai décennal, est susceptible d'être interrompu par l'assignation en justice (Civ. 3e, 17 mai 1995, RJDA 8-9/95, n° 1027), ou par la reconnaissance de responsabilité émanant de l'entrepreneur (Versailles, 6 sept. 1996, RDI 1997. 83. – Civ. 3e, 21 nov. 2000, RDI 2001. 80). Seuls les désordres visés par l'acte interruptif du délai sont concernés : les désordres postérieurs ne le sont pas (Civ. 3e, 19 mai 2009, n° 08-13.454). L'effet de l'interruption est de faire courir un nouveau délai pour les désordres concernés ; mais cette conséquence est peu conforme à l'objet de l'institution qui est, on le rappelle, de favoriser la réparation rapide et en nature du dommage.

B - Modalités de la mise en œuvre

505. Réserves. - *Lorsque le désordre a donné lieu à des réserves,* le maître de l'ouvrage doit demander immédiatement à l'entrepreneur de le réparer et de fixer un délai d'exécution des travaux de réparation ; le procès-verbal de réception avec réserves ne vaut pas, à lui seul, mise en œuvre (Civ. 3e, 19 avr. 1989, Bull. civ. III, n° 80 ; 3 mai 1989, Bull. civ. III, n° 95). Si l'entrepreneur donne son accord lors de la réception ou un peu plus tard, mais dans le délai d'un an, le délai de garantie est interrompu (Versailles, 6 sept. 1996, RDI 1997. 83). Une fois les *travaux exécutés* conformément à l'accord, un nouveau délai, pour ce qui les concerne, devrait courir (conséquence de l'effet interruptif, V. *supra,* n° 456). Si l'entrepreneur ne donne pas son accord, le maître de l'ouvrage doit mettre en œuvre la garantie par la mise en demeure puis en procédant, s'il y a lieu, au remplacement de l'intéressé. Il est probable que la mise en demeure et même le remplacement ne suffisent pas à interrompre le délai ; une assignation, même à titre conservatoire, est donc recommandée (Civ. 3e, 19 avr. 1989, Bull. civ. III, n° 80 ; 3 mai 1989, *ibid.* III, n° 95 ; 15 janv. 1997, RJDA 4/97, n° 588).

506. Désordre postérieur à la réception. - *Lorsque le désordre apparaît après la réception,* le maître de l'ouvrage doit, d'abord, le signaler par voie de notification écrite (LR ; V. *supra,* n° 484) avant l'expiration du délai d'un an. S'il reste un temps suffisant pour obtenir l'accord de l'entrepreneur aux travaux de reprise, la procédure décrite ci-dessus peut être suivie. Si le temps qui reste à courir est limité, il paraît préférable d'opter pour une notification sous forme d'assignation impliquant mise en demeure, car, en l'état du droit positif, la lettre recommandée n'est pas, sauf texte contraire, interruptive de prescription.

C - Délai d'exécution des travaux de reprise

507. Accord des parties. - Ce délai est fixé d'un commun accord avec l'entrepreneur concerné (art. 1792-6). Si l'entrepreneur garant a donné son accord, il suffit de s'en tenir à ce dernier. La non-exécution des travaux de reprise dans le délai fait à nouveau courir le délai d'un an au terme dudit délai. L'exécution des travaux conformément à l'accord donne lieu à un constat qui correspond, en fait, à l'équivalent de l'ancienne réception définitive. Elle implique l'accès aux lieux qui doit être permis par le maître de l'ouvrage, qui, s'il s'y oppose, ne peut imputer le solde des sommes dues au titre du marché sur le montant éventuellement dû au titre des travaux de reprises (Civ. 3e, 23 juin 2010, n° 09-15.808, BPIM 5/10, inf. 372). Théoriquement, un nouveau délai de garantie de parfait achèvement court à compter de cette date, puisque le délai a été interrompu ; mais la curiosité de cette situation invite à se demander si la jurisprudence ira jusque-là. Un arrêt laisse entendre que c'est à l'entrepreneur d'établir qu'il a bien satisfait aux réserves (Civ. 3e, 1er avr. 1992, n° 90-18.498, Bull. civ. III, n° 109), mais une autre décision est moins affirmative (Civ. 3e, 20 juin 2001, BPIM 5/01, n° 311). Si les travaux de reprise sont pris en charge par l'entrepreneur « remplaçant », un nouveau contrat d'entreprise est conclu avec lui ; théoriquement, les travaux exécutés dans le délai convenu avec lui font l'objet d'une réception qui sert de point de départ aux garanties décennale et biennale et à la garantie de parfait achèvement. Mais si le délai de garantie est également interrompu à l'égard de l'entrepreneur garant, un étrange imbroglio est à craindre. À l'issue des travaux, il est dressé un état des lieux qui est en fait une réception surtout si les reprises sont le fait d'un tiers. On peut penser que la garantie décennale court à compter de cette date ; pour la Cour de cassation, en cas de réceptions successives ce n'est pas la dernière, tenue alors comme une réception d'ensemble, qui est à prendre en considération, mais chacune des réceptions (Civ. 3e, 2 mars 2011, n° 10-15.211, RDI 2011. 287). Dans les marchés publics, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des travaux (CCAG, art. 44-1) et en cas de réserves à la réception, il n'est pas nécessaire que cette prolongation soit explicite (CE 26 janv. 2007, req. n° 264306, Sté MAS entreprise générale) ; elle doit

l'être pour les désordres dénoncés après la réception (CAA Nantes, 24 juill. 1997, req. n° 92133, BPIM 6/97, inf. 387).

§ 3 - Caractère non exclusif de la garantie

508. La garantie de parfait achèvement laisse subsister les autres cas de responsabilité (V. *infra,* n°s 509 s.), et ne fait pas toujours échec à l'assurance construction (V. *infra,* n° 512).

A - Survivance des autres cas de responsabilité

1° - Garanties biennale et décennale

509. Un même désordre peut relever à la fois de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale ou décennale (Civ. 3e, 4 févr. 1987, Bull. civ. III, n° 16 ; 20 févr. 1991, n° 89-17113, Bull. civ. III, n° 61 ; 12 oct. 1994, n° 92-16.533, Bull. civ. III, n° 172). Les garanties biennale et décennale obligent alors, outre l'*entrepreneur* tenu de la garantie de parfait achèvement (arrêts précités ; V. aussi : Civ. 3e, 31 oct. 1989, RGAT 1990. 62 ; 24 févr. 1993, RGTA 1993. 618), les *autres constructeurs* assujettis, dont l'architecte (Civ. 3e, 8 oct. 1997, BPIM 6/97, n° 388) et, sans doute, le contrôleur technique, qui, alors, sont tenus *in solidum* (Civ. 3e, 8 oct. 1997, préc.). L'éviction de la garantie décennale ne dispense pas le juge de vérifier si la garantie de parfait achèvement peut s'appliquer lorsque cette question lui est posée (Civ. 3e, 4 déc. 2012, n° 11-28.188, BPIM 1/13, inf. 44).

2° - Responsabilité contractuelle de droit commun

510. Un même désordre peut relever à la fois de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun, lorsque la garantie décennale ou biennale n'est pas encourue (Civ. 3e, 23 sept. 2008, RDI 2008. 555) : désordre intermédiaire (apparu dans l'année de la réception, mais n'entrant pas dans le champ des garanties décennale ou biennale : Civ. 3e, 22 mars 1995, n° 93-15.233, Bull. civ. III, n° 80 ; 19 févr. 2002, RDI 2002. 241) ; désordre réservé à la réception (Civ. 3e, 13 déc. 1995, n° 92-11.637, Bull. civ. III, n° 255 ; 11 févr. 1998, n° 95-18.401, Bull. civ. III, n° 29 ; 28 janv. 1998, n° 96-13.460, Bull. civ. III, n° 19 ; 2 oct. 2001, RDI 2002. 89 ; 20 nov. 2007, n° 06-18.232, les conséquences des désordres réservés doivent alors être appréciables à la réception). La responsabilité de droit commun est une responsabilité pour faute pour les désordres intermédiaires (Civ. 3e,

22 mars 1995, préc.) ; elle est encourue tant par l'*entrepreneur* tenu également de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3e, 22 mars 1995, préc. ; 13 déc. 1995, préc. ; 11 févr. 1998, préc.) que par les *autres constructeurs* (Civ. 3e, 17 nov. 1993, no 91-17.982, Bull. civ. III, no 147 ; 7 juill. 2004, no 03-11.248) et, en particulier, l'architecte (Civ. 3e, 13 déc. 1995, préc. ; 5 nov. 1997, BPIM 1/98, no 26). L'exigence d'une faute prouvée pour les désordres intermédiaires ne semble pas devoir s'étendre aux désordres réservés qui révèlent le manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat (Civ. 3e, 19 juin 1996, RDI 1996. 581. – Paris, 31 janv. 2001, RDI 2001. 258). Mais la solution est différente pour l'architecte ou le contrôleur technique (Civ. 3e, 4 avr. 2001, no 99-16.998, RDI 2001. 258. – Civ. 3e, 7 juill. 2004, préc.).

511. Il est indifférent, pour la recevabilité de l'action en responsabilité de droit commun, que la garantie de parfait achèvement ait, ou non, été mise en œuvre dans le délai d'un an (Civ. 3e, 11 févr. 1998, préc.) ; si l'entrepreneur a fait une proposition de reprises, refusée par le maître de l'ouvrage, ce dernier peut exercer l'action en responsabilité qui subsiste « concurremment » avec la garantie (Civ. 3e, 30 juin 2009, no 08-18.410). L'expiration du délai de garantie de parfait achèvement n'emporte pas, en soi, décharge de la responsabilité de droit commun (Com. 12 nov. 1996, no 94-17.032, Bull. civ. IV, no 263). Il en résulte que l'action en responsabilité de droit commun est autonome (Civ. 3e, 27 janv. 2010, no 08-21.085, Bull. civ. III, no 20).

B - Survivance de l'assurance construction

512. L'assurance dommages-ouvrage joue après la réception lorsque, après mise en demeure, l'entrepreneur concerné n'a pas satisfait à ses obligations relatives à la garantie de parfait achèvement. Elle concerne, non seulement les désordres qui entrent dans le champ d'application de la garantie décennale, mais aussi les désordres réservés à la réception (Civ. 3e, 23 avr. 1986, Bull. civ. III, no 46 : mais en l'espèce les désordres présentaient le degré de gravité requis en matière décennale et la question de savoir si cette condition est nécessaire n'est pas clairement résolue). L'assurance de responsabilité ne s'applique qu'à la condition que la responsabilité décennale du constructeur soit encourue, y compris lorsque le désordre apparaît pendant la garantie de parfait achèvement (V. Civ. 3e, 1er févr. 1989, Bull. civ. III, no 24 ; 6 déc. 1989, *ibid.* III, no 224 ; 1er juill. 1992, JCP 1992. IV, no 2692).

ACTUALISATION

155, 512. Défaut de déclaration de l'activité de construction de maison individuelle. - Le défaut de déclaration de l'activité de construction de maison individuelle prive le maître de l'ouvrage de ses demandes en garantie formées à

l'encontre de l'assureur de la société de construction, laquelle avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes (Civ. 3e, 26 sept. 2018, no 17-23.741, Dalloz actualité, 12 nov. 2018, obs. R. Bigot).

512. Désordres réservés et assurance dommage ouvrage. - En application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations (Civ. 3e, 1er avr. 2021, no 19-16.179, D. actu. 28 avr. 2021, obs. C. Dreveau).

Chapitre 3 - Responsabilité des constructeurs

513. La responsabilité des constructeurs est d'abord celle qui est la conséquence de la mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles. Cette responsabilité est donc contractuelle, qu'elle soit encourue avant ou après la réception des travaux (V. *infra,* nos 514 s.). Mais elle est également délictuelle lorsque les victimes des dommages sont des tiers (V. *infra,* nos 663 s.).

Section 1re - Responsabilité contractuelle

514. Principe. - La responsabilité contractuelle des constructeurs varie suivant la nature de l'obligation à laquelle il n'a pas été satisfait, et suivant la nature du dommage dont se plaint la victime. La loi soumet les locateurs d'ouvrage et les personnes assimilées à une garantie décennale et une garantie biennale (qualification que l'on continuera d'adopter même si aujourd'hui la durée de l'obligation peut théoriquement dépasser deux ans et qu'avec la réforme de la prescription, la responsabilité de droit commun est également portée à dix ans dans certains cas : C. civ., art. 1792-4-3). Mais ces garanties ne couvrent pas tous les désordres qui affectent la construction (V. *infra,* nos 515 s.). La responsabilité contractuelle de droit commun subsiste à côté des garanties légales (V. *infra,* nos 636 s.). Le nouveau code civil consacre les articles 1217 et suivants à l'inexécution du contrat, les articles 1231 et suivants traitant spécialement de la réparation du préjudice. Ils ont vocation à s'appliquer, en particulier lorsque les garanties instituées par les articles 1792 et suivants ne peuvent être mises en œuvre.

Art. 1er - Garantie décennale et garantie biennale

515. Il convient de préciser les principes généraux applicables (V. *infra* n° 516 s.) qui gouvernent la mise en œuvre des garanties décennale (V. *infra,* nos 569 s.) et biennale (V. *infra,* nos 587 s.), d'identifier les acteurs en présence (V. *infra,* nos 539 s.), les dommages garantis (V. *infra,* nos 591 s.), et enfin de préciser le régime juridique des garanties (V. *infra,* nos 603 s.).

§ 1er - Principes généraux

516. La construction des régimes de garantie permet de revenir sur leur nature juridique (V. *infra,* nos 517 s.), l'évolution historique (V. *infra,* nos 522 s.) et enfin, le régime des dispositions transitoires (V. *infra,* nos 534 s.).

A - Nature juridique des garanties

517. Débat. - La question mérite que l'on s'y attarde. En 1940, un juriste écrivait : « On ne peut parler d'une solution doctrinale ; chaque auteur, en effet, développe à son sujet [au sujet de la garantie décennale] une solution particulière au point qu'on a pu parler d'un véritable chaos » (DE SAINT-MAURICE, La responsabilité des architectes, thèse, Grenoble, 1940). Une mise au point est donc nécessaire.

518. Le point de départ de la réflexion doit être la réception des travaux, car c'est elle qui a faussé l'analyse. Un fort courant d'opinion s'est d'abord dégagé en faveur de l'effet extinctif ou exonératoire de la réception (V. not. ROUAST, *op. cit.,* n° 947 ; LIET-VEAUX, dans les premières éditions du Droit de la construction ; V. encore, éd. 1978, p. 324). Ce courant, qui a laissé des traces (V. CASTON, *op. cit.* 1re éd., qui parle de l'effet exonératoire de la réception, n° 202 ; MALINVAUD, JESTAZ, par JOURDAIN et TOURNAFOND, *op. cit.,* n° 76 : « par définition même, la réception éteint l'obligation de l'entrepreneur et dégage ce dernier de toute responsabilité »), voyait dans la réception la fin du contrat. Dès lors, les garanties instituées par la loi dans les articles 1792 et 2270, qui ne couraient qu'à compter de la réception, ont fait figure de « mesures exceptionnelles », car se greffant sur un contrat expiré. La thèse a alors été soutenue que cette responsabilité post-contractuelle était purement légale, ce qui n'avait pas grande signification et se bornait à constater un phénomène sans l'expliquer. Puis a été évoquée l'idée d'une responsabilité délictuelle, mais l'option était d'autant plus contestable que, dans le marché à forfait au moins, la jurisprudence estimait que la responsabilité était présumée, et qu'il était impossible de voir dans l'article 1792 une

application de l'article 1384 du code civil (GALLIÉ, De la responsabilité de l'architecte envers le propriétaire de travaux privés, thèse, Rennes, 1910, p. 14 s.).

519. L'analyse péchait par manque de rigueur. À l'évidence, la réception, si elle marque l'exécution de certaines obligations du locateur d'ouvrage, ne dégage pas ce dernier de toute responsabilité, et il saute aux yeux qu'elle n'a guère d'effet extinctif (ce qui, à notre avis, laisse intact le débat sur sa nature juridique ; V. *supra,* n°s 435 s.). Comme le notait J. CARBONNIER, « l'œuvre est là qui subsiste, *res* du contrat qui continue à unir le propriétaire et l'entrepreneur » (RTD civ. 1958. 272). R. RODIÈRE a bien montré l'origine de l'erreur, et l'on s'étonne qu'une controverse puisse encore subsister. Les hésitations relatives au fondement de la garantie décennale sont la conséquence d'une formule maladroite de COLMET DE SANTERRE qui, le premier semble-t-il, a affirmé que la garantie était exceptionnelle. Cette formule a conduit les principaux auteurs à ne réserver leur curiosité qu'à l'examen de l'article 1792, alors que « l'assomption de toute obligation contractuelle doit éveiller chez le juriste l'idée de rechercher quelles conséquences entraînera son inexécution… ». « Il est assez remarquable, ajoute R. RODIÈRE, que ces questions soient rarement posées au sujet des entrepreneurs… ; cette attitude, critiquable en soi, est néfaste dans ses conséquences : elle conduit à voir dans l'article 1792 un texte exorbitant du droit commun, position initiale qui pèche fâcheusement sur l'intelligence du texte… La garantie légale trouve son statut technique dans l'ordre de la responsabilité contractuelle » (RODIÈRE, *in* BEUDANT et LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, t. 12, n°s 190 et 204).

520. Responsabilité contractuelle. - Tout est dit dans ce commentaire : c'est la violation d'une obligation contractuelle qui est sanctionnée par la garantie légale, et même si la responsabilité contractuelle est protéiforme et si plusieurs manifestations en sont concevables, depuis l'inexécution de l'obligation, jusqu'à la garantie de qualité d'une obligation exécutée, c'est dans le contrat que se trouve la cause de la dette. La jurisprudence a d'ailleurs admis l'existence d'une garantie dans d'autres contrats de louage d'ouvrage que le contrat d'entreprise de construction (V. *supra,* n°s 122 s.), malgré le silence de la loi ; il ne viendrait à l'esprit de personne de soutenir aujourd'hui que le bijoutier chargé de monter une parure est dégagé de toute obligation par le double effet de la réception qui met fin au contrat, et de l'absence de texte l'obligeant à garantir le client.

521. La majorité de la doctrine contemporaine s'est ralliée au fondement contractuel de la garantie décennale, même si certains auteurs confondent encore le fondement et le régime qui, lui, est aménagé par la loi. C'est parce que le constructeur n'a pas rempli son obligation d'exécuter un ouvrage sans vice qu'il doit sa garantie (BASSET, *op. cit.,* p. 70 ; SOINNE, *op. cit.,* n° 166 ; GROSS, La notion de garantie dans le droit moderne ; CARBONNIER, obs. RTD civ. 1958. 272) ; et même si celle-ci peut présenter une certaine autonomie (GROSS, *op. cit.*), elle reste dans l'ordre de la responsabilité contractuelle dont il faudrait peut-être, il est vrai, redéfinir les termes. Comme le notait

fort justement J. MAZEAUD, la responsabilité qui découle des articles 1792 et 2270 « est contractuelle, car si les conditions de cette responsabilité se trouvent modifiées à la réception, sa nature demeure inchangée » (dans le même sens : MALINVAUD, JESTAZ, par JOURDAIN et TOURNAFOND, *op. cit.,* n° 84 ; SAINT-ALARY, La vente d'immeuble à construire et l'obligation de garantie à raison des vices de la chose, JCP 1968. I. 2146 ; H., L. et J. MAZEAUD, Traité de la responsabilité civile, t. 2, nos 1070-10 s. ; H. MAZEAUD, chron. préc., Mélanges R. Savatier, 1965, Dalloz, p. 645 ; RODIÈRE, *op.* et *loc. cit.* ; J. FOSSEREAU, *op. cit.,* D. 1977. Chron. 13 ; NAUWELAERS et BOYON, note sous CE 9 janv. 1976, AJDA 1976. 95 ; DE SOTO, obs. RD publ. 1977. 197 ; en ce sens, encore semble-t-il bien qu'il se livre à une étude critique de la thèse purement contractuelle : A. CASTON, *op. cit.,* éd. 1978, nos 6 s., et spéc. n° 32 : « c'est une responsabilité contractuelle aménagée par la loi » écrit-il ; V. BOUBLI, *op. cit.,* 2e éd., nos 210 s. ; 3e éd., nos 255 et 290 ; V. aussi AUBY et PÉRINET-MARQUET, *op. cit.,* nos 1201 s. ; KARILA, 2e éd., p. 180, qui parle de responsabilité à fondement « légal » tout en retenant une position « moyenne et nuancée » ; comp. MODERNE, chron. préc., Mon. TP 27 mars 1978 ; *contra :* ROUGEVIN-BAVILLE, concl. sur CE 2 févr. 1973, Lebon 95). Le même fondement doit être reconnu à la garantie biennale. La consécration d'une responsabilité de droit commun par les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 confirme que la responsabilité des constructeurs après la réception des travaux a une nature contractuelle : alors même que la responsabilité encourue par le constructeur ne s'identifie pas toujours à ce qu'il est convenu d'appeler « la garantie décennale », la généralisation de la prescription à dix ans, sauf cas particulier (biennale), le souligne. La garantie décennale, comme la garantie biennale ont pour objet de contrôler la qualité du travail exécuté afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage : à l'issue du délai légal, le prestataire est « déchargé » des garanties (C. civ., art. 1792-4) ; il en résulte que la réception est une condition nécessaire à la mise en œuvre de ces garanties et influence l'assurance obligatoire (Civ. 3e, 27 févr. 2013, n° 12-12.148, Bull. civ. III, n° 29. – Civ. 3e, 17 févr. 2015, n° 13-25.491, BPIM 2/15, inf. 114). *Le dispositif relatif à ces garanties est d'ordre public* : les clauses excluant ou limitant la responsabilité des articles 1792 à 1792-4 sont réputées non écrites (C. civ., art. 1792-5).

B - Évolution historique

1° - Code civil

522. Le code civil ne consacre que deux articles au régime juridique de la responsabilité des constructeurs : les articles 1792 et 2270. Le premier est placé au chapitre « Louage d'ouvrage et d'industrie », le second à celui de la prescription. La rédaction des deux textes, particulièrement maladroite, est à l'origine des problèmes posés par la garantie

décennale. Le délai de garantie est visé par l'article 1792, de sorte que l'article 2270 semble faire double emploi avec lui. L'article 1792 ne concerne que le marché à forfait et la construction des édifices, en sorte qu'une interprétation littérale aurait pu conduire à limiter le domaine de la garantie décennale aux situations visées par le texte. Sous l'influence d'AUBRY et RAU s'est alors dégagée une doctrine qui donne à chacun des textes un domaine et un régime particulier (t. 5, § 374, note 18 ; sur l'évolution, V. BOUBLI, *op. cit.,* n°s 14 s.).

523. La *responsabilité décennale a d'abord éclaté.* Lorsque l'article 1792 s'appliquait, la *responsabilité était présumée.* Plusieurs conditions devaient alors être remplies :

524. 1° marché à *prix fait,* ce qui correspondait à la lettre du texte ; 2° construction d'un *édifice* : la jurisprudence a longtemps hésité (Civ. 1re, 27 janv. 1959, Bull. civ. I, n° 54 : ascenseur dans un gouffre naturel) avant d'admettre cette condition (not. Civ. 1re, 19 juin 1969, Bull. civ. III, n° 500 ; V. déjà : Civ. 1re, 5 janv. 1960, *ibid.* I, n° 5 ; V. FOSSEREAU, *op.* et *loc. cit.*), dont elle a fait ensuite un élément nécessaire du système (Civ. 1re, 9 oct. 1973, Bull. civ. III, n° 512, D. 1973. somm. 158 : court de tennis) ; 3° *désordre* affectant le *gros œuvre* et d'une *gravité* suffisante pour compromettre la « solidité de l'édifice » (Civ. 1re, 19 juin 1969, préc.), ou « le rendre impropre à sa destination » (Civ. 1re, 5 janv. 1960, préc.) ; 4° enfin, pendant un temps, on a estimé que la *présomption* de responsabilité *ne concernait pas l'architecte,* bien qu'il fût visé par l'article 1792, car il ne contractait pas à forfait (Civ. 1re, 5 avr. 1965, Bull. civ. I, n° 242, JCP 1965. I. 1918, chron. Liet-Veaux ; comp. Civ. 1re, 14 déc. 1964, D. 1965. 409, note Plancqueel), mais *cette jurisprudence a été abandonnée* (Civ. 3e, 6 avr. 1976, Bull. civ. III, n° 131, D. 1976. IR 192 ; 3 mai 1978, Bull. civ. III, n° 175 ; comp. CE 2 févr. 1973, Lebon 95, concl. Rougevin-Baville, AJDA 1973. II. 159, note Moderne, Gaz. Pal. 1973. 2. 550, note Rougeaux).

525. Lorsque l'article 1792 ne s'appliquait pas, la *responsabilité relevait de l'article 2270,* mais la faute des constructeurs *devait en général être prouvée* (Civ. 1re, 14 déc. 1964, préc. ; 30 nov. 1964, Bull. civ. I, n° 527, RTD civ. 1965. 367, obs. G. Cornu). Relevaient de ce régime tous les locateurs d'ouvrage qui n'avaient pas contracté à forfait. Ce texte n'exigeant pas la construction d'un édifice, on estimait généralement qu'il s'appliquait à tous gros ouvrages immobiliers (Civ. 1re, 5 janv. 1960, Bull. civ. I, n° 5 ; CE 17 juill. 1967, JCP 1967. II. 15103, note Liet-Veaux ; V. sur la question : BOUBLI, *op. cit.,* 2e éd., n° 371). Mais un auteur autorisé (FOSSEREAU, *op. cit.,* p. 16 et 20) s'est efforcé de montrer que la tendance de la jurisprudence, lorsqu'elle appliquait encore l'ancien article 2270, était d'exiger la construction d'un édifice (arg. Civ. 1re, 9 oct. 1973, préc.) et des désordres graves susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination ou d'en compromettre la solidité.

526. Les *menus ouvrages,* qui par cette interprétation ne donnaient lieu à aucune garantie (de même que les ouvrages ne constituant pas des édifices si l'on suit la doctrine exposée ci-dessus…), ont été alors soumis au *droit commun,* c'est-à-dire à la responsabilité trentenaire avec action à « bref délai » (Civ. 1re, 4 janv. 1958, Gaz. Pal. 1958. 1. 168, RTD civ. 1958. 252, obs. H. Mazeaud, RTD civ. 1958. 272, obs. Carbonnier. – Civ. 2e, 19 mai 1958, Gaz. Pal. 1958. 2. 195, JCP 1958. II. 10808, note Starck. – Civ. 1re, 4 janv. 1958, D. 1958. 457, note Rodière), mais l'incertitude était telle qu'on ne savait alors si le « droit commun » était celui des articles 1645 et 1646 du code civil (visés par les arrêts préc.) ou celui de l'article 2270 (visé par Civ. 1re, 25 oct. 1967, Bull. civ. I, no 311), devenu le texte de principe en matière de louage d'ouvrage, l'article 1792 étant limité au seul marché à forfait (V. BOUBLI, *op. cit.,* 3e éd., no 19).

2° - Loi du 3 janvier 1967

527. La réforme de 1967 n'a été qu'incidente. La loi régit la vente d'immeuble à construire et elle ne réforme les articles 1792 et 2270 qu'accessoirement. De l'article 1792 disparaît la mention relative au marché à forfait : on entendait ainsi faire échec à la jurisprudence Teillaud de 1965 concernant l'architecte (V. *supra,* no 441) ; dans l'article 2270 apparaît pour la première fois la garantie biennale des mêmes ouvrages.

528. En *matière décennale* la loi simplifie, en principe, les choses. Dans le régime antérieur, si l'on admet la thèse restrictive qui n'applique l'article 2270 qu'aux édifices et aux désordres graves (V. *supra,* no 441), l'article 1792 et l'article 2270 sont soumis aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne le marché à forfait et la preuve de la faute. Or, AUBRY et RAU ont fondé la présomption de responsabilité sur le caractère forfaitaire du marché, l'entrepreneur étant suspect, car tenté de « gagner sur la qualité » (*op.* et *loc. cit.*). Comme l'intention non équivoque du législateur était de maintenir la présomption en ne la limitant pas au seul marché à forfait (Rapp. WAGNER, no 2237, séance du 14 déc. 1966 à l'Assemblée nationale : « le champ d'application de l'article 1792 se trouve élargi »), il ne subsiste plus, au lendemain de la loi de 1967, aucune différence de fond entre les deux textes. Si la garantie décennale n'est admise qu'en cas de construction d'un édifice (même si la notion est assouplie en jurisprudence : MALINVAUD, JESTAZ, par JOURDAIN et TOURNAFOND, *op. cit.,* no 87 ; AUBY et PÉRINET-MARQUET, *op. cit.,* no 1218 ; MALINVAUD et BOUBLI, obs. RDI 1979. 343 s.), en faisant de l'article 1792 le texte de principe, il faut décider par application de l'article 2270 que la garantie ne joue que lorsque le désordre se manifeste dans les gros ouvrages et qu'il est suffisamment grave (V. MALINVAUD et BOUBLI, obs. RDI 1979. 70 ; B. BOUBLI, *op. cit.,* no 23).

529. En *matière biennale,* sont désormais couverts les désordres aux menus ouvrages, à des conditions qui seront exposées plus loin. La loi, complétée par le décret précité,

n° 67-1166 du 22 décembre 1967 (JO 28 déc.), tente de distinguer dans les bâtiments à usage d'habitation ou ayant un objet similaire les gros des menus ouvrages. Théoriquement, elle envisage toutes les éventualités susceptibles de se produire. Hélas, si l'on suit la jurisprudence qui limite la garantie décennale aux désordres graves affectant les gros ouvrages, et si l'on estime que la loi du 3 janvier 1967 limite la garantie biennale aux seuls désordres affectant les menus ouvrages, le sort des malfaçons affectant le gros œuvre, sans en compromettre la solidité ou rendre l'immeuble impropre à sa destination, *doit encore relever du droit commun* (Civ. 3e, 10 juill. 1978, RDI 1979. 72 ; 29 mai 1979, *ibid.* 1979. 473, obs. Malinvaud et B. Boubli : fissures).

3° - Loi du 4 janvier 1978 et législation postérieure

530. Protection du consommateur. - La loi du 4 janvier 1978 (JO 5 janv.) s'inscrit dans le courant favorable à la *protection du consommateur* qui s'est développée depuis 1975. C'est une loi de protection du maître de l'ouvrage et plus spécialement du petit propriétaire et de l'accédant. Deux raisons majeures à ce texte, qui rejoignent, sous une autre forme, celles mises en évidence par la commission Spinetta : 1° les interminables discussions sur la présomption de responsabilité que d'aucuns continuaient à contester, malgré sa consécration, sans équivoque, par la loi de 1967 : la discussion a permis d'alimenter un abondant contentieux et de retarder la solution des litiges. 2° La régression de la notion de bonne foi dans les contrats. La pratique entendait soustraire certains désordres à toute garantie (désordres intermédiaires) ; la loi entend les mettre à la charge des constructeurs, sauf à ne pas les obliger pour une durée excessive. Le rapport de la commission Spinetta reprend en partie ces idées. Constatant le doublement de la charge des sinistres entre 1969 et 1974, et relevant un taux de croissance de la « densité de sinistres » de 15 % l'an, il dégage trois grands axes de la réforme qui veut assurer : « une protection effective de l'usager » ; « le développement d'une structure industrielle de production » ; « la moralisation du secteur ».

531. Sous-assurance. - La commission a mis surtout l'accent sur la sous-assurance du secteur de la construction. Il y avait environ 50 % de non-assurés dans l'ingénierie et la maîtrise d'œuvre ; 40 % dans l'entreprise ; 90 % chez les fournisseurs. Parmi les maîtres d'ouvrages, 50 % n'étaient pas assurés. La loi du 4 janvier 1978 est donc tout naturellement, et en priorité, une loi « portant réforme de l'assurance construction ». Tel est d'ailleurs son intitulé. Mais elle réforme en profondeur les garanties décennale et biennale. D'une part, elle consacre expressément la *présomption de responsabilité* (art. 1792). D'autre part, elle distingue deux fonctions dans l'édification d'un immeuble ; la *fonction construction,* limitée, dans le principe, aux seuls ouvrages de viabilité aux fondations, à l'ossature, au clos et au couvert ; la *fonction équipement,* relevant des garanties industrielles. La première relève de la garantie décennale, la seconde de la garantie biennale qui, dans le nouveau régime, est une « garantie de bon

fonctionnement ». Enfin, « les éléments intérieurs à l'espace délimité par le clos et le couvert » sont, d'après une formule riche d'incertitudes, « réinsérés dans le droit commun ».

532. Textes. - La loi a été complétée par deux décrets. L'un relatif à l'assurance (Décr. n° 78-1093 du 17 nov. 1978, D. 1978. 430 ; et deux arrêtés du même jour, D. 1978. 431 et 434), l'autre au contrôle technique (Décr. n° 78-1146 du 7 déc. 1978, JO 9 déc. complété par Décr. n° 92-1186 du 30 oct. 1992, JO 6 nov.). Les dispositions relatives à la responsabilité, seules examinées dans ce chapitre, sont codifiées. Elles ont été pour la plupart inscrites dans les articles 1792 et suivants et dans l'article 2270 du code civil. L'article 1792-5 réputant non écrites les clauses limitant ou excluant la responsabilité inscrite, sous une forme ou une autre, dans les articles 1792 à 1792-4, on en déduit que les garanties sont *d'ordre public.*

533. Ces dispositions ont connu plusieurs aménagements : 1° l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, qui a surtout précisé le champ d'application de l'assurance obligatoire, a également modifié les articles 1792-2 (l'*ouvrage,* remplace le *bâtiment* ; la notion d'*indissociabilité* des équipements est explicitée) et 1792-3 (qui redéfinit les conditions de la garantie *de bon fonctionnement des éléments d'équipement*), et a institué un article 1792-7 qui exclut du champ des garanties les équipements *dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle,* ainsi qu'un article 2270-2 désormais déplacé ; 2° la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, a supprimé les anciens articles 2270 et 2270-2, qui deviennent les articles 1792-4-1 (fixe la durée de la prescription décennale et biennale) et 1792-4-2 (concerne la durée des actions en responsabilité dirigées contre le sous-traitant), et a créé un nouvel article 1792-4-3 (action en responsabilité de droit commun contre les constructeurs). En marge de ce dispositif, d'autres textes sont intervenus qui peuvent concerner la matière (C. civ., art. 1386-1 s. ; C. consom., art. L. 217-1 s.).

C - Régimes transitoires

534. Plusieurs régimes peuvent coexister pendant quelques années encore (V. *infra* n° 535). Comme l'écrivait P. MALINVAUD, « il y a encore de beaux jours pour la législation ancienne, y compris pour celle antérieure à 1967 » (RDI 1979. 210, V. *infra,* n°s 536 et 537 s.).

1° - Code civil

535. Sont soumis au régime du code civil les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1967 (fixée au 1er juill. 1967). La garantie est due conformément aux articles 1792 et 2270 anciens.

2° - Loi du 3 janvier 1967

536. La loi du 3 janvier 1967 a été complétée, dans certaines dispositions relatives à la vente, par une loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 (D. 1967. 260) et par un décret précité du 22 décembre 1967. Une distinction est à faire suivant que le contrat a été conclu entre le 1er juillet 1967, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier, et le 28 décembre 1967, date de publication du décret, ou après le 28 décembre 1967. Les contrats conclus entre le 1er juillet 1967 et le 28 décembre 1967 sont soumis à la loi de 1967, mais la distinction entre gros et menus ouvrages s'opère conformément aux dispositions applicables sous le régime du code civil. Pour les contrats conclus après le 28 décembre 1967, la distinction se fait en application du décret du 22 décembre 1967, qui, en outre, se prononce pour l'unité de réception. Une difficulté : que décider si certains contrats sont conclus avant et d'autres après l'entrée en vigueur de la loi ? Sont-ils soumis à un régime unique (peu probable) ou à la loi applicable à la date de leur conclusion ? (V. B. BOUBLI, *op. cit.,* n° 53). En tout cas, il paraît acquis que la loi du 3 janvier 1967 n'a pas un caractère impératif d'ordre public la rendant applicable aux effets des contrats conclus avant son entrée en vigueur (R. SAINT-ALARY, La vente d'immeubles à construire et l'obligation de garantie à raison des vices de construction, JCP 1968. I. 2146 ; BOUBLI, *op. cit.,* n° 52 ; arg. les arrêts qui font encore application des dispositions du code civil dans les litiges en cours).

3° - Loi du 4 janvier 1978

537. L'article 14 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 1979. Sont soumis aux dispositions du texte « les contrats relatifs aux chantiers *dont la déclaration réglementaire d'ouverture* [est] établie postérieurement à cette date » (V. Civ. 1re, 3 avr. 1984, Bull. civ. I, n° 122). La loi *s'applique par chantier* : c'est la déclaration réglementaire ou la formalité qui en tient lieu, qui est à considérer. Elle s'applique *à tous les contrats relatifs aux chantiers,* et pas seulement au contrat d'entreprise. Il en résulte, semble-t-il, qu'un contrat de fournitures conclu antérieurement au 1er janvier 1979 est soumis au nouveau texte, si le chantier est ouvert après cette date. C'est, dans le cas particulier, une mesure que l'on peut regretter, car le contrat de fourniture est une vente, et l'application immédiate de la loi équivaut à lui reconnaître un effet partiellement rétroactif (CASTON, chron. préc., AJPI 1978. 117 ; BOUBLI, *op. cit.,* n° 57).

538. Ce sont les articles 1792 et suivants du code civil qui gouvernent la matière. Ces textes ayant été modifiés par l'ordonnance du 8 juin 2005 (V. *supra,* n° 482), les garanties décennale et biennale ne s'appliquent qu'aux conditions prévues par les textes modifiés, pour les marchés contrats ou conventions conclus après la publication de cette ordonnance qui a eu lieu le 9 juin 2005. Des dispositions particulières s'appliquent à la vente d'immeuble à construire (C. civ., art. 1642-1, 1646-1), au

contrat de construction de maison individuelle (CCH, art. L. 231-1), au contrat de promotion immobilière (C. civ., art. 1831-1), au contrôleur technique (CCH, art. L. 111-24).

§ 2 - Acteurs des garanties

539. Malgré une rédaction sibylline de la loi, on s'accorde pour admettre que les personnes tenues à la garantie décennale sont également tenues de la garantie biennale (V. *infra,* n°s 540 s.), sauf exclusion particulière (ex : contrôleur technique) pour mieux protéger l'autre partie au contrat (V. *infra,* n°s 562 s.).

A - Personnes tenues aux garanties

540. La loi oblige les locateurs d'ouvrage (V. *infra,* n°s 541 s.), les personnes qu'elle assimile à des constructeurs et le fabricant de composants (V. *infra,* n°s 545 s.).

1° - Locateurs d'ouvrage

541. Constructeurs. - L'article 1792-1 du code civil répute constructeurs, et soumet à garantie, « les architectes entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ».

542. Sont tenus à garantie : l'*architecte* et, plus généralement, le maître d'œuvre, dont les techniciens d'étude ; l'*entrepreneur* ; le *contrôleur technique* qui, en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, est soumis à la présomption édictée par les articles 1792 et suivants, dans la limite de la mission qui lui est confiée (le texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005, précise les modalités de sa contribution à la dette en cas de concours de responsabilité ; rappr. : Civ. 3e, 15 janv. 2003, n° 00-16.106, Bull. civ. III, n° 5, qui semble étendre sa responsabilité aux dommages consécutifs ; V. *supra,* n° 246). Compte tenu des limites de la mission de base (sécurité des personnes et solidité des ouvrages), le contrôleur technique n'est pas tenu à la garantie biennale dans ce cas.

543. N'est pas tenu à garantie : le *sous-traitant* (Civ. 3e, 8 juill. 1971, Bull. civ. III, n° 450 ; 2 oct. 1979, JCP 1979. IV. 460) ; c'est un tiers au maître de l'ouvrage qui est responsable envers lui sur le fondement des articles 1382 et suivants (Cass., ass. plén., 12 juill. 1991, Bull. civ., n° 5 ; V. *supra,* n°s 368 s.). Toutefois, l'article 1792-4-2 soumet les actions en responsabilité dirigées contre le sous-traitant à la prescription de dix ou deux ans selon que les dommages en cause relèvent de la garantie décennale ou de la garantie biennale : il est permis de se demander si ce texte de prescription, désormais

placé après l'article 1792, ne modifie pas la nature de la responsabilité encourue par le sous-traitant (V. *supra,* n° 370).

544. Sont soumis à un statut imprécis : le *coordonnateur OPC* (pilotage de chantier) qui, n'étant pas un constructeur, n'est pas, en principe, assujetti aux garanties (V. Civ. 3e, 11 mai 1988, RDI 1988. 467) ; mais s'il sort de son rôle et s'il participe à la maîtrise d'œuvre, l'application des garanties n'est pas à écarter (Civ. 3e, 10 juill. 1996, BPIM 1/97, n° 38) ; le *coordonnateur SPS* (sécurité et santé sur le chantier), qui n'est pas un constructeur dans la mesure où il limite son intervention à la sécurité de chantier (Circ. min. trav. 10 avr. 1996, art. 5-3-1 ; BOMT 96/10 du 5 juin 1996, p. 21 ; avis du CE, sect., TP, 16 juin 1998, n° 362-051 ; décis. Bureau central de tarification 10 déc. 1997, RDI 1998. 116). Mais comme la sécurité doit être intégrée dans les ouvrages de bâtiment, si la coordination implique une intervention au niveau de la conception des instruments de sécurité des ouvrages, l'assimilation du coordonnateur à un constructeur n'est pas à exclure (V. CE 21 févr. 2011, req. n° 330515 , BPIM 2/11, inf. 126 ; V. *supra,* nos 190 s.).

2° - Personnes assimilées à des constructeurs

545. Il faut distinguer entre les vendeurs (V. *infra,* nos 546 s.) et les prestataires réputés constructeurs (V. *infra,* nos 548 s.).

a. - Vendeurs réputés constructeurs

546. L'article 1792-1, 2°, vise celui qui « vend après achèvement l'ouvrage qu'il a construit ou fait construire » ; l'article 1646-1 vise le vendeur d'immeuble à construire. Sont donc concernés : *le vendeur d'immeuble à construire,* qu'il opte pour une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou pour une vente à terme ; celui qui vend après achèvement l'ouvrage qu'il a fait construire, c'est-à-dire le professionnel de la vente, comme le marchand de biens (Civ. 3e, 9 déc. 1992, n° 91-12.097 , Bull. civ. III, n° 321 ; 28 mai 2002, RDI 2002. 324 . – Civ. 3e, 3 mars 2010, n° 09-11.282 , RDI 2010. 322), le lotisseur qui fait réaliser des VRD (Civ. 3e, 17 déc. 1997, n° 96-12.209 , Bull. civ. III, n° 224) et, par analogie, l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) (V. pour ce dernier, *contra* : CE 22 juin 1990, RDI 1990. 490), le particulier qui vend après achèvement l'ouvrage qu'il a fait construire ou rénover, même pour son propre usage (Civ. 3e, 19 déc. 1996, BPIM 1/97, n° 39 ; 12 mars 1997, n° 95-12.727 , Bull. civ. III, n° 61 ; 14 janv. 1998, n° 95-19.916 , Bull. civ. III, n° 11 ; 2 oct. 2002, RDI 2002. 546), sous condition, toutefois, qu'il y ait eu réception des travaux (Civ. 3e, 27 févr. 2013, n° 12-12.148 , Bull. civ. III, n° 29) ; celui qui vend après achèvement l'ouvrage qu'il a construit lui-même (Civ. 3e, 7 sept. 2011,

n° 10-10.763. – Chambéry, 4 mars 1997, RDI 1998. 97). Un arrêt décide, à propos de celui qui restaure lui-même l'ouvrage et le vend, que les travaux doivent être « achevés » pour que la garantie décennale s'applique (Civ. 3e, 14 mars 2001, n° 99-18.348, Bull. civ. III, n° 34 ; comp. : Civ. 3e, 9 juin 1999, n° 97-19.257, Bull. civ. III, n° 133, qui ne pose pas cette condition restrictive). Il importe, dans tous ces cas, que les travaux soient des travaux de construction immobilière (Civ. 3e, 9 déc. 1992, préc. ; 17 déc. 1996, BPIM 1/97, inf. 39 ; 14 janv. 1998, préc. ; comp. : Civ. 3e, 6 nov. 1996, RJDA 1/97, n° 110, qui écarte la VIC pour un ouvrage consistant en un « travail léger »). Le juge du fond doit caractériser la nature et, le cas échéant, l'importance des travaux réalisés (Civ. 3e, 29 janv. 2003, n° 00-21.091, Bull. civ. III, n° 18 ; 7 déc. 2005, n° 04-12.931, Bull. civ. V, n° 244). Lorsque la vente a lieu après achèvement, aucune condition de délai n'est fixée pour la mise en œuvre des garanties (Civ. 3e, 14 janv. 1998, n° 95-19.916, Bull. civ. III, n° 11). Il en résulte que le vendeur-maître de l'ouvrage et le vendeur-castor sont tenus à garantie lorsqu'ils procèdent à la vente, soit avant l'expiration du délai de dix ans qui suit la réception des travaux, soit avant l'expiration du délai de dix ans qui suit la DAT (déclaration d'achèvement des travaux), s'il n'y a pas de réception. La date à retenir pour apprécier le délai de prescription est celle de l'action et non celle de la vente (Civ. 3e, 7 sept. 2011, n° 10-10.596, Bull. civ. III, n° 145). Lorsque la garantie décennale n'est pas invoquée ou ne peut être mise en œuvre, la garantie de droit commun du vendeur d'immeuble a vocation à s'appliquer (Civ. 3e, 27 sept. 2000, RDI 2001. 84 ; 17 juin 2009, n° 08-15.503 ; comp. : Civ. 3e, 4 juin 2009, n° 08-13.239).

547. Le *vendeur d'immeuble à rénover* est soumis à la garantie décennale et à la garantie biennale (CCH, art. L. 262-1 et L. 262-2, issus L. n° 2006-872 du 13 juill. 2006, et art. L. 111-13, L. 111-15, L. 111-16 ; V. PÉRINET-MARQUET, Le nouveau statut de la vente d'immeubles à rénover, RDI 2006. 329 s.). La jurisprudence avait déjà admis que la vente portant sur des immeubles en rénovation relevait des garanties légales (Civ. 3e, 17 déc. 1996, BPIM 1/97, inf. 39 ; 29 janv. 2003 et 7 déc. 2005, préc.). La loi s'applique aux ventes relatives à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque les travaux doivent être réalisés dans un délai contractuellement fixé et que des sommes d'argent sont perçues par le vendeur avant la livraison. Les garanties courent à compter de la réception intervenue entre le vendeur et les constructeurs (CCH, art. L. 262-2).

b. - Prestataires réputés constructeurs

548. Sont concernés, outre le lotisseur et l'aménageur de ZAC, déjà cités (*supra,* n° 493) : le *constructeur de maison individuelle,* qui n'est qu'un locateur d'ouvrage (CCH, art. L. 231-1) ; celui qui fournit la *garantie de livraison à prix et délai convenus*

dans le CCMI et reprend le programme (Civ. 3e, 4 juin 2009, n° 07-16.647. – Comp. : Civ. 3e, 7 sept. 2011, n° 10-21.331, Bull. civ. III, n° 138, qui exclut de la garantie décennale celui qui fournit la garantie d'achèvement sans prendre la qualité de constructeur) ; le *promoteur immobilier* (C. civ., art. 1831-1) ; celui qui, sans être promoteur immobilier au sens de l'article 1831 du code civil, « accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage » (art. 1792-1, 3°). Peut être intéressé le *maître d'ouvrage délégué,* s'il ne se borne pas à être le mandataire du maître de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage délégué au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985, qui n'est qu'un mandataire, n'est pas concerné (CE 12 janv. 1994, RDI 1994. 244 ; CE 30 juin 1999, req. n° 163435, Cne de Voreppe, Lebon 225, BPIM 1/00, n° 23). De même, n'est pas un constructeur l'expert judiciaire (Civ. 3e, 27 juin 2001, n° 99-18.883, RDI 2001. 523). L'*expert-judiciaire* n'est pas un constructeur ; il n'est pas tenu des garanties légales (Civ. 3e, 27 juin 2001, RDI 2001. 523), sauf s'il accepte d'intervenir comme maître d'œuvre pour l'exécution des travaux de reprises (Civ. 3e, 4 juin 2008, n° 06-17.521) ; à défaut, il ne répond que de sa faute (Civ. 2e, 20 juill. 1993, n° 92-11.209, Bull. civ. III, n° 272).

3° - Fabricant de composants

549. L'article 1792-4 du code civil soumet aux garanties, selon des modalités particulières, « le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage (V. *infra,* nos 550 s.) ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de services à des exigences précises et déterminées à l'avance » (V. *infra,* nos 554 s. ; V. sur ce texte, Rapport de la Cour de cassation pour 2008, RDI 2009. 308). Il existe aussi un concours de responsabilités entre les constructeurs (V. *infra,* nos 559 s.).

a. - Fabricants concernés

550. Fabricant d'ouvrage. - Il résulte du texte que sont tenus à garantie : le *fabricant d'ouvrage* : en pratique, il s'agit du constructeur de maison préfabriquée qui la livre en « kit » ou la fournit déjà structurée pour être posée sur des fondations destinées à la recevoir ; le fabricant de *partie d'ouvrage et d'éléments d'équipement.* Logiquement, il conviendrait de distinguer « partie d'ouvrage » et « élément d'équipement ». Il est probable qu'un escalier préfabriqué, une coque de piscine, une salle de bains préconstruite sont des parties d'ouvrage, tandis qu'un système de chauffage, voire un « liner » de piscine sont des équipements. Toutefois, la distinction n'est pas toujours commode à faire, car on ignore exactement ce qu'est un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4. Devant cette difficulté, un comité a été institué qui fait l'inventaire des éléments pouvant entraîner la responsabilité du fabricant (COPAL : comité pour l'application de la loi). Cette responsabilité étant solidaire de celle de l'entrepreneur-poseur, il est convenu de qualifier ces éléments d'EPERS (éléments pouvant entraîner

la responsabilité solidaire). La liste des EPERS est réactualisée par le COPAL ; en outre, le Bureau central de tarification des assurances (BCT) fournit des indications en ce domaine, le tout sous réserve de l'appréciation du juge.

551. EPERS. - La partie d'ouvrage ou les équipements au sens de la loi, ayant une vocation spécifique, on les distingue des matériaux indifférenciés comme les tuiles (Civ. 3e, 4 déc. 1984, Bull. civ. III, n° 202 ; CE 20 mars 1992, req. n° 97819, Lebon 120).

– *Ont été considérés comme des EPERS* : une pompe à chaleur (Civ. 3e, 20 janv. 1993, RDI 1993. 231) ; des tubes (Versailles, 30 juin 1995, RDI 1996. 224) ; un système dalle de polystyrène et canalisation pour un plancher chauffant (Civ. 3e, 25 juin 1997, n° 95-18.234, Bull. civ. III, n° 150) ; un système de chauffage (Civ. 3e, 23 avr. 1997, BPIM 4/97, n° 262) ; une coque de piscine (Civ. 3e, 17 juin 1998, n° 95-20.841, Bull. civ. III, n° 126) ; les panneaux d'isolation d'un poulailler (Civ. 3e, 12 juin 2002, RDI 2002. 421) ; des fenêtres répondant à des conditions spécifiques (Civ. 3e, 4 janv. 2006, n° 04-13.489, Bull. civ. III, n° 1) ; des panneaux isothermes et bardages (Cass., ass. plén., 26 janv. 2007, n° 06-12.165, BPIM 2/07, inf. 123. – Civ. 3e, 25 avr. 2007, n° 05-17.838, BPIM 4/07, inf. 276 ; ; des bâtiments provisoires qui ne sont pas assimilés à des travaux de réparation (Civ. 3e, 13 janv. 2010, n° 08-13.562, Dalloz actualité 27 janv. 2010, obs. H. Berrah).

– *N'ont pas été considérés comme des EPERS* : du béton prêt à l'emploi (Civ. 3e, 24 nov. 1987, Bull. civ. III, n° 188) ; un revêtement d'étanchéité liquide (Civ. 3e, 26 mai 1992, n° 90-18.391, Bull. civ. III, n° 167) ; des crochets destinés à enrayer l'amas de neige (Civ. 3e, 11 janv. 1995, RDI 1995. 335) ; des poutres taillées à la mesure (Civ. 3e, 14 avr. 1999, BPIM 5/99, n° 368) ; des tuiles (Civ. 3e, 4 déc. 1984, Bull. civ. III, n° 202) ; des dalles d'un court de tennis (Civ. 3e, 27 janv. 1993, RJDA 7/93, n° 648) ; des tuyaux convenant à des usages polyvalents (Civ. 3e, 26 juin 2002, RDI 2002. 422) ; des matériaux servant au double vitrage (Civ. 3e, 20 nov. 2002, n° 01-14.010, Bull. civ. III, n° 228 ; rappr. : 26 oct. 1988, RDI 1989. 218) ; des panneaux destinés à constituer des entrepôts frigorifiques, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être proposés par d'autres fabricants et qu'ils peuvent être découpés sur le chantier pour leur mise en œuvre (Civ. 3e, 22 sept. 2004, n° 03-10.325, Bull. civ. III, n° 151 ; 15 mars 2006, n° 04-20.228, Bull. civ. III, n° 63 ; rappr., toutefois, Cass., ass. plén., 26 janv. 2007 et Civ. 3e, 25 avr. 2007, préc., qui censurent un décision ayant relevé que le produit était proposé par d'autres fabricants ; V. aussi RDI 2000. 208 s., qui dresse une liste des EPERS et des matériaux qui n'en sont pas).

552. Distinction. - Le fabricant visé par l'article 1792-4 se distingue du sous-traitant en ce qu'il ne réalise pas un ouvrage « sur mesure » répondant à une commande spécifique : c'est lui qui, de sa propre initiative, crée un élément qualifié de « composant » ayant une fonction particulière dans l'ouvrage et qu'il fournira, à la demande, au constructeur. L'idée est contenue dans l'article 1792-4 qui précise que le composant doit « être conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance ». Le fabricant de composant *crée* un besoin. Le sous-traitant qui exécute à la demande une commande spécifique (Civ. 3e, 4 juill. 1989, Bull. civ. III, n° 210. – Civ. 3e, 7 nov. 2012, n° 11-18.138, Bull. civ. III, n° 163 : travail effectué en atelier dans ce dernier arrêt) *répond* à un besoin. La Cour de cassation qui estime que le composant doit répondre « à des exigences spécifiques » précise toutefois qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'il soit un EPERS, qu'il présente des caractéristiques telles qu'il soit réservé à un chantier exclusif (Cass., ass. plén., 26 janv. 2007 et Civ. 3e, 25 avr. 2007, n° 05-17.838, préc.). Il suffit que le composant ait été spécialement conçu et produit pour être intégré à l'ouvrage construit (Civ. 3e, 19 déc. 2007, n° 06-19.595, pour un bloc de filtration et les parois d'une piscine). Encore faut-il, pour éviter que l'on soit en présence d'une sous-traitance, que le produit n'ait pas été *commandé spécialement* à la mesure, mais qu'il ait été *conçu préalablement* selon un dimensionnement et des caractéristiques spécifiques prises en compte par l'auteur du projet immobilier.

553. Au fabricant de composant, la loi assimile l'*importateur d'ouvrage,* de partie d'ouvrage ou d'éléments d'équipement fabriqués à l'étranger, et le distributeur qui les a présentés comme son œuvre en y mentionnant son nom, sa marque de fabrique ou un autre signe distinctif. En revanche, le fournisseur non fabricant qui n'entre pas dans ces catégories n'est pas concerné.

b. - Conditions de la responsabilité du fabricant d'EPERS

554. Solidarité. - Selon l'article 1792-4, le fabricant est « solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ». Trois conditions cumulatives doivent être réunies :

555. 1° Le composant doit être un EPERS au sens déjà précisé (V. *supra,* nos 551 s.) ; il doit être conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, ce qu'il appartient au juge de rechercher (Civ. 3e, 5 juill. 2011, n° 10-19.928, BPIM 5/11, inf. 386). Le fabricant doit préciser la destination du produit en fournissant une documentation appropriée (Civ. 3e, 10 mars 1982, RDI 1982. 519 ; 13 mars 1991, Mon. TP 20 sept. 1991), ce qui confirme que c'est lui qui crée le besoin et qu'il ne se borne pas à y répondre. Le produit doit être conçu pour une

destination précise (Civ. 3e, 19 déc. 2007, préc. *supra,* n° 552 ; V. aussi : Civ. 3e, 6 oct. 1999, BPIM 6/99, inf. 431 : un capteur solaire prévu pour un modèle type de maison n'est pas nécessairement adaptable à une maison d'un autre type) mais il n'est pas nécessaire qu'il soit réservé à un chantier précis et exclusif (Cass., ass. plén., 26 janv. 2007, n° 06-12.165, Bull., ass. plén., n° 2. – Civ. 3e, 25 avr. 2007, n° 05-20.585, Bull. civ. III, n° 58).

556. 2° Le composant doit aussi être mis en œuvre sans modification par le poseur (Civ. 3e, 25 avr. 2007, n° 05-20.585, BPIM 4/07, inf. 276, 2e esp.) ; le composant lui-même qui ne doit pas être « transformé » par l'entrepreneur-poseur, y compris pour l'adapter (V., toutefois, Civ. 3e, 4 janv. 2006, n° 04-13.489, Bull. civ. III, n° 1, qui nuance cette condition). La modification exclut la responsabilité solidaire du fabricant (Civ. 3e, 26 mai 1994, RDI 1994. 461 ; 6 oct. 1999, BPIM 6/99, n° 431, préc.). Cet arrêt avait donné à penser que la charge de la preuve de la non-conformité de l'installation de l'EPERS aux consignes de pose incombait au fabricant. Mais un autre (Civ. 3e, 17 juin 1998, n° 95-20.841, Bull. civ. III, n° 126) laisse plutôt entendre que le maître de l'ouvrage doit établir que les consignes de pose ont été respectées.

557. 3° La mise en œuvre doit être conforme aux règles édictées par le fabricant (Civ. 3e, 25 avr. 2007, n° 05-17.838, BPIM 4/07, inf. 276, 3e esp.). Le fabricant doit donc fournir des consignes de pose ou un mode d'emploi (arrêts précités). S'il s'abstient, le poseur n'en est pas moins tenu de se conformer aux règles de l'art ou aux normes susceptibles de concerner la pose du produit… mais alors la question de savoir si l'article 1792-4 s'applique est discutée. L'information sur la destination du produit et les consignes de pose sont, en effet, deux choses différentes (sur l'obligation de conseil du fabricant : Civ. 3e, 31 janv. 1990, n° 88-17.549, Bull. civ. III, n° 39).

558. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est solidairement responsable envers le maître de l'ouvrage, des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage qui a procédé à la mise en œuvre par les articles 1792 et suivants. Il en résulte que l'action en responsabilité dirigée contre l'entrepreneur qui a installé l'EPERS interrompt la prescription contre le fabricant (Civ. 3e, 13 janv. 2010, n° 08-19.075, Bull. civ. III, n° 7). Toutefois, le poseur peut être un sous-traitant, qui, lui, n'est pas tenu des obligations édictées par les articles 1792 et suivants. L'opinion est cependant émise que le fabricant est solidairement tenu des obligations qui pèsent sur l'entrepreneur principal : il peut donc être tenu même s'il fournit un sous-traitant et que c'est ce dernier qui procède à la pose. Un arrêt – statuant il est vrai à propos d'un fournisseur non fabricant au sens de l'article 1792-4 – décide cependant que celui qui fournit le sous-traitant est un tiers à l'égard du maître de l'ouvrage envers lequel il engage sa responsabilité délictuelle (Civ. 3e, 28 nov. 2001, BPIM 1/02, n° 38 ; sur la distinction entre le fabricant et le sous-traitant, V. Civ. 3e, 10 janv. 2001, RDI 2001. 177, et les

observations de P. Malinvaud ; V. aussi : H. PÉRINET-MARQUET, Le fabricant sous-traitant, une hybridation difficile, JCP 1989. I. 3399) ; mais une autre décision laisse la porte ouverte à l'action en garantie décennale contre le fabricant qui a fourni le sous-traitant (Civ. 3e, 29 mars 2006, n° 05-10.219, Bull. civ. III, n° 82). C'est au maître de l'ouvrage qu'il appartient d'établir que les conditions de la solidarité sont réunies, en établissant, notamment, que la pose a été faite conformément aux directives du fabricant (Civ. 3e, 17 juin 1998, préc. *supra,* n° 498). La responsabilité du fabricant est « empruntée » à celle du locateur d'ouvrage, puisqu'il est seulement tenu, solidairement, « des obligations » mises à la charge de ce dernier. Il n'est donc pas exclu qu'il puisse répondre de certains dommages au titre de sa propre responsabilité de fabricant non constructeur (de vendeur de chose mobilière, par exemple). Dans ses rapports avec l'entrepreneur qu'il a fourni, le fabricant est responsable selon le droit commun de la vente (Civ. 3e, 29 mai 2013, n° 11-24.156, BPIM 4/13, inf. 263. – Civ. 3e, 8 juin 2011, n° 09-69.894, Bull. civ. III, n° 93) : l'entrepreneur n'est pas subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 8 juin 2011, n° 09-69.894, préc. – V., à propos de l'action du sous-traitant qui a posé l'EPERS : Civ. 3e, 19 déc. 2007, n° 06-14.572, BPIM 2/08, inf. 138. – Civ. 3e, 8 oct. 2008, n° 07-10.644).

c. - Concours de responsabilités

559. Droit commun de la vente. - Le fabricant d'EPERS, au sens de l'article 1792-4 du code civil, n'en est pas moins un fabricant de chose mobilière (les éléments), qui a la qualité de vendeur à l'égard de celui qu'il fournit. Il répond donc des défauts de la chose conformément au droit commun de la vente de chose mobilière comme c'est le cas d'ailleurs du fabricant ou du fournisseur d'un produit qui n'est pas un EPERS (Civ. 3e, 7 janv. 2016, n° 14-17.033 et n° 14-17.669, BPIM 2/16, inf. 111, qui retient un manquement à l'obligation d'information). Selon la Cour de cassation, l'action de l'acquéreur se transmet aux propriétaires successifs de la chose, alors même qu'il y a une rupture dans la chaîne homogène des contrats : ainsi, le maître de l'ouvrage peut exercer directement l'action de l'entrepreneur contre celui qui a fourni ce dernier (Cass., ass. plén., 7 févr. 1986, JCP 1986. II. 20.616, note Bénabent, D. 1986. 293, note Malinvaud. – Civ. 3e, 7 mars 1990, n° 88-15.668, Bull. civ. III, n° 72 ; 28 mars 2001, n° 434 FS-D, inédit ; 12 déc. 2001, RDI 2002. 92 ; comp. Civ. 3e, 28 nov. 2001, n° 00-13.559, RDI 2002. 92, qui décide que le fabricant qui poursuit le sous-traitant engage sa responsabilité quasi délictuelle envers le maître de l'ouvrage et retient un manquement à son obligation de conseil ; V. l'analyse de ces deux arrêts par MALINVAUD, RDI 2002. 92). Le fondement de cette action est controversé. L'assemblée plénière s'était fondée sur la non-conformité de la chose livrée, qui permettait une action trentenaire (ramenée désormais à cinq ans : C. civ., art. 2224) ; la troisième chambre civile était plutôt favorable à l'action en garantie des vices cachés, qui devait être exercée à bref délai (Civ. 3e, 27 mars 1991, JCP 1992. II. 21935, obs.

Ginestet ; 28 juin 1995, n° 93-17.379, Bull. civ. III, n° 162 ; 17 juill. 1996, BPIM 1/97, n° 41 ; 17 mars 1999, n° 527 D ; le délai est désormais porté à deux ans à compter de la découverte du vice : C. civ., art. 1648, al. 1er). La première chambre, qui a donné l'impression de se rallier à cette solution, s'est cependant référée à la non-conformité dans plusieurs arrêts (Civ. 1re, 16 juin, 13 oct., 27 oct., 8 déc. 1993, D. 1994. Chron. 115, note Bénabent ; dans le même sens : Com. 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 199) ; la troisième chambre a donné l'impression de la suivre (Civ. 3e, 17 nov. 1999, BPIM 1/00, n° 27, qui relève la livraison de tiges non conformes). Sous réserve de cette difficulté (V. sur ce point : MALINVAUD, chron. RDI 1998. 321 s.), il semble que rien n'interdit au maître de l'ouvrage de se prévaloir de l'action de droit commun contre le fabricant d'EPERS : le principe du non-cumul ne devrait pas trouver matière à s'appliquer puisque la responsabilité encourue au titre de l'article 1792-4 est une garantie d'emprunt, non exclusive de la responsabilité personnelle (V. en ce sens : Civ. 3e, 26 juin 2002, RDI 2002. 423, sol. impl., le maître de l'ouvrage ayant invoqué les deux fondements). Les dispositions de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relatives à la « garantie légale de conformité » (C. konsom., art. L. 211-1 s.) ne semblent pas devoir s'appliquer aux rapports entre le maître de l'ouvrage et le fabricant pris en tant que vendeur : le texte qui vise pourtant le fabricant d'un bien meuble, ne concerne que les rapports entre le vendeur et l'acheteur agissant « en qualité de consommateur ».

560. Dans ses rapports avec le fabricant vendeur, l'*entrepreneur* peut invoquer la garantie des vices cachés (Civ. 3e, 29 mai 2013, n° 11-24.156, BPIM 4/13, inf. 263) sauf à exercer son action dans le délai de deux ans prescrit par l'article 1648 du code civil (à bref délai, *avant l'ordonnance du 17 févr. 2005*) à compter de la découverte du vice (sur le délai : Civ. 3e, 26 juin 2002, préc.), ou l'existence de défauts de conformité, le délai courant à compter de la livraison des matériaux (Civ. 3e, 26 juin 2002, RDI 2002. 424, qui statue sur l'action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant). Le fabricant mis en cause sur l'appel en garantie de l'entrepreneur qu'il a fourni répond du vice de la chose (V. Civ. 3e, 15 mars 2006, RJDA 8-9/06, n° 888), et il ne peut pas s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en invoquant le développement de la norme conformément à l'article 1386-11, 5°, du code civil (devenu l'art. 1245-8 issu de l'ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016), lorsque le produit a été vendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux (Civ. 3e, 28 nov. 2001, BPIM 1/02, inf. 34). L'action indemnitaire n'est pas subordonnée à l'exercice préalable de l'action rédhibitoire ou estimatoire (Com. 19 juin 2012, n° 11-13.176, Bull. civ. IV, n° 132 ; RDI 2012. 159). L'obligation de garantie du vendeur-fabricant est renforcée par une *obligation d'information et de mise en garde* au bénéfice de l'entreprise qui a été fournie (Civ. 3e, 4 déc. 2002, BPIM 1/03, inf. 27 ; 18 févr. 2004, RJDA 7/04, n° 801 ; 7 nov. 2006, RDI 2007. 94. – Civ.1re, 28 oct. 2010, n° 09-16.913, Bull. civ. I,

n° 215. – Civ. 3e, 7 janv. 2016, n° 14-17.033 et n° 14-17.669, BPIM 2/16, inf. 111), même si elle est sous-traitante (Civ. 3e, 19 déc. 2007, n° 06-14.572). Mais elle ne s'impose pas entre professionnels de la même spécialité (Civ. 3e, 4 janv. 2006, BPIM 2/06, inf. 112).

561. Produits défectueux. - Le fabricant d'EPERS est aussi un *fabricant de matériaux.* Est-il soumis à la responsabilité résultant des articles 1386-1 et suivants du code civil issus de la transposition de la directive CEE n° 85-534 du 25 juillet 1985 (L. 19 mai 1998 ; V. not. chron. P. MALINVAUD, RDI 1998. 641) devenus, à présent les articles 1245 et suivants ? La loi exclut le fabricant dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 (art. 1386-6 devenu l'art. 1245-5, dern. al.). Il en résulte que le fabricant d'EPERS n'est pas responsable à ce titre. En revanche, le fabricant de matériaux indifférenciés n'est pas exclu du champ d'application de la loi. On s'est demandé si le fabricant non vendeur, par exemple le sous-traitant, qui peut être qualifié de « producteur » au sens de la loi, voire de « poseur » au sens de l'ancien article 1386-8, ou d'incorporateur au sens du nouvel article 1245-7 n'était pas soumis à ces dispositions. Mais le sous-traitant est désormais responsable en application des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil. L'exclusion figurant au dernier alinéa de l'article 1386-6 ancien et de l'article 1245-5 nouveau, semble donc à présent le viser ; toutefois, un doute peut subsister au sujet du « poseur-incorporateur » au sens de l'ancien article 1386-8 du code civil (C. civ., nouv. art. 1245-7) qui peut être un sous-traitant ou un entrepreneur principal qui s'est fourni auprès du producteur.

B - Bénéficiaires des garanties

562. La loi définit plusieurs types de bénéficiaires des garanties : il peut s'agir du maître de l'ouvrage (V. *infra,* n° 563) ou son ayant-cause (V. *infra,* n° 564), de la copropriété (V. *infra,* nos 566 s.) ou les sociétés de construction (V. *infra,* n° 568).

1° - Maître de l'ouvrage

563. Le maître de l'ouvrage est le premier bénéficiaire désigné des garanties (art. 1792) ; c'est lui qui est partie au contrat d'entreprise ; il est le premier propriétaire de l'ouvrage. Le *maître d'ouvrage délégué* n'est qu'un mandataire du maître de l'ouvrage et il ne peut exercer l'action qu'au nom de son mandant dans la mesure des pouvoirs qui lui sont conférés (Civ. 3e, 16 mai 2001, n° 389, BPIM 4/01, n° 253 ; 24 oct. 2007, n° 06-16.504), ce qui implique que le mandat survive à la réception. Le *locataire,* n'est pas titulaire de l'action en garantie (Civ. 3e, 23 oct. 2012, n° 11-18.850, RDI 2013. 95), même si c'est lui qui a commandé les travaux (Civ. 3e, 1er juill. 2009, n° 08-14.717, Bull. civ. III, n° 162) à moins qu'il n'ait reçu un pouvoir du

maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 12 avr. 2012, n° 11-10.380, BPIM 3/12, inf. 237). Dans les marchés publics, le maître d'ouvrage délégué a qualité pour exercer l'action en garantie décennale tant que l'ouvrage n'est pas remis au déléguant (CE 10 avr. 1991, RDI 1991. 336 ; 31 mai 1995, RDI 1995. 746). Une fois l'ouvrage remis, c'est le maître de l'ouvrage qui a qualité pour agir (CE 17 juin 1998, req. n° 149793, Dpt de la Marne, BPIM 5/98, inf. 328. – Civ. 3e, 28 janv. 2009, n° 07-20.891).

2° - Ayants cause du maître de l'ouvrage

564. Au maître de l'ouvrage, il faut assimiler ses ayants cause universels s'il y a lieu (héritiers) et, selon la loi, les *acquéreurs successifs* de l'immeuble (art. 1792 et 1646-1. – Civ. 3e, 21 nov. 1990, n° 89-13.775, Bull. civ. III, n° 242. – Civ. 3e, 17 mars 1999, BPIM 3/99, n° 222. – Civ. 3e, 23 sept. 2009, n° 08-13.470, Bull. civ. III, n° 242), c'est-à-dire les ayants cause à titre particulier du maître de l'ouvrage. Les garanties se transmettent donc comme un accessoire de la chose vendue, et l'acquéreur peut avoir une pluralité de garants, les constructeurs, et le vendeur tenu à garantie. En pratique, il dirigera son action contre ce dernier qui appellera en cause les constructeurs. Le *locataire du maître de l'ouvrage,* qui est un simple créancier de celui-ci et non son ayant cause, n'a pas qualité pour exercer l'action en garantie décennale. Il est tiers au louage d'ouvrage (Civ. 1re, 9 oct. 1962 et la chron. LIET-VEAUX, D. 1963. 1 s.). La Cour de cassation dénie au locataire le droit d'agir en garantie décennale, même lorsqu'il a commandé des travaux pour son compte ; elle lui refuse la qualité de maître de l'ouvrage et considère que l'action en garantie est attachée à la propriété de la chose et non à sa jouissance (Civ. 3e, 1er juill. 2009, n° 08-14.714).

565. La circonstance que le maître de l'ouvrage a cédé le bien ne le prive pas sur la demande de l'acquéreur dirigée contre lui d'exercer l'appel en garantie contre les constructeurs s'il justifie d'un intérêt direct et certain (Civ. 3e, 31 mai 1995, n° 92-14.098, Bull. civ. III, n° 133 ; 17 janv. 1996, RJDA 6/96, n° 823 ; 3 juill. 1996, n° 94-18.503, Bull. civ. III, n° 167 ; V. déjà : Civ. 3e, 26 févr. 1963, Bull. civ. I, n° 122 ; 23 sept. 2009, n° 08-13.470, Bull. civ. III, n° 202 ; V. les arrêts cités à RDI 1987. 352 ; B. BOUBLI, Soliloque sur la transmission de l'action en garantie, JCP 1974. I, n° 2646). Il n'empêche que le maître de l'ouvrage s'est dessaisi de la chose et de l'action correspondante, et que la jurisprudence lui est parfois hostile lorsqu'il entend se prévaloir de la garantie pour son préjudice personnel, antérieur à la vente en particulier, qui lui est parfois contesté (Civ. 3e, 28 nov. 2001, BPIM 1/02, n° 35) ; mais si son préjudice est certain (vente au-dessous de la valeur du bien compte tenu des désordres, par exemple), son droit d'action est admis (Civ. 3e, 23 sept. 2009, préc.). Il en est de même s'il s'est réservé le droit d'action par une clause du contrat de vente (Civ. 3e, 16 nov. 2011, n° 10.17.680, BPIM 1/12, inf. 37) et qu'il invoque un préjudice certain. Le sous-acquéreur peut se prévaloir tant de la garantie décennale que de la

garantie biennale : c'est l'action en garantie du maître de l'ouvrage qui est exercée : si ce dernier a fait une déclaration de sinistre, elle profite à l'acquéreur (Civ. 3e, 23 sept. 2009, préc.), et l'assureur dommages-ouvrage peut appeler les constructeurs en garantie (Civ. 3e, 8 oct. 2008, no 07-15.939). Lorsque le désordre est apparent lors de la vente d'immeuble à construire, l'action de l'acquéreur contre son vendeur obéit normalement aux dispositions de l'article 1642-1 du code civil. Or, il résulte d'un arrêt que lorsque le désordre est apparent pour l'acquéreur, celui-ci peut néanmoins agir en garantie décennale contre le vendeur si le désordre était caché à la réception (Civ. 3e, 28 févr. 2001, no 99-14.848, Bull. civ. III, no 23 ; BPIM 3/01, no 193) ; il peut, également, agir contre le constructeur (Civ. 3e, 23 sept. 2009, préc. – V. en cas de vente après achèvement : Civ. 3e, 9 juill. 2014, no 13-15.923, Bull. civ. III, no 105).

3° - Copropriété

566. Lorsque l'immeuble est sous le régime de la copropriété, l'action appartient au copropriétaire pour les dommages concernant les parties privatives, sous réserve que le syndic soit préalablement informé (Civ. 3e, 15 nov. 1989, Bull. civ. III, no 202 ; 16 mars 1994, no 91-20.128, Bull. civ. III, no 56 ; 17 mars 1999, no 97-19.766, BPIM 3/99, no 218). Toutes les fois que le copropriétaire subit un préjudice personnel, que le dommage affecte les parties privatives et les parties communes (Civ. 3e, 14 mai 1974, Bull. civ. III, no 190 ; 28 avr. 1981, Bull. civ. III, no 83 ; 23 févr. 2000, no 98-17.932, BPIM 3/00, no 179) ou les seules parties communes (Civ. 3e, 18 déc. 1973, Bull. civ. III, no 637 ; 6 mars 1984, Bull. civ. III, no 60 ; 18 mars 1987, RDI 1987. 378 ; 30 juin 1993, no 91-18.696, Bull. civ. III, no 103 ; 20 mai 1998, no 96-14.080, Bull. civ. III, no 105), il peut également exercer l'action.

567. Lorsque les dommages affectent l'ensemble de l'immeuble ou les parties communes, l'action appartient au syndicat (Civ. 3e, 16 mars 1988, Bull. civ. III, no 60 ; 26 mai 1992, nos 89-21.897 et no 90-10.721, Bull. civ. III, no 168 ; 9 déc. 1992, Mon. TP 12 févr. 1993 ; 8 févr. 1995, RDI 1995. 551). La Cour de cassation décide, tantôt que le syndicat peut défendre les intérêts des copropriétaires pour les dommages à l'intérieur des parties privatives (Civ. 3e, 16 mars 1988, préc. ; 20 mai 1988, Bull. civ. III, no 105), tantôt qu'une telle action est irrecevable (Civ. 3e, 16 mars 1994, préc.), mais seul le défendeur qui a invoqué l'irrégularité peut en bénéficier (Civ. 3e, 26 juin 2002, RDI 2002. 419). La différence s'explique : le syndicat n'a pas qualité pour agir lorsque le trouble collectif touche *différemment* les divers copropriétaires (Civ. 3e, 27 sept. 2000, no 98-11.986, RDI 2001. 83). Lorsqu'il agit, le syndic doit être spécialement habilité par l'assemblée générale sous peine d'irrecevabilité (Civ. 3e, 22 nov. 2006, RDI 2007. 91) ; les constructeurs peuvent invoquer cette fin de non-recevoir (Civ. 3e,

12 oct. 1988, D. 1989. 53, note Givord et Giverdon ; 7 nov. 1990, n°s 89-12.380 et n° 89-12.419, Bull. civ. III, n° 222). L'habilitation peut cependant être donnée *a posteriori,* c'est-à-dire en cours d'instance, si le délai de garantie n'est pas expiré (Civ. 3e, 27 janv. 1988, Bull. civ. III, n° 20 ; 9 déc. 1998, n° 97-12.455, BPIM 1/99, n° 60 ; 11 mai 2000, BPIM 4/00, n° 251 ; 7 avr. 2009, n° 07-16.786). Cette ratification ne peut toutefois étendre les pouvoirs du syndic et l'autoriser à demander la réparation d'autres dommages (Civ. 3e, 15 juin 2000, BPIM 5/00, n° 323). L'absence d'habilitation n'empêche pas d'agir en référé (Civ. 3e, 5 févr. 1997, BPIM 1/98, n° 30). L'autorisation d'agir doit être précise (Civ. 3e, 11 mars 1992, Bull. civ. III, n° 83). Mais il est désormais admis que l'autorisation peut viser « tous les désordres immobiliers constatés ou à venir » (Civ. 3e, 12 déc. 2001, RDI 2002. 86), ce qui n'empêche pas que ce sont les dommages qui doivent être visés et non leur cause (Civ. 3e, 26 juin 2002, RDI 2002. 418) ; elle est valable pour tous les constructeurs (Civ. 3e, 4 déc. 2002, n° 00-18.022, Bull. civ. III, n° 248 ; 29 janv. 2003, n° 01-01.483, Bull. civ. III, n° 20) et leurs assureurs (Civ. 3e, 20 juin 2001, n° 99-20.242, Bull. civ. III, n° 80 ; 31 mars 2004, n° 02-19.114, Bull. civ. III, n° 65). Si l'habilitation donnée est irrégulière, seuls les copropriétaires sont fondés à invoquer cette irrégularité (Cass., ass. plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021, Bull. civ., n° 5 ; 23 juin 1999, n° 97-16.176, Bull. civ. III, n° 148 ; 29 janv. 2003, n° 01-01.483, Bull. civ. III, n° 20).

4° - Sociétés de construction

568. Lorsque l'immeuble est sous le régime de la société d'attribution, il est généralement admis, malgré quelques décisions qui peuvent faire hésiter, que l'action appartient à la société et que les associés, qui sont de simples créanciers, n'ont pas qualité pour exercer l'action en garantie contre les constructeurs (pour une société d'attribution en propriété : Civ. 3e, 5 mai 1975, Bull. civ. III, n° 152 ; 13 déc. 1989, Bull. civ. III, n° 229 ; pour une société de location-attribution : Civ. 3e, 6 déc. 1989, Bull. civ. III, n° 220 ; 19 juill. 1995, n° 93-13.395, Bull. civ. III, n° 200 ; 11 oct. 1995, RDI 1996. 219 ; plus généralement, lorsque la société attribue en jouissance les ouvrages qu'elle fait construire : Civ. 3e, 14 mars 2001, SACIS c/ Cts Beauvais, n° 379 FS-D ; V., pour des solutions plus incertaines : Civ. 1re, 28 nov. 1967, D. 1968. 163, obs. Cornu ; 6 mars 1967, Bull. civ. I, n° 69 ; 3 janv. 1969, JCP 1969. II. 15863, note Liet-Veaux. – Civ. 3e, 18 mars 1987, Bull. civ. III, n° 55 ; sur la possibilité, pour l'attributaire, d'exercer l'action en garantie par voie oblique : Civ. 3e, 16 juill. 1986, Bull. civ. III, n° 111). Lorsque la société est une coopérative de construction, l'action a été reconnue aux membres de la société (Civ. 3e, 14 nov. 1970, Bull. civ. III, n° 611).

§ 3 - Conditions propres à la garantie décennale

569. La garantie décennale est encourue pendant dix ans à compter de la réception des travaux (C. civ., art. 1792-4-3). Elle joue dans deux cas : lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination (art. 1792) ; lorsque le dommage affecte la solidité d'un élément d'équipement qui fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert (art. 1792-2 ; depuis l'ordonnance du 8 juin 2005 qui a modifié cet article, il est indifférent que l'ouvrage soit ou non un bâtiment). Il s'agit de conditions alternatives, et non-cumulatives : le second cas de garantie est d'ailleurs subsidiaire : si la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise, ou si cet ouvrage n'est pas rendu impropre à sa destination par le désordre, même s'il a son siège dans un élément d'équipement, alors on recherchera si les conditions du second cas de garantie ne seraient pas réunies. Pourtant, la tendance d'une certaine partie de la doctrine, qui a reçu l'appui de la jurisprudence, a été de distinguer selon la nature des équipements, alors que la loi ne fait pas cette distinction. En outre, la notion de bâtiment, qui figurait dans l'article 1792-2 avant sa modification en 2005, a suscité des difficultés d'interprétation, notamment pour déterminer le champ de l'assurance obligatoire. Une commission a émis diverses propositions (RDI 1998. 1 s.), qui ont été reprises dans un projet de loi (V., en particulier, RDI 2000. 359 et 368 s.). Finalement, l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 a non seulement corrigé le champ d'application de l'assurance obligatoire, mais a aussi modifié les conditions des garanties décennale et biennale. Les garanties légales s'appliquent à la construction d'un ouvrage (V. *infra,* n°s 570 s.) ; cette condition étant remplie, la garantie décennale est encourue dans les deux cas évoqués ci-dessus qui relèvent des articles 1792 (V. *infra,* n°s 580 s.) et 1792-2 (V. *infra,* n°s 584 s.) du code civil.

ACTUALISATION

464, 569. Date de la réception en cas d'autoconstruction et point de départ du délai de la garantie décennale. - Lorsque le vendeur est le constructeur, fait courir le délai de la garantie décennale, la date à laquelle l'ouvrage est utilisable et propre à sa fonction (Civ. 3e, 19 janv. 2017, n° 15-27.068 , Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. Dreveau).

569. Notion d'ouvrage. Garantie applicable. - La construction, sur plusieurs kilomètres, d'une conduite métallique fermée d'adduction d'eau à une centrale électrique constitue un ouvrage et non un équipement. L'intérêt majeur de la qualification d'ouvrage est d'intégrer le champ d'application de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. L'article 1792-2 du code civil, qui prévoit le rattachement à la garantie décennale aux éléments d'équipement indissociables aurait produit le même effet, à ceci près qu'il doit être combiné avec les

dispositions exclusives des garanties spéciales des constructeurs de l'article 1792-7 du code civil afférentes aux éléments d'équipement « dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage » (Civ. 3e, 19 janv. 2017, no 15-25.283, Dalloz actualité 7 févr. 2017, obs. Garcia).

Construction : délai de forclusion de l'article 1792-4-3 du code civil. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion (Civ. 3e, 10 juin 2021, no 20-16.837, D. actu. 21 juin 2021, obs. G. Casu et S. Bonnet).

A - Condition commune aux deux cas d'ouverture de la garantie : construction d'un ouvrage immobilier

570. L'ouvrage désigne à la fois le travail et son résultat (V. *infra,* no 571), il doit être immobilier (V. *infra,* no 572), impliquant un travail de construction (V. *infra,* nos 573 s.) et peut être pris comme un ensemble ou une partie d'un ensemble (V. *infra,* no 579).

1° - Nécessité d'un ouvrage

571. S'agissant du résultat, peu importe la nature de l'ouvrage réalisé. Il peut s'agir d'un bâtiment, d'un ouvrage de génie civil, d'un réseau de VRD (Civ. 3e, 31 oct. 2001, RDI 2002. 84). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait édifice. Ont été considérés comme des ouvrages : un court de tennis (Civ. 3e, 2 mars 1990, RDI 1990. 514) ; des ouvrages de génie civil (Civ. 3e, 12 juin 1991, RDI 1991. 348) ; un mur de soutènement (Civ. 1re, 26 févr. 1991, no 89-11.563, Bull. civ. I, no 75 ; 31 mars 1993, RJDA 11/93, no 894) ; une installation de production d'eau chaude (Civ. 3e, 18 nov. 1992, no 90-21.233, Bull. civ. III, no 298) ; une installation de chauffage à foyer fermé (Civ. 3e, 17 janv. 1996, BPIM 3/96, no 206 ; comp. : 28 févr. 1996, nos 94-17.154 et 94-18.203, Bull. civ. III, no 57, qui en fait un équipement ; 6 févr. 2002, no 00-15.301, BPIM 3/02, inf. 186, qui écarte l'existence de travaux de construction) ; un talus engazonné (Civ. 3e, 3 juill. 1996, RDI 1996. 575, toutefois, s'agissant ici, de génie civil, il faut qu'il y ait « incorporation de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction » : Civ. 3e, 12 juin 2002, RDI 2002. 321) ; un réseau de VRD (Civ. 3e, 17 déc. 1997, no 96-12.209, Bull. civ. III, no 224) ; un silo (Civ. 1re, 20 déc. 1993, RDI 1994. 55 ; 26 mars 1996, RDI 1996. 380 et, sur renvoi : Paris, 24 mars 1999, BPIM 5/99,

n° 371). Toutefois, la jurisprudence n'est pas très claire sur ce point. Un arrêt de la troisième chambre civile range le silo dans la catégorie des équipements et il faut vérifier qu'il relève d'un travail de construction pour que la garantie décennale soit susceptible d'être retenue (Civ. 3e, 20 juin 2001, n° 99-20.188, BPIM 4/01, n° 259, RDI 2001. 520) ; une véranda (Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 179) ; une cheminée (Civ. 3e, 25 févr. 1998, n° 96-16.214, Bull. civ. III, n° 46) ; une clôture de jardin (Civ. 3e, 17 févr. 1999, n° 96-21.149, Bull. civ. III, n° 38) ; une piscine médicale à parois en aluminium, même de dimension modeste, intégrée dans la structure de l'immeuble spécialement adapté pour la recevoir par la création d'un radier (Versailles, 22 janv. 2000, BPIM 2/01, n° 119) ; un aquarium intransportable en raison de son poids et de sa fragilité structurelle (Civ. 3e, 9 févr. 2000, AJDI 2000. 435) ; une serre (Civ. 3e, 2 mars 1999, n° 96-20.497, RDI 1999. 258) ; un ensemble composé d'une citerne et d'un poste de livraison de carburant avec les canalisations nécessaires (Civ. 3e, 19 juill. 2000, n° 98-20.111 ; des carrelages fixés à demeure par mortier ou produit d'encollage (Versailles, 29 janv. 2001, BPIM 3/01, n° 192) ; une rénovation importante (Civ. 3e, 24 janv. 2001, RDI 2001. 168. – Paris, 31 janv. 2001, RDI 251) ; un système de climatisation sophistiqué (Civ. 3e, 28 janv. 2009, n° 07-20.891. – Civ. 3e, 24 sept. 2014, n° 13-19.615 ; un ravalement assurant l'étanchéité (Civ. 3e, 4 avr. 2002, RDI 2002. 234) ; une installation de géothermie (Paris, 12 sept. 2002, RDI 2002. 543) ; l'équipement frigorifique d'un abattoir (Civ. 3e, 18 juill. 2001, n° 99-12.326, RDI 2001. 517) ; un caveau funéraire (Civ. 3e, 17 déc. 2003, n° 02-17.388, Bull. civ. III, n° 231) : un enrochement (Civ. 3e, 24 mai 2011, n° 10-17.106, RDI 2011. 459. – Rappr. : Civ. 3e, 20 mai 2014, n° 13-14.803, BPIM 4/14, inf. 257) ; une terrasse en bois fixée dans le mur de façade d'une maison et reposant sur des fondations (Civ. 3e, 7 nov. 2012, n° 11-25.370, Bull. civ. III, n° 160).

2° - Ouvrage immobilier

572. En principe, la nature immobilière de l'ouvrage est caractérisée par l'attache à perpétuelle demeure. Toutefois, la Cour de cassation retient le caractère immobilier d'ouvrages importants, dont le déplacement implique des moyens considérables : un silo, qui peut être rivé aux fondations ou assis sur celles-ci (Civ. 1re, 20 déc. 1993, n° 91-21.434, Bull. civ. I, n° 374) ; une serre assise sur des fondations (Civ. 3e, 2 mars 1999, n° 96-20.497, Bull. civ. I, n° 72) ; un aquarium intransportable en raison de son poids et de sa fragilité (Civ. 3e, 9 févr. 2000, AJDI 2000. 435) ; une véranda qui comporte des parties fixes et mobiles (Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 179). En revanche, ne présentent pas un caractère immobilier : une maison mobile (Civ. 3e, 28 avr. 1993, RDI 1993. 379) ; un bateau-logement (TGI Nanterre, 21 juin 1996, RDI 1996. 575) ; un barbecue accolé qui ne comporte pas de travaux en sous-œuvre

(Civ. 3e, 7 oct. 2008, n° 07-17.800, RDI 2009. 120) ; un abri de piscine repliable et mobile (Civ. 3e, 30 mars 2011, n° 10-10.766, BPIM 3/11, inf. 213).

3° - Ouvrage impliquant un travail de construction

573. L'ouvrage désignant, outre la chose, le travail qui contribue à la réaliser, ce travail doit être celui d'un constructeur (art. 1792) ; il s'entend donc d'un travail de construction. Une distinction est à faire selon que l'on réalise la chose ou que l'on travaille sur un existant.

ACTUALISATION

573 s. Modestes travaux et garantie décennale. - Ne constituent pas un élément constitutif de l'ouvrage, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux qui correspondent à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste ; ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale instituée par l'article 1792 du code civil (Civ. 3e, 28 févr. 2018, n° 17-13.478, D. 2018. 510 ; RDI 2018. 466 ; BICC n° 884, 15 juin 2018).

574. Réalisation de la chose. - Lorsqu'il y a réalisation de la chose, c'est-à-dire transformation du sol (édification d'un bâtiment, création de VRD), il ne devrait pas y avoir de problème : la chose et le travail se confondent, la garantie doit jouer. Toutefois, la Cour de cassation semblait exiger, avant l'ordonnance de 2005 qui a fait disparaître toute référence au « bâtiment », que le travail de « construction » fût un travail de « bâtiment ou de génie civil ». Elle a décidé, en effet, à propos des équipements, qu'ils doivent relever des « travaux de construction soumis à la garantie légale » (Civ. 3e, 22 juill. 1998, n° 95-18.415, Bull. civ. III, n° 170 ; 23 juin 2001, BPIM 4/01, n° 259 ; 31 oct. 2001, RDI 2001. 85, pour l'installation d'un chauffage), et elle a suggéré, toujours à propos des équipements, que ces travaux s'entendent de « travaux de bâtiment ou de génie civil » (Civ. 3e, 4 nov. 1999, Bull. civ. III, n° 209, RDI 2000. 57). On pouvait donc penser que certains ouvrages, non réalisés selon des techniques de bâtiment ou de génie civil, pouvaient échapper à la garantie décennale, et ceci indépendamment du dommage les affectant (Civ. 3e, 14 sept. 2005, n° 04-11.486, Bull. civ. III, n° 165. – Civ. 3e, 13 avr. 2010, n° 09-57.329, BPIM 3/10, inf. 220, à propos d'un « enrochement »). Reste à savoir si l'ordonnance du 8 juin 2005 change la donne. C'est, à notre avis, peu probable : les travaux de construction peuvent être de bâtiment ou de génie civil ; c'est le mode opératoire qui importe. La jurisprudence, qui considère que les silos, qui ne sont cependant pas, rigoureusement, le fruit de travaux de bâtiment ou de génie civil, sont des ouvrages soumis à la décennale (et même des « bâtiments » pour la première chambre civile) invite donc à la prudence. On peut aussi

se demander si la jurisprudence qui insiste sur l'assise immobilière de l'ouvrage ne privilégie pas ce facteur et si elle n'en fait pas l'élément révélateur de l'existence d'un travail de construction (existence de fondations, même si le silo est seulement « rivé » à celles-ci : Civ. 1re 20 déc. 1993, n° 91-21.434, Bull. civ. I, n° 374 ; dans le même sens, à propos d'une serre assise « sur des fondations… » et dont le mode d'implantation était « une immobilisation par incorporation au sol » : Civ. 3e, 2 mars 1999, RDI 1999. 258 ; V. aussi : Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 179). Un arrêt soumet à la garantie décennale l'installation frigorifique comportant une salle des machines qui alimente les réseaux desservant les autres locaux, le froid étant transporté par deux réseaux indépendants de tuyauterie (Civ. 3e, 18 juill. 2001, BPIM 6/01, n° 374), mais un autre exclut du champ de la garantie l'installation d'un système de production d'eau chaude (Civ. 3e, 26 avr. 2006, n° 05-13.971, Bull. civ. III, n° 101).

575. Travail sur existant. - Dans ce cas, il y a lieu de faire des distinctions :

576. En cas de *modification structurelle* de l'existant, il ne fait guère de doute qu'il y a construction d'ouvrage : surélévation (Paris, 23 janv. 1990, RDI 1990. 372), rénovation lourde (Civ. 3e, 30 mars 1994, RDI 1994. 457 ; 17 déc. 1996, BPIM 1/97, inf. 39 ; V. *supra,* n° 571), agrandissement (Versailles, 4 déc. 1987, D. 1989. 134, note Karila), restauration d'une salle de cinéma (Civ. 3e, 4 juill. 1988, Mon. TP 15 juill. 1988). L'importance des travaux est un critère à ne pas négliger (Civ. 3e, 26 janv. 2005, n° 03-14.427). Un arrêt a cependant jugé que des travaux d'aménagement n'étaient pas des travaux de construction (Civ. 3e, 15 déc. 1992, Gaz. Pal. 1993. 2. 482, note Plancqueel), tandis qu'un autre a estimé que d'importants travaux de reprise des désordres constituent un ouvrage au sens de la loi (Civ. 3e, 26 janv. 2005, n° 03-14.427 ; même sens, après une catastrophe naturelle : Civ. 3e, 13 déc. 2011, n° 11-10.014, BPIM 1/12, inf. 38).

577. En cas *d'adjonction d'un élément nouveau* à la construction, la tendance est de considérer que le nouvel élément est un ouvrage lorsqu'il est fait appel à des techniques de construction et non de pose (sur l'exclusion des techniques de pose : Civ. 3e, 26 avr. 2006, n° 05-13.971, Bull. civ. III, n° 101). La règle s'applique à des aménagements de *structure* : modification de toiture par apport d'éléments nouveaux tels que chevrons, voliges, liteaux, et panne faîtière (Civ. 3e, 9 nov. 1994, n° 92-20.804, Bull. civ. III, n° 184) ; installation d'une cheminée avec conduit maçonné, sortie en toiture et système de ventilation (Civ. 3e, 25 févr. 1998, Bull. civ. III, n° 46. – Civ. 3e, 6 juill. 2010, n° 09-14.328, BPIM 5/10, inf. 376) ; système d'isolation thermique impliquant des travaux de maçonnerie (Paris, 10 févr. 2000, RDI 2000. 344 ; *contra :* Civ. 3e, 26 juin 2002, RDI 2002. 416). Elle s'applique également à l'adjonction *d'éléments d'équipement* : chaudière dont l'évaporateur est associé à une

cuve enterrée (Civ. 3e, 18 nov. 1992, n° 90-21.233, Bull. civ. III, n° 298) ; chaudière à foyer fermé (Civ. 3e, 17 janv. 1996, BPIM 3/96, n° 206 ; V. aussi, *a contrario,* pour un insert ajouté à un existant sans travaux de maçonnerie : Civ. 3e, 6 févr. 2002, RDI 2002. 149 ; rappr. Civ. 3e, 18 déc. 2002, BPIM 1/03, n° 28, qui censure une décision qui avait retenu que l'insert était un équipement dissociable). En revanche, il a été jugé que des travaux de « rejointoiement » d'un mur ne sont pas des travaux de construction, car ils ne contribuent pas à la restauration du mur (Civ. 3e, 23 févr. 2000, n° 98-16.250, RDI 2000. 344) ; que le simple remplacement d'une chaudière ne constitue que la pose d'un élément d'équipement relevant de la garantie biennale (Civ. 3e, 11 mars 1992, n° 90-15.633, Bull. civ. III, n° 78 ; 28 févr. 1976, Bull. civ. III, n° 57).

578. En cas de *réparation ou de rénovation de façade,* la Cour de cassation distingue les travaux ayant une fonction esthétique de ceux destinés à préserver la pérennité de l'existant, ces derniers seuls relevant de la garantie décennale. Ainsi, il a été jugé que relève de la garantie décennale le ravalement ayant une *fonction d'étanchéité* (Civ. 3e, 3 mai 1990, n° 88-19.642, Bull. civ. III, n° 105 ; 18 déc. 1996 et 28 janv. 1997, RDI 1997. 238 ; 12 janv. 2005, n° 03-16.813. – Civ. 3e, 4 avr. 2013, n° 11-25.198, BPIM 3/13, inf. 200. – Paris, 6 mars 1991 et 8 mars 1991, RDI 1991. 349 ; *contra :* lorsque les dommages trouvent leur cause dans un défaut d'entretien de la façade : Civ. 3e, 7 avr. 2009, n° 08-10.551) ; même solution à propos d'un ravalement ayant une fonction pérenne et considéré comme un ouvrage, bien qu'il ait un autre objet que l'étanchéité (Civ. 3e, 20 juill. 1999, RDI 2000. 55). En revanche, elle décide que ne relèvent pas de la garantie décennale les ravalements ayant une fonction *purement esthétique* (peinture sur façade : Civ. 3e, 13 janv. 1988, RDI 1988. 349 ; 7 juill. 1993, RDI 1994. 75 ; 29 janv. 1997, RGDA 1997. 515, à propos d'une simple application de peinture). Un arrêt du 29 janvier 2000 (BPIM 2/00, n° 101) relève que le verdissement de façade est un désordre esthétique, et il précise que l'isolation de façade est un équipement : les cloques et fissurations l'affectant peuvent engager la responsabilité décennale, mais à condition que l'ouvrage (c'est-à-dire ici le bâtiment), et pas seulement l'équipement, soit impropre à sa destination. Un arrêt précédent (Civ. 3e, 17 nov. 1999, BPIM 1/00, n° 29) avait cependant jugé que l'impropriété à « sa » destination d'une pierre de façade suffisait à engager la responsabilité décennale. Un troisième arrêt, qui a donné lieu à un problème d'interprétation (Civ. 3e, 9 févr. 2000, n° 98-13.931, RDI 2000. 180, obs. Malinvaud), a écarté la garantie décennale à propos d'un revêtement assurant « l'imperméabilisation » d'une façade. Cet arrêt a suggéré une distinction entre « étanchéité » et « imperméabilisation » (MALINVAUD, *loc. cit.*) ; il faut surtout noter que la Cour de cassation a censuré la cour d'appel, parce qu'elle avait appliqué l'article 1792 alors que le demandeur s'était fondé sur la responsabilité de droit commun ; la troisième chambre civile est très sévère en cas de changement, par le juge, du fondement de la demande (Civ. 3e, 20 déc. 2000, n° 99-

15.101, Bull. civ. III, n° 193). Le Conseil d'État décide que les travaux de peinture qui n'ont pas été effectués à l'occasion de la construction ou de la reconstruction de l'immeuble, ne sont pas des ouvrages soumis à la garantie décennale (CE 18 juin 1997, req. n° 126612, OPHLM de la ville du Havre, BPIM 4/97, n° 263). Les parties peuvent convenir de ranger un ravalement dans la catégorie des ouvrages relevant de la garantie décennale (Versailles, 25 févr. 1995, BPIM 1/97, n° 51). Mais cette convention n'est pas opposable à l'assureur, sauf si le ravalement est effectivement un ouvrage (Civ. 3e, 24 janv. 2001, RDI 2001. 169 ; 26 mars 2008, n° 07-13.879 ; V. aussi *infra,* n° 646).

4° - Ouvrage pris comme un ensemble ou la partie d'un ensemble

579. L'ouvrage est normalement un *ensemble d'éléments constitutifs et d'éléments d'équipement* (art. 1792). Dans le premier cas de garantie décennale (V. *infra,* nos 580 s.), c'est la « solidité » de l'ouvrage et surtout l'impropriété à « sa » destination qui donnent lieu à garantie. L'ouvrage peut aussi être un sous-ensemble (bloc sportif d'une résidence collective, VRD, clôtures). L'ouvrage peut être également constitué par la partie d'un ensemble. L'exemple le plus topique est celui des travaux sur existant. Toutefois, lorsqu'un équipement est simplement posé, il ne s'agit pas de la construction d'un ouvrage. La Cour de cassation, qui devrait appliquer le droit commun en la matière, applique parfois la garantie biennale (V. *infra,* n° 589, à propos des chaudières). Compte tenu de la distinction faite par la jurisprudence et désormais légalisée (art. 1792-7) entre les équipements, selon qu'ils sont ou non à usage industriel ou professionnel (V. les arrêts du 17 juill. 1998 et du 4 nov. 1999, *infra,* n° 582), il y a lieu de penser que l'ouvrage en tant qu'ensemble comporte deux catégories d'équipements : ceux qui relèvent de l'ensemble construction et sont susceptibles d'être soumis à la décennale ; ceux qui ne sont pas soumis à celle-ci. C'est, semble-t-il, la « fonction » des équipements qui est à considérer et non leur technique d'installation (V. *infra,* nos 582 et 583).

B - Premier cas de garantie décennale : ouvrage impropre à sa destination ou dont la solidité est compromise (C. civ., art. 1792)

580. La garantie décennale est encourue selon l'article 1792 du code civil, lorsque la solidité de l'ouvrage est compromise (V. *infra,* n° 581) ou lorsqu'il est impropre à sa destination (V. *infra,* nos 582 s.). Ce n'est pas le siège du désordre qui importe, mais son degré de gravité. Le juge doit vérifier que cette condition est remplie (Civ. 3e, 7 déc. 2005, n° 04-12.931, Bull. civ. III, n° 244 ; 21 oct. 2008, n° 04-15.934). Des désordres esthétiques, même généralisés, ne répondent pas à la condition de gravité

du désordre permettant la mise en œuvre de la garantie décennale (Civ. 3e, 13 févr. 2008, n° 06-18.357). L'origine des désordres est indifférente (Civ. 3e, 28 févr. 2001, RDI 2001. 170 . – V. MALINVAUD, *in* RDI. 2012. 569). Toutefois, *la Cour de cassation, tient compte parfois de la seule non-conformité à certaines normes* ; ainsi en est-il des normes parasismiques obligatoires dans une région exposée au risque de séisme (Civ. 3e, 11 mai 2011, n° 10-11.713 , Bull. civ. III, n° 706. – *Contra* pour une norme non obligatoire : Civ. 3e, 1er déc. 2010, n° 09-15.282 , Bull. civ. III, n° 209) ou de la non-conformité aux normes de sécurité notamment pour des ascenseurs (Civ. 3e, 6 juill. 2010, n° 09-66.757 , BPIM 6/10, inf. 378. – CE 23 juill. 2010, req. n° 315034 , BPIM 5/10, inf. 377), à condition, semble-t-il, que ces non-conformités soient cachées à la réception (V. Civ. 3e, 27 janv. 2010, n° 08-20.938 , RDI 2010. 270).

ACTUALISATION

580. Contrat d'entreprise : application des normes parasismiques. - Le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques sismiques, modifié par le décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000, rend les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants (Civ. 3e, 19 sept. 2019, n° 18-16.986, D. actu. 9 oct. 2019, obs. F. Garcia).

1° - La solidité de l'ouvrage est compromise

581. L'atteinte à la solidité s'entend de celle qui affecte « l'ouvrage ». Elle n'implique pas sa « ruine ». Il suffit que des détériorations importantes soient relevées sur des éléments de l'ouvrage qui, en pratique, sont des éléments constitutifs. Cette question relève de l'appréciation des juges du fond.

- À titre d'exemples, *caractérisent l'atteinte à la solidité* : des dommages sur une cheminée extérieure (Civ. 3e, 29 nov. 1960, Bull. civ. III, n° 518) ; des carrelages à refaire (Civ. 3e, 9 déc. 1975, Bull. civ. III, n° 363) ; des nids-de-poule dans un garage (Paris, 28 sept. 1978, RDI 1979. 70) ; un défaut d'étanchéité (Civ. 3e, 12 mars 1986, Bull. civ. III, n° 28) ; l'infestation d'un chalet en bois par des capricornes (Civ. 3e, 25 sept. 2002, RDI 2002. 544 ; rappr. Civ. 3e, 26 juin 2002, RDI 2002. 424) ; l'implantation partielle sur le terrain d'autrui et toute erreur d'implantation qui entraîne un risque de démolition (Civ. 3e, 19 déc. 1972, Bull. civ. III, n° 688 ; 27 avr. 1994, RGAT 1984. 620. – Civ. 3e, 12 juin 2013, n° 12-19.103 , BPIM 3/97, inf. 192) ; sur ce point toutefois, certains arrêts ont retenu la responsabilité de droit commun (Civ. 3e, 20 janv. 1999, n° 76 D ; 17 mars 1999, n° 97-14.205 , BPIM 3/99, n° 209) ou l'effet de purge de la réception sans réserve (Civ. 3e, 28 févr. 2012, n° 11-13.670 , BPIM 3/12, inf. 238) bien que la tendance jurisprudentielle soit en faveur de la démolition de la

partie d'ouvrage qui empiète (Civ. 3e, 9 juill. 2014, n° 13-15.483 et Civ. 3e, 18 juin 2014, n° 13-10.404, BPIM 5/14, inf. 327) ; le non-respect des règles parasismiques facteur de perte de l'ouvrage par séisme (Civ. 3e, 25 mai 2005, n° 03-20.247, Bull. civ. III, n° 113 ; V. *supra* n° 615) ; les nuisances olfactives et acoustiques chez le voisin auxquelles il ne peut être remédiées que par des travaux importants (Civ. 3e, 31 mars 2005, n° 03-14.217, Bull. civ. III, n° 76) ; des excavations de terre ayant aggravé la pente d'un talus et entraînant un risque d'éboulement susceptible d'endommager l'ouvrage (Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 11-16.943, Bull. civ. III, n° 116).

- *Ne caractérisent pas l'atteinte à la solidité* : des dommages affectant une cheminée intérieure (Civ. 1re, 17 déc. 1964, Bull. civ. I, n° 577) ; des défauts affectant les marbres et parquets (Paris, 29 mai 1981, RDI 1982. 81) ; des fissures filiformes sur carrelages (Civ. 3e, 10 janv. 2001, n° 99-12.409, BPIM 2/01, qui en fait des équipements dissociables) ; des éclats de ciment sur les murs (Civ. 3e, 19 juin 1984, RDI 1985. 62) ; des fissurations de murs extérieurs et intérieurs en raison, selon la cour d'appel, de leur importance et de leur caractère évolutif, ces constatations étant insuffisantes (Civ. 3e, 23 oct. 2002, BPIM 6/02, n° 393).

2° - L'ouvrage est impropre à sa destination

582. Siège du désordre. - Selon l'article 1792, il suffit que l'ouvrage soit impropre à sa destination ; peu importe que le désordre ait son siège dans un « élément constitutif » ou dans un « élément d'équipement ». C'est l'ouvrage, pris dans son ensemble (Civ. 3e, 28 févr. 1996, n° 97-17.154, Bull. civ. III, n° 57 ; 10 avr. 1996, RDI 1996. 380), qui doit être impropre à sa destination naturelle ou convenue (V. Dalloz Action Droit de la construction 2000/2001, sous la dir. de MALINVAUD, n° 7238). L'impropriété de l'ouvrage à sa destination relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond (Civ. 3e, 8 oct. 1997 et 19 nov. 1997, RDI 1998. 96). Mais il est probable que le contrôle de la Cour de cassation va se renforcer avec l'évolution de la notion d'équipement. D'ores et déjà l'on observe un contrôle de motivation renforcé (Civ. 3e, 20 mai 2015, n° 20.15-107 : exiguïté d'une rampe de garage. – Civ. 3e, 7 juill. 2015, n° 14-21.805). L'appréciation « *in abstracto* », tient compte de la destination « normale » de l'ouvrage (exemple des rampes de garage préc.) ; l'appréciation « *in concreto* » tient compte de la destination « voulue » de l'ouvrage (exemple : niveau d'excellence acoustique requis pour un appartement d'exception : Civ. 3e, 10 oct. 2012, n° 10-28.309 et n° 10-28.310, Bull. civ. III, n° 140).

– *Il n'y a pas de problème lorsque le désordre affecte un élément constitutif* (rampe de garage ne permettant pas le passage des véhicules d'usage normal : Civ. 3e, 9 juin 1999, BPIM 4/99, n° 293. – Civ. 3e, 20 mai 2015, préc. ; défaut d'étanchéité des

façades : 8 oct. 1997, RDI 1998. 96 ; gouttières rouillées : Paris, 9 mars 2000, RDI 2000. 346 ; défaut d'isolation phonique : Civ. 3e, 27 mars 1999, BPIM 3/99, n° 220, si l'on estime du moins qu'il s'agit d'une atteinte à un élément constitutif). Au sujet de l'isolation thermique, il faut relever que la performance énergétique des bâtiments voulue par la loi Grenelle I (n° 2009-967 du 3 août 2009) et le décret du 26 octobre 2010 (n° 2010-1269), fait désormais l'objet d'une réglementation thermique qui s'applique à tous les bâtiments dont le permis de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2013 (V. G. DURAND-PASQUIER, RDI 2013. 184) et que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 précise les conditions dans lesquelles l'impropriété à la destination en matière de performance énergétique peut être retenue (CCH, art. 111-13).

– *Lorsque le désordre affecte un élément d'équipement, la loi de 1978* ne fait pas de distinction selon la nature des équipements et, sous la réserve de ce qui sera dit des équipements industriels (V. *infra*), la jurisprudence est toujours en ce sens ; peu importe, en particulier, que les éléments soient dissociables ou non (Civ. 3e, 23 janv. 1991, n° 88-20.221, Bull. civ. III, n° 30 ; 2 juill. 2002, RDI 2002. 417. – Civ. 3e, 5 juill. 2011, n° 10-19.274. – Civ. 3e, 7 juill. 2015, n° 14-21.805. – Civ. 3e, 7 avr. 2016, n° 15-15.441, BPIM 3/16, inf. 183. – Civ. 3e, 30 juin 2016, n° 15-17.146, pour un insert ayant contribué à un incendie. – Civ. 3e, 13 juill. 2016, n° 15-20. 712 et n° 15-24.654, pour des carrelages de façade décollés compromettant la sécurité. – Rappr. : Civ. 3e, 23 mai 2006, RDI 2006. 378 ; CE 8 déc. 1999, BPIM 3/00, inf. 180), principe qui devrait subsister car c'est l'impropriété de « l'ouvrage » (où à tout le moins d'une partie d'ouvrage : Civ. 3e, 12 juill. 1995, BPIM 1/96, inf. 52), à sa destination qui importe (V. MALINVAUD [dir.], Droit de la construction 2014/2015, Dalloz action, n° 473.390), cette destination résultant de l'ouvrage lui-même ou étant contractuellement définie (risque d'explosion dû au système de décilage d'un silo : Civ. 1re, 26 mars 1996, RDI 1996. 380 ; V. aussi Civ. 3e, 24 juin 2001, BPIM 4/01, n° 259 ; défectuosité du dallage d'un entrepôt : Civ. 3e, 11 févr. 1998, RDI 1998. 261 ; installation de production d'eau chaude sanitaire : 28 févr. 1996, n° 472 P, RJDA 12/96, n° 1246 ; carrelage d'une piscine : 7 mai 1997, BPIM 4/97, n° 264 ; chaudière défectueuse : 18 nov. 1992, n° 90-21.233, Bull. civ. III, n° 298 ; parquet sonore : 19 nov. 1997, BPIM 1/98, n° 33 ; portes palières découpables « au couteau » : 3 févr. 1999, BPIM 2/99, n° 138 ; 2 oct. 2001, RDI 2002. 86 : enduit de façade d'épaisseur insuffisante ; 2 juill. 2002, RDI 2002. 417, à propos d'une fosse sceptique ; revêtement de sol en graviers, inadapté : Paris, 23 févr. 2000, RDI 2000. 346 ; équipements défectueux d'un immeuble destiné à recevoir du matériel informatique : 17 déc. 1997, RDI 1998. 261 ; insuffisance phonique : Civ. 1re, 24 mars 1992, n° 89-13.756, Bull. civ. I, n° 91 ; 16 sept. 2003, RDI 2003. 581 ; 26 mars 2008, n° 07-12.022. – Cass., ass. plén., 27 oct. 2006, Bull. civ., n° 12 ; insuffisance

thermique : Civ. 3e, 27 sept. 2000, BPIM 6/00, inf. 370 ; insert de cheminée défaillant ayant contribué à causer un incendie : Civ. 3e, 30 juin 2016, n° 15-17.146) ; l'impropriété peut résulter d'une absence d'ouvrage (Civ. 3e, 22 mai 2012, n° 11-12.229 , RDI 2012. 446).

– Mais la jurisprudence qui s'est inspirée des travaux de la commission sur le champ de l'assurance construction (RDI 1998. 1 s.), a fait la distinction entre les *équipements à vocation industrielle* et les *équipements à vocation purement immobilière.* Ainsi, à propos d'une machine à soupe d'une porcherie (Civ. 3e, 22 juill. 1998, n° 95-18.415 , Bull. civ. III, n° 170, D. 1999. 201 , RDI 1998. 644, obs. Malinvaud , JCP 1998. II. 10183, obs. H. Périnet-Marquet ; 29 janv. 2003, n° 01-13.636 , RDI 2003. 187, obs. Malinvaud), et d'un système permettant l'automatisation de la fabrication du champagne (Civ. 3e, 4 nov. 1999, BPIM 1/00, n° 28), il a été jugé que ces équipements devaient constituer des *travaux de construction* et, spécialement dans le second arrêt, qu'ils devaient résulter de travaux de bâtiment ou de génie civil pour que la responsabilité décennale soit encourue. Un arrêt rendu à propos d'un silo (Civ. 3e, 24 juin 2001, BPIM 4/01, n° 259, préc.) est dans ce sens. Il résulte de cette jurisprudence que les désordres affectant des équipements *ne relevant pas de la fonction construction* ne peuvent être pris en considération pour apprécier l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, pourtant contractuellement convenue entre les parties (machine à soupe destinée à l'alimentation des porcs : Civ. 3e, 22 juill. 1998, Bull. civ. III, n° 170, RDI 1998. 644 ; 29 janv. 2003, RDI 2003. 187 ; système d'automatisation de la fabrication du champagne : Civ. 3e, 4 nov. 1999, n° 98-12.510 , Bull. civ. III, n° 209 ; Installation de machines à laver : Civ. 3e, 28 mars 1979, Bull. civ. III, n° 79 ; système de production d'eau chaude seulement posé : Civ. 3e, 26 avr. 2006, n° 05-13.971 , Bull. civ. III, n° 101 ; traitement du jus en période de production du vin : Civ. 3e, 11 mai 2006, n° 05-13.191 , Bull. civ. III, n° 115). En revanche, les équipements relevant de la *fonction construction* engagent la responsabilité décennale pour impropriété à la destination, lorsqu'ils sont défectueux, ainsi qu'en attestent les arrêts précités à propos de l'affaissement du dallage d'un entrepôt, des carrelages d'une piscine, etc.

ACTUALISATION

582. Garantie décennale et élément d'équipement dissociable ou non. - La Cour de cassation réitère sa jurisprudence (Civ. 3e, 15 juin 2017, n° 16-19.640 , publié au Bull.) en jugeant que des désordres affectant des éléments d'équipement, qu'ils soient dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale dès lors que ces derniers ont pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination (Civ. 3e, 14 sept. 2017, n° 16-17.323 , Dalloz actualité, 26 sept. 2017, obs. Garcia).

583. Ordonnance du 8 juin 2005. - L'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 a créé un article 1792-7 dans le code civil, qui dispose que « ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d'équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ». Le texte tient compte, non du mode d'installation de l'équipement, comme l'avait fait la jurisprudence, mais de sa destination : dès lors qu'il a pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, l'équipement défectueux ne peut engager la responsabilité décennale du constructeur pour impropriété de l'ouvrage à sa destination. Cette option est discutable. La jurisprudence citée plus haut n'était certes pas de nature à entraîner une approbation sans réserve : une salle de spectacle dont l'isolation phonique n'était pas satisfaisante pouvait échapper à la garantie ; mais la nature du travail d'isolation permettait d'espérer une appréciation réaliste des juges, pour peu qu'il fût qualifié de « travail de construction » ; même observation pour les procédés de sécurisation des personnes et des biens qui s'imposent compte tenu de la destination de certains ouvrages, en particulier lorsqu'ils sont ouverts au public. Une lecture restrictive, et en tout cas littérale de l'article 1792-7 du code civil, conduit à la conclusion que les équipements qui ont une fonction exclusivement professionnelle libèrent leur constructeur de toute garantie décennale, et de l'assurance obligatoire qu'elle entraîne. On ne voit que trois moyens, au demeurant aléatoires, d'éviter cet écueil : considérer que l'équipement n'a pas pour fonction « exclusive » l'exercice de l'activité professionnelle, mais dans certains cas l'exercice est périlleux ; réintroduire la fonction « construction » dans le processus d'installation de l'équipement, comme l'avait fait la jurisprudence : mais cette possibilité risque d'être fermée lorsque la fonction exclusivement professionnelle de l'équipement est certaine ; faire de l'équipement un ouvrage ou une partie d'ouvrage (cas de l'isolation phonique d'une salle de concert) ; mais cette requalification est-elle envisageable?

C - Deuxième cas de garantie décennale : le désordre affecte un équipement indissociable de l'ouvrage (C. civ., art. 1792-2)

584. L'ouvrage peut ou non être un bâtiment. - Avant sa modification par l'ordonnance du 8 juin 2005, l'article 1792-2 ne s'appliquait qu'aux éléments d'équipement d'un bâtiment. Cette précision était d'autant moins discutable qu'elle figurait, et figure toujours, dans l'article 1793 relatif au marché à forfait. Mais la garantie décennale étant couverte par l'assurance obligatoire instituée par la loi du 4 janvier 1978, la question du champ d'application de l'obligation d'assurance qui ne s'appliquait qu'aux bâtiments, et surtout des garanties souscrites, a suscité, dès l'origine, un débat sur la notion. L'article A 242-1 du code des assurances avait proposé une définition du bâtiment ; mais le texte a été annulé par le Conseil d'État (CE 30 oct. 1979, RDI 1980. 30). L'opinion a alors été émise qu'il s'agissait de l'espace qui sert d'abri à l'homme (V.,

pour des approches analogues ou voisines : MALINVAUD et JESTAZ, La notion de travaux de bâtiment, RDI 1985. 217 ; avis du COPAL, Le Moniteur 21 févr. 1986 ; rapport sur le champ d'application de l'assurance construction : RDI 1998. 1 s.). Statuant en matière d'assurance, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'était un « bâtiment » tout ouvrage immobilier construit à l'aide de techniques de travaux de bâtiment (Civ. 1re, 26 févr. 1991, n° 89-11.563, Bull. civ. I, n° 75). Cette formule a été reprise par la troisième chambre civile (Civ. 3e, 16 juin 1993, n° 91-21.226, D. 1994. 413, note R. Raffi ; AJDI 1993. 867 ; RDI 1993. 513, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; Civ. 3e, 26 janv. 1999, BPIM 2/99, n° 142). Ainsi ont été assimilés à un bâtiment en raison de ce critère et, en pratique, pour les besoins de la garantie par l'assureur : un silo (Civ. 1re, 19 déc. 1989, RDI 1990. 223 ; 20 déc. 1993, n° 91-21.434 Bull. civ. I, n° 374 ; 26 mars 1996, RDI 1996. 380, *contra :* Civ. 3e, 24 juin 2001, RDI 520) ; un court de tennis (9 mai 1994, n° 91-20.175, Bull. civ. I, n° 167) ; une piscine (Civ. 1re, 14 juin 1989, RDI 1989. 482. – Dijon, 9 sept. 1993, RDI 1994. 471) ; un mur de soutènement (Civ. 1re, 26 févr. 1991, n° 89-11.563, Bull. civ. I, n° 75 ; 31 mars 1993, Bull. civ. I, n° 153. – Civ. 3e, 16 juin 1993, n° 91-21.226, Bull. civ. III, n° 85) ; une dalle de béton armé (Civ. 1re, 30 janv. 1996, RGDA 1996. 392) ; des VRD (Civ. 3e, 6 janv. 1999, BPIM 2/99, n° 142. – Paris, 14 déc. 1990, RDI 1991. 80). Pour la première chambre civile, il était indifférent que l'ouvrage réalisé selon des techniques de travaux de bâtiment fût ou non à vocation industrielle ou commerciale (Civ. 1re, 26 mars 1996, n° 93-20.229, Bull. civ. I, n° 149). L'article 1792-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005, ne vise plus le bâtiment, mais « l'ouvrage ». Dès lors qu'il satisfait aux conditions déjà décrites (V. *supra,* nos 516 s.), il entre dans le champ d'application de l'article 1792-2, dont les conditions qu'il pose, pour que la garantie décennale soit retenue, se réduisent à celles relatives aux éléments d'équipement au sens de ce texte. Celui-ci s'applique donc au bâtiment comme à tout autre ouvrage de construction immobilière.

585. Le désordre doit affecter un élément d'équipement indissociable. - Dans la loi du 4 janvier 1978 la nature de l'équipement est indifférente. Il suffit qu'il fasse indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert (art. 1792-2). C'est le caractère immobilier de cet équipement qui importe (Civ. 3e, 20 mars 2002, RDI 2002. 234, qui insiste sur l'obligation des juges de motiver leur décision constatant la dissociabilité ou l'indissociabilité d'un équipement). La distinction préconisée par la jurisprudence dans le premier cas de garantie n'aurait pas dû trouver matière à s'appliquer ici, car pour immobiliser il faut, en pratique, avoir recours à des techniques de construction. La détérioration de support caractérise de surcroît l'atteinte à la solidité de la structure : la loi privilégie en effet l'immobilisation par destination. On l'a compris, si le critère qui conduit à exclure du champ de la garantie décennale des équipements à vocation industrielle ou commerciale, n'est pas tant leur destination que la nature du travail, qui doit être de construction, cette condition est

normalement remplie dans le deuxième cas de garantie, car la loi l'exige. Il a été jugé que sont des équipements indissociables : un dallage ou un carrelage dont la dépose détériore le support (Civ. 3e, 7 mai 1997, BPIM 4/97, no 264. – Civ. 3e, 11 févr. 1998, RDI 1998. 261) ; un carrelage contribuant à l'étanchéité (Civ. 3e, 25 nov. 1998, BPIM 1/99, no 37. – Paris, 23 sept. 1988, RDI 1989. 215) ; mais il a été jugé qu'un dallage d'une galerie marchande qui se décolle et se fissure n'est pas un équipement dissociable engageant la responsabilité décennale, seule la responsabilité de droit commun étant alors encourue (Civ. 3e, 13 févr. 2013, no 12-12.016, Bull. civ. III, no 20. – Civ. 3e, 11 sept. 2013, no 12-19.483, Bull. civ. III, no 103), – ce qui pose la question de savoir quelle est la nature de ces éléments : équipements ? dissociables ou non ? –, l'enduit d'un complexe d'étanchéité (Versailles, 23 juin 1995, RDI 1996. 73), une chape liquide (Civ. 3e, 26 nov. 2015, no 14-19.835, BPIM 1/16, inf. 34). Le juge doit caractériser l'indissociabilité de l'équipement (Civ. 3e, 3 mai 1989, RDI 1989. 469. – Civ. 3e, 22 oct. 2008, no 07-15.214, Bull. civ. III, no 157). Mais la Cour de cassation n'a pas fait la distinction qui s'imposait entre les articles 1792 et 1792-2 compte tenu du critère qu'elle avait retenu à propos des équipements industriels (certains arrêts ont exclu ces derniers du champ d'application des art. 1792 s., V. not. : Civ. 3e, 29 janv. 2003, RDI 2003. 187). La critique est aujourd'hui sans objet : l'ordonnance du 8 juin 2008 (C. civ., art. 1792-7) exclut du champ d'application de l'article 1792-2 (comme de l'art. 1792) les éléments d'équipement ayant pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle. Cette exclusion appelle les mêmes remarques que celles déjà faites, à une réserve près : l'article 1792-2 ne consacre pas un cas d'impropriété de l'ouvrage à sa destination.

586. Le désordre doit affecter la solidité de l'équipement. - Il résulte de la loi que la solidité de l'équipement doit être affectée. Mais un équipement doit surtout remplir une fonction. S'il n'est pas solide, il est fréquent qu'il ne la remplisse pas ; alors même qu'il est « solide », il peut ne pas la remplir s'il ne fonctionne pas. Sous couvert d'un cas d'atteinte à la solidité n'affectant pas directement la structure de l'ouvrage, c'est une impropriété à la destination de l'ouvrage qui est ici consacrée. La solution ne fait guère de doute pour les équipements liés à l'isolation thermique ou phonique. Dans ce cas, alors même que la loi range l'isolation phonique dans la garantie de parfait achèvement, la responsabilité décennale peut être retenue (Civ. 1re, 24 mars 1992, RDI 1992. 331. – Civ. 3e, 3 févr. 1999, BPIM 2/99, no 132). À présent que tous les ouvrages, qu'ils soient ou non de bâtiments, peuvent relever de la garantie décennale lorsque la solidité d'un équipement indissociable est compromise, il faut se demander s'il est nécessaire, dans ce cas, de distinguer selon que l'équipement a ou non une vocation industrielle : l'équipement indissociable et l'ouvrage qui le reçoit ne constituent-ils pas « un tout » dont il suffit de constater que la solidité est compromise (Rappr. : Civ. 3e, 17 juin 2008, no 07-13.313).

§ 4 - Conditions propres à la garantie biennale

587. Domaine. - La garantie biennale est prévue par l'article 1792-3. Elle s'applique aux éléments d'équipement d'un bâtiment qui ne relèvent pas de la décennale. Elle suppose la réunion des conditions suivantes :

588. 1° Dans le régime institué par la loi du 4 janvier 1978, l'ouvrage devait être un *bâtiment* : les observations exposées ci-dessus à propos du deuxième cas de garantie décennale (V. *supra,* n°s 584 s.) sont transposables pour la période antérieure au 9 juin 2005, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005 qui se borne à exiger qu'il y ait construction d'un *ouvrage* (au sens examiné *supra,* n°s 516 s). Il en résulte par exemple que si une piscine est assimilée à un bâtiment dans le régime antérieur, les équipements dissociables peuvent bénéficier de la garantie de deux ans ; comme elle constitue en tout cas un ouvrage, la garantie biennale s'applique aux équipements visés à l'article 1792-3.

589. 2° L'équipement affecté doit être *dissociable* des ouvrages de structure au sens de l'article 1792-2 étudié plus haut. Cela implique que l'équipement peut être déplacé ou enlevé pour être réparé ou remplacé, sans détérioration du support. Sont des équipements dissociables : un interphone (Paris, 12 mars 1990, Juris-Data, n° 020661) ; une chaudière dissociable (Chambéry, 12 sept. 1990, RDI 1991. 67. – Civ. 3e, 11 mars 1992, n° 90-15.633, Bull. civ. III, n° 78) ; un système de sonorisation (CAA Nantes, 15 nov. 1990, Gaz. Pal. 1992. Pan. 35) ; une chose inerte, par exemple un faux plafond (Civ. 3e, 7 déc. 1988, Bull. civ. III, n° 174 ; comp. : Civ. 3e, 14 oct. 1992, n° 91-11.628, Bull. civ. III, n° 267) ; une moquette (Paris, 9 mars 1989, Juris-Data, n° 020808) ; des carrelages simplement collés (Civ. 3e, 10 janv. 2001, BPIM 2/01, n° 120) ; un revêtement de peinture (CAA Paris, 19 janv. 1993, Gaz. Pal. 1994. Pan. 66 ; *contra* : Civ. 3e, 27 avr. 2000, RDI 2000. 346, qui décide qu'il ne s'agit même pas d'un ouvrage au sens des art. 1792 s.) ; un muret de terrasse (Civ. 3e, 7 oct. 2008, n° 07-17.800) ; une chape liquide qui est un équipement dissociable et non un ouvrage (Civ. 3e, 26 nov. 2015, n° 14-19.835, BPIM 1/16, inf. 34). Un équipement adjoint à l'existant n'est pas considéré comme un équipement dissociable : il relève de la responsabilité de droit commun (Civ. 3e, 10 déc. 2003, n° 02-12.215, Bull. civ. III, n° 224. – Civ. 3e, 19 déc. 2006, n° 05-20.543, RDI 2007. 163).

590. 3° Le désordre doit affecter le *bon fonctionnement de l'élément d'équipement.* Cette condition implique que l'élément ait vocation à « fonctionner », donc qu'il ait une dynamique propre. L'équipement pouvant aussi être une chose inerte, son inaptitude à remplir sa fonction aurait pu suffire ; mais sur ce point, la jurisprudence a évolué. Un

équipement dissociable inapte à sa fonction peut rendre l'ouvrage impropre à sa destination et conduire à appliquer la garantie décennale (V. Civ. 3e, 14 oct. 1992, no 91-11.628, Bull. civ. III, no 267, qui l'admet pour un faux plafond. – Civ. 3e, 2 juill. 2002, no 00-13.313, RDI 2002. 417. – V. aussi Civ. 3e, 27 janv. 2015, no 13-25.514, RDI 2015. 185, décollement de carrelages. – Civ. 3e, 13 févr. 2013, no 12-12.016, Bull. civ. III, no 202, qui tout en retenant la responsabilité de droit commun, réservent le cas où le désordre rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ; V. aussi *supra,* no 582). Si certains arrêts ont retenu la garantie biennale pour des éléments inertes ne remplissant pas leur fonction (carrelages : Civ. 3e, 1er févr. 2006, no 04-17.361, RDI 2006. 232 ; tissu mural : Civ. 3e, 26 sept. 2009, no 06-17.216, Constr. Urb. 2007, no 209, comm. Pagès de Varenne), d'autres plus récents écartent cette garantie lorsque l'élément n'est pas destiné à fonctionner, et retiennent la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 18 févr. 2016, no 15-10.750, BPIM 2/16, inf. 112 : revêtement végétal. – Civ. 3e, 11 sept. 2013, no 12-19.483, Bull. civ. III, no 103, carrelages. – Civ. 3e, 30 nov. 2011, no 09-70.345, Bull. civ. III, no 202, tissus tendus, en fait, moquette. – V. déjà : Civ. 3e, 22 mars 1995, no 95-15.233, Bull. civ. III, no 80). En revanche, il paraît clair que les *équipements industriels* au sens de l'article 1792-7, qui ne sont pas des éléments d'équipements d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants (V. *supra,* no 583), ne relèvent pas de la garantie biennale, quelle que soit la destination de l'ouvrage : c'est la responsabilité de droit commun qui devrait s'appliquer. Il faut signaler, à cet égard, un arrêt qui écarte la garantie biennale d'un vendeur d'immeuble à construire à propos de désordres affectant des branchements électriques, en relevant que la preuve d'un défaut d'exécution ou d'une mauvaise exécution du vendeur n'est pas rapportée (Civ. 3e, 4 juin 2008, no 07-12.844).

§ 5 - Conditions relatives au dommage garanti

591. Le dommage ou le désordre ne doit pas être connu à la réception (V. *infra,* nos 592 s.), il doit aussi être certain, conformément au droit commun de la responsabilité (V. *infra,* no 597) et causé par la chose (V. *infra,* nos 600 s.).

A - Désordre caché à la réception

592. Le désordre doit être caché à la réception, car la réception purge les vices apparents (V. *infra,* no 593), il ne doit pas être connu du maître de l'ouvrage (V. *infra,* no 594). Il convient aussi de faire une distinction entre les désordres réservés (V. *infra,* no 595) ou non (V. *infra,* no 596).

1° - Purge des vices apparents

593. Principe. - Bien que la loi ne fasse la distinction qu'à propos de la garantie de parfait achèvement (C. civ., art. 1792-6), et qu'elle prenne en compte le dommage et non le vice qui est à l'origine de celui-ci, un sort différent est réservé au désordre selon qu'il est apparent ou caché. Le *désordre garanti doit être caché à la réception* (Civ. 3e, 7 avr. 2016, no 15-11.256 , BPIM 3/16, inf. 184). La réception sans réserves purge l'ouvrage de ses défauts alors apparents (Civ. 3e, 18 nov. 1997, no 96-13.228 , BPIM 1/98, no 31 ; 21 juin 2000, no 98-20.548 , BPIM 5/00, no 326 ; 8 nov. 2005, no 04-16.932 , RDI 2006. 52 ; 14 janv. 2009, no 07-19.757 . BPIM2/09, inf. 130). Peu importe que le désordre ait pour origine un *vice du sol* (ce qui n'interdit pas de le constater, s'il y a lieu : Civ. 3e, 15 févr. 1989, Bull. civ. III, no 36, en particulier pour écarter ou retenir la force majeure : Civ. 3e, 15 juin 1988, Bull. civ. III, no 109 ; 1er déc. 1999, no 98-13.252 , Bull. civ. III, no 230), un *vice de la construction* (Civ. 3e, 30 avr. 2002, BPIM 3/02, inf. 187 ; 6 déc. 2006, RDI 2007. 90 , pour des non-façons ; V. toutefois : Civ. 3e, 1er juill. 2009, no 08-17.588 , BPIM 5/09, inf. 362, qui constate qu'un incendie n'a pas sa cause dans un vice de l'installation électrique), un *vice des matériaux* ou un *défaut de conformité.* Dans ce dernier cas, la circonstance que la non-conformité résulte de l'inobservation des règles de l'art (c'est alors un vice) des textes légaux (servitude de ne pas construire : c'est une situation analogue à un vice du sol) ou des documents contractuels importe peu, si le dommage est caché à la réception et qu'il présente les caractéristiques physiques requises pour l'application des garanties décennale et biennale (Civ. 3e, 10 avr. 1996, D. 1997. Somm. 349 ; 8 avr. 1998, RDI 1998. 373 ; 20 janv. 1999, BPIM 2/99, inf. 141 ; comp. : Civ. 3e, 4 juin 2008, no 07-12.844 et 14 janv. 2009, no 07-19.757 , BIPM 2/09, inf. 130). Les désordres ayant donné lieu à des réserves échappent en principe aux garanties (Civ. 3e, 6 déc. 1989, Bull. civ. III, no 224). Un arrêt avait cependant admis qu'il pouvait être couvert en assurance de responsabilité décennale s'il répondait aux conditions physiques des articles 1792 et suivants (Civ. 3e, 23 avr. 1986, Bull. civ. III, no 47) ; mais cette solution est condamnée par la jurisprudence postérieure (arrêt du 23 avr. 1986, par exemple) qui ne retient la garantie décennale que pour les désordres cachés, sous les réserves émises *supra,* nos 538 et 539. En revanche, par application de l'article L. 242-1 du code des assurances, les désordres réservés peuvent être pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage (Civ. 3e, 23 avr. 1986, Bull. civ. III, no 46).

2° - Compétence du maître de l'ouvrage

594. Désordre caché. - Par désordre caché, on entend le désordre qui n'a pas pu être décelé à la réception par le maître d'ouvrage profane (Civ. 3e, 10 janv. 1990, RDI 1990. 215), sauf s'il a été informé du défaut (Civ. 3e, 20 oct. 1993, Bull. civ. III, no 122). La

réception sans réserve fait *présumer,* cependant, l'ignorance du défaut (Req. 27 févr. 1929, S. 1929. 267. – Civ. 1re, 21 juill. 1970, Bull. civ. I, n° 249 ; rappr. : Civ. 3e, 3 déc. 1997, RDI 1998. 96). Cette règle est généralement retenue comme un principe (NANA, Les dommages causés par les vices de la chose, thèse, Paris I, 1982, LGDJ, n° 92 ; V. aussi : B. BOUBLI, Garanties dans la construction et politique de l'Habitat, *in* Mélanges P. Malinvaud, 2007, Litec, p. 88, qui fait la synthèse de la question et de la doctrine) ; c'est alors à l'entrepreneur d'établir la preuve contraire (Civ. 3e, 20 oct. 1993, RDI 1994. 56 ; 19 juill. 1995, BPIM 1/96, n° 53 ; 11 févr. 1998, RDI 1998. 260 ; 18 nov. 1997, BPIM 1/98, n° 31). Toutefois, un arrêt (Civ. 3e, 7 juill. 2004, n° 03-14.166, Bull. civ. III, n° 142), il est vrai isolé, semble remettre en cause ce vieux principe : il décide que le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve des réserves émises, ce qui peut se comprendre, et du caractère caché du désordre à la réception ce qui se conçoit moins, car il s'agit d'une preuve négative impossible à administrer et contraire au principe selon lequel le vice est présumé caché. De plus, une tendance se dessine en faveur d'une analyse *in concreto* de la capacité du maître de l'ouvrage à déceler les défauts : c'est au regard de la compétence du signataire du procès-verbal de réception qu'il faut se prononcer, ce qui est une condition utile à connaître en cas de maîtrise d'ouvrage déléguée (Civ. 3e, 14 mars 2001, BPIM 3/01, n° 186 ; 27 sept. 2000, BPIM 1/01, n° 44, RDI 2001. 81, qui énonce la règle). La présence de l'architecte, qui assiste le maître de l'ouvrage à la réception, ne change rien (Civ. 3e, 17 nov. 1993, RDI 1994. 252). Pourtant, l'architecte doit assister le maître de l'ouvrage de ses conseils, et il engage sa responsabilité s'il n'attire pas son attention sur la nécessité d'exprimer des réserves (Civ. 3e, 3 févr. 1999, BPIM 2/99, n° 126 ; 29 janv. 2003, n° 00-21.091, qui paraît revenir à l'appréciation du caractère apparent du vice au regard du maître d'ouvrage profane, mais qui prend la précaution de dire que c'était le cas en l'espèce ; V. *supra,* n° 461). Cette responsabilité ne se comprend que si le désordre était décelable par le maître de l'ouvrage, car, à défaut, le désordre est réputé caché et la garantie décennale est encourue par l'architecte. Une jurisprudence tend à tenir compte de la compétence réelle du maître de l'ouvrage : s'il est un promoteur professionnel, c'est en tenant compte de sa compétence que s'apprécie l'aptitude à déceler le défaut (Civ. 3e, 24 mars 1999, BPIM 3/99, n° 221) ; s'il n'a pas émis de réserves, il ne peut rechercher la responsabilité de l'architecte qui ne l'a pas invité à les exprimer, alors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences de cette carence (Civ. 3e, 27 sept. 2000, BPIM 1/01, n° 39).

ACTUALISATION

594. Construction et caractère caché d'un désordre. - La charge de la preuve du caractère caché d'un désordre ne repose pas sur le constructeur mais sur la partie qui en réclame la réparation (Civ. 3e, 2 mars 2022, n° 21-10.753, D. actu. 1er avr. 2022, obs. N. De Andrade).

3° - Cas du désordre non réservé tenu pour caché

595. Cas particulier. - Est également un désordre caché le *désordre apparent* à la réception et non réservé, lorsque le maître de l'ouvrage ne peut en apprécier immédiatement le degré de gravité et que *le dommage n'est connu que plus tard, dans son étendue, sa cause et ses conséquences* (Civ. 3e, 27 avr. 1977, Bull. civ. III, no 178 ; 17 nov. 1999, BPIM 1/00, no 30. – Civ. 3e, 27 janv. 2010, no 08-19.763, BPIM 2/10, inf. 116. – Civ. 3e, 29 janv. 2013, no 12-10.077, BPIM 2/13, inf. 127. – Civ. 3e, 11 févr. 1998, RDI 1998. 260, sol. impl. – Paris, 26 avr. 2000, RDI 2000. 574 ; 18 déc. 2001, RDI 2002. 150). Cette solution est étendue à la réception judiciaire (Civ. 3e, 16 sept. 2014, no 13-21.063, BPIM 6/14, inf. 394) ; elle se justifie, car tout désordre est présumé caché à la réception ; si l'on veut opposer au maître de l'ouvrage son caractère apparent, il faut établir que ce dernier était en mesure d'apprécier son ampleur dès son apparition (Civ. 3e, 4 avr. 2002, no 00-17.634, BPIM 3/02, no 188), solution retenue en cas d'empiètement toléré (Civ. 3e, 28 févr. 2002, no 11-13.670 et no 11-20.549, BPIM 3/12, inf. 238).

4° - Cas du désordre réservé tenu pour caché

596. Autre dérogation. - Pour des raisons moins évidentes que dans le cas précédent, il est admis que constitue aussi un désordre caché, le *désordre réservé à la réception* (il devrait alors relever de la responsabilité de droit commun : Civ. 3e, 2 oct. 2001, RDI 2002. 89), *qui ne s'est révélé que postérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences* (Civ. 3e, 12 oct. 1994, no 92-16.533, Bull. civ. III, no 172 ; 28 févr. 1996, RDI 1996. 217 ; 23 avr. 1997, RDI 1997. 448 ; 16 déc. 2008, no 07-21.673, BPIM 1/09, inf. 32. – Civ. 3e, 21 sept. 2011, no 09-69.933, Bull. civ. III, no 153).

B - Dommage certain

597. La condition de dommage certain est remplie lorsque le désordre est actuel et qu'il répond aux conditions légales lorsque l'action est engagée (V. *infra,* no 598). Le désordre futur est également susceptible d'entrer dans le champ des garanties s'il est d'ores et déjà certain (V. *infra,* nos 599 s.). Une distinction est à faire.

1° - Désordre évolutif

598. Notion. - Le désordre évolutif (V. J.-M. BERLY, Désordres évolutifs. État de la jurisprudence, RDI 2000. 115) est un désordre d'ores et déjà certain et relevant de la

garantie (décennale, en pratique) au stade « actuel », c'est-à-dire au moment où l'action est engagée, qui s'aggrave par la suite : *il est futur dans ses conséquences* (Civ. 3e, 18 nov. 1992, n° 91-12.797, Bull. civ. III, n° 297, qui est topique ; V. aussi : 3 déc. 1985, Bull. civ. III, n° 159 ; 20 déc. 1986, Bull. civ. III, n° 178 ; 13 févr. 1991, n° 89-12.535, Bull. civ. III, n° 52 ; 11 juill. 2001, RDI 2002. 85 ; 29 mai 2002 [2 arrêts], RDI 2002. 323). Ce désordre doit présenter le degré de gravité requis en garantie décennale (Civ. 3e, 13 févr. 1991, n° 89-12.535, Bull. civ. III, n° 52 ; 9 juill. 1997, BPIM 5/97, inf. 323, et les arrêts cités ci-dessus), et il doit être dénoncé dans le délai de la garantie par un acte interruptif de prescription (Civ. 3e, 3 déc. 1985, Bull. civ. III, n° 159 ; 18 nov. 1992, n° 91-12.797, Bull. civ. III, n° 297 ; 8 oct. 2003, n° 01-17.868, Bull. civ. III, n° 170. – Civ. 3e, 6 juill. 2011, n° 10-17.965, Bull. civ. III, n° 121. – Rappr. : Civ. 3e, 20 mai 2015, n° 14-14.773, BPIM 4/15, inf. 259). L'interruption fait courir un nouveau délai même si des travaux de renforcement consécutifs aux désordres primitifs ont été exécutés (Civ. 3e, 11 mars 2015, n° 13-28.351 et n° 14-14.275, BICC 15 juin 2015, n° 676 ; BPIM 3/15, inf. 195). Le désordre évolutif se présente en général sous deux formes :

1° désordre qui se propage : il s'agit d'un dommage qui s'étend sur d'autres parties de l'ouvrage (Civ. 3e, 8 oct. 2003, n° 01-17.868 : fissures sur garde-corps. – Civ. 3e, 25 janv. 1995, n° 93-12.610, Bull. civ. III, n° 26 : désordres de toiture qui se manifestent dans d'autres maisons ; V. aussi : Civ. 3e, 26 janv. 2000, BPIM 2/00, inf. 106 ; 16 mai 2001, n° 99-15.062, Bull. civ. III, n° 62, mais Civ. 3e, 4 nov. 2004, n° 03-13.414, Bull. civ. III, n° 187, écarte, avec raison nous semble-t-il, l'existence d'un désordre évolutif lorsque le dommage affecte successivement des maisons qui sont des ouvrages distincts). La Cour de cassation semble toutefois exiger que le désordre procède d'un même vice (Civ. 3e, 25 nov. 1998, RDI 1999. 259) ou de la même cause (Civ. 3e, 21 janv. 2004, n° 02-14.346 ; V. toutefois : Civ. 3e, 20 mai 1998, n° 96-14.080, Bull. civ. III, n 105, qui paraît moins exigeant), ou encore qu'il soit de même nature (Civ. 3e, 20 mai 1998, n° 96-14.080, Bull. civ. III, n° 105 ; V. toutefois : Civ. 3e, 18 janv. 2006, n° 04-17.400, Bull. civ. III, n° 17, qui n'applique pas la garantie à d'autres « corbeaux » que ceux initialement dénoncés). La dénonciation dans le délai interrompt la prescription et préserve la garantie pour ses évolutions futures (Civ. 3e, 11 janv. 1995, RDI 1995. 330. – Civ. 3e, 9 juill. 1997, BPIM 5/97, n° 323). Lorsque la propagation est inévitable, la réfection des parties non encore sinistrées peut être ordonnée (Civ. 3e, 14 janv. 1998, BPIM 2/98, n° 116 : canalisations ; CE 30 déc. 1998, req. n° 317006, Andrault, BPIM 2/99, n° 139) ;

2° désordre qui se répète. Lorsque le désordre se répète malgré une première réparation, il y a récidive ; outre que la réparation n'empêche alors pas la propagation

du désordre (Civ. 3e, 3 déc. 1985, Bull. civ. III, n° 159 ; 11 mai 2000, n° 98-17.179, Bull. civ. III, n° 103), elle peut ne pas suffire pour empêcher le désordre de se reproduire, ce qui n'empêche pas l'application de la garantie décennale (Civ. 3e, 20 mai 1998, n° 96-14.080, Bull. civ. III, n° 105 ; 25 nov. 1998, RDI 1999. 259) ; dans ce dernier cas, il est douteux qu'il s'agisse d'un désordre évolutif : il s'agit d'un dommage mal réparé, sauf si la cause est structurelle et implique une reprise complète des travaux. Sous réserve de cette dernière situation, on peut donc dire qu'est un désordre évolutif garanti celui qui présente trois conditions : être dénoncé dans le délai de la garantie ; présenter, lorsqu'il est dénoncé, le caractère de gravité requis pour relever de la garantie décennale (arrêts ci-dessus) ; constituer l'aggravation ou la suite des désordres initiaux et non constituer un désordre distinct sans lien de causalité avec le précédent (Civ. 3e, 11 mai 2000, RDI 2000. 344).

2° - Désordre futur

599. Notion. - Le désordre futur englobe le désordre évolutif. Il s'en distingue cependant en ce que, au moment où l'action est engagée, les *conséquences dommageables du désordre dénoncé ne se sont pas nécessairement produites* ; mais elles sont inéluctables, dans un avenir prévisible (Civ. 3e, 6 mai 1998, RDI 1998. 375). Le dommage va *s'aggraver en intensité* ; il est futur mais certain. Une jurisprudence, qui exige que le désordre doit être décennal « au stade actuel », donne à penser que le dommage futur se réduit au désordre évolutif (Civ. 3e, 19 juin 1996, n° 94-17.497, Bull. civ. III, n° 149 ; 7 juin 2001, RDI 2001. 388). Mais cette jurisprudence en contradiction avec d'autres arrêts (Civ. 3e, 3 déc. 1985, n° 84-13.375, Bull. civ. III, n° 159 ; 13 juill. 1993, Le Moniteur, 24 sept. 1993), semble à présent condamnée (Civ. 3e, 16 mai 2001, BPIM 4/01, n° 260, RDI 2001. 387, et l'analyse de P. MALINVAUD, qui distingue clairement désordre futur et désordre évolutif). Le désordre futur, distinct du désordre évolutif, relève de la garantie décennale à deux conditions : 1° au stade actuel, un désordre existe ; il est dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale, mais il ne présente pas encore le degré de gravité requis par les articles 1792 et 1792-2 ; 2° dans le délai de dix ans qui suit la réception, il doit présenter le degré de gravité prévu par ces textes (Civ. 3e, 28 mai 1986, RDI 1986. 468 ; 29 janv. 2003, RDI 2003. 185 ; 25 mai 2005, n° 03-20.247, Bull. civ. III, n° 113, pour un défaut de conformité ; 12 févr. 2008, n° 07-10.049). Le juge doit constater, par voie d'expertise le cas échéant, que le désordre présentera dans un délai prévisible, et en tout cas inférieur ou égal à dix ans à compter de la réception, les conditions requises pour être garanti (Civ. 3e, 12 févr. 2008, n° 07-10.049 ; 16 juin 2009, n° 08-14.046). Le désordre futur est caractérisé en cas de non-conformité aux règles parasismiques (Civ. 3e, 25 mai 2005, n° 03-20.247, Bull. civ. III, n° 113. – Civ. 3e, 11 mai 2011, n° 10-11.713, Bull. civ. III,

n° 70. – V. toutefois, la jurisprudence citée au n° 580 qui tient la seule violation des normes pour un dommage décennal) ; ou pour un talus qui menace de s'effondrer (Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 11-16.943, Bull. civ. III, n° 116 ; RDI 2012. 569, obs. Malinvaud).

C - Dommages causés par la chose

600. La chose peut causer des dommages aux existants (V. *infra,* n° 601) mais aussi des dommages dits consécutifs (V. *infra,* n° 602).

1° - Dommage aux existants

601. Manifestation. - Le dommage aux existants qui se manifeste *avant la réception* donne lieu à application de la théorie des risques : l'entrepreneur répond de la conservation de la chose s'il commet une faute (C. civ., art. 1789 : Civ. 3e, 9 oct. 1991, n° 90-12.059, Bull. civ. III, n° 234. – Civ. 2e, 26 mai 1992, n° 91-11.149, Bull. civ. II, n° 154). Toutefois, c'est en général la responsabilité contractuelle de droit commun qui est retenue (Civ. 3e, 7 nov. 2012, n° 11-20.532, Bull. civ. III, n° 162 ; RDI 2013. 103, obs. Malinvaud). La garantie décennale n'est pas applicable (Civ. 3e, 22 mars 2000, n° 98-20.250, RDI 2000. 353, obs. C. Saint-Alary-Houin, BPIM 4/00, inf. 252). Le dommage aux existants qui se manifeste *après la réception* peut affecter en réalité l'ensemble de l'ouvrage, en particulier lorsqu'il s'agit de rénover ou réhabiliter l'existant ; si les travaux exécutés sont des travaux de construction, et qu'il y a difficulté à dissocier l'existant des travaux neufs, l'ensemble est soumis à la garantie légale (Civ. 3e, 9 déc. 1992, n° 91-12.097, Bull. civ. III, n° 321 ; 9 nov. 1994, n° 92-20.804, Bull. civ. III, n° 184 ; 30 mars 1994, n° 92-11.996, Bull. civ. III, n° 70. – Paris, 22 mars 2001, RDI 2001. 386 ; V. déjà : Civ. 1re, 28 mai 1962, Bull. civ. I, n° 267. – Civ. 3e, 19 déc. 1972, Bull. civ. III, n° 688 ; 15 oct. 1970, *ibid.* III, n° 514 ; V. H. PÉRINET-MARQUET, La responsabilité relative aux travaux sur existants, RDI 2000. 483). Les existants doivent former un tout avec les ouvrages neufs (Civ. 3e, 5 juill. 2006, n° 05-16.277, Bull. civ. III, n° 167 ; comp. : Civ. 1re, 29 févr. 2000, n° 97-19.143, Bull. civ. I, n° 65, qui faisait bénéficier les existants de l'assurance de garantie décennale avec une certaine largesse ; V. aussi : Civ. 3e, 30 juin 2016, n° 15-17.146 qui retient la responsabilité décennale de l'installateur d'un insert). L'ordonnance du 8 juin 2005 applicable aux marchés conclus à partir du 9 juin 2005 précise que les obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, « totalement incorporés à l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles » (C. assur., art. L. 243-1-1-II). Il est probable que cette disposition influencera la jurisprudence en matière de

garantie décennale. Si la dissociation est possible, il semble que seule la responsabilité contractuelle de droit commun soit concevable ; elle pourrait être celle du dépositaire. La tentation de faire appel à la responsabilité quasi délictuelle semble se heurter à l'unité du patrimoine : le maître de l'ouvrage n'est pas un tiers. C'est également la responsabilité de droit commun qui devrait être appliquée lorsque le travail sur existant n'est pas un travail de construction (ravalement esthétique).

2° - Dommages consécutifs

602. Définition. - La jurisprudence considère que le débiteur de la garantie doit réparer les conséquences dommageables des désordres dont il est responsable lorsque le préjudice est « directement lié aux malfaçons de l'ouvrage » (Civ. 3e, 2 oct. 2002, RDI 2002. 543). Ces solutions admises avant la loi du 4 janvier 1978 (Civ. 3e, 22 févr. 1978, Bull. civ. III, n° 93) se maintiennent (intérêts d'emprunts : Civ. 3e, 13 mars 1991, RCA 1991, n° 250 ; accident mortel : Civ. 3e, 10 avr. 1996, BPIM 4/96, n° 279 ; perte de recette : Civ. 3e, 15 janv. 2003, n° 00-16.106, Bull. civ. III, n° 5 ; réduction des loyers : CE 24 oct. 1990, RDI 1991. 60 ; 10 févr. 1995, RDI 1995. 323 ; disparition du bétail : Civ. 1re, 7 juin 1989, RDI 1989. 485 ; perte d'une chance de réaliser un projet : Civ. 3e, 4 juin 1997, BPIM 5/97, n° 324 ; V. pour le dommage subi par un preneur à bail : Civ. 3e, 18 mars 2009, n° 08-11.011). Le dommage n'est pris en compte que s'il a sa cause dans le désordre et non dans l'opération de construction elle-même (achat foncier, frais d'acte et même intérêts d'emprunts : Civ. 3e, 6 mars 2002, n° 00-19-812). L'empiétement sur le terrain d'autrui est pris soit comme un désordre décennal (Civ. 3e, 27 avr. 1994, RGAT 1994. 820), soit comme un dommage causé par l'ouvrage (au voisin) relevant de l'article 1382 du code civil (Civ. 3e, 17 mars 1999, BPIM 3/99, n° 209 ; V. *supra,* n° 581). Les dommages consécutifs sont souvent tenus pour des dommages « immatériels » au sens de l'assurance construction obligatoire qui ne les couvre pas (Civ. 1re, 13 mars 1996, n° 93-20.177, Bull. civ. I, n° 130).

§ 6 - Régime juridique des garanties

603. La responsabilité des constructeurs est une responsabilité de plein droit (C. civ., art. 1792 ; V. *infra,* nos 604 s.), la durée des garanties permet de vérifier la solidité de l'objet (V. *infra,* nos 614 s.). Les garanties décennale et biennale, comme la garantie de parfait achèvement d'ailleurs, sont d'ordre public (V. *infra,* nos 624 s.). Il convient aussi d'évoquer la réparation du dommage (V. *infra,* nos 627 s.).

A - Présomption de responsabilité

604. Pour évoquer les présomptions de responsabilité, il convient de déterminer qui sont les personnes concernées (V. *infra,* n°s 605 s.) et quelles sont les causes d'exonération (V. *infra,* n°s 607 s.).

1° - Personnes concernées

605. Principe. - Cette présomption de responsabilité n'est expressément posée que pour la garantie décennale (art. 1792-2). Mais on s'accorde pour considérer que la garantie biennale n'y échappe pas (MALINVAUD, JESTAZ, par JOURDAIN et TOURNAFOND, Droit de la promotion immobilière, *op. cit.,* n° 129. – V. toutefois, Civ. 3e, 4 juin 2008, n° 07-12.844, qui relève que la preuve que le désordre procède d'une défaillance imputable au vendeur d'immeuble à construire n'est pas établie, alors que la garantie biennale était invoquée). La présomption pèse sur tous les constructeurs ou personnes assimilées au sens de la loi. La présomption est à la fois de fait et de droit. La présomption de fait relève de l'imputabilité et implique en général une relation avec la mission ou la prestation fournie (Civ. 3e, 28 janv. 1998, n° 95-16.328, RDI 1998. 263) ; le juge doit en principe rechercher si le dommage est imputable au fait du constructeur (Civ. 3e, 10 déc. 2015, n° 14-22.675 et n° 14-24.503, BPIM 1/16, inf. 35). La situation de *l'architecte* illustre cette particularité. (V. *Architecte [Civ.]*). Lorsqu'il est investi d'une *mission complète,* la présomption s'applique à lui dans sa totalité ; il est, à ce titre, expressément visé par la loi dans les articles 1792 et 1792-2. La Cour de cassation en déduit que lorsque la responsabilité de l'entrepreneur est retenue, la responsabilité de l'architecte est engagée de plein droit (Civ. 3e, 27 juin 2001, BPIM 5/01, n° 315 ; rappr. : Civ. 3e, 19 juill. 1995, n° 93-18.680, Bull. civ. III, n° 188 ; 20 juin 2001, BPIM 4/01, n° 262 ; rappr. : Civ. 3e, 2 juill. 2003, BPIM 5/03, inf. 291). L'architecte peut alors s'exonérer par la preuve d'une cause étrangère (Civ. 3e, 1 mars 1985, Bull. civ. III, n° 57 ; 19 juill. 1995, n° 93-18.680, Bull. civ. III, n° 188 ; 20 juin 2001, n° 99-20.242, Bull. civ. III, n° 80). Lorsqu'il est investi d'une *mission partielle,* il n'est responsable que dans la limite de celle-ci et il faut alors que le dommage lui soit imputable (Civ. 3e, 3 juin 1992, RDI 1993. 77 ; 28 janv. 1998, RDI 1998. 263) ; si cette mission est de conception, la présomption de droit est admise (Civ. 3e, 12 févr. 1997, n° 239 D ; 15 déc. 1999, RDI 2000. 183) ; si cette mission est de surveillance, certains arrêts semblent considérer qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens (Civ. 3e, 22 mai 1973 et 4 juill. 1974, D. 1974. 233, note J. Mazeaud ; 29 janv. 1978, RDI 1979. 211 ; 2 nov. 1982, RDI 1983. 232) ; d'autres appliquent la présomption de droit (Civ. 3e, 27 mars 1985, RDI 1985. 378). Il est permis à l'architecte d'établir que le sinistre est sans rapport avec sa mission (Civ. 3e, 3 juin 1992, RDI 1993. 77 ; 28 janv. 1998, n° 95-16.328, RDI 1998. 263, obs. Malinvaud ; 9 janv. 2002, n° 00-14.002, Bull. civ. III, n° 1) ; la présomption s'applique s'il n'y parvient pas (Civ. 3e, 14 févr. 1990, RDI 1990. 214 ; 9 déc. 1992, Le Moniteur 12 mars 1993 ;

19 juill. 1995, RDI 1995. 756 ; pour un BET : 24 mai 1989, RDI 1989. 471 ; sur le contrôleur technique, qui ne répond que dans les limites de sa mission, V. *supra,* n°s 236 s.). Lorsque le débat soulève la question du manquement du constructeur à son *obligation de conseil,* la présomption s'applique si le désordre relève de la garantie décennale par ses caractéristiques propres ; mais lorsque la responsabilité est de droit commun (Civ. 3e, 12 mars 1997, RDI 1997. 447), ou que le maître d'œuvre est investi d'une mission partielle pour laquelle la présomption se discute, il faut établir le manquement du constructeur à cette obligation (Civ. 3e, 25 févr. 1998, n° 96-10.598 , Bull. civ. III, n° 44. – CE 28 janv. 2011, req. n° 330693 , BPIM 2/11, inf. 112 ; V. RDI 1998. 100).

606. Succession d'opérateurs. - Lorsqu'un *constructeur,* dont la responsabilité est présumée, *succède à un autre,* la présomption est limitée aux travaux effectués par le successeur (Civ. 3e, 2 avr. 1979, RDI 1979. 472 ; 16 janv. 2008, n° 04-20.218 ; V., pour un architecte : Civ. 3e, 30 sept. 1998, RDI 1998. 643). Il est probable que, dans cette hypothèse, il faut distinguer présomption de fait et présomption de droit. Normalement, la présomption pèse sur le successeur qui doit prendre certaines précautions avant de succéder à son collègue ou confrère. S'il montre que le dommage n'est pas imputable à son fait par la simple preuve contraire, il est exonéré ; s'il ne le démontre pas, il ne peut s'exonérer que par la preuve de la cause étrangère. Un arrêt retient la responsabilité de plein droit du constructeur qui succède à un autre (Civ. 3e, 26 févr. 1980, JCP 1980. IV. 184 ; comp. : Civ. 3e, 4 févr. 1986, Gaz. Pal. 1986. Pan. 506. – Civ. 1re, 20 mars 1989, D. 1989. IR 118), et l'arrêt du 16 janvier 2008 précité prend la précaution de relever que les travaux exécutés par le successeur n'ont rien ajouté aux désordres existants. Lorsque deux ou plusieurs entreprises sont attributaires de *lots différents,* chacune n'est responsable que des désordres relevant de son lot (Civ. 3e, 20 févr. 1979 et 14 mars 1979, RDI 1979. 246 ; 26 sept. 2006, n° 05-15.537), BPIM 1/07, inf. 39. – Civ. 3e, 9 févr. 2011, n° 09-51.570, Bull. civ. III, n° 21.

2° - Causes d'exonération

607. Les causes d'exonération sont les causes classiques, à savoir la force majeure (V. *infra,* n° 608), le fait du tiers (V. *infra,* n° 609) ou du maître de l'ouvrage (V. *infra,* n° 610).

a. - Force majeure

608. Cause étrangère. - La présomption cède devant la preuve de la cause étrangère qui s'entend au premier chef de l'événement naturel imprévisible irrésistible et extérieur au débiteur caractérisant la force majeure (V. toutefois : Civ. 3e, 1er juill. 2009, n° 08-

17.588, BPIM 5/09, inf. 362). Après quelques atermoiements, la Cour de cassation a retenu en assemblée plénière que l'événement constitutif de force majeure doit être imprévisible et irrésistible (Cass., ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168, Bull. civ., n° 5 ; V. *Force majeure [Civ.]*). Les dispositions du code civil, modifiées par l'ordonnance du 10 février 2016, consacrent la définition de la force majeure à l'article 1218 nouveau (« évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées », empêchant l'exécution de l'obligation) ; ce texte, applicable en matière contractuelle, semble ne concerner que l'impossibilité d'exécution de l'obligation, l'évènement constitutif de force majeure pouvant alors soit l'empêcher, soit la suspendre. Cette disposition aura-t-elle vocation à s'appliquer aux causes exonératoires de responsabilité ? L'avenir le dira. Si l'on s'en tient aux solutions positives issues de l'arrêt d'assemblée plénière, la condition d'extériorité n'est pas abandonnée (Civ. 1re, 13 nov. 2008, n° 07-14.856, Bull. civ. I, n° 263). Il en résulte les conséquences suivantes :

– *les intempéries* lorsqu'elles sont exceptionnelles peuvent caractériser la force majeure (ouragan : Civ. 2e, 15 mai 1956, Bull. civ. II, n° 268. – Civ. 3e, 7 mars 1979, JCP 1979. IV. 169) ; mais la jurisprudence est plutôt réticente (Civ. 3e, 17 juill. 1996, BPIM 6/96, n° 408 ; 4 juill. 1997, Bull. civ. III, n° 124 : crues malgré un arrêté de catastrophe naturelle. – Civ. 3e, 18 déc. 2001, RDI 2002. 152. – Civ. 3e, 27 févr. 2008, n° 06-19.348, Bull. civ. III, n° 32 : sécheresse malgré un arrêté de catastrophe naturelle ; V. aussi pour la sécheresse : Civ. 3e, 27 juin 2001, RDI 2001. 524 ; 28 nov. 2001, RDI 2002. 88 ; 28 sept. 1983, RDI 1984. 58 ; 7 mai 1996, n° 888 D : tempête ; V. cep., pour des cas où la force majeure a été retenue : accumulation anormale de neige : Civ. 3e, 7 mars 1979, JCP 1979. IV. 169 ; sécheresse exceptionnelle et durable : Versailles, 2 févr. 2001, BPIM 3/01, n° 194. – Civ. 3e, 12 déc. 2001, RDI 2002. 88) ;

– *le vice du sol* n'est pas un cas de force majeure (art. 1792. – Civ. 3e, 20 mai 1998, n° 96-19.521, Bull. civ. III, n° 106 ; V. aussi : 21 mai 1969, Bull. civ. III, n° 392 ; 15 févr. 1989, Bull. civ. III, n° 37), sauf s'il s'agit d'un mouvement de terrain à grande profondeur manifestement imprévisible (Civ. 3e, 6 mars 1967, D. 1967. Somm. 83 ; 19 mars 1985, Bull. civ. III, n° 57 ; CE 25 mai 1990, RDI 1990. 365), d'un glissement de terrain non détectable par une étude classique (Civ. 3e, 20 nov. 2013, n° 12-27.873, BPIM 1/14, inf. 30) ; le tremblement de terre, en principe constitutif de force majeure n'est pas exclusif de la prise en compte d'un vice de la construction (Civ. 3e, 18 sept. 2013, n° 12-17.440, Bull. civ. III, n° 108) ;

– *le vice des matériaux* n'est pas un cas de force majeure (Civ. 3e, 7 mars 1990, n° 88-14.866, Bull. civ. III, n° 69 ; 21 févr. 1979, D. 1979. IR 317 ; 3 oct. 1962, Bull. civ. I,

n° 393 ; 2 avr. 2003, n° 01-17.724, Bull. civ. III, n° 74), même en cas d'attaque des capricornes (Civ. 3e, 21 févr. 1979, D. 1979. IR 317 ; 24 juin 1987, Gaz. Pal. 1987. Somm. 215, dans ce cas l'atteinte à la solidité de l'ouvrage est un cas de garantie décennale : Civ. 3e, 26 juin 2002, n° 00-12.023, RDI 2002. 424) ;

– *la teneur chimique anormale de l'eau* n'est pas un cas de force majeure (Civ. 3e, 4 juin 1986, Mon. TP 7 nov. 1986), sauf si les moyens de détection normaux ne permettent pas de discerner l'anomalie (Civ. 3e, 19 mars 1985, Bull. civ. III, n° 57) ;

– *le risque de développement de la norme* (produit non agréé par le CSTB après l'avoir été) n'est pas un cas de force majeure (Civ. 3e, 22 oct. 1980, RDI 1981. 78 ; 31 janv. 1990, n° 88-17.549, Bull. civ. III, n° 39 ; V. pour un fabricant qui se prévalait de l'art. 1386-11 du code civil, Civ. 3e, 28 nov. 2001, BPIM 1/02, n° 34 ; V. *supra,* n° 498 ; pour un contrôleur technique se prévalant du respect des normes : Civ. 3e, 3 avr. 2002, RDI 2002. 237). Lorsque la responsabilité du fabricant de produits défectueux est engagée sur le fondement des articles 1386-1 anciens (C. civ., nouv. art. 1245-1) et suivants du code civil, l'article 1386-11 ancien (C. civ., nouv. art. 1245-10) fait du risque de développement un cas d'exonération (V. *Responsabilité du fait des produits défectueux [Civ.]*) ; mais ce régime n'est pas applicable aux produits vendus avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 (Civ. 3e, 28 nov. 2001, n° 00-15.058, RDI 2002. 94, obs. Malinvaud, BPIM 1/02, n° 34, qui rappelle que l'avis du CSTB n'est pas un cas d'exonération). En cas de travail sur un existant, il a été jugé que l'état de l'existant pouvait être une cause étrangère exonératoire, car imprévisible pour le constructeur, alors même que celui-ci était intervenu pour prévenir un risque de défaut d'étanchéité, et que les travaux réalisés par lui n'avaient pas empêché le sinistre (Civ. 3e, 26 févr. 2003, n° 01-16.441, Bull. civ. III, n° 46, RDI 2003. 281, obs. Malinvaud) ;

– *l'état de l'existant* peut constituer un cas de force majeure (Civ. 3e, 26 févr. 2003, n° 01-16.441, préc.).

b. - Fait du tiers

609. Notion. - Le fait du tiers est celui d'une personne dont le présumé responsable ne répond pas : le fait du sous-traitant (Civ. 3e, 5 janv. 1978, Bull. civ. III, n° 9), sinon le fait du fabricant, ne sont donc pas considérés comme des causes d'exonération, car le constructeur répond du premier comme de lui-même et il répond des matériaux fournis (sur celui qui succède à un autre, V. *supra,* n° 606). Le fait du tiers peut résulter du fait d'un autre constructeur avec lequel le présumé responsable n'a aucun lien autre que le lien organique créé par la participation commune à la construction de l'ouvrage : l'architecte est un tiers pour l'entrepreneur et réciproquement (Civ. 3e, 16 oct. 1984, RDI

1985. 64 ; 19 juin 1996, n° 1148 D ; V. aussi pour le fait d'un autre entrepreneur que celui dont la responsabilité est recherchée : Civ. 3e, 20 nov. 2007, n° 06-18.559). Toutefois, si, dans le principe, le fait de l'un peut exonérer l'autre, l'hypothèse de l'exonération se rencontre rarement, car ce fait doit présenter les caractères de la force majeure qui, en pratique, ne sont guère réunis. Aussi assiste-t-on plutôt à une responsabilité *in solidum* des constructeurs et à un partage de responsabilité dans leur rapport entre eux (Civ. 3e, 3 janv. 1969, D. 1969. Somm. 67 ; 23 avr. 1969, D. 1969. Somm. 109 ; 12 juill. 1988, RDI 1989. 57 ; 22 févr. 1989, RDI 1989. 363).

c. - Fait du maître de l'ouvrage

610. Le maître de l'ouvrage, victime, peut contribuer à la réalisation du dommage et exonérer totalement ou partiellement les constructeurs présumés responsables, dans trois cas (V. PÉRINET-MARQUET, La responsabilité du maître de l'ouvrage dans la préparation et l'exécution du marché, RDI 2002. 451) :

611. Fautes. - Elles sont de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage qu'elles soient commises par lui, *avant les travaux* (manquement à l'obligation d'informer, en particulier sur la nature du sol : Civ. 3e, 11 oct. 2000, BPIM 1/01, n° 45, RDI 2001. 85 ; changement d'entrepreneur sans en informer l'architecte : Civ. 3e, 15 oct. 1970, Bull. civ. III, n° 516), *en cours de marché* (modifications inconsidérées au projet : Civ. 3e, 22 mai 1968, D. 1970. 453 ; 11 oct. 2000, préc. ; contraintes de prix excessives : CE 10 févr. 1995, RDI 1995. 323 ; établissement, par lui, des pièces du marché : Civ. 3e, 5 avr. 1995, RDI 1995. 551), *après l'exécution du marché* (transformation des lieux : Civ. 3e, 14 juin 1995, RDI 1995. 552 ; 10 janv. 2001, n° 99-13.103, BPIM 2/01, n° 121 ; usage excédant la charge autorisée : 8 juill. 1998, n° 96-14.520, Bull. civ. III, n° 157 ; phénomène de condensation imputable au client : 6 févr. 2002, n° 00-10.543, RDI 2002. 151. – Civ. 3e, 29 févr. 2012, n° 10-38.174, BPIM 3/12, inf. 239). N'est pas une négligence de nature à exonérer même partiellement les constructeurs, la non-souscription d'une assurance de dommage ou le fait de ne pas exiger que les constructeurs présents sur le chantier soient assurés (Civ. 3e, 12 janv. 2000, n° 98-14.478, RDI 2000. 210, obs. Leguay, D. 2000. 783, note M.-A. Rakotovahiny, BPIM 2/00, n° 104) ; il en va de même si le maître de l'ouvrage ne fait pas appel à un maître d'œuvre (Civ. 3e, 18 déc. 2001, RDI 2002. 151).

612. Acceptation des risques. - L'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération lorsqu'elle est *consciente et délibérée* (Civ. 3e, 25 janv. 1995, RDI 1995. 331 ; 9 juin 1999, n° 97-18.950, Bull. civ. III, n° 132 ; 15 déc. 1999, BPIM 2/00, n° 103 ; 28 nov. 2001, BPIM 1/02, n° 38 ; 20 mars 2002, RDI 2002. 236. – Civ. 1re, 21 janv. 1997, RDI 1997. 240 ; 15 déc. 2004, n° 02-16.581, Bull.

civ. III, n° 235 ; 26 avr. 2006, n° 04-16.382, Bull. civ. III, n° 102). *Il faut que le maître de l'ouvrage ait été informé des risques encourus* (Civ. 3e, 8 oct. 1997, BPIM 2/98, n° 117 ; 22 juill. 1998, RDI 1998. 646 ; 26 janv. 2000, BPIM 2/00, n° 103 ; 20 mars 2002, préc. ; 3 mars 2004, n° 02-17.022, Bull. civ. III, n° 44 ; 26 avr. 2006, préc. ; 21 nov. 2012, n° 11-25.200, BPIM 1/13, inf. 50 ; 11 juin 2014, n° 13-14.785 BPIM 4/14, inf. 258). La solution contraire a été, un moment, admise (Civ. 3e, 25 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 198 ; 27 nov. 1990, RDI 1991. 226). L'acceptation des risques est une cause d'exonération, tant de la garantie décennale ou biennale (arrêts préc.), que de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 19 janv. 1994, n° 92-14.303, Bull. civ. III, n° 6 ; 20 déc. 2000, RDI 2001. 174) ; il a été jugé que le constructeur peut néanmoins être condamné s'il a exécuté un travail qu'il savait inefficace (Civ. 3e, 21 mai 2014, n° 13-16.855, Bull. civ. III, n° 63). Elle ne se confond pas avec l'immixtion fautive qui est un autre cas d'exonération (Civ. 3e, 25 févr. 1998, n° 96-14.537, Bull. civ. III, n° 45 ; 6 mai 1998, RDI 1998. 377). Mais il n'y a pas en soi d'acceptation des risques lorsque le maître de l'ouvrage ne fait pas appel à un maître d'œuvre (Civ. 3e, 8 nov. 2000, BPIM 1/01, inf. 45 ; 30 mars 2005, n° 04-10.403).

613. Immixtion fautive. - Dans ce cas, il y a dénaturation du contrat d'entreprise qui se transformerait sans doute en un contrat de travail si le prestataire était une personne physique. Le maître de l'ouvrage doit être *notoirement compétent* dans le domaine précis d'intervention (technicien de la construction : Civ. 3e, 16 oct. 1974, D. 1974. IR 258 ; 10 mars 1982, RDI 1983. 232 ; 14 nov. 2001, RDI 2002. 87, pour un maître d'ouvrage assurant la maîtrise d'œuvre ; comp. Civ. 3e, 18 déc. 2001, n° 98-16.087, RDI 2002. 152, qui retient la responsabilité du maître d'ouvrage architecte assurant la maîtrise d'œuvre ; V. obs. P. MALINVAUD qui propose une distinction entre l'immixtion fautive du maître d'ouvrage notoirement compétent et maître d'ouvrage fautif, sous les deux arrêts), mais aussi, le cas échéant, spécialiste de la fonction attendue de l'ouvrage (spécialiste d'une chambre froide : Civ. 3e, 7 déc. 1988, Mon. TP 24 mars 1989 ; médecin, lors de l'installation d'une clinique : Civ. 3e, 21 oct. 1990, Mon. TP 13 juill. 1990 ; V. toutefois, Civ. 3e, 14 mars 2007, n° 05-20.799, qui rappelle opportunément que la compétence en création de supermarché n'implique pas une compétence en construction de bâtiment). Le seul fait d'être un professionnel de l'immobilier est insuffisant (Civ. 3e, 13 janv. 1982, Bull. civ. III, n° 14 ; 10 mars 1981, RDI 1981. 381 ; 21 févr. 1984, Bull. civ. III, n° 44. – Civ. 3e, 21 janv. 2015, n° 13-25.268, BPIM 2/15, inf. 116. – V. pour un cas d'assistance technique par un professionnel : Civ. 3e, 17 juill. 1997, BPIM 6/97, n° 392, qui écarte l'immixtion). *Le maître de l'ouvrage doit s'être immiscé dans la direction ou l'organisation des travaux.* Son ingérence doit être effective ; elle ne résulte pas de seuls souhaits exprimés fermement par un maître d'ouvrage profane. Elle implique des actes positifs (Civ. 3e, 7 mai 1996, BPIM 4/96,

n° 278. – Comp. : pour un marchand de biens non constructeur : Civ. 3e, 21 janv. 2015, préc.). Elle peut consister en la réalisation des plans (Civ. 3e, 11 mars 1981, Gaz. Pal. 1981. Pan. 267), en la conduite des travaux, le contrôle des mesures décidées par l'architecte (Civ. 3e, 18 févr. 1981, RDI 1982. 91). Elle peut aussi procéder d'un souci excessif d'économie (Civ. 3e, 10 avr. 1985, RDI 1986. 469 ; 25 févr. 1998, n° 96-14.537, Bull. civ. III, n° 45 ; 6 mai 1998, RDI 1998. 377). Les constructeurs doivent résister au maître de l'ouvrage ; c'est seulement lorsque celui-ci vient à bout de cette résistance et impose ses choix que l'immixtion est caractérisée (Civ. 3e, 21 févr. 1984, Bull. civ. III, n° 44, sol. impl.). Lorsque l'immixtion fautive est écartée, le juge n'a pas à rechercher une éventuelle acceptation des risques si cela ne lui est pas demandé (Civ. 3e, 25 févr. 1998, n° 96-14.537, Bull. civ. III, n° 45). Les deux notions sont autonomes (Civ. 3e, 20 mars 2002, préc.).

614. Étendue de l'exonération. - Le fait du maître de l'ouvrage est le plus souvent un cas *d'exonération partielle* (Civ. 3e, 11 oct. 2000, RDI 2001. 85 ; 10 janv. 2001, RDI 2001. 172), y compris en cas d'acceptation des risques (Civ. 3e, 14 nov. 1991, n° 90-10.050, Bull. civ. III, n° 272 ; V. toutefois Civ. 3e, 20 mars 2002, RDI 2002. 237, qui laisse l'entier dommage à la charge du maître de l'ouvrage). Mais il peut être un *cas d'exonération totale,* en particulier en cas d'immixtion fautive (Civ. 3e, 16 juill. 1987, Mon. TP 12 févr. 1988 ; V. toutefois Civ. 3e, 18 déc. 2001, n° 98-16.087, RDI 2002. 152, qui rejette le pourvoi contre un arrêt ayant admis un partage de responsabilité. Certes, l'immixtion n'était pas constatée ; mais le maître d'ouvrage était notoirement compétent [architecte] et il s'était immiscé [établissement des plans]). Dans ce cas, la sévérité peut s'expliquer par le fait que l'immixtion du maître de l'ouvrage équivaut à une dénaturation du contrat d'entreprise (V. aussi : CE 27 mai 1998, req. n° 149830, Dodin, BPIM 5/98, inf. 333, qui retient l'exonération totale pour une faute du maître de l'ouvrage).

B - Délais de garantie

615. Concernant les délais de garanties, il convient d'étudier leur nature juridique (V. *infra,* n° 616), la computation (V. *infra,* n° 617) et l'interruption des délais (V. *infra,* nos 618 s.) et enfin les effets de l'expiration des délais (V. *infra,* nos 623 s.).

1° - Nature juridique

616. Objet et durée. - La durée de la garantie est de dix ans (garantie décennale), ou de deux ans (garantie biennale). Ces délais sont à la fois des délais d'épreuve (la construction répond aux exigences fonctionnelles) et de solidité requises, et des délais

de l'action en justice (Civ. 3e, 18 mars 1980, Bull. civ. III, no 62). Cela veut dire que les désordres sont garantis s'ils se manifestent ou sont déjà certains dans le délai de dix ou de deux ans ; le maître de l'ouvrage ou tout autre bénéficiaire doit, en outre, exercer l'action en garantie dans le même délai s'il ne veut pas se voir opposer la prescription. Le moyen tiré de la prescription n'est pas d'ordre public. Il doit être invoqué par la partie intéressée ; le juge ne peut soulever ce moyen d'office (Civ. 1re, 23 févr. 1966, Bull. civ. I, no 135. – Civ. 3e, 13 juill. 1993, no 1323 D). Si certains défendeurs seulement ont soulevé la prescription devant le juge du fond, les autres ne peuvent le faire pour la première fois devant la Cour de cassation (Civ. 3e, 5 juill. 2000, RDI 2000. 575), et ils ne peuvent bénéficier de la prescription (Civ. 3e, 11 mai 2006, no 05-12.234, Bull. civ. III, no 114). *Le délai, lui, est d'ordre public.* C'est un délai *préfixe* (V. *infra,* no 556) qui a la nature d'un délai de forclusion : lorsque le délai de garantie est expiré, il n'est pas possible de se prévaloir de la garantie même par voie d'exception (Civ. 3e, 4 nov. 2004, no 03-12.481, Bull. civ. III, no 186). Il n'est pas permis de renoncer par avance au bénéfice de la prescription (Civ. 3e, 21 juin 1989, D. 1989. IR 202). Mais on peut renoncer à se prévaloir d'une prescription acquise, ce qui explique la jurisprudence sur le moyen d'office. Le seul fait de participer à une expertise n'est pas une renonciation (Civ. 3e, 17 janv. 1996, no 93-19.407, Bull. civ. III, no 15) ; mais la désignation d'un expert par le constructeur, l'engagement de dépenses et une correspondance non équivoque peuvent caractériser une renonciation à une prescription pourtant acquise (Civ. 3e, 3 mai 2001, no 99-19.241, Bull. civ. III, no 53).

2° - Computation

617. Distinction selon l'action. - *L'action principale en garantie* a pour point de départ la réception des travaux (C. civ., art. 1792-3 et 1792-4-2). Le délai est « franc ». Le jour de la réception n'entre pas dans le délai (Civ. 3e, 8 janv. 1980, Bull. civ. III, no 2). Le jour d'échéance est encore dans le délai (Civ. 3e, 8 janv. 1980, Bull. civ. III, no 3). La réception étant susceptible d'être prononcée avec ou sans réserve (art. 1792-6), certains auteurs en déduisent que pour les désordres réservés puis réparés, le délai a couru dès la réception, et que le délai applicable aux travaux de réparation est donc amputé. En réalité, après toute réparation, il y a une réception ou un procès-verbal constatant leur exécution, spécialement lorsque les reprises sont confiées à un autre constructeur, et tout indique que le délai de garantie court à compter de cette date (V. *supra,* nos 464, 501 et 505). Des arrêts précisent que la responsabilité est prolongée (Civ. 3e, 16 oct. 2002, no 01-10.330, Bull. civ. III, no 205 ; D. 2003. 300, obs. Malinvaud), tandis que d'autres retiennent que si les réserves sont levées mais que les désordres subsistent, la responsabilité reste encourue sans que le juge n'ait à se prononcer sur l'existence d'une réception expresse ou tacite lors de la levée des réserves (Civ. 3e, 5 déc. 2012, no 11-23.756, RDI 2013. 153). Il a été jugé qu'en

cas de reprises successives, il fallait tenir compte de chacune des réceptions pour déterminer le point de départ de la garantie (Civ. 3e, 2 mars 2011, n° 10-15.211, Bull. civ. III, n° 27). *L'action récursoire en garantie* exercée par le maître de l'ouvrage assigné par un acquéreur n'a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de garantie (Civ. 3e, 21 nov. 2012, n° 11-19.778, RDI 2013. 149. – V. aussi : Civ. 3e, 17 mars 1993, n° 91-19.271 Bull. civ. III, n° 37. – Civ. 3e, 19 juill. 1995, n° 93-21.879, Bull. civ. III, n° 189) ; cette solution peut se discuter lorsque l'action principale est engagée peu avant le délai de garantie (10 jours avant dans l'affaire jugée le 21 nov. 2012) et l'on peut se demander si le droit au juste accès au juge induit par l'article 6 de la CEDH, n'est pas alors compromis (V. Com. 17 mai 1994, n° 91-21.627, Bull. civ. IV, n° 182, à propos d'un délai résiduel de 8 jours). Lorsque l'ouvrage fait l'objet d'un décision de démolition à la suite d'une décision pénale consécutive à l'annulation du permis de construire pour erreur d'implantation, le point de départ du délai de l'action en garantie contre les constructeurs est la date de la décision ordonnant la démolition (Civ. 3e, 12 juin 2014, n° 13-16.042, Bull. civ. III, n° 80).

3° - Interruption

618. Délai préfix. - Les délais de garantie sont des délais préfix qui, en principe, ne peuvent ni être interrompus ni être suspendus (Civ. 3e, 26 nov. 1970, D. 1971. Somm. 93). L'interruption est cependant possible dans certains cas. Le délai qui a couru est alors rétroactivement anéanti et un nouveau délai recommence à courir (C. civ., art. 2231) qui, en pratique, a pour point de départ la décision qui ne rejette pas la demande. Le nouveau délai est de même durée que celui qui a été interrompu (Civ. 3e, 8 juin 1994, RDI 1994. 663) ; il s'applique aux désordres dénoncés et à ceux qui en sont l'aggravation si la dénonciation est intervenue en temps utile (Civ. 3e, 26 avr. 1984, RDI 1984. 418), et dans les seuls rapports avec la personne bénéficiaire de l'interruption (Civ. 3e, 15 févr. 1989, Bull. civ. III, n° 36 ; 23 févr. 2000, n° 98-18.340, Bull. civ. III, n° 39). L'interruption du délai de garantie décennale entraîne aussi l'interruption du délai de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, car les deux actions, quoique différentes, tendent au même but (Civ. 3e, 22 sept. 2004, n° 03-10.923, Bull. civ. III, n° 152. – Civ. 3e, 20 nov. 2013, n° 12-14.248, BPIM 1/14, inf. 321).

a. - Action en justice

619. Effets. - L'*assignation au fond* interrompt les délais pour les désordres dénoncés, qui doivent donc être précisés (Civ. 3e, 27 mars 1997, BPIM 3/96, n° 207 ; 20 mai 1998, n° 95-20.870, Bull. civ. III, n° 104). À l'assignation sont assimilées les conclusions reconventionnelles (Civ. 3e, 23 nov. 1983, RDI 1984. 316 ; 20 mars 2002, n° 99-

11.745, Bull. civ. III, n° 69). L'assignation, qui doit être déposée au greffe (Cass., ass. plén., 3 avr. 1987, Bull. civ., n° 2), doit invoquer la responsabilité en cause (cette responsabilité peut être invoquée à titre subsidiaire : Civ. 3e, 26 juin 2002, RDI 2002. 419, dans un cas où la responsabilité décennale était invoquée à titre principal et la responsabilité de droit commun à titre subsidiaire : l'interruption est retenue pour cette dernière ; V. toutefois : Civ. 3e, 22 sept. 2004, n° 03-10.923, Bull. civ. III, n° 152, qui retient que les actions en responsabilité décennale et de droit commun tendent au même but et décide que l'action en garantie décennale interrompt le délai de prescription de l'action en responsabilité de droit commun) et désigner les désordres qu'elle vise (arrêts préc. ; V. aussi : CE 26 oct. 1994, RDI 1995. 100 ; CAA Lyon, 10 déc. 1990, AJDA 1991. 161), qui peuvent l'être implicitement lorsqu'il s'agit de désordres évolutifs ou futurs (V. *supra,* nos 534 et 535). Elle doit aussi viser le débiteur responsable, ce qui va de soi. Il importe peu que le juge saisi ne soit pas compétent (C. civ., art. 2241. – Civ. 3e, 13 févr. 1985, RDI 1985. 260). Pendant l'instance, le délai ne court plus (Civ. 3e, 8 juin 1994, n° 92-18.055, Bull. civ. III, n° 118). Après l'interruption, un nouveau délai de deux ou de dix ans recommence à courir (Civ. 3e, 24 nov. 1987, D. 1988. Somm. 116 ; 11 mai 1994, RDI 1994. 458). L'effet interruptif n'est admis que si la *personne qui agit est la victime et qu'elle a qualité pour agir* ; le maître de l'ouvrage interrompt le délai au bénéfice de son ayant cause (Civ. 3e, 10 janv. 1990, RDI 1990. 217 ; 10 juill. 1996, n° 1319 D) ; le copropriétaire, qui a intérêt à agir, en particulier lorsqu'il subit un préjudice personnel, interrompt la prescription à son profit et au profit du syndicat pour les désordres affectant les parties communes, dès lors que sa demande et celle du syndicat, qui s'est jointe plus tard à la sienne, tendent à la « réparation des mêmes vices » et sont « indivisibles » (Civ. 3e, 20 mars 2002, RDI 2002. 239 ; comp. Civ. 3e, 20 mai 1998, RDI 1998. 420, qui est dans le même sens, et Civ. 3e, 7 juill. 1999, RDI 2000. 59, qui est en sens contraire) ; en revanche, l'action du syndic de copropriété n'interrompt pas le délai à l'égard des copropriétaires pour les désordres aux seules parties privatives (Civ. 3e, 16 mars 1994, n° 91-20.128, Bull. civ. III, n° 56 ; 15 nov. 1989, *ibid.* III, n° 212 ; sur l'action du syndic non habilité : 7 nov. 1990, n° 89-12.380, Bull. civ. III, n° 222 ; 6 nov. 1996, n° 94-212.12 ; sur l'action du syndic au profit des copropriétaires, V. : Civ. 3e, 20 mai 1998, BPIM 5/98, n° 249 ; comp. : 7 juill. 1999, RDI 2000. 59). De même, l'action de l'assureur multirisques habitation contre le constructeur (Civ. 3e, 20 oct. 2004, n° 03-14.374), ou celle de l'assureur DO (dommages ouvrage) contre les constructeurs pour leur rendre l'expertise opposable (Civ. 3e, 23 juin 2004, n° 01-17.723, Bull. civ. III, n° 124), n'interrompent pas la prescription au bénéfice du propriétaire assuré ou de l'ayant droit du maître de l'ouvrage (sur l'action de l'assureur DO subrogé : Civ. 3e, 4 juin 2009, n° 07-18.960, Bull. civ. III, n° 129). *L'effet interruptif est limité à la personne assignée.* Il ne s'étend pas aux personnes non mises en cause (Civ. 3e,

21 mai 2008, n° 07-13.561). L'acte interruptif produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (C. civ., art. 2242). L'effet interruptif est rétroactivement anéanti en application de l'article 2247 ancien et de l'article 2243 nouveau du code civil si : l'assignation est nulle pour défaut de forme ; le demandeur se désiste ; le demandeur laisse l'instance se périmer ; le demandeur est débouté (Civ. 3e, 20 déc. 1983, Bull. civ. III, n° 275. – Civ. 3e, 9 févr. 2000, n° 98-16.017. – Civ. 2e, 24 janv. 1996, n° 93-21.870, Bull. civ. II, n° 13) ; l'assignation est irrégulière faute d'habilitation du syndic de copropriété (Civ. 3e, 23 oct. 2002, n° 01-00.206, Bull. civ. III, n° 207). En application de l'ancien article 2247, l'assemblée plénière avait jugé que la caducité de l'assignation remettait en cause l'effet interruptif attaché à l'assignation elle-même (Cass., ass. plén., 3 avr. 1987, Bull. civ., n° 2) ; l'article 2243 ne visant plus les irrégularités de forme, on se demande si cette solution, et même certaines de celles exposées ci-dessus, doivent se maintenir.

620. Cas du référé. - L'*assignation en référé* a un effet interruptif (C. civ., art. 2241) même si le juge est incompétent (Civ. 3e, 30 juin 1998, n° 1136 D, BPIM 6/98, n° 402). La circonstance que le contrat prévoit une procédure de conciliation préalable devant une instance professionnelle n'empêche pas d'agir en référé pour l'allocation d'une provision (Civ. 3e, 23 mai 2007, n° 06-15.668, RDI 2007. 355, obs. Malinvaud) ou pour interrompre la prescription (Civ. 3e, 28 mars 2007, n° 06-13.209, Bull. civ. III, n° 43, RDI 2007. 355, obs. Malinvaud). L'effet interruptif est limité aux désordres dénoncés et aux personnes visées ; il ne concerne pas les personnes appelées à la cause par le défendeur pour leur rendre l'expertise opposable (Civ. 3e, 7 nov. 2012, n° 11-23.229 et n° 11-246340, Bull. civ. III, n° 250). L'ordonnance sur requête n'a pas d'effet interruptif mais l'opposition du maître de l'ouvrage à une rétractation d'ordonnance ayant prononcé une extension d'expertise a un effet interruptif (Civ. 3e, 14 déc. 2011, n° 10-25.178, Bull. civ. III, n° 214). Une fois l'ordonnance rendue, le juge des référés est dessaisi. Un nouveau délai court à compter de l'ordonnance (Civ. 3e, 11 mai 1994, RDI 1994. 458 ; 17 mai 1995, n° 93-16.568, Bull. civ. III, n° 120 ; 4 juin 1997, BPIM 4/97, à propos de la garantie biennale ; comp. : Civ. 3e, 11 janv. 1995, n° 93-10.327, Bull. civ. III, n° 10, RDI 1995. 330, qui semble faire courir le délai à compter de l'assignation), même si celle-ci ordonne une expertise (Civ. 2e, 6 mars 1991, n° 89-16.995, Bull. civ. II, n° 77 ; V., sur l'action en référé au titre des vices apparents dans la vente d'immeuble à construire : Civ. 3e, 21 juin 2000, RJDA 9 oct. 2000, n° 855 ; sur la jurisprudence administrative : CE 22 juill. 1992, RDI 1992. 521). L'article 2239 du code civil résultant de la réforme de la prescription précise toutefois que la prescription est suspendue lorsque le juge ordonne une mesure d'instruction avant tout procès : le délai de prescription ne recommence à courir que du jour où la mesure est exécutée ; on se demande si cette disposition peut s'appliquer au « référé-expertise ». L'effet interruptif est rétroactivement anéanti si le juge des référés

rejette la requête (Civ. 1re, 27 févr. 1996, n° 93-21.436, Bull. civ. I, n° 111), mais non si le juge des référés se déclare incompétent (Civ. 3e, 30 juin 1998, BPIM 6/98, n° 402). Si le juge du fond déboute le demandeur, l'effet interruptif attaché à une ordonnance de référé (qui prescrit une expertise, par exemple) est rétroactivement anéanti. Les principes exposés à propos de l'assignation au fond sur la rétroactivité de l'anéantissement sont applicables (V. sur les effets d'une action en garantie des vices apparents fondée sur l'art. 1648 du code civil, Civ. 3e, 21 juin 2000, RJDA 9-10/00, n° 855). L'action en justice a un effet suspensif lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction en application de l'article 2239 du code civil, ce qui peut viser le référé-expertise (V. MALINVAUD, RDI 2010. 105). Toutefois, l'article 2220 exclut du champ d'application du titre XX du code civil le délai de forclusion. Les garanties décennale et biennale sont soumises à un délai de prescription, mais d'autres actions (art. 1642-1 et 1648 par ex.), relèvent de la forclusion (Civ. 3e, 3 juin 2015, n° 14-15.796, RDI 2015. 422. – Civ. 3e, 8 juill. 2015, n° 14-12.436. – CCH, art. L. 111-11, al. 3, relatif à l'isolation phonique).

621. À l'assignation en référé, l'article 2244 ajoute comme cause d'interruption le *commandement de payer* ou la *saisie* signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Dans les marchés publics, l'arrêté de débet produit le même effet (CE 24 janv. 1986, Mon. TP 21 déc. 1986, p. 49).

b. - Reconnaissance de responsabilité

622. Aveu. - La reconnaissance de responsabilité de la part de celui qui bénéficie de la prescription équivaut à un aveu et entraîne l'interruption de la prescription (V. C. civ., art. 2240. – Civ. 3e, 4 avr. 1978, Bull. civ. III, n° 145). La reconnaissance peut être expresse ou, en tout cas, non équivoque (Civ. 3e, 15 mars 1989, RDI 1989. 362 ; 4 déc. 1991, n° 90-13.461, Bull. civ. III, n° 297, RDI 1992. 332, obs. Malinvaud et Boubli). Elle peut émaner de l'avocat qui représente le constructeur (Civ. 3e, 23 oct. 1984, Gaz. Pal. 1985. Pan. 39). Hormis ce cas, la reconnaissance de responsabilité doit émaner de celui à qui on l'oppose (Civ. 3e, 6 janv. 1999, n° 97-12.300, RDI 1999. 259, obs. Malinvaud, BPIM 2/99, n° 140). Un « donné acte » n'est pas une reconnaissance de responsabilité (Civ. 3e, 15 nov. 1989, Bull. civ. III, n° 212), pas plus que l'exécution de travaux dont l'étendue ne peut pas être déterminée (Civ. 3e, 31 janv. 1990, RDI 1990. 217), ou la reconnaissance de garantie de l'assureur DO (Civ. 3e, 11 mars 2009, n° 08-10.905, Bull. civ. III, n° 61). En revanche, une *transaction* qui décrit les dommages et convient des modalités de la réparation, peut valoir reconnaissance de la responsabilité dans la limite des désordres existants (Civ. 3e, 10 juill. 2002, RDI 2002. 420). En cas d'interruption, un nouveau délai court contre le constructeur, qui, en principe, n'est pas susceptible d'être rétroactivement anéanti.

4° - Effet de l'expiration des délais

623. Extinction des garanties. - À l'expiration du délai, un dommage susceptible de relever de la garantie décennale ou de la garantie biennale, qui n'a pas été dénoncé dans le délai, échappe à toute responsabilité, même si une faute du constructeur est alléguée (Civ. 3e, 10 avr. 1996, BPIM 4/96, n° 279 ; 22 mai 1997, BPIM 4/97, n° 266). En cas de dol du constructeur, il est généralement jugé que la responsabilité change de nature et qu'elle devient délictuelle (Civ. 3e, 21 nov. 1990, RGAT 1991. 125 ; 4 déc. 1991, RDI 1992. 74 ; 26 mai 1998, JCP 1998. IV. 267). Le dol est une faute volontaire qui n'implique pas l'intention de nuire (Civ. 3e, 18 déc. 1996, RJDA 4/97, n° 590). Un arrêt semble cependant s'engager dans une distinction entre le dol « contractuel » et le dol « extracontractuel ». Il décide que, sauf « faute extérieure au contrat », le constructeur est « contractuellement » tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive (Civ. 3e, 27 juin 2001, Bull. civ. III, n° 83, RDI 2001. 525, obs. Malinvaud, D. 2001. 2995, concl. J.-F. Watier, note Karila, JCP 2001. II. 10626, note Malinvaud ; V. déjà : Civ. 3e, 5 janv. 1983, RDI 1983. 233 ; 23 juill. 1986, Bull. civ. III, n° 129). Il semble qu'une distinction soit envisageable entre intention de nuire (faute extracontractuelle : responsabilité quasi délictuelle se prescrivant par dix ans à compter du dommage) et dol sans intention de nuire (faute contractuelle entraînant une prescription de trente ans ; V. *infra,* n° 660). Les nouvelles dispositions du code civil semblent assimiler la faute lourde au dol (C. civ., nouv. art. 1231-3 et 1231-4).

C - Caractère d'ordre public des garanties : effet sur les clauses relatives à la responsabilité

624. Prohibition. - Les garanties décennale et biennale, comme la garantie de parfait achèvement d'ailleurs, sont d'ordre public. L'article 1792-5 prohibe les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ainsi que celles qui excluent la solidarité mise à la charge du fabricant d'EPERS par l'article 1792-4.

625. Les clauses interdites sont celles qui excluent ou qui limitent la responsabilité décennale (ou biennale) et celles qui évincent la responsabilité solidaire (V. *infra,* n° 626). Comme le relève M. MALINVAUD, le caractère d'ordre public des garanties est, en effet, affirmé au « sens plein » (Dalloz Action, Droit de la Construction, 2014-2015, n° 475-830). Il en résulte qu'une clause ne peut ni exclure certains dommages ou certains ouvrages du champ des garanties (V., à titre de comparaison, la jurisprudence qui prohibe les clauses d'exclusion de garantie de certains ouvrages relevant de l'activité du constructeur du domaine de l'assurance obligatoire : Civ. 3e, 17 juin 1992, RDI 1992. 355 ; 3 mai 2001, Le Moniteur du 3 août 2001, p. 46 ; 7 juill. 1993, n° 91-

10.071, Bull. civ. I, n° 247 ; 10 déc. 1996, BPIM 3/97, n° 198), ni réduire le délai de garantie institué par la loi (V. antérieurement à la loi de 1978, à propos de la clause du contrat d'entreprise instituant un point de départ du délai de garantie jugé plus favorable pour lui par l'architecte qui s'en est prévalu : CE 25 avr. 1969, D. 1969. 498, qui valide cette option et Civ. 3e, 13 nov. 1974, D. 1975. IR 10, qui la condamne). L'article 2254 du code civil issu de la réforme de la prescription, qui autorise les parties à réduire la durée de la prescription sans qu'elle puisse être inférieure à un an, n'a donc pas vocation à s'appliquer. La question de savoir si une clause du contrat pourrait exclure de la garantie décennale les dommages consécutifs est évoquée par Ph. MALINVAUD (Dalloz Action, *op. cit.,* n° 475-840), qui estime que la validité d'une telle exclusion est peu probable au regard de l'article 1792 qui sert de visa aux décisions favorables à la réparation des dommages consécutifs (Civ. 3e, 18 juin 1980, Bull. civ. III, n° 121).

626. Cas particuliers. - En revanche, il est possible d'augmenter par voie conventionnelle la durée du délai de la garantie biennale dont le rapport Spinetta et les travaux préparatoires de la loi de 1978 montrent qu'il avait été conçu comme un plancher. L'article 2254 du code civil précise toutefois que la durée de la prescription ne peut être étendue à plus de dix ans, ce dont il résulte que le délai de la garantie décennale ne peut être augmenté, et que le délai de la garantie biennale ne peut l'être que dans cette limite. Il est également possible d'élargir le champ des désordres relevant de la garantie décennale (ou biennale, mais l'intérêt est aujourd'hui relatif) ou d'introduire des clauses de garantie mutuelle entre constructeurs. De telles clauses, qui se bornent à transférer la charge définitive du sinistre au constructeur garant (mais sans doute pas à l'assureur de responsabilité décennale), n'affectent en rien le droit d'action de la victime, car elles ne peuvent en principe exonérer un constructeur tenu à garantie de sa responsabilité solidaire (Civ. 3e, 18 juin 1980, RDI 1981. 79 ; 25 nov. 1987, D. 1987. IR 247. – Paris, 16 nov. 1979, RDI 1980. 300 ; CE 20 sept. 1999, req. n° 163141, BPIM 6/99, n° 435). Cette remarque est toutefois à l'épreuve de la jurisprudence récente. Un arrêt qui valide les clauses d'éviction de la solidarité et de l'obligation « *in solidum* », au moins lorsque la responsabilité encourue est celle de droit commun, encore qu'il énonce la règle en termes généraux (Civ. 3e, 19 mars 2013, n° 11-25.266, RDI 2013. 316, note Boubli. – Civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 14-29.347, RDI 2016. 290, obs. Boubli) suggère une distinction qui paraît théorique. À moins qu'elle ne soit d'origine légale (cas de l'art. 1792-4 c. civ.), la solidarité est en général prévue par le contrat ; on peut donc penser que le contrat qui peut créer la solidarité peut aussi l'écarter ; mais alors, cette solution aurait du mal à s'accommoder de la jurisprudence commerciale qui prononce des condamnations « solidaires ». D'ailleurs, l'arrêt autorise l'éviction tant de la solidarité que de l'obligation « *in solidum* ». Un précédent avait ouvert la voie (Civ. 3e, 11 mai 1988, paraissant admettre l'opposabilité des clauses d'exclusion de solidarité) alors que la Haute juridiction avait jusque-là bien distingué la solidarité de l'obligation « *in solidum* » (Civ. 3e, 18 juin 1980, n° 78-

16.096, Bull. civ. III, n° 121. – Civ. 3e, 25 nov. 1987, n° 85-17.170, Bull. civ. III, n° 196 ; RDI 1988. 215, note Malinvaud et Boubli). La solidarité des bureaux de contrôle technique, qui souhaitaient s'en affranchir, demeure d'ailleurs dans les rapports avec le maître de l'ouvrage, alors qu'elle est probablement imparfaite, et l'exclusion n'est admise qu'à l'égard des autres constructeurs (CCH, art. L. 111-24, al. 2). La réponse à la question de savoir si la solidarité imparfaite peut être exclue lorsque les garanties légales sont en cause est donc incertaine (sur la responsabilité de droit commun, V. *infra,* n° 662). Les clauses de garantie mutuelle sont en revanche valables (Civ. 3e, 3 nov. 1969, Bull. civ. III, n° 325 ; 22 mai 1969, D. 1969. 653 ; sur les difficultés de mise en œuvre de ces clauses, V. toutefois : B. BOUBLI, La responsabilité et l'assurance des constructeurs, 1979, n° 362 ; G. VINEY, RDI 1982. 319).

ACTUALISATION

626. Clause limitative de responsabilité solidaire ou *in solidum* de l'architecte. - À l'occasion de l'interprétation d'une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de maîtrise d'œuvre, la Cour de cassation confirme que l'architecte est autorisé à prévoir que sa responsabilité ne pourra être engagée solidairement, ni *in solidum*, avec celle des autres intervenants à l'opération (Civ. 3e, 14 févr. 2019, n° 17-26.403, D. actu. 28 févr. 2019, obs. D. Pelet).

D - Réparation du dommage

627. La réparation du dommage est un principe important, il faut étudier la responsabilité solidaire des constructeurs (V. *infra,* nos 628 s.), et établir l'étendue et la forme des réparations (V. *infra,* nos 633 s.).

1° - Responsabilité « in solidum » des constructeurs

628. En application du principe de la responsabilité *in solidum* des constructeurs, il faut établir quelle est l'obligation (V. *infra,* n° 629) et la contribution à la dette de réparation (V. *infra,* nos 630 s.).

a. - Obligation à la dette

629. Solidarité parfaite ou imparfaite. - Lorsque le titre constitutif de l'obligation le permet (Civ. 3e, 25 janv. 2005, n° 03-20.842, Bull. civ. III, n° 14, D. 2005. Pan. 1424) ou si les codébiteurs sont dans une situation permettant de la retenir entre commerçants, leur responsabilité peut s'accompagner d'une condamnation

solidaire à réparer les conséquences du dommage causé à la victime ; cette *solidarité* « parfaite » doit être établie (Civ. 3e, 26 janv. 2005, préc.). Le plus souvent, les constructeurs présumés responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil n'ont en général aucun lien de droit entre eux ; s'ils sont deux ou plusieurs et qu'aucun n'établit un cas de force majeure, leur responsabilité est engagée *in solidum* envers le maître de l'ouvrage ou ses ayants cause. Chacun répond pour le tout sans pouvoir opposer au créancier la division de la dette ou d'autres exceptions (Civ. 3e, 22 nov. 1978, Bull. civ. III, no 356 ; V. HUET, L'obligation *in solidum* des constructeurs et le jeu de la solidarité dans la responsabilité des constructeurs, RDI 1983. 11). L'obligation *in solidum* est une forme de solidarité, sans représentation mutuelle ; la solidarité est imparfaite. L'engagement « *in solidum* » reçoit des justifications diverses : les fautes « se pénètrent et se complètent quant à leurs conséquences dans des conditions telles qu'elles forment un tout indivisible » (Civ. 3e, 29 nov. 1969, Bull. civ. III, no 509 ; 25 mars 1980, Bull. civ. III, no 69 ; 6 oct. 1993, no 91-20.397, Bull. civ. III, no 120) ; le « dommage unique » a plusieurs causes (Civ. 3e, 23 janv. 1974, D. 1974. IR 112 ; 4 févr. 1986, RDI 1986. 369 ; 4 juill. 1990, Gaz. Pal. 1991. Pan. 19), le fait de chaque constructeur étant censé être à l'origine de l'entier dommage (Civ. 3e, 26 janv. 2005, no 03-15.124). L'engagement « *in solidum* » est la conséquence d'une décision judiciaire dont l'objet est de favoriser l'indemnisation de la victime. En pratique, trois conditions sont nécessaires : un concours de responsabilités : peu importe que les fautes soient prouvées (Civ. 3e, 20 févr. 1969, Bull. civ. III, no 158), que l'une soit prouvée et l'autre présumée (Civ. 3e, 25 janv. 1978, Bull. civ. III, no 51), que les deux soient présumées (Civ. 3e, 27 juin 2001, préc. *supra,* no 561) ; peu importe, également, qu'une responsabilité soit contractuelle et l'autre extracontractuelle (Civ. 3e, 25 mars 1980, Gaz. Pal. 1980. Pan. 316) ou qu'elles soient de même nature (Civ. 3e, 2 oct. 1979, JCP 1979. IV. 359) ; un dommage unique (arrêts précités sur ce point) ; l'absence de cause étrangère exonérant l'un des constructeurs (Civ. 3e, 25 janv. 1978, Bull. civ. III, no 51 ; comp., lorsque l'entrepreneur a procédé à la réparation en nature et que le vice originel est de conception, en sorte que les désordres subsistent, Civ. 3e, 11 oct. 2000, BPIM 1/01, no 46, qui retient la seule responsabilité du maître d'œuvre. – Sur les clauses excluant la solidarité parfaite ou imparfaite, V. *supra* nos 625 et 626).

ACTUALISATION

629. Clause d'exclusion de solidarité et faute de l'architecte. - La clause d'exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant *in solidum* avec d'autres constructeurs, et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage à son encontre, quand sa faute a concouru à la réalisation de

l'entier dommage (Civ. 3e, 19 janv. 2022, n° 20-15.376, D. actu. 14 févr. 2022, obs. N. De Andrade).

b. - Contribution à la dette

630. Répartition. - Le constructeur, tenu *in solidum* avec d'autres, peut se garantir d'une partie de la dette en demandant au juge de répartir la contribution des codébiteurs en exerçant un recours contre son coobligé (Civ. 3e, 31 mai 1998, Bull. civ. III, n° 221). Le recours contre le coobligé doit être exercé dans le délai du recours par le maître de l'ouvrage contre le débiteur concerné (Civ. 3e, 13 mai 1987, D. 1987. IR 128 ; 15 févr. 1989, Bull. civ. III, n° 36 ; 17 mars 1993, RDI 1993. 228). Théoriquement, s'il a payé le maître de l'ouvrage, il peut exercer contre les autres constructeurs l'action subrogatoire. Mais celle-ci est difficile à mettre en œuvre car, par l'action subrogatoire, le constructeur présumé responsable qui a payé ne peut prétendre se soustraire à sa propre dette et, en outre, il est généralement admis que le codébiteur en faute ne peut agir contre celui dont la responsabilité est présumée (Civ. 3e, 11 déc. 1973, Bull. civ. III, n° 622). Il s'agit, sans doute, de l'application d'une règle, qui se répand, selon laquelle la subrogation n'est admise que lorsqu'il n'existe aucun lien contractuel entre celui qui a payé et le coresponsable, et entre ce dernier et le maître de l'ouvrage. Ainsi, l'action subrogatoire, non recevable dans les rapports entre constructeurs de premier rang, est possible dans les rapports entre l'architecte et le sous-traitant de l'entrepreneur ou entre l'architecte et le fournisseur de l'entrepreneur (Civ. 3e, 9 juin 1999, BPIM 5/99, n° 369 ; comp. : Civ. 3e, 29 mars 2000, BPIM 3/00, n° 178, qui admet l'action personnelle).

631. Action personnelle. - La jurisprudence préfère donc justifier le recours entre constructeurs qui n'ont entre eux aucun lien de droit, en le fondant sur leur action personnelle. Les constructeurs étant des tiers entre eux, c'est l'article 1240 du code civil qui s'applique (C. civ., art. 1382 anc.) : le constructeur intéressé exerce contre l'autre l'action personnelle en réparation du dommage que lui cause la faute commise par ce dernier dans la réalisation du dommage (Civ. 3e, 30 avr. 2002, RDI 2002. 324) ; cette faute doit être établie. Il s'opère alors un partage de responsabilité en fonction des fautes respectives de chacun des constructeurs (Civ. 3e, 16 janv. 1969, Bull. civ. III, n° 43 ; ; 22 nov. 1978, RDI 1979. 218 ; 27 mars 1996, RDI 1996. 383 ; 25 nov. 1998, n° 97-11.408, Bull. civ. III, n° 221. – Civ. 1re, 16 févr. 1994, n° 90-19.090, Bull. civ. I, n° 72). La faute du débiteur doit être établie (Civ. 3e, 25 nov. 1998, préc. ; 29 mars 2000, BPIM 3/00, n° 178 ; 22 juin 2005, n° 03-16.557, RDI 2005. 439, obs. Boubli ; 21 oct. 2008, RDI 2008. 557). Cette faute peut résulter de la mauvaise exécution du contrat : le fait fautif est alors pris en lui-même, « en dehors de tout point de vue contractuel » (Civ. 1re, 9 oct. 1962, Bull. civ. I, n° 405. – Civ. 3e, 31 janv. 1969,

JCP 1969. II. 15937 ; 15 oct. 1970, Bull. civ. III, n° 515 ; 11 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 190). Le fait doit être objectivement illicite, ce qui est rarement le cas du manquement à l'obligation de conseil (Civ. 3e, 10 janv. 1970, RDI 1979. 346 ; 25 nov. 1998, n° 97-11.408, Bull. civ. III, n° 221). L'action personnelle fondée sur la faute n'est pas sans inconvénient lorsqu'il y a une responsabilité *in solidum* entre constructeurs présumés responsables ; le recours de celui qui a payé est susceptible d'être privé d'effet si la faute du codébiteur n'est pas établie ; ce risque est théoriquement exclu lorsque l'action est exercée à titre subrogatoire : il s'opère alors un partage par part virile (Cass., ch. mixte, 20 déc. 1968, D. 1969. 37, 2e esp.). Pour éviter que celui qui a payé ne supporte seul la dette, il faut sans doute avoir recours à la théorie de l'enrichissement sans cause…

632. Lorsque les coobligés sont liés par un contrat, celui qui a payé peut se retourner contre son contractant en invoquant sa responsabilité contractuelle, ce qui peut avoir pour effet de lui transférer toute la charge du dommage (entrepreneur garanti par le sous-traitant responsable : Civ. 3e, 22 sept. 2004, n° 03-11.391, BPIM 1/05, inf. 40).

2° - Étendue et formes de la réparation

633. Évaluation du dommage. - Le juge qui constate un préjudice, même dans son principe, doit l'évaluer (Civ. 3e, 6 févr. 2002, RDI 2002. 152). Toutefois, la Cour de cassation a pu mettre à la charge du maître de l'ouvrage la preuve de son montant alors même qu'un expert avait été commis (Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-18.836). La réparation doit être *intégrale* (Civ. 3e, 13 mars 1973, D. 1973. IR 88 ; 28 nov. 1978, RDI 1978. 347 ; 24 oct. 1990, Le Moniteur du 11 janv. 1990). Elle couvre tous les chefs de préjudice indemnisables (défaut de conformité impliquant le rétablissement à l'identique : Civ. 3e, 13 avr. 1983, RDI 1983. 458 ; désordres esthétiques, etc., V. *supra,* nos 588 s.), dès lors que le dommage est certain (ce qui vise, en particulier, les désordres évolutifs et les désordres futurs). Le dommage résultant de l'*absence d'ouvrage,* et plus généralement des « non-façons », est également pris en compte : il y a absence d'ouvrage lorsqu'un équipement ou un élément constitutif fait défaut et qu'il en résulte un dommage entrant dans le champ d'application des garanties. La réparation doit tenir compte de la nécessité d'exécuter ces ouvrages, soit pour permettre à l'ouvrage d'être conforme à sa destination (Cass., ass. plén., 7 févr. 1986, Bull. civ., n° 2), soit pour éviter l'apparition de nouveaux désordres (Civ. 3e, 9 oct. 1991, n° 87-18.226, Bull. civ. III, n° 231 ; 11 oct. 2000, RDI 2001. 86). En l'absence d'immixtion fautive ou d'acceptation délibérée des risques, le maître de l'ouvrage est une victime, et la réparation doit tenir compte de la nécessité de réaliser les travaux omis (absence d'ouvrage) qui étaient à l'origine du sinistre (Civ. 3e, 17 janv. 1996, BPIM 6/96, n° 411 ; 2 oct. 1996, n° 1567 D, inédit ; 28 févr. 2000, BPIM2/01, n° 123 ; Civ. 3e, 11 avr. 2012, n° 10-26.971, BPIM 3/12, inf. 241). Il ne s'agit que d'appliquer la règle

selon laquelle l'origine du dommage est indifférente (Civ. 3e, 20 févr. 2001, RDI 2001. 170). Il n'y a pas d'enrichissement du maître de l'ouvrage, car celui-ci n'a pas à supporter injustement une dépense rendue nécessaire par la faute du constructeur (V. *infra,* n° 635) : il faut rappeler, en effet, que l'entrepreneur prend à son compte *l'aléa technique* dans le marché de travaux (V. B. BOUBLI, Les modifications apportées au marché par le maître de l'ouvrage, RDI 2002. 482). Entre également dans la réparation le coût des études, essais et vérifications rendus nécessaires pour l'exécution des travaux de reprise (Civ. 3e, 15 mai 2001, RDI 2001. 392), les dommages immatériels, en particulier s'ils sont la conséquence d'un dommage causé à « l'ouvrage ». La TVA est exclue de la réparation si la victime la récupère (Civ. 1re, 17 nov. 1998, RJF 4/99, n° 405 ; 19 févr. 2002, RDI 2002. 240). La réparation doit être évaluée à la date à laquelle le juge statue : dès lors, le montant de la TVA ne peut être fixé au taux applicable à la date à laquelle les travaux de réfection seront exécutés (Civ. 3e, 25 sept. 2002, BPIM 6/02, n° 395). Le préjudice né du retard est distinct de celui dû aux malfaçons et il doit être réparé en sus (Civ. 3e, 12 mars 1974, Bull. civ. III, n° 113).

634. Réparation en nature. - La réparation peut être ordonnée en *nature,* c'est-à-dire par une condamnation prescrivant la remise en état des lieux, lorsque cela est possible (Civ. 3e, 28 févr. 1969, Bull. civ. III, n° 182). Le juge apprécie cette possibilité (Civ. 1re, 28 mai 1962, Bull. civ. I, n° 266 ; 13 janv. 1964, D. 1964. Somm. 69. – Civ. 3e, 4 juin 1975, Bull. civ. III, n° 211). S'il ordonne une réparation en nature ou s'il constate qu'elle est réalisée, il ne déduit pas la plus-value procurée par la remise en état (Civ. 3e, 16 juin 1993, n° 92-10.636, Bull. civ. III, n° 86. – Com. 4 mars 1974, Bull. civ. IV, n° 75. – Civ. 3e, 9 déc. 1975, Bull. civ. III, n° 363). Le maître de l'ouvrage n'a pas à supporter la charge des prétendues améliorations lorsque les travaux réalisés sont nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage à sa destination (Cass., ass. plén., 7 févr. 1986, Bull. civ., n° 2) ou à la prévention du risque de réapparition des désordres (Civ. 3e, 9 oct. 1991, n° 87-18.226, Bull. civ. III, n° 231 ; 26 janv. 2000, BPIM 2/00, n° 103 ; 28 févr. 2001, BPIM 2/01, n° 123). *Il n'y a donc pas lieu de déduire la plus-value procurée par la réfection de l'ouvrage* (Civ. 3e, 7 mars 1968, Bull. civ. III, n° 97 ; 12 déc. 1973, D. 1974. Somm. 28. – Com. 4 mars 1974, Bull. civ. IV, n° 75 ; V. aussi : Civ. 3e, 16 juin 1993, n° 92-10.636, Bull. civ. III, n° 86, RDI 1993. 513, obs. Malinvaud et Boubli, RTD civ. 1994. 118, obs. Jourdain ; 11 juill. 2001, n° 1204 FS). Toutefois, il ne faut pas que, sous couvert de réparation en nature, le maître de l'ouvrage modifie l'ouvrage (ardoises au lieu de tuiles : Civ. 3e, 30 oct. 1982, RDI 1983. 233). Le mode de réparation étant défini par le juge, il semble que le maître de l'ouvrage ne puisse pas s'opposer à la réparation en nature si elle est ordonnée (Civ. 1re, 3 oct. 1962, Bull. civ. I, n° 393. – Civ. 3e, 28 févr. 1969, Bull. civ. III, n° 182). Il

est néanmoins permis de se demander si le juge a la faculté de substituer une réparation en nature à une réparation par équivalent lorsque celle-ci est demandée et que le défendeur s'en tient à cette demande. C'est peu probable, car il modifierait l'objet du litige. En revanche, il paraît admis que l'entrepreneur ne peut imposer la réparation en nature au maître de l'ouvrage qui la refuse et qui n'a plus confiance en lui (Civ. 3e, 28 sept. 2005, n° 04-14.586, Bull. civ. III, n° 180, RDI 2005. 458, obs. Malinvaud, RDI 2005. 442, obs. Boubli, RTD civ. 2006. 129, obs. Jourdain, RTD civ. 2006. 311, obs. Mestre et Fages ; 22 oct. 2008, n° 07-17.451).

635. Indemnité. - S'il décide d'allouer *une indemnité* pour réparer le préjudice représenté par le coût de la remise des lieux en état, le *juge civil ne tient pas compte d'un abattement pour vétusté,* car il faut « replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » (Civ. 2e, 16 déc. 1970, Bull. civ. II, n° 346. – Civ. 3e, 6 mai 1998, BPIM 4/98, n° 270). À défaut, elle « supporterait injustement une dépense rendue nécessaire par la faute d'un tiers » (même arrêt). Si la réfection totale est seule de nature à indemniser intégralement le préjudice subi, il n'y a pas lieu de procéder à un abattement pour vétusté sur l'indemnité qui contribue à cette réparation (Civ. 3e, 20 juin 2007 n° 06-14.241) ou de faire supporter au maître de l'ouvrage les prétendues améliorations (Civ. 3e, 26 sept. 2012, n° 11-17.602, BPIM 6/12, inf. 449. – Civ. 3e, 20 nov. 2013, n° 12-29.259, Bull. civ. III, n° 147. – V. toutefois, Civ. 3e, 22 mai 2012, n° 11-12.229, RDI 2012. 446, qui exclut de la réparation les « travaux nécessaires » et paraît déroger au principe posé par l'arrêt de 2013 qui, il est vrai, lui est postérieur). Les principes exposés à propos de la réparation en nature sont adaptables (sur la jurisprudence administrative qui tient compte d'un abattement pour vétusté : CE 10 févr. 1993, RDI 1993. 219 ; et pour enrichissement, lorsqu'il estime que des travaux neufs procurent cet avantage : CE 23 juin 1995, req. n° 130414, Lebon T. 906, sauf si les travaux de reprises sont conformes aux exigences du contrat : CE 12 avr. 1995, D. 1996. Somm. 144, obs. Ph. Terneyre). L'indemnité allouée comporte intérêt au taux légal, même lorsqu'elle est provisionnelle (Civ. 2e, 19 oct. 2000, RDI 2001. 86) (sur la TVA, V. Mémento Urbanisme Construction 2016, n° 91290).

Art. 2 - Responsabilité contractuelle de droit commun

636. Caractère résiduel. - La responsabilité contractuelle est applicable lorsque le dommage ne relève pas de la garantie décennale ou biennale, soit que l'ouvrage n'est pas un de ceux visés aux articles 1792 et suivants, soit que les conditions relatives au désordre garanti ne sont pas réunies. Dans ce dernier cas, elle a un caractère résiduel. Le principe d'une responsabilité contractuelle de droit commun subsidiaire aux garanties décennale et biennale, dont nous avons été pendant longtemps l'un des rares

défenseurs (BOUBLI, la Responsabilité des architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage, 1re éd.), a été contesté par une importante partie de la doctrine au nom de l'effet exonératoire de la réception ; mais la jurisprudence n'a pas suivi ce courant discutable : aujourd'hui, la responsabilité contractuelle de droit commun, dans les limites de son domaine propre, survit à la réception des travaux ; les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil la consacrent (V. *infra,* nos 637 s.). La responsabilité de droit commun est donc encourue, tant par ceux qui peuvent être soumis pour les dommages en relevant, de la garantie décennale et de la garantie biennale (Civ. 3e, 13 juill. 2016, no 15-20.147 ; V., pour un constructeur qui n'a pas satisfait à l'obligation de s'assurer en responsabilité décennale : Civ. 3e, 23 nov. 2005, no 04-16.023, Bull. civ. III, no 225, RDI 2006. 54, obs. Malinvaud, RDI 2006. 33, obs. Dessuet ; plus généralement, V. *infra,* nos 645 s.) que par ceux qui ne sont pas tenus à ces garanties. Le *sous-traitant,* figure parmi ces derniers ; il est toujours tenu d'une responsabilité contractuelle de droit commun envers l'entrepreneur principal, qui est fondée sur la violation d'une obligation de résultat (Civ. 3e, 13 juin 1990, no 88-17.234, Bull. civ. III, no 145 ; 17 déc. 1997, BPIM 2/98, no 103 ; 27 mai 1999, no 902 D, BPIM 4/99, no 285 ; 4 nov. 1999, BPIM 1/00, no 21. – Versailles, 13 déc. 1999, RDI 2000. 177). Le droit commun du contrat d'entreprise mettant à la charge de l'entrepreneur une obligation de résultat (V. *supra,* nos 72 s.), celle-ci est illustrée dans la construction immobilière, par la jurisprudence relative au sous-traitant qui n'est qu'un entrepreneur soumis au droit commun de la responsabilité contractuelle dans ses rapports avec le donneur d'ordres. Toutefois, les solutions positives ne sont pas toujours très claires.

§ 1er - Responsabilité avant réception

637. Avant la réception de l'ouvrage, il est possible d'engager la responsabilité de l'entrepreneur, il convient alors de définir les dommages concernés (V. *infra,* nos 638 s.) et d'en rappeler le régime (V. *infra,* nos 654 s.).

A - Dommages concernés

638. Il faut distinguer le retard dans l'exécution (V. *infra,* no 639), les dommages causés par l'ouvrage (V. *infra,* no 640) et les malfaçons (V. *infra,* nos 641 s.).

1° - Retard dans l'exécution

639. Débiteur. - En cas de retard (qui normalement s'apprécie à la livraison, mais peut poser problème dès la réception), la responsabilité en incombe à l'entrepreneur qui

manque alors à son obligation de résultat de respecter le délai contractuel (Civ. 3e, 29 janv. 1998, BPIM 2/98, n° 109 ; V. *infra,* nos 394 s.) ; la faute du maître de l'ouvrage ne l'exonère totalement que si elle est la cause exclusive du dommage (Civ. 3e, 8 nov. 2005, n° 04-17.701, Bull. civ. III, n° 212, RDI 2006. 57, obs. Malinvaud). La responsabilité de l'architecte, plus généralement du maître d'œuvre, implique la preuve de sa faute (Civ. 3e, 31 mai 1989, Bull. civ. III, n° 120 ; sur le retard qui s'apprécie à la livraison de l'ouvrage, V. *supra,* nos 393 s.).

2° - Dommages causés par l'ouvrage

640. Existants et personnes physiques. - Ce sont les dommages causés aux existants ou aux personnes : les dommages causés aux *personnes* sur le chantier relèvent des accidents du travail. Si c'est le maître de l'ouvrage qui en est victime, la tendance jurisprudentielle est d'écarter l'existence d'une obligation contractuelle de sécurité et de préférer la responsabilité quasi délictuelle (Civ. 2e, 4 janv. 1963, Bull. civ. II, n° 16. – Civ. 3e, 27 nov. 1970, Bull. civ. III, n° 653 ; 19 oct. 1971, D. 1972. 77) devenue désormais « extra-contractuelle » (Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, désignant ainsi, le sous-titre II). L'obligation contractuelle de sécurité est admise à l'encontre du fabricant (Civ. 1re, 3 mars 1998, n° 96-12.078, Bull. civ. I, n° 95) ; les dommages aux *existants* pendant le chantier relèvent d'un régime imprécis. Certains arrêts se fondent sur la responsabilité du dépositaire tenu de restituer en bon état la chose remise (Civ. 3e, 6 juin 1972, Bull. civ. III, n° 368) ; d'autres préfèrent la responsabilité quasi délictuelle (Civ. 3e, 27 nov. 1970, préc. ; 22 avr. 1971, Bull. civ. III, n° 253), d'autres encore écartent l'application de l'article 1382 du code civil et ne semblent pas exclure la responsabilité contractuelle (Civ. 3e, 9 oct. 1991, n° 90-12.059, Bull. civ. III, n° 234. – Civ. 2e, 26 mai 1992, n° 91-11.149, Bull. civ. II, n° 154 ; V. déjà : Civ. 3e, 21 nov. 1972, Bull. civ. III, n° 623 ; 6 juin 1972, Bull. civ. III, n° 366 ; H. PÉRINET-MARQUET, La responsabilité relative aux travaux sur existants, RDI 2000. 483).

3° - Malfaçons prédécennales

641. Réception non prononcée. - Ce sont les désordres avant réception. En principe, ils donnent lieu à des réserves et relèvent de la responsabilité mise en œuvre une fois la réception intervenue (V. *supra,* n° 625) ; mais il arrive que le marché soit résilié avant achèvement. Si la résiliation donne lieu à un accord valant réception, il faut faire des réserves pour les défauts apparents et l'on se trouve dans le cas précédent (V. *supra,* n° 455). Si la résiliation ne vaut pas réception, la responsabilité de droit commun est encourue (Civ. 3e, 19 juin 1996, BPIM 5/96, n° 355 ; 3 juill. 1996, n° 95-10.808, RDI 1996. 581, obs. Malinvaud et Boubli).

B - Régime de la responsabilité

642. L'entrepreneur (V. *infra,* n°s 643 s.) et l'architecte (V. *infra,* n°s 644 s.) peuvent être responsables à différents niveaux. Il convient de déterminer lesquels.

1° - L'entrepreneur

643. Obligation de résultat. - Conformément au principe général applicable au contrat d'entreprise, l'entrepreneur est responsable pour n'avoir pas exécuté son obligation d'édifier et de livrer un ouvrage exempt de vices et défauts. *Il méconnaît alors une obligation de résultat* : le principe est posé à propos du sous-traitant (V. *supra,* n° 636) ; il est posé en termes généraux pour le contrat principal lorsque l'ouvrage ne relève pas de la garantie décennale (Civ. 3e, 5 févr. 1985, Bull. civ. III, n° 21 ; 19 févr. 2002 et 3 avr. 2002, RDI 2002. 240) ; il n'est guère discutable en cas de retard (V. *supra,* n°s 394 et 639) ; il est appliqué en cas de malfaçons prédécennales (Civ. 3e, 21 juill. 1999, BPIM 6/99, n° 432 ; 6 mai 2003, n° 01-03.521 , BPIM 4/03, inf. 234 ; 8 nov. 2005, n° 04-18.305 , RDI 2006. 55 ; 6 déc. 2005, n° 04-18.749 , RDI 2006. 136 . – Civ. 3e, 10 juill. 2013, n° 12-91.910, Bull. civ. III, n° 102). En cas d'effondrement ou de dommage en cours de chantier, les risques sont à la charge de l'entrepreneur (C. civ., art. 1788), qui assume la responsabilité du dommage qui lui est imputable (Civ. 1re, 2 déc. 1997, n° 95-19.466 , Bull. civ. I, n° 339 ; 22 oct. 2008, n° 07-17.451 , BPIM 6/08, n° 441 qui précise que le maître de l'ouvrage ne peut se voir imposer le mode de réparation décidé par l'entrepreneur). Lorsque le dommage est la conséquence d'un *défaut d'information* imputable à l'entrepreneur, on estime que le maître de l'ouvrage doit établir la faute de l'entrepreneur. Comme l'entrepreneur doit exécuter un ouvrage exempt de défauts (Civ. 3e, 21 juill. 1999, préc.), il semble que cette hypothèse se cantonne au cas où des dommages sont causés à la personne du maître de l'ouvrage. Dans certains cas, la jurisprudence a même mis à la charge du constructeur la preuve qu'il a rempli son devoir de conseil, en particulier lorsque le maître de l'ouvrage est un profane (Civ. 3e, 4 mai 1976, Bull. civ. III, n° 184 ; comp., toutefois : Civ. 3e, 20 juill. 1988, JCP 1988. IV. 351 ; 26 oct. 2005, n° 04-16.405 , RDI 2006. 56, obs. Malinvaud , RDI 2006. 191, obs. Trébulle , RJDA 2/06, n° 132).

2° - L'architecte

644. Obligation de moyens. - L'architecte (plus généralement le maître d'œuvre) *est tenu, estime-t-on, d'une obligation de moyens,* car il fournit un service intellectuel (V. *Architecte [Civ.]*). Quoique discutable, cette solution est, en général, celle de la jurisprudence, notamment en matière de retard (Civ. 3e, 31 mai 1989, Bull. civ. III,

n° 120. – Rappr., à propos du retard résultant de la non-délivrance d'un « consuel », document attestant de la sécurité de l'installation électrique, Civ. 3e, 5 déc. 2012, n° 11-24.449, Bull. civ. III, n° 180. – V. aussi, pour d'autres chefs de préjudice : Civ. 3e, 9 oct. 1979, JCP 1979. IV. 370 ; 11 juin 1985, RDI 1986. 77 ; 8 mars 1995, RDI 1995. 333 ; 14 mars 2007, n° 06-10.181. – Rouen, 15 mai 1991, RDI 1993. 230. – Paris, 29 avr. 1994, RDI 1994. 662 ; sur l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception, V. *supra,* nos 530 et 531). Mais certains arrêts n'hésitent pas à mettre à la charge de l'architecte la preuve qu'il a satisfait à son obligation de conseil (Civ. 3e, 4 mai 1976, Bull. civ. III, n° 184 ; *sur la prescription de l'action en responsabilité,* V. les règles générales *infra,* nos 656 s.).

§ 2 - Responsabilité après réception

645. La responsabilité décennale ou biennale n'évince pas, pour les constructeurs qui y sont tenus, la responsabilité contractuelle de droit commun. Cette dernière présente alors un caractère résiduel tant pour son régime (V. *infra,* nos 654 s.) que pour le domaine qu'elle couvre (V. *infra,* nos 646 s.).

A - Domaine de la responsabilité résiduelle

1° - Ouvrages soumis

646. Définition. - Tout ouvrage qui ne remplit pas les conditions pour entrer dans le champ d'application des garanties décennale et biennale, relève de la responsabilité de droit commun, en particulier s'il ne s'agit pas d'un travail de construction (Civ. 3e, 5 févr. 1985, Bull. civ. III, n° 21 ; 9 févr. 2000, BPIM 2/00, n° 101 : pour des travaux sur façade ; V. les arrêts cités *supra,* n° 516 ; J.-P. KARILA, La responsabilité pour les désordres affectant des travaux de ravalement ou de peinture, RDI 2001. 201). Il en résulte que si l'on n'est pas en présence d'un ouvrage, d'un élément constitutif d'ouvrage ou d'un élément d'équipement, au sens des articles 1792 et suivants, la responsabilité contractuelle de droit commun est seule encourue (Civ. 3e, 16 mai 2001, n° 99-15.062, Bull. civ. III, n° 62, RDI 2001. 350, obs. Leguay, RDI 2001. 387, obs. Tomassin, RDI 2001. 392, obs. Tomassin, D. 2002. 833, note. Karila. – Civ. 3e, 30 nov. 2011, n° 09-70.245, Bull. civ. III, n° 202). Les « équipements industriels », lorsqu'ils sont exclus des garanties légales, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.

2° - Dommages soumis

647. Lorsque l'ouvrage est soumis aux articles 1792 et suivants, la responsabilité de droit commun peut être néanmoins retenue si le dommage n'entraîne pas l'application des garanties décennale et biennale.

a. - Désordres apparents

648. Définition. - Si l'on excepte les désordres apparents à la réception prononcée sans réserves et dont les conséquences sont appréciables par le maître de l'ouvrage (ils échappent à toute responsabilité par l'effet de purge : Civ. 3e, 28 févr. 2012, n° 11-13.670, BPIM 3/12, inf. 238), la responsabilité de droit commun trouve matière à s'appliquer aux désordres apparents qui *ont donné lieu à des réserves* (Civ. 3e, 13 déc. 1995, n° 92-11.637, Bull. civ. III, n° 255, RDI 1996. 223, obs. Malinvaud et Boubli ; 28 janv. 1998, n° 96-13.460, Bull. civ. III, n° 19, RDI 1998. 257, obs. Malinvaud et Boubli, RDI 1998. 264, obs. Malinvaud et Boubli ; 2 oct. 2001, n° 99-21.759, RDI 2002. 89. – Civ. 3e, 27 janv. 2010, n° 08-21.185, Bull. civ. III, n° 20), alors même que ces dommages relèvent de la garantie de parfait achèvement ; peu importe que la personne dont la responsabilité est recherchée est l'entrepreneur qui doit cette garantie ou qu'il s'agit d'un autre constructeur (V. *supra,* nos 510 s.). Les désordres réservés qui sont tenus pour cachés au regard de la garantie décennale, car leur cause, leur ampleur et leurs conséquences ne sont appréciables que plus tard, sont théoriquement susceptibles de relever de la responsabilité de droit commun dans leur première manifestation, et de la garantie décennale lorsque les conséquences sont connues ; les réserves ne concernent que la première manifestation du désordre, non son importance (Civ. 3e, 28 févr. 1996, RDI 1996. 217 ; V. *supra,* nos 483 et 596) : un changement de régime de responsabilité dans le temps est-il concevable ? Une question du même ordre se pose pour les désordres non réservés qui ne se révèlent que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences : ils relèvent de la garantie décennale, à cet instant (V. *supra,* n° 595) ; avant cette révélation, ils ne peuvent justifier une condamnation au titre de la responsabilité de droit commun. La responsabilité de droit commun s'applique lorsque la réception est refusée : l'entrepreneur qui s'engage à effectuer les travaux de reprise et ne s'exécute pas, s'expose à des dommages-intérêts tenant compte le cas échéant du solde du prix restant dû (Civ. 3e, 24 juin 2014, n° 13-18.916, BPIM 5/14, inf. 328).

b. - Dommages intermédiaires

649. Définition. - Ce sont des désordres qui se manifestent après la réception, mais qui n'entrent pas dans la catégorie de ceux visés aux articles 1792 et suivants (sur la notion, Civ. 3e, 10 juill. 1978, Bull. civ. III, n° 285, JCP 1979. II. 19130, note Liet-Veaux, arrêt rendu sous l'empire de la loi antérieure à celle du 4 janvier 1978). Ce sont donc des dommages qui peuvent affecter des équipements non soumis à ces textes

(équipements industriels par exemple), ou qui affectent l'ouvrage ou ses équipements au sens des articles 1792 et suivants, sans en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination (désordres esthétiques). Ils relèvent, selon une jurisprudence constante, de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 9 oct. 1970, Bull. civ. III, no 682 ; 30 avr. 1985, RDI 1985. 380 ; 13 mars 1991, no 89-13.383, Bull. civ. III, no 91 ; 17 mars 1993, RDI 1993. 230 ; 22 mars 1995, RJDA 6/95, no 757 ; 4 oct. 1995, BPIM 1/96, no 54 ; 27 avr. 2000, no 98-15.970, RDI 2000. 346, obs. Malinvaud, RDI 2000. 364, obs. Leguay, BPIM 4/00, no 253. – Civ. 3e, 26 janv. 2000, BPIM 2/00, no 101. – Civ. 3e, 13 juill. 2016, no 15-20.147 – V. pour des équipements : Civ. 3e, 30 nov. 2011, no 09-70.345, Bull. civ. III, no 202) alors même que la garantie de parfait achèvement pourrait aussi s'appliquer (Civ. 3e, 27 janv. 2010, no 08-21.285, Bull. civ. III, no 20). La solution est admise pour les désordres qui affectent les peintures esthétiques de façade (Civ. 3e, 26 janv. 2000, no 98-13.423, BPIM 2/00, inf. 101), que la jurisprudence ne range pas parmi les équipements (Civ. 3e, 16 mai 2001, no 99-15.062, Bull. civ. III, no 62 ; 13 févr. 2008, no 06-18.357 ; sur l'application de la garantie des vices cachés du vendeur d'immeuble à construire dans ce cas : Civ. 3e, 31 mars 1999, no 97-17.770, Bull. civ. III, no 82 ; sur la question de savoir si des briques de façades qui se détachent entrent dans la catégorie des dommages intermédiaires, V. Civ. 3e, 18 juill. 2001, RDI 2002. 89 ; sur cette question, le débat risque d'être stérile car, si la théorie des dommages intermédiaires n'est pas retenue, la responsabilité de droit commun reste encourue ; mais une faute du constructeur est nécessaire lorsque le dommage est intermédiaire : V. *infra,* no 590). Les désordres qui affectent des équipements dissociables ajoutés sont généralement considérés comme intermédiaires (Civ. 3e, 18 janv. 2006, no 04-17.888, Bull. civ. III, no 16), tandis que ceux qui affectent les équipements d'origine relèvent en principe de la garantie biennale (Civ. 3e, 1er févr. 2006, RDI 2006. 232). L'architecte peut en répondre (Civ. 3e, 1er mars 2011, no 10-11.759, RDI 2011. 336) ; le vendeur après achèvement (Civ. 3e, 4 nov. 2010, no 09-12.988, Bull. civ. III, no 196) ou en l'état futur (Civ. 3e, 4 juin 2009, no 08-13.239, Bull. civ. III, no 130, sol. impl. – Civ. 3e, 13 févr. 2013, no 11-28.376, Bull. civ. III, no 21) également, bien que certains arrêts appliquent la garantie des vices cachés dans certains cas (Civ. 3e, 17 juin 2009, no 08-15.903, Bull. civ. III, no 143. – Civ. 3e, 11 mai 2010, no 09-13.358, RDI 2010. 450).

c. - Défauts de conformité

650. Définition. - S'ils sont constitutifs d'un désordre, ils sont soumis aux règles applicables à ces derniers : la responsabilité contractuelle de droit commun est donc exclue lorsque ces dommages relèvent de la garantie décennale (Civ. 3e, 25 janv. 1989, Bull. civ. III, no 20). S'ils constituent une violation des obligations contractuelles

sans constituer un désordre (matériau différent de celui prévu), la responsabilité contractuelle est encourue (V., à propos de la violation des prescriptions contractuelles en matière d'isolation phonique, *supra,* n° 445). Le maître de l'ouvrage doit émettre des réserves à la réception, car le défaut de conformité est souvent apparent (Civ. 3e, 14 févr. 1989, D.1989. IR 80 ; 30 avr. 1994, Bull. civ. III, n° 690). Il peut aussi refuser la réception (Civ. 3e, 11 mai 2005, RDI 2005. 299) : la clause d'équivalence des services rendus lorsque les matériaux ne présentent pas les mêmes avantages lui est inopposable (Civ. 3e, 20 nov. 2007, n° 06-18.757). Sur la possibilité d'invoquer la responsabilité pour non-façon après une action pour les conséquences d'une insuffisance phonique, V. Civ. 3e, 24 mars 2009, n° 08-16.460.

d. - Dommages annexes et aux tiers

651. Cas. - Les dommages consécutifs relèvent de la garantie des ouvrages et équipements lorsque cette garantie est en cause (V. *supra,* n° 602). – Les dommages aux existants peuvent relever de la responsabilité de droit commun selon les modalités évoquées à propos de la garantie décennale (V. *supra,* n° 601). – Les dommages aux tiers peuvent justifier une action propre (dommages aux existants) ou une action récursoire du maître de l'ouvrage dont la responsabilité est recherchée par le voisin, contre les constructeurs.

652. *Le maître de l'ouvrage dispose de l'action contractuelle personnelle* ; c'est elle qui fonde le recours en garantie (J. FOSSEREAU, Le clair-obscur de la responsabilité des constructeurs, D. 1976. 27). Cette action relève, en général, du droit commun de la responsabilité (Civ. 3e, 6 févr. 1969, Bull. civ. III, n° 109 ; 10 janv. 1978, Bull. civ. III, n° 27 ; 23 janv. 1991, n° 89-15.097, Bull. civ. III, n° 27, dans un cas où il existait une clause de garantie ; 5 avr. 1995, RDI 1995. 553 ; 24 mars 1999, n° 96-19.775, Bull. civ. III, n° 74 ; 26 févr. 2003, n° 01-16.630, BPIM 3/03, inf 170). Selon la jurisprudence, la preuve de la faute de l'entrepreneur est nécessaire (Civ. 3e, 24 avr. 2003, n° 01-18.017) ; mais certains arrêts sont plus nuancés (Civ. 3e, 13 avr. 2005, n° 03-20.575, Defrénois 2006. 72, obs. Périnet-Marquet, RDI 2005. 279, obs. Gavin-Milan-Oosterlynck, et RDI 2005. 299, obs. Malinvaud). L'action peut, parfois, relever des garanties légales lorsque le dommage entre dans les prévisions des articles 1792 et suivants (Civ. 3e, 27 avr. 1994, RGAT 1994. 820). En cas d'incendie, la Cour de cassation, après avoir posé que l'obligation de construire ne comporte pas, par elle-même, une obligation de sécurité (Civ. 3e, 27 nov. 1970, Bull. civ. III, n° 653), paraît désormais admettre l'existence d'une responsabilité contractuelle (Civ. 3e, 9 oct. 1991, n° 90-12.059, Bull. civ. III, n° 234 ; 8 juill. 1998, RDI 1998. 647 : pour un incendie ayant détruit le hangar sous lequel l'entrepreneur effectuait des travaux ; V. aussi, pour un accident mortel : Civ. 3e, 10 avr. 1996, BPIM 4/96, n° 279).

653. *Le maître de l'ouvrage dispose aussi de l'action subrogatoire dans les droits du tiers* qu'il a désintéressé (Civ. 3e, 8 mai 1969, Bull. civ. III, n° 358 ; 5 mai 1970, Bull. civ. III, n° 305 ; 15 févr. 1972, D. 1972. 380 ; 4 nov. 1971, JCP 1972. II. 17070 note B. Boubli). La troisième chambre civile autorise cette action lorsqu'elle est *fondée sur l'article 1382 (ancien) du code civil* (C. civ., nouv. art. 1240) mais non lorsqu'elle l'est sur l'article *1384, alinéa 1er,* ancien (C. civ., nouv. art. 1242) l'existence d'un lien contractuel entre le constructeur et le maître de l'ouvrage excluant que ce dernier puisse se prévaloir de la présomption (Civ. 3e, 24 mars 1999, n° 96-19.775, Bull. civ. III, n° 74, préc. ; 21 juill. 1999, BPIM 6/99, n° 434 ; 28 nov. 2001, n° 00-13.970, Bull. civ. III, n° 135 ; comp. : Civ. 2e, 6 juill. 1994, n° 92-18.689, Bull. civ. II, n° 182. – Civ. 3e, 17 mars 1987, Bull. civ. III, n° 52, qui sont en sens contraire ; rappr. Civ. 1re, 18 sept. 2002, n° 99-20.297, Bull. civ. I, n° 200, qui admet le recours fondé sur les troubles de voisinage ; V. aussi Civ. 3e, 26 févr. 2003, n° 01-16.630, qui n'exclut pas cette possibilité ; V. *infra,* n° 590). La faute du constructeur doit donc, en principe, être prouvée par le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 17 mars 1987, Bull. civ. III, n° 52 ; 31 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 199 ; 13 juin 1990, n° 88-19.228, Bull. civ. III, n° 81). Le maître de l'ouvrage est subrogé dans les droits du voisin pour exercer contre l'entrepreneur l'*action en réparation du préjudice fondée sur les troubles anormaux de voisinage* (Civ. 3e, 21 juill. 1999, 3 arrêts, n° 96-22.735, n° 97-21.370, n° 97-21.371, RDI 2000. 75, obs. Leguay, RDI 1999. 685, obs. Capoulade, RDI 1999. 656, obs. Malinvaud, RTD civ. 2000. 120, obs. Jourdain, BPIM 6/99, n° 434 ; 18 sept. 2002, n° 99-20.297, Bull. civ. III, n° 200 ; 26 févr. 2003, n° 01-16.630, Bull. civ. III, n° 160 ; 29 janv. 2008, n° 06-19.419) ; or, la contribution à la dette entre les coobligés, que peuvent être le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, pose des problèmes parfois difficiles à résoudre (V. MALINVAUD, obs. RDI 1999. 656) ; la tendance jurisprudentielle est, dans ce cas, de dispenser le maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute de l'entrepreneur. En cas d'*empiètement sur le terrain d'autrui,* la Cour de cassation a appliqué, tantôt la garantie décennale (Civ. 3e, 19 déc. 1972, Bull. civ. III, n° 688 ; 27 avr. 1994, RGAT 1994. 820), tantôt la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 6 févr. 1969, Bull. civ. III, n° 109 ; V. B. BOUBLI, *op. cit.,* 1979, n° 255), tantôt la responsabilité quasi délictuelle par subrogation aux droits du voisin, sur le fondement de l'article 1382 (Civ. 3e, 17 mars 1999, BPIM 3/99, n° 221 ; rappr. : Civ. 3e, 29 janv. 2008, n° 06-19.419). Toutefois, s'il a indemnisé le voisin et qu'il connaissait l'empiètement sans avoir émis de réserve, le maître de l'ouvrage est privé de l'action en responsabilité contractuelle (Civ. 3e, 28 févr. 2012, n° 11-13.670 et n° 11-20.549, BPIM 3/12, inf. 238).

B - Régime de la responsabilité résiduelle

654. La responsabilité de droit commun des constructeurs connaît en cas de dommage à l'ouvrage de multiples cas d'application protecteurs des intérêts du maître de l'ouvrage. Si elle reste complexe en ce qui concerne sa nature et sa preuve (V. *infra,* n°s 659 s.), il existe des exclusions (V. *infra,* n° 661) ; son régime se modifie s'agissant de son délai de prescription (V. *infra,* n°s 655 s.). L'action peut être transmise (V. *infra,* n° 660) et la validité des clauses de responsabilité est admise dans son principe (V. *infra,* n°s 657 s.).

1° - Prescription

655. La réforme de la prescription a substitué à la prescription de droit commun une prescription spécifique pour chaque intervenant au projet les responsables non constructeurs (V. *infra,* n° 656) et constructeurs (V. *infra,* n°s 657 s.).

a. - Responsables non constructeurs

656. Cas. - Les prestataires non constructeurs qui *fournissent un service* et ne relèvent pas de la garantie décennale (coordonnateur OPC, coordonnateur SPS, contrôleur technique pour les missions accessoires) sont responsables en droit commun. Avant la loi du 17 juin 2008, la prescription était en principe trentenaire ; mais la tendance étant de limiter la responsabilité à dix ans pour les constructeurs, on pensait généralement que cette solution avait vocation à se généraliser (Civ. 3e, 16 oct. 2002, Bull. civ. III, n° 205, arrêt n° 2, D. 2003. 300, obs. Malinvaud, qui pose un principe général). L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi de 2008, limite, sauf exception, la prescription de droit commun à cinq ans ; les dispositions de l'article 1792-4-3 (réd. L. 2008) instituent, pour leur part, un délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux, qui ne concerne que les constructeurs et leurs sous-traitants. Il semble donc que la prescription de l'action dirigée contre les prestataires non constructeurs se prescrive par cinq ans. Toutefois, le délai de cinq ans court à compter du jour où la victime a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action, ce qui risque de prolonger le délai bien au-delà du délai de cinq ans qui suit la réception… – Les prestataires *fabricants ou fournisseurs* sont responsables selon le droit commun de la garantie des vices ou répondent des défauts de conformité de la chose vendue. L'action se transmet ; si elle est fondée sur la garantie des vices, elle doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ., art. 1648 ; autrefois « à bref délai ») ; si elle dénonce un défaut de conformité, elle se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 précité.

b. - Responsables constructeurs

657. Cas. - La prescription, pour les dommages relevant de leur responsabilité de droit commun, est de dix ans à compter de la réception des travaux ; cette prescription

s'applique tant aux constructeurs de premier rang, susceptibles, par ailleurs, d'engager leur responsabilité « dite » décennale (l'expression n'est plus adéquate désormais) ou biennale, qu'au sous-traitant (C. civ., art. 1792-4-3). La solution avait été posée en termes de principe par la jurisprudence à propos *des dommages intermédiaires* (Civ. 3e, 11 juin 1981, Bull. civ. III, no 120 ; 7 oct. 1981, Bull. civ. III, no 149 ; V. B. BOUBLI, La responsabilité contractuelle de droit commun après la réception des travaux, RDI 1982. 1 s.), et avait été généralisée à la faveur d'une interprétation extensive de l'article 2270 du code civil (Civ. 3e, 12 mai 1993, RDI 1993. 514 ; 17 mars 1993, no 90-20.798, Bull. civ. III, no 38 ; 16 oct. 2002, no 01-10.482 , Bull. civ. III, no 205, D. 2003. 300 , préc., rendu sous l'empire de la loi de 1978, et qui semble concerner tous les constructeurs ; comp. : Civ. 1re, 13 mars 1996, RGAT 1996. 663, qui décide que les dispositions de l'art. 2270 ne peuvent être étendues à d'autres désordres que ceux relevant des garanties légales). L'article 1792-4-3 confirme cette évolution sans préciser, toutefois, si le délai de dix ans est à la fois un délai d'épreuve et d'action comme l'est celui de la garantie décennale des articles 1792 à 1792-2 ; si ce doit être le cas (V. Civ. 3e, 22 sept. 2004, no 03-10.923 , Bull. civ. III, no 152, RDI 2004. 569, obs. Malinvaud , qui décide que les deux responsabilités tendent au même but, et Civ. 3e, 26 juin 2002, no 00-21.638 , Bull. civ. III, no 149, RDI 2002. 419, obs. Malinvaud , RDI 2003. 36, obs. Leguay , qui décide que la prescription de chacune des actions est interrompue lorsque l'assignation vise le mêle désordre), autant dire que *tous les constructeurs répondent pendant dix ans à compter de la réception de tous les désordres cachés, à l'exception du cas prévu à l'article 1792-3 ; du coup la complexité du régime de la « garantie décennale » ne se justifie plus et n'a pour seul intérêt que de délimiter le domaine de l'assurance obligatoire.* Un doute peut encore subsister pour les défauts de conformité non constitutifs de désordres. Relèvent-ils du délai de prescription fixé par l'article 1792-4-3 (dix ans) ? Ou du délai de droit commun de l'article 2224 (cinq ans) ? Dans le régime antérieur, après avoir appliqué la prescription trentenaire (Civ. 3e, 18 avr. 1972, Bull. civ. III, no 234 ; 21 févr. 1990, D. 1990. IR 66), la Haute juridiction a, semble-t-il, opté pour la prescription décennale (Civ. 3e, 26 oct. 2005, no 04-15.419 , Bull. civ. III, no 202). Cette solution devrait se maintenir.

658. Dol. - En cas de *dol,* et pas seulement de faute lourde (Civ. 3e, 27 janv. 1987, RDI 1987. 355, mais on peut se demander si cette distinction tient toujours avec la jurisprudence sur le « dol contractuel » et l'assimilation à laquelle procède le nouvel article 1231-3 du code civil qui permet l'indemnisation au-delà du préjudice normalement prévisible (V. *ci-dessous*), il pouvait être fait échec à la prescription de dix ans dans le régime antérieur à la loi de 2008. La Cour de cassation a longtemps jugé que le dol est une faute extracontractuelle entraînant une responsabilité délictuelle, laquelle se prescrivait naguère par dix ans (C. civ., anc. art. 2270-1), et se prescrit désormais, comme toute action patrimoniale, par cinq ans (C. civ., art. 2224) ; la

faute dolosive est une faute volontaire qui n'implique toutefois pas nécessairement, selon la Cour de cassation, l'intention de nuire (Civ. 3e, 18 déc. 1996, RJDA 4/97, n° 590 ; 27 juin 2001, n° 99-21.017, Bull. civ. III, n° 83) ; elle est caractérisée par la conscience chez son auteur que ses agissements ne peuvent manquer de provoquer le désordre (Civ. 3e, 5 mai 1970, JCP 1970. IV. 168 ; 18 déc. 1972, D. 1973. 272 ; 22 janv. 1980, D. 1980. IR 486 ; 26 mai 1988, RDI 1988. 467 ; 31 janv. 1987, RDI 1987. 355 ; V., pour des manœuvres frauduleuses : Civ. 1re, 4 juill. 1951, Bull. civ. I, n° 169. – Civ. 3e, 24 oct. 1968, Bull. civ. III, n° 403 ; V., pour la violation des règles de l'art, jugée insuffisante pour caractériser le dol : Civ. 3e, 7 févr. 2001, n° 99-17.535, BPIM 2/01, n° 122). Les nouvelles dispositions du code civil, tout en tirant les conséquences du dol, ne le définissent que dans la conclusion du contrat et n'exigent alors pas l'intention de nuire (C. civ., art. 1137 et 1138). La jurisprudence antérieure à ces textes n'est donc pas nécessairement obsolète. La charge de la preuve incombe au demandeur (Civ. 3e, 8 avr. 2008, n° 07-12.480). L'analyse qui fait du dol une « faute extracontractuelle » a été critiquée par une partie de la doctrine qui a fait valoir que le dol est une faute de nature contractuelle engageant la responsabilité, alors trentenaire, de son auteur (MALINVAUD, JESTAZ, par JOURDAIN et TOURNAFOND, Droit de la promotion immobilière, *op. cit.,* n° 184). La Cour de cassation s'est d'abord laissée convaincre par cette critique (Civ. 3e, 5 janv. 1983, RDI 1983. 333 ; 23 juill. 1986, RDI 1987. 62) ; mais elle est revenue pendant un temps aux solutions antérieures (Civ. 3e, 21 nov. 1990, RGAT 1991. 125 ; 4 déc. 1991, RDI 1992. 74, et les arrêts précités). Puis, elle s'est ravisée par un arrêt du 27 juin 2001 (Civ. 3e, 27 juin 2001, n° 99-21.017, Bull. civ. III, n° 83, RDI 2001. 525, obs. Malinvaud, D. 2001. 2995, concl. Weber, note Karila, JCP 2001. II. 10626, note Malinvaud) qui fait une importante distinction en décidant que, « sauf faute extérieure au contrat, le constructeur est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ». L'arrêt consacre donc la *responsabilité contractuelle pour dol* (V. aussi : Civ. 3e, 16 sept. 2003, n° 02-14.836 ; 16 mars 2005, n° 04-12.950, Bull. civ. III, n° 65, RDI 2005. 226, obs. Malinvaud, RDI 2005. 189, obs. Leguay, D. 2005. 2198, obs. Karila) soumise, à l'époque à laquelle il a été rendu, à la prescription trentenaire ; il évince l'application de l'adage « La fraude corrompt tout », longtemps invoqué pour expliquer le passage à la responsabilité délictuelle, ce qui s'explique par le fait que l'intention de nuire n'est pas une condition du dol au sens de cette jurisprudence. Le « dol contractuel » se rapproche davantage de la « faute inexcusable » du droit social, que de la faute intentionnelle propre au délit civil : la fraude ne dénature plus la responsabilité. L'arrêt du 27 juin 2001 réserve cependant la faute « extracontractuelle », sans doute caractérisée, elle, par « l'intention de nuire » ; seulement voilà : dans ce dernier cas, la responsabilité se prescrivait par dix ans (à compter du dommage, certes), tandis que la responsabilité contractuelle de droit

commun se prescrivait par trente ans… À présent que la prescription de droit commun est de cinq ans, et qu'il est dérogé à cette durée pour la responsabilité contractuelle des constructeurs (10 ans), c'est celle-ci qui devrait s'appliquer ; le problème, c'est qu'elle s'applique déjà, même en l'absence de dol. On a pu se demander quel était alors l'intérêt du « dol contractuel » en matière de prescription aujourd'hui et celui éventuel du « dol extra-contractuel » caractérisé par l'intention de nuire. Un arrêt, tout en retenant semble-t-il la responsabilité contractuelle, a décidé que le maître de l'ouvrage était recevable, en cas de dol, à exercer l'action contre le constructeur après l'expiration de la garantie légale (Civ. 3e, 27 mars 2013, no 12-13.840, Bull. civ. III, no 39, à propos de l'action de l'acquéreur du bien contre le constructeur pour un ouvrage édifié en 1985 et vendu en 2004 !).

2° - Régime de la preuve

659. Présomption. - La responsabilité des locateurs d'ouvrage est fondée sur la violation d'une obligation de résultat ; un arrêt précise que tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 27 janv. 2010, no 08-18.026, Bull.civ. III. no 22 ; V. le principe posé à propos du sous-traitant, *supra,* nos 636 et 643). Elle est rappelée à propos du vendeur d'immeuble à construire lorsqu'elle n'est pas recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants (Civ. 3e, 31 mars 1999, no 97-17.770, Bull. civ. III, no 82). En ce qui concerne l'*entrepreneur,* l'obligation de résultat est affirmée (Civ. 3e, 5 févr. 1985, Bull. civ. III, no 21 ; 13 janv. 1988, RDI 1988. 228 ; 30 mars 1989, RGAT 1989. 613 ; 29 janv. 1997, no 118 D ; 17 nov. 1999, BPIM 1/00, no 35 ; 19 févr. 2002 et 3 avr. 2002, RDI 2002. 240). Mais la preuve de la faute est exigée lorsque les désordres sont intermédiaires (Civ. 3e, 9 mars 1988, Bull. civ. III, no 52 ; 13 mars 1991, no 89.13.833, Bull. civ. III, no 91 ; 22 mars 1995, no 93-15.233, Bull. civ. III, no 80 ; 23 juin 1999, RDI 1999. 656). Un doute subsiste sur la portée de l'obligation de résultat en cas de concours entre la responsabilité de droit commun et la garantie de parfait achèvement dans ce cas : la jurisprudence semble exiger que le maître de l'ouvrage prouve la faute du constructeur dont la responsabilité est recherchée selon le droit commun (Civ. 3e, 22 mars 1995, RJDA 1995, no 757 ; 9 juill. 1997, RDI 1997. 591 ; V. aussi *supra,* no 510). La preuve de la faute s'impose si le maître de l'ouvrage invoque un manquement à l'obligation d'information ou de conseil (Civ. 3e, 11 févr. 1998, no 96-12.228, Bull. civ. III, no 30 ; 22 juill. 1998, no 97-11.727, Bull. civ. III, no 172 ; 8 oct. 1997, no 96-11.027, Bull. civ. III, no 189 ; V. aussi, pour des travaux de faible importance : Civ. 3e, 24 juin 1987, RDI 1987. 457 ; rappr. : 31 mai 1989, RDI 1989. 471). En ce qui concerne l'*architecte,* la preuve de sa faute est exigée (Civ. 3e, 10 juill. 1978, Bull. civ. III, no 485 ; 31 mai 1989, Bull. civ. III, no 120 ; 13 déc. 1995, no 92-11.637, Bull. civ. III, no 255, RDI 1996. 223, obs. Malinvaud et Boubli ; 21 juin

2000, BPIM 5/00, n° 317 ; 16 févr. 2005, n° 03-16.266, Bull. civ. III, n° 37 ; 16 mars 2005, n° 04-12.950, Bull. civ. III, n° 65, RDI 2005. 226, obs. Malinvaud, RDI 2005. 189, obs. Leguay, D. 2005. 2198, obs. Karila), *a fortiori,* s'il lui est reproché un manquement à l'obligation de conseil (Civ. 3e, 25 févr. 1998, n° 96-10.598, Bull. civ. III, n° 44).

3° - Transmission de l'action

660. L'action en responsabilité contractuelle de droit commun se transmet aux acquéreurs successifs (Civ. 3e, 28 févr. 1996, RDI 1996. 222 ; 27 mars 1996, BPIM 3/96, n° 205 ; 8 oct. 1997, n° 96-11.155, Bull. civ. III, n° 184. – Civ. 3e, 10 mars 2009, n° 08-11.173, BPIM 3/09, inf. 212. – *Contra* : Civ. 3e, 7 mai 1986, Bull. civ. III, n° 62 ; 7 juill. 2004, n° 02-11.335, dans le cas particulier de dégâts causés à l'immeuble par un terrain pollué), mais non l'action en responsabilité délictuelle (Civ. 3e, 18 juin 1997, BPIM 5/97, n° 325). L'action se transmet lorsque la responsabilité du constructeur est engagée pour faute dolosive (Civ. 3e, 27 mars 2013, n° 12-13.840, BPIM 3/13, inf. 203). En cas de vente, le syndicat de copropriété peut en bénéficier (Civ. 3e, 26 mai 1992, n° 89-21.897, Bull. civ. III, n° 168, R., p. 285, RTD civ. 1993. 131, obs. Jourdain, RJDA 1992, n° 701, RCA 1992. Comm. 392).

4° - Exclusion de toute responsabilité postdécennale ou postbiennale

661. Sauf le cas du dol précédemment évoqué, un désordre relevant d'une garantie légale ne peut donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute (Civ. 3e, 10 avr. 1996, n° 94-17.030, 1re esp., Bull. civ. III, n° 100 ; V. aussi : 10 avr. 1996, 2e esp., BPIM 4/96, n° 286 ; 22 mai 1997, BPIM 4/97, n° 266). Il en résulte que la responsabilité postbiennale ou postdécennale est exclue pour les dommages relevant de ces garanties (Civ. 3e, 29 mars 2000, RDI 2001. 74, à rapprocher de : Civ. 3e, 31 mars 1999, n° 97-17.770, Bull. civ. III, n° 82, *supra,* n° 625).

5° - Clauses de responsabilité

662. Licéité de principe. - Les clauses de responsabilité ne sont pas illicites en droit commun (V. Civ. 3e, 11 janv. 1984, RDI 1984. 191, qui admet la validité d'une clause limitative de responsabilité décennale avant la loi du 4 janvier 1978. – V. G. VINEY, Les clauses aménageant la responsabilité des constructeurs, RDI 1982. 329). L'article L. 212-1 du code de la consommation (issu de l'ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016, anc. art. L. 132-1 s.), répute abusives, aux conditions qu'il précise, les clauses entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ce qui, implicitement les

valide entre professionnels. Toutefois, la jurisprudence se montre stricte quant à l'appréciation de la qualité de « professionnel » ; elle estime que la clause limitative de garantie figurant au contrat d'un bureau de contrôle technique est inopposable à la SCI maître de l'ouvrage qui est un professionnel de l'immobilier et non de la construction ; la clause est alors abusive et cet abus dégénère en nullité de la clause (Civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 14-29.347, RDI 2016. 290 note Boubli. – Sur la question, V. *supra,* nos 624 s.). La jurisprudence hésite également à appliquer la présomption de connaissance du vice au constructeur (Civ. 3e, 20 juin 1990, JCP 1990. IV. 216). Quant au fabricant ou au fournisseur au sens de la loi du 19 mai 1998, il ne peut stipuler aucune clause visant à « écarter ou à limiter » sa responsabilité (C. civ., art. 1245-14 [anc. art. 1386-15] ; V. déjà : Civ. 3e, 3 janv. 1984, Bull. civ. III, n° 4. – Civ. 1re, 5 mai 1982, Bull. civ. I, n° 163). Si une clause limitative est valablement stipulée, elle est inopposable au maître de l'ouvrage lorsque le constructeur a commis un dol ou une faute lourde, laquelle, exceptionnellement, lui est assimilée dans ce cas particulier (Civ. 1re, 3 avr. 1962, Bull. civ. I, n° 196 ; 8 mars 1965, Bull. civ. I, n° 168). La Cour de cassation paraît favorable aux clauses évinçant la solidarité parfaite ou imparfaite des constructeurs lorsque la responsabilité encourue est de droit commun (Civ. 3e, 19 mars 2013, n° 11-25.266, RDI 2013. 316, obs. Boubli ; V. *supra,* n° 626). Des clauses relatives à l'étendue de la responsabilité, on peut rapprocher celles qui affectent la durée de la prescription. La durée de la prescription peut, en application de l'article 2254 du code civil, être abrégée ou augmentée. L'augmentation du délai ne peut dépasser dix ans, ce qui assigne, pour les constructeurs, un intérêt limité à la faculté réservée par la loi. La réduction du délai quant à elle, ne peut laisser subsister un délai de prescription inférieur à un an. La question est de savoir si le délai de dix ans institué par l'article 1792-4-3 du code civil est d'ordre public et s'il peut ou non être abrégé : l'article 1792-5 ne range pas les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 parmi les dispositions d'ordre public ; mais l'article 1792-4-2 aligne la prescription des actions dirigées contre le sous-traitant sur celle des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du même code; cet alignement exclut-il l'application de l'article 2254 au sous-traitant ? Invite-t-il à limiter l'opposabilité d'une clause réduisant le délai au seul donneur d'ordres ?

Section 2 - Responsabilité extracontractuelle

663. Formulation. - La responsabilité naguère délictuelle, fondée sur les anciens articles 1382 et suivants du code civil, devient une responsabilité extracontractuelle dans le nouveau code civil (C. civ., art. 1240 s.). Elle est encourue à l'égard des *tiers* au contrat (V. *infra,* nos 664 s.). Les fondements classiques de la responsabilité permettent d'en revoir les contours (V. *infra,* nos 670 s.), il faut apporter une attention particulière au régime de responsabilité du fait des produits défectueux (V. *infra,* nos 679 s.). L'action en responsabilité délictuelle ou extracontractuelle désormais ne se

transmet pas de plein droit à l'acquéreur de l'immeuble (Civ. 3e, 18 juin 1997, BPIM 5/97, n° 325).

Art. 1er - Acteurs de la responsabilité

664. En dehors de la définition du tiers au contrat, c'est-à-dire lorsque les parties au litige n'ont entre elles aucun lien de droit (V. *infra,* n° 665), en matière de construction, il existe aussi des rapports particuliers (V. *infra,* nos 666 s.).

A - Cas général

665. Notion. - Sont des *tiers* entre eux et, à ce titre, peuvent se prévaloir contre les constructeurs de la responsabilité des articles 1240 et suivants du code civil (anc. art. 1382 s.) : 1° les *penitus extranei,* totalement étrangers à l'opération de construction : le piéton victime de la chute d'un matériau, par exemple. 2° Certaines personnes qui n'ont entre elles aucun lien direct, bien qu'elles soient concernées par l'opération de construction :

– le *sous-traitant* qui est un tiers à l'égard du maître de l'ouvrage, lequel doit rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants (Cass., ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602, Bull. civ., n° 5, RDI 1992. 27, note Boubli ; V. *supra,* n° 369), y compris lorsque le sous-traitant a manqué à son obligation de conseil à l'égard des constructeurs et qu'il en résulte un préjudice pour le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 28 nov. 2001, n° 00-13.559, RDI 2002. 95 ; sur les actions engagées contre le sous-traitant, V. *supra,* n° 369) ;

– le *locataire du maître de l'ouvrage* qui est un tiers à l'égard des constructeurs (Civ. 1re, 9 oct. 1962, Bull. civ. I, n° 405 ; chron. LIET-VEAUX au D. 1963. 1 s., arrêt de principe ; 24 oct. 1967, Bull. civ. I, n° 309. – Civ. 3e, 8 mars 1978, Bull. civ. III, n° 101 ; 11 oct. 1989, RDI 1990. 89, jur. constante ; V. Civ. 3e, 15 oct. 2008, n° 07-13.971, qui permet au locataire d'agir en responsabilité quasi délictuelle contre le voisin à qui des infiltrations sont imputables, alors que le bailleur n'est pas tenu de le garantir des conséquences de ce fait) ; le *locataire-accédant* est un tiers (Civ. 1re, 24 oct. 1967, Bull. civ. I, n° 309, qui statue dans un cas de location-vente) et le *crédit-preneur* également (Civ. 3e, 19 mars 2013, n° 12-13.066, BPIM 3/13, inf. 205, qui lui refuse le bénéfice de la garantie de l'assureur RC décennale). Toutefois, le preneur ne peut réclamer que la réparation de son préjudice propre et non la réparation des désordres (Civ. 3e,

18 janv. 2006, n° 03-20.999, RJDA 5/06, n° 569. – Civ. 3e, 29 févr. 2012, n° 10-28.174, BPIM 3/12, inf. 239).

– le *fournisseur du sous-traitant* est un tiers à l'égard du maître de l'ouvrage qui doit agir contre lui sur le fondement des articles 1382 et suivants (Civ. 3e, 28 nov. 2001, n° 00-13.559, D. 2002. IR 45, RDI 2002. 92 ; solution contraire lorsque le fournisseur a contracté avec l'entrepreneur principal : Civ. 3e, 12 déc. 2001, RDI 2002. 92 ; V. *supra,* n° 559).

– Sont également des tiers à l'égard du maître de l'ouvrage, *l'expert judiciaire* qui peut engager sa responsabilité si ses préconisations sont insuffisantes (Civ. 3e, 11 mars 2015, n° 13-28.351 et n° 14-14.275, BICC 15 juin 2015, n° 676), *l'expert désigné par l'assureur DO* qui ne prévoit pas les mesures pouvant éviter la récidive (Civ. 3e, 7 juill. 2015, n° 14-19.998) et *l'administrateur judiciaire* d'une procédure collective qui ne veille pas à l'efficacité de l'assurance RC décennale souscrite par le débiteur (Civ. 3e, 22 oct. 2014, n° 13-25.430, Bull. civ. III, n° 135).

B - Cas particuliers

666. Il faut évoquer les rapports entre les constructeurs entre eux (V. *infra,* n° 667), l'action récursoire dont dispose le maître de l'ouvrage (V. *infra,* n° 668) et enfin le cas du dol des constructeurs (V. *infra,* n° 669).

1° - Rapports des constructeurs entre eux

667. Existence ou absence de contrat entre eux. - Les constructeurs qui *ne sont pas liés entre eux par un contrat* (locateurs d'ouvrage liés au maître de l'ouvrage) sont des tiers dans leurs rapports entre eux. Tenus *in solidum* envers le maître de l'ouvrage, ils sont fondés à agir l'un contre l'autre sur le fondement des articles 1240 et suivants (C. civ., anc. art. 1382 s. : Civ. 3e, 16 janv. 1969, Bull. civ. III, n° 43 ; 14 sept. 2005, RDI 2005. 460 ; 18 janv. 2006, n° 04-18.950, Bull. civ. III, n° 15 ; V. *supra,* n° 630). La faute du débiteur doit être établie (Civ. 3e, 25 nov. 1998, n° 97-11.408, Bull. civ. III, n° 221 ; 21 oct. 2008, RDI 2008. 557 ; Civ. 3e, 2 nov. 2011 n° 10-20.499, BPIM 6/11, inf. 454) ; elle peut résulter du contrat liant ce débiteur au maître de l'ouvrage, conformément au principe selon lequel le fait dommageable est pris en dehors de tout point de vue contractuel. La Cour de cassation répugne à autoriser le constructeur qui a désintéressé le maître de l'ouvrage à exercer l'action de ce dernier par subrogation dans ses droits (V. toutefois : Civ. 3e, 9 juin 1999, n° 97-20.361, BPIM 5/99, inf. 369), spécialement lorsque *les parties sont liées par un contrat* ; elle fonde l'action récursoire

sur la responsabilité de droit commun, qui, dans ce cas, est contractuelle (Civ. 3e, 8 juin 2011, n° 09-69.894, RDI 2011. 894, obs. Malinvaud, garantie des vices cachés par un fournisseur. – V., pour un sous-traité : Civ. 3e, 22 sept. 2004, n° 03-11.391, BPIM 1/05, inf. 40. – Pour le maître de l'ouvrage, V. *supra,* n° 652). Lorsque le constructeur triomphe dans son recours, il est procédé au partage en fonction de la gravité des fautes, et donne lieu à une appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3e, 26 nov. 1991, RGAT 1992. 140). La responsabilité intégrale du tiers a été parfois admise (Civ. 3e, 22 juin 1977, Bull. civ. III, n° 283 ; comp. : 9 juin 1999, BPIM 5/99, n° 369, à propos du recours de l'architecte contre le fournisseur de l'entrepreneur ; sur l'analyse, V. *supra,* nos 630 s.).

2° - Action récursoire du maître de l'ouvrage

668. Assimilation au tiers. - Le maître de l'ouvrage est assimilé à un tiers lorsqu'il est reconnu responsable de dommages qui, en réalité, sont imputables aux constructeurs. Cette situation se rencontre surtout dans les rapports de voisinage. Le maître de l'ouvrage mis en cause par la victime appelle alors les constructeurs en garantie. En principe, cette action a un fondement contractuel (Civ. 3e, 6 févr. 1969, Bull. civ. III, n° 109 ; 24 mars 1999, RJDA 10/99, n° 1155 ; 28 nov. 2001, n° 00-13.970, Bull. civ. III, n° 135 ; 24 mars 2003, BPIM 4/03, inf. 170).Elle doit être exercée dans le délai de garantie dont il dispose contre le constructeur ; la Cour de cassation estime en particulier, lorsque la responsabilité décennale est en cause, que l'appel en garantie doit intervenir avant l'expiration du délai de dix ans, alors même qu'en l'espèce, l'action principale avait été engagée dans un délai qui ne laissait au maître de l'ouvrage que 10 jours pour agir (Civ. 3e, 21 nov. 2012, n° 11-19.778, RDI 2013. 149). Le maître de l'ouvrage exerce alors son *action personnelle* (V. *supra,* n° 652). Mais le maître de l'ouvrage peut aussi agir par *subrogation* aux droits du tiers désintéressé sur le fondement de *l'article 1382 devenu l'article 1240* (Civ. 3e, 15 oct. 1970, Bull. civ. III, n° 515 ; 25 mars 1998, n° 96-11.812, Bull. civ. III, n° 72 ; 4 nov. 1971, Bull. civ. III, n° 533, qui évoque les deux fondements ; V. *supra,* n° 653), mais non sur le fondement de l'*article 1384, 1°,* devenu l'article 1242 du code civil (Civ. 3e, 24 mars 1999, n° 96-19.775, Bull. civ. III, n° 74, RJDA 11/99, n° 1155 ; 28 nov. 2001, préc. ; V., sur l'analyse, V. *supra,* n° 653). L'option pour l'action subrogatoire est discutée, et la jurisprudence favorable est déjà ancienne. Néanmoins, lorsqu'il exerce le recours par subrogation aux droits du voisin qui l'avait assigné sur le fondement des *troubles de voisinage,* le maître de l'ouvrage peut agir contre l'entrepreneur sur le même fondement (Civ. 1re, 18 sept. 2002, n° 99-20.297, Bull. civ. I, n° 200. – Civ. 3e, 26 févr. 2003, n° 01-16.630, BPIM 3/03, inf. 170 ; 29 janv. 2008, n° 06-19.419). Le maître de l'ouvrage devient ainsi le garant de l'entrepreneur pour les troubles de voisinage résultant de son fait (V. toutefois, pour un empiètement constaté avant réception : Civ.

3e, 17 sept. 2014, n° 12-24.122 et n° 12-24.612, RDI 2014. 644, qui vise l'art. 1184, al. 2 anc. c. civ., qui n'est plus repris expressément par le nouveau code dans les art. 1224 s.).

3° - Cas du dol

669. Interrogation. - En cas *de dol des constructeurs,* la jurisprudence a longtemps considéré que la responsabilité était délictuelle (Civ. 3e, 24 oct. 1968, Bull. civ. III, n° 403 ; 7 oct. 1981, Bull. civ. III, n° 149 ; V., sur l'analyse, *supra,* n° 589), tout en refusant d'assimiler la faute lourde au dol (Civ. 1re, 8 févr. 1967, Bull. civ. I, n° 53. – Civ. 3e, 13 mars 1984, RDI 1984. 318 ; *contra* : CE 3 avr. 1991, D. 1991. Somm. 377). Cette jurisprudence appréhendait le dol comme une faute extracontractuelle, n'impliquant pas nécessairement l'intention de nuire (Civ. 3e, 18 déc. 1996, RJDA 4/97, n° 590). Mais depuis un arrêt du 27 juin 2001 (n° 99-21.017, Bull. civ. III, n° 83, RDI 2001. 525, obs. P. Malinvaud, D. 2001. 2995, concl. J.-F. Weber, note J.-P. Karila, JCP 2001. II. 10626, note Malinvaud), la Cour de cassation distingue désormais deux cas de dol, ce qui suscite des interrogations aggravées par le nouveau régime de la prescription (V. *supra,* n° 589).

Art. 2 - Fondement de la responsabilité

670. Le fondement traditionnel de la responsabilité délictuelle, ou extracontractuelle (depuis l'Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, JO 11 févr.), supposait en principe une faute de la part de celui sur qui on voulait faire peser la responsabilité. La responsabilité pour faute était celle de droit commun (V. *infra,* n° 671). Le fondement des responsabilités en tenant à la garde (V. *infra,* n° 672), à l'entretien de la chose (V. *infra,* n° 673), et aux troubles de voisinage (V. infra, nos 674 s.) relèvent aussi de ce régime.

§ 1er - Faute

671. Preuve. - Ce sont les règles classiques qui s'appliquent : la faute doit être prouvée ; le tiers est responsable sur le fondement de l'ancien article 1382, devenu 1240 (Civ. 16 juill. 1903, DP 1904. 83 : chute d'un mur mitoyen en cours de chantier. – Civ. 1re, 6 juin 1962, Bull. civ. I, n° 298 : construction sans précaution sur un sol meuble ; 2 nov. 1964, Bull. civ. I, n° 481 : démolition mal contrôlée. – Civ. 3e, 4 mars 1971, D. 1971. Somm. 153 : méconnaissance des droits du voisin. – Civ. 3e, 6 févr. 1969, Bull. civ. III, n° 109 ; 10 nov. 2009, n° 08-17.526, Bull. civ. III, n° 248,

empiétement sur le terrain d'autrui, le cas échéant en sous-sol ; V., sur ce dernier point, *supra,* n° 586 ; sur le dommage au tiers imputable en partie au maître de l'ouvrage : Civ. 3e, 15 avr. 2008, n° 06-20.263).

§ 2 - Garde

672. Chantier. - Pendant le chantier, la garde appartient en principe à l'entrepreneur (Civ. 3e, 10 déc. 1970, Bull. civ. III, n° 690 ; V. aussi : Civ. 1re, 7 févr. 1962, D. 1962. 433. – Civ. 3e, 15 déc. 1970, Bull. civ. III, n° 690), qu'il s'agisse de l'immeuble (Civ. 3e, 20 nov. 1975, D. 1976. IR 185 ; 8 mars 1978, D. 1978. 641) ou des engins de chantier (Civ. 2e, 15 avr. 1964, Bull. civ. II, n° 287). Un arrêt exige cependant que les éléments caractérisant la garde (direction et contrôle) soient établis à la charge de l'entrepreneur (Civ. 3e, 20 oct. 1971, Bull. civ. III, n° 505 ; comp. : 24 juin 1992, RDI 1993. 9), ce qui peut déboucher sur une distinction entre la garde de la structure (masse de l'immeuble), incombant au maître de l'ouvrage, et la garde du comportement, incombant à l'entrepreneur (travaux ; arg. en faveur de cette dernière : Civ. 2e, 4 juill. 1956, Bull. civ. II, n° 501 ; 15 avr. 1964, Bull. civ. II, n° 287 ; 29 avr. 1966, Bull. civ. II, n° 507). L'entrepreneur gardien est, en principe, l'entrepreneur principal ou l'entrepreneur pilote (Req. 11 mars 1935, DH 1935. 252). Mais la garde peut être reconnue à l'entrepreneur d'opération, même s'il est sous-traitant (Civ. 2e, 1er févr. 1967, Bull. civ. II, n° 44). Le sous-traitant peut d'ailleurs répondre aussi du dommage causé au voisin sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Après la réception, la garde incombe au maître de l'ouvrage, avec un doute pour les travaux relevant du parfait achèvement. Les dispositions de l'ancien article 1384 du code civil sont reprises dans l'article 1242 nouveau qui, comme le précédent, réserve le cas de l'incendie qui n'engage la responsabilité du détenteur de l'immeuble qu'en cas de faute.

§ 3 - Ruine du bâtiment

673. Après réception. - Lorsque, après réception, un dommage est causé au tiers (passant) par la ruine du bâtiment, le maître de l'ouvrage propriétaire en répond sur le fondement de l'ancien article 1386 (C. civ., art. 1244 nouv.) si un défaut d'entretien ou un vice de la construction est établi (Civ. 2e, 8 juin 1994, D. 1994. IR 181 ; V. aussi : 17 oct. 1990, D. 1990. IR 261 ; V. *Responsabilité du fait des bâtiments [Civ.]*). Le maître de l'ouvrage a un recours contre le constructeur auteur du vice. Celui-ci étant, par hypothèse, établi, ce recours semble devoir être fondé sur l'article 1382 ancien (C. civ., art. 1240 nouv.) car l'obligation de construire ne comporte pas, en principe, d'obligation de sécurité (Civ. 3e, 27 nov. 1970, Bull. civ. III, n° 653 ; comp. : 15 févr. 1972, D. 1972. 380). Avant la réception des travaux, il semble que l'article 1386 (C. civ.,

art. 1240 nouv.) ne s'applique pas (Req. 2 avr. 1897, DP 1897. 612. – Civ. 1re, 18 mai 1960, Bull. civ. I, no 275). Il a été jugé que lorsque le dommage n'est pas causé dans les conditions prévues par l'ancien article 1386, l'ancien article 1384 (C. civ., art. 1242 nouv.) s'applique au gardien, même propriétaire (Civ. 2e, 16 oct. 2008, Bull. civ. II, no 211. – Civ. 2e, 22 oct. 2009, Bull. civ. II, no 255).

§ 4 - Troubles de voisinage

674. Tout propriétaire supporte une obligation de ne pas causer à ses voisins un dommage excédant la mesure des inconvénients tenus pour normaux (V. *infra,* nos 677 s.) : « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (V. par ex. : Civ. 3e, 13 avr. 2005, no 03-20.575), le trouble peut résulter de l'immeuble lui-même (V. *infra,* no 675), ou des travaux (V. *infra,* no 676).

A - Troubles résultant de l'immeuble

675. Tiers privilégié. - Le voisin est un « tiers privilégié » (V. en cas de cession de sa propriété : Civ. 3e, 8 oct. 2008, RDI 2009. 169), qui invoque une source autonome de droit, lorsque la construction d'autrui lui cause un trouble anormal (V. G. DURRY, RTD civ. 1974. 609 ; V. *Troubles de voisinage [Civ.]*). C'est le *maître de l'ouvrage* qui est en principe tenu de réparer les conséquences des troubles anormaux de voisinage causés au voisin en sa qualité de propriétaire : il répond notamment du dommage résultant pour le voisin de la seule existence de l'immeuble (Civ. 3e, 18 juill. 1972, Bull. civ. III, no 478 ; 27 nov. 1979, RDI 1980. 303 ; 21 avr. 1982, RDI 1982. 519 ; 26 janv. 1993, Gaz. Pal. 1993. 277, note Liet-Veaux. – TGI Nanterre, 27 avr. 1978, RDI 1979. 74 : ombre projetée sur le terrain voisin). Le trouble anormal doit être caractérisé (ce qui n'est pas le cas de la seule privation d'ensoleillement : Civ. 3e, 20 janv. 1999, no 96-18.199, ou de la construction d'autres édifices voisins d'un lotissement : Civ. 3e, 21 oct. 2009, no 08-16.692, Bull. civ. III, no 231 ; mais ce peut être le cas de vues régulières sur le fonds voisin : Civ. 3e, 12 oct. 2005, RDI 2005. 459, ou de l'obturation de jours dans le respect du permis de construire : Civ. 3e, 14 févr. 2007, no 05-22.107). Le maître de l'ouvrage ne devrait pas pouvoir exercer de recours en garantie contre l'entrepreneur, puisque le dommage est la conséquence de la seule existence de l'immeuble : une faute de l'entrepreneur serait sans lien de causalité avec le dommage (V. cep. : Civ. 3e, 4 nov. 1971, JCP 1972. II, no 17070 ; 8 juill. 1971, Bull. civ. III, no 451 ; 3 mai 1979, RDI 1980. 67 ; V. P. MALINVAUD, La responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des voisins, RDI 2002. 492). Mais la jurisprudence qui fait de l'entrepreneur un « voisin occasionnel » de la victime pour retenir sa responsabilité

pendant les travaux (V. *infra,* n° 676), soulève la question de savoir si cette qualité permet de lui faire supporter les conséquences préjudiciables pour autrui, de la seule existence de l'immeuble. On peut rapprocher du trouble résultant de l'immeuble celui consécutif aux *antennes relais.* La compétence est administrative pour l'interruption d'émission, l'interdiction d'implantation ou l'enlèvement ; elle est judiciaire pour les dommages causés aux tiers (T. confl. 14 mai 2012, RDI 2012. 514) qui peuvent relever des troubles anormaux de voisinage.

B - Troubles résultant des travaux

676. Nuisances. - Lorsque le voisin se plaint de dommages en cours de chantier sur le fondement des troubles de voisinage, il est admis que la responsabilité de l'*entrepreneur* est engagée envers la victime (Civ. 3e, 10 janv. 1968, Bull. civ. III, n° 11 ; 30 juin 1998, n° 96-13.039, Bull. civ. III, n° 144), ou envers le maître de l'ouvrage qui l'appelle en garantie (Civ. 3e, 10 janv. 1978, JCP 1978. IV. 86). Cependant, le risque de voisinage étant un risque de propriété, il serait plus logique de ne retenir la responsabilité de l'entrepreneur que s'il a commis une faute ou s'il peut être pris en tant que gardien. En effet, le voisin peut toujours imputer au maître de l'ouvrage les nuisances dont il a été victime en cours de chantier (Civ. 3e, 13 nov. 1986, Bull. civ. III, n° 172 ; 30 juin 1998, n° 96-13.039, Bull. civ. III, n° 144 ; 6 févr. 2002, n° 00-15.330, RDI 2002. 524, obs. G. Trébulle) ; or, le maître de l'ouvrage ne pouvait, en principe, exercer l'action subrogatoire contre l'entrepreneur que s'il lui reprochait une faute (V. *supra,* nos 653 et 668), sauf à invoquer sa responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 21 juill. 1999, BPIM 6/99, n° 434 ; 28 nov. 2001, BPIM 1/02, n° 37 ; V. *supra,* nos 653 et 668), en se prévalant notamment d'une clause contractuelle de garantie, s'il avait pris la précaution de la stipuler (Civ. 3e, 10 janv. 1978, préc.). Mais la Cour de cassation estime à présent qu'il peut, par subrogation aux droits du voisin, exercer une action récursoire contre l'entrepreneur sur le fondement des troubles de voisinage (Civ. 1re, 18 sept. 2002, Bull. civ. I, n° 200. – Civ. 3e, 26 févr. 2003, n° 01-16.630, BPIM 3/03, inf. 170 ; 29 janv. 2008, n° 06-19.419), et la preuve d'une faute de ce dernier n'est pas nécessaire (Civ. 3e, 24 sept. 2003, n° 02-12.873, Bull. civ. III, n° 160 ; 13 avr. 2005, n° 03-20.575, Bull. civ. III, n° 89 ; 20 déc. 2006, n° 05-10.855, Bull. civ. III, n° 254). L'entrepreneur est un « voisin occasionnel » qui répond à ce titre des troubles de voisinage (Civ. 3e, 22 juin 2005, n° 03-20.068, Bull. civ. III, n° 136 ; 21 mai 2008, RDI 2008. 546), à condition toutefois que le dommage soit en relation avec sa mission (Civ. 3e, 9 févr. 2011, n° 09-71.750, Bull. civ. III, n° 21. – Civ. 3e, 28 avr. 2011, n° 10-14.516, Bull. civ. III, n° 303). L'entreprise responsable est soit l'entreprise de premier rang (Civ. 3e, 21 juill. 1999, n° 96-22.735, Bull. civ. III, n° 182 ;

11 mai 2000, n° 98-18.249, RJDA 11/00, n° 1061 ; 13 avr. 2005, n° 03-20.575, Bull. civ. III, n° 89, RDI 2005. 299, RDI 2005. 279), soit le sous-traitant (Civ. 3e, 30 juin 1998, n° 96-13.039, Bull. civ. III, n° 144 ; 21 mai 2008, préc.), soit le constructeur de maison individuelle (Civ. 3e, 12 oct. 2005, n° 03-19.759, Bull. civ. III, n° 195, RDI 2005. 459, obs. Malinvaud, RDI 2006. 43, obs. Trébulle, RDI 2006. 205, obs. Bergel), soit le gestionnaire du projet (Civ. 3e, 22 juin 2005, n° 03-20.068, Bull. civ. III, n° 136, RDI 2005. 339, RDI 2005. 330, obs. Gavin-Milan-Oosterlynck, D. 2006. 40, obs. Karila, RTD civ. 2005. 788, obs. Jourdain) soit le mandataire d'un GME (Civ. 3e, 13 avr. 2005, n° 03-20.575, Bull. civ. III, n° 89, RDI 2005. 299, obs. Malinvaud, RDI 2005. 279, obs. Gavin-Milan-Oosterlynck), etc. L'entrepreneur peut opposer au voisin l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 21 nov. 2012, n° 11-25.200, BPIM 1/13, inf.50). Le maître de l'ouvrage peut également se voir reprocher une faute à l'origine du trouble dont se plaint le voisin (Civ. 3e, 18 juill. 1966, Bull. civ. III, n° 433). Dans ce cas, la coresponsabilité avec un constructeur sur le fondement des troubles de voisinage peut faire problème (sur l'action récursoire, V. *supra,* n° 668).

C - Troubles constitutifs de désordres

677. Faute. - L'entrepreneur est tenu envers le voisin des conséquences de sa faute (Civ. 1re, 18 juill. 1966, Bull. civ. I, n° 433) ; la notion de troubles anormaux de voisinage est alors sans utilité. Mais l'entrepreneur peut également être poursuivi sur le fondement des troubles de voisinage lorsque le dommage n'est pas, à proprement parler, constitutif d'un trouble, mais d'un désordre (Civ. 3e, 30 juin 1998, n° 96-13.099, Bull. civ. III, n° 144). Le maître de l'ouvrage, lui aussi, peut être responsable des dommages subis par le voisin, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, alors même que ces dommages constituent des désordres et non des nuisances (Civ. 3e, 4 févr. 1971, JCP 1971. II. 16781, 1re esp., note Lindon ; 21 avr. 1982, JCP 1982. IV. 232 ; 3 févr. 1999, n° 197 D ; 13 avr. 2005, n° 03-20.575, Bull. civ. III, n° 89. – Paris, 13 janv. 2000, RDI 2000. 184). Il dispose alors d'un recours contre les constructeurs, que la jurisprudence a tendance à fonder sur le contrat (Civ. 3e, 25 mars 1998, n° 96-11.812, RDI 1998. 379, obs. Malinvaud et Boubli, BPIM 3/98, n° 196, qui retient la responsabilité de l'architecte et du bureau de contrôle ; 24 mars 1999, n° 96-19.775, RDI 1999. 361, obs. Bruschi, RDI 1999. 412, obs. Malinvaud, RTD civ. 1999. 640, obs. Jourdain ; 17 mars 1999, n° 95-19.527, BPIM 3/99, n° 221) ; mais la jurisprudence sur « le voisin occasionnel » semble l'autoriser à exercer l'action subrogatoire dès lors que le désordre est rangé dans la catégorie des troubles de voisinage : il est admis en effet que le maître de l'ouvrage et le constructeur peuvent

être tenus *in solidum* de réparer les dommages résultant d'un trouble anormal de voisinage (Civ. 3e, 13 avr. 2004, n° 03-20.575, Bull. civ. III, n° 89 ; 25 mai 2005, n° 03-19.286, Bull. civ. III, n° 112). La cour de Paris, dans son arrêt du 13 janvier 2000 précité, relève que le constructeur garant est tenu d'une obligation de résultat.

678. Dommage et réparation. - Lorsque la responsabilité encourue est quasi délictuelle, ce sont les règles de droit commun de cette responsabilité qui s'appliquent à la réparation du dommage. La compétence est judiciaire même dans les marchés publics lorsque les parties sont liées par un contrat de droit privé (sous-traitance : T confl. 15 janv.1973, Sté Quillery-Goumy, RD publ. 1973. 1049) ; elle peut être administrative lorsque les parties n'ont pas de lien contractuel : le Tribunal des conflits qui avait admis la compétence administrative pour les marchés de travaux publics sauf si les parties sont liées par un contrat de droit privé (T. confl. 24 nov. 1997, n° 3060, RDI 1998. 251), étend la compétence administrative aux membres d'un groupement solidaire (T. confl. 9 févr. 2015, n° 3983, RDI 2015. 186). L'action en réparation se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action (C. civ. art. 2224). Mais lorsque l'action est exercée contre un constructeur, il est probable que c'est la prescription édictée aux articles 1792-4-2 et 1792-4-3 qui s'applique. Un doute subsiste en cas d'empiètement sur le terrain voisin : cet empiètement étant susceptible d'entraîner la prescription acquisitive de la propriété du sol, il est permis de penser que les dispositions de l'article 2272 sont applicables. Pour la réparation en nature ou par équivalent (V. *supra,* nos 612 s.), il convient de rappeler aussi que le préjudice doit être entièrement réparé et qu'il s'étend, en matière quasi délictuelle, au dommage imprévisible.

Art. 3 - Responsabilité du fait des produits défectueux

679. Textes. - La loi n° 98-939 du 19 mai 1998 a transposé en la modifiant la directive du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux (V. *Responsabilité du fait des produits défectueux [Civ.]*). La réglementation, mise en conformité avec les dispositions de la directive par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, figure aux articles 1245 et suivants du code civil (anc. art. 1386-1 s. – V. *infra,* nos 680 s.). La loi s'appliquant au bien meuble incorporé dans un immeuble (C. civ., nouv. art. 1245-3, anc. art. 1386-3), elle concerne les acteurs de la construction et consacre une responsabilité du fabricant qui peut coexister avec d'autres formes de responsabilité (V. *infra,* nos 682 s.). Comme le relève MALINVAUD, la responsabilité du fait des produits défectueux *s'ajoute* et ne se substitue pas aux autres (La loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et le droit de la construction, D. 1999. Chron. 85 ; Dalloz-Action, Construction Urbanisme 2014-2015, n° 478-690).

§ 1er - Généralités

680. Prestataires visés. - La loi s'applique à différents *prestataires* à l'exception des « personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 » du code civil (art. 1245-5, al. 5, anc. art. 1386-6). Sont assujettis :

1° le fabricant de biens meubles, pris en sa qualité de producteur professionnel (C. civ., art. 1245-2, anc. art. 1386-6). Il sera intéressant de savoir si le producteur peut être indifféremment un sous-traitant ou un fournisseur-vendeur de produits de construction : rien ne semble s'y opposer ; toutefois, le sous-traitant, désormais responsable sur le fondement des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, fait apparemment partie des personnes exclues par l'article 1245-5 [anc. art. 1386-6], dernier alinéa, qui vise les articles 1792 à 1792-6 ; en revanche, il pourrait être pris en tant « qu'incorporateur » (V. 3°) ;

2° le distributeur de biens meubles, dans la présentation extensive qu'en donne l'article 1245-5 2 (anc. art. 1386-6°) qui vise toute « forme de distribution ». Au distributeur la loi assimile le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel (C. civ., art. 1245-6, anc. art. 1387) ;

3° l'incorporateur de biens meubles. L'article 1245-7 (anc. art. 1386-8) rassemble dans la même responsabilité le producteur et celui qui réalise l'incorporation : ils sont solidairement responsables. Ce dispositif est susceptible de concerner toutes les entreprises d'opération, de l'entrepreneur principal au sous-traitant. Aussi, la loi exclut-elle de son champ d'application les personnes dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 du code civil, ce qui vise le fabricant d'EPERS et le sous-traitant sauf s'il est pris en tant qu'incorporateur. Dans le secteur de la construction, les articles 1386-1 et suivants concernent donc, outre les sous-traitants dans les limites indiquées, les fournisseurs de matériaux, y compris selon une interprétation autorisée (MALINVAUD, op.cit., n° 478-820), le fournisseur [et non le fabricant] d'EPERS. Les « entrepreneurs incorporateurs » et les constructeurs de maison individuelle, devraient échapper à l'application de la loi lorsqu'ils ont la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants. Mais il n'est pas impossible qu'ils soient pris comme des producteurs, lorsque le dommage ne relève pas de la garantie décennale ou de la garantie biennale (Ph. MALINVAUD, *op. cit.,* n° 478-800).

681. Bien meuble. - La loi s'applique à tout *bien meuble* même incorporé dans un immeuble. Il en résulte que les éléments constitutifs d'un ouvrage immobilier sont des produits au sens de la loi, qu'il s'agisse de matière première indifférenciée (sable), de

produits élaborés (bois), ou de produits finis (tuiles). Ces produits doivent être défectueux au point de ne pas offrir « la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » (C. civ., art. 1245-3, anc. art. 1386-4). La sécurité ne se limite pas aux personnes (amiante), bien que celle-ci ait été spécialement prise en compte. Elle s'étend aux biens autres que le produit lui-même (art. 1245-1 [anc. art. 1386-2] : dommages à l'ouvrage ; V. pour une application : Civ. 1re, 7 nov. 2006, RDI 2007. 94). Elle concerne non seulement le contractant mais aussi les tiers : le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit « qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (art. 1245 [anc. art. 1386-1]).

§ 2 - Cas particulier de la construction

682. La responsabilité des produits défectueux dans la construction immobilière peut être en concours avec d'autres (V. *infra,* n° 683) ; son régime est spécifique (V. *infra,* nos 684 s.).

A - Concours de responsabilités

683. Cas. - Un concours de responsabilités est inévitable dans plusieurs cas, sans que la solution du cumul d'actions puisse pour autant être aisément dégagée. Il s'agit, comme l'observe Ph. MALINVAUD, d'actions concurrentes et non alternatives. Il en résulte que la victime peut invoquer la responsabilité des articles 1245 et suivants (C. civ., anc. art. 1386-1) et suivants du code civil, *en même temps* que d'autres responsabilités compatibles, ce qui vise :

1° le sous-traitant, avec les réserves déjà émises, contre lequel il sera également possible d'invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun (c'est l'entrepreneur principal qui agit), ou la responsabilité quasi délictuelle de droit commun (maître d'ouvrage qui agit) ;

2° l'entrepreneur principal, contre lequel on peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception. Après réception, les dommages relevant de la responsabilité décennale ou biennale échappent au concours. En revanche, ceux relevant de la responsabilité de droit commun peuvent ne pas y échapper (en ce sens, Ph. MALINVAUD, *op. cit.,* n° 478-800 ; toutefois, il faut supposer que l'entrepreneur principal est un producteur au sens de la loi, ce qui peut se discuter, V. *supra,* n° 680) ;

3° les vendeurs (fournisseurs en fait), fabricants de produits autres que des EPERS, contre lesquels il est possible d'invoquer outre la responsabilité des articles 1245 et

suivants (C. civ., anc. art. 1386-1), celles relevant de la non-conformité et des vices cachés. Il appartiendra à la victime de choisir l'action la plus efficace et d'invoquer l'autre, à titre subsidiaire.

B - Régime de la responsabilité spécifique

1° - Charge de la preuve

684. Preuve. - La *preuve du défaut* incombe à la victime, comme c'est le cas en matière de vice de la chose. Le lien de causalité entre le défaut et le dommage doit également être établi par elle (C. civ., art. 1386-9 anc., C. civ., art. 1245-8 nouv. ; comp. art. 1386-11 , anc. C. civ., art. 1245-10 nouv.). Le débiteur ne devrait pas pouvoir invoquer de *cause d'exonération,* puisque le lien de causalité entre le défaut et le dommage est, par hypothèse, établi par la victime. Ainsi, il ne peut invoquer le fait du tiers (C. civ., art. 1245-13 , anc. art. 1386-14) ou le respect des règles de l'article, des normes existantes ou des règles administratives (art. 1245-9 [anc. art. 1386-10]. – Civ. 3e, 31 janv. 1990, n° 88-17.549 , Bull. civ. III, n° 39. – Civ. 3e, 14 nov. 1991, n° 89-18.699 , Bull. civ. III, n° 271). La loi l'autorise cependant à établir que le dommage ne lui est pas imputable, mais qu'il procède d'autres causes (faute de la victime : art. 1386-13 ; faute de l'incorporateur : art. 1386-11 devenu art. 1245-10). Elle institue, en outre, des *causes d'exonération spécifiques.* Lorsque le fabricant réalise une partie composante d'un ensemble (équipement incorporé dans un immeuble), il peut s'exonérer de la responsabilité en établissant que la partie dans laquelle le composant a été incorporé comporte un vice de conception, qu'il y a eu une défaillance dans les instructions données par le producteur du produit d'accueil (C. civ., art. 1245-10 [anc. art. 1386-11]). Sont également des causes d'exonération l'ordre de la loi (art. 1386-11 , 5°) et le risque de développement (C. civ., art. 1245-10 , 4° [anc. art. 1386-11 , 4°]). Sur ce dernier point, la loi déroge au droit commun (V. *supra,* n° 540) : la circonstance que le produit ait été conforme à l'état des connaissances scientifiques au moment de sa mise en circulation, et que le défaut n'ait alors pas pu être décelé, est une cause d'exonération, sous une réserve, toutefois : si le défaut s'est révélé dans un délai de dix ans à compter de sa mise en circulation, le producteur qui n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables répond de celles-ci (C. civ., nouv. art. 1245-11 , al. 2 [anc. art. 1386-12 , al. 2] ; sur la non-application de cette cause d'exonération aux faits antérieurs à la promulgation de la loi, V. Civ. 3e, 28 nov. 2001, BPIM 1/02, n° 34).

2° - Clauses de responsabilité

685. Clause de responsabilité. - Les clauses *limitatives ou exonératoires de responsabilité* sont interdites et réputées non écrites (C. civ., nouv. art. 1245-14 , anc.

art. 1386-15, al. 1er). Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables (al. 2). Il résulte de cette exception que la limitation ou l'exclusion de responsabilité dans le contrat de sous-traitance entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal paraît possible (Ph. MALINVAUD, *op. cit.,* n° 478-760). On ne sait trop, cependant, ce que recouvre la notion de produit non utilisé par la victime pour son usage personnel ; en outre, la clause de responsabilité, qui serait alors opposable au tiers victime (le maître de l'ouvrage) compte tenu du caractère hybride de la responsabilité spécifique, incitera celui-ci à invoquer le droit commun de la responsabilité quasi délictuelle qui ne sera pas nécessairement moins favorable : il est permis de se demander, en effet, si la preuve du défaut du produit ou la preuve de la faute du fabricant (ici du sous-traitant) ne conduisent pas à établir le même fait (V. *supra,* n° 678).

3° - Prescription

686. Délai. - L'action en responsabilité doit être exercée dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur (C. civ., nouv. art. 1245-16, anc. art. 1386-17). Toutefois, le producteur est déchargé de la responsabilité qui pèse sur lui dix ans après la mise en circulation du produit (art. 1386-16 ; V. lorsque le produit a été mis en circulation avant l'entrée en vigueur de la loi : Com. 24 janv. 2006, n° 02-11.323, Bull. civ. IV, n° 16, RTD civ. 2006. 571, obs. Jourdain). Il en résulte qu'après dix ans aucune responsabilité n'est encourue et que celle-ci ne l'est qu'à la condition que l'action de la victime, qui se prescrit par trois ans, ait été exercée dans ce délai. La loi réserve le cas où la responsabilité du producteur serait engagée en *raison de sa faute* (C. civ., nouv. art. 1245-15, anc. art. 1386-16). Le plafond de dix ans n'est alors plus applicable. La loi fait donc une distinction entre le *défaut* de la chose, et la *faute* du fabricant. Certes, on peut imaginer, *in abstracto,* que le défaut ne soit pas la conséquence d'une faute. Mais dans quels cas ? Le fabricant est un professionnel, réputé, en droit commun, connaître les vices du produit qu'il met sur le marché ; il est alors traité comme s'il était de mauvaise foi, au moins à l'égard des non-professionnels, donc des victimes. Quelle est donc la faute qu'il convient de prouver pour échapper au délai de dix ans ? Le *dol effectif,* et pas seulement présumé ? Difficile de le dire.

Index alphabétique

Abus de droit

modification du projet 105

refus des sous-traitants 57

Acceptation du sous-traitant 325 s.

implicite 339

Achèvement de l’ouvrage 386 s., 448 s.

V. Réception des travaux

Acompte 408

action directe 351

avance 352

bon d'acompte 409

en cours d'opération 115

distinction 408 s.

non-paiement 281, 407, 410

paiement 54, 423

présomption de vérification des parties payées 113

restitution 129

retard 105, 134

retenue de garantie 425

sur travaux exécutés 408

usage 408

Action directe 375 s.

bénéficiaires 376 s.

effets de l'action directe 383 s.
exercice de l'action 380 s.
mise en demeure 351 s.
ouvriers contre le maître de l'ouvrage 376 s.
sous-traitance
V. Action directe (sous-traitance)

Action directe (sous-traitance) 348 s.

actions subsidiaires 356
conditions d'ouverture 350 s.
domaine 349
effets 354 s.
exercice de l'action 351 s.
redressement ou liquidation judiciaire 353

Action en responsabilité

prescription 656 s., 686
V. Responsabilité

AFNOR

V. Agence française de normalisation

Agence française de normalisation 52

adhésion des parties 52
compte prorata 186 s.
pluralité d'entreprises 174 s.

◯
référence au marché 450
◯
risques (charge) 473 s.

Agence de renseignements commerciaux 62 s.

Agence de voyage 8, 30, 62 s.

◯
mandataire 30

Agrément 336 s.

◯
implicite 339

Alea technique 633

◯
appréciation souveraine 124

Architecte

◯
garantie biennale et décennale 541 s.
◯
maîtrise d'œuvre 171
◯
mandat 31
◯
obligation de moyens 644
◯
présomption de responsabilité 605 s.
V. Présomption de responsabilité
◯
réception des travaux 461 s.
◯
responsabilité (retard) 396

Artisan 4

V. Entrepreneur

Ascenseur 62 s., 169

Assurance

◯
champ d'application 584 s.
◯
construction 512 s.
◯
contrôle technique 232 s., 248
◯
défaut d'assurance 428 s., 612
◯
dette commune 189
◯
dommage 240, 480
◯
dommage-ouvrage 497, 512 s., 593
◯
dommages immatériels 598
◯
facultative 233
◯
garantie des salaires 378
◯
obligatoire 234, 504, 569, 580, 625
◯
réforme 155 s., 237
◯
responsabilité décennale 593 s., 601
◯
sous-assurance 531 s.
◯
tarification (Bureau central) 551

Avance 352

◯
acompte, distinction 408 s.

Avocat

◯
mandataire 30

Bouleversement de l’économie du marché 301

Bref délai 124 s.

Bureaux d’étude technique 169

Cession de marché 313

Clauses de responsabilité 662, 685

- limitatives ou exonératoires de responsabilité 685
- validité entre professionnels 662

Co-traitance 193

Composants 549 s.

V. Fabricant

Compte prorata 186 s.

Conformité (Défaut de) 488 s.

- responsabilité contractuelle de droit commun 650

Conseil

- obligation 96 s., 225 s.

Consignation 416

Consommateur

- conclusion du marché 255

Constructeur 166 s.

- dommage, réparation 565 s.
  V. Réparation du dommage
- entrepreneur 174 s.
  V. Entrepreneur (construction immobilière)
- garantie biennale et décennale 541 s.

◯
maîtrise d'œuvre 167 s.
V. Maître d'œuvre
◯
personnes assimilées 546 s.
◯
présomption de responsabilité 605 s.
V. Ce mot
◯
responsabilité 636 s.
V. Responsabilité contractuelle des constructeurs
◯
vendeur réputé constructeur 546 s.

Construction immobilière 140 s.

◯
construction de maison individuelle 147 s.
V. Ce mot
◯
formule ensemblier 144 s.
◯
formule maître d'œuvre 152
◯
montage de l'opération 142 s.
◯
promotion immobilière 142 s.

V. Constructeur, Maître de l'ouvrage

Construction de maison individuelle

◯
montage de l'opération 147 s.

Contrat

◯
commodat 36
◯
de dépôt 34
◯
d'assistance bénévole 38
◯

d'association 37
d'études préliminaires rémunéré 248
de fourniture (distinction de la sous-traitance) 306
de transport 35
V. Marché

Contrat de construction de maison individuelle 374

Contrat de travail
distinction 12 s.

Contrôle technique 231
assurance facultative ou obligatoire 233 s.
avis 245
contenu 242 s.
contrat de contrôle technique 235 s.
missions 238 s.
de base 246
obligatoire 238 s.
rapport avec la compagnie d'assurance 248
rapports avec les autres constructeurs 247
rapports avec le maître de l'ouvrage 244 s.
spontané 241

Coordinateur

V. Coordination sécurité et protection de la santé (SPS)

Coordination OPC (ordonnancement et pilotage de chantier) 180 s.

- contrat de POC 185
- garantie biennale et décennale 541 s.
- mission de coordination 184 s.

Coordination sécurité et protection de la santé (SPS) 190 s.

- chantiers assujettis 191 s.
- choix du coordinateur 194 s.
- contrat de coordination 200
- contrôleur technique 203
- coordinateur 190
  - obligations 204 s.
  - responsabilité civile 207 s.
  - responsabilité pénale 211 s.
- coordinateur qualifié 195 s.
- garantie biennale et décennale 541 s.
- mise en place 191 s.
- mission de coordination 206
- régime juridique 204 s.

Décès de l’entrepreneur 136

Défaut de la chose

- apparents 120 s.
- cachés 122 s.
- conformité
V. Conformité (Défaut de)
- désordres
V. Désordre
- laissé-pour-compte 121
- malfaçons 120, 125
V. Malfaçons
- vice caché 122 s.
V. Vice caché

Définition 3 s.

Délai

- livraison 389 s.

Délais de garantie 615 s.

- action en justice 619 s.
- computation 617
- expiration, effets 623
- interruption 618 s.
- ordre public 626
- reconnaissance de responsabilité 622

Désordre

◯
affectant un élément constitutif 582
◯
affectant un élément d'équipement 582
◯
affectant un équipement indissociable du bâtiment 584 s.
◯
apparents 648
◯
caché 592 s.
V. Vice caché
◯
couvert par la garantie de parfait achèvement 481 s.
◯
couvert par la retenue de garantie 430 s.
◯
équipements à vocation industrielle 582
◯
équipements à vocation purement immobilière 582
◯
évolutif 598
◯
futur 599
◯
garanti 593 s.
V. Garantie biennale

Devis 254 s.

◯
attribution des risques 467 s.
◯
descriptif 266 s.
◯
estimatif 266
◯
marché sur devis 305 s.
◯
marché à forfait 266
V. Marché à forfait

◯
marché privé 254
V. Marché
◯
non-respect 512
◯
quantitatif 266

Distributeur d'ouvrage

◯
assimilation à fabricant 553

Documents contractuels 492

Dol

◯
du constructeur 623, 658
◯
contractuel ou extracontractuel 623

Dommages 600 s.

◯
annexes et aux tiers 651 s.
◯
consécutifs 602
◯
aux existants 602
◯
intermédiaires 649
◯
réparation 652 s.

Édition 9

Effets du contrat 55 s.

Entrepreneur 4

Entrepreneur (construction immobilière) 174 s.

◯
compte prorata 186 s.
◯

coordination OPC (ordonnancement et pilotage de chantier) 180 s.
coordination sécurité et protection de la santé (SPS) 190 s.
V. Coordination sécurité et protection de la santé (SPS)
garantie biennale et décennale 541 s.
obligation de résultat 643
obligations 230
pluralité d'entreprises 174 s.
présomption de responsabilité 605 s.
V. Présomption de responsabilité

Entrepreneur (Obligations) 220 s.

conservation de la chose 221
construction immobilière 230
exécution du marché 222
garde du chantier 229
prix fixé (respect) 222
réglementation 224
règles de l'art 224
renseignement et conseil 225 s.
responsabilité 223, 394 s.
risques avant réception 221
sanctions 223

Entrepreneur (principal)

- acceptation et agrément du sous-traitant 325 s.
- obligations 325 s.
- présomption de responsabilité 605 s.
- rapports avec le maître de l'ouvrage 372

EPERS 550 s.

V. Fabricant

Équipement

- constitutif 582
- dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage 583
- indissociable de l'ouvrage 584 s.
- à vocation industrielle 582
- à vocation purement immobilière 582

V. Désordre

Fabricant 462 s.

- de composants 549 s.
- concours de responsabilités 559 s.
- distributeur d'ouvrage, assimilation 553
- d'EPERS 550 s.
- garantie 549 s.
-

importateur d'ouvrage, assimilation 553
◯
de matériaux 561
◯
responsabilité 554 s.
◯
solidaire 558
◯
sous-traitant, distinction 552

Façonnier 4

V. Entrepreneur

Fait du tiers 609

◯
présomption de responsabilité 608

Faute 670 s.

◯
absence, preuve 77, 130
◯
abus de droit 105
◯
architecte 396, 404, 461 s.
V. Architecte
◯
de conservation 86
◯
constructeur 83, 623 s., 649 s.
◯
contrôleur technique 244 s.
◯
coordonnateur 207 s.
◯
délégué 159
◯
d'imprudence 27
◯
entrepreneur 18, 85, 221, 285, 331, 376, 543

◯
extracontractuelle 623, 658
◯
garagiste 99
◯
inexcusable 214
◯
locateur 18, 85
◯
lourde 80, 207, 669
◯
maître de l'ouvrage 160, 331 s., 361, 399, 672 s.
◯
non accepté 366
◯
présomption 32
◯
présomption de responsabilité, distinction 245
◯
preuve 73, 77, 83 s., 372, 641 s., 659, 667
◯
résiliation pour faute 287
◯
responsabilité 672 s.
◯
sous-traitant 78
◯
victime 65, 74, 88, 398
◯
volontaire 623

Force majeure 607 s.

◯
présomption de responsabilité 608
◯
risques 118
V. Risques

Forfait

V. Marché à forfait

Formation du contrat 41 s.

Garagiste

- contrat 7, 52
- exécution complète 81
- obligation de moyen ou de résultat 62, 71 s., 77
- obligation de renseignement 99
- obligation de sécurité 101 s.
- réparateur 71, 74, 123
- responsabilité 76, 123
- rétention 116

Garantie

- absence de fourniture de garantie 420
- biennale 509, 517 s.
  V. Garantie biennale
- caution solidaire 419
- constitution 418 s.
- décennale 509, 517 s.
  V. Garantie décennale
- marchés concernés 416
- mise en demeure
  -

fourniture 420 s.
mise en œuvre 499 s.
régime de la garantie 420 s.
remplacement par clause de réserve de propriété 422
retenue de garantie 423 s.
V. Retenue de garantie
versement direct du montant du prêt 418

Garantie biennale 515 s.

bénéficiaires 562 s.
conditions 587 s.
copropriété 566 s.
délais 615 s.
V. Délais de garantie
dommage garanti 591 s.
législation, évolution 522 s.
nature juridique 517 s.
ordre public 624 s.
personnes tenues à la garantie 540 s.
V. Constructeur
présomption de responsabilité 604 s.
V. Présomption de responsabilité
société de construction 598

textes applicables 538
vice caché 593 s.
V. Vice caché

Garantie décennale 517 s.

bénéficiaires 563 s.
certain 597 s.
conditions 569 s.
consécutifs 602
copropriété 566 s.
délais 615 s.
V. Délais de garantie
désordre
affectant un équipement indissociable du bâtiment 584 s.
évolutif 598
futur 542
dommage 597 s.
dommage garanti 591 s.
dommages causés par la chose 600 s.
aux existants 601
gravité du dommage 580 s.

législation, évolution 80 s.
nature juridique 517 s.
ordre public 624 s.
ouvrage peu solide ou impropre à sa destination 570 s.
personnes tenues à la garantie 540 s.
V. Constructeur
présomption de responsabilité 604 s.
V. Présomption de responsabilité
réparations, rénovations 578
société de construction 568
textes applicables 538
travail sur existant 575 s.
vice caché 593 s.
V. Vice caché

Garantie de parfait achèvement 474 s.

apparents 485
apparus dans l'année de la réception 484
assurance construction 512
ayant fait l'objet de réserves 483
défauts de conformité 488 s.
délai d'exécution des travaux de reprise 507

délai de la garantie 504
◯
désordre après réception 506
◯
désordre ayant donné lieu à réserves 505
◯
désordres couverts 483 s.
◯
domaine d'application 481 s.
◯
entrepreneur concerné 478 s.
◯
fonction 476 s.
◯
garanties biennale et décennale 509
◯
mise en œuvre 504 s.
◯
modalités de la mise en œuvre 505 s.
◯
nature de la garantie 480
◯
objet 500 s.
◯
régime juridique 500 s.
◯
réserves 485 s.
◯
responsabilité contractuelle de droit commun 510 s.

Garde 672 s.

◯
du chantier 229
◯
immeuble en construction 229
◯
responsabilité 672 s.
◯

transfert 112

Géomètre-expert 170

Immeuble à rénover

vendeur réputé constructeur 547

Immixtion fautive

du maître de l'ouvrage 613

Importateur d’ouvrage

assimilation à fabricant 553

Ingénieurs 169

Insolvabilité 344, 376, 381

Intempéries 398, 608

Isolation phonique 494 s.

Laboratoire d’analyse 66

Laissé-pour-compte 121

Livraison de l’ouvrage 388 s.

clause pénale 403

délai 394 s.

imputable au constructeur 401 s.

imputable au maître de l'ouvrage 407

mise en demeure 401

pénalités 404

réception, distinction 389 s.

responsabilité de l'architecte 396
responsabilité de l'entrepreneur 394 s.
responsabilité du maître de l'ouvrage 399
retard 400 s.
révision du prix du marché 407
sanctions 401 s.

Locateur d'ouvrage 56 s.

garantie biennale et décennale 541 s.
louage de choses 69 s.
V. Louage de choses
louage de services 59 s.
V. Louage de services

V. Entrepreneur

Lotisseur 545 s.

Louage

d'ouvrage 3 s.
d'ouvrage et d'industrie 3 s.
par devis et marchés 3
de services 3 s.

Louage de choses 69 s.

causes d'exonération 74

chose conforme 81
clauses limitatives et exonératoires 80
conservation la chose 82 s.
faute du locateur 73
livraison dans le temps convenu 87 s.
obligation de renseignement et de conseil 96 s.
obligation de sécurité 100 s.
obligations de moyen ou de résultat 71 s.

Louage de services 59 s.

exécution du travail 60 s.
obligation de renseignement et de conseil 63 s.
obligation de sécurité 65 s.

Maître d’œuvre

architecte 171
V. Architecte
bureaux d'étude technique 169
formule maître d'œuvre 152 s.
garantie biennale et décennale 541 s.
géomètre-expert 170
ingénieurs 169

métreur-vérificateur 170
techniciens d'études 168 s.

Maître de l'ouvrage 4, 154 s.

compétence 163 s.
construction immobilière 155 s.
contrôle technique 244 s.
V. Contrôle technique
défauts
apparents 120 s.
cachés 122 s.
V. Défaut de la chose
définition 155 s.
délégué 158 s.
prérogatives 162 s.
responsabilité 117 s.
responsabilité à l'égard des tiers 160
risques 126 s., 612
V. Maître de l'ouvrage (Obligations du)

Maître de l'ouvrage (Obligations du) 95 s.

acceptation des risques 612
acceptation du sous-traitant 325 s.

faciliter le travail 105 s.
◯
immixtion fautive 613
◯
livraison 114
◯
paiement du prix 115 s.
◯
rapports avec l'entrepreneur principal 372
◯
rapports avec le sous-traitant 368 s.
◯
réception 110 s.
◯
responsabilité (fautes) 611 s.

Maîtrise d'œuvre 167 s.

V. Maître d'œuvre

Malfaçons

◯
conformité, distinction 120
◯
vice caché, distinction 125

Mandat

◯
agence de voyage 30
◯
architecte 31
◯
avocat 30
◯
contrat de promotion immobilière 32
◯
distinction 29 s.

Marché

◯
avant contrat 254

◯
avec consommateur 255
◯
cession de marché 313
◯
contrat d'études préliminaires rémunéré 254
◯
contrat, forme 257 s.
◯
sur dépenses contrôlées 309 s.
◯
devis 254
◯
sur devis ou au métré 305 s.
◯
dévolution 253 s.
◯
documents annexés 259
◯
à forfait
V. Marché à forfait
◯
de gré à gré 256
◯
à maximum 311
◯
modèles-type 258
◯
privé 249 s.

Marché à forfait 260 s.

◯
clauses contractuelles modificatives 271
◯
conditions 264 s.
◯
définition 260 s.
◯
devis 266

◯
documents annexés 266
◯
droit commun 278 s.
◯
d'origine 269
◯
exécution et cessation du marché 276 s.
◯
forme 264 s.
◯
modification 270
◯
plan 269 s.
◯
preuve 265
◯
prix 273 s.
◯
règles spéciales 282 s.
◯
résiliation du marché 278 s.
◯
résiliation unilatérale 137 s., 279
◯
travaux supplémentaires 287 s.
V. Travaux supplémentaires

Matériaux

◯
créance 28
◯
fourniture 14, 318, 472
◯
incorporés 571, 680
◯
non utilisés 473
◯
preuve 414

◯
propriété 25 s., 469
◯
qualité 76, 224
◯
valeur 129 s.
◯
vice 619 s.

■Médecin 351 s.

◯
contrat de travail 16
◯
honoraires 48
◯
obligation d'information 63 s.
◯
obligation de moyens 60 s.
◯
prescription de la créance 28
◯
prestation intellectuelle 8
◯
responsabilité 60 s.
◯
soins 60

■Métreur-vérificateur 170

■Mise en demeure

◯
action directe 351 s.
◯
agrément du sous-traitant 330
◯
assurance construction 512
◯
clause pénale 403
◯

garantie
- fourniture 420 s.
- mise en œuvre 500 s.
- réparation en nature 500 s.
- retard 92, 401 s.
- risques 129, 472

Nantissement 351 s.

Nature du contrat 6 s.

Non-conformité
- résultant d'une exécution différente 489 s.
- résultant de l'inachèvement 493

Normes techniques 490

Nullité 131 s.
- sous-traitance 336, 343 s.

Obligation
- à la dette 628
- *in solidum* 629 s.
- de moyen ou de résultat 71 s., 366, 642 s.
- de renseignement et conseil 96 s., 225 s.
- de résultat 60 s.
- de sécurité 65 s., 100 s.

V. Entrepreneur (Obligations)

■Organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment (OPQCB) 171, 220

■Ouragan 607 s.

■Ouvrier 4

V. Entrepreneur

■Paiement 408 s.

◯
acompte
V. Acompte

◯
conditions 409 s.

◯
délai 410

◯
garantie 415 s.
V. Garantie

◯
prise d'attachement 409

◯
refus 69

◯
suspension 411

■Paiement (sous-traitance) 341 s.

◯
action directe 348 s.

◯
direct 357 s.

◯
garanties principales 344 s.

◯
marchés privés 344 s.

◯
marchés publics 357 s.

◯
obligation de l'entrepreneur principal 344 s.

◯
obligation du maître de l'ouvrage 347
◯
sous-traitance irrégulière 361

Piscine

◯
bâtiment 295, 584
◯
carrelage 582
◯
garantie 550 s.
◯
permis de construire (non) 146
◯
réception 457

Plan

◯
annexé au devis 266
◯
architecte, erreur 222
◯
d'origine 269 s.
◯
maison individuelle 148 s.
◯
marché à forfait 268 s.
◯
plan arrêté 268 s.

Pourparlers 44

Prescription 655 s.

◯
action en responsabilité (délai de 3 ans) 686
◯
décennale 657 s.
◯
dol 658

◯
légale publique ou privée 491
◯
responsables constructeurs 657 s.
◯
responsables non constructeurs 656
◯
trentenaire 657

Présomption de responsabilité 604 s.

◯
architecte 605
◯
causes d'exonération 607 s.
◯
constructeur et personnes assimilées 605 s.
◯
entrepreneur 605
◯
fait du maître de l'ouvrage 610 s.
◯
fait du tiers 609
◯
fautes 611
◯
force majeure 608
◯
immixtion fautive 613
◯
personnes concernées 605 s.

Prestataire

◯
réputé constructeur 548

Prêt de main d’œuvre

◯
distinction de la sous-traitance 321

Preuve du contrat 51 s.

Privilège

- architectes et entrepreneurs 414
- général 19
- immeubles 19
- meubles 116
- de pluviôse 359
- salaires 19
- vendeur 64

Prix 46 s.

- fixation par le juge 37 s.
- fixation par les parties 47 s.
- marché à forfait 577 s.

Promotion immobilière

- mandat d'intérêt commun 32

Réception

- livraison, distinction 388 s.

Réception des travaux 433 s.

- achèvement 448 s.
- architecte (assistance) 461 s.
- classification 439 s.

◯
complet 450
◯
définition 435 s.
◯
définitive 444 s.
◯
effets 463 s.
◯
expresse 454 s.
◯
forme 454 s.
◯
garanties, point de départ 464 s.
◯
judiciaire 454 s.
◯
moment 443 s.
◯
partielle 452
◯
provisoire 444 s.
◯
qualification 437 s.
◯
relatif 449
◯
réserves 452
◯
résiliation amiable 455
◯
risques, charge 467 s.
V. Risques
◯
tacite 456 s.

Règles de l’art 490

Remise de dette 440

Remonte-pente 68

Remorquage 62

Rénovation 578

Réparation du dommage 627 s.

- absence d'ouvrage 633
- aléa technique 633
- contribution à la dette 630 s.
- indemnisation 635
- en nature 634
- obligation à la dette 629
- préjudice, évaluation 633 s.
- responsabilité *in solidum* des constructeurs 629 s.

V. Responsabilité contractuelle des constructeurs, Responsabilité délictuelle des constructeurs

***Res perit domino* 129, 469 s.**

Résiliation

- marché à forfait 137 s.

Résolution 134 s.

Responsabilité

- architecte 396
V. Architecte
- clauses interdites 624 s.
-

concours de responsabilités 559 s.
constructeur
contractuelle de droit commun 510 s.
prescription 657
coordinateur
entrepreneur 223, 394 s.
entrepreneur principal 372
responsabilité civile 207 s.
responsabilité pénale 211 s.
fabricant 554 s.
V. Fabricant
in solidum des constructeurs 628 s.
maître de l'ouvrage 117 s.
sous-traitance occulte 331
présomption de responsabilité 605 s.
V. Présomption de responsabilité
prestataire non constructeur 656
sous-traitant 364 s.
V. Sous-traitant
V. Garantie biennale, Garantie décennale, Responsabilité contractuelle des constructeurs, Responsabilité délictuelle des constructeurs

Responsabilité contractuelle des constructeurs 514 s., 636 s.

action contractuelle du maître de l'ouvrage 652

action subrogatoire 653
après réception 645 s.
architecte
obligation de moyens 644
avant réception 639 s.
dommages concernés 639 s.
clauses de responsabilité 662
défauts de conformité 650
désordres apparents 648
dommages annexes et aux tiers 651 s.
dommages causés par l'ouvrage 640
dommages intermédiaires 649
droit commun 636 s.
entrepreneur
obligation de résultat 643
garantie biennale
V. Garantie biennale
garantie décennale
V. Garantie décennale
malfaçons prédécennales 641

prescription 655 s.
V. Prescription
preuve 659
régime 642 s.
responsabilité post décennale ou post biennale (non) 661
responsabilité résiduelle 646 s.
dommages soumis 647 s.
ouvrages soumis 646
retard dans l'exécution 639
transmission de l'action en réparation 660

Responsabilité délictuelle des constructeurs 663 s.

action récursoire du maître de l'ouvrage 668
constitutifs de désordres 677 s.
dol 669
faute 671
garde 672
locataire du maître de l'ouvrage 665
penitus extranei 665
rapports des constructeurs entre eux 667
réparation 678

résultant de l'immeuble 675
◯
résultant des travaux 676
◯
ruine du bâtiment 673
◯
transmission de l'action 663
◯
troubles de voisinage 674 s.

Responsabilité du fait des produits défectueux 679 s.

◯
biens concernés 681
◯
cas particulier de la construction 683 s.
◯
clauses de responsabilité 685
◯
concours de responsabilités 683
◯
distributeur de biens meubles 680
◯
fabricant de biens meubles 680
◯
incorporateur de biens meubles 680
◯
législation 680 s.
◯
personnes concernées 680
◯
prescription 686
◯
preuve, charge 684

Retard 400 s.

◯
imputable au constructeur 401 s.
◯
imputable au maître de l'ouvrage 407

◯
mise en demeure 92, 401 s.

Retenue de garantie 423 s.

◯
acomptes versés 425 s.
◯
caution bancaire 426 s.
◯
constitution 424 s.
◯
contrat 424
◯
désordres garantis 430 s.
◯
exception d'inexécution 432
◯
garantie de bonne fin des travaux 429
◯
régime 427 s.
◯
travaux concernés 429

Retrait

◯
du sous-traitant 366

Risques 126 s.

◯
acceptation par maître de l'ouvrage 612
◯
après la réception 472
◯
avant réception des travaux 221, 468 s.
◯
construction immobilière 126 s.
◯
force majeure 127
◯

mise en demeure 129, 472
normes AFNOR 473
occultation par maître de l'ouvrage 612
répartition conventionnelle 473

Ruine du bâtiment 673

Sous-traitance 314 s.

acceptation 325 s.
agrément 325 s.
en chaîne 325
conclusion du sous-traité 323
contrat 317 s.
contrat de droit privé 322
contrats voisins 321
nature juridique 318 s.
objet 317
contrat de fourniture, distinction 321
contrat relevant de la sous-traitance réglementée 317 s.
implicite 339
irrégulière 361, 366
marché privé 325 s.

◯
marché public 337 s.
◯
occulte 324
◯
responsabilité du maître de l'ouvrage 331
◯
sous-traité 317 s.
V. Sous-traitant

Sous-traitant

◯
faculté de retrait 366
◯
non accepté 336
◯
obligation de résultat 355
◯
occulte 325 s.
◯
paiement 343 s.
V. Paiement (sous-traitance)
◯
préjudice 334
◯
rapports avec les autres constructeurs 373
◯
rapports avec l'entrepreneur principal 363 s.
◯
rapports avec le maître de l'ouvrage 368 s.
◯
responsabilité
◯
envers entrepreneur principal 363 s.
◯
envers maître de l'ouvrage 369
◯
responsabilité envers entrepreneur principal 363

Sous-traité 315 s.

- nullité 367

V. Sous-traitance, Sous-traitant

Transaction 622

Travail dissimulé 165

Travaux supplémentaires 286 s.

- autorisation écrite du maître de l'ouvrage 297
- bouleversement de l'économie du marché 300
- conditions résultant du texte 297 s.
- construction d'un bâtiment 295 s.
- domaine d'application 291 s.
- marché principal 293
- marchés
  - non soumis à l'article 1793 301
  - soumis à l'article 1793 291 s.
- modifiant l'objet du contrat 290 s.
- ne modifiant pas l'objet du contrat 287 s.
- ratification des travaux par le maître de l'ouvrage 299

Troubles de voisinage 675 s.

Vendeur

- réputé constructeur 546 s.

■**Vente**

◯
distinction 20 s.

◯
critère 21 s.

■**Vice caché 122 s.**

◯
appréciation 124

◯
bref délai 125

◯
compétence du maître de l'ouvrage 594

◯
désordre non réservé tenu pour caché 595

◯
désordre réservé tenu pour caché 596

◯
garantie 593 s.

V. Défaut de la chose

■**Victime**

◯
faute 65, 74, 88, 398

Actualisation

Bibliographie. - M. MEKKI, La loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016, une réforme de la réforme ?, D. 2018. 900.

Création des tribunaux judiciaires La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (JO 24 mars), dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a été adoptée pour simplifier les procédures judiciaires. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les tribunaux de grande instance ont fusionné avec les tribunaux d'instance pour devenir les tribunaux judiciaires.

46. Ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 - Outre l'octroi de dommages et intérêts, le nouvel article 1165 du code civil, tel que modifié par l'article 7, 1°, de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 portant ratification de l'ordonnance du 10 février 2016,

prévoit que le juge peut, en cas d'abus dans la fixation du prix, être saisi d'une demande tendant à obtenir la résolution du contrat.

Dépassement du budget des travaux : caractérisation du lien de causalité. Le lien de causalité entre le préjudice consécutif au dépassement du budget et la faute de l'architecte ayant sous-évalué les travaux n'est pas établi si le maître de l'ouvrage devait nécessairement payer le surcoût correspondant aux prestations complémentaires dont l'évaluation a été omise (Civ. 3e, 19 janv. 2022, no 20-15.376, D. actu. 14 févr. 2022, obs. N. De Andrade).

71 s. Nature de l'obligation du garagiste. - Il résulte des anciens articles 1147 et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, no 20-19.732 et no 20-18.867, 2 arrêts, D. actu. 17 mai 2022, obs. C. Hélaine).

97. Étendue du devoir de conseil et caractère averti du maître de l'ouvrage. - Le maître d'ouvrage qui connaissait l'état de grande vétusté de l'existant ne peut reprocher à l'entrepreneur intervenant pour de simples réparations de n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité de faire davantage de travaux (Civ. 3e, 28 févr. 2018, no 17-13.478, Dalloz actualité, 22 mars 2018, obs. Garcia).

155, 512. Défaut de déclaration de l'activité de construction de maison individuelle. - Le défaut de déclaration de l'activité de construction de maison individuelle prive le maître de l'ouvrage de ses demandes en garantie formées à l'encontre de l'assureur de la société de construction, laquelle avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes (Civ. 3e, 26 sept. 2018, no 17-23.741, Dalloz actualité, 12 nov. 2018, obs. R. Bigot).

203. Interdiction du cumul de fonction - L'interdiction édictée par l'article R. 4532-19 du code du travail vise le coordonnateur personne physique, sans distinguer selon qu'il exerce en son nom personnel ou au nom de la personne morale qu'il est chargé « de gérer, d'administrer ou de représenter » (Civ. 3e, 12 avr. 2018, no 16-17.769 ,Dalloz actualité, 11 mai 2018, obs. Garcia).

241. Missions du diagnostiqueur d'amiante. - Conformément à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostiqueur d'amiante ne saurait se limiter à un simple contrôle visuel. Même si le contrat circonscrit sa prestation à de simples constats visuels des parties accessibles, celui-ci reste néanmoins tenu de procéder à la mise en œuvre de moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, en réalisant notamment des sondages non destructifs ou en émettant des réserves relatives aux zones non analysées. À défaut, ce dernier engage sa

responsabilité (Civ. 3e, 14 sept. 2017, n° 16-21.942, Dalloz actualité, 20 sept. 2017, obs. Pelet).

260, 262, 290 s. Apurement des comptes d'un marché à forfait. - La cour d'appel a exactement retenu que les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartées dès lors que les dispositions de l'article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF p. 03.001 (Civ. 3e, 3 déc. 2020, n° 19-25.392, D. actu. 11 janv. 2021, obs. G. Casu et S. Bonnet).

261, 264, 290. Application de la notion de marché forfaitaire à une partie des travaux convenus. - Un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus (Civ. 3e, 25 juin 2020, n° 19-11.412, D. actu. 23 juill. 2020, obs. G. Casu et S. Bonnet).

268 s. Marché à forfait. Responsabilité du tiers au contrat. - Le fait que le maître de l'ouvrage fournisse et impose à l'entrepreneur des métrés erronés du maître d'œuvre ne constitue pas un bouleversement de l'économie du contrat à la demande du maître de l'ouvrage de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat (Civ. 3e, 19 janv. 2017, n° 15-20.846, Dalloz actualité 10 févr. 2017, obs. Diab).

303. Travaux supplémentaires : nécessité d'une preuve par écrit. - La preuve de la commande de travaux supplémentaires doit être rapportée par écrit si leur montant excède 1 500 euros, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage non commerçant (Civ. 3e, 17 nov. 2021, n° 20-20.409, D. actu. 9 déc. 2021, obs. C. Dreveau).

327 s. Caution. Sous-traitance. Action directe. - L'acceptation tacite du sous-traitant par le maître d'ouvrage autorise la caution de l'entrepreneur à exercer par subrogation l'action directe du sous-traitant, mais elle n'est pas fondée à réclamer les sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution d'un contrat distinct (Civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-10.719, Dalloz actualité 19 juin 2017, obs. Garcia).

344 s. Absence de condition suspensive pour la caution de l'entrepreneur principal. - Il résulte de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, qui trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant, que l'entrepreneur principal doit, sous peine de nullité du contrat, fournir la caution avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci (Civ. 3e, 21 janv. 2021, n° 19-22.219, D. actu. 16 févr. 2021, obs. F. Garcia).

346. Sous-traitance : suspension non-autorisée des travaux en cours de chantier. - Si le sous-traitant ne résilie pas unilatéralement le contrat pour défaut d'agrément du maître de l'ouvrage (L. du 31 déc. 1975, art. 3) ou s'il n'en sollicite pas la nullité pour

absence de garantie de paiement (art. 14), le contrat doit recevoir application, de sorte que le sous-traitant ne peut pas suspendre ses travaux (Civ. 3e, 10 nov. 2021, no 20-19.372, D. actu. 7 déc. 2021, obs. F. Garcia).

420. Garantie du paiement de l'entrepreneur : invalidité du cautionnement conditionné. - Il ressort des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre (Civ. 3e, 4 mars 2021, no 19-25.964, D. actu. 24 mars 2021, obs. F. Garcia).

454. Réception contradictoire : preuve par tous moyens de la convocation de l'entreprise absente. - L'exigence du caractère contradictoire de la réception est respectée dès lors que le maître d'ouvrage rapporte la preuve, par tous moyens, que l'entreprise de travaux qui ne s'est pas présentée le jour de la réception a régulièrement été convoquée pour y participer, en temps utile (Civ. 3e, 7 mars 2019, no 18-12.221, D. actu. 18 mars 2019, obs. D. Pelet).

Incompatibilité entre la réception expresse et tacite. Dès lors que le maître de l'ouvrage a expressément accepté de recevoir l'ouvrage par la signature d'un procès-verbal, l'architecte ne peut pas solliciter du juge le constat d'une réception tacite à l'égard d'un autre constructeur non convoqué à la réception expresse, sous peine de violer l'exigence du contradictoire (Civ. 3e, 8 nov. 2021, no 20-20.428, D. actu. 15 nov. 2021, obs. C. Dreveau).

456 s. Paiement du prix et réception tacite. - Le régime spécial du contrat de construction de maison individuelle n'exclut pas la reconnaissance d'une réception tacite de l'ouvrage. Une telle réception est notamment caractérisée lorsque 95 % du prix a été payé et que les locataires sont entrés dans les lieux, ce dont il résulte une volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux (Civ. 3e, 20 avr. 2017, no 16-10.486, D. 2017. 919 ; Dalloz actualité, 9 mai 2017, obs. Garcia).

Présomption de réception tacite : paiement intégral et prise de possession. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception ; mais le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, dont la « volonté non équivoque » du maître d'ouvrage de recevoir les travaux se déduit. Celui qui conteste la réception tacite doit donc prouver que cette volonté fait défaut pour renverser cette présomption simple : la charge de la preuve est renversée sur ce point (Civ. 3e, 30 janv. 2019, no 18-10.197, D. actu. 21 févr. 2019, obs. D. Pelet).

Conditions d'admission de la réception tacite. En l'absence de réception expresse, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté

non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (Civ. 3e, 18 avr. 2019, no 18-13.734, D. actu. 22 mai 2019, obs. D. Pelet).

457. Absence de réception tacite en cas de contestation de la qualité des travaux. - Les contestations constantes de la qualité des travaux exécutés et la demande d'une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur peuvent permettre de désuire l'absence de la réception tacite par le maître de l'ouvrage, malgré la prise de possession et le paiement d'une partie des factures (Civ. 3e, 1er avr. 2021, no 20-14.975, D. actu. 27 avr. 2021, obs. C. Dreveau).

459 s. Conditions de mise en œuvre de la réception judiciaire. - Au visa de l'article 1792-6 du code civil, la Cour de cassation met fin à une jurisprudence fluctuante en précisant quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande de réception judiciaire. Pour la Cour, il n'y en a que deux : l'absence de réception amiable et l'existence de travaux en état d'être reçus (Civ. 3e, 12 oct. 2017, no 15-27.802, Dalloz actualité, 8 nov. 2017, obs. Garcia).

464, 569. Date de la réception en cas d'autoconstruction et point de départ du délai de la garantie décennale. - Lorsque le vendeur est le constructeur, fait courir le délai de la garantie décennale, la date à laquelle l'ouvrage est utilisable et propre à sa fonction (Civ. 3e, 19 janv. 2017, no 15-27.068, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. Dreveau).

484. Garantie de parfait achèvement : obligation de notification des désordres avant l'assignation. - En l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies (Civ. 3e, 15 avr. 2021, no 19-25.748, D. actu. 6 mai 2021, obs. C. Dreveau).

492. Absence de mise en conformité en cas de violation d'un DTU sans désordre. - Il résulte de la combinaison des article 1134 et 1240 du code civil qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3e, 10 juin 2021, no 20-15.277, D. actu. 24 juin 2021, obs. G. Casu et A. Cottin).

512. Désordres réservés et assurance dommage ouvrage. - En application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement,

n'a pas exécuté ses obligations (Civ. 3e, 1er avr. 2021, no 19-16.179, D. actu. 28 avr. 2021, obs. C. Dreveau).

569. Notion d'ouvrage. Garantie applicable. - La construction, sur plusieurs kilomètres, d'une conduite métallique fermée d'adduction d'eau à une centrale électrique constitue un ouvrage et non un équipement. L'intérêt majeur de la qualification d'ouvrage est d'intégrer le champ d'application de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. L'article 1792-2 du code civil, qui prévoit le rattachement à la garantie décennale aux éléments d'équipement indissociables aurait produit le même effet, à ceci près qu'il doit être combiné avec les dispositions exclusives des garanties spéciales des constructeurs de l'article 1792-7 du code civil afférentes aux éléments d'équipement « dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage » (Civ. 3e, 19 janv. 2017, no 15-25.283, Dalloz actualité 7 févr. 2017, obs. Garcia).

Construction : délai de forclusion de l'article 1792-4-3 du code civil. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion (Civ. 3e, 10 juin 2021, no 20-16.837, D. actu. 21 juin 2021, obs. G. Casu et S. Bonnet).

573 s. Modestes travaux et garantie décennale. - Ne constituent pas un élément constitutif de l'ouvrage, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux qui correspondent à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste ; ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale instituée par l'article 1792 du code civil (Civ. 3e, 28 févr. 2018, no 17-13.478, D. 2018. 510 ; RDI 2018. 466 ; BICC no 884, 15 juin 2018).

580. Contrat d'entreprise : application des normes parasismiques. - Le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques sismiques, modifié par le décret no 2000-892 du 13 septembre 2000, rend les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants (Civ. 3e, 19 sept. 2019, no 18-16.986, D. actu. 9 oct. 2019, obs. F. Garcia).

582. Garantie décennale et élément d'équipement dissociable ou non. - La Cour de cassation réitère sa jurisprudence (Civ. 3e, 15 juin 2017, no 16-19.640, publié au Bull.) en jugeant que des désordres affectant des éléments d'équipement, qu'ils soient dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale dès lors que ces derniers ont pour conséquence de rendre l'ouvrage

impropre à sa destination (Civ. 3e, 14 sept. 2017, no 16-17.323, Dalloz actualité, 26 sept. 2017, obs. Garcia).

594. Construction et caractère caché d'un désordre. - La charge de la preuve du caractère caché d'un désordre ne repose pas sur le constructeur mais sur la partie qui en réclame la réparation (Civ. 3e, 2 mars 2022, no 21-10.753, D. actu. 1er avr. 2022, obs. N. De Andrade).

626. Clause limitative de responsabilité solidaire ou *in solidum* de l'architecte. - À l'occasion de l'interprétation d'une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de maîtrise d'œuvre, la Cour de cassation confirme que l'architecte est autorisé à prévoir que sa responsabilité ne pourra être engagée solidairement, ni *in solidum*, avec celle des autres intervenants à l'opération (Civ. 3e, 14 févr. 2019, no 17-26.403, D. actu. 28 févr. 2019, obs. D. Pelet).

629. Clause d'exclusion de solidarité et faute de l'architecte. - La clause d'exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant *in solidum* avec d'autres constructeurs, et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage à son encontre, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (Civ. 3e, 19 janv. 2022, no 20-15.376, D. actu. 14 févr. 2022, obs. N. De Andrade).

Copyright 2022 - Dalloz – Tous droits réservés